

이 과제는 2023년 중앙노동위원회
학술연구용역사업의 일환으로 진행되었음
발간등록번호 : 11-1492130-000032-01

중앙노동위원회 패소사건 실태 및 원인 분석을 통한 개선방안 연구

연구기관 : 광운대학교 산학협력단



연구진

책임연구원 : 이 준 희 (광운대학교 법학부, 교수)

제 출 문

중앙노동위원회 위원장 귀하

본 보고서를 중앙노동위원회 수탁연구 『중앙노동위원회 패소사건
실태 및 원인 분석을 통한 개선방안 연구』의 최종보고서로 제출
합니다.

2023. 12. 31.

광운대학교 산학협력단

단장 정 영 욱

< 차례 >

제1장 서론

I. 문제의 제기 및 연구 필요성	1
II. 연구 방법	2

제2장 한국 노동위원회제도의 특수성

I. 한국 노동위원회 제도의 연혁적 발전과 소관업무의 확대	3
1. 미국식 노동위원회 제도 도입	3
2. 노동위원회 기능의 확대와 한국적 독자성 확립	3
II. 한국 노동위원회 제도의 특징	5
1. 미국식 행정심판제도	5
2. 피신청인이 사인인 행정심판제도	5
3. 심판과 조정 기능을 동시에 수행하는 분쟁해결 제도	7

제3장 노동위원회의 취소소송 패소의 원인과 시사점

I. 소극적 관점	9
1. 노동위원회 조사관 및 공익위원의 전문성 부족	9
2. 판정문 작성의 신중함과 전문성 결여	13
3. 노동위원회의 조사 능력 및 권한 부족	15
4. 노동위원회의 소송수행 능력 및 전략 부족	16
5. 법원의 노동위원회 판정 존중 미흡	19
II. 적극적 관점	22
1. 법원과는 다른 차원의 구체적 타당성 확보 추구	22
2. 새로운 법리 구축 가능성 탐색	25
III. 소결	29

제4장 개선 방안

I. 제도 운용상의 개선 방안	31
1. ‘패소사건 검토회의’ 내실화 또는 ‘상소 판단 전문위원회’ 구성	31
2. 노동위원회 판정의 일관성 및 선례구속성 확대를 위한 “주요 사건 판정 사례집” 발간	32
3. 노동관련 전문 법무법인을 통한 소송 대리 확대와 내부 송무인력 전문성 강화	33
4. 소송 수행 과정에서의 피고보조참가인 측과의 협력 강화	33
5. 화해를 통한 분쟁의 종국적 종결 확대	34
6. 비상임 공익위원의 충원과 전문성 강화를 위한 중앙노동위원회 ‘서울 사무소’ 설치	34
II. 법령 개정을 통한 개선 방안	34
1. 지방노동위원회 초심판정에 대한 ‘재심신청 허가제’ 도입	34
2. 부당해고, 부당노동행위, 차별시정 사건에 대한 노동위원회의 신청 전치주의 도입	36
3. 중앙노동위원회 재심판정 취소소송 관할을 고등법원으로 조정	36

제5장 주요 쟁점별 법리 검토

1. 노동위원회 조사관의 실질적 조사권의 의미와 개선 방안	38
2. 근로자성 판단 관련 법리	40
3. 채용내정, 시용, 수습 관련 법리	44
4. 인사평가, 배치전환 관련 법리	47
5. 징계의 정당성 관련 법리	54
6. 직장 내 괴롭힘 판단 관련 법리	55
7. 근로관계 종료 관련 법리	58
8. 기간제 근로자의 갱신기대권 관련 법리	59
9. 고용승계기대권 관련 법리	62
10. 교섭단위 분리제도 관련 법리	64
11. 부당노동행위 관련 법리	71

제6장 요약 및 결론	76
-------------------	----

참고문헌	78
------------	----

부록1. 주요 사건 경과 및 패소 원인 분석	80~331
--------------------------------	--------

부록2. 노동위원회 판정 분류 체계안	332~341
----------------------------	---------

제1장 서론

I. 문제의 제기 및 연구 필요성

- 중앙노동위원회제도는 노·사·공익 3자(근로자위원, 사용자위원, 공익위원)로 구성되어 조정 및 심판 기능을 담당하는 준사법적 성격을 지닌 독립된 전문 행정위원회로서, 노사관계에서 발생하는 노사간의 이익분쟁(노동쟁의 조정) 및 권리분쟁(부당해고, 차별, 부당노동행위 등) 사항을 신속하고 공정하게 조정 및 판정하는 기능을 수행하고 있음.

노동위원회법 제1조 [목적] 이 법은 노동관계에 관한 판정 및 조정(調整) 업무를 신속·공정하게 수행하기 위하여 노동위원회를 설치하고 그 운영에 관한 사항을 규정함으로써 노동관계의 안정과 발전에 이바지함을 목적으로 한다

- 노동위원회 제도의 특징은 하나의 기관에서 조정 기능과 판정 기능을 동시에 수행한다는 점이며, 그 중 판정 기능에 해당하는 부당해고구제심판, 부당노동행위구제심판, 차별구제심판 등 노동위원회의 심판 결과인 판정에 대해서는 행정법원에 취소소송을 제기할 수 있도록 절차가 구성되어 있음.
- 노동위원회의 행정심판 결과에 대한 사법적 통제를 완전히 배제할 수는 없으나, 노동위원회 판정에 대한 당사자의 불복과 소송 제기는 최종적인 분쟁의 확정인 소송 종결시까지 지연되는 결과를 가져오게 됨.
- 노동위원회 제도의 “신속한 판정”이라는 목적이 달성되기 위해서는, 노동위원회 단계에서 절차가 최종적으로 종결되는 것이 가장 바람직하며, 법원에 취소소송이 제기되는 비율이 늘어날수록, 분쟁의 최종적인 확정이 지연됨은 물론, 노동위원회 판정에 대한 당사자의 신뢰도가 낮아지는 현상을 피할 수 없음.
- 그러나, 최근 노동위원회에 구제를 신청하거나 구제신청의 상대방이 된 당사자의 불복 비율이 늘어나고 노동위원회의 부당해고 등 판정사건이 법원으로 가서 종결되는 사례가 늘었다는 조사 결과가 발표되었음.¹⁾
- 이에 이 보고서는 중앙노동위원회 판정에 관한 취소소송에서 중앙노동위원회가

1) 중앙노동위원회, 「보도자료(노동위원회의 부당해고 등 판정사건, 더 신속해졌지만, 법원으로도 더 많이 갔다)」, 2023. 4. 2; 참여연대, 「이슈리포트(노동위원회 운영실태 보고서)」, 2022. 1. 26. 등 참조.

패소한 최근 3개년(2020~2022)간의 중요 사건을 분석하고, 그 원인과 의미를 확인·분석하는 한편 이를 통제하기 위한 개선 방안을 제시하려 함.

- 이를 위해, 우선 중앙노동위원회와 법원의 판단이 달라지고 결과적으로 중앙노동위원회의 “패소”라는 결과로 이어지는 사건 해결의 흐름이 갖는 특수한 의미를 분석하고 그 분석을 토대로 패소의 원인과 대안을 도출하려 함.
- 또한, 개별적인 중요 패소 사례를 선정하여 각 사례별로 주요 사실관계와 다투어진 쟁점, 중앙노동위원회가 택한 법리와 법원이 택한 법리 등을 분석하여 패소의 원인과 대안을 제시하고자 함.
- 이 내용은 제도개선 방안과 별도로 ‘부록’으로 첨부함

II. 연구 방법

- 본 연구는 2020년, 2021년, 2022년 3개년간 노동위원회가 최종적으로 법원 소송 절차에서 패소한 것으로 확정된 사건을 중심으로 분석하고, 노동위원회 제도를 운영하고 있는 주요 해외 국가의 입법례를 통해 확인되는 제도 운영 현황을 비교하는 문헌연구 및 비교법학방법론을 기본적인 연구방법론으로 택하고 있음.
- 분석 대상이 패소사례로 국한되어 있으므로, 실태조사 및 패소사례에 대한 통계학적 분석은 본 연구의 주된 대상이 아님.
- 개별적인 패소 사례 분석은 역시 문헌분석의 연구 방법을 택하고 있으나, 노동위원회와 법원의 각 심급별 진행 경과와 당사자의 주장, 최종적으로 법원이 택한 법리, 노동위원회의 소송 수행상 판단 등을 문헌을 통해 확인하는 외에 실무상 관행과 추론 등의 방법을 통해 현황을 이해하고자 했음.

제2장 한국 노동위원회제도의 특수성

I. 한국 노동위원회 제도의 연혁적 발전과 소관업무의 확대

1. 미국식 노동위원회 제도 도입

- 우리나라에 노동위원회 제도가 도입된 기원은, 일본의 제국주의 침탈에서 해방된 이후 미국의 군정(軍政)이 실시되던 시기에 군정 정부의 주도 하에 1945. 12. 8. 노동조정위원회²⁾가 설치된 시점이라고 할 수 있음.
- 미 군정 하에서의 노동조정위원회는 정부 수립후 우리 정부 주도하에 1949. 6. 6. 설립된 노동조정위원회(勞動調停委員會)로 이어지며, 1953. 3. 8. 노동위원회법이 제정³⁾된 이후, 동 법률에 따라 1954. 2. 20. 노동위원회가 출범하였음.
- 노동조정위원회도 지방노동조정위원회, 중앙노동조정위원회의 체계를 가지고 있었으므로, 중앙노동위원회의 전신은 중앙노동조정위원회라고 할 수 있음.
- 노동위원회는 당시의 노동조합법, 근로기준법 등에서 정한 사항의 심사와 결의, 노동쟁의조정법에서 정한 노동쟁의의 조정과 중재 업무를 담당했는데, 구체적으로는 노동조합 규약 또는 결의의 취소·변경 결의, 단체협약의 지역적 구속력 결정, 노동조합의 해산 의결, 안전보호시설에 대한 쟁의행위 중지 명령 의결, 근로자의 귀책사유로 인한 해고예고의 예외 인정, 휴업보상 및 장해보상의 예외 인정, 재해보상의 심사와 중재, 당시의 근로기준법⁴⁾에 규정되어 있던 근로조건 위반에 대한 손해배상 청구에 대한 판정 등을 행하였음.
- 미 군정하에서 우리나라에 설치된 노동조정위원회는 미국 전국노사관계위원회(NLRB)의 기능을 참조하여 구성되었으며, 1953년 제정·시행된 노동위원회법 역시 연합군 사령부를 주도하던 미국의 영향을 강하게 받아 제정된 일본 노동위원회법의 영향에서 자유로울 수 없었기 때문에, 우리나라 노동위원회 제도는 주로 대륙법계의 영향을 받은 다른 법제도와는 달리 미국 제도의 특징을 갖게 되었음.⁵⁾

2) 美軍政法令 제34호, 1945. 12. 8. 시행.

3) 법률 제281호, 1953. 3. 8. 시행.

4) 법률 제286호, 1953. 8. 9. 시행.

5) 노동법실무연구회(이준상·김근홍 집필 부분), 「노동조합 및 노동관계조정법 주해(제2판)」, 2023, 박영사, 904쪽 이하.

2. 노동위원회 기능의 확대와 한국적 독자성 확립

- 1960년대와 1970년대의 산업화 시기에 노동위원회법에는 중재재정에 대한 불복과 중재재정의 효력 규정, 긴급조정제도, 부당노동행위 구제제도⁶⁾ 등이 도입되었으며, 임시총회 소집권자 지명, 휴업수당 지급 예외 인정, 안전보호시설에 대한 쟁의 행위 중지 명령 사후 승인, 쟁의행위 적법성 심사 등의 권한이 추가되었음.
- 1980년대에 이르러 노동위원회의 권한은 조정 절차의 일원화와 조정 기간의 단축, 직권중재 대상의 확대와 축소, 노동조합 규약 또는 결의의 취소·변경 사유 축소, 재해보상의 심사·중재 전치규정 삭제 등의 변화를 겪었으며, 휴면노동조합에 대한 해산 의결 제도, 휴업수당 지급 예외 인정 권한, 단체협약의 시정명령 의결 권한 등의 권한이 신설되었음. 특히, 1989년 ‘부당해고등’의 구제제도가 도입되면서⁷⁾, 노동위원회의 부당해고 판정 및 구제명령권한이 신설되었음.
- 1990년대에는 노동위원회의 권한과 관련하여, 노동위원회의 알선 기능 폐지 및 조정전치주의 도입, 직권중재 축소와 중재재정 관련 분쟁해결제도 도입, 긴급조정 제도의 개선, 부당노동행위 구제명령에 대한 긴급이행명령 제도 도입, 노동조합의 결의처분에 대한 노동위원회 의결 요청 요건 강화, 휴면노동조합의 해산 의결 근거 규정을 법률에 직접 규정, 단체협약의 시정명령 의결 대상 한정, 단체협약의 해석·이행방법에 대한 견해 제시, 노사협의회 의결 사항 임의중재제도 도입 등이 이루어졌음.⁸⁾
- 2000년대에 들어서도 노동위원회의 권한이 지속적으로 확대되었음. 조정 전 지원 및 사후조정 제도 도입, 필수공익사업에 대한 직권중재 제도 폐지 등의 기능이 추가된 것이 대표적임. 특히 2007년에는 금전보상명령·이행강제금 제도 도입⁹⁾, 기간제·단시간 근로자 및 파견근로자에 대한 차별시정 제도 신설¹⁰⁾, 필수유지업무 제도 도입으로 인한 필수유지업무 결정권 신설¹¹⁾ 등 큰 폭의 제도 변화가 있었으며, 노동위원회가 담당하는 권한이 크게 확대되었음.
- 특히, 2007. 1. 1. 권리구제대리인 제도가 공인노무사에 대해 시행¹²⁾되었으며, 이는 2015. 1. 20. 변호사로 확대되어¹³⁾ 사회취약계층의 노동위원회 제도 활용을 촉진하는 중요한 계기가 되었음.

6) 노동조합법(법률 제1329호, 1963. 4. 17. 시행) 제39조 [부당노동행위].

7) 근로기준법(법률 제4099호, 1989. 3. 29. 시행) 제27조의3 [정당한 이유없는 해고등의 구제신청].

8) 근로자참여및협력증진에관한법률(법률 제5312호, 1997. 3. 13. 제정·시행) 제24조 [임의중재].

9) 근로기준법(법률 제8293호, 2007. 7. 1. 시행) 제33조의6 [이행강제금].

10) 기간제 및 단시간근로자 보호 등에 관한 법률(법률 제8074호, 2007. 7. 1. 시행) 제8조 이하; 파견근로자보호 등에 관한 법률(법률 제8372호, 시행 2007. 4. 11. 시행) 제21조 [차별적 처우의 금지 및 시정 등].

11) 노동조합 및 노동관계조정법(법률 제8158호, 2007. 7. 1. 시행) 제42조의2 이하.

12) 노동위원회법(법률 제8474호, 2008. 1. 1. 시행) 제6조의2 [공인노무사의 권리구제 대리].

13) 노동위원회법(법률 제13044호, 2015. 7. 21. 시행) 제6조의2 [공인노무사의 권리구제 대리].

- 2010년 이후에는, 2010. 1. 1. 노동조합 및 노동관계조정법(이하 ‘노동조합법’) 개정에 따른 복수노동조합 교섭창구 단일화 절차 관련 업무가 노동위원회의 관할로 추가되었으며¹⁴⁾, 2022년에는 사업주의 근로자에 대한 성차별 등에 대한 구제¹⁵⁾와 일학습병행제 대상 근로자에 대한 차별적 처우에 대한 구제¹⁶⁾ 등이 노동위원회의 관할로 추가되었음.¹⁷⁾
- 이상과 같은 연혁적 흐름 속에서 우리 노동위원회는 노동쟁의의 조정뿐만 아니라 부당해고와 부당노동행위에 대한 판정 권한, 기간제·단시간·파견근로자 등에 대한 차별구제신청에 대한 판정 권한, 성차별에 대한 판정 권한 등 광범위한 판정 기능을 보유한 복합적 행정심판기구로 그 성격이 확대되었음.

II. 한국 노동위원회 제도의 특징

1. 미국식 행정심판제도

- **[행정청과 독립된 별도의 심판기구]** 노동위원회는 행정청과 독립된 별도의 행정심판기구라는 점에서 통상의 행정심판기구와 구별되는 특징을 가지고 있음.
 - 이는 행정의 적법성과 합목적성을 행정권 스스로 확보하는 자율적 통제에 중점이 있는 대륙법계 행정심판제도와는 구별되는, 사법기능을 보충하는 권리구제기구로서의 행정심판의 성격이 강조된 미국법계의 영향을 받은 행정심판기구로서의 특징이라고 할 수 있음.
- **[행정심판기구가 행정청의 상급 기구가 아님]** 통상의 행정심판기구는 행정처분을 직접 행한 처분청의 직근상급기관이 재결청이 되거나, 처분청의 사안에 대한 소관 감독기관 또는 제3의 기관이 재결청이 되는 것과는 달리, 노동위원회는 특정 행정청의 상급기관이 아닌 독자적인 행정심판 기구의 성격을 가지고 있음.

2. 피신청인이 사인인 행정심판제도

- **[법원의 사법심사를 보충하는 기능]** 노동위원회는 행정심판의 피청구인이 행정청이

14) 노동조합 및 노동관계조정법(법률 제9930호, 2010. 1. 1. 시행) 제29조의2 [교섭창구 단일화 절차].

15) 남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률(법률 제18178호, 2022. 5. 19. 시행) 제26조 [차별적 처우등의 시정신청].

16) 산업현장 일학습병행 지원에 관한 법률(법률 제16559호, 2020. 8. 28. 시행) 제28조 [차별적 처우의 금지].

17) 남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률(법률 제18178호, 2022. 5. 19. 시행) 제26조 [차별적 처우등의 시정신청].

아닌 일반 사인(사용자)이라는 특징이 있으며, 노동위원회, 특히 초심 지노위 판정(또는 시정명령)의 대상이 행정청이 아닌 사인이 된다는 점에서 일반적인 행정심판기구와 구별됨.

- 이는 근로자의 권리구제에 있어서 법원을 통한 사법적 권리구제 수단이 상대적으로 상당한 비용 부담이 요구되고, 절차가 상당히 복잡하며, 분쟁이 최종적으로 종결되기까지 상당한 기간이 소요된다는 문제점을 해소하기 위한 보충적 권리구제기구로서 노동위원회 제도가 도입되었다는 목적과 기능의 특수성에서 기인하는 특징임.

- **[불완전한 직권심리주의]** 노동위원회 심리구조는 기본적으로 당사자주의와 함께 직권심리주의를 택하고 있으며¹⁸⁾, 그 근거는 행정심판법 제39조 및 제36조, 근로기준법 제29조와 노동위원회법상의 ‘조사관’ 제도이지만, 직권심리주의가 완전히 관철되고 있다고 보기 어려움.

근로기준법 제29조(조사 등)

- ① 노동위원회는 제28조에 따른 구제신청을 받으면 지체 없이 필요한 조사를 하여야 하며 관계 당사자를 심문하여야 한다.

노동위원회법 제23조(위원회의 조사권 등)

- ① 노동위원회는 제2조의2에 따른 소관 사무(제3호의 업무는 제외한다)와 관련하여 사실관계를 확인하는 등 그 사무집행을 위하여 필요하다고 인정할 때에는 근로자, 노동조합, 사용자, 사용자단체, 그 밖의 관계인에 대하여 출석·보고·진술 또는 필요한 서류의 제출을 요구하거나 위원장 또는 부문별 위원회의 위원장이 지명한 위원 또는 조사관으로 하여금 사업 또는 사업장의 업무상황, 서류, 그 밖의 물건을 조사하게 할 수 있다.

행정심판법 제36조(증거조사)

- ① 위원회는 사건을 심리하기 위하여 필요하면 직권으로 또는 당사자의 신청에 의하여 다음 각 호의 방법에 따라 증거조사를 할 수 있다.
 1. 당사자나 관계인(관계 행정기관 소속 공무원을 포함한다. 이하 같다)을 위원회의 회의에 출석하게 하여 신문(訊問)하는 방법
 2. 당사자나 관계인이 가지고 있는 문서·장부·물건 또는 그 밖의 증거자료의 제출을 요구하고 영치(領置)하는 방법
 3. 특별한 학식과 경험을 가진 제3자에게 감정을 요구하는 방법
 4. 당사자 또는 관계인의 주소·거소·사업장이나 그 밖의 필요한 장소에 출입하여 당사자 또는 관계인에게 질문하거나 서류·물건 등을 조사·검증하는 방법
- ② ~ ④ <생략>

행정심판법 제39조(직권심리)

위원회는 필요하면 당사자가 주장하지 아니한 사실에 대하여도 심리할 수 있다.

18) 서울행법 2012. 9. 25. 선고 2012구합2474 판결, 서울고법 2013. 6. 14. 선고 2012누32446 판결.

- 그러나, 노동위원회는 일반 행정심판기구가 처분청인 행정청의 상급기관이나 감독기관으로서 직접적인 통제권을 행사하는 경우가 많은 것에 비하여, 신청인이나 피신청인에 대하여 구속력 있는 명령을 발하거나 수사·조사할 수 있는 권한이 약하여 노동위원회 조사관의 조사권은 현실적으로 상당히 제약되어 있음.
- 노동위원회 조사관의 조사권한 제약의 원인은 ① 법령상 조사관의 조사권한과 구제신청 당사자에 대한 구속력에 관한 규정의 모호성, ② 각급 위원회 조사관의 숫자 부족, ③ 조사관 각 개인에 대한 과도한 사건 배정, ④ 사건처리 기한의 제약 등 다양한 원인에 기인하는 것으로 판단됨.
- 이는 미국의 전국노사관계위원회(NLRB)가 부당노동행위 분쟁과 관련한 판정 권한 행사와 관련하여 독점적인 행정 수사(administrative investigation)에 관한 권한을 부여받고 있으며, 적어도 부당노동행위 사건에 관한 한 연방과 주 정부의 다른 행정기관 또는 경찰기관의 개입을 배제할 수 있다는 점에서 구별됨.¹⁹⁾
 - 미국 전국노사관계위원회(NLRB)의 수사권은 법무총장(General Counsel)의 지휘를 받는 전국노사관계위원회 소속 감독관이 행사함.

3. 심판과 조정 기능을 동시에 수행하는 분쟁해결 제도

- [조정기구로서의 출발] 노동위원회는 1949년 미 군정 하에서의 노동조정위원회를 그 출발점으로 하며, 본래의 기능은 노사관계에 있어서 노동관계 당사자의 이견을 조정하는 조정기구로서의 성격을 가지고 있었다고 보이며, 이는 미국의 전국노사관계위원회(NLRB)가 본질적으로 조정기구로서의 성격을 갖는 것과 유사함.
- [심판기구로서의 기능 강화] 그러나, 점차 부당노동행위 구제신청, 부당해고 구제신청, 각종 차별구제신청 등 당사자의 직접적인 권리구제 기능으로서의 심판 기능이 더해졌고, 노사관계에 관한 사항에서도 교섭단위 분리결정 신청 등에 대한 결정 기능이 추가되어, 최근에는 당사자의 권리구제를 위한 심판기능이 더욱 강조되고 있음.
- 이에 대해서는 권리분쟁 사항에 대한 해결은 원칙적으로 법원의 재판을 통해 행하여져야 하며, 사법관계인 근로계약관계에서 발생하는 권리·의무에 관한 분쟁이 행정소송으로 연결되는 것도 구제절차와 소송물에 관한 소송법의 기본 원리에 부합하지 않으므로, 현행 노동위원회를 노동법원과 같은 체계로 확대개편하지 않는 한 노동위원회의 판정기능이 지나치게 강조되는 것은 타당하지 않다는 견해가 있음.²⁰⁾

19) 김미영, '미국 연방노동관계법 부당노동행위제도의 형성과 발전', 『강원법학(제38권)』, 2013, 257쪽; 박은정, '미국·일본·한국 노동위원회제도에 대한 연혁적 고찰', 『노동법학(제61호)』, 2017, 92쪽.

- 노동위원회의 권리분쟁 사항에 대한 판정적 기능은 이미 법령과 관행에 의해 오랜 기간 노동위원회의 기능으로 자리잡고 오히려 확대되어 왔으므로, 노동위원회의 기능을 조정하기보다는 해당 기능을 더욱 적절히 수행할 수 있도록 제도를 개선하는 방향을 모색하는 것이 현실적임.

20) 김형배, 「노동법(제27판)」, 박영사, 2021, 870쪽 이하.

제3장 노동위원회의 취소소송 패소의 원인과 시사점

- 중앙노동위원회의 재심판정에 대하여 당사자가 불복하여 행정소송이 제기되고, 이 소송 과정에서 노동위원회가 패소하는 경우가 발생하는 것에 대해서는 다양한 관점에서의 분석이 가능함.
- 노동위원회가 법원 소송 절차에서 패소하는 것은 노동위원회의 전문성과 소송 수행 능력 부족 등에서 그 원인을 찾는 소극적 관점과, 노동위원회의 독립성과 노동사건과 관련한 법원과 구별되는 독자적 관점 수립을 촉진한다는 의미에서 적극적으로 평가하는 관점이 있을 수 있음.

I. 소극적 관점

1. 노동위원회 조사관 및 공익위원의 전문성 부족

- 중앙노동위원회 재심판정에 대한 취소소송에서 중앙노동위원회가 패소하게 되는 가장 중요한 원인으로서는 신청사건을 처리하는 데 있어서의 조사관과 공익위원의 전문성 부족을 들 수 있음.
- 통상의 노동위원회 심판 절차에 있어서 심판회의의 진행, 공익위원 및 노·사위원의 심문, 주심위원의 판정서 작성 등에 있어서 조사관이 작성·보고한 조사보고서와 기타 조사자료 등이 결정적인 영향을 미치는 바, 중앙노동위원회 판정의 전문성 부족 현상은 공익위원의 전문성 부족만으로 치부할 수는 없으며, 담당 조사관과 공익위원의 전문성 부족이 함께 원인이 된다고 보는 것이 합리적임.
- **[확립된 대법원 판례 법리를 간과한 경우]** 대표적으로 이미 대상 근로자의 비위행위에 대한 2년의 징계 시효가 지난 후에 뒤늦게 정부 감사에 적발된 상황에서 사용자가 비위행위 그 자체가 아니라 정부 감사에 적발되어 형사처벌을 받은 것을 이유로 징계한 사안을 들 수 있음.²¹⁾

중노위 2017. 3 29. 중앙2017부해73 판정, ○○○○연구원 부당해고 사건
<사건 개요> ○○○○연구원(공공기관)에 1994. 3월 입사하여 2016년경까지 약 23년여 동안 총 13차례의 근로계약을 갱신하여 근무해오던 신청인은, 사무국장으로 근무하던 기간 중인

21) 중노위 2017. 3 29. 중앙2017부해73 판정; 대법원 2019. 10. 18. 선고 2019두00000 판결.

2012.6월 ~ 8월 사이에 회사의 인테리어 공사업무를 총괄하는 과정에서 시공업체로부터 3회에 걸쳐 총 3,000만원을 받는 비위행위를 저질렀고, 이러한 행위가 2015. 12월 정부 감사에서 적발되어 2016. 9월 배임수재죄로 벌금 1,500만원의 약식명령 받았다(이후 정식 재판에서 유죄가 확정되어 벌금 1000만원이 확정되었다).

같은 달 ○○○○연구원은 원고에 대해 징계면직 처분을 하였는데, 비위행위(배임수재) 자체에 대한 징계시효(2년)는 이미 만료된 상황이라 비위행위 자체가 아닌 ‘배임수재로 약식명령을 받아 연구원의 위신을 크게 손상 하였다’는 이유로 면직처분을 하였다.

이에 원고는 면직처분이 부당해고임을 주장하며 서울지노위에 구제신청을 하였다.

<노동위원회 판정>

- 서울지노위·중앙노동위원회 - 이 사건 징계면직은 정당하다며 원고의 신청을 기각

<법원의 판단>

- 대법원 - 징계시효가 만료되어 징계권이 소멸하였다는 이유로 원심을 파기환송

징계사유에 해당하는 비위행위 자체에 대한 징계시효가 만료된 이후 비위행위가 수사대상이 되거나 언론에 보도되었다고 하여 이를 들어 새로운 징계사유가 발생한 것으로 본다면, 비위행위에 대한 징계시효가 연장되는 것과 다름없어 일정 기간의 경과를 이유로 징계권 행사를 제한하고자 하는 징계시효의 취지에 반할 뿐 아니라, 새로운 징계사유의 발생이 사용자 등에 의하여 의도될 우려도 있다. 따라서 비위행위 자체에 대한 징계시효가 만료된 경우 비위행위에 대하여 나중에 수사나 언론보도 등이 있더라도 이로 인해 새로운 징계사유가 생긴 것으로 보거나 수사나 언론보도 등의 시점을 새로운 징계시효의 기산점으로 볼 수 없다.

- 이 사건 원고의 비위행위(배임수재)는 2012년도에 벌어졌으나, 3년이 지난 2015년 정부 감사에서 적발되어 2016년에 배임수재로 약식명령을 받고 회사 측의 징계면직이 이루어졌는데, 중앙노동위원회는 배임수재로 약식명령을 받은 사실 등을 비위행위 자체와 구별되는 독자적인 징계사유(‘회사의 위신을 크게 손상시킨 행위’)에 해당하는 것으로 보고, 그때부터 징계시효를 기산하여 아직 시효가 완성되지 않았다고 판단하여 징계의 정당성을 인정하였음.

- 중앙노동위원회의 이러한 판단은 “비위행위 자체에 대한 징계시효가 만료된 이후 수사나 언론보도가 있는 경우 이를 새로운 징계사유가 발생한 것으로 본다면 징계시효의 연장과 다름없어 징계시효 제도의 취지에 반한다”는 확립된 기존 대법원 판례 법리²²⁾와 정면으로 배치되는데, 중앙노동위원회 재심판정서에는 관련 대법원 판결 또는 관련 법리가 전혀 언급되지 않은 것으로 보아, 징계시효 제도 관련 법리에 대한 조사관과 공익위원의 이해가 미진했던 것으로 이해됨.

- 피신청인 측의 초·재심 답변서에는 “이 사건 근로자의 금품 수수 행위(비위행위)는 징계 소멸시효가 사유 발생일로부터 2년이 도과되어 이 사건 연구원은 내부 징계 처분을 하지 못하고 고발조치만 하였다”고 기술되어

22) 대법원 1995. 3. 10. 선고 94다14650 판결; 대법원 2008. 7. 10. 선고, 2008두2484 판결.

있어 관련 사실관계는 심판회의 단계에서 이미 충분히 소명된 것으로 보임.

- [기본적인 법리를 알지 못한 경우] 대표적인 사례는, 사용자가 선행 징계처분을 취소하고 새로운 징계를 하면서 그 시점을 이전 시기로 소급하여 통지한 사건에서, 중앙노동위원회는 해고시기를 해고처분 이전으로 소급적용하는 것은 이미 유효하게 존재하고 있는 근로관계의 실제적 사실관계를 별도의 특별한 이유 없이 부정하고 있는 것으로서 그 효력이 없다는 이유로 부당해고임을 인정했던 사건을 예로 들 수 있음.²³⁾

- 이에 대하여 법원은 “사용자는 해고통지문이 근로자에게 도달한 시점을 기준으로 퇴직일자를 계산하였고, 이를 기준으로 급여, 해고예고수당, 퇴직급여 등을 처리한바 법리상, 사실상 모두 문제가 없다”고 하여 해고의 정당성을 긍정했음.

중노위 2019. 6. 18. 중앙2019부해466 판정, ○○농업협동조합 부당해고 사건
<사건 개요> 신청인인 근로자 K는 1997. 4. 1. □□농업협동조합에 입사하여 약 20년간 근무하다, 2016. 7. 12. ○○농업협동조합으로 인사발령을 받아 근무하던 중 2018. 11. 19. 부당하게 해고되었다고 주장한다. 피신청인인 ○○농업협동조합(이하 ‘사용자’)은 2018. 11. 23. 근로자 K에 대하여 ‘복무 규정위반(무단결근, 근태기록 임의삭제)’을 사유로 정직 6개월의 징계처분(이하 ‘선행 징계처분’)을 하였으나 이후 2018. 12. 7. 선행 징계처분을 취소하고 2018. 12. 10.자로 해고통지문을 보내기로 결정하였으며, 2018. 12. 13. 근로자 K에게 해고통지문을 내용증명우편으로 발송하였고, 근로자 K는 2018. 12. 14. 이를 수령하였다. 근로자 K는 2019. 1. 14. 경기지방노동위원회에 ‘이 사건 직권면직 처분은 부당해고에 해당한다’고 주장하면서 구제신청을 하였다. <노동위원회 판정> ○ 경기지방노동위원회 - 구제신청 기각 ‘이 사건 직권면직 처분은 징계처분이 아니고 선행 정직처분 취소 후 이루어진 것이므로 이중징계에 해당하지 않고, 이 사건 직권면직 처분을 함에 있어 징계절차를 거치지 않은 것을 절차적으로 위법하다고 볼 수 없다’는 이유로 근로자 K의 구제신청을 기각했다. ○ 중앙노동위원회 - 초심판정 취소, 구제신청 인용 ‘이 사건 직권면직 처분은 이중징계에 해당하지 않으나, 해고의 시기는 해고처분 이후 장래의 일자를 정하는 것이 원칙인데, 이 사건 직권면직 처분은 해고의 시기를 해고처분 이전으로 소급 적용하여 이미 유효하게 존재하고 있는 근로관계를 부정하는 것으로서 해고의 기본 성질에 위배되어 효력이 없다’는 이유로 초심판정을 취소하고 근로자 K의 구제신청을 인용했다.

23) 중노위 2019. 6. 18. 중앙2019부해466; 서울고등법원 2020. 11. 27. 선고 2020누00000 판결; 피고 보조참가인이 상고한 뒤(중앙노동위원회는 상고하지 않음) 대법원 심리불속행 기각으로 완결(대법원 2020두00000).

<법원의 판단>

○ 서울고등법원 - 재심판정 취소, 해고의 정당성 인정

이 사건 직권면직은 이중징계에 해당하지 않고, 해고의 시기 역시 소급되지 않았으므로 이 사건 직권면직 처분이 해고의 효력발생시기를 해고통지 이전으로 소급하여 위법함을 전제로 한 재심판정은 위법하다고 하여 1심법원과 같은 취지로 판결했다. 대법원은 심리 불속행기각 판결을 내렸다. 특히 사용자가 해고통지문의 말미에 기재된 “2018. 12. 10.”을 해고시기로 특정하였다고 할 것이고, 위 해고시기의 기재로 인하여 이 사건 근로자가 이 사건 해고에 대처하는 데 어려움을 겪었다고 볼 수 없으므로, 이 사건 해고는 근로기준법 제27조의 해고예고 규정에 반하여 위법하다고 볼 수 없다고 판결했다.

- 이 사건은 초심판정과 재심판정이 엇갈린 경우이고, 초심판정과 같은 법원의 판단이 3심까지 쭉 이어진 사건임. 판단이 엇갈린 지점은 해고통지문에 기재된 해고일과 실제 해고의 효력 발생시기와 관련한 쟁점임.
- 중앙노동위원회 재심판정문은 상대방 있는 단독행위는 그 의사표시가 상대방에게 도달하는 때에 효력이 발생한다는 법리에 따라 해고통지의 효력 발생시기도 해고통지가 근로자에게 도달하는 시점이라는 민법상 의사표시의 일반 법리를 간과하고 “해고 시기는 해고처분 이후로 장래의 일자를 정하는 것이 원칙”이라는 확인되지 않은 원칙을 근거로 판단을 내렸음.
- 그러나, 법원에서 인정된 사실관계에 따르면 사용자는 해고통지문이 근로자에게 도달한 시점을 기준으로 퇴직일자를 계산하였고, 이를 기준으로 급여, 해고예고 수당, 퇴직급여 등을 처리한바 법리상·사실상 모두 문제가 될 것이 없는 상황임에도, 중앙노동위원회는 이를 모두 간과한 판단을 내린 문제점이 있음.
- 결국 이 사건은 사실관계의 조사 미비, 법학 일반이론 및 근로기준법상 일반 사항에 관한 공익위원의 전문성 미비 양자 모두가 문제되어 법원에서 패소하게 된 것으로 판단됨.
- 한편, 조사관 및 공익위원의 전문성을 제고할 수 없는 가장 큰 요인 중 하나는 조사관 및 공익위원의 숫자가 부족하기 때문이라고 판단되며, 특히 공익위원의 전문성과 판정의 일관성을 확보하기 위해서는 상임위원의 정원을 대폭 증가시키고 상임위원의 전문성을 강화할 수 있는 방안을 강구하여야 함.
- 위원장을 포함한 상임위원은, 현재 중앙노동위원회 3명, 서울지방법노동위원회 4명, 경기지방법노동위원회 2명, 부산지방법노동위원회 2명이며, 그 외의 지방노동위원회는 위원장 1명이 상임위원으로 확보되어 있을 뿐임.²⁴⁾

24) www.nlrc.go.kr/nlrc/intro/mb_list_hp.go (최종 검색일 2023. 9. 29).

2. 판정문 작성의 신중함과 전문성 결여

- 노동위원회의 판정문은, 첫째, 당사자가 판정문을 통해 노동위원회의 판정 이유와 근거, 정당성 등을 확인할 수 있어야 하며, 둘째, 사후에 노동위원회 판정에 대한 취소소송 등이 제기되었을 때에 노동위원회 판정의 적법성과 정당성을 입증할 수 있어야 하며, 셋째, 이후 유사한 사례에서 노동위원회에 권리구제를 신청하려는 장래의 잠재적 당사자가 권리구제 신청 여부를 판단할 수 있는 기초자료로서 기능하여야 함.
- 따라서, 노동위원회 판정문, 특히 중앙노동위원회 판정문은 중앙노동위원회가 내린 결론에 이르게 된 배경이 된 사건의 사실관계와 법리적 근거, 유사 사례에 관한 이론과 판례의 태도 등을 충분히 소명할 수 있도록 자세하고 논리적으로 완결성이 있게 작성되어야 함.
- 대표적으로 저성과자임을 이유로 해고된 근로자에 대한 해고의 정당성을 노동위원회가 부정했으나, 법원이 해고의 정당성을 긍정하면서 노동위원회 재심판정을 취소한 ○○○기술원 부당해고 사건을 들 수 있음.²⁵⁾

중노위 2018. 4 30. 2018부해233 판정, ○○○기술원 부당해고 사건
<사건 개요> 신청인인 근로자는 2002. 7. 8. 정부출연연구기관인 원고 회사에 연구원(박사)으로 입사하여 수차례 계약을 갱신하였는데, <2011년도 인사위원회>에서 재계약 보류대상으로 심의를 받으며 ‘내외 신뢰회복이 필요’하다는 평가와 함께 1년의 재계약 체결하였고, <2012년도 인사위>에서는 ‘목표성과 달성을 위해 얼마나 시간이 필요하냐’는 얘기를 듣고 다시금 1년 재계약 하였다. <2016년도 인사위>에서 ‘저성과자’로 재계약 심의 받으며 ‘직무수행계획서의 신뢰성과 구체성 결여, 2년 연속 인사평가 최하위임에도 실적 개선의지 안 보임’이라는 평가와 함께, 1년(2016.7.8. ~ 2017.7.7) 재계약하되 자구노력과 회사의 지원 프로그램을 시행하여 1년 후 다시 판단하기로 의결하였다. 한편 신청인은 2010~2013년 최하평가를 받고, 2014년에 저성과를 이유로 타부서로 전보된 이후 2014~2016년에도 최하등급을 받았다. 인사평가는 정량(성과)평가 80%·정성(역량)평가 20%로 구성되어 있고, 정량평가에는 재정기여도, 논문·특허·기술료 등 개인성과 항목이 있었는데, 신청인 근로자의 성과는 전보 이후 2017년까지 연구과제 3건·논문 2건·특허 3건에 불과하였다. 2017. 7. 24 인사위원회는 신청인에 대하여 ‘최근 3년 간 인사평가 최하위 등급을 받는 등 저성과자에 해당’한다는 이유로 면직 의결하였고(단체협약에 따라 사전에 노사 동수로 구성된 계약조정위원회의 심의 완료), 2017. 8. 7. ‘재임용 기준 미충족에 따른 고용계약기간 종료로 인해 2017. 9. 7.자 당면면직’을 통지하였는 바, 이에 신청인이 부당해고 구제신청을 하였다. <노동위원회 판정>

25) 중노위 2018. 4 30. 2018부해233 판정; 대법원 2020. 3. 12. 선고 2019두00000 판결.

○ 전남지노위·중앙노동위원회 - 기간의 정함이 없는 근로자에 대한 정당한 이유 없는 부당해고라고 판정

참가인 근로자가 2002. 7. 8. 입사한 후 근로계약기간의 단절 없이 1년·3년 단위로 수차례 계약을 갱신하여 무기계약 근로자로 전환되었으므로, 면직처분은 근로기준법 제23조의 제한을 받는 해고에 해당하고, “인사평가 최하위 등급을 받았다는 것만으로 해고의 정당성 인정하기 어렵다. 저성과자라 하더라도 해고는 최후 수단이다. 평가의 주된 목적은 근로자 역량 보완, 향상임에도 불구하고 평가등급만 통지할 뿐 근로자 요구 시에만 구체적인 내용을 열람할 수 있어 근로자의 자율적 개선을 유도하지 못하여 목적 달성이 불가능하다. 회사가 지속적인 면담이나 경고조치 등을 행한 사실이 없다. 근로자의 저성과로 인해 회사에 어떠한 손실이 발생되었는지 여부가 구체적으로 확인되지 않는다”는 점 등을 들어, 사회통념상 고용관계를 유지할 수 없을 정도에 이르지 않아 이 사건 면직은 부당해고라고 판정하였다.

<법원의 판단>

○ 고등법원 - 기간제 근로자의 갱신 거절에 합리적 이유가 있다고 인정. 재심판정 취소

법원은 ‘재임용 규정 및 실태상 박사연구원은 통상 3년의 재계약을 체결하였으나 참가인 근로자는 장기간 저성과로 인해 인사위원회 재심의를 거쳐 1년 후 재평가를 전제로 단 1년 기간의 재계약을 체결한 점, 원고 회사가 노동조합과 재계약 갱신거절에 관한 단체협약을 체결한 점 등’에 비추어 갱신 결정 절차를 단지 형식에 불과한 것으로 볼 수 없다며 기간의 정함이 있는 근로자로 보았다. 아울러 참가인 근로자는 정부출연연구기관의 박사연구원으로 연구업무에 직접 종사하고 있어, 기간제법 제4조 제1항 단서 등에 따른 무기계약전환 예외 사유에 해당하여 무기계약으로 전환되지도 않았다고 판단하였다.

그리고 이를 전제로 기간제 근로자의 갱신기대권 인정 및 갱신거절의 합리성 여부를 검토하였는데, ‘인사규정에 재계약 관련 규정 존재, 입사 이후 장기간 재직하며 수차례 재계약을 체결한 점 등’을 들어 갱신기대권은 인정하였으나, ‘인사평가가 합리적이고 공정한 것으로 보이는 점(평가 항목이 세분화·객관화되어 있는 점 등), 인사규정 및 단체협약의 당연면직 사유인 저성과자에 해당(3년 연속 최하등급)하는 점, 회사는 저조한 성과에도 불구하고 여러 차례 계약을 갱신하는 등 개선 기회를 부여한 점 등’의 사실에 주목하여 갱신거절에 합리성이 있다고 보아 이 사건 면직처분이 정당하다며 중앙노동위원회의 재심판정을 취소하였다.

- 이 사건에서 중앙노동위원회 판정문을 살펴보면, 면직의 정당성 판단에 있어, 기 제출된 자료 및 인정 사실들에 비추어 보더라도 중앙노동위원회가 제시한 부당해고를 뒷받침하는 이유가 다소 빈약함. 이는 피신청인 측이 제시한 증거와 기록들이 상당히 구체적이고 풍부하다는 점을 고려하면, 판정의 정당성을 입증할 수 있는 근거제시에 더욱 노력을 기울였어야 할 것으로 판단됨.

- 특히, 성과평가 및 인사평가와 관련한 정당성 판단 문제는 사실관계와 당시의 상황 등에 대한 해명을 통해 소명되는 부분이 많고, 판단의 정당성을 입증하는 것이 매우 어려우므로 향후 이와 관련한 정밀한 판단기준 마련이 요구됨.

- 즉 중앙노동위원회가 이 사건 판정이유를 통해 저성과자 해고의 정당성 판단에 관해, 준사법기관으로서 수급자들에게 의미 있는 예측가능성을 제공하지 못하고 있는 것으로 보이며, 이는 법원 심리 과정에서도 마찬가지였던 것으로 판단됨.

3. 노동위원회의 조사 능력 및 권한 부족

- 2020년, 2021년, 2022년 3개년간 주요 패소사례를 검토하면, 법원이 심판 대상 사건의 사실관계에 대한 판단 및 인정을 달리하여 결국 중앙노동위원회가 패소하게 된 사건이 전체 220건 중 86건으로 39.09%에 이릅니다.

[패소 사건 중 판결 이유에 나타난 패소 원인 비율 (2020~2022년)]

	2020년	2021년	2022년	계 (%)
사실 인정을 달리한 경우	24	37	25	86 (39.09)
새로운 증거 제출 등 신청인	1	5	3	9 (4.09)
법리 판단을 달리한 경우	22	20	33	75 (34.09)
법령 적용을 달리한 경우	9	11	28	48 (21.82)
기타	0	1	1	2 (0.91)
계	56	74	90	220

- 법원이 중앙노동위원회가 조사하여 인정한 사실관계의 내용 및 그 의미에 대한 판단이 잘못되었다는 것을 이유로 재심판정을 취소하는 것은, 많은 경우 노동위원회 심판 단계에서 조사관 및 공익위원, 노·사위원의 사실관계 조사 및 심리가 미진했다는 것을 나타낸다고 볼 수 있음.
 - 특히, 구제신청 접수 초기부터 사실관계 조사를 담당하는 조사관의 조사가 정확하지 못했다는 비판을 피하기 어려움.
 - 이는 조사관의 조사권한을 근로감독관의 수사권한에 준할 정도로 강화하고, 조사관 1인이 담당하는 배정 사건 수를 제한함으로써 더욱 정확한 조사에 임할 수 있도록 하는 등의 대책이 필요하다고 판단됨.
- 한편, 광의에서 사실관계 인정을 달리했다는 점에서는 유사하나, 당사자가 소송 과정에서 새로운 증거를 제출하거나, 교섭단위 분리의 정당성을 판단하던 중 회사가 분할되는 등 사정변경이 발생하는 경우(4.09%)는 ‘사실 인정을 달리한 경우’에서 제외하는 것이 바람직함.
 - 이는 노동위원회의 초심 또는 재심 판정 단계에서 사건조사가 잘못된 것과는 전혀 다른 경우이기 때문임.
 - 이와 관련하여, 당사자가 노동위원회 심판 단계에서 제출하지 않았던 새로운 증거를 제출하거나, 주장하지 않았던 새로운 사실관계를 주장하면서 행정심판의

위법·부당을 다투는 것은 타당하지 않다는 점에서, 행정심판에 대한 취소소송에서 새로운 증거 제출이나 새로운 사실관계의 주장을 허용하지 않아야 한다는 주장이 있음.

- 실질적 증거의 법칙(substantial evidence rule)

- 미국 연방행정절차법(FAPA)은 1946년 “법원은 행정위원회의 인정사실에 대하여 합리적 증거의 존부만을 심사하고 스스로 새로운 사실인정을 하는 것은 회피하여야 한다”는 내용의 실질적 증거의 법칙(substantial evidence rule)을 인정하고 있으므로, 당사자가 행정심판 절차 내에서 제출하지 않은 증거를 사법심사 단계에서 법원에 제출하는 것은 허락되지 않음.²⁶⁾
- 따라서, 미국의 전국노사관계위원회(NLRB)의 사실인정은 법원을 구속하는 것이 원칙이라는 점에서 우리나라와 큰 차이가 있음. 일본도 사실적 증거의 법칙을 인정하고 있지 않음.

- 우리나라 대법원 판례는 실질적 증거의 법칙을 부인하고 있음.

- “부당노동행위구제신청에 관한 중앙노동위원회의 명령 또는 결정의 취소를 구하는 소송에 있어서 그 명령 또는 결정의 적부는 그것이 이루어진 시점을 기준으로 판단하여야 할 것이지만 노동위원회에서 이미 주장된 사유만에 한정된다고 볼 근거는 없으므로, 중앙노동위원회의 명령 또는 결정 후에 생긴 사유가 아닌 이상 노동위원회에서 주장하지 아니한 사유도 행정소송에서 주장할 수 있다고 보아야 할 것이다”²⁷⁾

4. 노동위원회의 소송수행 능력 및 전략 부족

- 중앙노동위원회를 피고로 하여 제기된 행정소송에 대응함에 있어서, 노동위원회가 절차로서의 소송을 수행하는 능력이나 기술 측면에서의 부족함으로 인해 소송 절차를 경제적으로 관리하고 있지 못하다는 비판이 가능함.
- 2020년, 2021년, 2022년 3개년간 주요 패소사례에서 소송 진행 경과를 살펴보면, 1심과 2심에서 패소했음에도 불구하고 상고하여 대법원 판결을 받는 경우가 전체 패소 사건의 40%에 이르는 것을 확인할 수 있음.
- 대법원 상고사건의 상당수는 심리불속행기각으로 종결되어, 대법원의 본격적인 심사를 받지도 못하고 있음.

26) 김홍영, ‘노동위원회의 판정에 대한 사법심사’, 「노동법의 쟁점과 과제(김유성 교수 화갑기념)」, 2000, 법문사, 585쪽 이하; 손창희, ‘노동위원회 명령과 사법심사의 한계’, 「조정과 심판(제3호)」, 2000. 11, 중앙노동위원회, 5쪽 이하.

27) 대법원 1990. 8. 10. 선고 89누8217 판결.

- 법원의 1심과 2심 판결이 같은 취지로 내려질 경우 해당 사안에 대한 법원의 태도를 어느 정도 파악할 수 있음에도 불구하고 대법원에 상고하고 패소하는 것은 소송경제 측면에서도 바람직한 상황이라고 할 수 없음.
- 패소사건 중 1심에서 승소했으나, 2심에서 패소하고, 최종적으로 대법원에서 패소한 경우도 2년간 총 220건의 패소사건 중 30건으로, 13.64%에 이름.
- 또한, 이는 중앙노동위원회가 운영하는 “패소사건 검토회의”가 소송 결과를 정확히 예측하여 대응하지 못하고 있거나 실효성이 없음을 나타내는 것으로 판단할 수도 있음.

[패소 사건 소송 진행 경과 분석 (2020~2022년)]

		2020년		2021년		2022년		계	
소송 경과		건수	비율(%)	건수	비율(%)	건수	비율(%)	건수	비율(%)
3심	피고패>피고패>피고패	24	42.86	27	36.49	37	41.11	88	40.00
	피고패>피고승>피고패	1	1.81	2	2.70	0		3	1.36
	피고승>피고승>피고패	1	1.81	2	2.70	0		3	1.36
	피고승>피고패>피고패	7	12.50	6	8.11	17	18.89	30	13.64
	대법원 상고비율	33	58.93	37	50.00	54	60.00	124	56.36
2심	피고패>피고패	16	28.57	20	27.03	21	23.33	57	25.91
	피고(일부)승>피고패	1	1.81	1	1.35	3	3.33	5	2.27
	피고패>항소취하	1	1.81	0		4	4.44	5	2.27
	2심 확정 비율	18	32.14	21	28.38	28	31.11	67	30.45
1심	피고패	5	8.93	16	21.62	8	8.89	29	13.18
	1심 확정 비율	5	8.93	16	21.62	8	8.89	29	13.18
계		56		74		90		220	

- [사실인정에 문제가 있었고, 1심과 2심 법원 판결에서 동일한 사항이 지적됐음에도 상고를 강행한 사례] 대표적인 사례로는, 기간제 근로자 갱신기대권 인정 사건에서 동일 또는 유사한 시기에 갱신 과정에서 다수의 갱신 거절 사례가 존재하는지 여부는 매우 중요한 판단 지표 중 하나인데, 노동위원회 심판 과정에서 이를 간과한 것이 1심과 2심 법원 판결에서 지적됐으며, 그와 같은 사실관계 인정 차이가 중요한 패소 원인임에도 불구하고 그대로 대법원에 상고한 사건을 들 수 있음.²⁸⁾

28) 중노위 2019. 4. 29. 중앙2019부해238, 241 병합; 대법원 2021. 2. 4. 선고 2020두00000 판결.

중노위 2019. 4. 29. 중앙2019부해238, 241 병합, 주식회사 ○○개발 갱신거절 사건

<사건 개요>

신청인인 근로자 B는 2016. 8. 9.부터 경기 ○○시에 있는 롯데캐슬 아파트에서 기전 반장으로 근무하던 중 2018. 9. 1. 아파트 입주자대표회의로부터 아파트 관리업무를 위탁 받은 (주)○○개발로부터 부당하게 근로관계가 종료되었다고 주장하는 사람이다.

이 사건 입주자대표회의는 2015. 7. 2. □□종합관리(주)와 사이에 ‘이 사건 입주자대표회의가 □□종합관리(주)에게 아파트의 관리를 2015. 7. 1.부터 2018. 6. 30까지 위탁하는 내용의 계약’을 체결하였는데, 계약 내용 중에는 ‘관리주체가 변경되거나 계약이 만료되는 경우, 관리사무소에 근무하는 □□종합관리의 직원은 공동주택관리업무의 계속성 등을 위하여 이 사건 입주자대표회의가 새로운 관리주체에게 그 고용을 승계할 수 있다’는 내용이 포함되었다. 또한 입주자대표회의는 2018. 6. 28. (주)○○개발 사이에 이 사건 아파트의 관리를 2018. 7. 1.부터 2021. 6. 30.까지 위탁하는 내용의 계약을 체결하였다.

이후 (주)○○개발은 2018. 6. 13. 이 사건 아파트 관리사무소에서 근무하던 직원 15명에 대하여 면접을 실시하였고, 근로자 B와 2018. 8. 31.까지 근무하기로 하는 계약을 체결하였으며, 이후 2018. 8. 30. 근로자 B에게 ‘근로계약이 2018. 8. 31.부로 만료(종료)된다는 내용의 통보서를 교부하였다. 근로자 B는 2018. 11. 27. 경기지방노동위원회에 부당해고 구제신청을 하였다.

<노동위원회 판정>

○ 경기노위·중앙노동위원회 - 갱신기대권을 인정하여 구제신청을 인용

(※)○○개발이 갱신기대권을 갖고 있는 근로자 배○○에 대하여 합리적 이유 없이 근로계약의 갱신을 거절하고 근로관계를 종료한 것은 부당하다.

<법원의 판단>

○ 서울행정법원·고등법원 - 갱신기대권 부정, 재심판정 취소(근로관계 종료의 정당성 인정)
대법원 - 심리불속행 기각

① 근로계약, 취업규칙, 단체협약 등에 ‘기간만료에도 일정한 요건이 충족되면 당해 근로계약이 갱신된다’는 취지의 내용이 존재하지 않는 점, ② 근로자 B가 □□종합관리와 두 차례에 걸쳐 근로계약을 갱신한 뒤 (주)○○개발과 근로계약을 체결하였으나 두 회사는 다른 회사이므로 이전 회사와의 근로계약 갱신의 전례가 현 회사와의 사이에서 ‘근로계약이 갱신된다는 신뢰관계’를 형성하게 하지는 않는 점, ③ 근로자 B가 (주)○○개발과 근로계약을 체결하면서 이전 회사 재직 기간에 상응하는 퇴직금을 정산하지 아니한 점, ④ (주)○○개발과 근로자 B 사이에 체결된 근로계약에서 정한 근로계약기간이 2개월에 불과한 점, ⑤ 근로자 B와 이전 회사 사이의 근로계약 갱신은 별도의 심사절차가 없었지만, (주)○○개발 사이의 근로계약 체결은 면접 절차 등을 거쳐 이루어졌고, 위 면접절차에서 15명 중 9명이 탈락할 정도로 면접절차는 실제 의미를 갖고 있었던 점에 비추어보면 근로계약이 갱신된다는 신뢰관계를 인정하기는 어렵다.

근로자 B가 근로기간 동안 보인 근무태도에 비추어 보면 근로계약의 갱신을 거부할 합리적인 이유가 있고, 이 사건 근로자의 근무태도와 관련하여 □□종합관리나 (주)○○개발로부터 징계를 받은 적이 없다고 하더라도 달리 보기 어렵다.

- 이 사건 근로자 B의 소속이 변경될 당시 (주)○○개발은 기존에 □□종합관리

(주)에서 일하던 직원 15명을 그대로 승계한 것이 아니고, 별도의 면접절차를 거쳤으며, 그 중에서 9명을 제외하고 6명만을 채용하였으며, 이와 같은 사실 관계에 대해 노동위원회와 법원의 판단이 달랐기 때문에 결론이 달라진 사건임.

- 이 사건은 초심, 재심 노동위원회, 사실심인 1심 판결과 2심 판결이 모두 동일한 갱신기대권 판단 기준을 인정했으나, 사실관계의 해석만을 달리한 사건이고, 그 결과 노동위원회의 결정을 법원이 정 반대로 뒤집는 결론을 내린 사건임에도 중앙노동위원회가 상고²⁹⁾한 것은 무리한 절차진행이라고 하지 않을 수 없음.

5. 법원의 노동위원회 판정 존중 미흡

- 노동사건은 특히 근로자와 노동조합, 사용자가 근로조건이나 노사관계의 쟁점을 두고 충돌하는 것으로서, 일반적인 소송사건과는 구별되는 고유한 특질이 있음.
 - 특히 강행법규 이외에 노사간의 교섭으로 성립되는 단체협약, 노사간의 의견청취 또는 동의를 통해 형성되는 취업규칙, 사업장 관행 등 성문 법규 이외의 다양한 법원이 노사 당사자의 협의 내지 합의를 통해 형성되고 있으므로, 이를 둘러싼 법률분쟁은 일반적인 소송사건과는 전혀 다른 특질이 존재함.
- 따라서, 법관에 의한 경직적인 규범인식과 판단을 통해 노사관계 내지 노동관계에서 언제나 타당하고 정의로운 결론에 이를 수 있다고 판단하기는 어려움. 그러한 이유로 독일 연방노동법원은 1명의 직업법관 외에 2명의 명예법관으로 재판부를 구성하고 있으며, 명예법관은 노동 분야의 전문적인 지식을 갖춘 사용자측 명예법관과 근로자측 명예법관으로 구성하여³⁰⁾, 법률전문가의 법해석에 구체적 타당성을 더하는 방안을 택하고 있음.
- 노동위원회는 기간제 근로자의 갱신기대권 사건에서 갱신기대권 인정 요건을 법원보다 대체로 넓게 인정하는 경향이 있으며³¹⁾, 원하청 노사관계에서 하청 근로자로 조직된 노동조합의 원청 사업주에 대한 단체교섭을 더욱 넓게 인정하는 경향을 보이고³²⁾, 부당해고 사건에 대해서는 해고처분의 정당성을 대체로 좁게 인정³³⁾

29) 2020. 10. 26. 중앙노동위원회 상고

30) 차성안, '독일의 사회법 분쟁 해결과 사회법원의 역할', 「사회보장법학(제8권 제1호)」, 2019, 56쪽 이하.

31) 과거 OO전자 사건에서 중앙노동위원회는 갱신기대권을 인정한 반면 이에 대해 법원이 기간 만료를 인정하면서 중앙노동위원회 재심판정을 취소했던 사건(중노위 2006. 10. 18. 2006부해228, 237, 2006부노52 판정; 대법원 2008. 1. 17. 선고 2007두22047 판결)이 대표적이며 이러한 경향은 최근 까지도 이어지고 있음.

32) 단체교섭권 인정과 관련하여서는 최근 사건으로는 특별히 산업안전보건 쟁점과 관련한 원청 사업주의 단체교섭 의무를 인정한 OO제철 중노위 판정(충남지노위 2021. 11. 11. 판정 2021부노46, 중노위 2022. 3. 24. 판정 2021부노268), 원청 사업주에게 사내하청 협력업체 사업주와의 공동 단체교섭 의무를 인정하면서도 단체협약체결권 및 쟁의행위 상대방의 지위는 부인한 OOOO해양 중노위 판정

하여 사용자가 해고를 더욱 신중하게 하도록 하는 등 법원 판례와는 다른 ‘문제 의식’에 기초한 판정을 내리는 경우가 다수 발견되고 있으며, 이는 노동사건에 관한 노동위원회의 전문성과 특징을 나타내는 것이라고 평가할 수 있음.

- 노동위원회가 이와 같이 법원과 다른 판단을 내리면서 노동위원회만의 판정의 흐름을 견지한 경우, 추후에 법원도 그와 같은 방향으로 법리를 수정해 나가는 경우를 발견할 수 있다는 점에서 노동위원회가 법원과 다른 태도를 보이는 것을, 패소 사례가 늘어난다는 이유만으로 부정적으로 평가할 것은 아니라고 판단됨.
- 다만, 노동사건에서 노동위원회가 법원의 판례 법리를 선도하는 역할을 하기 위해서는 치밀한 사실관계 분석과 정밀한 법리의 구성이 요구됨.
- 이와 같이 노동위원회의 고유의 지위와 역할, 전문성이 있음에도 법원이 노동위원회의 권위와 전문성을 인정하지 않고 쉽게 노동위원회의 사실인정이나, 판정 결과를 부정하는 판결을 내리고 있는 것은 법원이 노동위원회 판정을 존중하지 않는 태도에서 기인한다고 분석할 여지도 있음.
- [노동위원회의 사실인정에 합리성이 있음에도 불구하고 법원이 판단을 달리하여 재심판정을 취소한 사례] 대표적인 사례로는, 기간제 근로자 갱신기대권 인정 사건에서 갱신 거절의 합리성과 관련하여 노동위원회가 충분한 조사를 통하여 합리적으로 판단했으나, 법원이 판단을 달리하여 재심판정을 취소한 사건을 들 수 있음.³⁴⁾

중노위 2019. 2. 19. 2018부해1326 판정, ○○씨엠 갱신거절 사건
<사건 개요> 신청인인 근로자 S는 2014. 9. 1. ○○씨엠(주)에 계약직(촉탁)으로 입사 후 2015. 3. 24.부터 2018. 8. 31.까지 대구 M 아파트에서 경비원으로 근무했는데, 위 기간 동안 1~8개월의 근로계약기간으로 총 15회(최종 근로계약기간 2018. 2. 1.~8. 31.) 계약갱신을 통해 근무하였다. 피신청인인 ○○씨엠(주)은 2018. 8. 17. 근로자 S에게 근로계약이 2019. 8. 31.자로 종료된다는 취지의 근로계약 종료 통보서를 내용증명으로 발송하였다. 근로자 S는 위 내용증명으로 인한 통보는 부당해고에 해당한다고 주장하면서 경북지방 노동위원회에 구제신청을 하였다. <노동위원회 판정> ○ 경기노위·중앙노동위원회 - 갱신기대권은 인정되나 갱신 거절의 합리성 인정, 구제신청 기각

(경남지방노동위원회 2022. 6. 23. 판정 2022부노14, 중노위 2022. 12. 30. 판정 2022부노139.) 등을 들 수 있다.

33) 중노위 2018. 4. 10. 2018부해161 판정; 대법원 2020. 6. 4. 선고 2020두00000 판결.

34) 중노위 2019. 2. 19. 2018부해1326 판정; 대법원 2020. 12. 30. 선고 2020두00000 판결.

<법원의 판단>

○ 서울행정법원·고등법원 - 갱신기대권 인정, 갱신 거절의 합리성 부정, 재심판정 취소
대법원 - 심리불속행 기각

① 근로자 S와 사용자의 근로계약은 기간의 정함이 있는 근로계약이고 계약기간의 만료로 당연퇴직 되는 것이 원칙이므로, 사용자가 갱신거절의 과정에서 그 사유를 서면으로 통지할 필요는 없으나, ② 다만, 갱신거절 전 근로자 S는 전임 관리소장을 내부고발하였고, 갱신거절과 이러한 내부고발과의 사이에 연관이 있는 것으로 합리적인 의심이 드는 점, 사용자의 주장처럼 인사고과평가를 실시하고 이를 기준으로 갱신여부를 결정하였다는 관행이 존재하였다고 볼 수 없는 점, 가사 이러한 관행이 존재하였다고 하더라도 인사고과평가 자체가 객관성, 합리성, 공정성을 갖추었다고 보기 어렵다는 점 등의 사정을 종합하여 볼 때

근로자에게는 계약갱신에 대한 기대권이 발생하였고, 사용자가 갱신거절의 이유로 삼은 인사고과평가는 객관성, 합리성, 공정성을 갖추었다고 보기 어려우므로, 갱신거절의 정당한 사유가 인정된다고 보기 어렵다.

- 기간제 근로계약을 체결한 경우, 일정한 요건 하에서 갱신기대권이 인정된다는 점에 있어서는 노동위원회, 법원 모두 같은 결론을 도출하였으나, 갱신거절의 합리적 이유가 있는지 여부에 관하여는 노동위원회와 법원의 판단이 반대되었는데, 이는 사용자가 갱신거절의 주된 이유로 밝힌 ① 인사고과평가를 근거로 갱신을 거절해 온 관행이 있는지 여부, ② 인사고과평가 자체의 공정성, 합리성 등에 대한 사실관계 인정에 차이가 있었음.
- 인사고과평가 자체는 근로자에게 불리했던 것은 사실이나 법원은 그러한 인사고과평가 자체가 합리성에 의심이 들고, 인사고과평가를 근거로 근로자와의 갱신을 거절하는 관행이 있었다고 보기 어렵다고 판단한 반면, 중앙노동위원회는 인사고과평가의 객관성을 인정하였고 그 결과를 이유로 한 갱신거절에 합리성이 있다고 판단하였음.
- 노동위원회 판정문과 법원의 판결문을 검토해보면, 노동위원회 심리 과정에서도 사실관계에 대한 충분한 조사가 이루어졌다고 판단되지만, 각 당사자가 제기한 주장 중 어느 쪽의 주장이 합리적인지에 관한 판단이고, 수치화, 정량화하기는 곤란한 정황과 배경사항에 대하여 판단을 달리한 것이므로 중앙노동위원회의 판정이 위법하거나 부당하다고 보기는 어렵다고 판단되며,
 - 행정소송의 특수성을 고려하지 않고, 법원이 행정심판기구로서 노동위원회의 권위와 전문성에 기초한 판단을 존중하지 않고, 위법성과 부당성을 쉽게 인정하는 판결을 내린 것은 재고의 여지가 있다고 판단됨.
- 비록, 이 사건은 초심, 재심 노동위원회, 사실심인 1심 판결과 2심 판결이 모두 동일한 법적 기준을 인정하되 사실관계의 해석만을 달리한 사건이고, 그

결과 법원이 노동위원회의 결정을 정반대로 뒤집는 결론을 내린 사건이지만, 중앙노동위원회가 대법원에 상고한 것은 일응 타당성이 있다고 볼 여지가 있음.

II. 적극적 관점

1. 법원과는 다른 차원의 구체적 타당성 확보 추구

- [해고사건에서 노동위원회의 법리판단에 합리성이 있었지만, 충분한 근거제시에 실패한 사례] 대표적인 사례로는, 동일한 사실관계에 관한 판단에 있어서 노동위원회가 법원의 기존 판례와 다른 판단을 내리고 있으나, 그러한 판단을 내리게 된 충분한 법리적 근거를 제시하지 못하여 패소하게 된 사건을 들 수 있음.³⁵⁾

중노위 2018. 4. 10. 중앙2018부해161 판정, ○○○○개발 부당해고 사건
<사건 개요> 신청인은 동료직원들에 대한 폭언, 술자리 강요, 업무 떠넘기기 등의 행위를 하여, 동료들의 타부서 전출 요청을 받은 회사로부터 전보발령을 받은 바 있다. 그러나 전보 이후에도 동료에게 폭언을 하고 상급자의 정당한 업무지시를 거부하는 등의 행동을 계속 하여, 동료들이 회사에 진정 및 탄원을 하고 징계절차가 개시됐다. 신청인 근로자는 동료들에게 사과하지 않고, 징계위원회에서도 비위행위 자체를 부인하였으며, 자신의 페이스북에 “ㄸ○○○개발은 노동 착취당하고 근무한다는 걸. 대기업 같지만 감정인사와 비빈대로 인사. ㅋㅋ. 여행업계에서 말하는 좆○○○개발 징계해고자”라는 글을 게재 하였다. 이에 회사가 취업규칙에 따라 징계해고를 하자, 참가인은 서울지노위에 부당해고 구제신청을 하였다. <노동위원회 판정> ○ 서울지노위·중앙노동위원회 - 부당해고 판단 신청인에게 그 동안 징계 이력이 없고 우수사원 표창을 받은 적이 있다는 점을 고려 하여야 하고, 낮은 수위의 징계를 전혀 거치지 않고 곧바로 가장 무거운 해고를 한 것은 징계 재량권 남용으로 인한 부당해고라고 판단 <법원의 판단> ○ 고등법원 - 징계의 정당성 인정 (대법원 심리불속행 기각) 해고처분은 사회통념상 고용관계를 계속할 수 없을 정도로 근로자에게 책임 있는 사유가 있는 경우에 행하여져야 정당성이 인정되고, 사회통념상 당해 근로자와의 고용관계를 계속할 수 없을 정도인지는 당해 사용자의 사업의 목적과 성격, 사업장의 여건, 당해 근로자의 지위 및 담당직무의 내용, 비위행위의 동기와 경위, 이로 인하여 기업의 위계 질서가 문란하게 될 위험성 등 기업질서에 미칠 영향, 과거의 근무태도 등 여러 가지 사정을 종합적으로 검토하여 판단하여야 한다. 수 개의 징계사유 중 일부가 인정되지 않더라도 인정되는 다른 징계사유만으로도 당해 징계처분의 타당성을 인정하기에 충분한 경우에는 그 징계처분을 유지하여도 위법하지 아니하다.

35) 중노위 2018. 4. 10. 2018부해161 판정; 대법원 2020. 6. 4. 선고 2020두00000 판결.

여행업의 특성상 신속하고 적절한 고객 응대는 영업의 핵심적 부분이라는 점과 참가인 담당업무의 특성을 고려할 때, 참가인과 회사·동료들 간 협력과 신뢰관계는 고용을 계속할 수 있는지를 결정하는 기준이라고 보아야 한다. 그런데, ▲참가인이 동료직원들의 인격권을 침해하고, 회사 및 동료직원들과의 신뢰관계 심각하게 훼손한 점, ▲본인의 행위에 대해 동료들에게 사과한 바 없고, 징계위원회에서도 본인의 비위행위 자체를 부인하는 등 진심으로 반성하는 태도를 보이지 않은 점, ▲비록 참가인이 이전에 징계받은 전력이 없고 해고보다 낮은 강도의 징계처분도 존재하지만, 당초 회사가 징계보다 부서이동 등을 통해 개선기회를 주려하였음에도 참가인의 계속되는 비위행위와 징계과정에서 보인 태도로 인해 개선의 여지가 없다는 판단에 이르게 된 점, ▲상당수 동료직원들이 참가인의 복직을 반대하는 점 등에 비추어 더 이상 고용관계를 유지할 수 없는 상태에 있다고 볼 수 있다.

- ‘징계 양정의 적절성’이 핵심 쟁점이 된 사건으로, 중앙노동위원회는 참가인이 18년 근무하는 동안 징계받은 이력 없는 점, 동료에 대한 폭언·욕설 등은 일시적·순간적으로 흥분하여 한 행위로 보이는 점, 경고·견책·감봉·정직 등 해고보다 낮은 수위의 징계를 전혀 거치지 않고 가장 무거운 해고를 한 점 등을 고려할 때, 징계 양정이 과하여 부당해고라고 판단하였음.
- 그러나 2심 법원은 동료들과의 협력과 신뢰관계가 매우 중요한 여행업의 특성과 신청인 근로자의 행태상의 사유를 고려하고, 당초 회사가 징계보다 부서이동 등을 통해 개선기회를 주려하였음에도 참가인의 계속되는 비위행위와 징계과정에서 보인 태도로 인해 개선의 여지가 없다는 판단에 이르게 된 점 등을 고려하여 노동위원회와 다른 판단을 하였음.
- 중앙노동위원회 재심단계에서 객관적인 사실관계는 거의 다 드러난 것으로 보이며, 법원과 중앙노동위원회 사이에 사실관계 인정에서의 차이점은 발견되지 않으나, 그 사실관계를 기초로 한 징계 양정의 정당성 판단에서 서로 상반되는 결론을 내렸음.
- 상대적으로 중앙노동위원회는 ‘해고는 최후의 수단’이라는 점에 무게를 두고, 참가인이 그동안 징계이력이 없고 우수사원 표창을 받은 적이 있다는 점을 적극 고려하여, 해고보다 약한 징계조치를 먼저 취하여 개선을 도모하지 않고 바로 해고처분으로 나아간 것은 과한 조치라고 판단한 것으로 보이는 반면, 법원은 회사 및 참가인의 업무 특성상 동료들과의 신뢰관계가 매우 중요하다는 점에 착안하여, 실질적으로 ‘고용관계를 유지할 수 없을 정도에 이르렀는가’에 중점을 두고 판단하고 있음.
- 중앙노동위원회가 패소한 결정적인 요인은 그동안 판례가 제시해 온 징계 양정의 정당성 법리의 일관된 관점과 노동위원회의 관점에 차이가 있다는 점에 있음.

- 해고의 최후수단성을 강조하여 해고의 정당성 인정에 신중한 태도를 보여온 노동위원회가 특별한 경향성을 고려하면, 이를 지지할 수 있는 법리적 근거를 더욱 충분히 제시하여 법원의 확립된 판례의 태도를 변경시킬 정도에 이르지 못한 것이 유감이라고 생각됨.

○ 미국 전국노사관계위원회(NLRB)의 법원에 대한 관할권 확보 노력

- 연방노동관계법(NLRA) 제정 이후 Miranda Fuel Co. 사건까지
 - 미국에서 ‘공정대표의무’ 위반에 대한 판정 권한이 연방법원 또는 주 법원에 있는지 아니면 전국노사관계위원회(NLRB)에 있는지를 둘러싸고 오랜 관할권 분쟁이 이루어지고 있음.
 - 미국 전국노사관계위원회(NLRB)는 1962년 Miranda Fuel Co. 사건에 대한 판정³⁶⁾에서부터 공정대표의무 위반이 부당노동행위를 구성한다고 주장하면서³⁷⁾, 전국노사관계위원회는 연방노동관계법 제10조에 따라, 전국노사관계위원회가 부당노동행위 구제절차에 관한 전속적 관할권을 갖는다는 사실을 근거로 공정대표의무 위반 사건에 대해서도 배타적 관할권을 가진다고 주장했음.³⁸⁾
 - 이와 같은 전국노사관계위원회의 판정은 제2차 순회심판 항소법원 판결에서 부인되었는데³⁹⁾, 법원이 전국노사관계위원회의 판단을 배척한 주된 이유는 공정대표의무는 부당노동행위가 연방노동관계법에 규정되기 이전부터 법원의 판례에 의해 형성되어온 의무이며, 공정대표의무가 연방노동관계법 제8조의 부당노동행위에 해당한다는 명시적인 규정이 없다는 것이었으며, 이를 통해 공정대표의무 위반 사건에 대한 전국노사관계위원회의 배타적 관할을 인정하는 선점(preemption, 연방법률과 모순되거나 연방법률의 입법취지에 어긋나는 각 주의 법령은 그 범위 내에서 효력을 상실한다는 연방법 우선의 원칙)의 법리가 적용되는 것을 차단하고자 하였음.
 - 하지만 학계에서는 공정대표의무 위반이 부당노동행위에 해당하므로 전국노사관계위원회의 관할권에 속한다는 전국노사관계위원회 Miranda Fuel Co. 판정의 법리적 타당성을 법률해석의 정당성, 비용과 절차적 신속성 측면에서의 이점 등을 이유로 지지하는 견해가 다수 나타나고 있음.⁴⁰⁾
 - 공정대표의무 위반 사건이 사법심사의 대상이 되기보다는 노사관계의 매우 중핵적인 부분에 해당하는 문제로서 노사관계의 특수성을 인정하여 법원이

36) Miranda Fuel Co., 140 NLRB 181(1962).

37) Mitchell H. Rubinstein, 'Duty of Fair Representation Jurisprudential Reform', 「Univ. of Michigan Journal of Law Reform(Vol.42)」, 2009, 521쪽.

38) Gregory L. Hellrung, 'The National Labor Relations Board and the Duty of Fair Representation', 「Catholic Univ. L. Rev.(Vol.13)」, 1962, 173쪽.

39) NLRB v. Miranda Fuel Co. Inc., 326 F.2 172 (2d Cir. 1963).

40) James L. Baldwin III, 'The Duty of Fair Representation and its Applicability When a Union Refuses to Process an Individual's Grievance', 「South Carolina L. Rev.(Vol.20)」, 1968, 262쪽; Robert J. Deeny, 'The Duty of Fair Representation', 「Catholic Univ. L. Rev.(Vol.20)」, 1970, 306쪽 이하 등.

매우 신중하고 제한적으로만 개입하는 것이 바람직하다는 점을 학계가 인정한 것으로 생각됨.

- Vaca 사건 이후 전국노사관계위원회와 연방법원의 태도

- 연방노동관계법 위반 사건에 대하여 선점(preemption) 법리가 인정된 이유는 복잡한 노동 사건에서 각 주 법원들의 판결이 불일치할 경우의 위험이 지나치게 크다는 것을 우려하여⁴¹⁾ 전국노사관계위원회가 각 주 법원에 대하여 배타적인 관할권을 갖도록 하는 것이 바람직하다는 판단에 따른 것임.
- 법원은 노동3권 침해 사건이나 부당노동행위로 다투어지지 않은 공정대표 의무 위반 사건에 관해서는 1944년 Steele 사건에서부터 지속적으로 관할권을 행사해왔고, 미국 연방대법원은 1967년 Vaca 사건 판결⁴²⁾에서 공정대표의무 위반이 언제나 부당노동행위에 해당하는 것은 아니며, 공정대표의무 위반을 근거로 한 근로자의 손해배상 소송 등에 대해서는 법원이 관할권을 행사할 수 있다는 결론을 확립했음.⁴³⁾
- Vaca 사건에서 공정대표의무 위반 사건에 대한 전국노사관계위원회의 선점을 인정하지 않는 연방대법원의 견해가 확립된 이후에도 이후 일부 연방 법원 하급심 판결⁴⁴⁾에서 공정대표의무 위반 사건에 대한 전국노사관계위원회의 관할권을 인정하는 사례가 나타나기도 했으며, 공정대표의무 위반 사건에 관한 한 전국노사관계위원회와 법원이 각자의 원칙에 따라 각각 관할권을 행사하는 현상이 지속되고 있음.⁴⁵⁾
- 전국노사관계위원회(NLRB)는 미국 연방대법원의 판결에도 불구하고 공정대표의무 위반에 대한 구제신청사건을 여전히 처리하고 있는데⁴⁶⁾, 전국노사관계위원회가 이와 같이 독자적인 노선을 유지할 수 있었던 것은 전국노사관계위원회가 확립한 법해석과 법리의 타당성, 그에 대한 학계의 광범위한 지지, 비록 다른 입장을 가지고 있지만 위원회의 판단을 존중하는 사법부의 태도 등이 기초가 된다고 볼 수 있음.

41) David L. Gregory, 'The Labor Preemption Doctrine: Hamiltonian Renaissance or Last Hurrah?', 『William & Mary L. Rev.(Vol.27)』, 1986, 523쪽.

42) Vaca v. Sipes, 386 U.S. 171 (1967).

43) John E. Higgins 외, 『The Developing Labor Law(7th) Vol. II』, Bloomberg BNA, 2017, 25-5 쪽.

44) Stanley B. Stout v. Construction and General Laborers District Council of Chicago and Vicinity, 226 F. Supp. 673 (N.D. Ill. 1963); Local 12, United Rubber Workers v. NLRB, 368 F. 2d 12 (5th Cir. 1966) 등.

45) Gregory L. Hellrung, 'The National Labor Relations Board and the Duty of Fair Representation', 『Catholic Univ. L. Rev.(Vol.13)』, 1962, 183쪽.

46) Arriaga-Zayas v. Int'l Ladies' Garment Workers Union, 835 F.2d 11, 14 (1st Cir. 1987); Conley v. Int'l Bhd. of Electrical Workers Local 639, 810 F.2d 913, 916 (9th Cir. 1987); California Saw and Knife Works and Peter A. Podchernikoff, 320 NLRB 224 (1995); Cortes v. Airport Catering Servs. Corp., 386 F. Supp. 2d 14, 20 (D.PR. 2005) 등.

2. 새로운 법리 구축 가능성 탐색

○ [기존 규정의 해석 범위 확대를 통한 새로운 법리해석 시도가 실패한 사례]

대표적인 사례로는, 아직 대법원의 최종 결론이 내려지지 않는 않지만, 노동위원회의 교섭단위 분리(통합) 결정권한을 확대하여 두 개 이상의 독립된 사업 또는 사업장을 하나의 교섭단위로 통합하는 결정을 내리고자 시도했으나 하급심 법원에 의해 부인된 사건을 들 수 있음.

중앙노동위원회 2021. 2. 3. 2021단위1 판정, ○○○솔루텍 교섭단위 분리 사건

<사건 개요>

○○○솔루텍주식회사(회사)는 ○○전자(주) 제품의 수리업 및 유지보수업을 목적으로 설립된 ○○전자의 자회사이다. 이 회사의 사업부문은 상업시설 및 공장용 중·대형 에어컨의 수리업무를 담당하는 에어솔루션·종합공조 사업부(①)와 가정용 제품 유지·관리 업무를 담당하는 케어솔루션사업부(②)로 구분되어 있었다. ① 사업부 소속 인원은 회사의 정규 직 근로자들로 2020. 9월 말 기준 1,503명이었다. ② 사업부 소속 인원은 회사와 업무위탁 계약을 체결하여 ○○전자가 판매 또는 임대한 생활가전 제품(정수기, 공기청정기, 안마의자, 스타일러 등)에 대한 유지·관리 서비스 업무를 수행하였으며, '케어솔루션 매니저'라는 호칭으로 불렸다. 2020. 9월 말 기준 4,337명이었다.

민주노총 산하의 금속노조 서울지부 ○○○솔루텍지회(C 지회)는 2020. 5. 27. 설치되어 회사 ② 사업부 소속 케어솔루션 매니저들과 ① 사업부 소속 일반근로자들로 조직되어 있었다. 2020. 9월 기준 회사인 ○○○솔루텍 소속 총 조합원 수는 700명으로, 그 중 케어솔루션 매니저와 일반근로자의 비율이 약 7:3이었다. 또한 ○○○솔루텍 노동조합(이하 A 노조)은 한국노총 산하의 기업단위 노동조합으로 2020. 7. 2. ① 사업부 소속 일반근로자들을 조직대상으로 설립되었다. A 노조는 조합원 중에 케어솔루션 매니저는 없고 ○○○솔루텍의 정규직 근로자만 노동조합 규약상 가입이 가능하며, 2020. 9월 기준 A 노조의 전체 조합원 수는 276명이었다.

교섭창구 단일화 결과 C 지회가 교섭대표노동조합으로 확정된 이후 회사가 분할되어 두 개의 서로 다른 법인으로 나뉘어져 ① 사업부는 '○○○솔루텍'으로, ② 사업부는 '○○○케어솔루션'으로 나뉘어지자 분할 후 잔존 회사(○○○솔루텍) 사업 내에서 C 지회가 A 노조에 비하여 소수노조로 조직구도가 변화되고, C 지회소속 대다수 조합원들이 분할 이후 성립된 ○○케어솔루션 소속이 되었다. 이에 기존의 소수노동조합이었던 A 노조가 교섭단위 분리신청을 하였다.

<노동위원회 판정>

○ 서울지노위 2020. 11. 18. 2020단위36 판정 - 교섭단위 분리 필요성 인정

케어솔루션 매니저는 노동조합법 제2조 제1호에서 정한 근로자에 해당하고, 케어솔루션 매니저와 일반근로자 간에 근로조건 및 고용형태에서 현격한 차이가 있다고 보아 케어솔루션 매니저 직종을 별도의 교섭단위로 분리할 필요성을 인정하여 원고 보조참가인인 A 노조의 신청을 인용하였다.

○ 중앙노동위원회 2021. 2. 3. 2021단위1 판정 - 교섭단위 분리 필요성 부정

이 사건 회사분할로 재심 신청의 구제 이익이 없다고 볼 수 없고, 케어솔루션 매니저

직종을 별도의 교섭단위로 분리해야 할 필요성이 인정되지 않는다.

교섭대표노동조합인 C 지회가 케어솔루션 매니저 외에 일반근로자들의 이익을 대변하지 못한다거나, 단체교섭의 효율성을 저해할 우려가 있다고 단정하기 어렵고, 설령 C 지회가 교섭대표노동조합으로서 일반근로자들의 이익을 대변하지 못한다면, A 지회는 교섭대표 노동조합에 대해 추가 보충교섭을 요구하거나 노동위원회를 통한 공정대표의무 위반 문제를 제기하는 등 법적 절차에 따라 시정할 수 있는 제도가 마련되어 있으며, 교섭단위 분리를 선불리 결정해 줄 경우 결과적으로 교섭대표노동조합이 그 지위를 잃게 되는 등 노사관계 안정에 영향을 미칠 우려가 있고, 이로 인해 노동조합이 지향하는 통일적 근로조건 확보에 지장을 초래할 뿐만 아니라, 교섭창구 단일화 절차가 형해화될 가능성 또한 배제하기 어렵기 때문에 교섭단위 분리의 필요성이 없다.

A 노조가 교섭단위 분리 신청을 한 것은 교섭단위 분리를 통한 효율적인 단체교섭의 진행 등에 목적을 두기보다 케어솔루션 매니저들로 주로 조직된 C 지회의 조합원 수가 더 많은 관계로 교섭대표권을 확보하지 못한 A 노조가 케어솔루션 매니저 직종을 별도 분리 신청함으로써 일반근로자들에 대한 교섭대표권을 확보하기 위한 목적이 있는 것으로 보이고, 사용자인 회사는 케어솔루션 매니저가 소속된 C 지회와의 단체교섭을 하지 않겠다는 입장을 분명히 하면서 케어솔루션 매니저 직종을 별도의 법인으로 분리하여 관리하겠다는 입장인 것임을 알 수 있다.

또한, 초심지노위 결정 이후, 회사분할로 케어솔루션 매니저 직종이 ○○○솔루텍에 남아 있지 않으므로, 비록 사후적이지만 ○○○솔루텍으로서는 교섭단위를 분리해야 할 필요성이 남아있지 않다.

<법원의 판단>

- 서울행정법원 2021. 11. 12. 선고 2021구합00000 판결 - 교섭단위 분리 필요성 인정
※ 피고 : 중앙노동위원회 / 피고보조참가인 대리인 : 법무법인 여는

이 사건 재심결정으로 이 사건 초심결정을 취소하면 피고보조참가인이 교섭대표노동조합의 지위를 회복할 수 있다고 보더라도, 이 사건 회사분할이 이루어져 교섭창구 단일화 절차를 유지할만한 실익이 없어지는 사정변경이 발생하였으므로, 재심신청을 통해 달성하고자 하는 구제의 내용이 사실상 실현될 수 없다. 따라서 이 사건 재심결정 당시를 기준으로 볼 때 피고보조참가인이 재심결정을 구할 신청의 이익이 존재하지 않았다고 봄이 타당하다.

노동조합법상의 교섭창구 단일화 제도는 하나의 사업 또는 사업장에 2개 이상의 노동조합이 병존하는 경우 야기될 수 있는 현실적인 문제, 즉 복수의 노동조합이 각각 독자적인 교섭권을 행사할 수 있도록 할 경우 발생할 수 있는 노동조합과 노동조합 상호 간의 반목 및 노동조합과 사용자 사이의 갈등, 동일한 사항에 대해 같은 내용의 교섭을 반복하는 데서 비롯되는 교섭 효율성의 저하와 교섭비용의 증가, 복수의 단체협약이 체결되는 경우 발생할 수 있는 노무 관리상의 어려움, 동일하거나 유사한 내용의 근로를 제공함에도 노동조합 소속에 따라 상이한 근로조건 적용을 받는다는 발생하는 불합리성 등의 문제를 효과적으로 해결하는 데 그 취지가 있다.

이 사건에서 보건대, 케어솔루션 매니저 직종과 일반근로자 사이에 현격한 근로조건 차이 및 유의미한 고용형태의 차이가 존재하고, 케어솔루션 매니저 직종만을 별도의 교섭단위로 분리하여 교섭이 이루어진 관행이 존재하지 않기는 하나 이는 피고보조참가인이 설립되기 이전에 원고에 노동조합이 존재하지 않았기 때문이며, 케어솔루션 매니저 직종을 별도의 교섭단위로 분리함으로써 달성하려는 이익이 교섭창구 단일화 절차를 유지함으로써 달성되는 이익보다 더 크다고 볼 수 있다.

- 서울고등법원 2022. 10. 12. 선고 2021누00000 판결 - 항소 기각

- 피고인 중앙노동위원회가 상고하여 대법원 심리 중(대법원 2022두00000)

- 중앙노동위원회의 2021. 2월 ○○○솔루텍 교섭단위 분리 신청 사건은, 지노위가 교섭단위 분리 신청을 받아들여 분리 필요성을 인정한 사안에 대하여, 재심신청 이후 회사 분할로 인해 교섭단위가 물리적으로 분리되었음에도 불구하고 노동위원회가 교섭단위 분리 필요성을 부정하여 초심을 취소한 사건임.
- 이 사건은 재심판정을 취소하고 교섭단위 분리 필요성을 인정한 1심 서울행정법원의 판결에 대한 중앙노동위원회가 항소하였으나 서울고등법원에서 항소기각 판결이 내려졌고, 이를 다시 상고하여 대법원에 계류 중임(대법원 2022두00000).
- 이 사건에 대한 중앙노동위원회 판정은 노동조합법 제29조의3 제2항에 따른 “현격한 근로조건의 차이, 고용형태, 교섭 관행 등”을 고려하였을 때 교섭단위 분리 필요성이 현저하며, 교섭단위 분리 신청의 원인이 된 당사자의 의도나 의사는 분리 결정 판단에서 고려하지 않는다는 중앙노동위원회 스스로의 매뉴얼⁴⁷⁾에도 어긋나는 결정을 내렸다는 점에서 문제점이 많은 판정임에도 불구하고 중앙노동위원회가 대법원까지 상고를 지속하고 있는 다소 이해하기 어려운 흐름을 보여주는 사건임.
- 2019년에서 2021년에 이르는 기간에 노동계 노동계에 우호적인 정당과 협력하여, 노동조합 산별교섭, 업종별 교섭 등 초기업단위 단체교섭을 요구할 때 사용자가 이를 따르도록 하는 방안⁴⁸⁾과 여러 개의 사업 또는 사업장을 하나의 교섭단위로 묶어서 결과적으로 초기업별 단체교섭이 이루어지도록 하는 방안⁴⁹⁾ 등에 관한 입법이 추진되었으나, 노동계의 주장에 따른 입법이 원활하게 추진되지 않고 있는 상황이었음.
- 이는 중앙노동위원회의 당시 판정이, 단순히 금속노조 서울지부 ○○○솔루텍 지회의 단체교섭권 보장 목적 이외에 또 다른 고려가 있었던 것으로 볼 수 있는 배경이 되며, 그것은 초기업 수준에서의 교섭단위 설정 가능성에 대한 이론적 실험이라고 판단할 수 있음.
 - ○○○솔루텍지회 지회가 ○○○솔루텍에서 교섭대표노동조합의 지위를 유지하면서, 분할된 회사인 ○○케어솔루션에서도 단체교섭권을 확보하게 된다면, 서로 다른 두 법인을 하나의 교섭단위로 묶을 수 있는 계기를 만들 수 있기 때문에, 이는 교섭단위를 사업 또는 사업장 단위로 전제하는 현행 노동조합법 체제 하에서 법개정 없이 교섭단위의 외연을 확대하여 노동계

47) 중앙노동위원회, 「복수노조 업무 매뉴얼」, 2011, 152쪽.

48) 의안번호 2104376, 2020. 9. 29. 강은미 의원 대표발의, 노동조합 및 노동관계조정법 일부개정법률안(강은미 의원 등11인).

49) 의안번호 2104441, 2020. 10. 7. 안호영 의원 대표발의, 노동조합 및 노동관계조정법 일부개정법률안(안호영 의원 등 10인).

의 요구를 실현할 수 있는 계기가 되기 때문임.

Ⅲ. 소결

- 이상에서 노동위원회가 법원 소송 절차에서 패소하는 원인을 소극적 관점과, 적극적으로 평가하는 관점 두 가지 방향에서 자세히 살펴보았음.
- 현재의 노동위원회의 재심 유지율에 대하여 긍정적으로 평가하는 관점이 존재함.⁵⁰⁾
- 우선 노동위원회가 법원의 취소소송 절차에서 패소하게 되는 원인을 소극적인 관점에서 살펴보면, 첫째, 노동위원회 조사관 및 공익위원의 전문성 부족, 둘째, 판정문 작성의 신중함과 전문성 결여, 셋째, 노동위원회의 조사 능력 및 권한 부족, 넷째, 노동위원회의 소송수행 능력 및 전략 부족, 다섯째, 법원의 노동위원회 판정 존중 미흡 등 크게 다섯가지 측면에서의 분석이 가능함.
- 노동위원회 조사관 및 공익위원의 전문성 부족이 원인이 된 대표적인 패소 사례로는 확립된 대법원 판례 법리를 간과한 경우와 기본적인 법리를 알지 못한 경우 두 가지 대표사례를 제시했음.
- 노동위원회의 조사 능력 및 권한 부족 문제는 조사관 및 공익위원, 특히 상임위원 증원과 전문성 강화 등의 대책이 필요하나, 한편으로는 당사자들이 노동위원회 심판 과정에서 제출되지 않았던 새로운 증거를 소송 과정에서 제출하는 것이 법원이 노동위원회가 인정한 사실관계를 부정하고 결국 노동위원회 판정을 취소하게 되는 중요한 원인이 되기 때문에 미국 연방행정절차법이 규정하고 있는 '실질적 증거의 법칙(substantial evidence rule)'에 대해 검토할 필요가 있음을 제안하였음.
- 노동위원회의 소송수행 능력 및 전략 부족을 나타내는 대표적인 사례로는 사실 인정에 문제가 있었고, 1심과 2심 법원 판결에서 동일한 사항이 지적됐음에도 불구하고, 중앙노동위원회가 상고를 강행하여 패소한 사례를 제시했음.
- 한편, 법원의 전문적인 노동 관련 행정심판기구인 노동위원회 판정을 존중하는 태도를 견지할 필요가 있으나, 그러한 태도가 부족하여 너무 쉽게 노동위원회 판정을 취소하는 관행도 지적했음. 이에 대해서는 노동위원회의 사실인정에 합리성이 있음에도 불구하고 법원이 판단을 달리하여 재심판정을 취소한 사례를 제시하였음.

50) 노동법실무연구회(이준상·김근홍 집필 부분), 「노동조합 및 노동관계조정법 주해(제2판)」, 2023, 박영사, 915쪽.

- 우선 노동위원회가 법원의 취소소송 절차에서 패소하게 되는 원인을 적극적인 관점에서 긍정적으로 분석할 수 있는 측면을 살펴보면, 첫째, 법원과는 다른 차원의 구체적 타당성 확보 추구 경향과, 둘째, 새로운 법리 구축 가능성 탐색의 가능성을 모색한 것으로 평가할 수 있음을 밝혔다.
- 그 근거로서, 노동위원회 패소 사례 중에, 해고사건에서 노동위원회의 법리 판단에 합리성이 있었지만, 소송 과정에서 그 법리판단에 대한 충분한 근거 제시에 실패하여 패소한 사례와, 기존 규정의 해석 범위 확대를 통한 새로운 법리해석 시도가 실패하여 패소한 사례를 대표사례로 제시하였음.
- 또한, 노동위원회가 법원의 판결과 다른 결론을 취하여 대립하는 것이 반드시 문제가 있는 것은 아니라는 점을 뒷받침하기 위해, 미국 전국노사관계위원회(NLRB)가 공정대표의무 위반 사건에 대한 배타적 관할권을 확보하기 위하여 각 주 법원은 물론 연방대법원의 판례와도 다른 판정 태도를 유지하고 있는 사례를 제시하였음.
- 노동위원회의 재심판정 유지율이 어느 정도 수준 이상 확보되지 못하는, 즉 법원의 취소소송 단계에서 패소 사례가 좀처럼 줄지 않는 원인에 대하여는 이상과 같은 긍정과 부정 두 가지 측면에서의 분석과 평가가 가능하며, 각 원인에 대응하기 위한 개선방안에 대한 논의가 필요함.

제4장 개선 방안

- 이상에서 검토한 패소 원인에 대한 검토를 토대로 노동위원회 심판제도 운영 및 소송 대응을 더욱 합리화 하기 위한 개선 방안을 제시하되, 현행법 하에서 제도 운용을 달리함으로써 개선할 수 있는 방안과 노동위원회법 등 관련 법률을 개정하여 개선할 수 있는 방안을 각각 제시하고자 함.

I. 제도 운용상의 개선 방안

1. ‘패소사건 검토회의’ 내실화 또는 ‘상소 판단 전문위원회’ 구성

- 위에서 살펴본 바와 같이 중앙노동위원회 재심판정에 대한 소송이 1심 또는 2심 법원 단계에서 종결되지 않고 대법원까지 상고되어 패소하는 사례가 상당수 존재하는 것은 소송경제적 측면, 당사자의 권리구제 신속화의 측면에서 모두 바람직하지 못함.
- 따라서, 신청인이 하급심 법원의 판단에 불복하여 상소하는 경우를 제외한다 하더라도, 중앙노동위원회가 승소 가능성에 매우 낮음에도 불구하고 대법원에 기계적으로 상고하는 경우를 최소화하기 위한 방안을 강구할 필요가 있음.
 - 최근 중앙노동위원회가 법무지원과와 송무인력을 대폭 확충하고 있으나, 재심 유지율이 획기적으로 개선되지 않고 있음은 물론, 1심 판결과 2심 판결에서 일관된 법리가 적용되어 패소한 사건에 대해서도 대법원에 상고하여 패소하는 사례가 줄어들지 않고 있는 원인에 대한 근본적인 검토가 필요함.
 - 중앙노동위원회 차원에서 운영되는 것으로 알려진 ‘패소사건 검토회의’의 기능을 활성화하거나, 이를 외부 법률전문가가 포함된 “상소 판단 전문위원회”로 대체하여 각 심급의 소송 단계에서 상소 필요성 및 승소 가능성에 대한 사전 검토를 내실화할 필요가 있음.
- 중앙노동위원회 차원에서 운영되는 ‘상소 판단 전문위원회’가 실효성 있게 운영되기 위해서는, 중앙노동위원회가 법무부의 소송지휘를 받지 않도록 하여, 소송 수행 여부를 독자적으로 결정하도록 할 필요가 있음.
 - 앞에서 설명한 바와 같이, 중앙노동위원회는 여타의 행정심판 기구와는 구별되는 권리분쟁 해결 기능을 수행하고 있으므로, 법무부의 소송 지휘 대상에서 제외하는 것이 체계적으로 문제가 되지는 않는다고 판단됨.

2. 노동위원회 판정의 일관성 및 선례구속성 확대를 위한 “주요 사건 판정 사례집” 발간

- 대법원의 법관도 임기가 종료하면 교체되지만, 대법원 판결의 견해와 결과는 대법원의 견해라고 승인되고 있음. 그러나 중앙노동위원회 판정이 과연 중앙노동위원회의 견해라고 할 수 있을지에 관해서는 상당한 의문을 제기할 수밖에 없음.
- 상임위원 또는 비상임 공익위원의 성향이나 견해에 따라 판정이 달라지며, 사실상 중앙노동위원회의 이전 판정 결과가 선례로서 존중되지도 않고 있는 것이 현실이므로, 중앙노동위원회의 공식적이고 일관된 판정의 경향이 존재한다고 보기 어려운 상황임.
- 이러한 상황에서는 노동위원회에 권리구제를 신청하는 당사자들의 예측가능성을 충분히 확보할 수 없으며, 노동위원회의 일관된 판정 누적이 필수적으로 요구되는 법원 판례에 영향을 미쳐 판례 변경을 이끌어내는 효과를 기대하기 어려움.
- 따라서, 지노위 및 중앙노동위원회 판정 중 중요한 선례가 될 수 있는 판정문을 체계적으로 정리하고 그 법리를 분석한 평석이 첨부된 “주요 사건 판정 사례집”을 정기적으로 발간하여 서로 다른 공익위원으로 구성된 각 사건의 심판회의 구성원들이 선례를 참조하여 사건을 검토하고 판정을 내릴 수 있도록 할 필요가 있음.
 - 사례집 발간 뿐만 아니라, 조사관, 공익위원과 근로자위원·사용자위원 등에 대한 사례집 배포, 정기 교육을 실시하여 노동위원회가 노동위원회만의 일관된 판정의 경향을 구축하고 장차 노동위원회 판정이 법원의 판례에 버금가는 선례구속성과 영향력을 확보할 수 있도록 하여야 할 것임.
- 미국 전국노사관계위원회(NLRB)의 행정규칙 제정권을 활용한 판정 통제
 - 미국 전국노사관계위원회(NLRB)가 수행하는 대표적인 심판 기능인 부당노동행위 판정에 대해서는, 법원 판례와 달리 선례구속의 원칙이 인정되지 않고 있음.
 - 그러나, 미국 전국노사관계위원회는 판정의 일관성 확보를 위해 연방행정절차법⁵¹⁾에 따라 부여된 행정규칙 제정권⁵²⁾을 적극적으로 활용하여 연방 노동관계 법령의 해석에 관한 전국노사관계위원회의 해석 기준을 행정규칙으로 제정하여 공표하고 있음.

51) 5 U.S.C Chapter 5 (Administrative Procedure).

52) 5 U.S.C §551(5)(adjudication):(7)(rule making).

- 대표적인 사례가 연방공정노동법상 사용자 개념에 관한 공동사용자 법리를 밝히고 있는, 2020. 2. 25. 연방노사관계법상 공동사용자 지위(Joint Employer Status Under the National Labor Relations Act)에 관한 규칙(NATIONAL LABOR RELATIONS BOARD 29 CFR Part 103, Final rule) (시행: 2020. 4. 27.)임.⁵³⁾
- 노동위원회가 미국 전국노사관계위원회와 같이, 노동관련 법령의 특정 조항에 대한 해석 지침을 노동위원회 규칙으로 제정하여 준수하도록 하는 것은 현실적으로 가능성이 크지 않으므로, 그 대안으로서 공식적인 “주요 사건 판정 사례집” 정기 발간을 제안함.

3. 노동관련 전문 법무법인을 통한 소송 대리 확대와 내부 송무인력 전문성 강화

- 중앙노동위원회 법무지원과에는 다수의 송무인력이 배치되어 있으나, 소송 수행 이외에 각급 위원회 조사관 교육, 위원회 사무처리, 자료 작성 등 다양한 부수업무 수행이 요구되어, 소송 수행 전문인력으로 경험을 축적하고 고도의 소송 전략을 수립·실행할 것을 기대하기 어려움.
- 따라서, ① 노동위원회 내부 조직구조 개편을 통해, 송무담당 인력이 담당하는 부수업무를 대폭 축소하여 본연의 소송 수행에 집중할 수 있도록 하고, ② 전문 노동팀을 보유하고 있는 전문성 있는 외부 법무법인을 재심판정 취소소송 수행 대리인으로 선임하는 비중을 확대할 필요가 있음.
- 부수적으로, 외부 법무법인 노동소송 전문 변호사와 중앙노동위원회 내부 송무인력의 협업 과정에서 노동위원회 송무인력이 더욱 높은 수준의 소송 수행 역량을 습득할 수 있을 것으로 기대됨.

4. 소송 수행 과정에서의 피고보조참가인 측과의 협력 강화

- 중앙노동위원회가 피고가 되는 취소소송에서는 중앙노동위원회 재심판정의 신청인 또는 피신청인이 피고보조참가인으로 소송 과정에 참여하게 됨.
- 따라서, 소송 준비 과정에서부터 증거 준비, 서면 준비 등 모든 과정에 이르기까지 피고보조참가인과의 협력을 긴밀히 하여, 원고 측의 새로운 증거 제출, 새로운 사실관계 소명 등에 효과적으로 대응할 수 있도록 대비할 필요가 있음.

53) National Labor Relations Board(2020. 2. 25), “NLRB Issues Joint-Employer Final Rule,” Retrived on March 18th, 2020.

5. 화해를 통한 분쟁의 종국적 종결 확대

- 지노위 또는 중앙노동위원회 심판 절차에서 행해지는 화해의 가장 특징적인 효과는 노동위원회법 제16조의3 제5항에 따라 “재판상 화해”의 효력이 있어, 사건이 종국적으로 종결되는 결과를 얻을 수 있는 점이라고 할 수 있음.
- 따라서 지노위 또는 중앙노동위원회가 심판 절차에서 화해를 더욱 적극적으로 시도하여 화해 성립률을 높이는 것이 중앙노동위원회 재심판정에 대한 취소소송 제기 규모를 줄이는 효과적인 수단이 될 수 있을 것으로 기대됨.

6. 비상임 공익위원의 충원과 전문성 강화를 위한 중앙노동위원회 ‘서울 사무소’ 설치

- 모든 노동위원회에 전문성 있는 상임위원, 비상임 공익위원의 숫자를 충원하여야 하지만, 특히 중앙노동위원회가 세종시에 위치하고 있음으로 인해 상대적으로 풍부한 수도권 지역의 전문인력을 확보하지 못하는 문제가 있음.
- 따라서, 신청인과 피신청인의 주된 사무소 소재지가 모두 수도권에 위치할 경우 수도권에서 중앙노동위원회 심판회의를 개최할 수 있도록 서울사무소를 설치하여, 수도권 소재 노동법제 및 노사관계 전문가가 중앙노동위원회 공익위원으로 활동할 수 있는 기회를 확대하는 방안을 적극적으로 검토할 필요가 있음.

II. 법령 개정을 통한 개선 방안

1. 지방노동위원회 초심판정에 대한 ‘재심신청 허가제’ 도입

- 지노위 초심판정에 대한 당사자의 승복 가능성을 높이고, 당사자가 중앙노동위원회에 무분별하게 재심신청을 하는 것을 제한하기 위하여, 당사자가 중앙노동위원회에 재심신청을 하고자 하는 경우 지노위에 재심신청 허가를 신청하고, 지노위의 허가를 얻은 경우에만 중앙노동위원회에 재심을 신청할 수 있도록 하는 노동위원회법을 개정하는 방안을 검토할 필요가 있음.
- 재심신청 허가제는 중앙노동위원회에 지나치게 많은 재심신청이 제기되는 것을 제한하고, 중앙노동위원회가 중요한 사건에 집중하여 심리할 수 있도록 하는 효과를 기대할 수 있으며, 이를 통해 중앙노동위원회 재심판정에 대한 신뢰성이 확대되어 중앙노동위원회 재심판정이 취소소송을 통해 취소되는 경우를 줄일 수 있을 것임.

- 소송법상 상고허가제 도입 해외사례

- 소송법적으로는 독일이 민사재판에서 ‘상고 허가제’를 도입하여 운용하고 있는데, 독일에서 연방대법원에 상고하기 위해서는 항소심 법원이 판결을 통해 허가하거나 또는 상고심 법원이 상고불허가에 대한 불복을 받아들여 상고를 허가한 경우에 한하여 제기될 수 있음.⁵⁴⁾
- 일본의 경우는 최고재판소에 의한 상고수리 제도가 운용되고 있음.⁵⁵⁾
- 우리나라는 상고심절차에 관한 특례법⁵⁶⁾ 제4조에 따라서 대법원이 심리 불속행기각 판결을 내릴 수 있도록 허용하고 있음.

- 당사자가 지노위의 재심신청 허가신청 기각에도 불구하고, 초심판정에 불복하고자 하는 경우 곧바로 법원에 행정소송을 제기하는 것을 허용하는 방안을 검토할 수 있을 것임.

○ [지노위 초심판정에 대한 행정소송 제기 가능성] 현행 행정소송법⁵⁷⁾ 제18조는 “취소소송은 법령의 규정에 의하여 당해 처분에 대한 행정심판을 제기할 수 있는 경우에도 이를 거치지 아니하고 제기할 수 있다. 다만, 다른 법률에 당해 처분에 대한 행정심판의 재결을 거치지 아니하면 취소소송을 제기할 수 없다는 규정이 있는 때에는 그러하지 아니하다”라고 규정하여 1998. 3. 1. 이후⁵⁸⁾ 줄곧 행정심판에 대한 임의적 전치주의를 택하고 있음.

- 또한, 동법 제19조는 항고소송은 원칙적으로 원처분에 대하여 제기하도록 하되, 재결취소소송의 경우에는 재결 자체에 고유한 위법이 있음을 이유로 하는 경우에 한하고 있음.⁵⁹⁾

- 행정소송법 제18조의 규정 태도로 인하여, 지방노동위원회의 판정에 대하여 곧바로 취소소송을 제기할 수 있는지에 관하여 견해가 대립함.

- 취소소송 제기를 긍정하는 견해, 즉 중앙노동위원회 재심 절차를 임의절차라고 해석하여야 한다는 견해는 현행 법령의 해석과 지방노동위원회 판정의 조기 확정을 통한 법적 안정성 확보, 권리구제의 신속성 도모, 소송경제 등을 근거로 함.⁶⁰⁾
- 반드시 중앙노동위원회 재심 절차를 거쳐야 취소소송 제기가 가능하다고 보는 견해는, 노동위원회 제도 자체의 실효성이 훼손되며 노동문제를 전문

54) 이호원, ‘주요 국가의 상고 제한제도 ? 미국, 프랑스, 독일, 일본 제도를 중심으로 -’, 『인권과 정의(제460호)』, 2016, 30쪽 이하.

55) 이호원, ‘주요 국가의 상고 제한제도 ? 미국, 프랑스, 독일, 일본 제도를 중심으로 -’, 『인권과 정의(제460호)』, 2016, 32쪽.

56) 법률 제9816호, 2009. 11. 2. 시행.

57) 행정소송법(법률 제14839호, 2017. 7. 26. 시행).

58) 행정소송법(법률 제4770호, 1998. 3. 1. 시행).

59) 정하중, 『행정법개론』, 2007, 법문사, 741쪽.

60) 권창영, 『근로기준법상 이행강제금제도에 관한 연구』, 서울대 박사학위논문, 2008, 142쪽 이하.

적인 행정심판기구인 노동위원회에서 구제받도록 한 제도의 취지를 근거로 함.⁶¹⁾

- 현행 행정소송법과 노동위원회법의 문리해석에 따르면, 지방노동위원회의 처분(초심판정)에 대하여 반드시 중앙노동위원회의 재심을 거쳐야 행정소송을 제기할 수 있다고 해석되는 것은 아님. 그러나, 해석상 논란을 회피하기 위하여 지노위 초심판정에 대하여 곧바로 행정소송을 제기할 수 있도록 허용하기 위해서는 법률에 그것이 가능하다는 점을 명확히 규정하는 법개정이 선행되는 것이 가장 바람직함.

2. 부당해고, 부당노동행위, 차별시정 사건에 대한 노동위원회의 신청 전치주의 도입

- 현행법 하에서는, 대표적으로 부당해고를 당한 근로자를 가정할 경우를 상정하면, 법원에 해고무효 확인 소송을 제기하거나, 노동위원회에 부당해고 구제신청을 제기할 수 있어 다양한 권리구제 방법을 스스로 선택할 수 있음.
- 이는 노동위원회에 대한 권리구제신청이 여러 선택지 중 하나로서의 가치만 가진 것으로 인식되는 원인이 되고 있으며, 결과적으로 노동위원회의 초심판정과 재심판정의 내용과 권위에 대한 존중을 약화시켜, 재심판정에 대하여 불만이 있는 신청인 또는 피신청인인 당사자가 쉽게 취소소송을 제기하도록 조장하는 결과로 이어지고 있음.
- 따라서, 노동 관련 구제신청 사건에서 대표적인 사안인 부당해고, 부당노동행위, 차별시정 사건에 대해서는, 노동위원회에 구제신청을 하지 않으면 법원에 소송을 제기하지 못하도록 우선적 관할권 인정 또는 노동위원회 구제신청 전치주의를 도입하여, 노동위원회에 우선적인 관할권을 부여할 필요가 있음.

3. 중앙노동위원회 재심판정 취소소송 관할을 고등법원으로 조정

- 중앙노동위원회 재심판정에 관한 취소소송의 관할을 고등법원으로 격상·조정하는 방안을 적극적으로 검토할 필요가 있음.
- 이를 통해, 중앙노동위원회 재심판정에 대해서 사법부가 더욱 신중한 판단을 내릴 수 있도록 강제하는 한편, 노동분쟁이 사실상 5심 구조로 운용되는 결과 초래되는 소송 불경제와 장기간의 법적 안정성 침해 상황을 어느 정도 완화할 수 있을 것으로 기대됨.

61) 김선수, '노사갈등의 현황과 쟁점', 『전환기의 노사관계와 노동법, 한국노동법학회 창립 40주년 기념 학회 자료집』, 1998, 57쪽; 노동법실무연구회(이준상·김근홍 집필 부분), 『노동조합 및 노동관계조정법 주해(제2판)』, 2023, 박영사, 958쪽; 정하중, 『행정법개론』, 2007, 법문사, 742쪽; 서울행정법원 2021. 4. 29. 선고 2020구합87999 판결 등.

- 미국의 전국노사관계위원회(NLRB)가 행하는 교섭단위 확정에 대한 결정, 교섭 대표 선거 실시 등에 대해서는 연방법원에 대한 취소소송 제기가 허용되지 않으며, 부당노동행위 구제명령에 대해서 불복할 경우 연방고등법원에 소송을 제기할 수 있도록 하고 있음.⁶²⁾

62) 김미영, '미국 연방노동관계법 부당노동행위제도의 형성과 발전', 『강원법학(제38권)』, 2013, 257쪽.

제5장 주요 쟁점별 법리 검토

- 이 장에서는 노동위원회 주요 패소 사례에서 쟁점이 되었던 사항에 대하여 그 핵심적인 내용을 간략히 정리하여 제시하고자 함.

1. 노동위원회 조사관의 실질적 조사권의 의미와 개선 방안

(1) 불완전한 직권심리주의

- 노동위원회 심리구조는 기본적으로 당사자주의와 함께 직권심리주의를 택하고 있으며⁶³⁾, 그 근거는 행정심판법 제39조 및 제36조, 근로기준법 제29조와 노동위원회법상의 ‘조사관’ 제도이지만, 직권심리주의가 완전히 관철되고 있다고 보기 어려움.

근로기준법 제29조(조사 등)

- ① 노동위원회는 제28조에 따른 구제신청을 받으면 지체 없이 필요한 조사를 하여야 하며 관계 당사자를 심문하여야 한다.

노동위원회법 제23조(위원회의 조사권 등)

- ① 노동위원회는 제2조의2에 따른 소관 사무(제3호의 업무는 제외한다)와 관련하여 사실관계를 확인하는 등 그 사무집행을 위하여 필요하다고 인정할 때에는 근로자, 노동조합, 사용자, 사용자단체, 그 밖의 관계인에 대하여 출석·보고·진술 또는 필요한 서류의 제출을 요구하거나 위원장 또는 부문별 위원회의 위원장이 지명한 위원 또는 조사관으로 하여금 사업 또는 사업장의 업무상황, 서류, 그 밖의 물건을 조사하게 할 수 있다.

행정심판법 제36조(증거조사)

- ① 위원회는 사건을 심리하기 위하여 필요하면 직권으로 또는 당사자의 신청에 의하여 다음 각 호의 방법에 따라 증거조사를 할 수 있다.
1. 당사자나 관계인(관계 행정기관 소속 공무원을 포함한다. 이하 같다)을 위원회의 회의에 출석하게 하여 신문(訊問)하는 방법
 2. 당사자나 관계인이 가지고 있는 문서·장부·물건 또는 그 밖의 증거자료의 제출을 요구하고 영치(領置)하는 방법
 3. 특별한 학식과 경험을 가진 제3자에게 감정을 요구하는 방법
 4. 당사자 또는 관계인의 주소·거소·사업장이나 그 밖의 필요한 장소에 출입하여 당사자 또는 관계인에게 질문하거나 서류·물건 등을 조사·검증하는 방법

행정심판법 제39조(직권심리)

- 위원회는 필요하면 당사자가 주장하지 아니한 사실에 대하여도 심리할 수 있다.

63) 서울행법 2012. 9. 25. 선고 2012구합2474 판결, 서울고법 2013. 6. 14. 선고 2012누32446 판결.

- 노동위원회는 일반 행정심판기구가 처분청인 행정청의 상급기관이나 감독기관으로서 직접적인 통제권을 행사하는 경우가 많은 것에 비하여, 신청인이나 피신청인에 대하여 구속력 있는 명령을 발하거나 수사·조사할 수 있는 권한이 약하여 노동위원회 조사관의 조사권은 현실적으로 상당히 제약되어 있음.
- 노동위원회 조사관의 조사권한 제약의 원인은 ① 법령상 조사관의 조사권한과 구제신청 당사자에 대한 구속력에 관한 규정의 모호성, ② 각급 위원회 조사관의 숫자 부족, ③ 조사관 각 개인에 대한 과도한 사건 배정, ④ 사건처리 기한의 제약 등 다양한 원인에 기인하는 것으로 판단됨.
- 이는 미국의 전국노사관계위원회(NLRB)가 부당노동행위 분쟁과 관련한 판정 권한 행사와 관련하여 독점적인 행정 수사(administrative investigation)에 관한 권한을 부여받고 있으며, 적어도 부당노동행위 사건에 관한 한 연방과 주 정부의 다른 행정기관 또는 경찰기관의 개입을 배제할 수 있다는 점에서 구별됨.⁶⁴⁾
- ※ 미국 전국노사관계위원회(NLRB)의 수사권은 법무총장(General Counsel)의 지휘를 받는 전국노사관계위원회 소속 감독관이 행사함.

(2) 조사관의 실질적 심사권한 확충 필요

- 법원이 중앙노동위원회가 조사하여 인정한 사실관계의 내용 및 그 의미에 대한 판단이 잘못되었다는 것을 이유로 재심판정을 취소하는 것은, 많은 경우 노동위원회 심판 단계에서 조사관 및 공익위원, 노·사위원의 사실관계 조사 및 심리가 미진했다는 것을 나타낸다고 볼 수 있음.
- 특히, 구제신청 접수 초기부터 사실관계 조사를 담당하는 조사관의 조사가 정확하지 못했다는 비판을 피하기 어려움.
- 이는 조사관의 조사권한을 근로감독관의 수사권한에 준할 정도로 강화하고, 조사관 1인이 담당하는 배정 사건 수를 제한함으로써 더욱 정확한 조사에 임할 수 있도록 하는 등의 대책이 필요하다고 판단됨.

64) 김미영, '미국 연방노동관계법 부당노동행위제도의 형성과 발전', 『강원법학(제38권)』, 2013, 257쪽; 박은정, '미국·일본·한국 노동위원회제도에 대한 연혁적 고찰', 『노동법학(제61호)』, 2017, 92쪽.

2. 근로자성 판단 관련 법리

(1) 노동조합법상 근로자 개념

- 노동조합법상 근로자 : 직업의 종류를 불문하고 임금·급료 기타 이에 준하는 수입에 의하여 생활하는 자
- 근로기준법상 근로자 : 직업의 종류와 관계 없이 임금을 목적으로 사업이나 사업장에 근로를 제공하는 자(근기법§2-1)
- 양 근로자 개념의 관계(대법원 2001두8568)
 - ① 근로기준법은 현실적으로 근로를 제공하는 자에 대하여 국가의 관리·감독에 의한 직접적인 보호의 필요성이 있는가 라는 관점에서 개별적 노사관계를 규율할 목적으로 제정된 것
 - ② 노동조합법은 노무공급자들 사이의 단결권 등을 보장해 줄 필요성이 있는가라는 관점에서 집단적 노사관계를 규율할 목적으로 제정된 것
 - ※ 실업 중인 자나 구직 중인 자 포함(대법원[전] 2007두4995), 골프장 캐디의 근로자성 인정(대법원 2011다78804)

(2) 종속성 개념

- 인(격)적 종속성 : 근기법상의 근로자와 노동조합법상의 근로자를 구별하는 기준
- 경제적 종속성 : 노동조합법상의 근로자와 자영업자를 구별하는 기준

노동조합법상 근로자성 판단기준 - 학습지교사 판례 (대법원 2018. 6. 15. 선고 2014두12598, 12604 판결)	
노무제공자의 소득이 특정 사업자에게 주로 의존하는지	• 학습지교사는 겸업이 현실적으로 어려워, 회사로부터 받는 수수료가 학습지교사들의 주된 소득원
노무를 제공받는 특정 사업자가 보수·계약 내용을 일방적으로 결정하는지	• 회사가 학습지교사의 계약, 보수를 일방적으로 결정
노무제공자가 특정 사업자의 사업수행에 필수적인 노무를 제공함으로써 그 사업을 통해 시장에 접근하는지	• 학습지교사가 제공한 노무는 학습지 사업에 필수적이고, 학습지교사는 회사의 사업을 통해 학습지 개발 및 학습지 회원에 대한 관리·교육 등에 관한 시장에 접근
노무제공자와 특정 사업자의 법률관계가 상당한 정도로 지속적·전속적인지	• 학습지교사는 회사와 지속적으로 계약 체결(1년 단위로 위탁계약체결, 계약기간 자동연장), 상당한 정도로 전속적

어느 정도 지휘·감독관계가 존재하는지	• 신규 학습지교사를 상대로 입사실무교육 실시, 특정 단위 조직에 배정한 후 관리회원 배정·업무처리지침 존재, 학습지도서 제작·배부하고 표준필수업무 시달, 2~3달에 1회 집필시험·매월 말 지국장에게 회원리스트, 회비납부 여부 등 자료 제출하고, 정기적으로 홈페이지에 로그인하여 진도상황과 진단평가결과 및 회비수납상황등 입력·학습지교사에게 일정한 지시를 하고, 주3회 오전에 지국장주재 조회와 능력향상과정 참여 의무
특정사업자로부터 받는 임금·급료등 수입이 노무제공의 대가인지	• 학습지교사들은 자신이 제공한 노무에 대한 대가명목으로 수수료 지급받음

(3) 사용자 개념의 확대 주요 쟁점

○ 하나의 사업 또는 사업장의 범위

- ① 하청근로자는 원청회사의 영역 내에서 근로를 제공하므로, 하청회사와 원청회사는 ‘하나의 사업 또는 사업장’이라고 보는 견해
→ 원청은 하청 회사와 같은 교섭단위 내에 있으므로 하청노조와의 교섭의무가 있지만, 창구단일화를 해야 한다는 결론
- ② 하청회사와 원청회사는 서로 다른 사업이므로 ‘하나의 사업 또는 사업장’이 아니라고 보는 견해
→ 원청은 하청노조와의 교섭의무가 없으며, 개별적으로 교섭의무가 인정되더라도 창구단일화의 대상이 아님

(4) 단체교섭권의 주체와 상대방

- 단체교섭권의 주체 : 노동조합 대표자(노동조합법 §29-①)
※ 복수노조의 경우에는 교섭대표노조의 대표자
- 단체교섭의 상대방 : 근로조건 결정권이 있는 사용자
- 사용자의 개념에 관한 견해 대립
 - 실질적 지배력설 : 학계의 다수설, 일본 아사히방송판결, 일부 대법원 판례(대법원 2014두12598·12604; 대법원 2015두38092; 대법원 2016두41361; 대법원 2019두33712 등).
 - 공동사용자개념 인정설

- 근로계약관계 필요설: 명시적묵시적 근로계약관계 필요, 일부 대법원 판례(대법원 69누152; 대법원 90누9438; 대법원 95누3565; 대법원 97누3644; 대법원 96누1504; 대법원 2005다39136; 대법원 2005다64385; 대법원 2015도1927 등).

(5) 부당노동행위의 주체로서의 사용자

○ 부당노동행위 금지명령의 수범자로서의 사용자

- 원칙 : 노동조합법상의 사용자(노동조합법 §2)
- 근로계약관계 필요설 : 근로계약관계가 있는 사용자만 부당노동행위의 주체가 될 수 있다고 보는 견해
- 실질적 지배력설 : 사용자 개념의 외연을 확대하여, 근로관계에 미치는 실질적인 영향력 내지 지배력을 보유한 주체는 부당노동행위 금지명령의 수범자로서의 사용자에 해당한다고 보는 견해
 - ※ 부당노동행위 금지명령의 수범자로서의 사용자와 구제명령의 수범자로서의 사용자를 동일시

○ 부당노동행위 구제명령의 수범자로서의 사용자

- 사업주인 사용자에게 국한하는 견해 : 사업주만이 부당노동행위 원상회복이 가능하므로
- 부당노동행위 금지명령의 수범자와 동일시 하는 견해 : 근로계약관계 필요설, 실질적 지배력설

○○통운 사건 (중노위2021. 6. 2. 판정 중앙2021부노14)
<판정 요지> [1] 근로자와 사용종속적 노무제공계약을 직접 체결한 원사업주뿐만 아니라, 원사업주가 아닌 사업주라 할지라도 원사업주 소속 근로자의 기본적인 노동조건 등에 관하여 일정 부분 실질적이고 구체적으로 지배·결정할 수 있는 지위에 있는 자는 노동조합법상 단체교섭 의무를 부담하는 사용자로 인정됨. ○○통운은 비록 이 사건 대리점 택배기사의 원사업주는 아니지만, 이 사건 노동조합이 요구한 6개 교섭의제에 대해 실질적이고 구체적인 지배·결정권을 가지고 있다고 판단되므로, ○○통운은 노동조합법상 단체교섭 의무를 부담하는 사용자에 해당함.

- [2] ○○통운은 이 사건 노동조합에 대해 노동조합법상 단체교섭 의무를 부담하는 사용자에 해당하고, ○○통운이 노동조합법상 사용자가 아니라는 이유로 이 사건 노동조합의 교섭요구에 응하지 아니하고 그 사실을 공고하지 않은 것은 단체교섭 거부의 부당노동행위에 해당하며, ○○통운은 노사의 자율적 선택에 따라 단독 내지 대리점주와 공동으로 이 사건 노동조합의 교섭요구에 성실히 응해야 함.
- [3] ○○통운이 전국택배노조의 단체교섭 요구를 거부한 것은 부당노동행위에 해당함. 노동조합법상 사용자가 단체교섭 의무를 부담하는 상대방은 사용자와 명시적·묵시적 근로계약을 맺은 근로자뿐만이 아님. 원·하청 등 간접고용 관계에서 원청사용자가 하청 근로자의 노동조건에 실질적인 권한을 행사하는 일정 부분에 대해서는 원청사용자의 단체교섭 당사자 지위를 인정할 수 있음. 대리점 택배기사는 ○○통운의 택배서비스 사업시스템에 편입돼 있고, 사업 수행에 필수적 노무를 제공하고 있어 ○○통운은 이들에 대한 구조적 지배력과 영향력을 갖고 있음.

3. 채용내정, 시용, 수습 관련 법리

(1) 채용내정

- 사용자가 노동력을 미리 확보하기 위하여 일정한 요건이 충족 되면 채용할 것을 약정하는 근로계약관계(해약권유보)
 - ※ 졸업예정자의 졸업, 해외 유학 중인 자의 학위취득 요구 등
- 요건 충족에도 불구하고 사용자가 본채용을 거부할 경우 해고와 동일하게 취급하여 근로기준법 제23조에 따른 정당성을 판단
- 채용 확정 통지시 통지된 발령 예정일 이후에 채용내정을 취소할 경우 사용자는 임금을 지급할 의무를 부담

(대법원 2000다51476)

회사가 1997. 11월경 원고들에게 최종 합격통보를 해 줌으로써 원고들과 회사 사이에 근로계약관계가 유효하게 성립되어 늦어도 입사지정일인 1998. 4. 6 이후에는 원고들이 회사의 근로자가 되었다고 할 것이므로 그 후 회사가 원고들에게 한 신규채용의 취소 통보는 실질적으로 해고에 해당함

(2) 수습계약

- 정식 근로계약. 단 채용된 근로자의 직업능력 양성·교육을 위한 기간을 설정하는 계약

(3) 시용계약

- 정식 근로계약 체결의 전제로 직업능력과 기업 적응성 등을 판단하기 위한 기간을 설정하는 계약
 - ※ 시용계약인지 수습계약인지 여부는 계약서상 명칭이 아닌 실제 체결된 계약의 내용을 중심으로 판단해야
- 시용(근로)계약의 법적성질
 - 해지권유보부근로계약 : 정식 근로계약이지만 직업능력이 부족하거나 기업 적응성이 부족하다고 판단될 경우 본채용을 거절할 수 있다는 의미에서 사용자에게 해지권이 유보된 것 (대법원 98두5965 등)

- 기타 학설 : 정지조건부 근로계약설, 해제조건부 근로계약설 등

○ 시용(근로)계약의 유효요건

- 기간 : 근로자의 직업능력이나 기업 적응성 판단에 필요한 합리적인 기간으로 한정 (통상 3개월 ~ 12개월)
- 근거 : 근로계약, 취업규칙 등에 명문의 근거 필요

○ 본채용 거부의 법적 성격 : 해고

- 본채용 거부는 근로기준법 제23조 제1항의 해고와 동일하므로, '정당한 이유'필요
- '정당한 이유'는 일반해고보다 넓게 인정되지만, 객관적으로 합리적인 이유가 존재하여야 함 (대법원 92다44695; 대법원 2003다50580)

시용계약 기간 중의 업무상 재해와 해고 시기 제한 (대법원 2021. 4. 29. 선고 2018두00000 판결)	
<사건 개요> ○ 근로자와 사용자는 근로자의 적성·자질·능력·적응도 등을 평가하여 채용 여부를 판정한다는 내용의 수습계약을 최대 3개월의 기간으로 체결했음. ○ 이 근로자가 시용기간 중인 2015년 12월 10일에 사무실 이전을 위해 사무실 서랍장을 들어 옮기다가 허리를 다치는 부상을 입었음. 이 근로자는 사고 당일 병원에 입원했다가 퇴원했는데, 병원에서 “부분취업 치료 가능”이라는 의사 소견서를 받았음. ○ 이 근로자가 계속 출근하면서 통원치료를 받던 중에 회사는 이 근로자를 물건을 들지 않아도 되는 조립실로 배치전환을 함. 그리고 시용계약의 마지막 기한이 도래한 2016년 1월 4일에 근무평가를 실시하여, 근무평가 결과 시용계약에서 정한 기한이 10일 정도 도과한 이후인 2016년 1월 14일에 본채용 거부 통보를 함	
	판정(결) 주요 내용
지노위	본채용 거부의 합리적 이유 없음 → 부당해고 (2016. 6. 1)
중앙노동위원회	초심 유지 (2016. 9. 26)
서울행정법원	중앙노동위원회 재심판정 취소 → 본채용 거부의 합리성 인정 → 해고 정당성 인정 (2017. 9. 7)
서울고등법원	항소 기각 → 본채용 거부의 합리성 인정 → 근로자측이 새롭게 제기한 해고 시기 제한 규정 위반 주장 기각→해고 정당성 인정(2018. 4. 6)
대법원	파기 환송 → 해고 시기 제한 규정 위반 인정 → 부당해고 (2021. 4. 29)

<판결 요지>

- [1] 근로기준법 제23조 제2항은, 사용자는 근로자가 업무상 부상 또는 질병의 요양을 위하여 휴업한 기간과 그 후 30일 동안은 해고하지 못한다고 규정하여 해고를 제한하고 있다. 이는 근로자가 업무상의 재해로 인하여 노동력을 상실하고 있는 기간과 노동력을 회복하는데 필요한 그 후의 30일간은 근로자를 실직의 위협으로부터 절대적으로 보호하기 위한 것이다.
- [2] 이와 같은 규정의 내용과 입법 목적에 비추어 보면, 요양을 위하여 필요한 휴업에는 정상적인 노동력을 상실하여 출근을 전혀 할 수 없는 경우뿐만 아니라, 노동력을 일부 상실하여 정상적인 노동력으로 근로를 제공하기 곤란한 상태에서 치료 등 요양을 계속하면서 부분적으로 근로를 제공하는 부분 휴업도 포함된다. 이 경우 요양을 위하여 휴업이 필요한지는 업무상 부상 등의 정도, 치료 과정 및 치료 방법, 업무의 내용과 강도, 근로자의 용태 등 객관적인 사정을 종합하여 판단하여야 한다.
- [3] 위와 같이 근로자의 노동력 회복을 도모하고 생계를 유지하도록 일정 기간 해고를 절대적으로 제한하는 근로기준법 제23조 제2항의 내용과 취지 및 판단 기준 등에 비추어 볼 때, 업무상 재해를 입은 근로자를 보호하기 위한 해고 제한의 필요성은 시용(시용) 근로자에 대하여도 동일하게 인정되므로, 시용 근로관계에 있는 근로자가 업무상 부상 등으로 요양이 필요한 휴업 기간 중에는 사용자가 시용 근로자를 해고하거나 본계약 체결을 거부하지 못한다.

4. 인사평가, 배치전환 관련 법리

(1) 인사권

○ 인사권의 개념

- 근로자의 채용, 배치, 이동, 인사고과, 승진, 징계, 해고 등 사업 또는 사업장 내에서 근로자의 지위 변동이나 처우에 관계되는 사용자의 경영상 결정권한
- 근로제공 과정에서의 지휘명령권을 인사권에 포함시키는 경우도 있으나, 일반적으로는 포함시키지 않는 것이 일반적

○ 인사권의 범주 : 평가권, 배치전환권(인사이동), 징계권

- 근로기준법에는 인사권에 관한 근거 규정이 없으며, 제23조 제1항을 준용
- 인사권은 사용자의 고유한 권한이라는 인식이 강했지만, 최근에는 점차 근로자들의 참여와 통제가 필요하다는 관점이 확대

○ 인사권 행사의 주체 : 사용자 → 재량의 영역이지만 남용할 수 없음(인사경영권)

- 근무평가가 해고규제 회피, 퇴직 종용 수단이 되는 등 법질서에 반하거나 공정성을 현저히 위배한 경우 사법심사의 대상
- 근로기준법 제23조의 “정당한 이유” 필요

○ 인사권 행사의 목적 : 직무 수행 능력, 방법, 성과, 발전가능성 평가

- 평가 대상자 측면 → 평가 대상자의 업무수행 능력 및 방법의 적정성을 평가
→ 평가 대상자의 개선방안 모색
- 조직 측면 → 평가 대상자에게 제시한 목표 및 업무수행 방법의 적정성 평가
→ 향후 평가 대상자에게 제시할 목표와 지원 방안 마련
→ 조직 전체의 사업목표와 추진계획 마련
- 해고나 재계약 거절만을 목적으로 하는 평가는 정당성 부정

(2) 인사평가

○ 평가 방법의 공정성·합리성

- 상대평가와 절대평가 → 상대평가 : 평가대상자들의 서로 비교하여 평가
→ 절대평가 : 절대적 기준에 따라 개별 대상자를 평가
- 절대평가가 합리성을 인정받기 쉬우나, 평가내용·항목 등이 합리적으로 설계되고, 기준·절차가 투명하게 평가가 지속되는 경우 상대평가라도 합리성을 인정받을 수 있음
- 상대평가의 경우에도 최하 등급을 임의분포(강제배당×)로 하는 등 절대평가 방식으로 보완한 경우 합리성 인정받을 여지 큼
- 상대평가를 통해 최하위 등급을 받은 사실만으로 곧바로 업무 수행 능력이 현저히 부족하다고 판단해서는 안 되며 다른 정당성 요소들 종합적으로 고려하여야 함

(서울행법2003구합39306)

평가등급을 S · A · B · C 4등급으로 나누고 S, A, B등급에 대해서는 일정비율을 할당하였지만 C등급의 경우 절대평가에 따른 임의분포 방식이었고, 실제로 2회 연속 C등급을 받은 근로자를 대상으로 선정한 것은 정당함(MBC 조연출 사건)

(서울행법2005구합23879)

업무평가등급을 S(상위 10%) · A · B · C · D(하위 10%) 의 5개로 분류하여 상대평가에 따라 최하등급(D)에 일정 비율의 인원을 할당한 경우, 4회 연속 최하위 등급(D)을 받았다는 것만으로 저성과자라고 볼 수는 없음

- 계량평가와 비계량평가(=정량평가와 정성평가)

- 생산량, 영업실적, 업무능력 등 성과가 객관적 수치로 표현될 수 있을 경우에는 계량평가가 합리성을 인정받기 쉽지만, 비계량적 평가가 포함되어 있다고 하여 반드시 불합리한 것은 아님
- ※ 업무능력을 포함한 대부분의 성과평가에는 기업조직에의 융화 정도 등 수치로 계량할 수 없는 주관적 평가척도가 포함되어 있으므로, 일부 평가 항목에 주관적 판단 기준이 포함되어 있다는 이유만으로 평가방법이 부당하다고 단정할 수 없음

(서울남부지법 2009가합21769)

영업직원에 대한 평가에 있어, 영업실적이 19%에 불과하고, 다면평가 40%, 인사평점 40%를 반영한 것은 불합리함

- 평가기간의 지속성

- 평가가 장기간 동안 꾸준히 이루어지고 평가 자료가 해당 기간 동안 충분히 축적되어 있는 경우 평가 결과의 객관성을 인정받기 용이

(서울행법99구10178)

4년여 기간 동안 근무하면서 상사 및 동료 직원들과 마찰을 일으켰을 뿐만 아니라, 직무 수행 능력이 부족하여 담당업무를 변경하는 등 불량한 근무태도로 대기발령한 것은 정당 (하나로클럽사건)

- 중복평가 : 평가자의 수

- 수직 또는 수평 관계에 있는 다수의 평가자가 동시 또는 순차적으로 피평가자에 대해 평가하는 경우 평가의 공정성과 객관성을 인정받을 수 있는 가능성이 높아짐

- 중복평가 : 평가자와의 거리

- 평가자와 피평가자 사이의 거리(밀접도)
- 중복평가 시스템 하에서 평가자들 사이의 평가 결과의 격차가 큰 경우 접근도가 높은 평정자들의 평가가 우선

- 평가기준의 직무관련성

- 평가기준은 사업 또는 사업장 내에 존재하는 업종이나 직무의 종류에 따라 평가 대상자가 수행하는 업종 또는 직무의 특성을 반영하여 다양하고 구체적으로 마련되어 있어야 함

(서울남부지법 2009가합21769)

국책연구원의 연구원이 국민의례 거부를 이유로 원고의 근무실적이 우수하지 못하다고 본 데에는 합리적인 이유가 있다고 보기 어려움

○ 업무능력 향상을 위한 교육훈련 기회 제공

- 업무와 직접 연관된 적절하고 명확한 교육목표와 프로그램 제시
- 정당한 관리자에 의한 프로그램 운영과 평가, 점검
- 취업규칙 또는 단체협약에 업무능력 향상 프로그램 대상자 선정 기준과 절차, 내용 등에 대한 근거규정 설치 필요
 - ※ 성과평가제도가 곧바로 근로조건이 되는 것은 아니지만 평가제도 도입이나 변경이 근로조건 변경을 직접적으로 초래하게 되는 경우 취업규칙 작성 및 변경과 관련된 절차를 거쳐야 함

(대법원 2010두15964)

근로자가 10년 넘게 수도사업관리소 시설관리과에서 근무하였는데, 5개월이 채 안 되는 기간을 부여하고, 실제 근무하고 있던 분야와 무관한 소방설비기사 자격증을 취득하도록 하여, 이후 실패를 이유로 직권면직한 것은 부당함

○ 의견 개선 기회 제공

- 평가과정 및 평가 결과 조치 시 의견 개선 기회를 제공하고 이를 반영하여야 함
- 이의 제기 기회 제공 절차가 마련되어 있지 않았다는 것이 곧바로 평가절차의 정당성을 부정할 수 있는 이유는 아님
- 그러나 이의제기 절차를 두고 피평가자에게 소명기회를 제공한 경우 평가결과 의 타당성과 신뢰성이 인정될 가능성이 높아짐
- 역량과 적성에 부합하는 업무로의 배치전환 요청을 거부하는 것도 의견 개선 기회 미부여로 판단

(대법원 2006두18287)

감리업무에 종사하는 근로자가 기술적인 업무능력과 전문성 등은 있으나 대인관계상의 문제로 고객사인 시공사와 잦은 업무상 마찰을 빚어, 근로자가 회사에 다른 부서로 전보발령 해 줄 것을 요청했으나 회사가 이를 거절하고 특별한 업무를 부여하지 않으면서 인사고과 결과 최하위등급을 받은 것을 이유로 해고했다면 그 해고처분은 정당성이 없음

(3) 배치전환

○ 배치전환의 개념

- 배치전환의 의의 : 근로자의 직무내용, 직급 또는 근무장소가 동일한 기업 내에서 상당히 장기간 또는 영구적으로 변경되는 것
 - ※ 근로자가 원 소속 기업 근로자의 신분을 유지하면서 다른 기업 사용자의 지휘·감독을 받아 근로를 제공하는 전출과, 원래 기업과의 고용관계를 단절하고 새로운 기업으로 소속을 변경하는 전직 등과 구별

○ 배치전환과 근로자의 동의

- ① 근로계약서에 근로제공 장소가 명시된 경우
- ② 근로계약에 업무 내용이 명백히 기재되어 있는 경우
- ③ 의사·간호사·기사 등과 같이 특수한 자격·기술이 필요한 경우
→ 배치전환시 대상 근로자의 동의 필요
- 인사이동의 업무상 필요성과 정당한 이유가 있다고 판단될 경우 동의 생략 가능

○ 배치전환에 대한 제한

- 사용자의 재량
 - 근로계약 당사자 사이에 직무내용이나 근로장소에 대한 특약이 없다면 사용자는 인사권에 기하여 근로자에게 배치전환명령을 내릴 수 있음
- 근로기준법 §23-①에 의한 제한
 - 종전의 업무범위를 현저히 벗어나 장기적으로 근로제공의무의 내용에 영향을 미치는 인사조치의 경우
 - 근로기준법 §23-①의 “정당한 이유” 요구 → 사회통념의 관점에서의 일반적·객관적 정당성 필요
 - ※노동위원회에 대한 부당징계구제신청 절차를 통한 구제 가능
- 권리남용 금지 법리에 의한 제한
 - 통상적인 인사조치로서의 배치전환의 경우

- 사용자의 재량권이 공정하게 행사되었는지 심사 : 업무상 필요성, 근로자의 개별적 사정 이익교량
 - ※ 배치전환명령의 무효 확인, 손해배상청구 등을 목적으로 하는 민사소송 절차를 통한 구제 가능. 다만, 위법한 배치전환명령에 따르지 않아 징계를 당한 경우 노동위원회 부당징계구제절차 활용 가능
- 배치전환의 제한에 관한 판례의 태도
 - 근로기준법 §23-①의 “전직” 규정을 근거로 배치전환의 경우에도 해고와 마찬가지로 ‘정당한 이유’가 필요하다고 하면서, 정당한 이유의 판단기준으로 ① 배치전환의 필요성, ② 대상 근로자에게 미치는 생활상 불이익, ③ 절차적 정당성 등을 심사
 - 배치전환의 필요성 : 근로자의 적합 직무 부여를 위한 정당한 평가에 따른 배치전환은 목적의 정당성 인정 가능
 - ※ 근무 장소를 합의하여 근로계약에 명시한 경우 근로자의 동의 필요
 - 생활상 불이익 : 배치전환(인사이동)으로 인해 초래되는 근로자의 생활상의 불리함이 업무상 필요성과 비교형량하여 사회통념상 과도하다고 판단되면 근로자의 동의가 없는 배치전환의 정당성이 상실됨 (∴ 권리남용)
 - ※ 배치전환으로 인한 임금 감소, 가족간 별거, 환자·노인·자녀 돌봄 어려움 초래 등
 - 절차적 정당성 : 단체협약, 취업규칙 등에 인사발령의 절차(협의, 통보 등)를 규정하고 있다면 이를 준수해야 하나 이 절차를 거치지 않은 배치전환이 곧바로 무효가 되는 것은 아님
- 배치전환과 징계의 구별
 - 기업활동을 계속적으로 유지하기 위하여 노동력 재배치와 수급조절의 필요성에 따라 발령한 인사명령이라면 징계처분이 아닌 배치전환으로 판단

(4) 강등의 문제

○ 낮은 직위로의 강등 조치의 정당성

- 강등 조치의 효과 : 직책수당 미지급, 급여 삭감, 담당 업무 · 권한 축소 등

- 강등조치의 근거 : 취업규칙, 단체협약 등에 정한 절차에 따라야 함
- 강등조치가 징계인 경우 : 징계의 정당성 요건 충족 필요
- 징계 아닌 통상적인 인사조치인 경우 : 징계의 절차적 정당성 요건 불필요

○ 강등 조치의 정당성 판단

- 정당한 인사평가 전제
- 강등조치의 정당한 목적과 필요성
- 근로자의 생활상 불이익

(서울행법 2021구합00000)

- 업무능률 증진, 경제적 수익성 제고 등과 같이 추상적, 일반적인 경영상 필요성이 인정된다 하더라도, 이를 이유로 한 모든 형태의 전직처분이 정당화되는 것은 아니고, 해당 전직처분이 실제로 그와 같은 목적을 달성하기 위한 적합한 수단이어야 업무상 필요에 따른 정당한 인사권의 행사라고 평가할 수 있음
- 비록 참가인이 감급된 것은 아니지만 팀장에서 팀원으로 변경됨으로 인하여 실질적으로 강등된 것과 같은 지위의 변경이 있게 되었음 팀장은 팀원에게 지시를 할 수 있는 위치에 있게 되고, 월 60만 원의 직책급업무추진비를 받게 되는 이익이 있음. 그런데 팀장의 지위를 상실하게 되면서 위 업무추진비도 받지 못하게 되었고, 팀장 직위에 있음으로 인해 얻게 될 자긍심이나 리더십을 발휘할 기회 모두 박탈당하게 되었음. 비록 참가인이 팀원이 됨으로 인하여 시간외 근무수당 등을 지급받을 수 있게 되었다고 하더라도, 이는 추가적인 근로에 대한 대가이므로 설령 그 수당 등이 업무추진비를 초과할 수 있다고 하더라도 이를 가지고 참가인에게 불이익이 발생하지 않은 것이라고 볼 수는 없음. 따라서 참가인은 이 사건 인사 명령으로 인하여 유무형의 생활상 불이익을 받았다고 봄이 타당함
- 조직변경으로 인하여 팀장에서 팀원이 된 사람은 오로지 참가인뿐임. 따라서 회사로서는 이와 같이 유독 참가인에게만 불이익한 조치를 하면서 참가인의 의견을 청취하고, 이를 반영하기 위한 노력을 기울였어야 할 신의칙상 필요가 있고, 이러한 절차 진행이 원고에게 큰 부담이 되었을 것으로도 보이지 않음. 이는 원고의 조치가 합리성에 기초한 조치가 아니라 감정적 조치일 가능성이 높음을 방증한다고 볼 수 있음

5. 징계의 정당성 관련 법리

(1) 징계해고의 제한

- 근로기준법 제23조는 “정당한 이유” 없는 징계해고를 금지
- 징계해고를 금지한다고 보는 이유 : “... 그 밖의 징벌”
 - 근로기준법 제23조에 규정된 “해고, 휴직, 정직, 전직, 감봉 등이 징벌의 수단으로 사용된 것으로 해석
- 근로기준법 제23조의 “정당한 이유” 요건은 그 밖의 근로관계 종료 사유에 폭넓게 준용

(2) 징계(해고)의 “정당한 이유” 판단 요건

- 사유의 정당성 : 해고 사유의 정당성, 주로 행태상의 해고인 경우
- 절차의 정당성 : 징계위원회 등 개최 여부(소명기회 제공), 예고절차 준수, 서면통보 등의 절차
 - ※ 징계위원회, 인사위원회 등은 취업규칙, 단체협약 등에 규정이 있을 경우 요구
- 양정의 정당성 : 근로자의 비위사실이 해고를 할 정도에 이르는가의 판단

(3) 징계사유 결정 권한

- 사용자의 고유권(지시권)이라고 보는 견해
- 노사간의 합의(계약, 단체협약 등)가 필요하다고 보는 견해

(4) 취업규칙상 징계사유와 단체협약상 징계사유의 관계

- 조합원에 대한 해고 사유는 단체협약에 정한 사유에 한한다는 노사 합의 : 유효
- 단체협약에 없는 취업규칙상의 사유에 의한 해고를 금지하는 노사 합의 : 유효
- 별도 합의 없는 경우 단체협약상 사유 이외의 징계사유를 취업규칙에 정하는 것 : 유효
 - ※ 고유권설

6. 직장 내 괴롭힘 판단 관련 법리

(1) 근로법 제76조의2 개요

근로기준법 제76조의2(직장 내 괴롭힘의 금지)

사용자 또는 근로자는 직장에서의 지위 또는 관계 등의 우위를 이용하여 업무상 적정범위를 넘어 다른 근로자에게 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위(이하 "직장 내 괴롭힘"이라 한다)를 하여서는 아니 된다.

- 주체 - 사용자 또는 근로자는
- 객체 - 다른 근로자에게
- 제압수단 - 직장에서의 지위 또는 관계등의 우위를 이용하여
- 정당성 한계 - 업무상 적정범위를 넘어
- 금지행위 유형 - 1. 신체적·정신적 고통을 주거나
2. 근무환경을 악화시키는
- 금지명령 - 를 하여서는 아니 된다

※ 타 법령에 의해 금지되거나 처벌이 예정되어 있는 행위는 원칙적으로 근로기준법상 직장 내 괴롭힘 개념에 포섭시키지 않으려는 것이 제도 설계의 취지였음.

(2) 업무상 적정범위를 넘어

- 업무상 적정 범위 내에 있는 행위는 허용
 - 신상품 발표회를 앞둔 팀장의 지속적 보완 요구 (정부 매뉴얼 p22), 실적 부진에 대한 정당한 평가에 따른 승진 누락 (정부 매뉴얼 p23) 등
- 업무 관련성이 있어도 적정성이 없으면 괴롭힘
 - 완수가 불가능하도록 과도하거나 어려운 업무를 부여하여 견디기 어렵게 만드는 행위(소위 “타게 만드는”, “태우는”) 등

○ 괴롭힘 “행위”가 업무 관련성이 있어야 하나?

- 고용노동부 매뉴얼(2019. 2)은 괴롭힘 행위가 포괄적 업무 관련성이 있어야 한다고 명시
- 업무관련성이 없어도 지위 또는 관계 등의 우위를 이용한 행위라면 근로기준법이 금지하는 괴롭힘으로 보아야 함
- 가해행위가 “업무상 적정범위를 넘어”에서 행해지면 될 뿐, “업무관련성”이 있어야 하는 것은 아님
 - ※ 남녀고용평등법상 “직장 내 성희롱”과 구별
- 업무관련성 요구는 괴롭힘 행위의 범위를 부당하게 축소하는 것으로서 행정 명령인 매뉴얼의 규정 가능 한계를 벗어남
 - ※ 사례 : 같은 아파트에 다른 층에 사는 직장 상사가 집으로 불러서 잔심부름을 시키는 행위는 업무관련성은 없지만 직장에서의 지위의 우위를 이용한 행위로 직장 내 괴롭힘에 해당함

(3) 괴롭힘 해당성 판단을 위한 추가 판단 지표

○ 괴롭힘 가해자의 “집단성”

- 근로기준법상은 집단성을 명시하지 않았으나, “우위”를 규정하여, 피해 근로자가 저항하지 못하거나 저항을 포기하게 하는 집단성에 필적하는 힘의 불균형성 요구

○ 괴롭힘 가해행위의 “반복성·지속성”

- 1회의 괴롭힘 가해 행위 또는 일시적인 가해행위로서 반복될 가능성이 없는 경우는 직장 내 괴롭힘에 해당하지 않음 → 형법상 별개의 범죄에 대한 구성요건 해당성 검토 가능
- 가해행위가 지속적 또는 반복적으로 이루어지거나, 그런 우려가 있는 경우 근로기준법이 규율하는 직장 내 괴롭힘에 해당

○ 괴롭힘 가해행위의 “일방성”

- 가해행위가 특정인 또는 특정 집단으로부터 다른 특정인 또는 특정 집단을 향하여 일방적으로 가해져야 함 → 근로기준법은 “다른 근로자에게”라고 규정

- 쌍방의 상호간 적대행위가 이루어진 경우에도 방어행위를 제압할 정도의 가해행위가 있었는지에 대한 비교 형량 필요

7. 근로관계 종료 관련 법리

(1) 합의해지

- 사직 : 근로자의 사직의 의사표시를 하고 사용자가 이에 동의하여 양자간 의사합치로 이루어지는 근로계약관계 종료
 - ※ 근로자의 사직서 제출과 승인
- 권고사직 : 사용자가 사직을 권유하고 근로자가 이에 동의하여 양자간 의사합치로 이루어지는 근로계약관계 종료
 - ※ 근로자가 자의의사에 따라 동의한 경우가 아니면 해고로 간주

(2) 해고(解雇)

- 근로자의 의사에 반하여, 근로계약관계를 종료시키겠다는 사용자의 일방적 형성적 의사표시에 의하여 이루어지는 근로계약관계 종료

(3) 자동 종료

- 사망, 정년퇴직, 사용자의 파산·해산, 근로계약기간 만료 등

(4) 기간의 정함과 해고의 구별

- 기간의 정함 : 그 정한 기간이 종료하면 근로계약관계가 당연히 종료됨. 당사자가 기간제한을 초과한 근로계약기간을 합의한 경우에도 합의가 무효가 되지는 않음
- 해고 : 사용자의 일방적 의사에 의한 근로관계 종료, 기간과 무관

8. 기간제 근로자의 갱신기대권 관련 법리

(1) 갱신기대권의 개념

- 원칙 : 기간을 정한 근로계약은 정한 기간이 만료되면 근로자와 사용자 사이의 근로계약관계가 당연히 종료됨
- 예외(갱신기대권 발생 요건) : 근로계약관계의 당사자간 근로계약기간을 정한 때에도
 - ① 반복갱신 : 그 기간의 정함이 단지 형식에 불과하다고 인정될 수 있는 특별한 사정이 있는 경우(대법원 2005두5673)
 - ② 신뢰형성 : 그러한 특별한 사정이 없더라도 근로자에게 정당한 갱신기대권이 인정되는 경우(대법원 2007두1729)

(2) 갱신기대권의 효과

- 정당한 이유가 없는 사용자의 갱신거절은 부당해고로서 무효
- 갱신기대의 신뢰가 형성되었는지 여부의 판단 기준
 - 기간제 근로계약이 갱신될 것이라는 신뢰가 있는지 여부는 ▲관련한 사내규정이 있는지 여부, ▲근로계약이 이루어지게 된 동기 및 경위, ▲계약갱신의 기준 등 갱신에 관한 요건이나 절차의 설정 여부 및 그 실태, ▲근로자가 수행하는 업무의 내용 등을 종합적으로 고려해,
 - ① 근로계약, 취업규칙, 단체협약 등에서 기간이 만료되더라도 일정한 요건이 충족되면 당해 근로계약이 갱신된다는 취지의 규정을 두고 있거나,
 - ② 근로계약 당사자 사이에 일정한 요건이 충족되면 근로계약이 갱신된다는 신뢰 관계가 형성되어 있어 근로자에게 근로계약이 갱신될 수 있으리라는 정당한 기대권이 인정되는 경우에는
 - 계약이 갱신될 수 있으리라는 정당한 신뢰가 인정되어 갱신기대권이 인정될 수 있다는 것이 대법원 판례의 태도.

[갱신기대권의 의미]

갱신기대권 인정 사례 (2016두50563)	갱신기대권 부정 사례 (2009두9765)
여객선 운항 사업자가 여러 차례 변경되었으나 근로자는 선박의 기관장으로 근무하면서	손해사정사회사가 ▲인력 채용이 탄력적으로 이뤄져야 할 필요가 커 근로자들 대부분을

▲1년 단위로 계약을 장기간 체결해왔으며, ▲직무수행 능력에 문제가 있었다거나 ▲연령에 따른 작업능률 저하나 위험성이 증대되었다는 등의 사정이 보이지 않으므로, 갱신기대권이 인정됨.	계약직으로 채용했다는 점, ▲계약기간이 만료되는 경우 근로계약이 자동해지 된다고 규정한 점, ▲이 사건 근로자와 같은 업무에 종사한 근로자들에 대해 갱신을 거절한 바 있는 점 등을 종합적으로 고려하면 기간을 정한 것이 단지 형식에 불과하다고 볼 수 없음.
--	---

갱신기대권 있는 기간제 근로자의 해고
(대법원 2021. 10. 28. 선고 2021두00000 판결)

<사건 개요>

- 원고는 공동주택 관리업을 영위하는 회사이며, 참가인 근로자들은 계약직 경비원으로 근무했음.
- 회사와 근로자A, B는 다음과 같이 근로계약을 연달아 체결함.
 - ① 근로자A : 2차례 근로계약 체결 / 2018.8.14.~2018.12.31.
 - ② 근로자B : 11차례 근로계약 체결 / 2015.1.10.~2018.12.31.
- 회사는 소속 경비원 8명에 대해 2018년 하반기 근무평가를 했고, 그 중 근로자A, B와, 이 사건 외 근로자 1인만 업무 부적격자로 판정함. 업무 부적격자는 근무평가 결과 총점이 70% 미만인 자임.
 - ※ 100점~90점 : 4명 / 90점~80점 : 1명 / 70점~60점 : 근로자A, 근로자B, 이 사건 외 근로자
- 회사는 근로자A, B에게 2018.12.31. 근로계약이 만료됨을 통지했으나, 근로자A, B는 부당해고 구제신청을 하였음

	판정·판결 날짜	갱신기대권	합리적 이유	해고 정당성
경기지노위	2019. 5.15.	○	×	부당
중앙노동위원회	2019. 8.19.	○	×	부당
서울행정법원	2020. 8.21.	○	○	정당
서울고등법원	2021. 6.17.	○	○	정당
대법원	2021.10.28.	○	○	정당

<판결 요지>

- [1] 기간을 정하여 근로계약을 체결한 근로자의 경우 그 기간이 만료됨으로써 근로자로서의 신분관계는 당연히 종료되고 근로계약을 갱신하지 못하면 갱신 거절의 의사표시가 없어도 그 근로자는 당연 퇴직되는것이 원칙임. 다만 ① 근로계약, 취업규칙, 단체협약 등에서 기간이 만료되더라도 일정한 요건이 충족되면 당해 근로계약이 갱신된다는 취지의 규정을 두고 있거나, ② 근로계약 당사자 사이에 일정한 요건이 충족되면 근로계약이 갱신된다는 신뢰관계가 형성되어 있어 근로자에게 근로계약이 갱신될 수 있으리라는 정당한 기대권이 인정되는 경우에는, 사용자가 합리적인 이유 없이 부당하게 근로계약 갱신을 거절하는 것은 예외적으로 그 효력이 없고, 종전의 근로계약이 갱신된 것과 동일하다고 인정하는 것임(대법원 2007두1729; 대법원 2011두12528 등 참조). 그러므로 기간제 근로계약의 종료에 따른 사용자의 갱신 거절은 근로자의 의사와 관계없이 사용자가 일방적으로 근로 관계를 종료시키는 해고와는 구별되는 것이고, 근로관계의 지속에 대한 근로자의 신뢰나 기대 역시 동일하다고 평가할 수는 없음.

[2] 한편 근로기준법 제27조는 사용자가 근로자를 해고하려면 해고사유와 해고시기를 서면으로 통지하여야 그 효력이 있다고 규정하고 있는데 이는 해고사유 등의 서면통지를 통하여 사용자로 하여금 근로자를 해고하는 데 신중을 기하도록 하고, 해고의 존부 및 시기와 그 사유를 명확하게 하여 사후에 이를 둘러싼 분쟁이 적정하고 용이하게 해결될 수 있도록 하며, 근로자에게도 해고에 적절히 대응할 수 있게 하기 위한 취지임(대법원 2011다 42324 ; 대법원 2015두48136 등 참조).

기간제 근로계약은 그 기간이 만료됨으로써 당연히 종료하는 것이므로 갱신 거절의 존부 및 시기와 그 사유를 명확하게 하여야 할 필요성이 해고의 경우에 견주어 크지 않고, 근로기준법 제27조의 내용과 취지에 비추어 볼 때 기간제 근로계약이 종료된 후 갱신 거절의 통보를 하는 경우에까지 근로기준법 제27조를 준수하도록 예정하였다고 보기 어려움.

이러한 사정을 종합하여 보면, 기간제 근로계약이 종료된 후 사용자가 갱신 거절의 통보를 하는 경우에는 근로기준법 제27조가 적용되지 않는다고 봄이 타당함.

9. 고용승계기대권 관련 법리

(1) 기업 인수 합병 등에 의한 변동 관련 개념

○ 영업양도

- 사업의 전부 또는 일부를 일체로서, 동일성을 유지하면서 다른 회사나 개인에게 양도하는 것을 목적으로 하는 채권계약
- 회사법상 주식회사의 경우 사업의 전부 또는 중요한 일부의 양도에는 원칙적으로 주주총회의 특별결의를 요함 (상법 §374, §434)
- 사업 : 단순한 재산이나 권리의무의 집합체가 아닌 일정한 목적을 위하여 조직화된 일체로서 기능하는 기업조직(대법원 1999. 8. 20. 선고 98다765 판결)
 - ※ 대법원의 정의 : 일정한 영업목적에 의하여 조직화된 업체 즉 인적·물적 조직을 그 동일성은 유지하면서 일체로서 이전하는 것
- 영업양도시 근로관계 존속에 관한 견해 대립 : 특약필요설, 자동승계설, 원칙 승계설(통설, 판례)

○ 자산인수 = 사업이전

- 기업의 시설과 자산만을 다른 회사나 개인에게 양도하는 것을 목적으로 하는 채권계약
- 양도인과 인수인 사이에 특약이 있는 경우에 특약에 따른 고용 승계 인정

(2) 고용승계기대권 (판례)

용역업체 변경시고용승계 기대권 : ○○원자력발전소 사건 (대법원 2021.4.29. 선고 2016두00000 판결)
<사건 개요> ○ 피고보조참고인(이하 ‘H원자력본부 제1발전소’)은 청소업무를 외주업체에 맡기고 1, 2년 단위로 용역도급계약을 체결해왔으며, 원고인 이 사건 근로자들은 청소용역 도급계약을 맺은 B회사에 입사하여 2013.9.1.부터 2014.8.31.까지 H원자력본부 제1발전소에서 근무해왔다. ○ 용역계약의 내용에 포함된 2014년도 H원자력본부 제1발전소 청소용역시방서에서는 “계약 상대방은 종업원을 채용하고자 할 때는 당해 업무를 수행할 수 있는 자만을 채용하여야 하며, 특별한 사정이 없는 한 현재 근무하고 있는 종업원을 고용승계 및 용역계약기간 중 고용유지 하여야 한다(제10조 제1항)” 라고 규정되어 있다.

- 이 사건 청소용역을 도급받아수행한 용역업체들은 특별한 사정이 없는 한 종전 용역업체에서 근무한 근로자들의 고용을 대부분 승계하여 왔으며, C회사는 이 사건 용역계약 체결 이전에도 2007.9.1.부터 2008.8.31.까지 H원자력본부 제1발전소의 청소용역을 도급받아 수행하였던 적이 있었는데, 그 당시에 그 이전 용역업체에서 근무한 근로자 23명 전원의 고용을 승계했다.
- H원자력본부 제1발전소는 2014.9.1.부터 2015.8.31.까지 청소 용역업체를 C회사로 변경하였으며, C회사는 23명 중 4명에 대해 고용승계를 거부하였다.
- 이에 원고들은 자신들이 정당하게 고용이 승계될 것이라는 기대권이 있다고 주장하면서, C사의 고용승계 거부는 부당해고라고 주장한다.

<판결 요지>

- 도급업체가 사업장 내 업무의 일부를 기간을 정하여 다른 업체(이하 ‘용역업체’라 한다)에 위탁하고, 용역업체가 위탁받은 용역업무의 수행을 위해 해당 용역계약의 종료 시점까지 기간제근로자를 사용하여 왔는데, 해당 용역업체의 계약기간이 만료되고 새로운 용역업체가 해당 업무를 위탁받아 도급업체와 용역계약을 체결한 경우, 새로운 용역업체가 종전 용역업체 소속 근로자에 대한 고용을 승계하여 새로운 근로관계가 성립될 것이라는 신뢰 관계가 형성되었다면, 특별한 사정이 없는 한 근로자에게는 그에 따라 새로운 용역업체로 고용이 승계되리라는 기대권이 인정된다. 이와 같이 근로자에게 고용승계에 대한 기대권이 인정되는 경우 근로자가 고용승계를 원하였는데도 새로운 용역업체가 합리적 이유 없이 고용승계를 거절하는 것은 부당해고와 마찬가지로 근로자에게 효력이 없다.
- 이때 근로자에게 고용승계에 대한 기대권이 인정되는지는 새로운 용역업체가 종전 용역업체 소속 근로자에 대한 고용을 승계하기로 하는 조항을 포함하고 있는지 여부를 포함한 구체적인 계약내용, 해당 용역계약의 체결 동기와 경위, 도급업체 사업장에서의 용역업체 변경에 따른 고용승계 관련 기존 관행, 위탁의 대상으로서 근로자가 수행하는 업무의 내용, 새로운 용역업체와 근로자들의 인식 등 근로관계 및 해당 용역계약을 둘러싼 여러 사정을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다.

10. 교섭단위 분리제도 관련 법리

(1) 미국식 교섭제도토양에서 형성된 제도

- 교섭단위(bargaining unit) 개념은 미국의 배타적 교섭대표제도의 토양에서 형성된 개념
 - 미국에서는 단체교섭 당사자 확정 단위와 교섭단위 개념은 사실상 같은 것
 - 미국에서 교섭단위를 둘러싼 쟁점이 주로 교섭단위의 결정 및 안정적 유지에 집중되어 있는 것과 달리, 우리나라에서 ‘교섭단위’라는 용어는 통상 복수노조가 조직되어 있는 사업 또는 사업장에서 분리를 전제로 사용하는 개념

(2) 교섭단위의 개념

- “제29조의2에 따라 교섭대표 노동조합을 결정하여야 하는 단위”(제29조의3)
 - 하나의 사업 또는 사업장 단위 교섭에서 교섭창구 단일화 절차를 진행하는 범주로서 교섭단위 개념을 사용 = 단체교섭 당사자 확정 단위로서의 교섭단위
- 단체교섭 당사자 확정 단위
 - 단체교섭을 진행하기 위해서 실질적 자주성을 갖춘 근로자의 단결체가 정당한 단체교섭권이 있는 주체로서 자격을 인정받고 단체교섭을 진행할 수 있는 지역적·인적 범위

(3) 교섭단위의 원칙적 외연

- 교섭단위 결정의 기본적 원칙 : 사업 또는 사업장
 - 사업 : 법인과 같이 경영상 일체를 이루는 기업체 그 자체
 - 사업장 : 법인격으로서 독자성을 가고 있을 필요는 없지만 독자적인 경영상 판단 하에서 재정, 인사, 노무 등이 독립되어 운영되는 단위로서 사업의 일부
 - ※ 사업장의 개념으로서 “장소적 구획” 개념을 추가로 요구하는 견해 존재 (김상호)

○ 두 군데 이상의 사업장이 하나의 교섭단위로 묶이는 경우

- 개념상 가능하다고 볼 수 있으나, 현행법상 복수노조 하에서 교섭창구 단일화 절차를 진행하고자 할 때에는 교섭단위는 사업 또는 사업장 단위로 제한됨

※ ‘산도.고경지회’는 산도브레이크와 인근의 고경산업을 묶어 전국민주노동조합총연맹 하의 전국금속노동조합 대구지부 산하의 지회로 설립된 조직이었음. 독자적인 규약과 조직을 가지고 있었던 산도.고경지회는 산도브레이크와 고경산업을 각각 단체교섭을 요구했지만, 만약 각각의 사용자가 동의하여 통합교섭에 응했다면 두 개의 기업을 포괄하는 교섭단위가 인정될 수 있었음[대구지방법원 2005. 3. 31. 선고 2004카합910 결정(단체교섭 응낙가처분 사건); 대구지방법원 2005. 9. 28. 선고 2005카합397 결정(가처분 이의 사건) 등]

(4) 교섭단위 분리(통합)시기와 주체

○ 교섭단위 분리(통합) 신청 시기 [시행령 §14의11]

- 사용자가 교섭요구사실을 공고하기 전, 또는 교섭대표노조가 결정된 날 이후에 교섭단위 분리(통합)신청 가능

※ 교섭대표노조가 결정되어 교섭이 진행 중인 경우 분리(통합)신청 가능

○ 교섭단위 분리(통합) 신청권자

- 노동조합 또는 사용자 양쪽이나 어느 한 쪽
- 사용자는 물론 교섭창구 단일화 절차에 참여하지 않은 노동조합이나 창구단일화 절차가 진행 중일 때에는 존재하지 않았던 신생 노동조합도 교섭단위 분리 신청권 보유

○ 교섭단위 분리 결정

- 노동위원회 (지방노동위원회 → 중앙노동위원회)

(5) 교섭단위 분리(통합) 판단 요소

○ 교섭단위 분리(통합) 요소 [노동조합법 제29조의3 제2항]

- ① 현격한 근로조건 차이, ② 고용형태, ③ 교섭관행 등 고려

- 당사자의 교섭단위 분리 합의, 당사자의 입장 등 주관적 요소 배제, 객관적 요소만 고려하며, 숙련도, 경력, 학력, 근속연수 등 근로자 개인적 속성 차이는 현격한 근로조건 차이가 아님

- 통합 요건은 규정 없음

○ 3가지 요소를 모두 충족해야 하는지 여부

- 노동조합법 제29조의3 제2항이 “등을 고려하여”라고 규정하고 있으므로, 노동위원회는 이 세 가지 요소들을 고려하면 될 뿐, 반드시 세 가지 요소가 모두 존재해야 하는 것은 아님. 다만, 고려 요소 중 어느 하나도 존재하지 않는다면 교섭단위 분리 필요성을 검토할 수 없음

서울행정법원 2021. 11. 12. 선고 2021구합00000 판결
(서울고등법원 2022. 10. 12. 선고 2021누00000 판결 : 항소기각
/ 대법원 2022두00000 심리 중)

노동조합법 제29조의3 제2항에서 규정하고 있는 ‘교섭단위를 분리할 필요가 있다고 인정되는 경우’란 하나의 사업 또는 사업장에서 별도로 분리된 교섭단위에 의하여 단체교섭을 진행하는 것을 정당화할 만한 현격한 근로조건의 차이, 고용형태, 교섭관행 등의 사정이 있고, 이로 인하여 교섭대표노동조합을 통하여 교섭창구를 단일화하는 것이 오히려 근로조건의 통일적 형성을 통해 안정적인 교섭체계를 구축하고자 하는 교섭창구 단일화 제도의 취지에도 부합하지 않는 결과를 발생시킬 수 있는 예외적인 경우를 의미한다

○ 교섭단위 분리 필요성 판단시 당사자의 주관적 의도 반영 여부

- 필요설: 김상호, 심요섭 / 부정설: 박종희, 이승욱, 이준희, 중앙노동위원회(그러나 중앙노동위원회의 복수노조 업무매뉴얼(2019) 100쪽은 “주관적인 요소는 배제하고 근로조건의 차이 등 객관적인 요소를 기준으로 노동위원회가 교섭단위 분리 필요성이 있는 경우 허용”한다고 명시하고 있다)
- 해당 교섭단위 내의 노동관계 당사자의 주관적 의도는 교섭단위 분리를 신청하거나 교섭단위 통합을 신청하는 과정에서 드러나며, 당사자의 주관적 의도가 고려되면 노동위원회의 교섭단위 분리결정의 일관성이 확보되지 않아서 예측가능성이 현저히 낮아질 수 있다는 점에서, 교섭단위 분리의 필요성은 객관적인 관점에서 노동조합법 제29조의3 제2항에 명시된 고려 요소들에 검토한 뒤, 역시 객관적으로 교섭창구 단일화 제도가 지향하는 취지와 제도의 목적, 교섭구조의 합리화에 부합하는지 여부를 검토하여 결정하는 것이 바람직

(6) 교섭단위 분리와 교섭대표노동조합의 지위

- 단체협약 체결 이후에는 교섭대표노동조합의 지위를 유지해야 한다는 견해
 - 교섭단위 분리 결정 당시의 교섭대표노동조합이 사용자와 단체협약을 체결했는지를 기준으로, 교섭대표노동조합이 단체협약을 체결하기 전에는 교섭단위 분할로 형성된 각각의 교섭단위에서 다시 교섭창구 단일화 절차를 행하도록 하고, 교섭대표노동조합이 단체협약을 체결한 후에는 그 단체협약 유효기간 만료 3개월이 되는 날로부터 분리된 교섭단위별로 교섭창구 단일화 절차를 진행하도록 해야 한다는 견해
- 단체협약 유효기간 내에서도 교섭단위 분리가 가능하다고 보는 견해(중노위, 법원)
 - 교섭단위가 분리되면 이전의 교섭단위와 분리 결정으로 인하여 형성된 교섭단위는 동일성을 갖는다고 보기 어려우므로, 교섭단위 분리 결정이 내려지면 원칙적으로 이전 교섭단위에서 결정된 교섭대표노동조합의 교섭대표권은 상실된다는 견해.
 - 다만 이전 교섭단위 하에서 교섭대표노동조합이 체결한 단체협약이 유효하게 적용되고 있었다면, 분리 결정 이후의 각 교섭단위에 대해서도 그 단체협약은 여전히 적용되고 있다고 보는 것이 타당하며, 이 경우에는 단체교섭을 개시할 필요성이 없으므로 교섭창구 단일화 절차를 진행하여 교섭대표노동조합을 새로 결정할 이유는 없다고 판단.
 - 기존 단체협약의 효력이 유지되는 동안에는 그 단체협약을 체결한 당사자인 기존 교섭대표노동조합이 단체협약의 이행과 관련한 각종 권한과 책임을 부담
 - 다만, 교섭단위 분리 결정 이후 형성된 새로운 특정 교섭단위에서 기존 단체협약을 계속 적용하는 것이 타당하지 않다고 판단될 경우 새로운 교섭단위 내의 노동조합들은 새로운 단체협약 체결을 위해 사용자에게 단체교섭을 요구할 수 있음

(7) 사용자의 부당노동행위 의사와 교섭단위 분리

- 교섭단위분리 신청 목적이 부당노동행위 의사에 기한 경우
 - 사용자가 교섭단위 분리를 신청하는 목적이 교섭대표노동조합의 교섭대표권을 무효화시키기 위한 의도에 따른 것이라면 교섭단위 분리 신청 행위 자체를 부당노동행위라고 보아 교섭단위 분리 신청을 불허해야 하는 것인가의 문제

- ① 교섭단위 분리 결정 여부가 사용자의 의도에 따라 좌우되는 것이 아님
 - ② 노동위원회는 사용자의 신청 의도와는 무관하게 객관적인 단체교섭 질서와 필요에 부합하는 결정을 내려야 함
 - ③ 사용자가 노동위원회에 교섭단위 분리신청을 하는 행위가 부당노동행위에 해당 하는지 여부는 신청 행위 자체만을 가지고 판단하기는 어렵기 때문에 사후적인 노동위원회 구제절차나 사법기관의 수사절차를 통한 확인절차가 필요한데, 부당노동행위에 해당할 가능성이 있다는 사실만으로 단체교섭과 단체협약의 당사자인 사용자의 교섭단위 분리신청 자체를 금지하는 것은 부당
- 따라서 사용자의 교섭단위 분리 신청 목적을 사전적으로 검토하여 교섭단위 분리 결정을 불허하는 사유로 인정하는 것은 타당하지 않음

교섭단위의원 확대 가능성 (서울행정법원 2021. 11. 12. 선고 2021구합00000 판결의 사실관계)
<사건 개요> ○ ○○○솔루텍주식회사(회사)는 ○○전자(주) 제품의 수리업 및 유지보수업을 목적으로 설립된 ○○전자의 자회사이다. 이 회사의 사업부문은 상업시설 및 공장용 중·대형 에어컨의 수리 업무를 담당하는 에어솔루션·총합공조 사업부(①)와 가정용 제품 유지·관리 업무를 담당하는 케어솔루션 사업부(②)로 구분되어 있었다. ① 사업부 소속 인원은 회사의 정규직 근로자들로 2020.9월 말 기준 1,503명이었다. ② 사업부 소속 인원은 회사와 업무위탁계약을 체결하여 ○○전자가 판매 또는 임대한 생활가전 제품(정수기, 공기청정기, 안마의자, 스타일러 등)에 대한 유지·관리 서비스 업무를 수행하였으며, ‘케어솔루션매니저’라는 호칭으로 불렸다. 2020.9월 말 기준 4,337명이었다. ○ 민주노총 산하의 금속노조 서울지부 ○○○솔루텍지회(C 지회)는 2020.5.27.설치되어 회사 ② 사업부 소속 케어솔루션매니저들과 ① 사업부 소속 일반근로자들로 조직되어 있었다. 2020년 9월 기준 회사인 ○○○솔루텍소속 총 조합원 수는 700명으로, 그 중 케어솔루션매니저와 일반근로자의 비율이 약 7:3이었다. 또한 A 노조는 한국노총 산하의 기업단위 노동조합으로 2020.7.2.① 사업부 소속 일반근로자들을 조직대상으로 설립되었다. A 노조는 조합원 중에 케어솔루션매니저는 없고 ○○○솔루텍의 정규직 근로자만 노동조합 규약상 가입이 가능하며, 2020.9월 기준 A 노조의 전체 조합원 수는 276명이었다. ○ 교섭창구 단일화 결과 C 지회가 교섭대표노동조합으로 확정된 이후 회사가 분할되어 두 개의 서로 다른 법인으로 나뉘어져 ① 사업부는 ‘○○○솔루텍’으로, ② 사업부는 ‘하이케어솔루션’으로 나누어지자 분할 후 잔존 회사(○○○솔루텍) 사업 내에서 C 지회가 A 노조에 비하여 소수노조로 조직구도가 변화되고, C 지회소속 대다수 조합원들이 분할 이후 성립된 하이케어솔루션소속이 되었다. 이에 기존의 소수노동조합이었던 A 노조가 교섭단위 분리신청을 하였다.
<노동위원회 판정> ○ 서울지노위 2020. 11. 18. 2020단위36 판정 - 교섭단위 분리 필요성 인정 케어솔루션 매니저는 노동조합법 제2조 제1호에서 정한 근로자에 해당하고, 케어솔루션 매니저와 일반근로자 간에 근로조건 및 고용형태에서 현격한 차이가 있다고 보아 케어솔루션 매니저 직종을 별도의 교섭단위로 분리할 필요성을 인정하여 원고보조참가인인 A 노조의 신

청을 인용하였다.

○ 중앙노동위원회 2021. 2. 3. 2021단위1 판정 - 교섭단위 분리 필요성 부정

- 이 사건 회사분할로 재심 신청의 구제 이익이 없다고 볼 수 없고, 케어솔루션 매니저 직종을 별도의 교섭단위로 분리해야 할 필요성이 인정되지 않는다.
- 교섭대표노동조합인 C 지회가 케어솔루션 매니저 외에 일반근로자들의 이익을 대변하지 못한다거나, 단체교섭의 효율성을 저해할 우려가 있다고 단정하기 어렵고, 설령 C 지회가 교섭대표노동조합으로서 일반근로자들의 이익을 대변하지 못한다면, A 지회는 교섭대표노동조합에 대해 추가 보충교섭을 요구하거나 노동위원회를 통한 공정대표의무 위반 문제를 제기하는 등 법적 절차에 따라 시정할 수 있는 제도가 마련되어 있으며, 교섭단위 분리를 선불리 결정해 줄 경우 결과적으로 교섭대표노동조합이 그 지위를 잃게 되는 등 노사관계 안정에 영향을 미칠 우려가 있고, 이로 인해 노동조합이 지향하는 통일적 근로조건 확보에 지장을 초래할 뿐만 아니라, 교섭창구 단일화 절차가 형해화될 가능성 또한 배제하기 어렵기 때문에 교섭단위 분리의 필요성이 없다.
- A 노조가 교섭단위 분리 신청을 한 것은 교섭단위 분리를 통한 효율적인 단체교섭의 진행 등에 목적을 두기보다 케어솔루션 매니저들로 주로 조직된 C 지회의 조합원 수가 더 많은 관계로 교섭대표권을 확보하지 못한 A 노조가 케어솔루션 매니저 직종을 별도 분리 신청함으로써 일반근로자들에 대한 교섭대표권을 확보하기 위한 목적이 있는 것으로 보이고, 사용자인 회사는 케어솔루션 매니저가 소속된 C 지회와의 단체교섭을 하지 않겠다는 입장을 분명히 하면서 케어솔루션 매니저 직종을 별도의 법인으로 분리하여 관리하겠다는 입장인 것임을 알 수 있다.
- 또한, 초심지노위 결정 이후, 회사분할로 케어솔루션 매니저 직종이 ○○○솔루텍에 남아있지 않으므로, 비록 사후적이지만 ○○○솔루텍으로서는 교섭단위를 분리해야 할 필요성이 남아있지 않다.

<법원의 판단>

○ 서울행정법원 2021. 11. 12. 선고 2021구합00000 판결 - 교섭단위 분리 필요성 인정

※ 피고 : 중앙노동위원회 / 피고보조참가인 대리인 : 법무법인 여는

- 이 사건 재심결정으로 이 사건 초심결정을 취소하면 피고보조참가인이 교섭대표노동조합의 지위를 회복할 수 있다고 보더라도, 이 사건 회사분할이 이루어져 교섭창구 단일화 절차를 유지할만한 실익이 없어지는 사정변경이 발생하였으므로, 재심신청을 통해 달성하고자 하는 구제의 내용이 사실상 실현될 수 없다. 따라서 이 사건 재심결정 당시를 기준으로 볼 때 피고보조참가인이 재심결정을 구할 신청의 이익이 존재하지 않았다고 봄이 타당하다.
- 노동조합법상의 교섭창구 단일화 제도는 하나의 사업 또는 사업장에 2개 이상의 노동조합이 병존하는 경우 야기될 수 있는 현실적인 문제, 즉 복수의 노동조합이 각각 독자적인 교섭권을 행사할 수 있도록 할 경우 발생할 수 있는 노동조합과 노동조합 상호 간의 반목 및 노동조합과 사용자 사이의 갈등, 동일한 사항에 대해 같은 내용의 교섭을 반복하는 데서 비롯되는 교섭 효율성의 저하와 교섭비용의 증가, 복수의 단체협약이 체결되는 경우 발생할 수 있는 노무 관리상의 어려움, 동일하거나 유사한 내용의 근로를 제공함에도 노동조합 소속에 따라 상이한 근로조건의 적용을 받는 데서 발생하는 불합리성 등의 문제를 효과적으로 해결하는데 그 취지가 있다.
- 이 사건에서 보건대, 케어솔루션 매니저 직종과 일반근로자 사이에 현격한 근로조건의 차이 및 유의미한 고용형태의 차이가 존재하고, 케어솔루션 매니저 직종만을 별도의 교섭단위로

분리하여 교섭이 이루어진 관행이 존재하지 않기는 하나 이는 피고보조참가인이 설립되기 이전에 원고에 노동조합이 존재하지 않았기 때문이며, 케어솔루션 매니저 직종을 별도의 교섭단위로 분리함으로써 달성하려는 이익이 교섭창구 단일화 절차를 유지함으로써 달성되는 이익보다 더 크다고 볼 수 있다.

○ 서울고등법원 2022. 10. 12. 선고 2021누00000 판결 - 항소 기각

○ 피고인 중앙노동위원회가 상고하여 대법원 심리 중(대법원 2022두00000)

11. 부당노동행위 관련 법리

(1) 부당노동행위제도 개요(노동조합법 §81)

- 정당한 조합활동 및 단체행동 참가를 이유로 한 불이익 처우
- 근로자에게 특정 노동조합에 가입하지 아니할 것 또는 탈퇴할 것을 고용조건으로 하는 행위
- 정당한 이유 없는 단체교섭의 거부 · 해태
- 노동조합을 조직하거나 운영하는 것에 대한 지배 · 개입
- 노동조합이나 전임자에 대한 경비원조

(2) 불이익취급

- 불이익취급의 개념 (노동조합법 §81-①-1, 5)
 - 근로자가 노동조합에 가입 또는 가입하려고 하였거나 노동조합을 조직하려고 하였거나 기타 노동조합의 업무를 위한 정당한 행위를 한 것을 이유로 그 근로자를 해고하거나 그 근로자에게 불이익을 주는 행위
 - 근로자의 정당한 노동조합 활동
 - ① 노동조합법 §81-①-1 : 노동조합에 가입 또는 가입하려고 하였거나 노동조합을 조직하려고 하였거나 기타 노동조합의 업무를 위한 정당한 행위
 - ② 노동조합법 §81-①-5 : 정당한 단체행위에 참가한 것을 이유로 하거나 또는 노동위원회에 대하여 사용자가 이 조의 규정에 위반한 것을 신고하거나 그에 관한 증언을 하거나 기타 행정관청에 증거를 제출한 것
 - 사용자의 불이익 처분 : 해고 등 경제적 불이익, 정신적 불이익(생활상의 불이익), 조합활동상의 불이익 등
 - “이유로” : 부당노동행위 의사 필요
- “이유로” 관련 문제 : 처분 이유의 경합. 부당노동행위 의사가 추정되지만, 사용자가 주장하는 해고사유의 정당성도 인정되는 경우

- 정당사유설 : 처분의 정당한 이유가 있는 한, 사용자의 부당노동행위 성립 부정
- 상당이유설 : 정당한 노동조합활동이 없었더라면 불이익처분이 없었을 것이라는 관계가 인정되면 부당노동행위 성립
- 부당노동행위 긍정설 : 부당노동행위 의사가 존재하면 부당노동행위 성립
- 대법원의 2분설 : ① 표면상의 해고사유와는 달리 실질적으로 근로자의 정당한 노동조합 활동을 이유로 한 해고는 부당노동행위에 해당, ② 적법한 해고사유가 있는 경우에는 사용자가 조합활동을 못마땅하게 여긴 흔적이 있다고 하더라도 부당노동행위에 해당하지 않음
 - ※ 노동조합활동을 실질적 해고사유로 삼았는지 여부는 사용자측의 해고사유와 부당노동행위 의사의 존재를 추정할 수 있는 여러 사정을 비교, 검토하여 판단

(대법원 1994. 12. 23. 선고 94누3001 판결)

회사의 회장이 노동조합에서 제명된 근로자에 대한 징계절차가 진행되기에 앞서 “제명이 철회되도록 노조와 화해하라. 그렇지 못하면 회사를 위하여 사직서를 제출하라. 제명처분이 철회되면 선처하겠다”는 취지의 발언을 한 사실이 인정되나, 이는 회사의 단체협약에 “회사는 종업원 이 노동조합 가입을 거부하거나 탈퇴할 때에는 즉시 해고하여야 하며 노동조합에서 제명한 자의 경우 특별히 업무에 지장이 없는 한 회사는 적절한 조치를 취하여야 한다”는 규정에 따라 노동조합으로부터 제명처분이 이루어진 그 근로자에 대하여 적절한 조치를 취할 수밖에 없고 그 근로자에 대하여 노동조합의 제명처분에 따른 어떤 조치를 취하지 아니하는 경우 노동조합과의 관계에 부정적인 영향을 끼칠 것을 염려한 회사가 그 근로자 개인을 위하여 노동조합으로부터의 제명처분이 철회되도록 노력할 것을 권하면서 제명처분이 철회되면 징계에 있어서 선처하겠다는 취지에서 이루어진 것으로 보여진다면 그것이 근로자가 노동조합을 조직 또는 운영하는 것을 지배하거나 이에 개입하는 행위를 하였다고 할 수 없다

○ 불이익취급의 성립요건

- 객관적 요건 → 불이익한 대우
- 주관적 요건 → 사용자 등의 부당노동행위 의사

(3) 반조합계약 : 비열계약

○ 유니온숍(unionshop)협정의 정당성 인정 여부와 근거

- 일반적 조직강제 허용설: 단결선택의 자유 보장을 위해 특정 노동조합에의 조직강제는 허용되지 않는다는 견해(다수설)
- 제한적 조직강제 허용설: 단결선택의 자유를 보장해도, 어느 정도 조정이 가능하므로 특정 노동조합에의 조직강제도 허용된다는 견해
- 소극적단결권 보장설: 단결강제는 허용되지 않는다는 견해

○ 유니온숍규정의 효력이 미치는 근로자의 범위(노동조합법 §81-2 단서)

- 신규채용 근로자→ 유니온숍규정이 유효한 경우, 신규입사자는 단체협약에 정한 일정한 기간 내에 노동조합에 가입하여야 함
- 기존 미조직 근로자
 - ① 긍정설: 기존 미조직 근로자도 노동조합에 가입해야 한다는 견해
 - ② 부정설: 제3자에게 불리한 소급약정을 노동조합과 사용자가 하는 것은 허용되지 않는다는 견해(다수설, 행정해석)
- 소수노조 가입 근로자 → 유니온숍규정의 효력이 미치지 않음

(대법원 2019두47377)

근로자의 노동조합 선택의 자유 및 지배적 노동조합이 아닌 노동조합의 단결권이 침해되는 경우에도 지배적 노동조합이 사용자와 체결한 유니온숍협정의 효력을 그대로 인정할 수는 없고, 유니온숍협정의 효력은 근로자의 노동조합 선택의 자유 및 지배적 노동조합이 아닌 노동조합의 단결권이 영향을 받지 아니하는 근로자, 즉 어느 노동조합에도 가입하지 아니한 근로자에게만 미침. 따라서 신규로 입사한 근로자가 노동조합 선택의 자유를 행사하여 지배적 노동조합이 아닌 노동조합에 이미 가입한 경우에는 유니온숍협정의 효력이 해당 근로자에게까지 미친다고 볼 수 없고, 비록 지배적 노동조합에 대한 가입 및 탈퇴 절차를 별도로 경유하지 아니하였더라도 사용자가 유니온숍협정을 들어 신규입사 근로자를 해고하는 것은 정당한 이유가 없는 해고로서 무효로 보아야 함

(4) 지배·개입

○ 지배 · 개입의 의의

- 노동조합을 조직하거나 운영하는 것을 지배하거나 이에 개입하는 행위
- 지배 → 상대방의 의사결정을 좌우할 정도의 행위
개입 → 지배 정도는 아니지만 자신이 관여할 수 없는 문제에 대해서 간섭하는 행위

○ 지배 · 개입의 성립

- 객관적 요건 : 지배·개입의 행위가 존재하여야 함
→ 물리적인 실력 행사, 사용자의 견해 표명 등 포함
- 주관적 요건 : 지배·개입의 의사가 있어야 함
→ 객관적·외형적인 정황을 종합하여 그 의사를 추정할 수 있는 정도면 충분. 구체적인 결과나 손해의 발생을 필요로 하지 않음

○ 노동조합의 조직에 대한 지배 · 개입

- ① 어떤 직종의 근로자를 노조에 가입시키지 않도록 사용자가 강요
- ② 노동조합의 대항 단체 결성을 지원하거나 비호하는 경우
- ③ 노동조합 결성 방해 또는 조합원의 탈퇴 종용 등

○ 노동조합 내부 문제에 대한 지배 · 개입

- ① 사용자가 위원장 불신임을 위해 임시총회 소집 지시, 비리를 설명한 행위
 - ② 조합장 불신임, 노조 해산결의 등 내부 문제에 적극 개입한 행위
 - ③ 노조 자체 직원의 채용에 대한 중단 요구
- ※ 시설관리권에 따른 합리적인 범위 내의 회사 내 주요장소에 대한 출입 통제 가능

○ 노동조합 활동에 대한 지배 · 개입

- 사용자가 노조에 행하는 모든 행위가 지배·개입이 되는 것이 아니며, 노동조합의 운영 또는 활동에 부당하게 간섭하는 것만이 해당
- ① 노조집회 참석 방해를 목적으로 조합원들에게만 특근을 지시하는 행위
- ② 조합활동의 곤란을 주려는 의도에 따른 전임자 원직복귀명령
- ③ 이전부터 공제해 오던 조합비를 공제하지 않는 행위

- ④ 노조의 조직과 운영에 관한 조합원 상대 설문조사 실시 행위
- ⑤ 개개의 조합원에게 쟁의행위 불참을 권유하는 행위
 - ※ 쟁의행위 위법성에 대해 항의하거나 쟁의발생 사유에 대해 반박하는 경우 등은 사용자의 정당한 의사표현에 해당
- ⑥ 어떤 직종의 근로자를 노조에 가입시키지 않도록 강요하는 행위
- ⑦ 불법적 직장폐쇄를 장기간 유지하여 노조 와해를 초래하는 행위
- ⑧ 금전으로 조합간부 매수, 향응을 통한 노동조합의 어용화, 조합행사 및 정당한 쟁의행위에 대한 간섭 및 교란

○ 신의칙·법령에 반하는 협조 거부

- 합리적인 이유를 제시하고 노동조합과 새로운 합의를 위한 적절한 노력을 하지도 않은 채 일방적으로 신의칙에 반하여 기존 관행을 파기하는 행위
 - ※ ① 관행적으로 허용해 오던 근무시간 중의 조합활동 시간 할애 거부
 - ② 관행적으로 허용해 오던 조합사무실 출입에 대한 불허

제6장 요약 및 결론

- 본 연구는 최근 노동위원회에 구제를 신청하거나 구제신청의 상대방이 된 당사자의 불복 비율이 늘어나고 노동위원회의 부당해고 등 판정사건이 법원으로 가서 종결되는 사례가 늘어남에 따라, 중앙노동위원회 판정에 관한 취소소송에서 중앙노동위원회가 패소하는 사례 또한 상당한 수에 이르고 있다는 점에 주목하여, 최근 3개년(2020~2022)간의 중요 사건을 분석하고, 그 원인과 의미를 확인·분석하는 한편 이를 통제하기 위한 개선 방안을 제시하려는 목적으로 수행되었음.
- 그러한 목적에 이바지하기 위해, 한국 노동위원회 제도의 특수성과 그러한 특수성에서 비롯되는 한계, 그 특수성과 연계된 패소 사례 및 빈도에 관한 새로운 이해의 시도, 개선 방안 도출, 개별 사례별 분석·정리 등 다양한 시도가 이루어졌음.
- 먼저, 한국 노동위원회 제도의 특수성과 관련하여, 미국식 노동위원회 제도가 일본을 통해 도입됨에 따라 미국식 행정심판제도의 한 유형으로 우리나라에 정착되게 되었다는 점을 확인했음.
 - 그 결과 피신청인이 사인인 특수한 행정심판제도의 성격을 띄게 되고, 심판과 조정 기능을 동시에 수행하는 매우 독특한 분쟁해결 제도가 되었음. 이는 우리나라 노동위원회 제도의 독자성이 강조될 수 있는 계기가 되며, 동시에 다양한 방면으로 노동위원회의 기능을 확대할 수 있는 가능성이 될 수 있음.
- 노사관계의 조정기능을 넘어, 권리분쟁에 대한 판정 기능이 강조됨에 따라, 노동위원회 판정에 대한 취소소송 제기가 증가하게 되고, 자연스럽게 노동위원회가 피고가 된 사건에서 노동위원회가 패소하는 경우가 늘어나게 되었음.
- 노동위원회가 법원에 제기된 취소소송에서 패소하는 원인은 두 가지 관점에서 인식할 수 있음.
 - 먼저, 소극적 관점으로는 노동위원회가 법원에서 패소하는 경우가 증가하는 원인은, 노동위원회 조사관 및 공익위원의 전문성 부족, 판정문 작성의 신중함과 전문성 결여, 노동위원회의 조사 능력 및 권한 부족, 노동위원회의 소송수행 능력 및 전략 부족, 법원의 노동위원회 판정 존중 미흡 등에서 찾을 수 있음.
 - 다음으로, 적극적 관점으로는, 노동위원회가 법원과는 다른 차원의 구체적

타당성 확보를 추구하고, 새로운 법리 구축 가능성을 적극적으로 탐색하는 등 스스로의 기능에 충실한 한편, 독자적 기능과 장점을 강화하려고 노력하고 있기 때문에 법원 판례와 다른 결론을 취하는 사례가 늘고, 그것이 패소 사례 증가의 원인이 된다고 이해할 수도 있음.

○ 그러나, 노동위원회가 판정한 사건이 법원에서 부인되는 사례가 증가하는 것은 바람직하지 못하므로, 패소율을 개선할 수 있는 다각적인 제도 개선 방안이 강구될 필요가 있음. 본 연구에서는 그 방안을 제도 운용상의 개선 방안과 법령 개정을 통한 개선 방안으로 나누어 검토했음.

- 먼저 제도의 실제 운용의 묘를 살리는 개선방안으로는, ‘패소사건 검토회의’ 내실화 또는 ‘상소 판단 전문위원회’ 구성, 노동위원회 판정의 일관성 및 선례 구속성 확대를 위한 “주요 사건 판정 사례집” 발간, 노동관련 전문 법무법인을 통한 소송 대리 확대와 내부 송무인력 전문성 강화, 소송 수행 과정에서의 피고보조참가인 측과의 협력 강화, 화해를 통한 분쟁의 종국적 종결 확대, 비상임 공익위원의 충원과 전문성 강화를 위한 중앙노동위원회 ‘서울 사무소’ 설치 등을 제안했음.

- 운용방안의 개선으로는 한계가 있어서, 본격적인 법령 개정을 통한 개선이 시도될 경우에는 지방노동위원회 초심판정에 대한 ‘재심신청 허가제’ 도입, 부당 해고, 부당노동행위, 차별시정 사건에 대한 노동위원회의 신청 전치주의 도입, 중앙노동위원회 재심판정 취소소송 관할을 고등법원으로 조정하는 방안 등을 법령 개정을 통해 시도할 것을 제안하였음.

○ 또한, 노동위원회가 패소한 주요 사례에서 빈번하게 쟁점이 되었던 사항에 대하여 그 핵심적인 11개 분야에 대하여 그 내용을 주요 학설과 판례를 중심으로 간략히 정리하여 본 연구의 실무적 활용도를 제고하고자 하였음.

- 노동위원회 조사관의 실질적 조사권의 의미와 개선 방안, 근로자성 판단 관련 법리, 채용내정, 시용, 수습 관련 법리, 인사평가, 배치전환 관련 법리, 징계의 정당성 관련 법리, 직장 내 괴롭힘 판단 관련 법리, 근로관계 종료 관련 법리, 기간제 근로자의 갱신기대권 관련 법리, 고용승계기대권 관련 법리, 교섭단위 분리제도 관련 법리, 부당노동행위 관련 법리 등임.

○ 마지막으로, 노동위원회가 법원에서 패소한 주요 사례들을 2020년, 2021년, 2022년 3개년의 사건을 중심으로 90여 개의 사건을 선정하여 각 사건별로 주요 사실관계와 다투어진 쟁점, 중앙노동위원회가 택한 법리와 법원이 택한 법리 등을 분석하여 패소의 원인과 대안을 제시하고자 하였음.

참고문헌

- 김형배, 「노동법(제27판)」, 박영사, 2021
- 노동법실무연구회, 「노동조합 및 노동관계조정법 주해(제2판)」, 2023, 박영사
- 정하중, 「행정법개론」, 2007, 법문사
- 권창영, 「근로기준법상 이행강제금제도에 관한 연구」, 서울대 박사학위논문, 2008
- 김미영, 「미국 연방노동관계법 부당노동행위제도의 형성과 발전」, 「강원법학(제38권)」, 2013
- 김선수, 「노사갈등의 현황과 쟁점」, 「전환기의 노사관계와 노동법」, 한국노동법학회 창립 40주년 기념학회 자료집), 1998
- 김홍영, 「노동위원회의 판정에 대한 사법심사」, 「노동법의 쟁점과 과제(김유성 교수 화갑기념)」, 2000, 법문사
- 박은정, 「미국·일본·한국 노동위원회제도에 대한 연혁적 고찰」, 노동법학(제61호), 2017
- 손창희, 「노동위원회 명령과 사법심사의 한계」, 「조정과 심판(제3호)」, 2000. 11, 중앙노동위원회
- 이호원, 「주요 국가의 상고 제한제도 ? 미국, 프랑스, 독일, 일본 제도를 중심으로 -」, 「인권과 정의(제460호)」, 2016
- 차성안, 「독일의 사회법 분쟁 해결과 사회법원의 역할」, 「사회보장법학(제8권 제1호)」, 2019
- 중앙노동위원회, 「복수노조 업무 매뉴얼」, 2011, 152쪽.
- 참여연대, 「이슈리포트(노동위원회 운영실태 보고서)」, 2022. 1. 26.
- 중앙노동위원회, 「보도자료(노동위원회의 부당해고 등 판정사건, 더 신속해졌지만, 법원으로도 더 많이 갔다)」, 2023. 4. 2;
- John E. Higgins 외, 「The Developing Labor Law(7th) Vol.Ⅱ」, Bloomberg BNA, 2017
- David L. Gregory, 「The Labor Preemption Doctrine: Hamiltonian Renaissance or Last Hurrah?」, 「William & Mary L. Rev.(Vol.27)」, 1986
- Gregory L. Hellrung, 「The National Labor Relations Board and the Duty of Fair Representation」, 「Catholic Univ. L. Rev.(Vol.13)」, 1962
- James L. Baldwin III, 「The Duty of Fair Representation and its Applicability When a Union Refuses to Process an Individual's Grievance」, 「South

Carolina L. Rev.(Vol.20)J, 1968

Mitchell H. Rubinstein, 'Duty of Fair Representation Jurisprudential Reform',
Univ. of Michigan Journal of Law Reform(Vol.42)J, 2009

Robert J. Deeny, 'The Duty of Fair Representation', Catholic Univ. L.
Rev.(Vol.20)J, 1970

부록 1. 주요 사건 경과 및 패소 원인 분석

일련번호	2020-1					
판결번호	대법원 2020. 2. 6. 선고 2019두00000 판결					
중노위판정번호	중노위 2014. 10. 2. 중앙2014부해668/부노99(병합)					
사건 종류	부당노동행위					
세부 쟁점	부당노동행위, 불이익취급, 지배·개입, 부당노동행위 의사					
심급별 소송결과	1심 법원	청구 인용	2심 법원	1심 유지	대법원	심리불속행기각
상 고 인	중앙노동위원회위원장		참 가 인		○○기업(주)	
피상고인	전국금속노동조합		피고측 대리인 선임 여부		안 함	
노동조합 지원 여부	있음		원고측 대리인 선임 여부		선임	
재심 결과	초심 유지					
초심의 대법원 판례 일치여부	불일치		재심의 대법원 판례 일치여부		불일치	
기타 특이사항						

주요 사실관계 <사건 개요> 가. 피고보조참가인 ○○기업(주)(이하 '참가인')는 각종 내연기관 부품제조 및 판매업 등을 영위하는 회사이다. 원고 전국금속노동조합(이하 '원고 금속노조')을 제외한 나머지 원고들(이하 '원고 근로자들')은 참가인의 아산공장이나 영동공장에 근무하는 근로자로 산업별 노동조합인 원고 금속노조 충남지부 M 아산지회 또는 충북지부 M 영동지회의 조합원이다. 나. 참가인은 2011. 10. 18. 및 2011. 11. 1. 원고 근로자들을 포함한 27명의 근로자들에 대하여 2011. 3. 25.부터 2011. 7. 31.까지의 단체협약 및 취업규칙 위반행위(불법파업, 명예훼손, 공장 점거 등)를 이유로 징계해고처분(이하 '1차 해고처분')을 하였다. 1) ○○노무법인은 2012. 1. 19.경 경영정상화를 위한 전략회의 문건으로써 참가인에게 아래와 같은 취지의 의견을 제시했다. 그리고 ○○노무법인은 2012. 2. 3. 참가인에게 아래와 같은 내용의 BC 제출용으로 작성된 'M(주)-제출용 자료' 문건을 전달했다. 2) 참가인은 2012년 7월경 위와 같은 문건들 내용의 취지와 동일하게 교섭대표 노동조합인 제2노조와 기존 단체협약 제31조의 규정인 "징계위원회의 위원은 노사 각 5인의 징계위원으로 구성하고, 징계위원회 의결은 참석인원의 과반수의 찬성으로 의결하며 가부동수일 경우에는 의장이 결정한다. 단, 해고는 2/3 이상으로 결정한다." 중 "단, 해고는 2/3 이상으로 결정한다."는 부분을 삭제하는 단체협약을 체결했다. 3) 제2 노조가 교섭대표 노동조합으로 결정되자, 참가인은 2012년 7월경 위와 같이 단체협약 제31조 단서 규정을 삭제하는 것으로 단체협약을 개정했다. 2012년 9월경 국회에서 참가인의 부당노동행위 의혹이 제기되고, 2012년 10월경 ○○노무법인에 대한 설립인가가 취소되었다.
--

다. 2012년 11월경 해고무효 확인청구 민사사건의 제1심법원인 대전지방법원 천안지원과 2013년 4월경 부당징계 및 부당노동행위 구제 재심판정 취소청구 행정소송의 제1심법원인 서울행정법원이 각각 참가인 패소 판결을 선고했다. 이에 참가인은 2013. 5. 28. 스스로 1차 해고를 취소하고 해고된 27명 전원을 2013. 6. 3.자로 복직시켰다.

라. 참가인은 원고 근로자들에게 (가) 2011. 3. 25.부터 2011. 5. 18.까지 M지회의 일련의 불법쟁의행위(작업거부, 태업, 집단조퇴, 특근·잔업 거부, 근무시간 중 집회 및 간부회의, 전면파업, 업무방해 등)를 주도하거나 가담하였고, (나) 2011. 5. 18.부터 시작된 직장폐쇄 기간 중 같은 해 7. 31.까지 이루어진 M지회의 일련의 불법행위(공장 점거, 공장진입 시도, 공장 정문 봉쇄 등)를 주도하거나 가담하였다는 등의 아래와 같은 징계사유가 있고, 이는 징계양정기준상 합계 100점 이상으로 해고사유에 해당한다면서 원고 근로자들을 2013. 10. 21.자로 해고하였다(이하 '이 사건 해고').

마. 원고들은 2013. 12. 30. '이 사건 해고는 부당해고이자 부당노동행위(불이익취급, 지배·개입)에 해당한다.'라고 주장하면서 충남지방법노동위원회에 부당해고 및 부당노동행위 구제신청을 하였다.

<심급별 결과>

[충남지노위] '이 사건 해고에는 2012년 단체협약 제113조를 위반한 절차상 하자가 있으므로 부당하다. 그러나 이 사건 해고가 부당노동행위에 해당하지는 않는다.'라는 이유로 부당해고 구제신청은 인용, 부당노동행위 구제신청은 기각

[중노위] 위 각 재심신청을 모두 기각. 초심 유지

[1심 법원] 부당노동행위 성립을 인정하여 재심판정 중 부당노동행위 성립 부인 부분 취소

[2심 법원] 1심 판결 유지

[대법원] 심리불속행기각

판결 요지

(1) 지배·개입의 부당노동행위

모든 인정사실 등을 종합하면, 참가인은 1차 해고 당시 가졌던 지배·개입 부당노동행위 의사를 사실상 계속 유지하며 이 사건 해고를 단행했다고 봄이 타당하다. ○○노무법인의 위와 같은 자문은 원고들 등을 다시 해고함으로써 M지회의 영향력을 약화하기 위함이었다.

이 사건 해고는 1차 해고의 유지가 어려운 경우를 대비하여 ○○노무법인이 제시한 예비적 방안과 주요 내용에서 일치한다. 이러한 예비적 방안은 통상적인 사용자가 일반적으로 강구할 수 있는 내용이 아니다. 참가인은 1차 해고를 스스로 취소한 것은 위와 같은 제반 사정 때문이었을 뿐만 아니라, 오히려 ○○노무법인 자문을 실현하기 위한 것이었다고 보이고, 이와 달리 지배·개입 의사를 끊기 위한 노력의 일환이었다고는 도저히 보이지 않는다. 그뿐만 아니라, 참가인이 이 사건 해고를 단행하기까지 1차 해고 당시의 지배·개입의사를 단호히 끊으려는 의사, 즉 참가인이 ○○노무법인 자문의 영향력을 일소하고 거기에서 벗어나 M지회와 건전한 노사관계를 새롭게 형성하려는 의사에서 이를 위한 상당한 노력이나 시도를 하여 그러한 노력 등이 대외적으로 드러나 객관적으로 인식할 수 있게 되었다고 인정할 만한 사정들에 관한 충분한 설명과 그 증명이 보이지 않는다.

이런 사정 등에 비추어 보면, 1차 해고 당시 참가인이 가졌던 지배·개입 의사는 이 사건 해고 당시에도 여전히 지속되었다고 보는 것이 경험칙에 비추어 자연스럽다.

1차 해고 후인 2011년 12월경부터 2013년 8월경까지 총 65차례 임금교섭이 있었다. 그런데 그

전에 ○○노무법인은 M지회의 영향력을 약화하고 제2 노조의 영향력을 강화하는 방안으로 참가인에게 '개별적 임금교섭', '제2 노조보다 더 높은 수준 지급 불가 등을 이유로 M지회와 임금교섭 지연' 방안을 제시했다. 참가인과 M지회 사이의 임금교섭 장기화는 ○○노무법인이 참가인에게 자문한 방안과 거의 일치한다. 따라서 달리 특별한 사정이 없는 한 참가인은 ○○노무법인의 자문에 따랐다고 보는 것이 옳다.

참가인은 원고들에 대한 징계양정과 제2 노조 조합원에 대한 징계양정 사이의 차이에 합리적 기준이 있다는 외관을 형성·부각하려 했다. 하지만 그 차이는 ○○노무법인이 2011년 10월경 제안한 '선처 프로그램 활용' 방안을 참가인이 수용하여 제2 노조 조합원에 적용한 결과로 보인다. 그리고 참가인은 1차 해고 취소 후에도 관리직원을 통해 원고들 등을 관찰하고 녹음하는 통제 조치를 했다. 이 때문에 원고들을 비롯한 M지회와 참가인 사이의 노사 갈등과 M지회와 제2 노조 사이의 노노 갈등이 더욱 깊어졌다.

참가인은 원고들의 쟁의행위 가담 정도 등을 고려하지 않고 당시 말았던 직책에 따라 일률적으로 해고했다고 보인다. 따라서 설령 원고들이 1차 해고 이후 다른 조합원이나 관리직원에게 폭언·욕설하여 참가인의 사규를 위반했다하더라도, 그러한 사정만으로는 이 사건 해고가 정당하다고 볼 수는 없다.

또한 이 사건 쟁의행위의 경위, 원고들의 M지회 내 지위와 역할, 이 사건 쟁의행위에 관여한 정도 등에 비추어 볼 때 쟁의행위가 간헐적이고 장기간이라는 사정만으로는 이 사건 쟁의행위가 쟁의권의 남용에 해당한다고 볼 것은 아니다. 이 사건 해고로 M지회의 단체행동권 등이 저해될 우려가 충분히 있다고 보인다.

(2) 불이익취급의 부당노동행위

참가인이 이 사건 해고의 이유로 들고 있는 사유와는 달리 실질적으로는 원고들이 노동조합 업무를 위해 쟁의행위를 했다는 이유로 이 사건 해고를 단행했다고 봄이 타당하다.

① 참가인은 애당초부터 M지회의 운영 등에 지배·개입하려는 의사를 가지고 M지회의 주요 보직자이던 원고들 등을 대상으로 1차 해고를 단행했다. 1차 해고 상의 절차상 하자가 드러나자, 그 절차적 하자만을 치유할 뿐이고, 원고들이 제1, 2 쟁의행위에 관여한 정도 등 주요한 징계양정 사유를 실질적으로 조사·반영하여 징계양정을 하는 것 없이 실질적으로는 1차 해고 때와 같은 의도와 목적에서 이 사건 해고를 단행했다.

② 참가인은 임금교섭과 이 사건 쟁의행위가 진행되던 중에 그 교섭 상대방인 M지회의 주요 임원 등에 대하여 이 사건 해고를 단행했다. 하지만 이 사건 쟁의행위는 제1, 2 쟁의행위와 달리 목적뿐 아니라 절차도 정당하고, 이 사건 해고로 M지회의 단체행동권 등이 실질적으로 제한받았으며, 이 사건 해고가 참가인의 관리력 확보를 위해 M지회의 운영에 대한 지배·개입 의사에 기하여 이루어졌다. 이 사건 해고가 단체협약 중 신분보장 규정을 위반한 절차적 잘못이 있는지 여부는 위와 같은 인정에 방해되지 않는다.

③ 참가인은 노사 갈등과 노노 갈등이 심화·장기화 됨에 따라 사업장의 관리·지배력을 강화할 필요성이 있었다. 참가인은 이 사건 쟁의를 약화하기 위해서라도 그 쟁의행위의 중심인물이던 원고들을 해고할 동기가 충분히 있었다.

패소 이유 (동일한 사실관계에 관하여 기존 대법원 판례 법리와 다른 결론)

초심 지노위 판정과 중노위 재심판정은 부당해고는 인정했으나, 부당노동행위, 특히 불이익취급, 지배·개입의 부당노동행위의 성립을 부인하였다. 부당노동행위가 성립하지 않는다고 노동위원회가 판단한 이유는 부당노동행위 의사의 존재를 부인한 때문이다.

부록.1. 주요 사건 경과 및 패소 원인 분석

부당노동행위 의사의 존재는, 노동위원회가 비록 조사관의 실질적 조사권을 인정하면서도 실질적인 조사권한 행사가 어려운 구조 하에서, 실제적 진실발견을 위한 수사나 조사를 할 수 없다는 한계로 인해 입증하기가 지난한 문제이다. 따라서 비록 사실관계가 동일하다 하더라도 부당노동행위 의사를 노동위원회가 인정하지 못한 것에 결정적 문제점이 있다고 보기는 어렵다. 그러나, 해당 사건의 사실관계를 보면 부당노동행위 의사를 인정할 수 있는 수많은 객관적 정황이 발견된다는 점에서 부당노동행위 사건에 대하여 노동위원회가 지나치게 소극적인 것은 아닌가 하는 문제를 제기하지 않을 수 없다. 어차피 부당노동행위 의사는 객관적 정황과 사실관계를 토대로 추론할 수밖에 없기 때문에 더욱 그러하다.

일련번호	2020-2					
판결번호	대법원 2019. 10. 18. 선고 2016두00000					
중노위판정번호	중노위 2015. 11. 5. 중앙2015부해807					
사건 종류	부당해고					
세부 쟁점	기간제근로자의 계속근로기간 산정, 갱신기대권					
심급별 소송결과	1심 법원	재심판정취소	2심 법원	1심 취소	대법원	파기환송
상 고 인	○○광역시		참 가 인		서○○	
피상고인	중앙노동위원회위원장		피고측 대리인 선임 여부		선임 안 함	
노동조합 지원 여부	없음		원고측 대리인 선임 여부		선임 함	
재심 결과	초심취소					
초심의 대법원 판례 일치여부	일치		재심의 대법원 판례 일치여부		불일치	
기타 특이사항						

주요 사실관계

<사건 개요>

참가인은 ○○광역시 산하 ○○강관리본부에 공개채용절차를 통해 입사하여 2012.9.3.~2012.11.30.까지 기간제근로자로 일하며 사무보조업무(기간제근로자 일일 근무상황부 정리, 시간 외 근무사항 정리, 민원 전화상담 등)를 담당하였다.

위 계약기간 만료 후, 참가인은 공채절차 없이 2012.12.1.부터 2013.12.31.까지 총 5차례의 기간제근로계약을 체결하여 기존 업무를 수행하였다. 그러나 참가인은 이후 진행된 공개채용절차에서 탈락하여 2013.12.31.부로 근로계약이 종료되었고, 2014.1.16.~2014.6.18.까지 실업급여를 받았다. (공채절차에는 430여명이 응시하여 1차 서류전형에 97명이 통과한 후 최종 64명이 합격하였다. 참가인은 1차 서류전형에서 탈락하였는데, 당시 참가인과 같은 기존 기간제근로자 60명이 공채에 응시하였으나 최종합격자는 3명이였다.)

한편 참가인이 하던 업무는 위 공채로 채용된 기간제근로자(계약기간 2014.1.1.~2014.10.30.)가 수행하였는데, 2014.6.17. 개인 사정으로 갑자기 사직하자, ○○강관리본부는 업무공백을 메우기 위해 기존 경력자들에게 연락하던 중 참가인이 근로가 가능한 상태라 하여 참가인을 재채용하였다. 이때 계약기간은 전임자의 잔여기간인 2014.10.30이 아닌 2014.12.31.까지로 하였다.

참가인의 계약종료까지 두 달이 채 남지 않은 2014.10.15.경 본부는 참가인을 비롯한 기간제 4명과 계약기간을 2015.4.18.까지로 연장하는 근로계약을 체결하였는데, 2014.11.26. 본부는 행정착오라는 이유로 이 계약을 철회한다고 통보하였다가 지방노동위원회에서 2015.4.18.까지 근로관계를 유지한다는 화해가 성립하여 참가인을 복직시킨 후 2015.4.18. 근로관계를 종료하였다.

이에 참가인이 ○○지방노동위원회에 부당해고 구제신청을 하였다.

<심급별 결과>

※ 지노위-중노위-1심-2심-3심판결에 이르기까지 매 심급마다 결론이 달라진 사건인데, 주된 쟁점이 된 부분은 참가인이 공개채용절차에 탈락하여 근무를 종료하였다가 이후 재채용 되기 전까지의 ‘공백기간’(2014.1.1.~2014.6.18.) 동안 근로관계가 단절된 것인지 여부였다. 이 사건의 경우 근로관계가 단절된 것으로 보면 총 근로기간이 2년에 미달하지만, 단절이 아니라 계속된 것이라면 총 근로기간이 2년을 초과하여 기간제법 제4조의 무기계약전환 요건을 충족하게 되는 결정적 차이가 발생하는 사안이었다.

[○○지노위] 공백기간 동안 근로관계가 단절되어 계속근로기간이 2년에 미달하여 무기계약전환 대상이 아니고, 갱신기대권도 없어 부당해고가 아니라고 판정

[중노위] 공백기간 전후로 동일한 업무를 수행하였고, 수차례 계약갱신을 통하여 재고용 절차를 반복하며 상시업무에 2년 이상 계속 근로하여 무기계약근로자로 전환되었으므로, 부당해고에 해당한다며 초심판정 취소

[1심 법원] 무기계약으로 전환되지 않았고 갱신기대권도 인정되지 않아 부당해고가 아니라며 재심판정 취소

[2심 법원] 수차례 계약갱신을 통하여 재고용 절차를 반복하며 상시업무에 2년 이상 계속 근로하여 무기계약근로자로 전환되었으므로, 부당해고에 해당한다며 1심 판결을 취소하였다.

[대법원] 공백기간 동안 근로관계가 단절되어 총 근로기간이 2년에 미달한다는 이유로 원심을 파기환송하였다.

판결 요지

기간제법 규정의 형식과 내용 및 입법 취지에 비추어 볼 때, 반복하여 체결된 기간제 근로계약 사이에 근로관계가 존재하지 않는 공백기간이 있는 경우에는, 그러한 공백기간을 둔 것이 기간제법 제4조 제2항의 적용을 잠탈하려는 사용자의 의도에 따른 것인지 여부, 또는 이러한 공백기간의 길이와 공백기간을 전후한 총 사용기간 중 공백기간이 차지하는 비중, 공백기간이 발생한 경위, 공백기간을 전후한 업무내용 및 근로조건의 유사성, 사용자가 공백기간 동안 해당 기간제 근로자의 업무를 대체한 방식과 기간제근로자에 대해 취한 조치, 공백기간에 대한 당사자의 인식, 다른 기간제근로자들에 대한 근로계약 반복·갱신 관행 등을 종합하여 공백기간 전후의 근로관계가 단절 없이 계속되었다고 평가될 수 있는지 여부를 가린 다음, 공백기간 전후의 근로기간을 합산하여 기간제법 제4조의 계속근로한 총기간을 산정할 수 있는지 판단하여야 한다.

※ 다만 대법원은 기간제법상 무기계약 전환 여부를 판단(계속근로의 총 기간 산정)하기 위해 이 사건 공백기간 전후로 근로관계가 단절된 것인지 여부만을 검토하였을 뿐, 갱신기대권에 관해서는 판단을 하지 않았다.

패소 이유 (사실관계에 관한 인정 차이)

부록.1. 주요 사건 경과 및 패소 원인 분석

기간제근로자가 반복적으로 기간의 정함 있는 근로계약을 체결하여, 공백기간 없이 계속 근무하였다면 그 기간의 시작과 끝을 합하여 총 근로기간을 산정하면 되지만, 어떠한 이유에서건 공백기간이 있었던 경우에, 이것이 실제로 근로기간이 단절된 기간인가, 아니면 사용자가 기간제법상 무기계약전환간주 규정을 잠탈할 목적 등에서 의도적으로 유도한 공백기간인가의 판단은 근로관계의 존부를 좌우하는 결정적인 쟁점사항이 된다.

대법원은 이와 관련하여, 그동안 여러 차례 판결을 통해 근로관계 계속성에 관한 법리 확립하여 왔는데, 이번 사건에서도 기존 법리를 재차 확인하였다.

이번 사건의 사실관계는 이미 지노위와 중앙노동위원회의 조사 과정에서 드러난 그대로인데, 대법원은 이러한 사실 요소들이 갖는 법적 의미, 특히 공백기간 동안의 근로관계 단절 여부의 판단에 있어 아래와 같은 관점을 취하여, 공백기간을 단절기간으로 보고 계속근로기간이 2년에 미달하여 무기계약근로자로 전환되지 않은 것으로 판단하였다.

- 공백기간 비중: 근로관계 최초 개시일인 2012.9.3.부터 마지막으로 종료된 2015.4.18.까지 근로한 총기간은 약 25개월인데, 이 사건 공백기간은 5개월 18일로 짧지 않고 비중도 작지 않다.
- 공백기간 발생 경위: ① 공백기간은 계절적인 요인이나 방학 기간 등 업무성격에 기인한 것이 아니고, 휴식 기간 등 일시적인 휴업기간도 아니었으며, 단지 참가인이 공개채용절차에서 탈락하여 발생한 것으로 그 기간 동안 실업급여도 지급받았다. ② 참가인이 재채용된 것은 공개채용절차로 채용되어 참가인이 종래 맡았던 사무보조업무를 수행하던 근로자가 우연히 발생한 개인사정으로 갑자기 사직하게 된 데 따른 것으로, 당시 참가인은 바로 근무가 가능한 상태여서 결원을 보충하기 위함이었다. ③ 당초 공개채용은 지방자치단체인 원고가 복지정책 측면에서 저소득층을 포함한 다양한 계층의 사람들에게 고용 기회를 제공하기 위해 실시한 것으로, 기존 경력자들을 우대하지 않고 오히려 대부분 신규로 채용하였는 바, 기간제법 적용을 잠탈하기 위한 목적으로 단정하기 어렵다.

중노위 단계에서 사실관계에 대한 충분한 조사가 이루어졌음에도 불구하고, 각 사실 요소의 법적 의미를 달리 판단하여 패소에 이른 것으로 보인다. 대법원의 근로관계 계속성에 관한 법리는 이제는 거의 확립되어 있다시피 하지만, 이번 사건에서도 1심-2심-3심의 결론이 계속 뒤집힐 정도로 실제 사실에 적용하는 데에 불확실성이 존재하는 것으로 보인다.

중앙노동위원회 재심판정의 수용성을 높이기 위해 사법부의 판결례를 광범위하게 수집, 분석하여 이를 토대로 보다 정교한 내부적 판단기준을 마련하는 등의 대응이 필요한 것으로 보인다.

일련번호	2020-4					
판결번호	대법원 2019. 10. 18. 선고 2019두00000 판결					
중노위판정번호	중노위 2017. 3 29. 중앙2017부해73					
사건 종류	부당해고					
세부 쟁점	징계시효, 소의 이익, 갱신기대권, 징계사유 및 양정의 정당성					
심급별 소송결과	1심 법원	각하	2심 법원	항소기각	대법원	파기환송
상 고 인	김○○		참 가 인		재단법인 ○○○○연구원	

피상고인	중앙노동위원회위원장	피고측 대리인 선임 여부	선임 안 함
노동조합 지원 여부	없음	원고측 대리인 선임 여부	선임 함
재심 결과	초심유지		
초심의 대법원 판례 일치여부	불일치	재심의 대법원 판례 일치여부	불일치
기타 특이사항			

주요 사실관계

<사건 개요>

원고는 ○○○○연구원(공공기관)에 1994.3월 입사하여 2016년경까지 약 23년여 동안 총 13차례의 근로계약을 갱신하여 근무해왔다.

원고는 사무국장으로 근무하던 기간 중인 2012.6월 ~ 8월 사이에 회사의 인테리어 공사업무를 총괄하는 과정에서 시공업체로부터 3회에 걸쳐 총 3,000만원을 받는 비위행위를 저질렀고, 이러한 행위가 2015.12월 정부 감사에서 적발되어 2016.9월 배임수재죄로 벌금 1,500만원의 약식명령 받았다 (이후 정식재판에서 유죄가 확정되어 벌금 1000만원이 확정되었다).

같은 달 ○○○○연구원은 원고에 대해 징계면직 처분을 하였는데, 비위행위(배임수재) 자체에 대한 징계시효(2년)는 이미 만료된 상황이라 비위행위 자체가 아닌 ‘배임수재로 약식명령을 받아 연구원의 위신을 크게 손상 하였다’는 이유로 면직처분을 하였다. (* 초심과 재심답변서에 의하면, 원고의 배임수재행위가 적발된 시점에는 이미 2년의 징계시효가 도과하여 그 행위 자체에 대해서는 별도의 징계처분을 하지 못하였다고 적혀있다.)

이에 원고는 면직처분이 부당해고임을 주장하며 서울지노위에 구제신청을 하였다.

<심급별 결과>

[서울지노위, 중노위]는 이 사건 징계면직은 정당하다며 원고의 신청 기각

[1심 법원]은 구제절차 진행 중 예정된 근로계약기간이 만료되어 소의 이익 없다고 각하

[2심 법원]은 원고에게 갱신기대권이 인정되어 근로관계가 존속한다는 이유로 소의 이익을 인정하고, 원고가 배임수재로 약식명령을 받아 공공기관인 회사의 위신을 크게 손상한 것은 별도의 징계사유로서 징계시효가 도과하지 않았다고 판단하였으나, 과거 수차례 금전문제로 징계를 받은 전력이 있는 점 등에 비추어 이 사건 징계면직이 정당하다고 보아 원고의 항소 기각

[대법원] 징계시효가 만료되어 징계권이 소멸하였다는 이유로 원심 파기환송

판결 요지

징계사유에 해당하는 비위행위 자체에 대한 징계시효가 만료된 이후 비위행위가 수사대상이 되거나 언론에 보도되었다고 하여 이를 들어 새로운 징계사유가 발생한 것으로 본다면, 비위행위에 대한 징계시효가 연장되는 것과 다름없어 일정 기간의 경과를 이유로 징계권 행사를 제한하고자 하는 징계시효의 취지에 반할 뿐 아니라, 새로운 징계사유의 발생이 사용자 등에 의하여 의도될 우려도 있다. 따라서 비위행위 자체에 대한 징계시효가 만료된 경우 비위행위에 대하여 나중에 수사나 언론보도 등이 있더라도 이로 인해 새로운 징계사유가 생긴 것으로 보거나 수사나 언론보도 등의 시점을 새로운 징계시효의 기산점으로 볼 수 없다.

※ 다만 대법원은 징계시효가 만료된 것으로 결론 내림으로써, 노동위원회, 1·2심 법원에서 쟁점이 된 소의이익, 갹신기대권, 징계사유·양정의 정당성에 관해서는 판단하지 않았다.

패소 이유 (주요 법리에 대한 판단 차이)

이 사건 원고의 비위행위(배임수재)는 2012년도에 벌어졌으나, 3년이 지난 2015년 정부 감사에서 적발되어 2016년에 배임수재로 약식명령을 받고 회사측의 징계면직이 이루어졌다. 그리고 초·재심답변서에는 “이 사건 근로자의 금품 수수 행위(비위행위)는 징계 소멸시효가 사유 발생일로부터 2년이 도과되어 이 사건 연구원은 내부 징계 처분을 하지 못하고 고발조치만 하였다”고 기술되어 있다.

중앙노동위원회는 이러한 사실을 인지하고 있었음에도 불구하고, 배임수재로 약식명령을 받은 사실 등을 비위행위 자체와 구별되는 독자적인 징계사유(‘회사의 위신을 크게 손상시킨 행위’)에 해당하는 것으로 보고, 그때부터 징계시효를 기산하여 아직 시효가 완성되지 않았으며 징계의 정당성 검토로 나아갔다. 중앙노동위원회의 이러한 판단은 ‘비위행위 자체에 대한 징계시효가 만료된 이후 수사나 연로보도가 있는 경우 이를 새로운 징계사유가 발생한 것으로 본다면 징계시효의 연장과 다름없어 징계시효 제도의 취지에 반한다’는 대법원 판례 법리(대법원 2008. 7. 10. 선고, 2008두2484 판결)와 배치된다.

뿐만 아니라 초·재심답변서에 이미 비위행위의 징계시효가 도과하였다는 사실이 드러나 있었음에도, 중앙노동위원회는 징계의 정당성 심의에 앞서 징계시효 만료 가능성에 대해 충분히 검토하지 아니한 것으로 보인다. 중앙노동위원회 재심판정서에는 위 대법원 2008두2484 판결 내지 같은 취지의 판결이 인용되어 있지 않은데, 중앙노동위원회가 사법부의 판결례를 폭넓게 파악하지 못한 측면이 있는 것으로 보이며, 징계시효제도 관련 법리에 대한 이해 역시 미진했던 부분이 있는 것으로 보인다.

비록 중앙노동위원회가 재심 및 하급심법원의 재판결과에 불복하여 대법원에 상고를 제기한 것은 아니지만, 중앙노동위원회의 이러한 미진한 점들이 장기간의 소송전과 대법원 패소라는 결과로 이어진 것으로 볼 수 있다. 구제신청인이 중노위 판정결과에 불복하여 다투는 것은 별론으로 하더라도, 이번 사건의 경우 중앙노동위원회가 재심판정 단계에서 좀 더 신중을 기하였다면 충분히 대응할 수 있었던 사안으로 보인다.

일련번호	2020-5					
판결번호	대법원 2020. 6. 4. 선고 2020두00000					
중노위판정번호	중노위 2018. 4. 10. 중앙2018부해161					
사건 종류	부당해고					
세부 쟁점	징계, 해고, 해고의 정당성, 징계양정					
심급별 소송결과	1심 법원	청구 기각	2심 법원	1심 취소 (재심 취소)	대법원	상고기각 (심리불속행)
상 고 인	고○○		참 가 인		고○○	

피상고인	○○○○개발 주식회사	피고측 대리인 선임 여부	선임 안함
노동조합 지원 여부	없음	원고측 대리인 선임 여부	선임 함
재심 결과	초심유지		
초심의 대법원 판례 일치여부	불일치	재심의 대법원 판례 일치여부	불일치
기타 특이사항			

주요 사실관계

<사실 관계>

참가인은 원고 회사(여행사)에서 18년여 동안 전화상담·항공권 발권 등의 업무를 수행하였다. 참가인은 동료직원들에 대한 폭언, 술자리 강요, 업무 떠넘기기 등의 행위를 하여, 동료들의 타부서 전출 요청을 받은 회사로부터 전보발령을 받은 바 있다. (참가인은 고객 앞에서 동료에게 “이 새끼가 내가 얘기 중인데 어디를 쳐다봐? 눈깔 이리 안돌려”라고 소리지른 바 있고, 동료들에게 “니네들이 공부를 못해서 이런 후진 회사에 들어온 거야”라는 등의 발언을 하였다.)

그러나 전보 이후에도 동료에게 폭언을 하고 상급자의 정당한 업무지시를 거부하는 등의 행동을 계속하여, 동료들이 회사에 진정 및 탄원을 하고 징계절차가 개시되기에 이르렀다. 참가인은 동료들에게 사과하지 않고, 징계위원회에서도 비위행위 자체를 부인하였으며, 그 와중에 자신의 페이스북에 “ㄱ○○○개발은 노동 착취당하고 근무한다는 걸. 대기업 같지만 감정인사와 비빈대로 인사. ㄱㄱ. 여행업계에서 말하는 좆○○○개발 징계해고자”라는 글을 게재하였다.

이에 회사가 징계해고를 하자, 참가인은 서울지방노동위원회에 부당해고 구제신청을 하였다.

※ 회사의 취업규칙은 ‘회사·사원의 명예를 훼손, 회사 내 폭언·욕설, 업무지시 거부’를 금지하고, 고용계약 해지사유로 ‘동료를 폭언·폭행하여 회사 위계질서를 문란케 한 경우’를 명시하였다.

한편 참가인의 상급자 중 한 사람은 참가인의 이런 행위를 제대로 관리하지 못했다는 이유로 감봉 1개월의 징계도 받기도 하였으며, 상당수 동료직원들이 참가인의 복직을 반대하였다.

<심급별 결과>

※ 지노위부터 1심법원까지 부당해고(징계재량권 남용)로 보았으나, 2심은 적법한 해고로 보았다. [서울지노위, 중노위] 비위행위의 정도에 비해 징계양정이 과하여 부당해고에 해당한다고 판정

[1심 법원] 징계재량권 남용으로 보아 재심판정이 적법하다고 판결

[2심 법원] 징계재량권의 남용·일탈이 아니라 재심판정은 위법하다며 1심 판결을 취소

[대법원] 심리불속행기각

판결 요지

피징계자에게 징계사유가 있어서 징계처분을 하는 경우에 어떠한 처분을 할 것인가 하는 것은 징계권자의 재량에 맡겨진 것이고, 다만 징계권자가 재량권의 행사로서 한 징계처분이 사회통념상 현저하게 타당성을 잃어 징계권자에게 맡겨진 재량권을 남용한 것이라고 인정되는 경우에 한하여 그 처분을 위법하다고 할 수 있고, 그 징계처분이 사회통념상 현저하게 타당성을 잃어 재량권의 범위를 벗어난 위법한 처분이라고 할 수 있으려면 구체적인 사례에 따라 징계의 원인이 된 비위사실의 내용과 성질, 징계에 의하여 달성하려고 하는 목적, 징계양정의 기준 등 여러 요소를 종합하여 판단할 때에 그 징계 내용이 객관적으로 명백히 부당하다고 인정할 수 있는 경우라야

한다(대법원 2002.8.23. 선고 2000다60890 판결).

해고처분은 사회통념상 고용관계를 계속할 수 없을 정도로 근로자에게 책임 있는 사유가 있는 경우에 행하여져야 정당성이 인정되고, 사회통념상 당해 근로자와의 고용관계를 계속할 수 없을 정도인지는 당해 사용자의 사업의 목적과 성격, 사업장의 여건, 당해 근로자의 지위 및 담당직무의 내용, 비위행위의 동기와 경위, 이로 인하여 기업의 위계질서가 문란하게 될 위험성 등 기업질서에 미칠 영향, 과거의 근무태도 등 여러 가지 사정을 종합적으로 검토하여 판단하여야 한다(대법원 2014.7.10. 선고 2012다100760판결).

수 개의 징계사유 중 일부가 인정되지 않더라도 인정되는 다른 징계사유만으로도 당해 징계처분의 타당성을 인정하기에 충분한 경우에는 그 징계처분을 유지하여도 위법하지 아니하다(대법원 2002.9.24. 선고 2002두6620 판결).

※ 대법원이 심리불속행기각함에 따라, 위 요지는 2심 법원의 판결 요지를 인용하였다.

패소 이유 (재량권 인정 범위 판단 차이)

참가인의 비위행위 등 일련의 사실관계를 놓고 이것이 참가인을 징계해고할 정도의 것인가, 즉 '징계 양정의 적절성'이 핵심 쟁점이 된 사건이다.

중앙노동위원회는 참가인이 18년 근무하는 동안 징계받은 이력 없는 점, 동료에 대한 폭언·욕설 등은 일시적·순간적으로 흥분하여 한 행위로 보이는 점, 경고·견책·감봉·정직 등 해고보다 낮은 수위의 징계를 전혀 거치지 않고 가장 무거운 해고를 한 점 등을 고려할 때, 징계 양정이 과하여 부당해고라고 판단하였다.

그러나 2심 법원은 여행업의 특성상 신속하고 적절한 고객 응대는 영업의 핵심적 부분이라는 점과 참가인 담당업무의 특성을 고려할 때, 참가인과 회사·동료들 간 협력과 신뢰관계는 고용을 계속할 수 있는지를 결정하는 기준이라고 전제한 후,

▲참가인이 회사와 동료를 비하하고, 동료들에게 폭언과 욕설을 하고, 페이스북에 회사를 모욕하고 명예를 훼손하는 글을 게재함으로써, 동료직원들의 인격권을 침해하고, 회사 및 동료직원들과의 신뢰관계 심각하게 훼손한 점, ▲본인의 행위에 대해 동료들에게 사과한 바 없고, 징계위원회에서도 본인의 비위행위 자체를 부인하는 등 진심으로 반성하는 태도를 보이지 않은 점, ▲비록 참가인이 이전에 징계받은 전력이 없고 해고보다 낮은 강도의 징계처분도 존재하지만, 당초 회사가 징계보다 부서이동 등을 통해 개선기회를 주려하였음에도 참가인의 계속되는 비위행위와 징계과정에서 보인 태도로 인해 개선의 여지가 없다는 판단에 이르게 된 점, ▲상당수 동료직원들이 참가인의 복직을 반대하는 점 등에 비추어 더 이상 고용관계를 유지할 수 없는 상태에 있다고 보아, 이 사건 징계해고는 징계재량권을 일탈하거나 남용한 것이 아니라고 판단하였다.

중앙노동위원회 재심단계에서 객관적인 사실관계는 거의 다 드러난 것으로 보이나, 그 사실관계를 바탕으로 한 징계 양정의 정당성 판단에서 중노위와 법원이 상반되는 결론에 이르렀다. 상대적으로 중앙노동위원회는 '해고는 최후의 수단'이라는 점에 무게를 두고, 참가인이 그동안 징계이력이 없고 우수사원 표창을 받은 적이 있다는 점을 적극 고려하여, 해고보다 약한 징계조치를 먼저 취하여 개선을 도모하지 않고 바로 해고처분으로 나아간 것은 과한 조치라고 판단한 것으로 보인다. 반면 법원은 회사 및 참가인의 업무 특성상 동료들과의 신뢰관계가 매우 중요하다는 점에 착안하여, 실질적으로 '고용관계를 유지할 수 없을 정도에 이르렀는가'에 중점을 두고 판단한 듯하다. 비록 종전에 징계이력이 없더라도 비위행위가 중대하여 신뢰관계가 심각하게 훼손되었고 개선의 여지가 없는 근로자라면, 그에 대한 해고처분을 징계권 남용으로 볼 수 없다는 것이다.

결국 중앙노동위원회가 패소한 결정적인 요인은 그동안 판례가 제시해 온 징계 양정의 정당성

법리의 일관된 관점과 노동위원회의 관점에 차이가 있다는 점에 있다. 해고의 최후수단성을 강조하여 해고의 정당성 인정에 신중한 태도를 보여온 노동위원회가 특별한 경향성을 고려하면, 이를 지지할 수 있는 법리적 근거를 더욱 충분히 제시하여 법원의 확립된 판례의 태도를 변경시킬 정도에 이르지 못한 것이 유감이라고 판단된다.

다만 이 사건의 경우 참가인(징계해고된 근로자)이 2심 판결에 불복하여 상고하였으나, 대법원이 심리불속행기각함으로써 대법원의 구체적 판단은 이루어지지 않았다.

일련번호	2020-6					
판결번호	대법원 2020. 2. 27. 선고 2019두00000					
중노위판정번호	중노위 2017. 12. 13. 2017부해1011					
사건 종류	부당해고					
세부 쟁점	근로기준법상 근로자성, 상시근로자 산정 방법, 근로계약					
심급별 소송결과	1심 법원	청구 기각	2심 법원	1심 취소 (재심 취소)	대법원	상고 기각 (심리불속행)
상 고 인	중앙노동위원회위원장		참 가 인		길○○	
피상고인	이○○(○○○○회트니스)		피고측 대리인 선임 여부		선임 안 함	
노동조합 지원 여부	없음		원고측 대리인 선임 여부		선임 함	
재심 결과	초심유지					
초심의 대법원 판례 일치여부	불일치		재심의 대법원 판례 일치여부		불일치	
기타 특이사항						

주요 사실관계

<사실관계>

원고는 실내골프연습장을 운영하는 자이고, 참가인은 골프강사 업무를 수행하였으나 별도 계약서를 작성하지는 않았다.

참가인은 회원과 개별적으로 골프강습계약을 체결하고, 강습일정·강습료 등을 개별적, 임의적으로 결정하였으며, 원고는 참가인의 강습방식이나 내용, 시간준수여부에 관여하지 않았다. 또한 회원의 불만이 제기되면 원고는 다른 강사를 안내하였을 뿐 참가인에게 불이익 조치를 취한 바 없다(원고의 사업장에는 골프 강사에게 적용되는 취업규칙·인사규정이 없었고, 출퇴근카드와 같은 출퇴근 확인 수단도 없었다).

회원들이 강습료를 사업장에 납부하면 원고가 월별로 정산하여 참가인에게 지급하였는데, 이는

강사의 잠적으로 인한 회원의 환불요구 등에 대비하기 위함이었다. 참가인의 보수는 ‘고정급+매출에 따른 인센티브’로 구성되어 있었으며, 강습료 대부분은 강사인 참가인에게 지급되었다.

* 보수 산정방법 : 고정급+강습료 매출의 일정 비율(매출 100만원 이상: 매출액 30%, 300만원 이상: 70%, 500만원 이상: 80%)

참가인은 4대 보험에 가입되어 있었고, 참가인의 요청으로 원고가 재직증명서를 발급한 바 있다.

참가인에 대한 회원들의 불만이 제기되자 원고는 참가인과 면담한 후 퇴직처리하였는데, 이에 원고가 부당해고를 주장하며 구제신청을 하였다.

<심급별 경과>

[서울지노위] 근로기준법상 근로자에 해당하고, 서면통지의무 불이행으로 부당해고로 판정

[중노위] 초심 유지

[1심 법원] 청구 기각

[2심 법원] 참가인은 근로자가 아니고 원고와 위임계약을 체결한 것이며, 설령 근로자이더라도 상시 5인 미만 사업장이어서 근기법상 해고규정(제23조 제1항, 제27조 서면통지의무)이 적용되지 않는다는 점, 항소기각하고 재심판정 취소

판결 요지

근로기준법상 근로자에 해당하는지는 계약의 형식이 고용계약, 도급계약 또는 위임계약인지 여부보다 근로제공 관계의 실질이 근로제공자가 사업 또는 사업장에 임금을 목적으로 종속적인 관계에서 사용자에게 근로를 제공하였는지 여부에 따라 판단하여야 한다. 여기에서 종속적인 관계가 있는지 여부는, 업무 내용을 사용자가 정하고 취업규칙 또는 복무규정 등의 적용을 받으며 업무수행과정에서 사용자가 상당한 지휘·감독을 하는지, 사용자가 근무시간과 근무장소를 지정하고 근로제공자가 이에 구속을 받는지, 근로제공자가 스스로 비품·원자재나 작업도구 등을 소유하거나 제3자를 고용하여 업무를 대행하게 하는 등 독립하여 자신의 계산으로 사업을 영위할 수 있는지, 근로제공을 통한 이윤의 창출과 손실의 초래 등 위험을 스스로 안고 있는지, 보수의 성격이 근로 자체의 대상적 성격인지, 기본급이나 고정급이 정하여졌고 근로소득세를 원천징수하였는지, 그리고 근로제공 관계의 계속성과 사용자에 대한 전속성의 유무와 그 정도, 사회보장제도에 관한 법령에서 근로자로서 지위를 인정받는지 등의 경제적·사회적 여러 조건을 종합하여 판단하여야 한다. 다만 기본급이나 고정급이 정하여졌는지, 근로소득세를 원천징수하였는지, 사회보장제도에 관하여 근로자로 인정받는지 등과 같은 사정은 사용자가 경제적으로 우월한 지위를 이용하여 임의로 정할 여지가 크다는 점에서 그러한 점들이 인정되지 않는다는 것만으로 근로자성을 쉽게 부정하여서는 안 된다(대법원 2006. 12. 7. 선고 2004다29736 판결 등 참조).

※ 대법원이 심리불속행기각함에 따라, 위 요지는 2심 법원의 판결 요지를 인용하였다.

패소 이유 (사실관계에 관한 인정 차이)

중앙노동위원회는 ‘참가인의 업무내용인 ‘회원 방문 시 골프강습’이 원고에 의해 정해진 점, 강습 내용·방식에 관해 원고로부터 지휘·감독을 받지는 않았으나 이는 업무의 특성에 기인하는 것일 뿐인 점, 주1회 직원회의에 참석하고 카톡으로 타석센터 점검이나 청소 업무 등의 지시를 받은 점,

상당기간 고정급을 지급받아 왔으며 고정급과 강습료에 따른 성과급이 강습에 대한 대가로 볼 수 있는 점, 근무시간과 장소에 구속이 있었던 점, 제3자를 고용해 업무를 대행케 할 수 없었던 점, 원고가 재직증명서를 발급해준 적 있고 근로소득세를 원천징수 하였으며 4대보험에 가입한 점 등’을 이유로 참가인의 근로자성을 인정하였다.

그러나 2심 법원은 ‘업무 지휘·감독 여부, 보수의 성격, 근무시간 및 장소에의 종속성’을 중점

검토하여, 근로자성을 부정하였다. (1) 업무 지휘·감독과 관련해 법원은 ‘참가인이 회원과 개별적으로 골프강습계약을 체결하고, 강습일정·시간·강습료 등을 개별적·임의적으로 결정한 점, 골프강습 방식, 내용, 시간 준수 여부, 강습 태도에 관여하지 않았고 불이익 조치를 취한 바 없으며 취업규칙 인사규정 등 별도의 제재 수단도 마련되어 있지 않았던 점, 카톡 메시지로 특정 회원에게 레슨 잘 부탁한다거나 램프·타석센서 확인을 요청하거나 단체 채팅방에 일과 중 스마트폰 자제 요청 한 바 있으나, 이에 응하지 않더라도 불이익 조치는 없었으며 시설정비 및 청소 업무는 외부업체가 담당 중이었던 점 등’을 들어 원고는 강습업무를 위임하고 영업활동 장소 제공한 것이지, 업무 지휘·감독을 한 것은 아니라고 판단하였다. (2) 보수의 성격에 관해서는 ‘매월 고정급 + 강습료 매출액의 일정 비율을 별도 지급하기로 합의하고 강습료 대부분을 참가인에게 지급한 점 등’에 비추어 이는 회원에 제공한 서비스 대가이지 원고에 대한 근로 제공 대가는 아니라고 보았다. (3) 아울러 ‘참가인이 회원과 별도로 강습일정·시간을 조율하였고, 출퇴근 확인 수단도 없었으며, 근무시간 중 영업활동이나 개인용무를 보는 것이 가능’하였으므로, 시간적·장소적 종속성도 강한 수준이 아니라고 보았다.

생각건대, 2심 법원이 중앙노동위원회의 판단을 취소한 핵심 요인은 구체적인 업무수행 과정에서 참가인에게 상당한 독립성과 자율성이 있었던 것으로 인정한 데 기인하는 것으로 보인다. 중앙노동위원회는 ‘참가인의 업무내용이 원고 사업장회원에게 대한 골프강습으로 미리 정해져있었고, 강습방법의 자율성은 업무 특성에 기인하는 것일 뿐’이라고 본 반면, 법원은 ‘강습업무가 구체적으로 어떤 행태로 이루어졌는지’에 주목한 것으로 보인다. 골프강습이라는 업무내용은 원고가 정한 것일지 몰라도, 강습일정·방법·강습료 등을 강사인 참고인이 개별적으로 결정하고, 원고가 이에 인사조치를 취하거나 근태관리를 할 수 있는 수단이 마련되어 있지 않았다는 사실에 중점을 두어, 참가인에게 근로자로서의 종속성을 인정하기 부족하다고 판단하였다.

이 사건은 당초 1심 법원은 중노위와 같은 관점에서 사실관계를 해석하여 중앙노동위원회 재심판정의 결론을 그대로 유지하였으나, 2심 법원에서 결론이 뒤집어진 사건으로, 근로자성 판단의 현실적인 어려움과 불확실성이 드러난 사건 중 하나로 볼 수 있다. 근로자의 종속성 인정의 핵심인 업무 지휘·감독의 존부를 판단함에 있어, 특정 직업·직종·직무 등에 대한 일률적인 결론을 내릴 수는 없으나, 그동안 누적된 판정·판결례들 광범위하게 분석하여, 사법적 판단기관으로서 노동위원회와 법원 간 결론의 일관성, 예측가능성을 높이려는 노력 필요할 것으로 보인다.

※ 상시근로자수 산정과 관련하여, 중앙노동위원회는 강사들의 근로자성 인정하여 상시 5인이상 사업장으로 보아 해고 서면통지 불이행을 이유로 부당해고 판정을 하였으나, 2심 법원은 강사의 근로자성을 부정함으로써 5인 미만 사업장으로 판단해 부당해고 여부는 판단하지 않았다.

일련번호	2020-7					
판결번호	대법원 2019. 12. 12. 선고 2019두00000					
중노위판정번호	중노위 2017. 11. 22. 2017부해948					
사건 종류	부당보직해임					
세부 쟁점	구제명령 대상의 존부, 인사권, 성과평가, 배치전환					
심급별 소송결과	1심 법원	재심판정취소	2심 법원	항소기각	대법원	상고기각 (심리불속행)
상 고 인	중앙노동위원회위원장		참 가 인		정○○	

부록.1. 주요 사건 경과 및 패소 원인 분석

피상고인	주식회사 ○○○○○○코 리아	피고측 대리인 선임 여부	선임 안 함
노동조합 지원 여부	없음	원고측 대리인 선임 여부	선임 함
재심 결과	초심취소		
초심의 대법원 판례 일치여부	일치	재심의 대법원 판례 일치여부	불일치
기타 특이사항			

주요 사실관계

<사실관계>

이 사건 근로자는 (주)○○엔터테인먼트와 재무이사로 근로계약을 체결하고, 재무이사 및 경영지원본부장 업무를 수행해왔는데, 최대주주가 바뀌면서 상호가 변경되고 새 대표이사가 취임하였다. 새 대표이사는 이 사건 근로자에게 기존 회사에서 수행하던 업무를 계속하라고 지시하였으나 근로자는 기존 근로계약에 따라 재무이사 업무만 수행할 것이며 부당한 업무지시를 하지마라고 요구하며 경영지원본부장 사임서를 제출하였다. 한편 새 대표이사는 일정금액 이상 지출 시 자신의 승인을 얻을 것을 지시하였는데, 이후 근로자가 이러한 업무명령을 불이행하였다는 이유로 근로자를 자금관련 결재라인에서 배제하였다. 또한 일체 업무 관련 대외비용지출 시 새 대표이사의 사전승인을 받을 것(이에 근로자가 이메일로 외부 업무계획 승인요청 하였으나 유선이나 사내에서 처리하라며 불승인되었다), 최근 3개월간 담당업무 내역을 보고할 것을 지시하였고, 이 사건 근로자는 ‘결산, 재고실사, 자금계획 수립, 자금일보 검토, 자금지출 검토, 주요 계약서 검토, 외주제작업체 및 거래업체 미팅, 사업보고서 검토, 투자 미팅, 기타 자회사 관련 업무’ 등을 수행한 것으로 보고하였다. 이 사건 근로자의 휴가 중 사무실 자리가 1인실에서 2인실로 변경된 것에 대해 회사는 사무실 확장에 따른 자리 재배치는 이미 공지된 사항이며 업무효율을 위한 조치라는 답변을 하였다.

이에 근로자는 서면으로 보직해임명령을 받은 건 아니나, 자신을 자금관련 결재라인에서 배제한 조치는 경영지원본부장 보직에서 해임한 것이라며 부당보직해임 구제신청을 하였다.

<심금별 결과>

[서울지노위] 업무조정·권한축소일 뿐 구제신청 대상인 보직해임이 부존재한다며 각하
[중노위] 부당보직해임으로 보아 초심판정을 취소하고 원직복직 명령

[1심 법원] 구제명령 대상의 부존재로 구제신청을 각하해야 한다며 재심판정 취소
[2심 법원] 항소 기각
[대법원] 심리불속행기각

판결 요지

보직해임은 일반적으로 근로자가 직무수행능력이 부족하거나 근무성적 또는 근무태도 등이 불량한 경우, 근로자에 대한 징계절차가 진행 중인 경우 등에 있어서 당해 근로자가 장래에 있어서 계속 직무를 담당하게 될 경우 예상되는 업무상의 장애 등을 예방하기 위하여 일시적으로 당해 근로자에게 보직을 부여하지 아니함으로써 직무에 종사하지 못하도록 하는 잠정적인 조치로서의 보직의 해제를 의미한다(대법원 1996. 10. 26. 선고 95누15926 판결, 서울행정법원 2010. 6. 18. 선고 2009구합42977 판결, 서울행정법원 2011. 7. 14. 선고 2010구합46746 판결 등 참조).

※ 2심 법원은 1심의 재심판정 취소 판결을 인용하여 항소를 기각하는 한편 “원고와 참가인 사이의 근로관계가 종료되어 이 사건 재심판정이 무의미하게 되었으나, 이미 부과된 이행강제금 납부라는 공법상 의무는 여전히 남아 있으며, 법원의 확정판결에 따라 구제명령이 취소되면 이행강제금의 부과 징수가 즉시 중지되고 이미 징수한 이행강제금은 반환하게 된다(근로기준법 시행령 제15조). 따라서 이 사건 소는 원고가 이행강제금의 납부의무로부터 벗어나거나 기납부한 이행강제금을 반환받을 수 있는 가장 직접적이고 효과적인 구제수단이라 할 것이므로, 원고에게는 이 사건 재심판정의 취소를 구할 소의 이익이 있다”고 덧붙였다.

※ 대법원이 심리불속행기각함에 따라, 위 요지는 1심 법원의 판결 요지를 인용하였다.

패소 이유 (사실관계에 관한 인정 차이)

구제신청 대상인 ‘보직해임’이 존재하는가를 놓고 중노위와 법원의 판단이 달랐다. 중앙노동위원회는 회사가 이 사건 근로자에게 취한 ‘일정금액 이상 결제 건에 대해 새 대표이사의 승인을 받으라는 업무지시를 불이행하였으므로 모든 자금관련 결재라인에서 배제한다는 조치’는 근로자를 경영지원본부장에서 “보직해임”한 것으로 보고 그 정당성 판단으로 나아간 반면, 법원은 초심인 서울지노위와 마찬가지로 당초 구제명령 대상인 보직해임은 존재하지 않는다고 보고, 중앙노동위원회가 당해 구제신청을 각하했어야 한다며 재심판정 취소판결을 하였다.

중앙노동위원회는 서면으로 행한 보직해임의 인사명령은 없었으나 ‘자금관련 업무 뿐 아니라 휴가 등 일반 행정업무에 대한 결재권한도 다른 사람으로 변경된 점, 이 사건 근로자가 결재라인에서 배제되는 것 이외에 당시 다른 결재라인 변경은 크게 없었던 점, 대외업무 비용지출 시 대표이사의 사전승인을 받으라고 지시하고는 정작 승인을 거부하여 사실상 대외업무 수행이 불가능해진 점, 금융감독원 전자공시시스템 상 2017년 상반기 회사 경영 공시에는 이 사건 근로자를 경영지원본부장으로 명시하였으나 2017년 하반기 경영 공시에서는 다른 사람을 명시한 점’ 등에 비추어, 실질적으로 경영지원본부장직의 보직해임(직위해제)이 있었던 것으로 보았다. (※ 그리고 중앙노동위원회는 이를 전제로 사실관계 및 책임 소재에 다툼이 있으며 보직해임 할만큼 중대한 것인지 입증이 충분치 않은 점, 종전과 동일한 급여를 수령하였더라도 경영지원본부장의 직위에서 배제되어 사실상 업무 수행에서 배제됨으로써 직장에서의 신분상 불이익을 입은 점, 보직해임조치가 7개월 이상 지속되어 업무상 필요성에 비하여 생활상의 불이익이 큰 점 등을 이유로 보직해임이 부당하다고 판정하였다.)

그러나 법원은 보직해임이란 중국적 조치가 아닌 잠정조치라는 점에 입각하여, 이 사건 근로자가 제출한 최근 3개월 업무 내역, 경영지원본부장이란 보직에 자금결재 관련 권한은 없다는 회사의 주장에 근로자가 다투지 않는 사실 등을 바탕으로, 회사가 근로자를 자금관련 결재라인에서 배제한 것일 뿐 경영지원본부장 업무 전반의 권한을 박탈 내지 회수한 것으로 볼 수 없다고 판단하였다.

중앙노동위원회의 재심판정이 취소된 결정적 요인은 직무의 범위 및 권한을 법원과 달리 판단한 데에 있는 것으로 보인다. 근로자에게 사실상의 불이익이 발생하였다는 현상에만 지나치게 치우쳐 판단한 결과가 아닌가 하며, 사실관계의 의미를 파악함에 있어 보다 객관성과 균형성을 갖고 접근할 필요가 있어 보인다.

일련번호	2020-8
판결번호	대법원 2020. 5. 14. 선고 2020두00000

부록.1. 주요 사건 경과 및 패소 원인 분석

중노위판정번호	중노위 2018. 6. 26. 2018부해403					
사건 종류	부당해고					
세부 쟁점	기간제 근로계약, 갱신기대권					
심급별 소송결과	1심 법원	재심판정취소	2심 법원	항소기각	대법원	상고기각 (심리불속행)
상 고 인	중앙노동위원회위원장		참 가 인		주식회사 ○○○○○	
피상고인	정○○		피고측 대리인 선임 여부		선임 안 함	
노동조합 지원 여부	없음		원고측 대리인 선임 여부		선임 안 함	
재심 결과	초심유지					
초심의 대법원 판례 일치여부	불일치		재심의 대법원 판례 일치여부		불일치	
기타 특이사항						

주요 사실관계 <사실관계> 이 사건 근로자는 2016. 6. 13. 참가인 회사(벽돌 제조·판매)의 서울사무소 영업책임자로 입사하여, 아래와 같은 내용을 명시하여 3차례 근로계약서를 작성하였다. · 기간: (1차) 2016.6.13.~2017.6.12. (2차) 2017.1.1.~2017.12.31. (3차) 2017.4.1.~2017.12.31. · “연봉계약기간은 회사 연봉계약 시행기준에 의거하여 1년으로 한다. 단, 상호간 특별한 이의 사항이 없으면 본 “연봉계약”의 효력 및 변경사항은 자동으로 연장 및 적용된다.” ※ 타 지역의 영업책임자들도 마찬가지로 계약기간 명시 및 연봉계약 체결. 반면 기간의 정함 없는 근로자들은 근로계약서에 ‘월급제’로 명시 ※ 근로계약서상에 계약 갱신이나 재계약 요건·절차에 관한 내용은 미포함 2017. 2월 이 사건 근로자가 사내 동호회 활동 중 부상을 당하여 근로복지공단에 요양급여신청을 하였는데, 당시 회사가 제출한 서류에는 직종 ‘상용직’, 고용형태 ‘정규직’으로 표시되어 있었으며, 온라인 구인·구직사이트에도 동일 직무에 관해 정규직으로 채용 공고가 나와있었다. 2017.12.20. 회사는 이 사건 근로자에게 사직권고장을 교부하였고, 이후 고용보험 피보험자격 상실사유로 ‘기간 만료’가 아닌 ‘경영상 필요 및 불황으로 인원감축’으로 적시하였다. 이에 이 사건 근로자는 부당해고임을 주장하며 노동위원회에 구제신청을 하였다. <심급별 결과> [서울지노위] 기간제근로자로서 기간 만료로 계약이 종료되었으며, 갱신기대권 부정 [중노위] 초심 유지 [1심 법원] 기간의 정함이 없는 근로자이고, 부당해고라고 판결 [2심 법원] 기간제근로자이지만, 갱신기대권이 있고, 합리적 이유 없이 계약 갱신을 거부하여 부당해고라고 판결 [대법원] 심리불속행기각
--

판결 요지

근로자와 사용자가 근로계약을 체결하면서 기간을 정한 근로계약서를 작성한 경우라 하더라도, 그 계약서의 내용과 근로계약이 이루어지게 된 동기 및 경위, 기간을 정한 목적과 당사자의 진정한 의사, 동종의 근로계약 체결방식에 관한 관행 그리고 근로자보호법규 등을 종합적으로 고려하여 그 기간의 정함이 단지 형식에 불과하다는 사정이 인정되는 경우에는, 계약서의 문언에도 불구하고 기간의 정함이 없는 근로계약을 맺었다고 볼 것이나, 위와 같은 사정이 인정되지 않는 경우에는 처분문서인 근로계약서의 문언에 따라 근로자와 사용자 사이에는 기간의 정함이 있는 근로계약이 맺어진 것이라고 봄이 원칙이다(대법원 2007. 7. 12. 선고 2005두2247 판결 참조).

기간을 정하여 근로계약을 체결한 근로자의 경우 그 기간이 만료됨으로써 근로자로서의 신분관계는 당연히 종료되고 근로계약을 갱신하지 못하면 갱신 거절의 의사표시가 없어도 당연 퇴직되는 것이 원칙이다. 그러나 근로계약, 취업규칙, 단체협약 등에서 기간만료에도 불구하고 일정한 요건이 충족되면 당해 근로계약 등에서 기간만료에도 불구하고 일정한 요건이 충족되면 당해 근로계약이 갱신된다는 취지의 규정을 두고 있거나, 그러한 규정이 없더라도 근로계약의 내용과 근로계약이 이루어지게 된 동기 및 경위, 계약 갱신의 기준 등 당해 근로관계를 둘러싼 여러 사정을 종합하여 볼 때 근로계약 당사자 사이에 일정한 요건이 충족되면 근로계약이 갱신된다는 신뢰관계가 형성되어 있어 근로자에게 근로계약이 갱신될 수 있으리라는 정당한 기대권이 인정되는 경우에는, 사용자가 이를 위반하여 부당하게 근로계약의 갱신을 거절하는 것은 부당해고와 마찬가지로 아무런 효력이 없고, 이 경우 기간만료 후의 근로관계는 종전의 근로계약이 갱신된 것과 동일하다(대법원 2011. 4. 14. 선고 2007두1729 판결 참조).

근로자에게 이미 형성된 갱신에 대한 정당한 기대권이 있음에도 불구하고 사용자가 이를 배제하고 근로계약의 갱신을 거절한 데에 합리적 이유가 있는지가 문제될 때에는 사용자의 사업 목적과 성격, 사업장 여건, 근로자의 지위 및 담당 직무의 내용, 근로계약 체결 경위, 근로계약의 갱신에 관한 요건이나 절차의 설정 여부와 그 운용 실태, 근로자에게 책임 있는 사유가 있는지 여부 등 당해 근로관계를 둘러싼 여러 사정을 종합하여 갱신 거부의 사유와 그 절차가 사회통념에 비추어 볼 때 객관적이고 합리적이며 공정한지를 기준으로 판단하여야 하고, 그러한 사정에 대한 증명책임은 사용자가 부담한다(대법원 2017. 10. 12. 선고 2015두44493 판결 참조).

※ 대법원이 심리불속행기각함에 따라, 위 요지는 2심 법원의 판결 요지를 인용하였다.

패소 이유 (사실관계에 관한 인정 차이)

본 사건은 ‘기간의 정함이 없는 계약인지 여부’, ‘갱신기대권 인정 여부’가 주요 쟁점이 된 사건이다.

중노위와 2심 법원은 공통적으로 기간의 정함이 있는 근로계약으로 보았다. 하지만 ‘갱신기대권 인정 여부’를 놓고 상반된 판단을 내림으로써, 종국적으로 전혀 다른 결론에 이르게 되었다.

2심 법원은 ‘기간의 정함이 없는 계약인지 여부’를 판단함에 있어서는 처분문서인 근로계약서의 문언(계약기간 명시)에 충실한 해석을 한 것으로 보이나, ‘갱신기대권 인정 여부’의 판단에 있어서는 근로계약서상 조항들을 보다 유기적으로 해석하고, 나아가 사직권고장, 고용보험 신고사유, 근로복지공단에 제출한 사업장 확인서 및 재해조사서에 적시된 고용형태, 회사의 채용공고상 고용형태, 회사의 기간제근로자 정책 등을 종합적으로 고려하였다.

생각건대, 2심 법원은 근로계약이 개시되던 당시에 계약당사자들이 의도한 계약의 내용을 최대한 존중하되, 이후 근로계약이 반복되는 과정에서 신뢰관계가 형성되었는지 여부를 판단하는 문제에 있어서는 전후의 여러 정황을 보다 폭넓게 고려한 것으로 보인다.

반면 중앙노동위원회는 근로계약서의 문언에 치중한 것으로 보인다. 중앙노동위원회는 먼저 근

부록.1. 주요 사건 경과 및 패소 원인 분석

로계약서에 계약기간이 명시되어 있는 점을 이유로 기간의 정함이 있는 근로자로 판단한 다음, 마찬가지로 근로계약서에 계약 갱신에 관한 규정 없다는 점을 주요 논거로 삼아 갱신기대권을 부정하였다.

중앙노동위원회의 이러한 논리 전개는 기간의 정함이 있는 근로자라는 판단에 이르자 다소 성급하게 기간제근로자이므로 기간 만료로 근로관계가 종료한다는 결론을 내린 것이 아닌가 한다. 설령 기간제근로자로 판단하였더라도, 갱신기대권 문제는 기간제인지 여부와 무관하게 근로계약 당사자 사이에 어떤 신뢰관계가 형성되어 있는지를 살펴보아야 하는 문제이다. 이런 측면에서의 미흡함이 중앙노동위원회의 패소 원인이 된 것으로 보인다.

다만 동일한 사실관계를 놓고 ‘기간의 정함이 없는 계약인지 여부’에 대해 1심과 2심 법원의 판단이 전혀 달랐던 점을 생각하면, 어떤 사실에 법적의미를 부여하고 무게 중심을 둘 것인지에 있어 불명확한 측면이 존재하였던 사건으로 보인다.

일련번호	2020-9					
판결번호	대법원 2020. 2. 6. 선고 2019두00000					
중노위판정번호	중노위 2017. 12 20. 2017부해1048, 1088(병합)					
사건 종류	부당해고					
세부 쟁점	기간제 근로계약, 갱신기대권					
심급별 소송결과	1심 법원	재심 취소	2심 법원	항소기각	대법원	상고기각 (심리불속행)
상 고 인	중앙노동위원회위원장		참 가 인		김○○	
피상고인	주식회사 ○○		피고측 대리인 선임 여부		선임 안 함	
노동조합 지원 여부	지원 있음		원고측 대리인 선임 여부		선임 함	
재심 결과	초심유지					
초심의 대법원 판례 일치여부	불일치		재심의 대법원 판례 일치여부		불일치	
기타 특이사항						

주요 사실관계

<사실관계>

참가인 근로자(1952년생)는 2014. 6월부터 다른 용역업체에 소속되어 ‘○○ 청소업무’를 수행하던 중, 2015. 7. 1.자로 원고 회사가 위 청소업무 용역사업을 수주하게 되자, 원고 회사와 2015. 7. 1 ~ 2015. 9. 30. 3개월의 근로계약을 체결하였다(1차 근로계약).

고용불안을 느낀 근로자들은 2015. 9월말 ○○○민주연합노조에 가입하였는데, 원고 회사가 기간만료 계약종료를 통보하자(고령으로 인한 업무능력 및 사고 대처능력 저하), 위 노조의 중재로 2015. 10. ~ 2017. 6. 30. 기간으로 2차 근로계약을 체결하였다. 한편 2015. 10월 중, 원고 회사 소속 60세 이상 근로자 두 명이 ○○ 청소업무 중 차에 치어 사망하는 사고가 있었다.

(※ 근로계약서에는 '기간 만료 1개월 전부터 업무성과, 직무역량, 근태 등에 따라 재계약 여부를 결정한 다', '기별 업무평가를 한 후 계약을 유지 또는 해지할 수 있다', '○○시와 용역계약이 해지되거나 만료될 때 근로계약은 해지된다'는 조항이 포함되어 있었다.)

'○○ 청소업무'의 발주자는 ○○시로, ○○시의 결정에 따라 원고 회사는 이 사건 1차 용역계약(기간 2015. 7. 1 ~ 2017. 6. 30.) 동안 18명을 고용하였으나, 이후 2차 용역계약(기간 2017. 7. 1 ~ 2019. 6. 30.)에서는 원고 회사 이외에 다른 용역업체도 추가됨에 따라 12명만 고용이 가능하게 되었다.

원고 회사는 2017. 5. 15.경 기간 만료로 인한 근로계약종료 통보를 하였고, 참가인은 경기도노위에 부당해고 구제신청을 하였다.

<심급별 결과>

[경기도노위] 갱신기대권이 인정되고 갱신거절에 합리적 이유 없어 부당해고라고 판정

[중노위] 초심 유지

[1심 법원] 갱신기대권 인정되나 갱신거절에 합리적 이유가 있다며 재심판정 취소

[2심 법원] 항소 기각

[대법원] 심리불속행기각

판결 요지

기간을 정하여 근로계약을 체결한 근로자의 경우 그 기간이 만료됨으로써 근로자로서의 신분 관계는 당연히 종료되고 근로계약을 갱신하지 못하면 갱신 거절의 의사표시가 없어도 그 근로자는 당연 퇴직되는 것이 원칙이다. 다만 근로계약, 취업규칙, 단체협약 등에서 기간이 만료되더라도 일정한 요건이 충족되면 당해 근로계약이 갱신된다는 취지의 규정을 두고 있거나, 그러한 규정이 없더라도 근로계약의 내용과 근로계약이 이루어지게 된 동기 및 경위, 계약 갱신의 기준 등 갱신에 관한 요건이나 절차의 설정 여부 및 그 실태, 근로자가 수행하는 업무의 내용 등 당해 근로관계를 둘러싼 여러 사정을 종합하여 볼 때, 근로계약 당사자 사이에 일정한 요건이 충족되면 근로계약이 갱신된다는 신뢰관계가 형성되어 있어 근로자에게 근로계약이 갱신될 수 있으리라는 정당한 기대권이 인정되는 경우에는, 사용자가 이에 위반하여 부당하게 근로계약의 갱신을 거절하는 것은 부당해고와 마찬가지로 아무런 효력이 없다. 이때 기간 만료 후의 근로관계는 종전의 근로계약이 갱신된 것과 동일하다(대법원 2011. 4. 14. 선고 2007두1729 판결, 대법원 2014. 2. 13. 선고 2011두12528 판결 등 참조).

기간제법 제4조 제1항 단서의 예외 사유에 해당하지 않는 한 2년을 초과하여 기간제근로자로 사용하는 경우 기간의 정함이 없는 근로계약을 체결한 것으로 간주하고 있으나, 기간제법의 입법 취지가 기간제근로자 및 단시간근로자에 대한 불합리한 차별을 시정하고 근로조건 보호를 강화하기 위한 것임을 고려하면, 기간제법 제4조 제1항 단서의 예외 사유에 해당한다는 이유만으로 갱신기대권에 관한 위 법리의 적용이 배제된다고 볼 수 없다.

갱신기대권 법리와 함께 기간제법 등의 입법취지, 사업장 내에서 정한 정년의 의미, 정년 이후에 기간제 근로계약을 체결하는 근로계약 당사자의 일반적인 의사 등을 고려하면, 정년을 이미 경과한 상태에서 기간제 근로계약을 체결한 경우에는, 앞서 본 제반 사정 외에 해당 직무의 성격에 의하여 요구되는 직무수행 능력과 당해 근로자의 업무수행 적격성, 연령에 따른 작업능률 저하나 위험성 증대의 정도, 해당 사업장에서 정년을 경과한 고령자가 근무하는 실태 및 계약이 갱신된 사례 등을 종합적으로 고려하여 근로계약 갱신에 관한 정당한 기대권이 인정되는지 여부를 판단하여야 한다(대법원 2017. 2. 3. 선고 2016두50563 판결 참조).

사용자가 근로자의 목숨을 보호하는 것은 사용자의 안전배려의무 중에서 가장 중요한 내용이다. 이것이 근로계약 체결 후에만 문제되는 것은 아니다. 사용자는 근로자를 채용하거나 근로계약을 갱신하는 단계에서도 장차 근로자로 하여금 해당 업무에 종사하게 하는 것이 근로자의 목숨을 크게 위협하는 위험에 노출하는 것은 아닌지를 반드시 중요하게 고려해야 한다. 이런 측면에서 볼 때, 근로자의 고령에 따른 위험 대처능력의 유무와 정도 등을 고려하는 것이 고령자고용촉진법의 취지에 반한다고 볼 수는 없다.

※ 대법원이 심리불속행기각함에 따라, 위 요지는 1·2심 법원의 판결 요지를 인용하였다.

패소 이유 (사실관계에 관한 인정 차이)

중노위와 법원은 모두 참가인 근로자의 갱신기대권을 인정하였으나, 갱신거절의 합리성에 관해 동일한 사실관계를 놓고 그 경중 및 법적 평가를 달리하여, 각기 다른 결론에 이르렀다.

중앙노동위원회는 ‘원고 회사는 정년이 도과된 근로자뿐만 아니라 징계전력도 있는 근로자도 근로계약을 갱신한 바 있고, 참고인 근로자가 청소업무를 수행하는 장소인 ○○는 고속화도로로서 위험한 곳이긴 하나 원고의 근로자들이 업무 중 사망한 사고는 운전자의 졸음운전 등에 기인한 것이지 사고근로자들이 고령으로 사고대처능력이 떨어져 발생한 것이라 단정하고 어렵고, 참가인 근로자를 원고 회사의 다른 용역현장으로 전보가 가능함에도 이를 전혀 고려하지 않았다’는 등의 이유로, 갱신거절에 합리적 이유가 없어 부당해고라고 판정하였다.

그러나 법원은 근로계약서에 ‘업무평가를 통해 재계약 여부 결정, ○○시 청소용역계약이 해지·만료되면 근로계약 종료’된다는 취지의 조항이 있고, 원고 회사는 ○○시와 1차 용역계약에 이어 업무내용·장소가 유사한 2차 용역계약을 체결하여 용역계약이 사실상 유지되는 점 등에서,

참가인 근로자에게 ○○시 용역계약 유지를 전제로 근로계약 갱신의 신뢰가 형성되었다 보면서도, ‘▲발주자인 ○○시의 결정으로 고용인원이 12명으로 감소한 점, ▲근무장소인 ○○는 업무 특성상 고도의 사고 위험성이 존재하고, 고령 근로자는 위험 상황 인식 및 대처능력 떨어질 수 있으며 실제 사망사고가 발생했던 사실 등에 비추어 갱신 결정에 근로자의 연령을 고려한 것은 부당하지 않은 점, ▲참가인의 징계전력(상급자에 대한 폭언으로 정직 2개월)은 가볍지 않고, 갱신 여부는 징계전력 뿐 아니라 연령·품행·경력 등을 종합하여 결정하는 것으로 차별적이지 않은 점 등’을 중시하여 갱신거절의 합리성을 인정하여 중앙노동위원회의 판정을 취소하였다.

2심 법원은 중앙노동위원회의 근로자 채용 또는 계약 갱신 결정 시 근로자의 고령에 따른 위험 대처능력의 유무와 정도를 고려하는 것은 고령자고용촉진법 취지 반한다는 주장에 대해, ‘장차 근로자로 하여금 해당 업무에 종사하게 하는 것이 근로자의 목숨을 크게 위협하는 위험에 노출하는 것은 아닌지를 사용자의 안전배려의무의 가장 중요한 내용’이라며, 그 주장을 배척하였다.

중앙노동위원회는 1심·2심 법원의 재심판정 취소판결에 불복하여 상고를 제기하였는데, 갱신기대권 인정 여부와 갱신거절의 합리성 여부는 별개의 쟁점인 만큼, 갱신기대권이 인정되는 경우에도 거절의 합리성 여부에 관해서는 보다 엄격한 판단이 요구된다 하겠다. 이번 사건의 경우 법원은 갱신기대권을 인정하면서도, 근로자가 이미 근로계약 체결 당시 60세가 넘어 고령인 점, 근무장소 및 업무의 위험성 등 현실적인 요소들을 적극 고려하여 근로계약 당사자 간의 형평성을 도모하고자 한 것으로 보인다. 갱신거절 합리성 판단 시 법원이 취하는 법적관점에 중앙노동위원회가 더욱 주목할 필요가 있어 보인다.

인구구조의 변화, 고령근로자 증가 등으로 향후 갱신기대권 및 갱신거절의 적법여부를 다투는 사건은 더욱 증가할 것으로 예상된다. 중앙노동위원회의 판정이 사법부에서 취소되는 사례가 증가할 경우 중노위 판정의 신뢰도 훼손이 불가피할 것으로 우려되는 바, 기 누적된 판정 및 판결례와 관련 자료들을 광범위하게 수집·검토하여 판정의 신뢰성을 높이는 준비가 필요한 시점이라 사료된다.

일련번호	2020-10					
판결번호	대법원 2020. 1. 30. 선고 2019두00000					
중노위판정번호	중노위 2018. 1. 29. 2017부해1117					
사건 종류	부당인사발령					
세부 쟁점	구제이익, 인사발령의 정당성(업무상 필요성, 생활상 불이익, 사전협의절차)					
심급별 소송결과	1심 법원	청구 기각 (재심 유지)	2심 법원	1심 취소 (재심 취소)	대법원	상고 기각 (심리불속행)
상 고 인	중앙노동위원회위원장		참 가 인		임○○	
피상고인	주식회사 ○○○		피고측 대리인 선임 여부		선임 안 함	
노동조합 지원 여부	없음		원고측 대리인 선임 여부		선임 함	
재심 결과	초심 유지					
초심의 대법원 판례 일치여부	불일치		재심의 대법원 판례 일치여부		불일치	
기타 특이사항						

주요 사실관계 <사실 관계> 참가인 근로자는 1994년 원고 회사에 입사하였는데, 남부영업부 김해영업소 영업소장으로 근무하다 2016. 5. 1. 같은 영업부 내의 창원영업소 소장으로 발령받았다. 2016년도 전국 영업소장 최종 평가에서 29명 중 29위를 기록하였고, 원고 회사는 2017. 4. 1. 참가인 근로자를 보직해임하고 판매예비로 분류한 후, 2017. 5. 1. 영업전문직군에서 사무직군으로 전환하여 남부영업부 지원팀(부산 소재)으로 전보하고 차장직급과 채권관리 직무 부여하였다. 한편, 원고 회사는 2016. 7. 1. 부로 영업소장 평가방식 일부 변경한 바 있는데, ‘업적평가항목(매출, 이익)’의 비중을 60%→50%로 축소하는 반면 ‘과정관리평가항목(예누리, 반품, 미수, 활동일지, 취약점 개선)’의 비중을 30%→60%로 확대하였다. 이러한 변경은 매출과 이익의 경우, 각 영업소 특성이나 외부영향을 받는 것으로 영업소장 개인의 역량을 정확히 평가하는 항목이 되기 어렵다는 이유에서였으며, 변경 시행 전 참가인 근로자를 포함한 영업소장들에게 원고 회사 측의 설명과 안내가 이루어졌다. 이에 참가인은 경남지노위에 부당인사조치라며 금전손실(사무직군으로 전환됨에 따라 못 받게 된 판매인센티브) 청구, 원상 직무 복귀를 요구하는 구제신청을 하였다. <심급별 결과> [경남지노위] 부당한 인사평가에 기해 이루어진 부당한(업무상 필요성 결여, 생활상 불이익 극심 등) 인사발령이라고 판정 [중노위] 초심 유지 [1심 법원] 재심 유지

[2심 법원] 업무상 필요성이 있고, 감수 가능한 생활상 불이익이 있을 뿐이며, 신의칙상 절차도 모두 거친 정당한 인사권 행사라는 이유로 1심 판결 및 재심판정을 취소
[대법원] 심리불속행기각

판결 요지

근로자에 대한 전직이나 전보처분은 근로자가 제공하여야 할 근로의 종류·내용·장소 등에 변경을 가져온다는 점에서 근로자에게 불이익한 처분이 될 수도 있으나, 원칙적으로 인사권자인 사용자의 권한에 속하므로 업무상 필요한 범위 안에서는 상당한 재량을 인정하여야 하고, 그것이 근로기준법 제23조 제1항에 위배되거나 권리남용에 해당하는 등 특별한 사정이 없는 한 무효라고 할 수 없고, 전직처분 등이 정당한 인사권의 범위 내에 속하는지의 여부는 당해 전직처분 등의 업무상의 필요성과 전직에 따른 근로자의 생활상의 불이익을 비교·교량하고, 근로자가 속하는 노동조합(노동조합이 없으면 근로자 본인)과의 협의 등 그 전직처분을 하는 과정에서 신의칙상 요구되는 절차를 거쳤는지 여부를 종합적으로 고려하여 결정하여야 한다(대법원 2009. 4. 23. 선고 2007두20157 판결).

전보처분 등을 함에 있어서 근로자 본인과 성실한 협의절차를 거쳤는지의 여부는 정당한 인사권의 행사인지의 여부를 판단하는 하나의 요소라고는 할 수 있으나, 그러한 절차를 거치지 아니하였다는 사정만으로 전보처분 등이 권리남용에 해당하여 당연히 무효가 된다고는 볼 수 없다(대법원 1997. 7. 22. 선고 97다18165,18172 판결).

※ 대법원이 심리불속행기각함에 따라, 위 요지는 2심 법원의 판결 요지를 인용하였다.

패소 이유 (사실관계에 관한 인정 차이)

중노위와 법원이 파악한 기초 사실에는 거의 차이 없으나, 각 사실관계의 경중을 달리 평가함으로써 인사평가 및 인사발령의 정당성을 달리 판단하였다.

중노위는 ① 원고 회사는 영업소장 평가결과를 인사관리 참고자료로 활용하고 있는 점, ② 2015년과 2016년 평가에 따른 인사조치에 영업소장 보직 해임과 직군전환이 함께 있는 점, ③ 참가인 근로자는 2016년 상반기 평가 점수가 28명 중 12위였으나, 2016. 5. 1. 영업실적이 좋지 않은 창원영업소장으로 전보된 후 평가 점수가 29명 중 29위로 하락한 점, ④ 영업소 실적 개선을 위해서는 3개월에서 6개월 이상의 기간이 필요하므로 이 기간이 포함된 하반기 평가는 참가인 근로자의 업무능력이 반영된 것이라 보기 어려운 점, ⑤ 2017년 1분기에는 창원영업소의 실적이 개선되어 남부영업부 12개 영업소 중에서 판매달성률 1위를 한 점 점 등을 종합할 때, 인사발령의 기준이 되는 2016년 영업소장 평가는 정당하지 않다고 보았다. 또한 정당하지 않은 평가를 기준으로 실시한 이 사건 인사발령은 업무의 능률증진이나 근로자의 능력개발과 근로의욕의 고양 등 기업의 합리적 운영에 기여하지 못하는 것으로 업무상 필요성이 인정되지 않고, 판매인센티브를 지급받지 못하는 경제적 불이익과 계속된 사직 권고라는 정신적 불이익 등 생활상 불이익이 크므로 인사발령 역시 부당하다고 판정하였다.

반면 2심 법원은 합리적 재량권 범위를 벗어난 인사권 남용이 아니라고 보아 중노위 재심판정과 1심 판결을 취소하였다. 1) 먼저 <업무상 필요성 인정 여부>에 관해, ‘▲2016년도 중에 평가방식을 일부 변경한 것은 영업소장 개인의 역량을 정확히 평가하기 위한 것으로 객관적 합리성을 갖춘 것인 점, ▲반품이 과다했던 10개 영업소에 2016년도 상반기 평가에서 별도의 평가기준(반품점수 비중 상향)을 적용한 것은 차별소지가 있으나, 이들 중 일부 영업소장은 평가결과 상위권을 차지한 반면 참가인 근로자는 모든 영업소에 동일 기준을 적용한 하반기 평가에서조차 최하위를 기록한 사실에 비추어, 해당 평가가 편파적·자의적·주관적이어서 참고인 근로자에게 합리적 이유 없는 차별이라고 보기 어려운 점, ▲참고인 근로자가 2016년도 영업평가에서 여러 항목에 걸쳐 고르게 낮은 평가 받은 점(비록 2017년 1분기에 판매달성률 항목이 개선되었으나 이

점만으로 인사발령의 업무상 필요성을 곧바로 부정할 수 없다), ▲원고 회사 취업규칙이 ‘업무형편에 따라 사원에게 배치전환, 직무변경 기타 필요한 이동을 명할 수 있다’라고 규정하고, 인사권자인 원고 회사로서는 회사의 조직, 구성, 업무의 성질과 내용, 직원의 평소 근무태도, 평정과 평판 등을 종합적으로 고려하여 업무상 필요한 범위 내에서 상당한 재량을 가지고 근로자를 배치할 수 있고, 실제로 원고 회사는 업무 효율 증대를 위해 영업소장 평가결과에 따라 보직해임 및 전보하는 인사관행이 있었다는 점’ 등을 근거로 업무상 필요성을 인정하였다. 2) <생활상 불이익 존재 여부>에 관해서는 ‘▲이 사건 인사발령 후에도 종전과 같은 수준의 기본급, 비연고지 지원급, 식대를 수령한 점, ▲판매인센티브는 사무직군으로 전환됨에 따라 받지 못하게 된 것일 뿐인 점, ▲이 사건 인사발령으로 부여받은 채권관리업무가 전혀 수행할 수 없거나 완전히 새로운 업무가 아닌 점 등’에 비추어 감내할 수 없는 생활상 불이익은 없는 것으로 보았다. 3) 2017. 3월부터 이 사건 인사발령 전까지 상급자와 4~5차례 면담을 진행한 사실에 비추어, 신의칙상 요구되는 협의절차 역시 거친 것으로 보았다.

중노위가 패소한 것은 사실관계에 대한 경중 판단, 법적의미 판단에서 법원과 달리 판단한 데에서 기인한 것으로 보이고, 1심 승소 후 2심에서 패소하였기에 대법원의 최종적 판단을 받고자 한 것으로 보인다. 그러나 상고심이 법률심이라는 점을 고려할 때, 중노위가 패소한 것이 법리적 판단에 관한 차이 때문이 아니라, 단순히 사실관계에 대한 평가의 차이에서 비롯된 것이라면 상고 여부를 보다 심사숙고할 필요가 있다. 심리불속행기각 비율을 점검하고, 그 가능성에 대한 충분한 법적 검토가 필요할 것으로 보인다.

일련번호	2020-14					
판결번호	대법원 2020. 3. 12. 선고 2019두00000					
중노위판정번호	중노위 2018. 4 30. 2018부해233					
사건 종류	부당해고					
세부 쟁점	갱신기대권, 기간의 정함이 있는 근로계약 무기계약전환 예외 등					
심급별 소송결과	1심 법원	재심 취소	2심 법원	항소 기각	대법원	상고 기각 (심리불속행)
상 고 인	중앙노동위원회위원장		참 가 인		김○○	
피상고인	○○○기술원		피고측 대리인 선임 여부		선임 안 함	
노동조합 지원 여부	없음		원고측 대리인 선임 여부		선임 함	
재심 결과	초심유지					
초심의 대법원 판례 일치여부	불일치		재심의 대법원 판례 일치여부		불일치	
기타 특이사항						

주요 사실관계

<사실 관계>

참가인 근로자는 2002. 7. 8. 정부출연연구기관인 원고 회사에 연구원(박사)으로 입사하여 수차례 계약을 갱신하였는데, <2011년도 인사위원회>에서 재계약 보류대상으로 심의를 받으며 '내외 신뢰회복이 필요'하다는 평가와 함께 1년의 재계약 체결하였고, <2012년도 인사위>에서는 '목표성과 달성 위해 얼마나 시간이 필요하냐'는 얘기를 듣고 다시금 1년 재계약 하였다. <2016년도 인사위>에서 '저성과자'로 재계약 심의 받으며 '직무수행계획서의 신뢰성과 구체성 결여, 2년 연속 인사평가 최하위임에도 실적 개선의지 안 보임'이라는 평가와 함께, 1년(2016.7.8. ~ 2017.7.7) 재계약하되 자구노력과 회사의 지원 프로그램을 시행하여 1년 후 다시 판단하기로 의결하였다.

한편 참가인은 2010~2013년 최하평가를 받고, 2014년에 저성과를 이유로 타부서로 전보된 이후 2014~2016년에도 최하등급을 받았다. 인사평가는 정량(성과)평가 80%·정성(역량)평가 20%로 구성되어 있고, 정량평가에는 재정기여도, 논문·특허·기술료 등 개인성과 항목이 있었는데, 참가인 근로자의 성과는 전보 이후 2017년까지 연구과제 3건·논문 2건·특허 3건에 불과하였다.

2017. 7. 24 인사위원회는 참가인에 대하여 '최근 3년 간 인사평가 최하위 등급을 받는 등 저성과자에 해당'한다는 이유로 면직 의결하였고(단체협약에 따라 사전에 노사 동수로 구성된 계약조정위원회의 심의를 거쳤다), 2017. 8. 7. '재임용 기준 미충족에 따른 고용계약기간 종료로 인해 2017. 9. 7.자 당연면직'을 통지하였는 바, 이에 참가인이 부당해고 구제신청을 하였다.

※ 원고 회사의 인사규정 및 단체협약에는 '계약기간 중 3회 이상 업무평가 최하를 받을 경우 노사 동수의 계약조정위원회 심의를 거쳐 당연면직 된다'는 취지의 조항이 존재한다.

<심급별 결과>

[전남지노위] 기간의 정함이 없는 근로자에 대한 정당한 이유 없는 부당해고라고 판정

[중노위] 초심 유지

[1심 법원] 무기계약전환 예외에 해당하는 기간제근로자이고, 갱신거절에 합리적 이유 있다며 재심판정 취소

[2심 법원] 항소 기각

[대법원] 심리불속행기각

판결 요지

근로계약기간을 정한 근로계약서를 작성한 경우 처분문서인 근로계약서의 문언에 따라 특별한 사정이 없는 한 근로자와 사용자 사이에는 기간의 정함이 있는 근로계약을 맺었다고 보아야 하고, 이 경우 근로계약기간이 끝나면 그 근로관계는 사용자의 해고 등 별도의 조치를 기다릴 것 없이 당연히 종료함이 원칙이다. 다만 기간을 정한 근로계약서를 작성한 경우에도 예컨대 단기의 근로계약이 장기간에 걸쳐서 반복하여 갱신됨으로써 그 정한 기간이 단지 형식에 불과하게 된 경우 등 계약서의 내용과 근로계약이 이루어지게 된 동기 및 경위, 기간을 정한 목적과 채용 당시 계속근로 의사 등 당사자의 진정한 의사, 근무기간의 장단 및 갱신 횟수, 동종의 근로계약 체결방식에 관한 관행 그리고 근로자보호법규 등을 종합적으로 고려하여 그 기간의 정함이 단지 형식에 불과하다는 사정이 인정되는 경우에는 계약서의 문언에도 불구하고 사실상 기간의 정함이 없는 근로계약을 맺었다고 볼 것이며, 이 경우 사용자가 정당한 사유 없이 갱신 계약 체결을 거절하는 것은 해고와 마찬가지로 무효이다(대법원 2010. 6. 24. 선고 2007다31471 판결 등 참조).

근로계약, 취업규칙, 단체협약 등에서 기간만료에도 불구하고 일정한 요건이 충족되면 당해 근로계약이 갱신된다는 취지의 규정을 두고 있거나, 그러한 규정이 없더라도 근로계약의 내용과 근로계약이 이루어지게 된 동기 및 경위, 계약 갱신의 기준 등 갱신에 관한 요건이나 절차의 설정 여부 및 그 실태, 근로자가 수행하는 업무의 내용 등 당해 근로관계를 둘러싼 여러 사정을

종합하여 볼 때 근로계약 당사자 사이에 일정한 요건이 충족되면 근로계약이 갱신된다는 신뢰관계가 형성되어 있어 근로자에게 그에 따라 근로계약이 갱신될 수 있으리라는 정당한 기대권이 인정되는 경우에는 사용자가 이에 위반하여 부당하게 근로계약의 갱신을 거절하는 것은 부당해고와 마찬가지로 아무런 효력이 없고, 이 경우 기간만료 후의 근로관계는 종전의 근로계약이 갱신된 것과 동일하다(대법원 2011. 4. 14. 선고 2007두1729 판결 등 참조).

기간제법 제4조 제1항 단서의 예외 사유에 해당하지 않는 한 2년을 초과하여 기간제근로자로 사용하는 경우 기간의 정함이 없는 근로계약을 체결한 것으로 간주하고 있으나, 기간제법의 입법 취지가 기간제근로자 및 단시간근로자에 대한 불합리한 차별을 시정하고 근로조건 보호를 강화하기 위한 것임을 고려하면, 기간제법 제4조 제1항 단서의 예외 사유에 해당한다는 이유만으로 갱신기대권에 관한 위 법리의 적용이 배제된다고 볼 수는 없다(대법원 2016두50563 판결).

기간제 근로계약을 체결한 근로자에게 이와 같이 근로계약 갱신에 대한 정당한 기대권을 인정하는 취지는 기간제 근로계약의 남용을 방지함으로써 기간제근로자에 대한 불합리한 차별을 시정하고 기간제근로자의 근로조건 보호를 강화하려는 데에 있다. 그러므로 근로자에게 이미 형성된 갱신에 대한 정당한 기대권이 있음에도 불구하고 사용자가 이를 배제하고 근로계약의 갱신을 거절한 데에 합리적 이유가 있는지가 문제될 때에는 사용자의 사업 목적과 성격, 사업장 여건, 근로자의 지위 및 담당 직무의 내용, 근로계약 체결 경위, 근로계약의 갱신에 관한 요건이나 절차의 설정 여부와 그 운용 실태, 근로자에게 책임 있는 사유가 있는지 여부 등 당해 근로관계를 둘러싼 여러 사정을 종합하여 갱신 거부의 사유와 그 절차가 사회통념에 비추어 볼 때 객관적이고 합리적이며 공정한지를 기준으로 판단하여야 한다(대법원 2017. 10. 12. 선고 2015두44493 판결).

※ 대법원이 심리불속행기각함에 따라, 위 요지는 1·2심 법원의 판결 요지를 인용하였다.

패소 이유 (사실관계에 관한 인정 차이)

중노위와 법원은 기간제근로자 여부부터 상반되는 판단을 하여, 전혀 다른 결론으로 나아갔다.

중앙노동위원회는 참가인 근로자가 2002. 7. 8. 입사한 후 근로계약기간의 단절 없이 1년·3년 단위로 수차례 계약을 갱신하여 무기계약 근로자로 전환되었으므로, 면직처분은 근로기준법 제23조의 제한을 받는 해고에 해당하고, ‘인사평가 최하위 등급을 받았다는 것만으로 해고의 정당성 인정하기 어렵다. 저성과자라 하더라도 해고는 최후 수단이다. 평가의 주된 목적은 근로자 역량 보완, 향상임에도 불구하고 평가등급만 통지할 뿐 근로자 요구 시에만 구체적 내용을 열람할 수 있어 근로자의 자율적 개선을 유도하지 못하여 목적 달성이 불가능하다. 회사가 지속적인 면담이나 경고조치 등을 행한 사실이 없다. 근로자의 저성과로 인해 회사에 어떠한 손실이 발생되었는지 여부가 구체적으로 확인되지 않는다’는 점 등을 들어, 사회통념상 고용관계를 유지할 수 없을 정도에 이르지 않아 이 사건 면직은 부당해고라고 판정하였다.

반면 1·2심 법원은 참가인 근로자를 기간제 근로자로 인정한 후, 갱신기대권 및 갱신거절의 합리성 판단으로 나아갔다. 먼저 법원은 ‘재임용 규정 및 실태상 박사연구원은 통상 3년의 재계약을 체결하였으나 참가인 근로자는 장기간 저성과로 인해 인사위원회 재심의를 거쳐 1년 후 재평가를 전제로 단 1년 기간의 재계약을 체결한 점, 원고 회사가 노동조합과 재계약 갱신거절에 관한 단체협약을 체결한 점 등’에 비추어 갱신 결정 절차를 단지 형식에 불과한 것으로 볼 수 없다며 기간의 정함이 있는 근로자로 보았다. 아울러 참가인 근로자는 정부출연연구기관의 박사연구원으로 연구업무에 직접 종사하고 있어, 기간제법 제4조 제1항 단서 등에 따른 무기계약전환 예외 사유에 해당하여 무기계약으로 전환되지도 않았다고 판단하였다.

그리고 이를 전제로 기간제 근로자의 갱신기대권 인정 및 갱신거절의 합리성 여부를 검토하였는데, ‘인사규정에 재계약 관련 규정 존재, 입사 이후 장기간 재직하며 수차례 재계약을 체결한 점 등’을 들어 갱신기대권은 인정하였으나,

‘인사평가가 합리적이고 공정한 것으로 보이는 점(특히 인사평가의 구성이 정량평가 80%와 정성평가 20%로 이루어져있고, 평가 항목이 세분화·객관화(개인성과, 센터실적, 재정기여도, 조직기여도 등)되어 있는 점), 인사규정 및 단체협약의 당연면직 사유인 저성과자에 해당(3년 연속 최하등급)하는 점, 회사는 저조한 성과에도 불구하고 여러 차례 계약을 갱신하는 등 개선 기회

부록.1. 주요 사건 경과 및 패소 원인 분석

를 부여한 점 등'의 사실에 주목하여 갱신거절에 합리성이 있다고 보아 이 사건 면직처분이 정당하다며 중앙노동위원회의 재심판정을 취소하였다.

(※ 앞서 2014년에 이루어진 저성과자 전보 처분에 대해서도 '당시 참가인과 함께 전보된 자들 모두 이후 양호한 평가를 받고 복귀한 점에 비추어 해당 전보처분은 저성과자 퇴출목적 아니라 업무성과 및 역량개선을 위한 적법한 조치였다고 보았다.)

기간제 근로자 여부는 차치하더라도 면직의 정당성 판단에 있어, 기 제출된 자료 및 인정 사실들에 비추어 보더라도 중앙노동위원회가 제시한 부당해고의 이유가 다소 빈약한 듯하다. 즉 중앙노동위원회가 이 사건 판정이유를 통해 저성과자 해고의 정당성 판단에 관해, 준사법기관으로서 수급자들에게 의미 있는 예측가능성을 제공하지 못하고 있는 것으로 보인다. 향후 저성과자 인사관리를 둘러싼 분쟁이 더욱 늘어날 것으로 예상되는 상황에서 중노위 판정의 공정성과 신뢰성을 높이기 위한 대책 마련이 필요한 것으로 보인다.

일련번호	2020-16					
판결번호	대법원 2020. 4. 29. 선고 2020두00000					
중노위판정번호	중노위 2018. 6. 20. 2018부해416					
사건 종류	부당해고					
세부 쟁점	갱신기대권, 기간제 사용기간제한 예외, 단체협약 적용범위					
심급별 소송결과	1심 법원	재심 취소	2심 법원	항소 기각	대법원	상고 기각 (심리불속행)
상 고 인	중앙노동위원회위원장		참 가 인		김○○	
피상고인	○○○○공사		피고측 대리인 선임 여부		선임 안 함	
노동조합 지원 여부	없음		원고측 대리인 선임 여부		선임 함	
재심 결과	초심유지					
초심의 대법원 판례 일치여부	불일치		재심의 대법원 판례 일치여부		불일치	
기타 특이사항						

주요 사실관계

<사실관계>

원고 회사는 2010년대 들어 본격 중장기 해외사업확대를 추진하면서, 2012. 9월 '해외사업 프로젝트 기획 및 관리, 해외사업 타당성 분석, 해외사업 리스크 관리 등의 업무를 담당할 해외투자사업 프로젝트 실무경력 3년 이상의 전문가를 채용하며, 계약기간 2년(업무성과에 따라 정규직 전환 가능)'이라는 내용의 채용공고를 하였고, 이를 통해 참가인 근로자를 채용하였다. 한편 원고

회사의 계약직 관리규정에는 근무실적 평가(업무실적 60점, 직무수행능력 20점, 직무수행태도 20점)결과 일정 수준 이상이면 정규직 전환이 가능하다고 명시되어 있었다.

참가인은 총 4차례 근로계약을 체결하고, 해외공항 사업수주 제안서 작성, 네트워크 구축, 투자사업 추진 등 업무를 수행하였다.

- 1차 근로계약: 기간 2012.12.3.~2014.12.2. / 연봉 65,000,010원 / 평가결과 90점
- 2차 근로계약: 기간 2014.12.3.~2015.12.2. / 연봉 68,261,975원 / 평가결과 96점
- 3차 근로계약: 기간 2015.12.3.~2016.12.2. / 연봉 71,014,763원 / 평가결과 75점
- 4차 근로계약: 기간 2016.12.3.~2017.12.2. / 연봉 75,874,604원 / 평가결과 상반기 63, 하반기 45점

2016년 초, 원고 회사는 상임감사위원으로부터 '해외 사업 축소 및 인력 조정'을 골자로 한 감사 결과 통보를 받았고, 이를 계기로 해외사업규모를 축소하면서 이사회 결의를 거쳐 부서 통합 및 인력 감축을 실시하였는데 참가인의 담당업무도 축소되었다. 이후 원고 회사가 4차 계약기간 만료 통보를 하자 참가인 근로자는 부당해고 구제신청을 하였다.

<심급별 결과>

[서울지노위] 갱신기대권이 있고 갱신거절에 합리적 이유가 없어 부당해고라고 판정

[중노위] 초심 유지

[1심 법원] 갱신기대권 인정되나 거절에 합리적 이유가 있다고 보아 재심판정 취소

[2심 법원] 항소 기각

[대법원] 심리불속행기각

판결 요지

기간을 정하여 근로계약을 체결한 근로자의 경우, 그 기간이 만료됨으로써 근로자로서의 신분관계는 당연히 종료되고, 근로계약을 갱신하지 못하면 갱신거절의 의사표시가 없어도 그 근로자는 당연히 퇴직되는 것이 원칙이다. 그러나 근로계약, 취업규칙, 단체협약 등에서 기간이 만료되더라도 일정한 요건이 충족되면 당해 근로계약이 갱신된다는 취지의 규정을 두고 있거나, 그러한 규정이 없더라도 근로계약의 내용과 근로계약이 이루어지게 된 동기 및 경위, 계약갱신의 기준 등 갱신에 관한 요건이나 절차의 설정 여부 및 그 실태, 근로자가 수행하는 업무의 내용 등 당해 근로관계를 둘러싼 여러 사정을 종합하여 볼 때, 근로계약 당사자 사이에 일정한 요건이 충족되면 근로계약이 갱신된다는 신뢰관계가 형성되어 있어 근로자에게 그에 따라 근로계약이 갱신될 수 있으리라는 정당한 기대권이 인정되는 경우에는, 사용자가 이에 위반하여 부당하게 근로계약의 갱신을 거절하는 것은 부당해고와 마찬가지로 아무런 효력이 없고, 이 경우 기간만료 후의 근로관계는 종전의 근로계약이 갱신된 것과 동일하다(대법원 2011. 4. 14. 선고 2007두1729 판결, 대법원 2014. 2. 13. 선고 2011두12528 판결 등 참조).

노동조합법 제35조는 '하나의 사업 또는 사업장에 상시 사용되는 동종의 근로자 반수 이상이 하나의 단체협약의 적용을 받게 된 때에는 당해 사업 또는 사업장에 사용되는 다른 동종의 근로자에 대하여도 당해 단체협약이 적용된다'고 규정한다. 이에 따라 단체협약의 적용을 받게 되는 동종의 근로자라 함은 당해 단체협약의 규정에 의하여 그 협약의 적용이 예상되는 자를 가리키며, 단체협약 등의 규정에 의하여 조합원의 자격이 없는 자는 단체협약의 적용이 예상된다고 할 수 없어 단체협약의 일반적 구속력이 미치는 동종의 근로자라고 할 수 없다(대법원 1997. 10. 28. 선고 96다13415 판결, 2003. 6. 27. 선고 2002다23611 판결 등 참조).

※ 항소 기각, 상고심 심리불속행기각에 따라, 위 요지는 1심 법원의 판결 요지를 인용하였다.

패소 이유 (사실관계에 관한 인정 차이, 주요 법리에 대한 판단 차이)

<기간제 사용기간제한 예외 해당 여부>에 관해, 중노위와 법원 모두 참가인 근로자가 '상당한 전문적 지식과 경험을 갖춘 전문가'로서 직무를 수행하여, 기간제법 제4조 제1항 제6호 및 동법 시행령 제3조 제5호에 기해, 기간제한 예외에 해당하는 것으로 보았다. (* 통계법 제22조에 따라 고시된 한국표준직업분류 대분류 2 '전문가 및 관련 종사자'-세분류 '27159 그 외 경영 및 진단 전문가' '27340 조사전문가' 직업에 종사하는 사람으로서, 소득세법 제20조 제1항에 따른 최근 2년간 연평균 근로소득이 노동부장관이 최근 조사한 고용형태별근로실태조사의 한국표준직업분류 대분류 2의 직업에 종사하는 사람의 근로소득 상위 100분의 25인 경우)

<갱신기대권 유무>에 관해서도, ▲채용공고에서 2년 계약기간 후 업무성과에 따라 정규직 전환 가능하다고 공지 ▲회사의 '계약직 채용 및 관리예규'는 기간제 계약기간은 2년 내에서 운영할 수 있으나 계약 연장이 필요한 경우 예산 범위 내에서 매 1년 이내의 재계약 체결이 가능하고, 근무실적 평가결과 일정 수준 이상인 경우 심사거처 정규직 직원으로 전환 가능하다고 규정(근로계약의 연장 또는 정규직 전환의 절차나 요건에 관한 근거가 존재) ▲실제 원고 회사는 매년 정기·수시로 참가인 근로자에 대한 근무실적평가를 실시하고 계약 연장의 필요 여부를 평가함 ▲해외사업 규모 축소로 참가인 근로자의 업무 역시 상당히 축소되었으나 주로 수행한 해외투자업무는 지속되고 있었으므로 계약갱신을 기대할수 없을 정도로 담당 업무가 더 이상 존재하지 않는 경우로 보기 어려운 점 등을 이유로 중노위와 법원이 공통적으로 갱신기대권을 인정하였다.

그러나 <갱신거절의 합리적 이유 여부>에 관해 중노위와 법원은 결론을 달리하였는데, 중노위가 합리적 이유가 없어 부당해고라고 본 반면, 법원은 합리적 이유를 인정하여 부당해고가 아니라고 보았다.

중노위는 근무실적 평가에 주목하여 '근로계약 갱신 거절의 중요한 근거가 되는 근무실적 평가 점수의 연도별 편차가 크고, 평가기준 및 평가항목이 없어 고과제도로써 타당성과 신뢰성을 갖추지 못하였다'는 이유로 갱신 거절은 부당하다고 보았다.

반면 법원은 '직무의 수요'에 주목하였다. 법원은 원고 회사가 당초 해외투자사업 확대를 본격 추진하면서 관련 전문인력의 총원 필요성 때문에 참가인 근로자를 채용한 것인 만큼, 근로계약 갱신 여부를 결정함에 있어 가장 중요하게 고려되어야 할 요소는 '업무에 대한 수요'라고 보았다. 그러면서 업무에 대한 수요는 원고 회사의 해외투자사업 진행정도와 규모 및 여건과 밀접한 관련이 있고, 2016년부터 원고 회사의 해외사업이 축소되어 당해 인력의 총원 및 유지 필요성이 소멸하였으므로 갱신 거절에 합리적 사유가 있다고 판단하였다. (참가인 근로자의 근무평가 연도별 편차가 큰 것에 관해서는 원고 회사의 중장기 계획 수정에 따라 참가인 담당업무의 중요성 낮아지고, 실제 참가인의 발굴사업 실적이 없었던 데 따른 결과일 뿐이라고 보았다.)

한편 중노위는 비록 참가인 근로자가 원고 회사 노동조합의 조합원은 아니나 노동조합법 제35조(일반적 구속력)에 의해 원고 회사의 단체협약이 동종의 근로자인 참가인에게도 적용됨에도 불구하고, 원고 회사가 일방적으로 계약 종료 통보를 한 것은 단체협약이 정한 이의신청권을 박탈하여 중대한 절차적 위법이 있다고 주장하였다.

이에 법원은 노동조합법 제35조의 "단체협약 등의 규정에 의하여 조합원의 자격이 없는 자는 단체협약의 적용이 예상된다"고 할 수 없어 단체협약의 일반적 구속력이 미치는 동종의 근로자라고 할 수 없다"는 대법원 판례를 인용한 뒤, 원고 회사의 단체협약 제21조 제3항에 '인사결정 사항에 이의가 있는 경우 해당 조합원이나 조합은 10일 이내에 이의신청을 할 수 있으며 공사는 해당 조합원과 조합대표자에게 의견진술 및 변론의 기회를 부여한다'는 규정이 있긴 하나, 기간제 근로자에게 조합원 자격을 부여하고 있지 아니한 사실, 2010년부터 2018년까지 위 노동조합에 가입한 기간제 근로자는 전혀 없는 사실, 참가인 근로자 또한 노동조합에 가입되어 있지 않고 조합비를 납부한 적도 없는 사실에 비추어, 참가인 근로자는 노동조합의 조합원이 아닐 뿐만 아니라 조합원 자격도 없어 단체협약이 적용되지 않는다면 중노위의 주장을 인정하지 않았다.

이 사건에서 법원과 중노위 결론의 차이는 '갱신거절의 합리적 사유 존부 판단 시 중시한 사실 관계가 달랐던 점, 근무실적 평가의 적법성 판단 시 사실관계에 대한 평가를 달리한 점, 단체협약의 일반적 구속력에 관한 노동조합법 제35조의 해석·적용을 달리한 점'에서 기인하는 것으로 보인다.

그 중에서도 주목할 부분은 법원이 채용부터 근무실적평가, 근로계약관계 종료에 이르기까지 고용관계의 전과정에서 '사업과의 연계성'을 중시했다는 점이다. 이는 중노위가 판정 시 중요하게 고려하지 않은 부분이다. 다만 이 사건의 경우 사실관계에 특수성(참가인 근로자가 해외투자사업 전문가였다는 점, 객관적으로 당해 업무가 분산·축소·소멸되고 있었던 점)이 있어, 갱신거절의 합리성 판단에 있어 법원의 판단기준으로 일반화하기에는 신중할 필요가 있어 보인다.

이런 특수성 때문에 중노위로서는 1심 판결에 불복하여 항소할 여지가 충분히 있었던 것으로 생각되지만, 상고심이 법률심이라는 점을 고려할 때 대법원 상고 여부는 좀 더 신중히 검토할 필요가 있다. 대법원에서 심리불속행기각 가능성이 높음에도 무리하게 상고를 제기하는 것은 분쟁 상태를 장기화하고, 이는 곧 중노위 본연의 존재이유인 전문성·신속성을 스스로 훼손하는 결과를 초래할 수 있기 때문이다.

일련번호	2020-17					
판결번호	대법원 2020. 1. 30. 선고 2019두00000					
중노위판정번호	중노위 2018. 6. 25. 2018부해452					
사건 종류	부당해고					
세부 쟁점	당사자적격, 해고 서면통지절차 위반					
심급별 소송결과	1심 법원	재심 취소	2심 법원	항소 기각	대법원	상고기각 (심리불속행)
상 고 인	김○○		참 가 인		김○○	
피상고인	○○ 주식회사		피고측 대리인 선임 여부		선임 안 함	
노동조합 지원 여부	없음		원고측 대리인 선임 여부		선임 함	
재심 결과	초심취소					
초심의 대법원 판례 일치여부	일치		재심의 대법원 판례 일치여부		불일치	
기타 특이사항	피고(중앙노동위원회위원장)이 아닌 피고보조참가인이 상고함					

주요 사실관계

<사실관계>

2017. 9월 경 원고 회사의 회장은 자신의 형제인 베트남 법인(원고 회사가 지분 100% 보유) 대표로부터 연락을 받고 참가인 근로자와 면담을 하였다. 참가인은 2017.10월 중 베트남을 방문하여 베트남 법인 대표와 면접을 보고 귀국하였다가, 2017. 11. 27. 베트남으로 출국하여 근로계약서에 자필 서명하고 그날부터 기숙사에 거주하며 근무를 시작하였다. (근로계약서는 영어와 베트남어로 작성된 것이었으며, 고용자 및 근무처는 베트남 법인으로 기재되어 있었고 고용자란에

부록.1. 주요 사건 경과 및 패소 원인 분석

베트남 법인의 날인과 법인 대표의 자필 서명이 포함되어 있었다.)

이후 베트남 법인은 3개월의 수습기간 중이던 참가인 근로자가 업무처리가 미숙하여 정식채용이 어렵다 판단하였고, 당시 참가인 근로자와 갈등을 겪고 있던 베트남 법인은 원고 회사의 임원에게 연락을 취해 참가인 근로자에게 해고 통보해줄 것을 요청하였으며, 원고 회사의 임원은 2018. 1. 13. 참가인에게 구두로 해고를 통보하였다. 이에 참가인 근로자가 베트남 법인이 아닌 원고 회사가 실질적 사용자라며, 원고 회사를 피신청인으로 하여 부당해고 구제신청을 하였다.

<심급별 결과>

[경기지노위] 원고 회사는 당사자적격(피신청인)이 없다며 근로자의 구제신청을 각하

[중노위] 원고 회사는 실질적 사용자로서 당사자적격이 인정되고, 해고 서면통지절차를 위반하여 부당해고라고 판정

[1심 법원] 원고 회사는 피신청인(사용자) 당사자적격이 없다며 재심판정 취소

[2심 법원] 항소 기각

[대법원] 심리불속행기각

판결 요지

처분문서는 성립의 진정함이 인정되는 이상 법원은 그 기재 내용을 부인할 만한 분명하고도 수긍할 수 있는 반증이 없는 한 처분문서에 기재되어 있는 문언대로 의사표시의 존재 및 내용을 인정해야 한다(대법원 2013. 6. 13. 선고 2012다96403 판결 등 참조).

※ 상고심 심리불속행기각에 따라, 위 요지는 2심 법원의 판결 요지를 인용하였다.

패소 이유 (사실관계에 관한 인정 차이)

중노위는 원고 회사와 베트남 법인이 형식상 별개 법인의 형태를 취하고 있으나, 원고 회사의 회장이 참가인 근로자를 면접하고 채용 결정 과정에 관여한 점, 원고 회사의 상무가 참가인 근로자를 해고한 점 등을 들어 원고 회사가 “채용과 해고 등의 결정에 주도적으로 인사권을 행사”하였으므로 실질적인 사용자라고 판단하였다. 그리고 이를 전제로, 해고사유와 시기를 서면통지하지 않았으므로 부당해고라고 결론 내렸다(“근로자가 수습기간 중이라 하더라도, 시용근로관계에서 이 사건 사용자가 이 사건 근로자의 본 근로계약 체결을 거부하는 경우 구체적인 거부사유를 서면으로 통지하여야 함에도 불구하고 이 사건 사용자가 이 사건 근로자를 해고하면서 해고사유와 해고시기를 서면으로 통지하지 않은 것은 해고사유의 존재 여부와 관계없이 부당하다”).

반면 법원은 ‘원고 회사와 근로계약을 작성한 바 없는 점, 원고 회사에 근로를 제공하거나 원고 회사로부터 임금을 지급받지 않은 점, 원고 회사와 베트남 법인은 실질적으로 별개의 법인인 점 등’을 들어 원고 회사의 사용자성을 부정하였다.

▲참가인 근로자는 베트남으로 출국하여 고용자와 근무처가 베트남 법인으로 기재되어 있고, 고용자 란에 베트남 법인의 날인과 베트남 법인 대표의 자필 서명이 들어있는 근로계약서의 근로자 란에 자필 서명하여 베트남 법인과 근로계약을 체결한 점(원고와 작성한 근로계약서 없음),

▲베트남에서 베트남 법인이 제공한 기숙사에 기거하면서 근로를 제공하고 베트남 법인으로부터 임금을 지급받은 점,

▲비록 베트남 법인은 2016. 6. 30. 원고의 투자에 의해 설립되었고, 원고가 지분 100%를 보유하고 있으며 베트남 법인의 대표와 원고 회사 회장이 형제관계이긴 하나, ‘각각 별도로 재무제표를 작성하여 독립적으로 회계를 운영하고 있는 사실, 베트남 법인의 2017년 총 매출은 약 36억 원, 원고의 2017년 매출은 약 143억 원, 베트남 법인에 대한 매출은 약 82억 원, 베트남 법인으로부터의 매입은 약 5,900만 원 수준인 사실, 베트남 법인은 원고 회사 외에 다양한 국내외 업체와 거래를 하고 있는 사실, 베트남 법인은 관리 부문, 영업 부문, 생산관리부문, 생산 부문

등의 조직구조로 구성되어 있고 335명의 직원이 근무하고 있는 사실 등'에 비추어, 원고 회사와 베트남 법인 간의 재산과 업무 및 대외적인 기업거래활동 등이 명확히 구분되어 있지 않고 양자가 서로 혼용되어 있다고 볼 만한 사정을 찾을 수 없는바, 베트남 법인이 형식상으로만 원고와 별개의 법인격을 갖추었을 뿐 실질적으로는 원고의 전적인 지배를 받고 있어 그 법인격이 부인된다고 볼 수 없고, 베트남 법인이 참가인의 사업주로서의 실체성이 결여되어 있다고 보기 어려운 점 등을 이유로, 참가인의 사용자는 베트남 법인이어서 원고 회사는 부당해고 구제신청의 피신청인이 될 당사자 적격이 없으므로 구제신청은 각하되어야 한다고 판단하였다.

요컨대, 중노위는 채용과 해고 등의 결정에 주도적으로 인사권을 행사한 점을 중시하여 원고 회사의 당사자적격을 인정하고 해고의 정당성 판단으로 나아간 반면, 법원은 실제로 참가인 근로자가 근로계약을 체결하고 근무하고 임금을 받은 곳이 원고 회사가 아니라 베트남 법인이라는 점을 중요하게 보면서, 양 회사가 실질적으로 별개의 독립법인으로 사업을 운영하고 있었다는 점에서 원고 회사는 참가인의 사용자가 아니고 따라서 당사자 적격이 없다고 결론 내렸다.

근로기준법상 사용자성 인정 여부에 관해 대법원 판례가 상당히 누적되어 있고, 특히 판례가 실제 근로계약 체결 당사자가 누구인지, 근로제공 및 지휘·감독이 이루어진 곳이 어디인지를 중요한 판단의 요소로 삼고 있는 점을 고려하면, 본 사건에서 중노위가 다소 무리하게 사용자성을 넓게 인정한 것이 아닌가 생각된다.

일련번호	2020-18					
판결번호	대법원 2020. 4. 9. 선고 2020두00000					
중노위판정번호	중노위 2018. 7. 9. 2018부해486					
사건 종류	부당정직					
세부 쟁점	이중징계, 징계사유 존부, 징계재량권 일탈·남용					
심급별 소송결과	1심 법원	재심 취소	2심 법원	항소 기각	대법원	상고기각 (심리불속행)
상 고 인	정○○		참 가 인		정○○	
피상고인	○○○○○○○○ 주식회사		피고측 대리인 선임 여부		선임 안 함	
노동조합 지원 여부	없음		원고측 대리인 선임 여부		선임 함	
재심 결과	초심취소					
초심의 대법원 판례 일치여부	일치		재심의 대법원 판례 일치여부		불일치	
기타 특이사항						

주요 사실관계

<사실관계>

원고 회사는 2017. 10. 10.부로 참가인 근로자에게 현장파견 발령을 하였으나(1차 인사명령), 참가인이 새 업무는 더 높은 역량을 요하여 역량이 부족하다며 거부하였고, 이에 원고 회사는 "2017. 10. 10.부터 징계위원회 개최일인 2017. 10. 12.까지 1차 인사명령을 불이행" 을 징계사유로 하여 6개월 감봉처분을 하였다(1차 징계).

이후에도 참가인 근로자는 현장발령 자체가 부당하다며 계속하여 현장파견을 거부하며 본사로 출근하였고, 원고 회사가 2017. 12. 6. 현장파견을 재발령 하였음에도(2차 인사명령) 계속해서 새 업무수행을 거부하였다. 이에 원고 회사는 "2017. 12. 6.부터 징계위원회 개최일인 2017. 12. 28.까지 현장발령 불이행" 을 징계사유로 하여 1개월 정직처분을 하였다(2차 징계).

참가인 근로자는 자신에 대한 징계는 보복성이고 부당하다며 노동위원회에 구제신청을 하였다.

<심급별 결과>

[서울지노위] 1, 2차 징계혐의사실이 달라 이중징계가 아니라며 구제신청 기각

[중노위] 1, 2차 징계혐의사실이 동일하여 이중징계라는 이유로 초심판정 취소

[1심 판결] 1, 2차 징계혐의사실이 각기 달라 이중징계에 해당하지 않고, 징계사유가 인정되며, 징계재량권 일탈·남용도 없어 정당한 징계처분이라며 재심판정 취소

[2심 판결] 항소기각

[대법원] 심리불속행기각

판결 요지

사용자가 근로자에 대하여 이중징계를 한 경우 일사부재리의 원칙이나 이중처벌금지의 원칙에 위배되어 그 징계처분은 무효이고, 이같이 이중징계에 해당된다고 하기 위해서는 선행 처분과 후행 처분이 모두 법적 성질상 징계처분이어야 하고, 선행 징계처분이 취소됨이 없이 유효하게 확정되어야 하며, 선행 징계처분과 후행 징계처분의 징계혐의사실이 동일하여야 한다(대법원 2000. 9. 29. 선고 99두10902 판결 참조).

같은 내용의 인사명령에 대한 근로제공의무 불이행 상태가 계속되고 있었다 하더라도, 이 사건 각 징계혐의사실은 각 의무 불이행의 원인이 되는 인사명령 및 그 시점, 그 인사명령 불이행의 시기(始期)와 종기(終期)가 서로 달라 그 기본적인 사실관계가 동일하다고 평가하기 어렵다.

근로자가 사용자의 정당한 인사명령을 계속 불이행한다면, 이를 이유로 한 최초의 징계 이후에 새로운 징계의 필요성이 인정될 수 있다. 이 경우 사용자로서는 기존의 징계를 취소하고 종전의 인사명령 불이행 사실까지 징계혐의사실에 포함하여 새로운 징계를 내릴 수도 있을 것이다. 그러나 사용자가 새로운 징계를 하면서 기존의 징계를 취소하지 않은 조치가 징계권의 남용이라고 단정할 수는 없고, 기존의 징계와 새로운 징계의 공존 또는 병존에 따른 문제는 새로운 징계의 징계양정 등이 적정한지 여부 등을 통제함으로써 해결하는 것이 타당하다.

실질적으로 동일한 내용의 인사명령 불이행에 대하여 사용자가 당초 한 차례 징계한 바 있다는 사정만으로 그 불이행의 기간을 달리하는 후행 징계가 이중징계로서 무효라고 보게 된다면, 사용자로서는 정당한 인사명령의 불이행을 계속하고 있는 근로자에 대하여 향후 해당 근로자의 예상되는 인사명령 불이행의 종기 등까지도 고려하여 최초의 징계를 하여야만 한다는 결론에 이르게 되고, 이러한 결론은 사용자의 근로자에 대한 업무 지휘·감독권을 행해화할 우려가 있어 선뜻 받아들이기 어렵다.

근로자에 대한 전직이나 전보처분은 근로자가 제공하여야 할 근로의 종류·내용·장소 등에 변경을 가져온다는 점에서 근로자에게 불이익한 처분이 될 수도 있으나 원칙적으로 인사권자인 사용자의 권한에 속하므로 업무상 필요한 범위 안에서는 상당한 재량을 인정하여야 하는 것으로, 그것이 근로기준법에 위반되거나 권리남용에 해당하는 등 특별한 사정이 없는 한 무효라고는 할 수 없다. 전직처분 등이 정당한 인사권의 범위 내에 속하는지의 여부는 당해 전직처분 등의 업무상의 필요성과 전직 등에 따른 근로자의 생활상의 불이익을 비교·교량하고, 근로자가 속하는 노

동조합(노동조합이 없으면 근로자 본인)과의 협의 등 그 전직처분 등을 하는 과정에서 신의칙상 요구되는 절차를 거쳤는지의 여부에 의하여 결정되어야 한다(대법원 1991. 7. 12. 선고 91다 12752 판결 등 참조).

업무상 필요에 의한 전직 등에 따른 생활상의 불이익이 근로자가 통상 감수하여야 할 정도를 현저하게 벗어난 것이 아니라면 이는 정당한 인사권의 범위 내에 속하는 것으로서 권리남용에 해당하지 않는다고 할 것이고(대법원 1996. 4. 12. 선고 95누7130 판결 참조), 전직처분 등을 함에 있어서 근로자 본인과 성실한 협의절차를 거쳤는지의 여부는 정당한 인사권의 행사인지의 여부를 판단하는 하나의 요소라고는 할 수 있으나, 그러한 절차를 거치지 아니하였다는 사정만으로 전직처분 등이 권리남용에 해당하여 당연히 무효가 된다고 볼 수는 없다(대법원 1997. 7. 22. 선고 97다18165, 18172 판결 참조).

그리고 사용자가 전직처분 등을 함에 있어서 요구되는 업무상의 필요란 인원 배치를 변경할 필요성이 있고 그 변경에 어떠한 근로자를 포함시키는 것이 적절할 것인가 하는 인원선택의 합리성을 의미하는데, 여기에는 업무능률의 증진, 직장질서의 유지나 회복, 근로자 간의 인화 등의 사정도 포함된다(대법원 2013. 2. 28. 선고 2010두20447 판결 참조).

피징계자에게 징계사유가 있어서 징계처분을 하는 경우 어떠한 처분을 할 것인지는 징계권자의 재량에 맡겨져 있으므로, 징계권자의 징계처분이 사회통념상 현저하게 타당성을 잃어 징계권자에게 맡겨진 재량권을 남용하였다고 인정되는 경우에 한하여 그 처분이 위법하다고 할 수 있다. 징계처분이 사회통념상 현저하게 타당성을 잃어 재량권의 범위를 벗어난 위법한 처분이라고 할 수 있으려면 구체적인 사례에 따라 징계의 원인인 비위사실의 내용과 성질, 징계로 달성하려는 목적, 징계양정의 기준 등 여러 요소를 종합하여 판단할 때에 징계 내용이 객관적으로 명백히 부당하다고 인정되어야 한다(대법원 2017. 3. 15. 선고 2013두26750 판결 등 참조).

※ 상고심 심리불속행기각에 따라, 위 요지는 2심 법원의 판결 요지를 인용하였다.

패소 이유 (사실관계에 관한 인정 차이)

중노위와 법원의 결론이 엇갈린 것은 이 사건 2차 징계가 ‘이중징계’에 해당하는지에 관해 서로 다른 판단을 했기 때문이다. 중노위는 1·2차 징계혐의사실이 동일하여 2차 징계를 이중징계로 인정한 반면, 법원은 ‘각 의무 불이행의 원인이 되는 인사명령 및 그 시점, 인사명령 불이행의 시기(始期)와 종기(終期)가 서로 달라’ 1·2차 징계혐의사실이 다르다며 이중징계에 해당하지 않는다고 판단하였다. 그리고 법원은 이를 전제로 이 사건 징계처분(정직)의 정당성(징계사유의 존부, 징계재량권의 일탈·남용 여부)에 관한 검토로 나아갔다.

<이중징계 여부>

중노위는 1·2차 인사명령이 동일한 내용(특정 현장에 발령)이라는 점에 주목하여, 하나의 동일한 인사명령 불이행에 대해 두 번의 징계(이중징계)를 한 것이어서 징계가 무효라고 판정하였다.

이와 달리 법원은 “징계혐의사실이 형식적·실질적으로 동일하지 않은 경우라면 시간적으로 연속된 비위행위에 대하여 각각 징계에 처할 수 있으므로 이중징계가 아니”라고 판단하였다.

구체적으로는 “▲ ‘2차 징계인 정직은 1차 징계(감봉)가 확정되고 원고 회사가 제1차 인사명령의 내용을 다시 명령하는 제2차 인사명령을 재발령한 이후에도 참가인이 계속해서 따르지 않고 현장 근무를 거부하고 있다는 사실을 징계혐의사실’로 삼았고, ▲ 1차 징계(감봉) 이후에도 제1차 인사명령이 유효하게 효력을 유지하고 있는 동안 새롭게 발생한 인사명령 불이행은 비록 동일한 내용의 인사명령에 대한 것이라고 하더라도 ‘선행 징계인 감봉의 징계혐의사실과 그 기간이 중복되지 아니하는 이상 별개의 사실로 구분’되므로, 정직의 징계혐의사실이 감봉의 징계혐의사실과 동일하다고 볼 수 없고, ▲ 1차 징계인 감봉 기간(6개월)이 종료하기 전에 2차 징계(정직)가 확정되어 정직 기간이 함께 진행된다고 하더라도, 이는 ‘별개의 징계혐의사실에 대한 각각의 징계가 시간적으로 근접한 시점에 이루어짐으로써 각 징계가 효력을 가지는 기간이 중복되어서 발생하는 결과에 불과할 뿐’이고, 즉 선행 징계가 정직 등 그 기간 동안 새롭게 인사명령 불이행이 발생할 수 없는 성질의 것이 아니라 감봉인 이상, 그 ‘감봉 기간 중에도 새로이 인사명령 불이행이

발생할 수 있고 이를 사유로 별도의 징계를 하여 그 후행 징계의 효력이 발생할 수 있는 것'이므로, 이러한 후행 징계가 일사부재리의 원칙이나 이중처벌금지의 원칙에 위배되는 이중징계에 해당하는 것은 아니며, ▲인사명령에 대한 불이행은 그 불이행 기간의 장단에 따라 비위의 정도가 달라지므로 동일한 인사명령에 대한 불이행이더라도 장기간 계속될 경우 새로운 징계의 필요성이 발생할 수 있고, 징계위원회 개최 등 징계에 필요한 절차를 모두 준수한 이상 연이어 징계가 이루어졌다는 것만으로 위법하다고 평가할 수 없으며, 다만 이는 징계양정의 적정성 평가에서 고려할 요소에 불과하다"라고 보았다.

<징계사유 존부>

나아가 법원은 이 사건 정직(2차 징계)의 징계사유 존부에 관해, '회사의 업무상 필요성 및 근로자의 생활상 불이익과의 균형, 신의칙상 협의절차를 갖춘 것'으로 보아 징계사유가 존재한다고 보았다. (▲2차 인사명령 당시 현장에 47명이 근무 중이었고, 1차 인사명령 후 현장담당자가 참가인 근로자의 근무를 촉구하는 이메일을 보낼 정도로 참가인의 투입이 절실한 상태였던 것으로 보이는 점(업무상 필요성), ▲원고 회사는 2차 징계(정직) 전에 참가인과 면담을 수차례 진행하였고 참가인의 전보 의사와 희망업무 등을 확인하고자 하였으며, 참가인을 위한 특별교육을 실시하기도 하였으나, 참가인은 1차 징계(감봉) 철회를 조건으로 인사명령에 따를 의사가 있음을 피력한 점(신의칙상 협의절차), ▲설령 보복성 인사라는 의문이 생겼더라도, 참가인으로서 2차 인사명령에 응하여 자신의 근로제공의무를 다하면서 그 의문의 해소를 위하여 적합한 수단 및 정당한 절차를 거쳤어야 하나, 인사명령에 반하여 본사로 계속 출근한 행동은 적합하고 정당한 항의로 보기 어려운 점 등)

<징계재량권 일탈·남용 여부>

아울러 법원은 이 사건 정직(2차 징계)이 사회통념상 현저하게 타당성을 잃어 징계재량권을 일탈·남용한 징계처분이 아니라고 판단하였다. (▲근로제공의무는 근로자의 기본적인 의무인데, 참가인은 제1차 인사명령에 따른 업무내용에 관하여 구체적으로 알아보거나 부족한 역량을 구체적으로 언급한 바 없고, 업무 관련 특별교육을 수강하고도 계속 막연하고 추상적인 역량 부족만 내세우며 아무런 개선이나 노력 의지를 보이지 아니하였으며, 또한 참가인이 1차 징계에 관해 다투고 있었다고 하더라도 여전히 인사명령에 효력이 있고 1차 징계가 유효한 이상 이러한 사정이 2차 인사명령을 일방적으로 거부할 사유가 된다고 볼 수는 없는 점, ▲1차 인사명령 불이행으로 감봉(1차 징계)을 받았음에도, 2차 인사명령도 계속 불이행하여 그 기간이 2주 이상에 이르렀고, 장기간의 인사명령 불이행은 원고의 직장질서에 미치는 부정적 영향이 크고, 해당 현장에서의 인력부족과 관련하여 다른 근로자들에게 피해를 주는 결과도 발생하게 되는 점, ▲원고 회사는 정직(2차 징계) 이전에 보다 경한 징계인 감봉(1차 징계)을 하여 참가인의 태도 변화를 도모한 바 있고, 그럼에도 인사명령 불이행이 지속되자 정직에 이른 것이며, 정직 시에도 비교적 단기간인 1개월의 징계를 의결한 점 등)

이 사건에서 중노위가 이중징계로서 무효가 되는 경우에 관한 판례 법리를 다소 형식적으로 해석·적용한 면이 있는 것으로 보인다. 판례는 선행 징계처분과 후행 징계처분의 징계혐의사실이 동일한 경우에 일사부재리 원칙에 반하는 이중징계라고 보는데, 이 사건 1·2차 징계의 경우 각 의무 불이행의 원인이 되는 인사명령 및 그 시점, 인사명령 불이행의 시기와 종기가 서로 달라 동일한 사실관계로 보기 어려운 측면이 분명히 있었음에도, 중노위는 1·2차 인사명령의 내용이 같고 인사명령 거부 상태가 연속되는 점에 집중하여 그 전체를 하나의 징계혐의사실로 잘못 판단하고 말았다.

장기간 복수의 사건을 통해 확립된 대법원 판례 법리가 존재하는 경우라면 중노위가 이를 해석·적용함에 착오가 없어야 할 것이다. 판례 및 기타 법리에 관한 중노위의 전문성을 높여 신속하고 정확한 판정 역량을 강화해 나갈 필요가 있다.

일련번호	2020-19					
판결번호	서울고등법원 2019. 12. 6. 선고 2019누00000					
중노위판정번호	중노위 2018. 9. 4. 2018부해710					
사건 종류	부당해고					
세부 쟁점	해고, 해고의 존재, 의사표시					
심급별 소송결과	1심 법원	재심 취소	2심 법원	항소기각	대법원	-
항 소 인	중앙노동위원회위원장		참 가 인		이○○	
피항소인	주식회사 ○○○코리아		피고측 대리인 선임 여부		선임 안 함	
노동조합 지원 여부	없음		원고측 대리인 선임 여부		선임함	
재심 결과	초심유지					
초심의 대법원 판례 일치여부	불일치		재심의 대법원 판례 일치여부		불일치	
기타 특이사항	상고 없이 항소심 확정					

주요 사실관계 <사실관계> 참가인 근로자는 가구유통업을 하는 원고 회사에 2017. 9. 11. 입사하여 근무하였다. 원고 회사의 대표가 2017. 12. 8. 회의 중 화를 내며 참가인 근로자 등 직원에게 모두 사무실에서 나가라며 폭언을 하였는데, 그 무렵 임금체불로 회사와 직원 들 간 갈등이 있는 상황이었다. 2017. 12. 9. 오전 원고 대표와 참가인은 대화를 하던 중, 참가인 근로자가 이들의 시간을 달라고 하자 원고 대표가 욕설을 하였고 이에 참가인은 ‘저 가겠습니다’라고 말하고 대화가 종료되었다. 그날 오후 원고 대표는 참가인에게 카톡으로 ‘막말한 것을 사과하고, 이렇게 끝나는 건 아닌 거 같다’고 하였으며, 이후 통화에서도 ‘하는 거 변동 없으니까 마음 추슬러’라고 말하였다. 참가인 근로자는 2017. 12. 21. 원고 대표에게 임금체불, 폭언, 비난 등을 지적하는 카카오톡(‘인격 비하, 폭력적 행동 극복하기 어렵다. 격려해주는 리더와 일하고 싶다. 마지막이라 생각하고 의욕적으로 시작한 일이 이렇게 끝나 유감, 더 늦기 전에 저를 위한 올바른 선택을 하게 된 점 양해 바란다’는 취지)을 보내고 출근하지 않았다. 한편 참가인 근로자 등 원고 소속 근로자 2명은 서울지방법고용청에 임금체불 진정을 하였는데, 2018. 2. 1. 조사에서 담당 근로감독관에게 ‘대표가 문자로 사과하며 같이 일하자고 하였으나 참가인은 더 이상 같이 일 할 수 없다고 판단하여 회사를 나왔다’고 진술하였다. 이후 참가인 근로자는 원고 회사 대표가 2017. 12. 8.부터 같은 달 19. 등에 걸쳐 몇 차례에 걸쳐 참가인 근로자에게 해고 의사를 밝혔으며, 서울지노위에 부당해고 구제신청을 하였다. <심급별 결과> [서울지노위] 근로관계종료는 해고에 해당하고 서면통지의무를 위반하여 부당해고라고 판정 [중노위] 초심유지 [1심 법원] 해고가 아닌 자진퇴사로 보아 재심판정 취소

[2심 법원] 항소 기각 ※ 상고하지 않음.

판결 요지

근로기준법상의 해고란 사용자의 일방적인 의사에 의하여 근로계약관계를 종료시키는 경우를 의미한다(대법원 2001. 1. 19. 선고 2000다51919, 51926 판결, 대법원 2010. 3. 25. 선고 2009다95974 판결 등 참조).

패소 이유 (사실관계에 관한 인정 차이)

이 사건의 경우, 당사자들 간 대화내용, 카카오톡 메시지 내용, 기타 제반사정 등에 기할 때, 원고 회사의 대표의 언행을 해고의 의사표시로 볼 수 있는지, 즉 사용자의 일방적 의사에 의하여 근로계약관계를 종료시켰다고 볼 수 있는지 여부가 쟁점이 되었다.

중노위는 카카오톡 메시지, 대화내용, 당시 정황 등을 고려할 때 원고 대표가 근로자를 구두로 해고한 것이며, 해고 사유와 시기를 서면통지 하지 않아 부당해고라고 판정하였다.

그러나 법원은 사용자의 해고의사표시로 보기 어렵다며, 재심판정을 취소하였다. 법원은 ‘▲원고 회사 대표가 2017. 12. 8. 회의 중 ‘나가’라고 말한 부분은 회의실에서 나가라는 의미를 넘어 근로계약관계를 종료시키겠다는 의미로 해석하기는 어려운 점, ▲참가인 근로자가 직후 담당하던 소송 업무 등을 계속 수행하였고, 2017. 12. 9. 카카오톡 메시지에서도 근로계약관계가 계속됨을 전제로 한 모습을 보여준 점, ▲2017. 12. 19. 오전 대화 중 원고 대표는 참가인 근로자에게 해고의 의사표시를 한 바 없고 오히려 근로계약관계의 종료를 원하지 않았던 것으로 보이며, 이에 참가인이 이를 정도 결정할 시간을 달라고 요구하면서 특별한 결론이 나지 않은 채 대화가 종료된 점 ▲원고 대표는 위 대화 직후 참가인에게 ‘참가인이 그만두는 것까지 생각했다는 것에 화가나 막말을 하였고, 이렇게 끝내지 않았으면 좋겠다.’라는 취지의 카카오톡 메시지를 보냈고, 같은 날 오후 재차 참가인 근로자에게 전화하여 사과의 뜻을 전하면서 ‘마음 추스르고 변동 없이 기존대로 하자’라는 취지의 이야기를 하기도 한 점, ▲이러한 상황에서 참가인 근로자가 2017. 12. 21. 원고 대표에게 보낸 카카오톡 메시지는 결국 원고 대표의 폭언 등으로 인해 같이 근무하기 어렵다는 의미로 해석함이 상당한 점, ▲참가인은 임금체불 진정 관련 조사과정에서 서울지방고용노동청 담당 근로감독관에게 ‘원고 대표가 2017. 12. 19. 본인에게 폭언 등을 하자, 그의 사과에도 불구하고 참가인이 자발적으로 퇴사하였다’라는 취지로 진술한 점’ 등에 비추어 해고로 보기 어렵고 오히려 참가인 근로자가 자진하여 퇴사하였다고 봄이 타당하다고 판결하였다.

재심판정이 취소된 것은 결국 중노위와 법원의 사실 인정에 관한 차이에서 기인한 것으로 보인다. 해고의 의사표시란 근로자의 의사와는 무관하게 사용자에게 의한 일방적인 근로계약관계종료의 의사표시를 말하는데, 이 사건의 경우 사용자의 일방적인 의사로 보기에 모순되는 사실 및 정황들이 다수 존재하였던 것이 결정적이지 않았나 싶다. 해고 의사표시 존부에 관한 선례들을 포괄적으로 수집, 검토함으로써 중노위 판정의 정확성을 높여 대응하는 것이 필요하다고 생각된다.

일련번호	2020-20
판결번호	서울고등법원 2020. 4. 29. 선고 2019누00000 판결
중노위판정번호	중노위 2018. 11. 19. 중앙2018부해918

사건 종류	부당해고					
세부 쟁점	근로계약, 수습계약, 본채용 거부					
심급별 소송결과	1심 법원	재심판정취소	2심 법원	1심 유지	대법원	
상 고 인	중앙노동위원회위원장		참 가 인		(사)○○○○○○○○협회	
피상고인	강○○		피고측 대리인 선임 여부		안 함	
노동조합 지원 여부	없음		원고측 대리인 선임 여부		안 함	
재심 결과	초심유지					
초심의 대법원 판례 일치여부	불일치		재심의 대법원 판례 일치여부		불일치	
기타 특이사항						

주요 사실관계
<사건 개요> 가. 피고보조참가인 ○○○○○○○협회 (이하 '참가인'이라 한다) D지회는 2016. 6.경 E시와 'E시 특별교통수단 및 이동지원센터 운영 위·수탁협약'을 체결하고 교통약자를 위하여 특별교통수단을 운영하는 단체이고, 원고는 2018. 3. 5. 참가인 D지회와 근로계약을 체결하고, 특별교통수단이동지원센터(이하 '이 사건 부름콜센터')에서 운전원으로 근무하면서 차량운행 및 차량관리 업무를 수행하였다. 나. 참가인은 2018. 3. 21. 원고에게 '출근시간 미준수, 다른 직원과 원고 사이의 불화' 등을 이유로 2018. 3. 30.까지 출근하고 퇴사할 것을 권고하였다. 다. 참가인은 2018. 3. 30. 재차 원고에게 퇴사를 권고하였으나, 원고는 같은 날 국민신문고에 이 사건 부름콜센터의 운영 방식이 적정하지 않다는 취지의 민원을 신청하였으며, E시청 교통행정과는 위 부름콜센터에 대한 점검을 실시하고 조치결과를 원고에게 통보하였다. 라. 참가인은 2018. 4. 26. 운영위원회를 개최하여 원고의 직무수행과 자질을 평가한 후, 원고의 수습기간 2개월이 지나면 근로계약을 해지하기로 결정하고, 2018. 4. 27. 원고에게 '원고는 수습기간 참가인 D지회 구성원들과 불화를 일으키고, 참가인의 이미지를 손상시키는 행위를 하였으므로 2018. 5. 4.까지 위 D지회에서 근무한다.'라는 내용으로 통보하였다. 마. 원고는 2018. 5. 8. 경북지방노동위원회에 이 사건 해지통보가 부당해고에 해당한다고 주장하며 구제를 신청하였다. <심급별 결과> [경북지노위] 원고는 시용근로자에 해당하고, 참가인이 업무지시 거부, 각종 민원 제기, 직원 사이의 갈등 등을 이유로 원고의 본채용을 거부한 것은 정당하다는 이유로 구제신청 기각 [중노위] 재심신청을 기각. 초심 유지 [1심 법원] 본채용 거부의 정당한 이유가 없으므로 해고에 해당한다는 취지로 재심판정 취소

[2심 법원] 항소 기각

판결 요지

(1) 수습기간 면제 여부

참가인 취업규정은 신규 채용한 직원으로 하여금 2개월의 수습기간을 거치도록 정한 점, 그중 경력이 인정된 직원은 수습기간을 단축 또는 면제할 수 있다고 정한 점은 앞서 본 바와 같다. 이로부터 알 수 있는 다음과 같은 사정, 즉 참가인이 신규 채용한 근로자의 수습기간을 단축하거나 면제하는 것은 참가인의 재량에 달려 있고, 원칙적으로는 신규 채용한 모든 근로자로 하여금 수습기간을 거치도록 정한 점을 앞서 인정한 사실과 종합하여 보면, 가사 공개경쟁 채용시험을 거치지 않았다고 하더라도, 참가인에게 신규 채용된 원고는 참가인과 근로계약을 체결한 2018. 3. 5.부터 2개월간 시 용기간 중인 근로자의 지위에 있었다고 보아야 하고, 이와 달리 참가인이 명시적으로 원고의 수습기간을 면제하였다는 특별한 사정은 찾아볼 수 없다.

(2) 원고의 본채용을 거부할 합리적인 이유가 존재하는지 여부

가) 업무지시 거부의 점

① 참가인은 2018. 3. 21. 원고에게 '출근시각을 지키지 않았고, 출근시각에 관한 지시를 따르지 않았으며, 다른 직원들과 불화가 있으니 2018. 3. 30.까지 근무하고 퇴사하라.'라고 권유하였다. ② 참가인 D지회 상담실장 G는 그 무렵 원고를 비롯한 직원들에게 홍보용지를 나누어 주면서 '이 사건 부름콜센터가 운영하는 특별교통수단이 증편되었으니 홍보를 해달라.'라고 부탁하였는데, 원고는 '홍보는 E시청에서 해야지 왜 우리한테 시키냐?'라고 말하였다. ③ 원고가 2018. 3. 30.경 참가인 D지회장 H에게 '정해진 근무시간은 9시부터 6시까지인데 그 이전에 출근해 있으라는 지시를 이해할 수 없다.'라는 취지로 말하자, H은 '내가 시간을 못 박아서 일찍 출근하라고 한 적은 없다. 원고가 근무시간을 안 지킨다고 말한 사실도 없다. 대신 사회공동체는 일찍 나와서 준비하는 시간이 필요하다. 그런데 원고는 근로기준법을 언급하지 않았느냐.'라는 취지로 대답하였다. 계속해서 원고는 H에게 'G가 8시 40분까지 출근하라고 지시하기에 그 다음날 8시 40분에 출근하여 청소를 했다. 그런데 같은 직원인 G는 8시 55분에 출근하여 지시가 부당하다고 생각했다.'라는 취지로 말하였다. ④ G는 원고가 다른 직원들과 함께 공동구역 청소를 하지 않았다는 내용의 탄원서를 작성하여 제출하였다.

그런데 앞서 든 증거와 사실관계를 종합하여 알 수 있는 다음과 같은 사정을 고려하여 보면 위 인정사실만으로는 원고가 출근시각이나 업무와 관련된 참가인의 지시를 이행하지 않았거나, 업무에 관한 원고의 태도가 본채용을 거부할 정도로 불량하였다고 보기 부족하고, 달리 이를 인정할 만한 증거가 없다.

H은 스스로 원고가 출근시각을 어겼다고 지적하지 아니하였음을 인정하고 있고, 막연히 다른 사람들을 따라 일찍 출근하여 업무를 준비하도록 권하고 있을 뿐이어서 원고가 업무와 관련된 구속력 있는 지시를 따르지 아니하였다고 보기에는 부족하다. 나아가 원고는 우선 출근시각에 관한 G의 지시를 따르기도 하였는데, G 스스로가 그에 맞게 행동하지 않는 것을 보고 지시가 부당하다는 생각이 들어 이의를 제기하기에 이른 것이고, 이처럼 이의를 제기하였다는 사실만으로는 업무에 관한 원고의 태도가 불량하다고 볼 이유가 되지 못한다. 원고가 참가인 D지회에서 제공하기로 한 근로의 내용은 차량운행 및 차량관리 업무에 관한 것이므로 이 사건 부름콜센터의 홍보와 관련된 업무를 지시하는 데 이의를 제기한 것은 나름대로 합리적인 이유가 있을 뿐만 아니라, 위와 같이 이의를 제기할 당시 원고의 태도나 품성이 본채용을 거부할 정도로 불량하였다는 점에 대한 객관적인 자료도 찾아볼 수 없다. 원고가 공동구역 청소를 하지 않았다는 점에 대하여 구체적인 사실관계를 확인할 수 있는 객관적인 자료를 찾아볼 수 없다.

나) 각종 민원 제기의 점

참가인이 2018. 3. 21. 원고에게 업무지시를 이행하지 않거나 다른 직원과 불화가 있다는 이유로 조만간 퇴직하도록 권유한 사실은 앞서 본 바와 같고, 갑 제4호증부터 갑 제7호증까지, 갑 제11호증, 을가 제2호증의 각 기재 및 변론 전체의 취지를 종합하면 다음과 같은 사실을 인정할 수 있다.

① 원고는 참가인이 재차 퇴직을 권한 2018. 3. 30. 국민신문고를 통하여 '참가인 D지회장과 D지회 상담실장으로부터 정해진 출근시각보다 일찍 출근하도록 강요당하고, 외부 단체의 행사를 지원하도록 동원되었다. 참가인 D지회는 운전원들로 하여금 고객들로부터 이 사건 부름콜센터가 운영하는 특별교통수단의 비용을 현금으로 지급받고도 이를 지급받은 운전원의 카드로 결제하게 하여 카드 수수료 상당의 손실이 발생하게 하였고, 이 사건 부름콜센터의 운영 취지와 맞지 않게 만취 고객, 예약 취소 고객 등의 이용을 제한하고자 추진하였으며, 원고에게는 수습기간 도중 퇴사를 강요하였다. 위 D지회장은 이 사건 부름콜센터의 특별교통수단을 사적으로 이용하기도 하였다.'라는 내용의 민원을 제기하였다. 원고는 민원을 제기하면서 '분하고 억울하여 갑의 위치에서 갑질을 하는 H 지회장과 그 곁에서 똑같이 분수도 모르고 직원들의 위에서 군림하여 갑질을 하고 있는 G 상담실장에 대하여 듣고 보고 알게 된 일련의 일들을 E시 담당관에게 전화로 이야기하였다.'라는 내용을 기재하기도 하였다.

② E시는 2018. 4.경 원고의 민원제기에 따라 참가인 D지회의 특별교통수단 운행 업무가 적정하게 수행되는지 점검하여 그 결과를 통보하였고, 2018. 8.경에는 원고가 재차 제기한 민원에 따라 참가인 D지회에 카드 수수료 상당의 고지서를 발부하여 세입완료 조치하였다고 안내하기도 하였다.

위와 같은 사실을 종합하여 보건대 원고가 E시에 제기한 민원의 내용은 자신이 근무하는 이 사건 부름콜센터의 운영 실태를 지적하며 개선을 요구하는 것이고, 비록 그 표현이 다소 격정적인 수준이기는 하나, 이는 위 부름콜센터 운영의 개선을 요구하면서 원고가 불합리하다고 생각하는 점을 강조하는 과정에서 통상적으로 수반될 수 있는 수준에 머무르고 있는 것으로 보인다. E시가 원고의 민원 내용에 따라 참가인 D지회의 사업을 일부 점검하여 후속조치를 하기에 이르렀으므로 원고가 아무런 근거 없이 악의적으로 민원을 제기하였다고 보아지지도 아니한다. 따라서 원고의 행동이 참가인 또는 그 직원의 명예를 훼손하는 행위에 해당한다거나 그 밖에 원고의 업무적 격성을 의심하게 하는 사정에 해당한다고 보기 어렵다.

다) 직원 사이 갈등의 점

참가인이 2018. 3. 21. 원고에게 업무지시를 이행하지 않거나 다른 직원과 불화가 있다는 이유로 조만간 퇴직하도록 권유한 사실은 앞서 본 바와 같고, 을가 제3호증의 기재 및 변론 전체의 취지를 종합하여 보면 G 등 여러 명의 직원들이 2018. 5.경 원고의 복직을 반대한다는 내용의 탄원서를 작성한 사실이 인정되기는 한다. 그런데 앞서 든 증거로부터 알 수 있는 다음과 같은 사정에 비추어 보면 앞서 인정한 사실만으로는 원고와 참가인 D지회 직원들 사이의 갈등으로, 사회통념상 참가인이 원고의 본채용을 거부할 수 있을 만한 객관적이고 합리적인 이유가 있다고 보기 어렵다.

참가인 D지회 직원들이 제출한 탄원서의 내용은 대체로 원고와 다른 직원들 사이의 갈등에 관한 구체적인 사실관계를 언급하지 아니하고 '원고가 이 사건 부름콜센터의 운영에 관하여 불만이 있는데, 다른 직원들에게 함께 문제제기를 하자고 선동하였다', '잘못된 내용인 사소한 문제에 대해 모두 꼬투리를 잡는다'라는 취지에 그치고 있다. 그런데 앞서 본 대로 원고가 민원이나 이의를 제기한 데에 나름대로 합리적인 근거가 있고, 원고가 다른 직원들에게 이 사건 부름콜센터의 운영에 관한 문제를 언급한 것이 그 자체로 원고와 다른 직원들 사이의 갈등으로 이어졌다고 보기 어렵다. 탄원서 중 일부는 다른 사람이 대신 작성한 것으로 기재되어 있는데, 대신 작성하게 된 경위 등을 알 수 없어 진정한 의사로 작성한 것인지 의문이 든다.

원고는 시용기간 중에 있던 근로자이지만, 참가인이 원고의 본채용을 거부한 데에 사회통념상 상

부록.1. 주요 사건 경과 및 패소 원인 분석

당한 정도로 객관적이고 합리적인 이유가 존재한다고 보기 어렵다. 이와 다른 전제에 선 이 사건 재심판정은 위법하므로 취소되어야 한다.

패소 이유 (사실관계에 관한 인정 차이)

이 사건은 수습계약을 체결한 근로자에 대한 사용자의 본채용 거부의 정당성에 관한 사건으로서, 초심 지노위 판정과 중노위의 재심 판정은 본채용 거부의 합리성을 인정했으나, 법원은 1심과 2심 모두 본채용 거부의 정당성을 부인하여 부당해고라고 인정한 사건이다.

사실관계 주장이나 새로운 증거의 제시가 없었기 때문에, 완전히 동일한 사실관계에 대하여 노동위원회와 법원의 판단이 달라진 사건이다. 대상 사건의 사실관계를 살펴보면, 본채용 거부의 합리성을 인정할 수 있는 내용도 다수 발견되어 법원의 판단이 더욱 합리적이라고 단정하기는 어려운 것이 사실이다. 다만,, 탄원서 등 판단의 중요한 근거가 될 수 있는 증거들에 대한 해석이 법원과 차이가 있었다는 점을 고려할 때, 노동위원회 조사관이나 노동위원회 심문 과정에서 조사의 실질성을 제고할 수 있는 방안에 대한 고려가 절실하다는 점을 지적하고자 한다.

일련번호	2020-21					
판결번호	대법원 2020. 5. 28. 선고 2020두00000					
중노위판정번호	중노위 2018. 10. 1. 2018부해776					
사건 종류	부당전보					
세부 쟁점	인사명령(전보), 전보명령의 정당성					
심급별 소송결과	1심 법원	재심 취소	2심 법원	항소 기각	대법원	상고기각 (심리불속행)
상 고 인	중앙노동위원회위원장		참 가 인		유한회사 ○○○○건설	
피상고인	이○○		피고측 대리인 선임 여부		선임 안 함	
노동조합 지원 여부	없음		원고측 대리인 선임 여부		선임 함	
재심 결과	초심유지					
초심의 대법원 판례 일치여부	불일치		재심의 대법원 판례 일치여부		불일치	
기타 특이사항						

주요 사실관계

<사실관계>

원고 근로자는 토목건축공사 사업을 영위하는 참가인 회사에 2011년 입사하여, 전주 본사 기

술연구소에서 이사로 근무하였다. 참가인 회사는 2018. 2. 5. 사내규정 위반 등을 이유로 원고에게 강등(강격, 감급)의 징계를 하였고, 인사위원회 재심을 거쳐 2018. 2. 13. 징계가 확정되었다.

※ 징계 사유 : ‘보안이 확인되지 않은 외부파일 다운로드로 인한 컴퓨터 손상, 무단결근, 업무를 제대로 이행하지 않는 등의 행위로 회사에 피해를 끼친 점 등’의 취업규칙 위반

원고 근로자는 그 다음 날인 2018. 2. 14. 참가인 회사로부터 ‘징계 및 근무지 변경’에 관한 통지서를 받았는데, 통지서에는 “발령일자 2018. 2. 19. / 발령내용 징계[강등(강격, 감급)] 및 근무지 변경 / 命 ‘차장, ○○산업단지 현장’ 이라고 기재되어 있었다.

한편 원고 근로자는 2018. 2. 21. ‘근무장소: 창원 ○○산업단지 현장’이라고 적힌 연봉근로계약서에 서명하였고, 그에 따라 연간 총 급여가 6,300만 원에서 4,400만 원으로 감소하게 되었다.

이후 원고 근로자는 위 창원 현장으로의 전보가 선행 징계인 강등의 일환 또는 그 후속조치로 이루어진 보복성 인사라고 주장하며 서울지노위에 부당전보 구제를 신청하였다.

한편, 참가인 회사는 2018. 12. 28. 원고 근로자를 징계해고 하였다.

※ 징계사유 : ‘2016. 9. 22. 무단결근, 워크숍 자료 미제출 및 워크숍 중 소설구독, 상사의 정당한 업무지시 위반, 근무시간 중 회사 컴퓨터로 성인음란영상, 무협판타지소설 등을 수시로 다운로드 받아 열람·사용’ 등

<심급별 결과>

[서울지노위] 전보는 정당하다고 판정 (※ 다만 강등처분에 대해서는 절차상 위법으로 부당징계라고 판정하였으나, 이 부분은 당사자들이 더 이상 다투지 않았다)

[중노위] 전보가 정당하다는 보아 근로자의 재심신청을 기각(초심 유지)

[1심 판결] 전보는 정당한 인사권의 행사로 볼 수 없다며 재심판정 취소

[2심 판결] 항소기각

[대법원] 심리불속행기각

판결 요지

비록 배치전환에 당해 근로자에 대한 제재적인 의미가 내포되어 있다고 하더라도 그 자체가 단체협약이나 취업규칙 등에 정한 징계절차를 요하는 징계로서 규정되지 아니한 이상 그러한 징계절차를 거치지 않았다고 하더라도 효력에 영향이 없다고 할 것이다(대법원 1998. 12. 22. 선고 97누5435 판결 등 참조).

근로자에 대한 전보나 전직은 원칙적으로 인사권자인 사용자의 권한에 속하므로 업무상 필요한 범위 내에서는 사용자는 상당한 재량을 가지며 그것이 근로기준법 등에 위반되거나 권리남용에 해당되는 등의 특별한 사정이 없는 한 유효하고, 전보처분 등이 권리남용에 해당하는지 여부는 전보처분 등의 업무상의 필요성과 전보 등에 따른 근로자의 생활상의 불이익을 비교·교량하여 결정되어야 하고, 업무상의 필요에 의한 전보 등에 따른 생활상의 불이익이 근로자가 통상 감수하여야 할 정도를 현저하게 벗어난 것이 아니라면 이는 정당한 인사권의 범위 내에 속하는 것으로서 권리남용에 해당하지 않는다고 보아야 하며, 전보처분 등을 함에 있어서 근로자 본인과 성실한 협의절차를 거쳤는지의 여부는 정당한 인사권의 행사인지 여부를 판단하는 하나의 요소라고는 할 수 있으나, 그러한 절차를 거치지 아니하였다는 사정만으로 전보처분 등이 권리남용에 해당하여 당연히 무효가 된다고는 볼 수 없다(대법원 2009. 3. 12. 선고 2007두22306 판결 등 참조).

※ 상고심 심리불속행기각에 따라, 위 요지는 2심 법원의 판결 요지를 인용하였다.

패소 이유 (사실관계에 관한 인정 차이)

중노위와 2심 법원 모두 이 사건 전보 조치의 경우 그 성질이 징계가 아닌 사용자의 인사권 행사로 판단하였고, 이를 전제로 전보의 정당성 즉 인사명령의 정당성에 관한 검토로 나아갔다.

<전보의 정당성>

중노위는 이 사건 전보가 정당한 것이라고 판정하였는데, ▲회사가 2017. 11월 이후 4차례 ○○산업단지 현장에서 근무할 직원채용 공고를 하고 인력을 채용한 점, 토목건축공사업의 특성상 전국 각지에 공사현장이 발생할 수 있어 지방 및 현장근무가 불가피한 사정으로 인정될 수 있고 실제 원고 근로자가 근무하던 기술연구소와 지방 공사현장 간 인사발령이 이루어졌던 전례가 있는 점 등에서 업무상 필요성이 인정되고, ▲증가한 근로시간만큼의 연장근로수당이 연봉총액에 포함된 것으로 보이고, 2주에 한번씩 서울로 가서 진료를 받고 창원으로 복귀하고 있고, ‘○○산업단지’에서 근무하는 근로자들에게 숙식이 제공되고 유류비 등 실비가 지급되는 점 등에 비추어 생활상 불이익의 정도가 업무상 필요성에 비해 과도하다고 볼 수 없으며, ▲근무장소가 ‘○○산업단지’로 기재된 연봉근로계약서에 서명한 바 있고, 전보 시 사전에 근로자의 협의 내지 동의를 구하는 절차규정이 없으며, 2017. 3. 9. ‘전근 등에 관한 회사의 명령에 대하여는 불평 없이 절대 순종하겠음’이라는 내용의 서약서에 서명한 바 있고, 2017년 및 2018년 연봉근로계약서에 ‘업무상 필요한 경우에는 사용자는 근로자의 근무장소를 변경할 수 있다’고 명시되어 있는 점에 비추어 이 사건 전보에 근로자와 신의칙상 요구되는 협의절차를 준수하지 않았다고도 볼 수 없다고 보았다.

그러나 법원은 ‘강등과 별개로 이 사건 전보의 독자적인 업무상 필요성이 인정된다고 보기 어려울 뿐만 아니라, 일부 업무상 필요성이 인정된다고 하더라도 그에 비하여 전보로 인한 원고 근로자의 생활상 불이익이 상당하다고 보이므로, 이 사건 전보가 참가인 회사의 정당한 인사권의 행사 범위 내에 속한다고 볼 수 없다’고 판단하였다.

▲회사는 강등의 징계절차가 마무리된 직후인 2018. 2. 14. 인사발령통지서를 통해 강등과 전보를 불가분적으로 함께 통지한 점, 참가인 회사가 지노위에 ‘강등으로 인하여 부서 내 직급역전이 발생하고, 업무효율성을 위해 전보가 불가피했다’는 취지의 서면을 제출한 점 등에 의할 때, 원고가 차장 직급으로 강등(강격)되었다는 점이 이 사건 전보에 상당히 중요한 요인으로 작용한 것으로 판단되고 강등이 없었다면 별도로 이 사건 전보가 이루어졌을 것이라고 보기 어려운 점,

▲아울러 강등 사유 및 징계해고 사유와 회사측에서 이 사건 전보의 업무상 필요로 들고 있는 사유들은 상당 부분 중복되는 측면이 있으므로 원고에 대한 정당한 징계절차를 거침으로써 그 책임을 묻는 것이 타당하고, 이와 별개로 이 사건 전보를 하여야 할 업무상의 필요성이나 실효성을 인정하기는 어려운 점,

▲원고는 입사 이후 계속 기술연구소에서 근무하여 왔고, 2016년 이후에는 주로 특허 출원·관리, 비용 정산, 카탈로그 작성이나 홈페이지 개편 등 현장 지원 업무를 담당한 점, 참가인 회사는 원고를 창원으로 전보한 이후에도 3회에 걸쳐 현장직원을 추가 채용한 점, 전보 직후 체결한 연봉계약 결과 연간 총 급여가 기존 6,300만 원에서 4,400만 원으로 대폭 감소하였는데, 이는 단순히 직전년도 업무평가 점수가 낮았거나 외부파일 다운로드로 인한 회사컴퓨터 손상 등의 사정만으로는 온전히 설명이 어렵고, 당시 창원 ○○현장 차장의 급여가 4,300만~5,000만 원 수준이었던 점 등에 비추어, 강등에 따른 감급의 효과 및 전보로 담당하게 된 업무내용 등이 반영된 것이라고 볼 수밖에 없는 점,

▲전보로 현장근무하게 되면서 1일 근무시간이 1시간 증가한 반면 급여는 감소하였고 또한 기존 근무지(전주) 및 거주지(서울)와 ○○산업단지 현장(창원) 사이의 거리가 상당하여 전보로 인한 생활상의 불이익이 적지 아니하였을 것으로 보이는 점,

▲ 원고가 작성한 서약서에 ‘전근 등에 관한 회사의 명령에 대하여는 불평 없이 절대 순종하겠음’이라는 내용이 기재되어 있다 하더라도 이는 업무상 필요에 의한 전보에 따르겠다는 일반적인 의사표시일 뿐 이를 들어 참가인이 원고와의 협의를 거칠 필요성이 배제되는 것이라고 볼 수는 없는 점 등을 주요 이유로 설시하였다.

이 사건의 경우 중노위의 판정이 법원에서 취소된 것은 새로운 법리가 적용되었다거나 중노위가 기존 법리를 잘못 적용한 데서 기인하였다기보다, 사실관계 인정 및 그 법적 의미에 관한 해석이 달랐기 때문으로 보인다.

특히 핵심 쟁점은 업무상 필요성 존부에 관한 것이었는데, 중노위는 전보가 인사권행사의 일환 이라고 판단한 후 비교적 쉽게 그 정당성을 인정한 반면, 법원은 전보 전후에 있었던 강등 및 해고의 징계 사유와 경위를 모두 고려하여 별도로 전보라는 인사명령을 할 업무상 필요가 있었는지를 중점적으로 검토하여 결과적으로 이를 인정하지 않았다. 즉 법원은 엄격한 절차가 요구되는 징계절차를 통해 해결되어야 할 사안에 대해, 사용자의 재량권 영역으로서 비교적 사용자가 용이하게 취할 수 있는 조치인 전보 등 인사명령을 하는 경우, 그 인사명령의 업무상 필요성을 더욱 엄격하게 따져보겠다는 입장을 취한 것으로 보인다.

인사권 행사가 재량권의 범위 내에서 정당하게 이루어진 것인지 여부를 판단함에 있어 가장 우선되고 신중한 검토가 필요한 쟁점이 업무상 필요성이 존재하는지 여부에 관한 것이다. 중노위 재심 과정에서 이에 관한 검토가 다소 미흡했던 것으로 사료된다.

일련번호	2020-22					
판결번호	대법원 2020. 3. 27. 선고 2019두00000					
중노위판정번호	중노위 2018. 10. 8. 2018부해784					
사건 종류	부당해고					
세부 쟁점	사직 의사표시의 성질, 근로계약 해지통고, 사직, 해고					
심급별 소송결과	1심 법원	재심 취소	2심 법원	항소 기각	대법원	상고기각 (심리불속행)
상 고 인	한○○		참 가 인		한○○	
피상고인	○○축산업협동조합		피고측 대리인 선임 여부		선임 안 함	
노동조합 지원 여부	없음		원고측 대리인 선임 여부		선임 함	
재심 결과	초심취소					
초심의 대법원 판례 일치여부	일치		재심의 대법원 판례 일치여부		불일치	
기타 특이사항						

주요 사실관계

<사실관계>

참가인 근로자는 ○○축협(원고 회사)에 근무하였는데, 원고 회사는 2017. 8. 2. 참가인이 한 우 과다매입 및 원가 이하 판매로 회사에 손실을 입힌 것을 이유로 인사위원회를 개최하였다. 참가인 근로자는 이 자리에서 잘못을 인정하고 금년도말까지 근무(휴직)한 후 2017. 12. 31. 자로 사직하겠다는 의사를 밝혔다(이미 휴직계 및 사직서를 제출). 인사위원회는 원래 징계해직할 사안이나 참가인의 사직서 제출 등을 고려하여 징계 수위를 견책으로 낮추고 변상금액도 낮춰 징

게 의결을 하였다. 원고 회사는 같은 날인 2017. 8. 2. 참가인의 휴직원 및 사직원(“금번 개인 사정으로 사직하고자 하오니 청허하여 주시기 바랍니다”)에 대한 내부 결재를 마치고, 참가인 근로자에게 휴직발령을 냈으나 별도로 사직원 수리 사실을 통보하지는 않았다.

참가인 근로자는 2017. 10. 24. 원고 회사에 사직 철회서를 발송하였으나, 원고 회사는 2017. 12. 31. 자로 참가인을 의원해직 처리하여 근로관계를 종료하였다.

이에 참가인 근로자는 부당해고 구제신청을 하였다.

<심급별 경과>

[강원지노위] 사직원 제출 및 수리에 따라 근로관계는 합의해지 되었다며 구제신청을 기각
[중노위] 회사의 승낙 의사표시가 있기 전에 근로자가 사직원을 철회하였음에도 근로관계를 종료한 것은 해고에 해당하며, 서면 통지 의무 위반으로 부당해고라고 판단

[1심 법원] 재심 판정 취소

[2심 법원] 항소 기각

[대법원] 심리불속행기각

판결 요지

사직의 의사표시는 특별한 사정이 없는 한 당해 근로계약을 종료시키는 취지의 해약고지로 볼 것인 바, 사직 의사표시가 해약의 고지라고 인정되는 경우에는 그 의사표시가 사용자에게 도달한 이상 근로자로서는 사용자의 동의 없이 이를 철회할 수 없다. 그러나 근로자가 사직원을 제출하여 근로계약관계의 합의해지를 청약하는 경우에는 그에 대한 사용자의 승낙의사가 형성되어 그 승낙의 의사표시가 근로자에게 도달하기 이전에는 그 의사표시를 철회할 수 있고, 다만 근로자의 사직 의사표시 철회가 사용자에게 예측할 수 없는 손해를 주는 등 신의칙에 반한다고 인정되는 특별한 사정이 있는 경우에 한하여 그 철회가 허용되지 않는다. 근로자의 사직 의사표시가 당해 근로 계약을 종료시키는 취지의 해약고지인지 아니면 사용자에게 대한 근로계약관계 합의해지의 청약인지 여부는 그 의사표시가 기재된 사직서의 구체적인 내용, 사직서 작성·제출의 동기 및 경위, 사직서 제출 이후의 상황 등 제반 사정을 참작하여 판단해야 할 것이다(대법원 2000. 9. 5. 선고 99두8657 판결, 대법원 2007. 10. 11. 선고 2007다 11668 판결 등 참조).

패소 이유 (사실관계에 관한 인정 차이)

이 사건의 핵심 쟁점은 근로자의 사직의 의사표시를 근로계약관계 해지 “통고”로 볼 것인지, 아니면 합의해지를 “청약”한 것으로 볼 것인지에 관한 것인데, 중노위와 법원은 상반되는 해석을 하였다.

중노위는 참가인 근로자가 제출한 사직원은 근로계약관계의 합의해지를 “청약”한 것이어서, 원고 회사가 사직원을 수리하기 전에 참가인이 사직원 철회서를 제출함으로써 위 청약은 철회되었다고 판단하였다. 그리고 사직원이 적법하게 철회되었음에도 회사측이 근로계약관계를 종료한 것은 해고에 해당하고, 서면통지의무를 위반하여 부당해고라는 결론에 이르렀다.

반면 법원은 참가인 근로자가 사직원을 제출한 경위 및 이것이 징계 양정 등에 반영된 사실을 고려하여, 사직의 의사표시는 근로계약을 종료시키는 취지의 “해약의 고지”이므로, 사직의 의사표시가 원고 회사에게 도달한 이상 원고의 동의 없이 이를 철회할 수 없고, 근로계약관계는 참가인 근로자의 사직 의사표시에 기초하여 2017. 12. 31. 종료되었으므로, 재심판정은 위법하다고 판단하였다.

특히 법원은 “① 참가인은 참가인이 원고에게 끼친 손해와 관련하여 징계절차가 진행되는 중

에 이 사건 사직원을 제출하게 된 점, ② 참가인은 2017. 8. 2. 원고의 인사위원회에 출석하여 이 사건 사고에 대한 사죄와 반성의 의미로 2017. 12. 31.자로 사직하는 조건으로 사직서를 제출하겠다고 말한 점, ③ 원고의 인사위원회는 참가인이 이 사건 사직원을 제출한 사정을 참작하여 징계수위를 결정한 것으로 보이는 점 등”에 주목하여, 참가인의 2017. 8. 2. 사직의 의사표시는 근로계약을 종료시키는 취지의 해약의 고지로 봄이 타당하다고 보았다. 아울러 ‘비록 참가인이 제출한 사직원에 기재된 문구가 원고에게 허락을 청원하는 표현으로 작성되어 있다고 하더라도 그러한 단편적인 문구만으로 참가인의 사직의 의사표시가 합의해지의 청약에 해당한다고 단정할 수는 없고, 오히려 원고 회사의 인사규정에서 직원이 의원해직하고자 할 때에 별지 서식에 의한 사직원을 제출하도록 규정하여 위와 같은 문구는 원고가 제공한 서식에 기재된 부동문자일 가능성이 높은 점, 직원의 사직원 제출에 대하여 원고의 승인이나 수락 절차에 관한 인사규정이 없는 점’ 등을 들어 참가인 근로자 및 중노위의 주장을 인정하지 않았다.

위 <판결 요지>에서 인용한 것처럼, 대법원 판례에 의하면 사직의 의사표시는 “특별한 사정이 없는 한” 당해 근로계약을 종료시키는 취지의 해약고지에 해당하며, 해약고지인지 청약인지의 최종 판단은 의사표시가 기재된 “사직서의 구체적인 내용, 사직서 작성·제출의 동기 및 경위, 사직서 제출 이후의 상황 등” 제반 사정을 참작하여 이루어져야 한다.

이 사건의 경우, 사직서의 문구는 회사의 서식에 기재된 부동문자일 뿐이었고, 근로자 자신의 비위행위에 대해 책임을 지는 차원에서 사직의 의사를 밝힌 것이었으며, 실제 사직 의사표시가 징계 수위 결정에도 영향을 미친 사실이 인정된다. 이처럼 이 사건 사직의 의사표시를 ‘청약’으로 볼만한 특별한 사정이 있다고 보기 어렵다. 중노위로서는 대법원 판례 법리가 확립된 쟁점이라면 그에 입각하여 판단함으로써 판정의 신뢰 높일 필요 있다.

일련번호	2020-24					
판결번호	서울행정법원 2020. 1. 31. 2019구합00000 판결					
중노위판정번호	중노위 2019. 4. 15. 중앙2019부해188					
사건 종류	부당해고					
세부 쟁점	성희롱, 징계 양정, 재량권 일탈·남용					
심급별 소송결과	1심 법원	재심판정취소	2심 법원		대법원	
원 고	○○○○○○○연구원		참 가 인		허○○	
피 고	중앙노동위원회위원장		피고측 대리인 선임 여부		선임 안 함	
노동조합 지원 여부	없음		원고측 대리인 선임 여부		선임	
재심 결과	초심 취소					
초심의 대법원 판례 일치여부	일치		재심의 대법원 판례 일치여부		불일치	
기타 특이사항						

주요 사실관계

<사건 개요>

가. 원고는 법률에 따라 설립된 연구기관으로 방송·통신·미디어 관련 연구개발 등을 수행하며, 산하에 통신보안 연구기술과 관련된 임무를 수행하는 D연구소(이하 '이 사건 연구소')를 부설기관으로 두고 있다. 피고보조참가인(이하 '참가인'이라 한다)은 2015. 9. 15. 이 사건 연구소의 E센터장으로 채용되어 근무하였다.

나. 이 사건 연구소는 '미투 운동'과 관련하여 2018. 2. 14.부터 2018. 2. 23.까지 이 사건 연구소 내 성희롱·성범죄에 관한 제보 강화 기간을 운영하였다. E센터 소속 전·현직 연구원 12명은 2018. 2. 21. 이 사건 연구소에 참가인에 관한 성희롱 고충처리 신청서를 제출하였다. 이 사건 연구소는 2018. 3. 9.경부터 고충상담창구를 통해 참가인의 성희롱 사건에 관한 조사를 실시하였고, 3차에 걸쳐 성희롱·성폭력 심의위원회를 개최한 결과 2018. 6. 12. 참가인의 행위를 성희롱으로 의결하였다.

1) E센터 소속 전·현직 연구원 12명(I, J, Q, R, T, K, L, M, Z, AL, P, S)은 2018. 2. 21. 이 사건 연구소에 참가인에 관한 성희롱 고충처리 신청서를 제출하였다. 위 신청서에는 '참가인이 2015. 9. 부임 이후 현재까지 식사, 술자리 회식, 티타임, 세미나, 워크숍 등에서 남·여직원 가릴 것 없이 불쾌감을 유발하는 성적 발언을 지속하고 있다.'라는 내용과 함께 이 사건 징계사유 중 제1 내지 14징계사유에 해당하는 사례가 구체적으로 기재되어 있었다. 또한 위 신청서에서는 ① 근무 장소 분리, 타 부서 발령 등 2차 피해 방지를 위한 참가인과의 논리적·물리적 격리, ② 성희롱 사건에 관하여 상대적으로 약자일 수밖에 없는 여성 직원들의 이름은 가능한 부각되지 않도록 남성 직원들로만 증언 요청, ③ 이 사건 연구소 내 재발방지 대책 수립 등을 요청하였다.

2) 피해자들은 2018. 3. 2. 고충상담창구의 조사 과정에서 이 사건 징계사유에 해당하는 사례들이 발생한 시기와 장소, 피해자와 당시 느낌 등을 보다 구체적으로 보충한 '성희롱 고충 처리 신청 보충 자료'를 제출하였다. 피해자들 12명은 2018. 3. 9.부터 2018. 3. 13.까지 고충상담창구의 조사 과정에서 이 사건 징계사유에 관하여 문답 절차를 통한 조사를 받았다.

3) 참가인은 2018. 3. 21. 고충처리신청에 관한 조사 과정에서 이루어진 문답 조사에서, 직원들을 대상으로 H의 데카메론에 나오는 성직자와 민간인들의 성행위 관련 내용을 언급한 사실, 2017년 세미나에서 남녀의 성기가 사실적으로 표현된 작품을 자세히 설명한 사실, 2017년 "양잔디에서 골프채를 휘두르면 잔디가 깎여나간 자리가 마치여자의 XX(성기) 같다."라는 발언을 한 사실, 2016년 초 AM횃집 등 회식자리에서 건배사로 "잔대XX"라고 한 사실 자체는 인정하는 취지로 답변하였다.

다. 이 사건 연구소는 2018. 7. 25. 및 2018. 8. 17. 참가인에 대한 징계위원회를 개최하였고, 2018. 8. 24. 노골적인 성적 표현 및 성적 혐오를 불러일으키는 표현을 여러 장소에서 여러차례 행한 것을 징계사유로 하여(이하 '이 사건 징계사유')를 들어 참가인이 근무요령 제44조에 위반하고 성희롱·성폭력 예방지침 제3조에 해당하는 행위를 하였다고 보아 참가인에 대한 해임을 의결하였으며 이를 참가인에게 통지하였다. 이에 참가인은 재심을 신청하였으나, 이 사건 연구소는 2018. 9. 21. 및 2018. 10. 16. 재심징계위원회를 개최하여 2018. 11. 5. 재차 해임(2018. 11. 6.자)을 의결하였다.

라. 참가인은 이 사건 해임에 대하여 충남지방노동위원회에 구제신청을 하였다.

<심급별 결과>

[충남지노위] 징계사유가 모두 인정되고, 징계양정도 적정하다는 취지로 위 구제신청 기각
[중노위] 징계사유가 모두 인정되나, 징계재량권을 일탈·남용하였다는 취지로 위 재심신청 인용.
초심 취소

[1심 법원] 징계사유가 모두 인정되고, 징계재량권 일탈·남용도 없다는 이유로 재심판정 취소

판결 요지

1) 징계사유 인정 여부

성희롱을 사유로 한 징계처분의 당부를 다투는 행정소송에서 징계사유에 대한 증명책임은 그 처분의 적법성을 주장하는 피고에게 증명책임이 있다. 다만 민사소송이나 행정소송에서 사실의 증명은 추호의 의혹도 없어야 한다는 자연과학적 증명이 아니고, 특별한 사정이 없는 한 경험칙에 비추어 모든 증거를 종합적으로 검토하여 볼 때 어떤 사실이 있었다는 점을 시인할 수 있는 고도의 개연성을 증명하는 것이면 충분하다(대법원 2018. 4. 12. 선고 2017두74702 판결 등 참조).

12명에 이르는 다수의 피해자들 진술이 일관되고 상당히 구체적인 점, 피해자들의 진술이 고충처리 신청 이후 점점 구체화되기는 하였으나, 이는 고충처리 조사 및 성희롱·성폭력 심의위원회의 심의 과정에서 징계사유를 구체화할 필요성이 대두됨에 따라 피해자들이 기억을 상기하고 객관적인 자료를 수집하여 추가 제출하였기 때문인 것으로 보이는 점, 참가인과 피해자들의 관계, 고충처리 신청 경위와 취지 등에 비추어 보면 피해자들이 진술을 맞추거나 의도적으로 허위의 진술을 할 만한 이유를 찾아볼 수 없는 점, 참가인도 이 사건 징계사유에 해당하는 일부 언행을 한 사실 또는 그러한 경향의 언행을 지속한 사실을 인정하고 있는 점을 고려하면, 앞서 인정한 사실과 앞서 든 증거들에 의하여 참가인이 이 사건 징계사유에 해당하는 언행을 한 사실이 모두 인정된다.

참가인이 E센터장으로 재직할 기간 동안 약 2년 이상 위와 같은 행위가 계속적으로 이루어진 점, 참가인이 한 언행의 직접 상대방이 아니었다고 하더라도 그 자리에 동석해 있었던 직원의 경우 해당 언행의 내용이나 맥락에 따라 언어적 성희롱의 피해자가 될 수 있는 점, 피해자들은 참가인의 언행에 대하여 '당황스러움, 부끄러움, 수치스러움, 민망함, 굴욕감, 불쾌함, 혐오감' 등의 감정을 느꼈음을 일관되게 진술하고 있는 점 등에 비추어 보면, 이 사건 징계사유가 양성평등기본법 제3조 제2호, 남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률 제2조 제2호, 국가인권위원회법 제2조 제3호 라목 및 원고 근무요령 제44조, 이 사건 연구소 성희롱·성폭력 예방지침 제3조 제1호에서 정한 성희롱에 해당함을 충분히 인정할 수 있다.

2) 징계재량권 일탈·남용 여부

이 사건 징계사유는 참가인에게 사회통념상 고용관계를 존속시킬 수 없을 정도의 책임 있는 사유에 해당한다고 인정되므로, 이 사건 해임이 현저하게 타당성을 잃어 재량권의 범위를 벗어나거나 재량권을 남용한 것이라고 볼 수 없다. 따라서 원고의 주장은 이유 있다.

① 참가인은 정부출연 연구기관 산하 연구소의 센터장으로서 센터 소속 직원들에 대하여 지휘·감독하고 평가권한을 가지는 상급자의 지위에 있다. 그럼에도 참가인은 자신의 지위를 이용하여 직원들을 상대로 2년 이상의 기간 동안 직장 내 성희롱을 계속 반복함으로써 직원들의 근로환경과 근무의욕을 크게 저해하였으므로 그 비위의 정도가 중하다. 원고 징계요령 제21조, [별표6]에서 정한 징계양정기준에 의하면 기타 행위에 의한 품위유지의무 위반의 경우 비위의 정도가 심하고 고의가 있는 경우 해임이 가능하다.

② 이 사건 징계사유는 특정 직원을 상대로 성적인 사실관계를 묻거나 성적인 정보를 암시하는 발언이나 행동을 하거나, 여성의 성기를 일컫는 저속한 표현을 사용하거나, 다수의 직원이 참석한 세미나, 식사, 회식 자리에서 성관계나 성기에 관한 직접적인 표현을 한 것으로서 매우 부적절하다.

③ 참가인은 2015년부터 2017년까지 이 사건 연구소에서 실시하는 성희롱 예방교육을 이수하였음에도 자신의 잘못을 돌아보지 못한 채 분별없이 이 사건 징계사유에 해당하는 언행을 계속하

부록.1. 주요 사건 경과 및 패소 원인 분석

였다. 특정인의 직장 내 성희롱이 과거 왜곡된 사회적 인습이나 직장문화 등에서 비롯되어 특별한 문제의식 없이 습관적으로 이루어진 것이라고 하더라도 그러한 이유로 그 행위의 잘못을 가 법계 평가할 수 없다.

④ 성희롱 행위가 인정되는 이상 그 행위로 입게 되는 정신적 피해의 정도에 남녀의 차이가 반드시 존재한다고 단정할 수 없고, 이 사건 징계사유 중 남성 직원을 직접적인 상대방으로 삼아 이루어진 경우도 여럿 있으므로, 성희롱이 주로 신체적 접촉이 아닌 언어적 행위로 이루어진 점이나 피해자들 중 다수가 남성 직원이라는 점을 징계양정에서 참가인에게 유리한 사정으로 참작할 수 없다.

⑤ 피해자들이 참가인과의 관계, 참가인의 지위·직책, 이 사건 연구소 내에서 성희롱 문제가 제기된 적이 없었던 점 등을 고려하여 2018. 2. 전까지 참가인의 성희롱에 대한 불만이나 고충을 호소하지 못하였다는 사정은 결코 징계양정에서 참가인에게 유리한 사정으로 참작될 수 없다.

⑥ 참가인은 징계사유에 대한 조사 및 징계위원회 심의 과정뿐만 아니라 노동위원회를 거쳐 이 사건에 이르기까지 자신의 잘못을 인정하지 아니하고 언행을 정당화하며 책임을 회피하는 태도를 보이고 있다. 참가인은 피해자들이 문제를 제기한 이후 피해자들을 접촉하여 회유를 시도하는 등 2차 피해를 야기하기도 하였다. 이러한 참가인의 태도에 비추어 보면, 참가인이 이 사건 연구소에 계속 근무하는 것은 피해자들의 고용환경을 감내할 수 없을 정도로 악화시키는 결과를 가져올 수 있다고 보인다.

패소 이유 (사실관계에 관한 인정 차이)

이 사건은 신청인이 성희롱 가해행위로 인해 징계해고 된 사람이라는 점에 특수성이 있다. 이 사건에서 지노위는 징계사유가 모두 인정되고, 징계양정도 적정하다는 취지로 위 구제신청을 기각했으나, 중노위가 징계재량권을 일탈·남용하였다는 취지로 초심을 취소하고 구제신청을 인용했다. 그러나 사실관계를 보면, 행위자의 성희롱 발언이 여러 장소에서 당상히 장기간 동안 노골적으로 행해졌다는 점을 확인할 수 있다. 그와 같이 분명한 사실관계가 있음에도 불구하고 중노위가 사유는 있으나, 양정이 부당하여 징계 재량권을 일탈 내지 남용했다는 결론에 이른 것은 이해하기 어려운 판단이다.

이는 중노위 공익위원의 성희롱에 관한 인식이 매우 낮은 수준이거나 징계 재량권 일탈 또는 남용 여부를 판단하기 위한 전문성을 갖추지 못하였기 때문에 나온 판정이라고 이해하지 않을 수 없다. 사실관계 파악의 문제가 아니라, 확인된 사실관계에 대하여 법률 또는 법리를 적용하는 문제였다는 점에서 오류를 범하여 잘못된 판단을 하고, 그것이 피신청인이 법원에 취소소송을 제기하는 단초가 되었다는 점에서 대응방안 마련이 절실하다고 생각된다.

일련번호	2020-25					
판결번호	대법원 2021. 12. 27. 선고 2019두00000 판결					
중노위판정번호	중노위 2017. 10. 19. 중양2017부해827/부노144					
사건 종류	부당해고					
세부 쟁점	해고, 징계해고, 징계양정					
심급별 소송결과	1심 법원	재심판정취소	2심 법원	1심 유지	대법원	심리불속행기각
상 고 인	중양노동위원회위원장		참 가 인		최○○	

피상고인	○○택시(주)	피고측 대리인 선임 여부	선임 안 함
노동조합 지원 여부	있음	원고측 대리인 선임 여부	선임 함
재심 결과	초심 취소		
초심의 대법원 판례 일치여부	불일치	재심의 대법원 판례 일치여부	불일치
기타 특이사항			

주요 사실관계

<사건 개요>

가. 원고는 택시 여객운송사업을 하는 회사이고, 피고 참가인(이하 '참가인')은 원고의 택시를 운행하는 택시운전기사였다.

나. 참가인은 2016. 8. 13. 08:40경 원고의 C 택시를 운전하여 세종특별자치시 D아파트 E동 뒤편의 편도 4차로의 도로를 고운동 방면에서 어진동 방면으로 2차로를 따라 시속 약 77km로 진행하던 중 신호등이 설치된 교차로에서 신호를 위반하여 적색 신호에 위 교차로에 진입함으로써 반대차로에서 좌회전 신호에 따라 유턴 중이던 F 오토바이를 충격하는 교통사고를 일으켜, 위 오토바이 운전자에게 약 14주의 치료가 필요한 상해를 입게 하였다.

다. 원고는 2017. 1. 11. 상별위원회를 열어 참가인에 대한 '권고사직'을 의결하여 이를 참가인에게 통지하였으나, 참가인은 2017. 1. 18. 이의를 제기하며 재심 상별위원회를 신청하였다. 이에 원고는 2017. 2. 14. 참가인에게 이 사건 교통사고에 대한 수사종결 이후 재심 상별위원회를 개최하겠다고 통지하였다.

라. 참가인이 교통사고처리특례법위반(치상)으로 기소된 이후 원고는 2017. 4. 14. 재심 상별위원회를 개최하여 '단체협약 제100조 제4항 및 취업규칙 제42조 제4항의 「교통사고처리 특례법」 위반으로 인사사고 3주 이상 또는 물품피해 50만 원 이상 야기한 자'에 해당한다는 징계사유를 들어 참가인을 징계해고한다는 의결을 하였고, 2017. 4. 20. 위 의결에 따라 참가인에 대하여 징계해고 처분을 하였다.

마. 참가인은 2017. 5. 11. 충남지방노동위원회에 이 사건 해고는 정당한 이유가 없는 부당해고임과 동시에 노동조합가입을 이유로 불이익처급을 한 부당노동행위에 해당한다면서 구제신청을 하였다.

<심급별 결과>

[충남지노위] 참가인의 구제신청을 모두 인용하여, 부당해고이면서 부당노동행위임을 인정하고, 원고에 대하여 참가인의 원직복직 및 해고기간 미지급 임금의 지급을 명함

[중노위] 이 사건 해고가 부당노동행위에는 해당하지 아니한다고 하면서도, ① 이 사건 교통사고 이전에는 원고가 교통사고 발생을 이유로 징계처분한 사례가 없었던 점, ② 원고가 1개월 15일 동안 참가인에 대한 배차를 중단한 것은 적법한 징계절차나 인사명령 없이 이루어진 불이익 조치로서 사실상 징계처분과 다르지 아니고, 이는 이중징계의 소지가 있는 점, ③ 이 사건 해고에 앞서 참가인에게 다시 배차가 이루어진 것은 참가인을 해고하지 않겠다는 신뢰를 준 것으로 볼 수도 있는 점, ④ 원고가 주장하는 추가 분담금의 손해액을 인정하기 어려운 점 등의 사정을 들어 이 사건 해고가 징계 재량권을 남용하여 이루어진 부당해고에는 해당한다고 판단. 초심판정 중 부당노동행위 인정 부분만을 취소하고, 나머지 재심신청은 기각

[1심 법원] 해고의 정당한 사유가 있다고 보아 부당해고를 인정한 재심판정 취소
[2심 법원] 1심 판결 유지
[대법원] 심리불속행기각

판결 요지

징계권자가 일응의 징계양정기준을 정하고 그에 따라 징계처분을 하였을 경우에, 정해진 징계양정기준이 전혀 합리성이 없다거나 특정의 근로자만을 해고하기 위한 방편이라는 등의 특별한 사정이 없는 한, 이로써 바로 해당 징계처분이 형평의 원칙에 반하여 위법하다고 할 수는 없다(대법원 1997. 9. 12. 선고 97누7165 판결, 대법원 2015. 11. 26. 선고 2015두46550 판결 등 참조).

이 사건 교통사고는 원고와 참가인 사이에 '사회통념상 고용관계를 계속할 수 없을 정도로 근로자에게 책임 있는 사유가 있는 경우'에 해당하므로, 이를 들어 참가인을 징계해고한 이 사건 해고가 부당해고에 해당한다고 볼 수 없다.

(1) 원고의 취업규칙이 교통사고 피해자에게 3주 이상의 치료가 필요한 상해를 입히거나 50만 원 이상의 대물 손해를 입게 한 경우를 징계해고 사유가 되는 것으로 정하고 있는데, 택시운전기사가 승객의 안전을 책임지는 여객운송업무 종사자로서 교통법규를 준수할 의무뿐만 아니라 일반적인 운전자보다 더 높은 주의의무와 운전기량 및 자질이 요구됨에 비추어, 택시회사 소속 운전기사가 자신의 부주의로 위와 같은 사고를 발생시켰다면 이는 택시운전기사의 가장 본질적인 의무를 위반한 것으로 보아야 하므로, 위와 같이 일정한 규모 이상의 교통사고를 징계해고 사유로 삼은 것 자체가 부당하다고 볼 수 없다. 설령 위와 같은 취업규칙에 택시운전기사의 과실의 내용과 정도와 상대방의 과실 정도 등이 반영되어 있지 아니하여 위 취업규칙이 정한 해고사유 지나치게 확장될 위험이 있다거나 실무에 있어서 교통사고 자체를 원인으로 해고하는 예가 많지 않다고 하더라도, 이러한 사정은 징계해고의 재량권 일탈·남용을 판단함에 있어서 고려될 수 있는 요소일 뿐, 본인의 과실로 일정한 규모 이상의 교통사고를 야기한 택시운전기사를 해고할 수 있는 것으로 정한 위 취업규칙 자체가 부당하다고 볼 것은 아니다.

(2) 이 사건에서 원고의 주의의무 위반 내용은 신호등이 있는 교차로에서 신호를 위반한 것으로서, 그 위반의 정도가 매우 중하다고 평가할 수 있을 뿐만 아니라 이로 인하여 피해자에게 약 14주간의 치료를 요하고 치료비가 약 2억여원에 달하는 중한 상해를 입혔으므로, 이 사건 사고로 인하여 발생한 피해 내역이 매우 크다고 볼 수 있다.

(3) 이 사건에서 원고가 참가인에게 2016. 8. 14.부터 2016. 9. 30.까지 배차를 중지한 사실에 관하여는 당사자 사이에 다툼이 없고, 중앙노동위원회는 이러한 배차정지가 참가인의 의사에 반하는 것으로서 그 실질에 있어서 '정직'과 유사하므로 이 사건 해고는 동일한 원인에 대하여 실질적인 정직의 성격을 갖는 배차정지에 부가하여 이루어진 사실상 '이중징계'에 해당하는 것으로 보아 이 사건 해고가 과도한 징계양정에 해당한다고 판단한 것으로 보인다. 앞서 인정한 사실관계에 의하면, 원고가 2016. 8. 14.부터 2016. 9. 30.까지 참가인에 대하여 배차를 하지 아니한 것은 참가인의 사고 후유증 등 개인적인 사정을 들어 복직을 늦추고자 하는 참가인의 의사를 존중하여 이루어진 조치로 보일 뿐 달리 이러한 배차정지의 실질이 '정직'으로서 참가인의 의사에 반하여 배차를 거부한 것으로 평가할 수는 없다. 따라서 참가인에 대하여 앞서 본 바와 같이 2016. 8. 14.부터 2016. 9. 30.까지 배차가 정지되었고, 그에 더하여 이 사건 해고가 이루어졌다고 하여 이 사건 해고의 징계양정이 지나치게 중하다고 볼 수는 없다.

(4) L공제조합이 밝힌 원고의 향후 3년간 예상 추가분담금 계산에 의하면, 이 사건 사고로 인하여 원고는 L공제조합에 대하여 3년간 2억 원이 넘는 추가 분담금을 부담하여야 하는 손해를 입게 되었는바, 이 사건 교통사고로 원고에게 발생한 금전적 손실도 상당한 규모이다.

(5) 사용자가 비위행위가 있는 근로자를 징계하기 위한 절차를 거치는 도중에 근로자로부터 근로를 제공받았다고 하여 이를 두고 근로자에 대하여 당연히 징계해고를 하지 않겠다는 신뢰를 준 것으로는 볼 수는 없고, 따라서 원고가 참가인에 대하여 배차를 중단하였다가 이 사건 해고에 앞서 다시 배차를 하였다고 하더라도 마찬가지로 원고가 참가인에게 해고를 하지 않겠다는 신뢰를

준 것이라고 볼 수도 없다.

라. 소결론

따라서 참가인이 이 사건 사고를 발생시킨 것은 원고와 참가인 사이에 '사회통념상고용관계를 계속할 수 없을 정도로 근로자에게 책임 있는 사유가 있는 경우'에 해당하므로, 이를 들어 참가인을 해고한 이 사건 해고가 징계양정이 지나치게 무거운 것으로서 부당해고에 해당한다고 볼 수 없다. 그럼에도 중앙노동위원회는 이 사건 해고의 징계양정의 적정성에 대한 판단을 그르친 결과 이와 달리 이 사건 해고가 부당해고에 해당한다고 잘못 판단하고 말았으니, 중앙노동위원회의 이 사건 재심판정은 위법하므로 취소되어야 한다.

패소 이유 (사실관계에 관한 인정 차이)

이 사건은 사실관계는 동일하나, 그에 관한 법리적 판단의 결과가 달라진 사건이다. 쟁점은 참가인(신청인)의 행위들이 과연 징계사유에 해당하는가 하는 문제가 아니라, 비위행위 이후에 사용자가 취한 행동으로 인해 당사자가 해고당하지 않을 것이라는 신뢰를 가지게 되었는지, 이종징계에 해당하지는 않는지 등이 문제가 되었다. 이 두 가지 문제 모두 명확한 법리가 존재하는 부분이 아니어서 중노위의 판정에 결정적인 잘못이 있다고 보기는 어렵다.

다만, 1심 법원 판결 이후 중노위가 항소했으나, 2심 법원 판결을 통해 다시 한 번 패소했음에도 불구하고 대법원에 상고를 결정한 것은 유감이라고 하지 않을 수 없다. 대법원의 심리불속행기각판결은 중노위의 상고가 아무런 의미가 없는 조치였음을 보여준다. 중노위의 상고가 법무부의 소송지휘에 따른 결론이라는 것을 인정한다면, 권리구제형 행정심판이라는 노동위원회 제도의 특수성을 고려하여 노동위원회는 소송 수행에 있어서 법무부의 지휘를 받지 않도록 예외를 인정하는 방안을 적극적으로 고려해야 할 필요가 있다고 사료된다.

일련번호	2020-26					
판결번호	대법원 2020. 4. 29. 선고 2020두00000 판결					
중노위판정번호	중노위 2018. 3. 14. 2018부해110					
사건 종류	부당해고					
세부 쟁점	갱신기대권, 갱신 거절의 합리적 사유, 기간제 사용기간제한 예외					
심급별 소송결과	1심 법원	기각	2심 법원	1심 취소 (재심 취소)	대법원	상고기각 (심리불속행)
상 고 인	중앙노동위원회위원장		참 가 인		김○○	
피상고인	○○교통 주식회사		피고측 대리인 선임 여부		선임 안 함	
노동조합 지원 여부	없음		원고측 대리인 선임 여부		선임 함	
재심 결과	초심취소					

부록.1. 주요 사건 경과 및 패소 원인 분석

초심의 대법원 판례 일치여부	일치	재심의 대법원 판례 일치여부	불일치
기타 특이사항			

주요 사실관계

<사실관계>

참가인 근로자는 2007. 10. 17. 원고 회사에 입사하여 택시운전기사로 근무하다가 2012. 1. 31.자로 정년퇴직(만 60세)하였고, 이후 2012. 2. 1.부터 1년 단위로 촉탁직 근로계약을 체결하여 택시 기사로 근무하여 왔다. 원고 회사는 2017. 9. 30. 계약 만료를 앞두고, 참가인 근로자에게 기간 만료 통지를 하는 한편 재고용 평가를 실시하여 계약 갱신을 거절하였다.

원고 회사는 2014년 말 노동조합과 합의하에 촉탁직 기사 재고용 평가기준을 마련하였고 이를 2015년부터 일괄 적용하여 왔는데, 참가인 근로자는 2017년 재고용 평가에서 위 기준에 따라 여러 항목에서 감점이 발생하여 계약 갱신이 거절되었다(65세 이상 고령자(-10점), 운송수입금 미납(-10점) 및 경고(-5점), 교통사고(-20점) 등의 감점 항목에 해당함으로써, 재고용 기준인 70점에 미달하였다). 한편 2017년도 재고용 평가 대상 45명 중 4명이 70점 미달로 계약 갱신이 거절되었다.

이에 참가인 근로자는 부당해고 구제신청을 하였다.

<심급별 결과>

[부산지노위] 참가인 근로자에게 갱신기대권이 인정되지 않는다며 구제신청 기각

[중노위] 갱신기대권이 인정되고, 갱신 거절에 합리적 이유가 없어 부당해고라며 초심판정 취소

[1심 법원] 재심판정 유지

[2심 법원] 갱신 거절에 합리적 이유가 있다고 보아 1심 판결을 취소하였다. (재심 취소)

[대법원] 심리불속행기각

판결 요지

기간을 정하여 근로계약을 체결한 근로자의 경우, 그 기간이 만료됨으로써 근로자로서의 신분관계는 당연히 종료되고, 근로계약을 갱신하지 못하면 갱신거절의 의사표시가 없어도 그 근로자는 당연퇴직하는 것이 원칙이다. 그러나 근로계약, 취업규칙, 단체협약 등에서 기간이 만료되더라도 일정한 요건이 충족되면 당해 근로계약이 갱신된다는 취지의 규정을 두고 있거나, 그러한 규정이 없더라도 근로계약의 내용과 근로계약이 이루어지게 된 동기 및 경위, 계약 갱신의 기준 등 갱신에 관한 요건이나 절차의 설정 여부 및 그 실태, 근로자가 수행하는 업무의 내용 등 당해 근로관계를 둘러싼 여러 사정을 종합하여 볼 때, 근로계약 당사자 사이에 일정한 요건이 충족되면 근로계약이 갱신된다는 신뢰관계가 형성되어 있어 근로자에게 그에 따라 근로계약이 갱신될 수 있으리라는 정당한 기대권이 인정되는 경우에는, 사용자가 이에 위반하여 부당하게 근로계약의 갱신을 거절하는 것은 부당해고와 마찬가지로 아무런 효력이 없다. 이때 기간 만료 후의 근로관계는 종전의 근로계약이 갱신된 것과 동일하다(대법원 2011. 4. 14. 선고 2007두1729 판결, 대법원 2014. 2. 13. 선고 2011두12528 판결 등 참조).

그리고 기간제 및 단시간근로자 보호 등에 관한 법률(이하 ‘기간제법’)은 같은 법 제4조 제1항 단서의 예외 사유에 해당하지 않는 한 2년을 초과하여 기간제근로자로 사용하는 경우 기간의 정함이 없는 근로계약을 체결한 것으로 간주하고 있으나, 기간제법의 입법 취지가 기간제근로자 및 단시간근로자에 대한 불합리한 차별을 시정하고 근로조건 보호를 강화하기 위한 것임을 고려하면, 기간제법 제4조 제1항 단서의 예외 사유에 해당한다는 이유만으로 갱신기대권에 관한 위 법

리의 적용이 배제된다고 볼 수는 없다.

이러한 갱신기대권 법리와 함께 기간제법 등의 입법 취지, 사업장 내에서 정한 정년의 의미, 정년 이후에 기간제 근로계약을 체결하는 근로계약 당사자의 일반적인 의사 등을 모두 고려하면, 정년을 이미 경과한 상태에서 기간제 근로계약을 체결한 경우에는, 앞서 본 제반 사정 외에 해당 직무의 성격에 의하여 요구되는 직무수행 능력과 당해 근로자의 업무수행 적격성, 연령에 따른 작업능률 저하나 위험성 증대의 정도, 해당 사업장에서 정년을 경과한 고령자가 근무하는 실태 및 계약이 갱신되어 온 사례 등을 종합적으로 고려하여 근로계약 갱신에 관한 정당한 기대권이 인정되는지 여부를 판단하여야 한다(대법원 2017. 2. 3. 선고 2016두50563 판결 참조). 이때 갱신거절의 사유와 절차가 사회통념에 비추어 객관적이고 합리적이며 공정한지 여부에 관한 사정의 증명책임은 사용자가 부담한다(대법원 2017. 10. 12. 선고 2015두44493 판결 참조).

패소 이유 (사실관계에 관한 인정 차이)

중노위와 법원은 참가인 근로자가 정년퇴직 후 1년 단위의 촉탁직 근로계약을 체결해 온 만큼 만 55세 이상의 고령자로서 기간제근로자 사용기간 제한의 예외사유(기간제법 제4조 제1항 제4호)에 해당하는 점, 근로계약이 반복 갱신되어 갱신기대권이 인정되는 점에 의견이 일치하였다.

그러나 갱신 거절의 합리적 이유 존부에 관해서는 상반되는 결론을 도출하였다.

중노위는 ‘65세 이상 일괄 10점 감점’ ‘5년 지난 교통사고 2건을 이유로 20점 감점’ 등의 재고용 평가 기준은 객관적이고 합리적인 것이라고 보기 어렵다며 갱신 거절의 합리적 이유가 없어 부당해고라고 판정하였다. (1심 법원도 중노위와 같은 결론을 내렸다.)

반면 2심 법원은 ▲원고 회사는 2014년 말 노동조합 동의하에 촉탁직 근로자들의 계약 갱신 기준(재고용 규정)을 마련하여 2015년부터 모든 촉탁직 근로자의 재고용 평가에 위 기준을 예외 없이 적용하여 왔으며, 참가인 근로자에 대한 재고용 평가가 이루어진 2017년도에는 평가대상자 45명 중 70점 이상을 취득하지 못한 4명에 대한 계약 갱신이 거절되기도 한 바, 재고용 평가는 노사 협의로 만든 기준을 평가대상자 전원에 대하여 동일하게 적용하는 방식으로 이루어진 것으로 보이므로, 심사 절차가 형식적으로 진행되었다거나 사실을 명백히 오인하여 비합리적으로 평가되었다는 등의 특별한 사정이 없는 한, 심사 기준과 배점 방식, 평가 내용 등은 존중되어야 하는 점, ▲재고용 평가에서 참가인 근로자는 65세 이상이라는 이유로 ‘건강상태’ 항목에서 10점, 운송수입금 장기 미납을 이유로 ‘근태와 업무지시 위반’ 항목에서 10점, 2011. 4. 1. 및 2012. 4. 23. 교통사고 2건을 이유로 ‘교통사고’ 항목에서 20점, 운송수입금 장기 미납에 따른 경고 1건을 이유로 ‘경고나 시말서 제출, 취업규칙 위반’ 항목에서 5점이 각 감점되어(100점 - ‘건강상태’ 10점 - ‘근태와 업무지시 위반’ 10점 - ‘교통사고’ 20점 - ‘경고나 시말서 제출, 취업규칙 위반’ 5점), 총점 55점을 득하여 이는 근로계약 갱신이 불가능한 점수에 해당함이 명백한 점, ▲택시 운전기사는 장시간 운전 과정에서 상당한 집중력을 유지하면서 도로교통법에 따른 다양한 주의의무를 다하여 승객의 안전을 책임져야 하는데, 65세 이상의 고령자는 특별한 사정이 없는 한 젊은 운전기사보다 시력, 지구력, 체력, 반사신경 등 운전에는 필요한 능력이 부족할 수 있고, 그 경우 교통사고의 발생으로 승객이 다치거나 원고 회사에 손해가 발생할 가능성이 있어, 원고 회사는 이를 반영하여 재고용 평가 시 65세 이상에 대하여는 ‘건강상태’ 항목에서 특이사항이 없다면 일괄적으로 10점을 감점하여 왔으므로 참가인 근로자에게 특별히 부당하다고 보이지 않는 점, ▲참가인은 2016. 10.경부터 이 사건 계약 갱신 거절 시까지 지속적으로 원고 회사에 운송수입금 중 일부를 납부하지 않았고, 이에 원고 회사로부터 경고를 받아, 재고용 평가 중 ‘근태와 업무지시 위반’ 항목에서 10점이 감점된 것과 ‘경고나 시말서 제출, 취업규칙 위반’ 항목에서 5점이 감점된 것은 타당하다고 보이는 점(지속적이고 과다한 운송수입금 미납 행위는 취업규칙 및 임금협정서 위반으로 재고용 평가를 비롯한 인사고과에 불리하게 반영될 수 있는 사항임), ▲원고 회사는 재고용 평가 중 ‘교통사고’ 항목에서 입사 후 발생한 교통사고(경미한 자차 사고 제외) 1건 당 10점씩을 일괄적으로 감점하고 있는데, 이는 교통사고의 경중을 고려하지 않고 일률적으로 감점된다는 점에서 다소 불합리한 점이 있기는 하나, 택시운전기사의 교통사고 전력은 승객의 안전과 밀접한 관련이 있으므로, 해당 근로계약 기간 내에 발생한 교통사고뿐 아니라 그 이전에 발생한 교통사고도 재고용 평가에 반영되어야 할 필요성이 있는 점(실제로 원고 회사는 위 기준

부록.1. 주요 사건 경과 및 패소 원인 분석

을 모든 평가대상자에게 동일하게 적용하여 온 것으로 보이며, 자의적으로 참가인을 다르게 취급하였다거나 불이익을 입혔다고 보기 어려움) 등을 이유로, 참가인 근로자에 대하여 근로계약의 갱신을 거절한 데에는 사회통념상 상당하다고 인정될 만한 합리적인 이유가 있다고 보았다.

2심 법원이 중노위의 재심판정을 취소한 데에 이 사건 재고용 평가 기준의 적법성에 대한 상반되는 관점이 결정적이었던 것으로 보인다. 중노위는 연령을 이유로 일괄적으로 평가점수 10점을 감점한 것과 수년 전 교통사고를 이유로 20점을 감점하는 것이 지나치다는 데 주목한 것으로 보이는 반면, 2심 법원은 정년이 지난 촉탁직 근로자라는 점, 안전과 직결되는 택시운전기사라는 직업의 특수성, 재고용 평가기준이 노사합의로 마련되었고 그동안 대상자들에게 일률적으로 적용되어 온 사실 등에 주목한 것으로 보인다.

고령화로 향후 유사 사례가 증가할 가능성이 큰 만큼, 중노위로서는 정년이 지난 촉탁직 근로자의 계약 갱신과 관련해 법원이 어떤 점에 주목하여 갱신 거절의 합리성을 판단하고 있는지 충분히 검토하여 판정의 정확성을 높여 나가야 할 것이다.

일련번호	2020-28					
판결번호	서울고등법원 2020. 6. 5. 선고 2019누00000					
중노위판정번호	중노위 2018. 10. 26. 2018부해848					
사건 종류	부당해고					
세부 쟁점	무기계약직 전환 기대권, 기간제 근로계약					
심급별 소송결과	1심 법원	재심 취소	2심 법원	항소 기각	대법원	-
항 소 인	중앙노동위원회위원장		참 가 인		○○대학교치과병원	
피항소인	정○○		피고측 대리인 선임 여부		선임 안 함	
노동조합 지원 여부	없음		원고측 대리인 선임 여부		선임 함	
재심 결과	초심취소					
초심의 대법원 판례 일치여부	일치		재심의 대법원 판례 일치여부		불일치	
기타 특이사항	상고 없이 항소심 확정					

주요 사실관계

<사실관계>

이 사건 근로자는 2016. 4. 1. 육아휴직 대체근무자로 채용되어, 1, 2차 근로계약기간을 통틀어 2018. 3. 31.까지 2년간 근무하였는데, 참가인 회사는 이 사건 근로자가 연도별 근무성적평가 결과가 저조하였다는 점(2016년 평점 77.5점으로 34명 중 32등, 2017년 평점 84.5점으로 35명 중 25등)을 주된 근거로, 인사위원회의 심의를 거쳐 무기계약 전환을 거절하였다.

이에 이 사건 근로자는 경남지노위에 부당해고 구제신청을 하였다.

한편 참가인 회사는 무기계약직 전환 규정(대상자, 요건, 전환 절차 등)을 두고 있었고, 관행적으로 입사 2년차 도래 전 무기계약직 전환 기회를 부여하여 왔으며(휴직대체자에게도 적용), 2013년부터 2018년까지 전환 심의대상자 38명 중 22명이 무기계약직으로 전환된 바 있다. 또한 정부의 '공공부문 비정규직 근로자 정규직 전환 가이드라인'에 따라 2017. 12. 29. 정규직 전환 심의위원회를 개최하여 이 사건 근로자의 담당 직무를 정규직 전환 직무로 확정된 사실도 있다.

※ 참가인 회사의 '무기계약근로자관리규정' 주요 내용

- 동종의 유사한 업무에 종사하여 계약일로부터 근무기간 2년이 도래하고 계속근로의 의지가 있는 근무자를 대상으로 평가하여 인사위원회의 심의를 거친 후 적격자를 채용하도록 한다.
- 위 심의는 전환대상자의 업무실적, 직무수행능력, 직무수행태도 등을 종합적으로 고려하여야 한다.
- 인사위원회는 전환평가 결과를 고려하여 심의의결을 거쳐 최종 전환대상자를 선정한다.

<심급별 결과>

[경남지노위] 정당한 무기계약 전환 기대권이 인정되고, 합리적 이유 없이 무기계약 전환을 거절한 것은 부당하다고 판정

[중노위] 무기계약 전환 기대권은 인정하나, 거절에 합리적 이유가 있다며 초심 취소

[1심 법원] 합리적 이유 없이 무기계약직 전환을 거절한 것으로 보아 재심판정 취소

[2심 법원] 항소 기각 ※ 상고하지 않음.

판결 요지

기간을 정하여 근로계약을 체결한 근로자의 경우 그 기간이 만료됨으로써 근로자로서의 신분 관계는 당연히 종료되는 것이 원칙이다. 그러나 근로계약, 취업규칙, 단체협약 등에서 기간만료에도 불구하고 일정한 요건이 충족되면 당해 근로계약이 갱신된다는 취지의 규정을 두고 있거나, 그러한 규정이 없더라도 당해 근로관계를 둘러싼 여러 사정을 종합하여 볼 때 근로계약 당사자 사이에 일정한 요건이 충족되면 근로계약이 갱신된다는 신뢰관계가 형성되어 있어 근로자에게 그에 따라 근로계약이 갱신될 수 있으리라는 정당한 기대권이 인정되는 경우에는 사용자가 이에 위반하여 부당하게 근로계약의 갱신을 거절하는 것은 부당해고와 마찬가지로 아무런 효력이 없고, 이 경우 기간만료 후의 근로관계는 종전의 근로계약이 갱신된 것과 동일하다고 보아야 한다(대법원 2011. 4. 14. 선고 2007두1729 판결 등 참조).

구 기간제법은 제5조에서 '사용자는 기간의 정함이 없는 근로계약을 체결하고자 하는 경우에는 당해 사업 또는 사업장의 동종 또는 유사한 업무에 종사하는 기간제근로자를 우선적으로 고용하도록 노력하여야 한다.'라고 규정하고, 제8조 제1항에서 '사용자는 기간제근로자임을 이유로 당해 사업 또는 사업장에서 동종 또는 유사한 업무에 종사하는 기간의 정함이 없는 근로계약을 체결한 근로자에 비하여 차별적 처우를 하여서는 아니 된다.'라고 규정하고, 제9조 제1항에서 '기간제근로자 또는 단시간근로자는 차별적 처우를 받은 경우 노동위원회법 제1조의 규정에 따른 노동위원회에 그 시정을 신청할 수 있다.'라고 규정하고 있다. 위 각 규정의 내용 및 입법 취지에 앞서 본 기간제근로자의 기대권에 관한 법리를 더하여 살펴보면, 근로계약, 취업규칙, 단체협약 등에서 기간제근로자의 계약기간이 만료될 무렵 인사평가 등을 거쳐 일정한 요건이 충족되면 기간의 정함이 없는 근로자로 전환된다는 취지의 규정을 두고 있거나, 그러한 규정이 없더라도 근로계약의 내용과 근로계약이 이루어지게 된 동기와 경위, 기간의 정함이 없는 근로자로의 전환에 관한 기준 등 그에 관한 요건이나 절차의 설정 여부 및 그 실태, 근로자가 수행하는 업무의 내용 등 당해 근로관계를 둘러싼 여러 사정을 종합하여 볼 때, 근로계약 당사자 사이에 일정한 요건이 충족되면 기간의 정함이 없는 근로자로 전환된다는 신뢰관계가 형성되어 있어 근로자에게 기간의 정함이 없는 근로자로 전환될 수 있으리라는 정당한 기대권이 인정되는 경우에는 사용자가 이를 위반하여 합리적 이유 없이 기간의 정함이 없는 근로자로의 전환을 거절하며 근

로계약의 종료를 통보하더라도 부당해고와 마찬가지로 효력이 없고, 그 이후의 근로관계는 기간의 정함이 없는 근로자로 전환된 것과 동일하다고 보아야 한다(대법원 2016. 11. 10. 선고 2014두45765 판결 참조).

기간제 근로계약을 체결한 근로자에게 근로계약 갱신에 대한 정당한 기대권을 인정하는 취지는 기간제 근로계약의 남용을 방지함으로써 기간제근로자에 대한 불합리한 차별을 시정하고 기간제근로자의 근로조건 보호를 강화하려는 데에 있다. 그러므로 근로자에게 이미 형성된 갱신에 대한 정당한 기대권이 있음에도 불구하고 사용자가 이를 배제하고 근로계약의 갱신을 거절한 데에 합리적 이유가 있는지가 문제 될 때에는 사용자의 사업 목적과 성격, 사업장 여건, 근로자의 지위 및 담당 직무의 내용, 근로계약 체결 경위, 근로계약의 갱신에 관한 요건이나 절차의 설정 여부와 그 운용 실태, 근로자에게 책임 있는 사유가 있는지 여부 등 당해 근로관계를 둘러싼 여러 사정을 종합하여 갱신 거부의 사유와 그 절차가 사회통념에 비추어 볼 때 객관적이고 합리적이며 공정한지를 기준으로 판단하여야 하고, 그러한 사정에 대한 증명책임은 사용자가 부담한다(대법원 2017. 10. 12. 선고 2015두44493 판결 등 참조).

패소 이유 (사실관계에 관한 인정 차이)

중노위와 법원은 공통적으로 참가인 회사가 무기계약직 전환에 관한 대상자 요건 및 전환 절차 등에 관한 규정을 두고 있었다는 이유로, 이 사건 근로자에게 무기계약직 전환 기대권을 인정하였다.

하지만 무기계약 전환 거절에 합리적인 이유를 인정할 수 있는지 여부에 관해서는 상반되는 결론을 내렸다.

중노위는 ‘인사위원회의 심의를 거쳐 이 사건 근로자를 무기계약 전환 부적격자로 결정하였고, 2013년부터 모든 심의대상자가 무기계약으로 전환되지는 않았으며, 이 사건 근로자는 근로자는 2016년, 2017년 근무성적평가에서 각각 34명 중 32등, 35명 중 25등의 낮은 평가를 받았다’는 사실에 주목하여, 무기계약직 전환을 거절한 데 합리적 이유가 있다고 판정하였다.

그러나 1·2심 법원은 참가인 회사의 ‘근무평가 자체로 객관성과 공정성이 담보된 것이라고 볼 수 없다’며, 무기계약직 전환 거절에 합리적인 이유가 있다고 보기 어렵다고 보아 재심판정을 취소하였다. 법원은 ‘참가인의 비정규직 근무성적평가는, ㉠ 평가항목(평가요소)을 업무능력(기초적인 지식, 이해·판단력, 업무추진력, 종합실무능력), 업무태도(직장의 관습, 규칙, 규정 준수, 대민 친절성 및 마찰해소 노력, 직장 동료와의 업무협조 정도), 업무실적(자기업무의 신속성 및 정확성, 창의성 및 노력도, 조직에 대한 기여도)으로 하여, 평가기준(탁월 8, 우수 6, 보통 5, 미흡 4)에 따른 평점을 매기고 그 평점 합계(100점 만점)를 계산하는 방식으로, 대상 근로자의 상급 감독자가 제1평정을 하고, 제1평정자의 직근 상급 감독자가 제2평정을 한 다음 각 평정 점수의 평균을 구하는 절대평가 방식으로 이루어진 점, ㉡ 그런데 2016년 및 2017년 기간제 근무성적 평정내역 중 각 등수는 대상 근로자들의 직종 구분, 평정자의 동일 여부 등을 전혀 고려하지 아니한 채 위와 같이 절대평가 방식으로 산정된 평균 점수를 그 점수 순서대로 나열한 것에 불과하고, 대상 근로자의 담당 직무 내용에 대한 고려, 평정자 사이의 점수 편차를 조정하는 과정 등을 전혀 거치지 않아, 과연 그 평점 또는 등수가 객관성과 공정성을 가지는 것인지 의심스러운 점, ㉢ 이 사건 근로자를 포함한 7명의 무기계약직 전환 심의 대상자에 대한 근무성적평가표 역시 위와 같이 산정한 2016년 및 2017년 근무성적 평가 점수의 평균 점수를 낸 것에 불과하고, 참고사항으로 전체적으로 점수가 높은 이유에 관하여 ‘소속 부서장들이 기간제근로자의 무기계약직 채용을 염두에 두고 자신의 부하가 채용되기를 바라는 마음에 실제보다 높은 점수 부여’라고 기재되어 있기도 한 점, ㉣ 참가인의 각 연도별 계약직 근무성적평가는 대상 근로자의 상급 감독자 또는 제1평정자의 직근 상급감독자가 공석일 경우 1인의 평정만으로 최종 점수가 결정되기도 한 점 등에 비추어, 그 자체로 객관성, 합리성이나 공정성을 인정하기 어렵다’고 판단하였다.

그러면서 ‘인사위원회의 심의를 거쳐다거나, 2013년부터 2018년까지 참가인의 무기계약직 전환 심의대상자 38명 중 22명만이 무기계약직으로 전환되었다는 등의 사정만으로 전환 거절에 합리적인 이유가 있다고 볼 수는 없다’고 설시하였다.

요컨대 법원은 중노위와 달리 이 사건 전환 거절의 주된 이유가 된 근무평가가 그 자체로 객관적이고 공정한 것이었는지에 주목하여 중점적으로 검토하였다. 근무성적평가 내지 인사평가 결과에 따라 근로관계 종료 여부가 결정되는 경우에는 그 평가 자체의 공정성과 합리성, 객관성이 담보되어야만 근로관계 종료가 적법한 것이 될 수 있다는 법리는 그동안 다수의 판결례를 통해 확인되어 온 바 있다. 그럼에도 중노위의 재심 과정에서 근무평가 자체의 적법성에 대한 검토가 다소 미흡했던 것으로 보인다.

일련번호	2020-31					
판결번호	대법원 2020. 7. 23. 선고 2019두00000					
중노위판정번호	중노위 2018. 4. 10. 2018부해170					
사건 종류	부당해고					
세부 쟁점	당사자 적격(근로기준법상 근로자성)					
심급별 소송결과	1심 법원	재심 유지	2심 법원	1심 취소	대법원	상고 기각
상 고 인	중앙노동위원회위원장, 박○○		참 가 인		박○○	
피상고인	○○○중앙총부		피고측 대리인 선임 여부		선임 안 함	
노동조합 지원 여부	없음		원고측 대리인 선임 여부		선임 함	
재심 결과	초심유지					
초심의 대법원 판례 일치여부	불일치		재심의 대법원 판례 일치여부		불일치	
기타 특이사항						

주요 사실관계

<사실관계>

원고는 ○○○ 교회를 운영하는 종교단체이고, 참가인은 원고 교회에 오랜 기간 봉사하고 예전에 법학을 공부한 적이 있어 법률전문가이자 교회 행정의 책임자로 인정받아, 종무위원과 교무관장으로 직무를 수행하였다. 또한 종무위원급 이상인 교인만 임명되는 원고 산하 출판사의 이사와 봉사직인 여러 위원회 위원이나 간사를 겸하였다. (참가인은 매월 일정 금액의 보수를 받았으나, 교회 내부에서는 종무위원과 교무관장을 명예직이자 봉사직으로 널리 인식하고 있었다.)

원고 내부에서 발생한 갈등 과정에서, 참가인의 대응 방식이 ○○○헌(○○○의 최상위규범)을 위반하고 교단 내의 기강과 위계질서를 어지럽혔다는 이유로, 원고는 교인의 징벌에 관한 규정(○○○헌, 감사원 규정)에 따라 참가인에게 정권(교인으로서 권리를 정지) 3년의 징계를 결정하였고, 재심의를 거쳐 확정되었다.

부록.1. 주요 사건 경과 및 패소 원인 분석

※ ○○○헌에 따르면, 종무위원이 정권 3년의 징계를 받은 경우 징계 확정일에 당연히 종무위원 지위를 3년간 상실(당연해임)하고, 그 종무위원 지위 상실일에 당연히 3년간 교무관장의 지위를 상실(당연해임) 한다.

이후 참가인은 원고에게 퇴직금의 지급과 실업수당을 받기 위한 해고통지서의 발송을 요구하였고, 이에 원고는 퇴직금을 지급하고, 해고통지서(정권 3년의 징계에 의하여 정무위원과 교무관장의 각 지위를 상실했다는 내용)를 발송하였다. 한편 참가인은 이것이 부당해고라며 구제신청을 하였다.

<심급별 결과>

[서울지노위] 근로기준법상 근로자이고, 부당해고로 보아 근로자의 구제신청을 인용

[중노위] 초심 유지

[1심 법원] 재심판정 유지

[2심 법원] 근로기준법상 근로자가 아니라는 이유로, 1심 판결 및 재심판정 취소

[대법원] 상고 기각

판결 요지

근로기준법상 근로자에 해당하는지 아닌지는 계약의 형식이 고용계약인지 도급계약인지보다 그 실질에 있는 근로자가 사업 또는 사업장에 임금을 목적으로 종속적인 관계에서 사용자에게 근로를 제공하였는지에 따라 판단하여야 한다. 여기에서 종속적인 관계가 있는지는, 업무 내용을 사용자가 정하고 취업규칙 또는 복무(인사)규정 등의 적용을 받으며 업무수행 과정에서 사용자가 상당한 지휘·감독을 하는지, 사용자가 근무시간과 근무 장소를 지정하고 근로자가 이에 구속을 당하는지, 노무 제공자가 스스로 비품·원자재나 작업 도구 등을 소유하거나 제3자를 고용하여 업무를 대행하게 하는 등 독립하여 자신의 계산으로 사업을 영위할 수 있는지, 노무 제공을 통한 이윤의 창출과 손실의 초래 등 위험을 스스로 안고 있는지와, 보수의 성격이 근로 자체의 대상적 성격인지, 기본급이나 고정급이 정하여졌는지 및 근로소득세를 원천징수하는지 등의 보수에 관한 사항, 근로 제공 관계의 계속성과 사용자에 대한 전속성의 유무와 정도, 사회보장제도에 관한 법령에서의 근로자 지위 인정 여부 등의 경제적·사회적 여러 조건을 종합하여 판단해야 한다(대법원 2013. 6. 27. 선고 2011다44276 판결 등 참조).

종교활동은 헌법상 종교의 자유와 정교분리의 원칙에 의하여 국가의 간섭으로부터 그 자유가 보장되어 있다. 따라서 국가기관인 법원도 종교단체 내부관계에 관한 사항에서는 그것이 일반 국민으로서의 권리·의무나 법률관계를 규율하는 것이 아닌 이상 원칙적으로 실체적인 심리·판단을 하지 아니함으로써 당해 종교단체의 자율권을 최대한 보장해야 한다. 한편 종교단체가 그 교리를 확립하고 종교단체 및 신앙의 질서를 유지하기 위해 교인으로서의 비위가 있는 사람을 종교적인 방법으로 제재하는 것은 종교단체 내부의 규제로서 헌법이 보장하는 종교의 자유의 영역에 속하는 것임에 비추어, 법원이 그 징계의 효력 자체를 사법심사의 대상으로 삼아 효력 유무를 판단할 수는 없다(대법원 2005. 6. 24. 선고 2005다10388 판결, 대법원 2011. 10. 27. 선고 2009 다 32386 판결 등).

패소 이유 (사실관계에 관한 인정 차이)

이 사건의 핵심 쟁점은 종교단체 교인이 근로기준법상 근로자에 해당하는지에 관한 것이다. 중노위는 제출된 사실관계들로부터 근로자성을 인정하고 부당해고로 판정하였지만, 2심 법원과 대법원은 근로자가 아닌 것으로 보아 중노위의 판정을 취소하였다.

중노위는 ‘▲근무시간과 근무장소가 원고의 ‘인사관리 및 복무규정’에 의하여 정해진다. ▲보직인 교무관장은 원고의 ‘보수규정’에 따르면 선출직이나 임명직과 구별되는 일반직으로 분류된다. ▲근로의 대가로서 ‘보수규정’에 따라 기본급과 수당의 항목으로 월 220만원의 고정된 급여를 지

급받아 온 사실이 확인된다. ▲업무 중 참가인의 전결사항은 없고 모두 상급자의 결재를 받아 이루어졌고, 징계사유 중 하나가 출장업무의 사전품의 및 사후보고 미준수인 것으로 보아 이 사건 사용자에게 의한 지휘·감독이 있는 것으로 보인다. ▲근로소득세를 납부하고 고용보험을 비롯하여 4대 보험에 가입되어 있다. ▲원고가 참가인에게 ‘해고통지서’를 발송하였다.다’는 점에 주목하여, 참가인을 근로기준법상 근로자로 판단한 후, 인사관리 및 복무규정 위반하여 인사위원회의 의결 없이 징계하였고, 해고통지절차에 위법성이 있다는 이유로 부당해고라고 결론 내렸다.

반면 2심 및 대법원은 ‘▲참가인의 종무위원과 교무관장으로 임명의 경위나 배경, ▲매월 일정 금액의 보수를 받았으나 임금을 목적으로 노무를 제공한 것이 아니라 그 일정 종교활동에 헌신한 것에 대한 명예로운 사례이었다고 봄이 타당한 점(종무위원은 교무관장으로 임명되면 자신의 생업마저 그만두고서라도 교무관장의 직책을 수행하기도 했다. 이는 교회에 헌신적으로 봉사하기 위한 것으로 인식되었다. 교무관장으로서 이같이 교회에 헌신하여 봉사하는 데에 원고는 명예로운 사례를 함으로써 조금이나마 보답함과 아울러 그 종교적 활동에 전념할 수 있도록 하기 위하여, 교무관장에게 ‘임금’ 명목이 아니라 ‘보수’ 명목-활동비 명목을 포함-으로 매월 일정 금액도 지급하고 고용보험 자격도 취득하게 하였다), ▲민법 제686조는 “수임인도 특별한 약정이 있으면 위임인에 대하여 ‘보수’를 청구할 수 있다”고 규정함에 비추어 보면, 원고의 보수규정에 따라 교무관장에게 지급하는 ‘보수’를 근로의 대가로 근로기준법에 규정된 임금으로 이해해야만 하는 것은 아닌 점, ▲참가인과 같은 교무관장은 교무관의 의사를 정하는 과정에서 종무위원회의 의결을 거쳐야 한다는 것 외에는 결정적 지위에 있으면서도 상급자(교령, 종무원장)의 구체적인 업무지시를 받은 것도 아니고, 상급자가 의사 결정한 내용을 지시받아 단순히 실행하는 지위에 있지도 않은 점, ▲원고의 인사관리 및 복무규정은 각 관의 차장 관서 이하 근로자들에게는 전면적으로 적용되지만, 이들과 지위를 달리하는 각 관장에게까지 전면적으로 적용될 것을 염두에 둔 것은 아니었다고 보이는 점(교무관장은 참가인의 임명 이전부터 지금까지 위 규정과 무관하게 단지 교령의 의사에 따라 자유롭게 임면되었고, 더구나 교무관장은 그의 지휘·감독을 받는 차장 관서와 다르게 인사고과의 대상도 아님. 또한 원고의 인사관리 및 복무규정은 원고 내부에서 근무하는 각 차장 관서 이하 등의 근로자를 관리할 목적으로 행정청의 지도에 따라 참가인이 적극 관여하여 제정됨) 등’에 주목하여, 참가인이 임금을 목적으로 원고에게 종속되어 노무를 제공했다고 인정하기 어렵다며, 근로자성을 부정하였다.

그러면서 추가적으로, 원고가 참가인에게 정무위원과 교무관장의 각 지위를 상실했다는 내용을 담은 해고통지서를 교부한 것은 원고가 참가인과 관계를 종료시키는 의사표시가 아니라, 참가인에 대한 정권 3년의 징계가 확정됨으로써 참가인이 정무위원과 교무관장의 지위를 상실했다는 사실을 알려준 것(관념의 통지)에 불과하다고 판단하였다.

근로기준법상 근로자로 인정되기 위한 특성들(임금에의 종속성 등)의 판단에 있어, 대법원 및 2심 법원은 분쟁 당사자가 종교단체의 교인이라는 점에 주목하여, 해당 직무에의 임명 과정, 교인들의 보편적 인식, 직무수행의 특수성에 보다 무게를 두고 판단한 것으로 보인다. 아울러 법원은 이러한 관점의 연장선상에서 종교단체의 교인에 대한 징계조치가 원칙적으로 사법심사의 대상이 아니라는 법리도 재차 확인한 것으로 보인다.

그에 반해 중노위는 일반적인 회사나 단체와 개인 간 분쟁과 동일한 관점에서 다소 형식적으로 접근한 면이 있는 것으로 보이며, 전형적인 노무제공을 둘러싼 법률 분쟁임을 전제로 관련 사실을 해석하고 법리를 적용한 것이 아닌가 한다. 종교단체의 경우 헌법상 종교의 자유가 보장되고, 그에 따라 인적 구성 및 조직, 활동에 각기 특수성이 있는 만큼, 이를 최대한 존중하여 적법성 판단에 신중을 기할 필요가 있다 할 것이다.

일련번호	2020-32
판결번호	서울고등법원 2020. 7. 24. 선고 2019누00000

부록.1. 주요 사건 경과 및 패소 원인 분석

중노위판정번호	중노위 2018. 3. 2. 2017부해1188					
사건 종류	부당해고					
세부 쟁점	당사자적격(근로기준법상 근로자성)					
심급별 소송결과	1심 법원	재심 취소	2심 법원	항소 기각	대법원	-
항 소 인	중앙노동위원회위원장		참 가 인		최○○	
피항소인	주식회사 ○○○○○○		피고측 대리인 선임 여부		선임 안 함	
노동조합 지원 여부	없음		원고측 대리인 선임 여부		선임 함	
재심 결과	초심유지					
초심의 대법원 판례 일치여부	불일치		재심의 대법원 판례 일치여부		불일치	
기타 특이사항	상고 없이 항소심 확정					

주요 사실관계 <사실관계> 원고 회사는 신규사업을 모색하던 중, 당시 타 회사에서 반도체 관련 사업을 담당하던 참가인을 2015. 5. 11. 신사업 총괄 임원으로 선임하였다. 원고의 인사위원회는 참가인이 제시한 사업성 분석 보고서 등과 참가인의 경력을 이유로 신사업 총괄로 선임 의결한 것이었다. 원고와 참가인은 선임 다음날, 아래와 같이 ‘사업약정서(신규사업 추진 약정서)’를 작성하였다. * <요지> 참가인이 신규사업을 진행하여 흑자 전환 후 신규법인을 설립함에 있어 필요한 사항을 정함 * <주요 조항> 제4조(회사 규정의 준수) 참가인이 입사하여 신규사업 부문을 진행하는 경우 참가인 및 참가인이 영입한 초기 영업 인원은 원고의 정관 및 내부 규정을 준수하여야 한다. / 제5조(신규법인의 설립 시기) 신규법인 설립 시기는 참가인이 회사에 입사하여 영위하는 신규사업 부문이 흑자로 전환된 이후 해야 한다. / 제15조(합의해지) ① 참가인이 원고에 입사한 이후에는 본 계약을 해제할 수 없다. 다만, 참가인이 원고에 입사하여 신규사업을 진행한 후 2년 이내에 흑자가 발생하지 아니할 경우, 참가인과 원고는 상호 합의하여 본 계약을 해지할 수 있다. 한편 원고는 등기임원 수준의 급여와 처우를 제공하였으며, 참가인은 이메일로 원고의 전무에게, 2017. 1월 이후 주간회의에 참석하여 원고 대표이사에게 업무 현황을 보고하였다. 원고 회사가 2017. 6. 28. 참가인에게 내용 증명(사업약정서 제15조에 의거하여 2017. 6. 29.자로 계약을 종료하고 해고를 통보, 해고수당은 2개월분 급여인 13,334,000원이며 퇴직금과 함께 14일 이내에 지급 등)을 보내고, 2017. 6. 29. 취업규칙 등을 근거로 ‘해고(계약만료)’의 인사명령을 통보하자 참가인은 부당해고 구제신청을 하였다. <심급별 결과> [충남지노위] 참가인(비등기이사)은 근로자이고, 계약만료에 따른 해고가 부당하다고 판정 [중노위] 초심 유지
--

[1심 법원] 참가인은 근로자가 아니라 위임계약상 수임인이라며 재심판정 취소
 [2심 법원] 항소 기각 ※ 상고하지 않음.

판결 요지

회사의 임원이라고 하더라도, 업무의 성격상 회사로부터 위임받은 사무를 처리하는 것으로 보기에 부족하고 실제로는 업무집행권을 가지는 대표이사 등의 지휘·감독 아래 일정한 노무를 담당하면서 그 노무에 대한 대가로 일정한 보수를 지급받아 왔다면, 그 임원은 근로기준법에서 정한 근로자에 해당할 수 있다. 그러나 회사의 임원이 담당하고 있는 업무 전체의 성격이나 업무수행의 실질이 위와 같은 정도로 사용자의 지휘·감독을 받으면서 일정한 근로를 제공하는 것에 그치지 아니하는 것이라면, 그 임원은 위임받은 사무를 처리하는 지위에 있다고 할 수 있으므로, 근로기준법상 근로자에 해당한다고 보기는 어렵다. 특히 대규모 회사의 임원이 전문적인 분야에 속한 업무의 경영을 위하여 특별히 임용되어 해당 업무를 총괄하여 책임을 지고 독립적으로 운영하면서 등기이사와 마찬가지로 회사 경영을 위한 의사결정에 참여하여 왔고 일반 직원과 차별화된 처우를 받은 경우에는, 이러한 구체적인 임용 경위, 담당 업무 및 처우에 관한 특수한 사정을 충분히 참작하여 회사로부터 위임받은 사무를 처리하는지를 가려야 한다(대법원 2017. 11. 9. 선고 2012다10959 판결 참조).

결국 근로기준법의 적용을 받는 근로자에 해당하는지 여부는 계약의 형식에 관계없이 그 실질에 있어서 임금을 목적으로 종속적인 관계에서 사용자에게 근로를 제공하였는지 여부에 따라 판단하여야 할 것이며, 그에 대한 증명책임은 근로자임을 주장하는 자에게 있다 할 것이다[대법원 2006. 11. 9. 선고 2006다54637, 2006다54644(병합) 판결 참조].

패소 이유 (사실관계에 관한 인정 차이)

중노위와 법원은 이 사건 사실관계의 경중, 그 법적 의미를 달리 해석하여, 상반되는 결론을 도출하였다.

먼저 중노위 근로자성을 인정하고, 이를 전제로 이 사건 해고가 정당하지 않다고 판정하였는데, ‘▲입사 시 작성한 [사업약정서] 내용에 비추어 참가인 근로자가 맡은 신규사업부분이 흑자 전환되기 전까지는 근로자로 보이고, 회사 규정을 준수하게 되어 있는 점, ▲구두로 근로조건을 약정하고 매월 근로의 대가로 법정수당이 포함된 고정적인 급여를 지급받은 점, ▲비등기이사로서 이사회 의결권이 없는 점, ▲원고 회사의 주간보고에 참석하여 사업에 관한 보고를 하고 지시를 받았던 것으로 보이는 점, ▲취업규칙 및 인사관리 규정을 적용하여 해고의 인사명령을 한 점, ▲퇴직금을 14일 이내에 지급하려 한 점, ▲직장가입자로 4대 사회보험에 가입되어 있었던 점 등’을 중요하게 보았다.

반면 법원은 비록 참가인 근로자가 해고(계약만료)라고 기재된 인사명령 통보를 받았고 업무수행과정에서 주간보고서를 작성한 건 사실이나, ‘참가인의 지위, 원고 회사의 경영목적상 필요에 의하여 참가인이 이사로 선임된 경위, 선임과정에서 고려된 참가인의 능력과 담당 직위와의 상관관계, 참가인이 실제로 담당한 업무수행 실태, 포괄적인 권한 위임 여부, 참가인의 의사결정에 대한 원고의 참여·관여 정도, 참가인의 업무 수행 종료 경위 등’에 주목하여, 임금을 목적으로 사용자의 지휘·감독 아래 종속적인 관계에서 노무를 제공한 근로자로 인정하기에 부족하고 오히려 원고와의 신입관계 아래서 일정한 자율성을 가지고 업무를 수행한 자로서 위임받은 사무를 처리하는 지위에 있었다고 판단하였다. (▲원고는 반도체 사업 분야를 제대로 알지 못하였고, 참가인이 제시한 사업성 분석 보고서, 참가인의 종전 경력 등을 바탕으로 참가인을 신규사업 총괄관리 임원으로 선임함, ▲[사업약정서]는 참가인이 반도체 사업부문에 관하여 포괄적인 권한을 갖되, 흑자를 달성하지 못할 경우 계약이 해지될 수 있는 구조로서 권한 행사에 대한 책임을 부담하는 형태임, ▲또한 2년 이내에 흑자가 발생하지 아니할 경우 상호 협의하여 본 계약을 해지할 수 있다고 기재하여 근로계약 관계로 평가할 수 없는 내용을 포함함, ▲회사의 대표이사가 아니고 소속 임원이라도 일정한 노무를 담당한 것이 아니라 위임받은 사무를 포괄적으로 처리하였다면

부록.1. 주요 사건 경과 및 패소 원인 분석

근로자에 해당한다고 볼 수 없음. ▲참가인은 반도체사업부의 사업계획 수립, 사업실적 분석 및 보고, 반도체사업부 내의 팀 업무분장, 팀원 채용 계획 수립 및 채용조건 등의 결정, 팀원에 대한 업무 지휘·감독, 반도체 사업 관련 예산 집행 등에 관하여 전결권을 행사함. ▲위임인이 위임 사무의 방향을 제시하고 수임인이 처리결과를 보고하며 진행되는 업무 현황을 공유하는 체계는 업무책임자로서 해당 업무를 독립적으로 집행하는 관계에서도 통상적으로 필요한 것으로, 주간보고는 이러한 차원의 것인 점. ▲이 사건 내용증명이나 해고통보에 ‘해고수당’이나 ‘퇴직금’을 지급하겠다고 하는 등 고용관계를 전제로 하는 표현이나 내용이 기재된 사정이 있으나, [사업약정서] 제15조에 의하여 계약을 종료한다는 의사도 표시됨. ▲참가인은 원고의 직원과 구분되어 임원의 기준에 따른 보수, 처우를 받았고, 오히려 임원 인사관리규정에 따른 이사의 기준을 훨씬 상회하는 업무추진비, 업무용 차량 지원 등 차별화된 복리후생의 혜택을 받았으며, 참가인의 기본급은 등기이사과 유사한 수준임. ▲원고는 대표이사를 제외한 등기이사에게도 근로소득세를 원천징수하고 고용보험을 유지함)

결론적으로 법원은 참가인 선임의 기초가 된 신임관계가 현저히 상실되어 임원 업무를 수행할 수 없게 되었는지 여부나 사업약정서에서 정한 계약해지 사유가 충족되어 참가인에 대한 위임관계 해지가 적법한지 여부는 별론으로, 참가인이 근로기준법상 근로자에 해당한다는 전제에서 이 사건 통보의 내용을 근로자에 대한 일반적인 해고와 동일하게 취급하여 그 효력을 판단할 수는 없다며 재심판정을 취소하였다.

이처럼 법원이 참가인의 선임 경위, 업무수행 권한에 관한 약정 내용, 업무수행 실태, 지휘·감독 현황, 처우 수준 등에서 일반적인 사용종속관계를 넘어서는 특수성을 포착하여 근로자성을 부정하였다면, 상대적으로 중노위는 근로계약관계의 형식적인 지표들, 예를 들어 비등기임원인 점, 인사규정에 따라 해고통지가 이루어진 점, 퇴직금 지급, 정기적으로 업무보고가 이루어진 점 등을 강조하여 근로자성을 인정한 것으로 보인다.

대법원 판례가 “특히 대규모 회사의 전문적인 분야에 속한 업무의 경영을 위하여 특별히 임용되어 해당 업무를 총괄하여 책임을 지고 독립적으로 운영하면서 등기이사과 마찬가지로 회사 경영을 위한 의사결정에 참여하여 왔고 일반 직원과 차별화된 처우를 받은 경우”에는 그 특수성을 고려하여 근로자성을 판단한다는 법리를 제시하고 있음에도, 중노위가 이 사건에서 판례 법리를 적용, 해석함에 있어 검토가 다소 미진한 측면이 있는 것으로 보인다.

일련번호	2020-33					
판결번호	서울행정법원 2020. 7. 23. 선고 2019구합00000 판결					
중노위판정번호	중노위 2019. 11. 18. 중앙2019부해969					
사건 종류	부당정직					
세부 쟁점	징계, 정직,					
심급별 소송결과	1심 법원	재심판정취소	2심 법원		대법원	
원 고	○○○○○(주)		참 가 인		미참가	
피 고	중앙노동위원회위원장		피고측 대리인 선임 여부		선임 안 함	
노동조합 지원 여부			원고측 대리인 선임 여부		선임 함	
재심 결과	초심유지					

초심의 대법원 판례 일치여부	불일치	재심의 대법원 판례 일치여부	불일치
기타 특이사항			

주요 사실관계

<사건 개요>

가. 원고는 2019. 2. 28. 근로자 B에게 '징계위원회가 2019. 2. 26. B에 대하여 정직 1월의 징계처분을 의결하였다'고 통지하였고, B가 재심청구를 하지 아니함에 따라 위 징계처분은 2019. 4. 1. 시행되었다

1) (1 징계사유) 근로자 B는 2019. 1. 2. 09:50 ○○서비스센터에서 센터운영팀장 D가 '위 일 시에는 출근의무가 없으니 귀가하라'고 지시하자, 몸으로 D의 몸을 밀치고 가슴 부분 옷깃을 양 손으로 잡아당겼으며 가슴에 있는 명찰을 손으로 잡아 뜯음으로써 상사를 폭행하였다.

2) (2 징계사유) B는 2019. 1. 25. 11:20경 ○○서비스센터 센터운영팀 다용도실에서 D가 징계위원회 개최를 통보하자 '회사 그만두겠습니다'라고 말한 뒤 13:00경 소속장의 허가 없이 근무지인 ○○서비스센터에서 나가 무단이탈하였다.

3) (3 징계사유) B는 2019. 1. 7. 11:25경 ○○서비스센터 센터운영팀 사무실에서 '차갑고 뜨겁게 길러야 한다'고 말하면서 원고 소유인 시가 불상의 고무나무 상단을 커터칼로 자르고, 2019. 1. 25. 10:55경 위 센터에서 원고 소유인 시가 불상의 나무 상단 꽃 부분을 커터칼로 잘라 기물을 파손하였다.

4) (4 징계사유) ① B는 2019. 1. 28. ○○서비스센터 센터운영팀 사무실에서 센터운영팀장 D가 '위 사무실에 있는 책장들을 임의로 옮기지 말라'고 지시하였음에도 위 책장들을 임의로 고객지원팀 사무실로 옮겨 아무런 이유 없이 상사의 정당한 지시를 불이행하였다. ② B는 2019. 2. 1. 17:35경 ○○서비스센터에서 센터운영팀장 D가 B에게 '업무가 없으니 퇴근하라'고 지시하였음에도 불구하고, '알았다. 집에 가 봤자 쥐새끼 3마리가 싸우고만 있다'고 말하며 퇴근을 거부하여 아무런 이유 없이 상사의 정당한 지시를 불이행하였다.

나. B는 2019. 4. 22. 경기지방노동위원회에 이 사건 정직이 부당하다면서 구제신청을 하였다.

<심급별 결과>

[경기지노위] 구제신청 기각

[중노위] 일부 징계사유는 정당한 징계사유에 해당하지 아니하고, 나머지 징계사유에 비하면 정직은 그 징계양정이 과도하여 부당하다'는 취지의 이유를 들어 초심판정을 취소. 구제신청 인용.

[1심 법원] 징계양정의 적절성을 인정하여 재심판정 취소

판결 요지

가. 징계사유의 인정 여부

1) 제1 징계사유(상사폭행)

앞서 인정한 사실에 비추어 보건대, 제1 징계사유에서 특정된 사실관계는 모두 사실로 인정되고, 이는 취업규칙 제64조(징계해고) 제3호(상사의 정당한 업무지시에 정당한 사유 없이 불복하여 직

장의 규율을 문란케 한 자), 제5호(폭행, 협박, 문서위조 및 변조 등의 행위로써 직장규율을 문란케 한 자)에서 정한 징계사유에 해당하는 행위를 한 것이라고 할 수 있으므로, 제1 징계사유는 정당한 징계사유에 해당한다.

2) 제2 징계사유(무단이탈)

당사자들은 '제2 징계사유가 정당한 징계사유에 해당한다'는 것에 이견이 없다. 이는 취업규칙 제17조(복무규율) 제8호(소속장의 허가 없이 자기 근무지를 함부로 이탈하지 말 것)를 위반한 행위에 해당한다. 따라서 제2 징계사유는 정당한 징계사유에 해당한다.

3) 제3 징계사유(기물파손)

당사자들은 '제3 징계사유가 정당한 징계사유에 해당한다'는 것에 이견이 없다. 이는 취업규칙 제17조(복무규율) 제9호[회사의 재산과 시설물을 보호하고 자재, 소모품, 기타 물품을 절약하며, 사용(좌IV)을 위해서 회사의 물품을 사용치 말 것]을 위반한 행위에 해당한다. 따라서 제3 징계사유는 정당한 징계사유에 해당한다.

4) 제4 징계사유(지시불이행) 중 다툼이 없는 부분

위 징계사유의 사실관계는 각 영상 및 변론 전체의 취지에 의하여 인정될 뿐만 아니라, 당사자 사이에 다툼이 없는 사실이기도 한바, 이는 취업규칙 제64조(징계해고) 제3호(상사의 정당한 업무지시에 정당한 사유 없이 불복하여 직장의 규율을 문란케 한 자)를 위반한 행위에 해당한다. 따라서 위 징계사유는 정당한 징계사유에 해당한다.

원고는 또한 B가 ① 2019. 2. 1. 10:05경 ○○서비스센터에서 센터운영팀장 D가 '즉시 근태를 입력할 것'을 지시하자 아무런 이유 없이 이를 거부하고 14:00경 위 지시를 이행하여 상사의 정당한 지시를 불이행하였고, ② 2019. 2. 8. 09:10경 ○○서비스센터에서 센터운영팀장 D가 '즉시 근태를 입력할 것'을 지시하자 비밀번호가 기억나지 않는다는 이유로 이를 거부하고 12:00경 위 지시를 이행하여 상사의 정당한 지시를 불이행하였다고 주장한다.

앞서 인정한 사실에 의하면, 위 징계사유의 내용과 같이 'B가 근태 입력을 지연한 것' 자체는 사실로 인정된다. 그러나 B가 전산팀에 서비스 문의를 한 내용을 보면, B의 위와 같은 행동이 고의에 기한 행동이었다고 단정하기 어려운바, 상사의 정당한 업무지시에 '정당한 사유 없이' 불복하였다고 볼 수 없어, B가 취업규칙 제64조(징계해고) 제3호(상사의 정당한 업무지시에 정당한 사유 없이 불복하여 직장의 규율을 문란케 한 자)를 위반하였다고 할 수 없다. '4 징계사유 중 근태입력지시를 불이행하였다는 부분'은 정당한 징계사유에 해당하지 아니하나, 이를 제외한 나머지 징계사유는 모두 정당한 징계사유에 해당한다.

나. 징계양정의 적정 여부

앞서 인정한 사실을 종합하여 알 수 있는 다음과 같은 사정에 비추어 보면, 이 사건 정직은 징계 내용이 객관적으로 명백히 부당하다고 인정되지 아니하므로, 재량권의 범위를 벗어난 위법한 처분이라고 할 수 없다.

① 정당한 징계사유로 인정된 징계사유 중 가장 비위의 정도가 무거운 징계사유는 제1 징계사유(상사폭행)이다. 제1 징계사유에 해당하는 B의 행동은 'D에게 신체적·정신적 피해를 가한 것'임과 동시에, '상사의 지시를 거부하고 상사를 폭행함으로써 직장 질서를 심히 문란케 한 것'이기도 하다. 원고로서는 B의 행동을 엄히 처벌함으로써 재발을 방지하고, 직장질서를 바로 세울 필요성이 있다고 할 것이다. 더구나 B가 D를 폭행한 경위에 있어서 특별히 양정에 참작할 만한 사정도 보이지 아니한다. B가 적응장애, 우울증을 치료받은 전력이 있다는 점을 고려하더라도, 정직 1월의 징계가 객관적으로 명백히 부당하다고 보이지는 아니한다.

② 제1 징계사유 외에 정당한 징계사유로 인정되는 다른 징계사유를 보면, 그 비위의 정도는 비

교적 낮은 편이라고 할 것이지만, 제1 징계사유의 비위 내용과 더하여 살펴본다면, 정직 1월의 징계가 객관적으로 명백히 부당하다고 보이지는 아니한다.

③ B에 대한 동료 직원들의 평가를 보면, '평소 B가 업무를 성실히 수행하여 왔다'고 보이지도 아니하는바, B의 평소 모습에서 양정에 참작할 만한 유리한 사정을 찾기도 어렵다.

이 사건 징계사유 중 일부는 정당한 징계사유에 해당하지 아니한다. 그러나 '나머지 징계사유만으로 정직 1월의 징계처분을 하는 것'이 재량권을 일탈·남용한 것이라고 보이지는 아니하므로, 이 사건 정직은 부당징계에 해당하지 아니한다.

패소 이유 (사실관계에 관한 인정 차이)

이 사건은 사실관계는 동일하지만, 그에 대한 법리적 판단의 결과가 달라진 사건이다. 지노위는 초심 판단에서 징계의 정당성을 인정하고 구제신청을 기각했지만, 중노위는 징계 사유가 일부 인정되지만, 양정이 부당하여 정직의 징계는 부당하다고 하여 구제신청을 인용했다.

그러나, 법원은 징계사유의 정당성을 인정했다. 특히, 징계 사유 중 일부만 인정된 경우에도 그것만으로 정직의 징계하고 결정을 하기에는 부족함이 없다는 판단을 내렸다. 피신청인이 제시하는 다양한 입증자료가 있음에도 불구하고, 정직 1개월의 징계에 대한 징계 양정 과다를 인정한 것은 합리적인 판단이라고 할 수 없다는 점에서, 중노위 판정은 공익위원의 전문성이 문제가 있다는 것을 나타낸다고 볼 수밖에 없다. 그나마 다행인 것은, 중노위가 항소를 하지 않고 1심 법원의 판결을 수용했다는 점이라고 할 수 있다.

일련번호	2020-35					
판결번호	서울고등법원 2020. 8. 26. 선고 2020누00000					
중노위판정번호	중노위 2019. 7. 23. 2019부해630					
사건 종류	부당해고					
세부 쟁점	징계절차의 정당성, 소명기회, 인사위원회 구성, 절차상 하자 치유					
심급별 소송결과	1심 법원	재심 취소	2심 법원	항소 기각	대법원	-
항 소 인	○○○○건설 주식회사		참 가 인		○○○○건설 주식회사	
피항소인	인○○		피고측 대리인 선임 여부		선임 안 함	
노동조합 지원 여부	없음		원고측 대리인 선임 여부		선임 안 함	
재심 결과	초심유지					
초심의 대법원 판례 일치여부	불일치		재심의 대법원 판례 일치여부		불일치	
기타 특이사항						

주요 사실관계

<사실관계>

참가인 회사(건축공사업)는 도급받은 호텔 신축공사 수행을 위해 공사현장 총괄책임자로 호텔 공사 경력자인 원고를 채용하였는데(2018. 10. 1.부터 근무), 원고는 같은 해 12월부터 2019. 1. 13.에 걸쳐 다른 근로자와의 업무마찰 등을 이유로 여러 차례 결근, 조퇴, 휴가를 하였다. 이로 인해 원고는 참가인 회사로부터 시말서 제출요구를 받아 3차례 시말서를 제출한 바 있으나, 2019. 1. 14. 회사가 제안한 감급 및 감봉 처분은 거절하였다. 회사는 2019. 1. 15. 원고에 대하여 업무 중지 및 대기 발령을 명하고, 다음날인 2019. 1. 16. 14:00경 원고에게 당일 16:00 개최될 인사위원회 출석통지서를 전달하였다. (출석통지서 제목은 '현장총괄책임자로서 자격이 부족한 원고의 직급 및 감봉(감급)'이었으며, '출석요청에 불응 시 징계위원의 결정사항에 이의 없는 것으로 인정됨을 알려드린다'는 내용이 포함되어 있었다.)

같은 날 원고가 참석한 가운데 인사위원회(대표이사, 설계부 팀장(대표이사의 딸), 관리부 인사과장으로 구성)가 열려 원고에 대한 징계해고를 의결하고(16:30경부터 19:30까지 개최), 다음날 '이력 사칭, 업무능력과 통솔력 부족 및 불성실한 근무태도, 작업지시 잘못으로 인한 손해 야기' 등을 이유로 징계해고를 통보하였다. 이에 원고가 부당해고 구제신청을 하였다.

한편 회사의 규정에는 징계위원회 전까지 근로자에게 서면 출석통지를 하고 소명 기회를 부여한다', '징계위원회는 대표이사과 부서장 또는 그에 준하는 직급의 사원 중 대표이사가 임명하는 자로 총 3명 이내로 구성하되 근로자위원을 최소 1명 이상 포함한다'는 내용이 존재하였다.

<심급별 결과>

[전남지노위] 징계사유 존재, 양정 적정, 절차상 하자도 없다며 해고가 정당하다고 판정

[중노위] 초심 유지

[1심 법원] 징계절차에 하자가 있다며 재심판정 취소

[2심 법원] 항소 기각 ※ 상고하지 않음.

판결 요지

단체협약, 취업규칙 또는 징계규정에서 징계대상자에게 징계위원회에 출석하여 변명과 소명자료를 제출할 수 있는 기회를 부여한 경우 그 통보의 시기와 방법에 관하여 특별히 규정한 바가 없다고 하여도 변명과 소명자료를 준비할 만한 상당한 기간을 두고 개최일시와 장소를 통보하여야 하며, 이러한 변명과 소명자료를 준비할 만한 시간적 여유를 주지 않고 촉박하게 이루어진 통보는 실질적으로 변명과 소명자료제출의 기회를 박탈하는 것과 다를 바 없어 부적법하다고 보아야 할 것이고, 설사 징계대상자가 그 징계위원회에 출석하여 진술을 하였다 하여도 스스로 징계에 순응하는 것이 아닌 한 그 징계위원회의 의결에 터 잡은 징계해고는 징계절차에 위배한 부적법한 징계권의 행사라 할 것이다(대법원 2004. 6. 25. 선고 2003두15317 판결 등 참조).

단체협약이나 취업규칙에 정해진 해고에 관한 절차위반이 그 해고를 무효로 하느냐 여부는 일률적으로 말할 수는 없고 그 규정의 취지에 따라 결정되어야 할 것으로서, 단체협약 등에서 징계위원회의 구성에 근로자 측의 대표자를 참여시키도록 되어 있음에도 불구하고 이러한 징계절차에 위배하여 징계해고를 하였다면 이러한 징계권의 행사는 징계사유가 인정되는지 여부에 관계없이 절차에 관한 정의에 반하는 처사로서 무효라고 보아야 할 것이지만, 근로자 측에 징계위원 선정권 등을 행사할 기회를 부여하였는데도 근로자 측이 스스로 징계위원 선정을 포기 또는 거부한 것이라면 근로자 측 징계위원이 참석하지 않은 징계위원회의 의결을 거친 징계처분이라고 하더라도 이를 무효로 볼 수는 없다(대법원 2011. 7. 28. 선고 2008두11693 판결 등 참조).

취업규칙 등에서 노.사 동수로 징계위원회를 구성하도록 하고 있다면 이는 근로자들 중에서 징계위원을 위촉하여 징계위원회에 대한 근로자들의 참여권을 보장함으로써 절차적 공정성을 확보

함과 아울러 사측의 징계권 남용을 견제하기 위한 것이라고 할 것이므로, 피고의 취업규칙에 직접적으로 징계위원의 자격과 선임절차에 관해서 규정하고 있지는 않지만, 노측 징계위원들이 이 전부터 근로자들을 대표하거나 근로자들의 의견을 대변해왔다는 등의 특별한 사정이 없는 한 근로자들의 의견을 반영하는 과정 없이 임의로 노측 징계위원을 위촉할 수 있는 것으로까지 해석할 수는 없다고 할 것이다(대법원 2006. 11. 23. 선고 2006다48069 판결 등 참조).

패소 이유 (사실관계에 관한 인정 차이)

이 사건의 경우 징계절차 하자가 쟁점이 되었는데, 중노위는 하자가 징계를 무효로 할만큼 중대하지 않아 해고가 정당하다고 본 반면, 법원은 중대한 하자가 있다며 재심판정을 취소하였다.

중노위는 원고 근로자는 인사위원회에 출석하여 장시간에 걸쳐 소명하였고, 비록 일부 절차상 흠이 있다고 하더라도 이는 치유되었거나 징계절차를 무효로 할 정도로 중대하다고 할 수 없으므로 이 사건 징계절차가 적법하다고 판단하였다. 구체적으로 “사용자가 인사위원회 개최 예정 시각 2시간 전에 인사위원회 개최 사실을 통지하고 그 통지서의 제목이 ‘직급 및 감봉(감급)’으로 되어 있기는 하나, 이 사건 근로자가 인사위원회에 출석하여 장시간에 걸쳐 소명을 하였고, 인사위원회 진행 중에 징계의 종류가 달라질 수 있음을 고지 받은 이상 위와 같은 흠은 치유되었다고 볼 것”이고, “회사의 상별규정에 ‘상별위원회에 근로자위원이 최소한 1명 포함되어야 한다’고 규정되어 있는 것은 사실이나, 인사위원회가 이 사건 현장에서 개최된 점, 이 사건 현장에서 근무하는 근로자들은 대부분 이 사건 근로자의 지휘·감독을 받던 사람들인 점, 인사위원회는 장시간에 걸쳐 진행되었고 그 과정에서 이 사건 근로자가 상당한 소명을 한 점 등에 비추어 보면, 위 같은 흠은 이 사건 징계절차를 무효로 할 정도로 중대하다고 보기 어렵다”고 설시하였다.

하지만 1·2심 법원은 근로자에게 충분한 소명기회가 부여되지 않았고 인사위원회 구성에도 하자가 있다는 등의 이유로, 이 사건 징계해고는 절차상 하자로 부당하다고 판단하였다.

먼저 <충분한 소명기회가 부여되지 않았다>고 보았는데, “인사위원회는 원고에게 인사위원회 개최 일시와 장소를 통보하면서 변명과 소명자료를 준비할 만한 시간적 여유를 주지 아니하고 촉박하게 인사위원회 개최를 통보하였고, 원고가 인사위원회에 출석하여 진술을 하였으나 충분한 변명과 소명자료를 제출할 기회가 부여되었다고 볼 수 없으며, 원고가 징계사유를 다투어 원고 스스로 징계에 순응하였다고 볼 수 없으므로, 인사위원회 의결에 따른 이 사건 해고는 회사의 규정에서 정한 사전통보, 소명기회 부여의 취지에 반하여 절차적으로 위법하다”고 판단하였다.

구체적으로 “인사위원회는 2019. 1. 6. 14:00 원고에게 출석통지서를 전달하면서 불과 2시간 30분 가량의 시간적 여유만을 부여한 채 인사위원회에 참석하도록 하였고, 이러한 통보는 원고가 변명과 소명자료를 준비하기에 시간적으로 지나치게 촉박”한 점, “위 출석통지서에는 ‘현장총괄 책임자로서 자격이 부적합’하다는 다소 포괄적인 기재만 있을 뿐이어서 그 기재 내용만으로는 원고가 구체적인 징계 혐의사실을 구체적이고 명확하게 파악하기 곤란하고, 출석통지서의 제목에 ‘감봉(감급)’이라는 징계의 종류를 언급하고 있어 원고가 징계위원회에서 징계해고가 의결될 것이라고 예상하기도 어려운” 등을 이유로 제시하였다.

<인사위원회 구성에도 하자가 있다>고 보았는데, 회사규정에 의하여 “인사위원회에 근로자위원을 최소 1명 이상 포함하여야 함에도 근로자위원을 포함시키지 아니하고 징계해고를 의결하였으므로, 해고 조치는 절차적 정의에 반하여 위법하다”고 판단하였다. ‘인사위원회는 대표이사, 설계부 팀장(대표이사의 딸), 관리부 인사과장으로 구성되었고, 이들이 이전부터 근로자들을 대표하거나 근로자들의 의견을 대변해왔다고 인정할 만한 사정이 없는 점, 회사규정에 직접적으로 근로자위원의 선임절차에 관하여 규정하고 있지는 않지만, 대표이사로서는 근로자들의 의견을 반영하는 절차를 거쳐 근로자인 원고의 이익을 대변하고 회사의 징계권 남용을 견제하는 역할을 수행할 수 있을만한 부서장 또는 그에 준하는 직급의 사원을 근로자위원으로 임명하여야 할 것이나, 이러한 절차를 거쳤다고 인정할 증거가 없는 점’ 등을 지적하였다.

<징계절차상 하자도 치유되지 않았다>고 보았다. “원고에게 상당한 시간적 여유가 주어졌더라면 인사위원회에서 변명 및 소명 자료의 제출 정도가 달라졌을 가능성이 충분히 존재하고, 원고가 인사위원회에서 징계사유를 다투어 징계에 순응하였다고 볼 수 없으므로, 원고가 인사위원회

부록.1. 주요 사건 경과 및 패소 원인 분석

에서 구두로 진술할 기회를 부여 받았다거나 통지절차에 대한 이의를 제기하지 않았다는 사실만으로는 회사규정에서 정한 사전통보, 소명기회 부여의 취지를 몰각한 하자가 치유되었다고 보기 어렵”고, “회사규정에서 정한 근로자위원이 적법하게 임명되어 인사위원회에 참여하였다고 볼 수 없는 이상 … 절차적 공정성을 훼손한 중대하고 명백한 하자가 존재한다. 이와 같은 인사위원회 구성의 하자는 원고가 하자가 있는 인사위원회에 출석하여 명시적으로 이의를 제기하지 아니한 채 구두 진술을 하였다는 사정만으로는 사후적으로 치유될 수 없는 성질의 것이라고 봄이 상당”하다고 판단하였다.

중노위는 원고 근로자가 3달 남짓한 근무기간 동안 조퇴, 결근, 휴가로 사실상 출근하지 않은 일수가 상당하고, 그러한 행동에 대해 회사측이 여러 차례 경고하고 원고가 시말서를 제출한 적이 있는 사실 등에 주목하여, 비록 원고에 대한 징계를 의결하는 인사위원회 개최 통보를 인사위원회 당일에 통보한 것은 문제가 있으나 그동안 충분히 회사의 경고 및 원고의 소명이 있었다고 보아, 중대한 절차상 하자는 없다(내지 하자가 치유되었다)고 판단한 것으로 보인다. 이를 전제로 징계사유가 존재하고 양정 역시 적정하다고 보아 정당한 해고로 결론 내렸다.

이와 달리 법원은 중대한 절차상 하자가 존재하므로, 징계사유의 존부 및 징계양정의 적정성에 대하여 더 나아가 살필 필요 없이 해고가 부당하다고 판단 내렸다. 법원은 인사위원회 개최 전까지 상당기간 회사의 경고 및 원고의 시말서 제출 행위를 두고 원고에게 소명기회를 준 것으로 인정하지 않았고, 인사위원회 개최 당일에 출석통지를 한 사실, 인사위원회에 실제로 근로자측 대표라 할 수 있는 인사위원이 없었던 사실 등에 주목하여, 회사의 징계규정 및 징계법리를 위반한 중대한 절차상 하자가 있다고 보았다.

중노위가 근로자의 비위행위의 중대성에 집중하여 징계 절차의 정당성 검토에 다소 소홀했던 사건으로 보인다. 징계사유 존재, 양정의 적정성과 별개로 절차의 정당성은 근로자의 방어권 보장 차원에서 매우 중요한 요소이므로, 적어도 기존 판례법리에 입각하여 독립적 쟁점으로서 충분한 검토가 이루어질 필요가 있다.

일련번호	2020-40					
판결번호	서울고등법원 2020. 9. 11. 선고 2019누00000					
중노위판정번호	중노위 2018. 8. 29. 2018부해684					
사건 종류	부당해고					
세부 쟁점	수습계약, 시용계약, 해고, 본채용 거부					
심급별 소송결과	1심 법원	재심 취소	2심 법원	항소기각	-	
항 소 인	마○○		참 가 인		마○○	
피항소인	정○○(○○요양원 대표)		피고측 대리인 선임 여부		선임 안 함	
노동조합 지원 여부	없음		원고측 대리인 선임 여부		선임 함	
재심 결과	초심취소					
초심의 대법원 판례 일치여부	일치		재심의 대법원 판례 일치여부		불일치	

기타 특이사항	
---------	--

주요 사실관계 <사실관계> 참가인 근로자는 2017. 11. 14. 이 사건 요양원에 사회복지사로 입사하였는데, 요양원측은 ‘운영조직에 대한 미적응, 맡은 업무에 대한 책임 부재, 저조한 수습사원 업무평가 결과 등’의 이유로 2017. 12. 13. 근로계약관계를 종료하는 조치를 하였다. 요양원의 취업규칙에는 ‘신규 채용 시 3개월간 시용 및 수습기간이고, 업무수행능력, 품성 등이 정식 채용에 부적합한 경우 수습기간 중에도 근로계약을 해지할 수 있다’고 정하고 있고, 근로계약서에도 ‘3개월 간 수습기간을 부여한다’는 내용이 있었다. 한편 요양원이 2017. 11. 30. 실시한 ‘수습직원 업무평가’에서 참가인 근로자는 100점 만점에 평균 59.6점을 받아 정식채용 커트라인 60점에 미달하였는데 3명의 평가자 중 2명으로부터 60점 미만 평가를 받았다. (종사자의 자세, 동료와의 화합, 업무 관련 전문성, 수급자 관리 등 4개 영역을 다시 15개의 세부항목으로 나누어, 합계 100점을 각 세부항목당 5~10점씩 배점 하여 각 득점을 합산) 요양원은 2017. 12. 12. 16:30경 대표 및 직원 5명이 참석하여 1차 인사위원회를 열고 참가인에게 수습기간 만료 및 2차 인사위원회 출석통지를 하고, 같은 날 17:30분경 2차 인사위원회를 열어 참가인이 불참한 가운데 퇴사를 의결하였다. 이에 참가인이 부당해고 구제신청을 하였다. <심급별 결과> [서울지노위] 시용근로자의 업무평가 결과가 본채용 기준에 미달하고, 업무수행능력이 부족하다는 등의 사유로 본채용을 거부한 것은 정당하다고 판정 [중노위] 정규직근로자를 계약기간 만료로 해고한 것은 부당하다며 초심 취소 [1심 법원] 시용근로자에 대한 해고는 정당하다며 재심판정 취소 [2심 법원] 항소 기각 ※ 상고하지 않음.
--

판결 요지 시용기간 중에 있는 근로자를 해고하거나 시용기간 만료 시 본계약의 체결을 거부하는 것은 사용자에게 유보된 해약권의 행사로, 당해 근로자의 업무능력, 자질, 인품, 성실성 등 업무적격성을 관찰·판단하고 평가하려는 시용제도의 취지·목적에 비추어 볼 때 객관적으로 합리적인 이유가 존재하여 사회통념상 상당하다고 인정되는 한 통상의 해고보다는 광범위하게 인정된다(대법원 1999. 2. 23. 선고 98두5965 판결 참조). 수 개의 해고사유 중 일부가 인정되지 않으나 인정되는 다른 일부 해고사유만으로도 당해 해고의 타당성을 인정하기에 충분한 경우에는 그 해고를 그대로 유지하여도 위법하지 아니하다(대법원 2004. 6. 25. 선고 2002다51555 판결 참조). 근로기준법 제27조의 내용과 취지, 시용기간 만료 시 본채용 거부의 정당성 요건 등을 종합하면, 시용근로관계에서 사용자가 본채용을 거부하거나 시용기간 중에 있는 근로자를 해고하는 경우에는 해당 근로자로 하여금 그 사유를 파악하여 대처할 수 있도록 구체적·실질적인 사유를 서면으로 통지하여야 한다(대법원 2015. 11. 27. 선고 2015두48136 판결 참조).
--

패소 이유 (사실관계에 관한 인정 차이)

중노위는 ‘▲채용 공고에 경력조건으로 최소 1년 이상, 업무내용은 사회복지사, 고용형태는 기간의 정함이 없는 근로계약이라고 명시된 점, ▲근로계약서에 “필요에 의하여 신규 채용된 근로자에게 수습기간을 부여할 수 있다”고 하여 수습기간 부여를 임의규정으로 하고 있는 점 등’에 주목하여 참가인 근로자는 시용근로자가 아닌 본채용된 근로자로 보았다. 그러면서 본채용 근로자를 해고를 하려면 고용관계를 계속할 수 없을 정도의 정당한 사유가 필요하나, 신규 입사자를 대상으로 실시하는 업무평가 결과 근로자가 기준 점수에 미달했다는 이유로 본채용을 거부하는 것은 부당하며, 기타 귀책 및 비위행위들만으로 해고사유를 인정하기 어렵다며 부당해고로 판정하였다.

그러나 법원은 이 사건 조치는 시용근로자에 대한 해고에 해당하고, 해고에 합리적인 이유가 인정되고 절차상 하자도 없으므로, 이 사건 조치는 적법하므로 재심판정은 위법하여 취소되어야 한다고 보았다.

우선 <수습기간 중의 근로자에 해당하는지 여부>에 관해, ▲요양원의 취업규칙이 ‘신규 채용된 자는 최초로 근무를 개시한 날부터 3개월간을 시용 및 수습기간으로 한다’고 정하여, 그 문언상 수습기간을 선택적으로 적용하고 있거나 적용 예외 사유를 두고 있지 않다 ▲근로계약서는 ‘사용자는 필요에 의하여 신규 채용된 근로자에게 수습기간을 부여할 수 있고, 수습기간은 입사일로부터 3개월까지이며, 이 기간의 급여는 월급의 90%로 한다’라고 정하고 있는데 이 중 ‘3개월’ 부분과 90% 부분에는 펜으로 밑줄과 동그라미를 표시한 필적이 나타나 있어 근로계약서 작성 당시 수습기간과 해당 기간에 지급되는 급여 수준에 관한 설명을 들은 것으로 볼 수 있다 ▲2017. 11. 30. 참가인에 대해 작성한 ‘수습(시용)직원 업무평가표’에는 ‘수습(시용) 기간’이 2017. 11. 14.부터 2018. 2. 13.까지라고 기재되어 있고, 2017. 11.에 입사한 다른 근로자들에 대한 업무평가표에도 ‘수습(시용) 기간’이 모두 입사일로부터 3개월로 기재되어 있다는 사실 등을 들어, 참가인은 3개월의 수습기간을 적용받는 근로자에 해당한다고 봄이 타당하다고 판단하였다.

<이 사건 조치에 합리적인 이유가 있는지 여부>에 관해서는, 근로계약서에 따르면 수습기간은 입사일로부터 3개월이므로 그 만료일은 2018. 2. 13.이고, 달리 수습기간 단축 합의를 하였다는 사정을 찾아볼 수 없고, 수습기간 만료일까지 2개월이 남은 시점에 이루어진 이 사건 조치는 수습기간 중에 있는 근로자에 대한 해고에 해당한다고 전제된 후, 참가인에 대하여 인정되는 해고사유의 내용과 정도, 이 사건 요양원의 규모와 인력구성, 참가인의 채용 경위와 경력 등을 종합하여 보면 수습기간 중이던 참가인을 해고한 이 사건 조치는 객관적으로 합리적인 이유가 존재하여 사회통념상 상당하다고 보았다. (법원은 구체적으로 “▲취업규칙은 시용 및 수습기간 동안의 업무수행능력, 품성 등이 정식 채용에 부적합한 경우에는 시용 및 수습기간 중에도 근로계약을 해지할 수 있다고 정하고 있다원고는 참가인이 입사한 후 약 2주가 경과한 2017. 11. 30. 수습(시용)직원 업무 평가를 실시하였다. 위 평가는 종사자의 자세, 동료와의 화합, 업무 관련 전문성, 수급자 관리 등 4개 영역을 다시 15개의 세부항목으로 나누어 각 항목의 내용이 비교적 구체적이고, 합계 100점을 각 세부항목당 5~10점씩 배점하여 각 세부항목의 득점을 합산한 평가점수를 부여하도록 구성되어 있다. 참가인은 평균 59.6점으로 합격에 해당하는 60점에 미달하는 평가점수를 받았는데, 3명의 평가자 중 2명으로부터는 60점에 미달하는 점수를 받았으나 1명으로부터는 60점을 초과하는 점수를 받았다. 따라서 평가자들이 참가인에 대하여 의도적으로 부정적인 평가를 하였다고 보기 어렵고, 같은 달에 입사한 다른 근로자들 3명이 평균 67.6점~76점을 받은 점, 67.6점을 받은 다른 직원은 업무능력을 이유로 2017. 12. 1. 자진퇴사한 점 등에 비추어 보더라도 참가인에 대한 평가가 자의적이라거나 형평을 잃은 것이라고 보기도 어렵다. ▲위 업무 평가에서 각 평가자들은 참가인에 대하여 ‘타 시설장과 비교, 현 직원들 간의 허위 과장된 말로 집단행동을 주도하려 함. 장시간의 전화로 본인은 물론 사무실 직원들이 업무에 전념하지 못하게 함.’, ‘사회복지사로서 성품이 결여된 상태로 직원들을 비방하고 와해시켜 분위기를 이상하게 만들며 지시형으로 다가서려 함. 잦은 전화통화와 자리를 자주 비움. 동료 간의 협력 부족, 책임감, 창의성 부족함.’, ‘근무 중 전 직장 동료들과 잦은 전화사용으로 근무지 이탈이 잦으며, 종사자들, 각 부서별로 패를 만들려 함. 관련 업무의 전문성, 수행능력 이전에 근태와 자질이 문제인 듯.’이라는 평가의견을 기재하여 참가인의 근무태도를 지적하였다. 그 외에 영양사, 간호조무사 등 다른 직원들도 참가인의 사적인 통화내용, 다른 직원에 대하여 평가하거나 지적인 내용, 참가인이 근무지를 이탈한 일시, 참가인의 협조가 이루어지지 않은 업무 등을 구체적으로 언급하며 참가인의 근무태도가 불량하였다는 취지의 진술을 하였다”)고 실시하였다.)

<해고 절차에 하자가 있는지 여부>에 관해, ‘취업규칙에 “징계는 대표자가 결정한다”라는 규

정 외에 징계에 관하여 구체적인 절차를 규정하고 있지 않고, 특히 시용 및 수습기간 중의 근로계약 해지에 관하여 별도의 절차를 규정하고 있지 않은 점, 시용기간 중에 있는 근로자를 해고하는 것은 사용자에게 유보된 해약권의 행사로서 이를 징계해고라고 볼 수 없으므로, 이 사건 통보에 따른 해고에 징계해고 절차가 적용된다고 볼 수도 없는 점'을 들어 요양원측이 이 사건 통보 후 제2차 인사위원회를 개최하였다고 하더라도 이를 들어 절차상 하자가 있다고 볼 수 없다고 판단하였다.

결국 중노위와 법원의 결정적 차이는 중노위가 당초 참가인 근로자를 채용한 것을 본채용으로 인정하고 이를 전제로 해고의 정당성에 관한 판례 법리를 곧바로 적용한 반면, 법원은 시용(수습)채용임을 전제로 시용근로자 해고 관련 판례 법리를 적용한 데 있는 것으로 보인다. 즉 중노위가 법원과 달리 이 사건의 사실관계를 본채용으로 판단한 결과, 보다 엄격한 해고 정당성 판단 기준을 적용하며 이 사건 해고를 부당해고로 결론짓고 말았다. 근로자가 수습근로자이지 여부는 해고 여부, 그의 정당성 판단에 결정적인 영향을 미치는 핵심적 요소이므로, 그에 관한 사실관계 인정에 있어 보다 신중한 검토가 이루어져야 할 것이다.

일련번호	2020-47					
판결번호	서울고등법원 2020. 6. 3. 20219누00000 판결					
중노위판정번호	중노위 2017. 7. 11. 중앙2017부노52					
사건 종류	부당노동행위					
세부 쟁점	부당노동행위, 불이익취급, 지배·개입					
심급별 소송결과	1심 법원	재심판정인용	2심 법원	1심 취소	대법원	
상 고 인	○○운수 합자회사		참 가 인		미참가	
피상고인	중앙노동위원회위원장		피고측 대리인 선임 여부		선임 안 함	
노동조합 지원 여부	있음		원고측 대리인 선임 여부		선임 함	
재심 결과	초심취소					
초심의 대법원 판례 일치여부	일치		재심의 대법원 판례 일치여부		불일치	
기타 특이사항						

주요 사실관계

<사건 개요>

가. 원고는 운수업을 경영하는 법인이다. 대표사원은 C이고 실질적 경영자는 D이다.

나. 전국택시산업노동조합(이하 '이 사건 노동조합')은 H운송사업에 종사하는 근로자를 조직대상으로 하여 설립된 전국단위노동조합이다. 이 사건 노동조합은 2014. 9. 30.부터 원고 소속 근로

자인 I을 분회장으로 하는 J분회를 두고 있다.

다. 원고 내부에는 이 사건 노동조합 분회 외에 아산시 B를 소재지로 하고 원고 소속 근로자인 K을 위원장으로 하는 기업별 노동조합인 L노동조합이 있고, 그 조합원 수는 31명 정도이다.

라. 이 사건 노동조합은 '원고가 2016. 9. 12. 이 사건 노동조합 분회의 분회장인 I의 근로조건을 일방적으로 변경한 것은 불이익취급 및 지배·개입의 부당노동행위이고, 원고가 이 사건 노동조합이 근로조건 변경에 대한 논의를 요청하였다는 이유로 교섭창구 단일화 절차를 강행하고, 원고 소속 근로자들에게 L노동조합에 가입하도록 가입원서를 작성하게 하고 가입일자를 조작하도록 한 것은 지배·개입의 부당노동행위에 해당한다'고 주장하며 2016. 12. 5. 충남지방노동위원회에 부당노동행위 구제신청을 하였다.

1) 원고는 2009. 9. 10. 당시 근로자 대표 K과 사이에 1년 단위로 퇴직금을 중간정산하기로 합의하고, 2009년경부터 2015년경까지 원고 소속 전체 근로자들에 대하여 퇴직금을 매년 중간정산하여 왔다.

2) 원고는 2011년 이전부터 1인 1차제(택시가 배차되면 근로자는 택시를 운행한 후 매일 회사에 입고하지 않고 자신의 집에 택시를 가지고 갔다가 다음 날 택시를 운행하는 제도), 재량근로시간제, 일정 사납금제 방식으로 회사를 운영하였다. 원고는 2014. 8. 15. I 분회장과 사이에서도 1인 1차제, 재량근로시간제, 1일 사납금(N.F. 차량 115,660원, E.F. 차량 112,660원), 월급 600,000원을 내용으로 하는 근로계약을 체결하였다. 다만, I을 비롯한 원고 소속 근로자들은 월급 600,000원을 실제 지급받지 않고 이를 선 수령한 것으로 하고 1일 사납금 115,660원이 아닌 1일 77,000원 정도를 납입하였다.

3) I 분회장은 2016. 8. 말경 원고에 퇴직금 중간정산은 근로자퇴직급여보장법에 위배되므로 개선을 요청하면서 앞으로 자신은 퇴직금 중간정산을 받지 않겠다는 의사를 표시하였다.

4) 원고는 2016. 9. 12. '이 사건 노동조합 분회 근로시간 조정'이라는 제목으로 '2016. 10. 1.부터 운행시간 1일 8시간(출근시간 9시, 종료시간 18시)으로, 차량은 회사에 입고하고 5일 근무 1일 휴무 월 25일 근무. 이 사건 노동조합 분회 위원장께서는 시간을 꼭 준수하시고 모범이 되어주시기 바랍니다'는 내용의 공고문을 게시하였다.

5) 이 사건 노동조합 충남세종지역본부 의장 N은 2016. 9. 21. 원고에 임금협상 및 단체협상 교섭을 요구하였다. 원고는 이를 이 사건 노동조합의 교섭요구로 보아 2016. 9. 26.부터 2016. 10. 3.까지 교섭요구사실을 공고하였고(교섭요구 노동조합으로 이 사건 노동조합과 L노동조합), 2016. 10. 3.부터 같은 달 8.까지 교섭요구 노동조합 확정공고를 하였으며, 2016. 10. 9.부터 같은 달 14.까지 L노동조합을 과반수 노동조합으로 하는 공고를 하였다. 원고는 이 과정에서 교섭 참여 노동조합들에게 자율적으로 교섭대표노동조합을 결정할 수 있는 기간을 부여하지 않았다.

6) 이 사건 노동조합은 2016. 10. 12. 충남지노위에 과반수노동조합에 대한 이의신청을 하였다. 이에 원고는 같은 달 20. 자율적 교섭대표노동조합 결정기간을 2016. 10. 20.부터 같은 해 11. 3.까지로 하여 공고하였고, 충남지노위는 위 이의신청에 대하여 각하 결정을 하였다.

7) 원고는 2016. 10. 17. 원고 소속 전체 근로자를 대상으로 '밤샘주차(차고지이탈)가 시정교통행정과에 신고되어 2016. 11. 1.부터 출고 8시, 입고 16시로 근로시간을 변경한다'는 취지의 공고문을 게시하였다.

8) 원고는 2016. 11. 1.부터 이 사건 노동조합 분회 조합원을 제외한 나머지 근로자들에 대하여는 위 1일 8시간(출고 8시, 입고 16시)으로 근로시간을 변경한 것을 철회하고 2017. 1. 1.부터 이전과 같이 1인 1차제, 재량근로시간제, 1일 사납금 77,000원 정도를 납부하는 것으로 하였으나, 이 사건 노동조합 분회 조합원들에 대하여는 1일 8시간 근로하는 방식을 계속 유지하였다.

9) 한편, D은 '2016. 10. 1.경 원고 사업장에서 택시운전사로 근무하는 이 사건 노동조합 분회장인 I이 회사에서 2016. 9. 10. 지급한 퇴직금 중간정산에 이의를 제기하자 일방적으로 I의 근무형태를 실질임금이 줄어드는 기존 1인 1차제에서 1일 8시간 근무제로 변경하는 방법으로 불이익을 주고, 2016. 10. 5.경 위 사업장에서 L노동조합의 가입서류를 P, Q, R 등의 근로자들로부터 받아주고 교섭창구 단일화기간 중인 2016. 10. 16.경 일방적으로 L노동조합을 교섭대표 노동조합으로 확정하고 L노동조합과 사이에 임금협정을 체결함으로써 노동조합의 조직 또는 운영에 지배·개입하였다'는 공소사실로 기소되었고, 대전지방법원 천안지원은 이를 모두 유죄로 인정하여 D에 대하여 벌금 300만 원에 처하는 판결을 선고하였다. 이에 D이 항소하였다.

<심급별 결과>

[충남지노위] 구제신청 기각

[중노위] 충남지노위 판정 중 일방적 근로시간 변경, 조합원 가입 유도 행위에 대한 부분을 취소하고, 원고가 2016. 9. 12. 이 사건 노동조합 분회장의 근로조건을 일방적으로 변경한 것은 불이익취급 및 지배·개입의 부당노동행위임과 원고가 원고 소속 근로자들에게 L노동조합에 가입하는 원서를 작성하게 하고 가입 일자를 조작하도록 한 것은 지배·개입의 부당노동행위임을 인정한다는 취지로 판정

[1심 법원] 부당노동행위를 인정하여 원고의 청구 기각. 재심판정 유지

[2심 법원] 부당노동행위 성립을 부정하여 1심 법원 판단 취소. 재심판정 취소

판결 요지

(1) 근로시간 조정이 부당노동행위에 해당하는지 여부

I이 퇴직금 중간정산에 이의를 제기한 것은 개인적인 동기에 연유한 것일 뿐 노동조합의 업무를 위한 행위라고 보이지 아니하고, 원고가 I의 근로시간을 조정한 것은 위 퇴직금 중간정산에 관한 이의제기와 무관하다고 보이는바, 원고가 I의 정당한 노동조합 활동을 이유로 I에 대하여 불이익을 주는 차별적 취급행위를 하였다고 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 만한 증거가 없다. 따라서 원고의 이 부분 주장은 이유 있다.

가) I는 당초 부당노동행위 구제 신청 절차에서 제출한 각 이유서를 통하여 '원고가 1년마다 실시한 퇴직금 중간정산이 근로자퇴직급여 보장법에 위배되므로 개선을 요청하며, 앞으로 본인은 퇴직금 중간정산을 받지 않겠다고 하였다.'라는 취지로 주장한바 있다.

나) I는, D가 '남들 다 받는데 혼자만 왜 그러냐'는 취지로 이야기를 하자, 이의를 제기한 당일 현장에서 다시 퇴직금 중간정산을 받기로 의사를 번복하고 곧바로 퇴직금 수령증에 서명까지 하였으므로, 원고가 I의 퇴직금 중간정산에 대한 이의제기 때문에 굳이 근로시간을 조정하는 조치까지 취할 이유는 없었던 것으로 보인다. I 스스로도 관련 형사사건의 제1심 공판절차에서 증언할 당시 '퇴직금 중간정산에 대한 이의제기가 1일 8시간제로 근무형태가 변경된 원인이 되었을 것으로 막연히 미루어짐작하였다.'라는 취지로 진술하였을 뿐이지, 그렇게 생각하기에 이른 합리적인 근거나 납득할 만한 이유를 명확하게 설명하지 못하였다.

다) I을 포함한 원고 소속 M운전직 근로자들은 월간 근로시간을 특정하지 아니한 채 원고와 합의한 사납금을 납부하는 조건으로 초과 운송수입금을 자신의 수입으로 간주하는 방식으로 근로를 제공하여 왔는데, I은 이러한 근로방식이 여객자동차운수사업법에서 정한 운송수입금 전액 관리제에 위반된다고 지적하면서 임금영수증 작성을 거부하여 원고와 사이에 다툼이 발생하였고, 그러한 과정에서 I의 근로시간이 1일 8시간으로 조정되었던 것이라고 보인다. 그렇다면 관행적으로 이루어지고 있던 불법적인 근로방식을 합법적인 근로방식으로 전환하는 과정에서 I의 근로시간을 포함한 구체적인 근로형태가 변경된 것을 두고, 결과적으로 수입이 감소하게 되었다는 사정만을 들어 '근로자에게 불이익을 주는 행위'라고 단정하기는 어렵다.

(2) 전국택시산업노동조합으로의 가입을 유도하여 부당노동행위를 하였는지 여부

가) 중앙노동위원회가 이 사건 재심판정에서, 원고가 소속 근로자들에 대하여 전국택시산업노동조합으로 가입을 유도하거나 가입일자를 조작하는 등의 행위를 하였음을 인정한 근거자료는, ① 이 사건 노동조합 조합원인 S와 전국택시산업조합원인 Q 간의 대화녹취서, ② S와 전국택시산업노동조합 조합원인 P 간의 대화 녹취서, ③ I와 전국택시산업노동조합 조합원인 R 간의 대화 녹취서 중 S, Q, P, I, R 등의 진술 부분이라 할 것이다.

나) 그런데 형사사건에서 D에 대한 공소사실이 무죄로 확정되었는데 위 무죄 판단의 주된 이유는, 관련 형사사건에 제출된 증거들만으로는 D가 노동조합의 조직에 지배·개입할 의사로 전국택시산업노동조합에의 가입을 권유하는 등으로 그 가입서류를 근로자들로부터 받아 주었다는 점을 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다는 것이다.

다) 이러한 관련 형사사건에서 인정된 사실관계는 이 사건 재판에서도 유력한 증거자료가 되는 것인바, 이 사건에서 관련 형사사건에서의 위와 같은 사실판단을 채용하기 어렵다고 인정할 만한 특별한 사정을 찾아볼 수 없다.

라) 결국 중앙노동위원회가 이 사건 재심판정에서, 원고가 소속 근로자들에 대하여 전국택시산업노동조합으로 가입을 유도하거나 가입일자를 조작하는 등의 행위를 하였음을 인정한 근거로 삼은 S, Q, P, I, R 등의 진술은 모두 믿기 어렵고, 그밖에 이 사건에 제출된 증거들만으로는 D가 노동조합의 조직에 지배·개입할 의사로 전국택시산업노동조합에의 가입을 권유하는 등으로 그 가입서류를 근로자들로부터 받아 주어 부당노동행위를 행하였다는 점을 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다. 따라서 원고의 이 부분 주장도 이유 있다.

패소 이유 (사실관계에 관한 인정 차이)

이 사건은 사실관계는 동일하게 주장되었으나, 그에 관한 법리적 판단의 결과가 달라진 사건이다. 쟁점은 사용자의 행위를 부당노동행위로 볼 수 있을 것인가이다. 여기에 대해서는 초심 지노위 판정과 1심에서는 부당노동행위 성립을 부인했지만, 중노위는 인정했고, 2심 법원이 중노위의 판단을 지지했지만, 3심 고등법원이 부당노동행위 성립을 부인했다. 따라서 지배·개입 및 불이익 취급의 부당노동행위가 다투어진 이 사건에서 부당노동행위 인정 여부에 대해 상당한 논란이 있을 수밖에 없는 사건이었다는 점을 짐작할 수 있다.

한 가지 주목할 것은 2심 법원은 형사사건에서 사용자가 무죄로 확정된 것을 중요한 참고로 삼았다는 점이다. 여기에는 “원래 행정소송에서는 형사재판에서 인정된 사실에 구속받는 것은 아니라 할지라도 관련된 형사사건의 판결에서 인정된 사실은 행정소송에서 유력한 증거자료가 되는 것이어서 특별한 사정이 없는 한 관련된 형사사건에서 인정된 것과 반대되는 사실을 인정할 수 없다”라는 대법원 판례 법리(대법원 1983. 9. 13. 선고 81누324 판결, 대법원 1999. 11. 26. 선고 98두10424 판결 등)가 중요한 근거가 되었다.

중노위 판정에 결정적 실수가 있어서 패소한 사례라고 단정하기는 어렵지만, 관련된 판단 법리를 빠짐없이 종합적으로 검토할 수 있었다면 회피할 수도 있었을 것이라고 사료된다.

일련번호	2020-49
판결번호	서울고등법원 2020. 10. 23. 선고 2020누00000
중노위판정번호	중노위 2019. 1. 8. 2018부해1053
사건 종류	부당해고
세부 쟁점	근로시간면제자의 노동조합활동이 직무상 의무인지, 징계해고의 정당성

심급별 소송결과	1심 법원	재심취소	2심 법원	항소기각	대법원	-
항 소 인	김○○		참 가 인		김○○	
피항소인(원고)	○○○○○○○○ 주식회사		피고측 대리인 선임 여부		선임 안 함	
노동조합 지원 여부	있음		원고측 대리인 선임 여부		선임 함	
재심 결과	초심유지					
초심의 대법원 판례 일치여부	불일치		재심의 대법원 판례 일치여부		불일치	
기타 특이사항						

주요 사실관계

<사실관계>

참가인 근로자는 공공기관인 원고회사에서 2013. 11. 16.부터 2016. 6. 30.까지 노동조합의 사무처장직을 수행하면서 노동조합 및 노동관계조정법상의 근로시간면제자(연 1,760시간)로 지정되기도 하였고 또한 2016. 11. 1.부터는 노동조합의 위원장으로 재임한 바 있다.

경찰은 참가인이 노동조합 사무처장 업무수행 당시 조합비를 횡령한 혐의 등으로 수사에 착수하여 업무상횡령죄 및 배임수재죄로 기소하였고, 1심법원은 2017. 12. 21. 징역 10월 선고, 2심법원은 2018. 4. 5.심은 징역 10월에 집행유예 2년을 선고하였으며, 2019. 5. 30. 상고심 확정되었다. 한편 참가인의 형사사건은 다수 언론에 보도되었고, 관련 민원 제기가 상당히 있었다.

원고회사는 2018. 4. 6. 참가인에 대해 ‘장기간에 걸친 비위행위를 통해 높은 청렴성이 요구되는 공기업 직원에게 부여되는 법령준수 및 청렴의무라는 기본적 직무 위반, 이 사실이 외부에 알려지면서 회사의 체면이 손상되었고, 노동조합과 노동조합원간, 노동조합과 회사간 관계에 심각한 악영향을 미치는 등 조직 내 규율질서 문란을 초래하였다’며, 징계해임 하였다.

<심급별 결과>

[전남지노위] 징계사유에 비해 양정이 과중하여 부당해고라고 판정

[중노위] 초심유지

[1심 법원] 징계재량권을 남용한 것이라고 보기 어렵다며 재심판정 취소

[2심 법원] 항소 기각 ※ 상고하지 않음.

판결 요지

피징계자에게 징계사유가 있어서 징계처분을 하는 경우, 어떠한 처분을 할 것인지는 징계권자의 재량에 맡겨져 있다. 다만 징계권자의 징계처분이 사회통념상 현저하게 타당성을 잃어 징계권자에게 맡겨진 재량권을 남용하였다고 인정되는 경우에 한하여 그 처분이 위법하다고 할 수 있다. 징계처분이 사회통념상 현저하게 타당성을 잃어 재량권의 범위를 벗어난 위법한 처분이라고 할 수 있으려면 구체적인 사례에 따라 징계의 원인인 비위사실의 내용과 성질, 징계로 달성하려는 목적, 징계양정의 기준 등 여러 요소를 종합하여 판단할 때에 징계 내용이 객관적으로 명백히 부당하다고 인정되어야 한다(대법원 2005. 4. 29. 선고 2004두10852 판결, 대법원 2017. 3. 15. 선고 2013두26750 판결 등 참조).

한편 해고처분은 사회통념상 고용관계를 계속할 수 없을 정도로 근로자에게 책임 있는 사유가 있는 경우에 정당성이 인정되고, 사회통념상 근로자와 고용관계를 계속할 수 없을 정도인지는 사

용자의 사업 목적과 성격, 사업장의 여건, 근로자의 지위와 담당직무의 내용, 비위행위의 동기와 경위, 근로자의 행위로 기업의 위계질서가 문란하게 될 위험성 등 기업질서에 미칠 영향, 과거의 근무태도 등 여러 가지 사정을 종합적으로 검토하여 판단하여야 한다(대법원 2002. 5. 28. 선고 2001두10455 판결, 대법원 2017. 3. 15. 선고 2013두26750 판결 등 참조).

패소 이유 (사실관계에 관한 인정 차이)

중노위는 근로시간면제자인 노동조합 사무처장이 노동조합비 횡령 및 배임 수재행위로 유죄판결을 받은 비위행위와 그 사실이 언론에까지 보도된 것은 회사의 명예와 신용을 훼손하고 회사 내 규율질서를 문란하게 한 행위로서 징계사유가 되지만, 직접적인 직무관련성이 없기 때문에 직무상 의무위반은 징계사유로 삼을 수 없다고 판단하였다. 그러면서 근로자가 횡령금액을 개인용으로 사용한 사실이 없고, 전액 공탁한 점, 일부 징계사유는 인정되지 아니하는 점, 근로자는 징계감경 대상자에 해당되고 징계감경 제한사유에도 해당되지 않는 점 등을 고려하면 징계해고는 징계 양정이 과하여 부당하다고 판정하였다.

반면 법원은 <징계사유에 관한 판단 : 직무상 의무 위반>에 해당하는지에 관하여, ‘취업규칙이 ‘직무상 의무를 위반하거나 또는 직무에 태만한 때에는 이를 징계한다’고 규정하고 있는바, ‘직무’란 근로자가 사용자인 원고와의 근로계약에 따라 근로를 제공하기 위하여 담당하는 업무로서 원고가 직무상 명령 또는 지시에 따라 근로자에게 부여한 업무에 한정된다고 할 것이고, 노동조합을 포함하여 회사 이외의 자가 부여한 업무를 말하는 것이 아니라 할 것이다. 이 사건 범행은 참가인이 이 사건 노동조합의 사무처장으로서 업무를 수행하면서 이 사건 노동조합의 조합비를 운영·집행하는 과정에서 발생된 것임은 앞서 본 바와 같으므로, 이 사건 범행이 원고로부터 부여받은 직무를 위반한 것이라고 평가할 수 없다’고 판단하였다.

<징계사유에 관한 판단 : 회사체면 손상 및 규율질서 문란>에 해당하는지에 관하여는 ‘① 참가인의 이 사건 범행과 관련 형사사건 등이 언론에 공개되고, 국무총리실 등 정부기관에 참가인에 대한 인사조치 등을 요구하는 민원 등이 제기되었으며, 이 사건 노동조합의 대의원들도 참가인에 대한 엄벌을 촉구하고 원고 소속 근로자들이 이 사건 범행 등에 대한 실망감을 표출하는 글들을 블라인드앱에 올리기도 하는 등 대내외적으로 상당한 물의와 혼란이 야기된 점, ② 일반적으로 노동조합과 해당 사업장은 불가분의 관계에 있고, 이 사건 노동조합은 원고 소속 근로자 약 80% 가량이 가입한 단일노동조합으로 이 사건 범행 등으로 인한 파급력이 더욱 크며, 참가인 역시 기본적으로 원고 소속 근로자이므로, 참가인의 이 사건 범행 등으로 인한 위와 같은 대내외적 물의와 혼란은 결국 원고의 명예와 신용에도 악영향을 미치고 직장질서의 유지를 저해하는 결과를 초래할 여지가 상당한 점 등에 비추어 보면, 참가인의 이 사건 범행 등의 비위행위는 취업규칙에서 정한 징계사유에 해당한다고 보는 것이 타당하다’고 보았다.

<징계양정>에 관해 법원은 “▲원고는 안정적 전력 공급을 위해 전력설비 및 관련 시설물 개보수 공사 등을 수행하는 공기업으로서 원고 소속 근로자에게는 일반 사기업보다 더 높은 수준의 도덕성과 책임의식이 요구된다. ▲원고 소속 근로자인 참가인의 이 사건 범행 및 관련 형사사건이 다수의 언론 매체를 통해 보도되었고, 특히 이 사건 노동조합의 예산을 유혹비 등으로 사용한 사실이 언론 등을 통해 밝혀지면서, 공기업인 원고의 명예와 신용이 상당히 손상되었을 것으로 보인다. … 단일노동조합인 이 사건 노동조합의 간부가 그 업무수행 과정에서 비리행위를 저지른다면, 결국 단일노동조합인 이 사건 노동조합에 대한 신뢰가 무너지면서 건전한 노사관계 발전에도 저해가 되는 결과가 초래되고, 결국 사업주인 원고 역시도 회사 운영에 있어 다소간에 어려움을 겪을 수밖에 없다. 따라서 원고가 이 사건 범행의 직접적인 피해자는 아니라 할지라도, 이로 인한 원고의 손해가 결코 가볍다고 볼 수만은 없다. ▲참가인이 이 사건 범행으로 인해 직접적으로 취득한 재산상 이익은 없는 것으로 보이기에는 하나, ① 이 사건 노동조합의 예산으로 마련한 속칭 활동비를 재원으로 하여 이 사건 노동조합의 집행부 또는 간부들에게 지급된 돈 일부가 그 수령인들의 의사에 따라 간접적으로나마 이 사건 노동조합의 일반 조합원들에게 이익이 되는 방향으로 사용되었다 하더라도, 대외적으로 표시되는 지급인이 이 사건 노동조합 그 자체가 아닌 이 사건 노동조합의 위원장 또는 간부들이고, 위원장은 임명직이 아닌 선출직이며, 집행부 구성원은 통상 위원장과 정치적 의사를 함께했던 사람으로서 위원장이 교체될 경우 함께 바뀌는 것

에 비추어 볼 때, 활동비 지출에는 이 사건 노동조합의 위원장 또는 간부들의 조합원들에 대한 위상을 강화하고 지지율을 높이려는 목적이 있었음이 다분한 점, ② 이 사건 노동조합의 간부들이 속칭 활동비를 유흥비로 사용하기도 하였던 점 등에 비추어 보면, 참가인이 이 사건 범행으로 인한 이익을 간접적으로나마 향유하기도 했을 것으로 판단된다. ▲원고 취업규칙 및 단체협약에는 금고 이상의 형의 유죄판결이 확정되었을 때 해당 근로자를 해고할 수 있는 것으로 규정하고 있다. 비록 관련 형사사건의 판결확정일은 이 사건 징계 결정일 이후이므로 이를 이 사건 징계사유로 삼을 수 없다 하더라도, 위와 같이 금고 이상의 형으로 처벌받는 자에 대하여는 더 이상 근로관계를 유지하지 않겠다는 위 조합들의 취지를 고려하면, 이 사건 징계 당시 사실심의 최종심인 항소심에서 이 사건 범행 모두가 유죄로 인정되어 참가인이 징역형의 집행유예를 선고받았다는 점은 참가인을 해고한 이 사건 징계의 주요 양정요소로 삼기에 충분하다”고 하여, 참가인을 징계해고한 이 사건 징계가 원고의 징계재량권을 벗어나 이를 남용한 것이라고 보기 어렵다고 판단하였다.

결론적으로 단체협약에 따라 근로시간면제자로 지정되어 근로시간면제 한도 내에서 노동조합 활동을 한 것이 비위행위 등에 해당하여 문제가 되더라도 직무상 의무위반으로 볼 수 없다는 데에는 중노위와 법원의 의견이 일치하였다. 그러나 중노위는 직무상 의무위반이 아닌 데다 징계양정마저 과하다고 보아 부당해고로 결론지었나, 법원은 직무상 의무위반은 아니더라도 회사채명 손상 및 규율질서 문란의 징계사유를 인정하면서, 이에 더해 징계재량권 남용이 없으므로 정당한 해고라는 결론이 차이에 이르게 되었다. 중노위가 징계사유의 판단을 직무상 의무위반 여부에 국한하여 검토한 것으로 보이고, 대상 근로자의 노동조합 내 지위, 노동조합의 규모 등을 고려할 때 배임수재, 횡령의 범죄행위는 중한 비위행위라는 점을 간과한 것이 아닌가 생각된다.

일련번호	2020-54					
판결번호	서울행정법원 2020. 11. 12. 선고 2018구합00000					
중노위판정번호	중노위 2018. 11. 5. 2018부해916					
사건 종류	부당해고					
세부 쟁점	정규직 전환 기대권, 정규직 전환 거절의 합리적 이유					
심급별 소송결과	1심 법원	재심취소	2심 법원	-	대법원	-
원 고	김○○		참 가 인		○○시	
피 고	중앙노동위원회 위원장		피고측 대리인 선임 여부		선암 안 함	
노동조합 지원 여부	없음		원고측 대리인 선임 여부		선임 함	
재심 결과	초심유지					
초심의 대법원 판례 일치여부	불일치		재심의 대법원 판례 일치여부		불일치	
기타 특이사항						

주요 사실관계

<사실관계>

원고 근로자는 2017. 3. 20. 참가인과 사이에 기간제 근로계약(2017. 3. 20.~2017. 12. 22.)을 체결하고 근무하게 되었다. 참가인은 2017. 8. 24. 정부의 '공공부문 비정규직 근로자 정규직 전환 가이드라인'에 따라 2017. 12. 7. '기간제근로자 정규직 전환평가 실시계획'을 수립하였고, 기간제근로자 13명(원고 포함)을 '정규직 전환 평가대상자'로 선정하였다.

정규직 전환평가는 ① 직무심사 평가, ② 인성검사, ③ 면접시험으로 구성되어있고, '직무심사 평가'에서는 업무실적, 직무수행능력, 직무수행태도 등을 평가하고, 3명 이상의 평가위원이 매긴 점수가 평균 60점 이상이면서 평가위원 중 1명의 점수가 40점 미만이 아닌 경우에 합격되는 것이었다. 원고는 평가위원 1명이 낮은 점수를 주어 58.66점을 받아 불합격하였는데 정규직 전환 대상자 중 불합격한 사람은 원고뿐이었다.

참가인은 2017. 12. 22. '계약기간 만료'를 이유로 원고와 사이의 근로관계를 종료하였다.

<심급별 결과>

[경기지노위] 정규직 전환기대권이 인정되지만, 전환거절에 합리적 이유가 있다고 판정하였다.

[중노위] 초심유지

[1심 법원] 정규직 전환거절에 합리적 이유가 없다며 재심판정 취소 ※ 항소하지 않음.

판결 요지

근로계약, 취업규칙, 단체협약 등에서 기간제근로자의 계약기간이 만료될 무렵 인사평가 등을 거쳐 일정한 요건이 충족되면 기간의 정함이 없는 근로자로 전환된다는 취지의 규정을 두고 있거나, 그러한 규정이 없더라도 근로계약의 내용과 근로계약이 이루어지게 된 동기와 경위, 기간의 정함이 없는 근로자로의 전환에 관한 기준 등 그에 관한 요건이나 절차의 설정 여부 및 그 실태, 근로자가 수행하는 업무의 내용 등 당해 근로관계를 둘러싼 여러 사정을 종합하여 볼 때, 근로계약 당사자 사이에 일정한 요건이 충족되면 기간의 정함이 없는 근로자로 전환된다는 신뢰 관계가 형성되어 있어 근로자에게 기간의 정함이 없는 근로자로 전환될 수 있으리라는 정당한 기대권이 인정되는 경우에는 사용자가 이를 위반하여 합리적 이유 없이 기간의 정함이 없는 근로자로의 전환을 거절하며 근로계약의 종료를 통보하더라도 부당해고와 마찬가지로 효력이 없고, 그 이후의 근로관계는 기간의 정함이 없는 근로자로 전환된 것과 동일하다고 보아야 한다(대법원 2016. 11. 10. 선고 2014두45765 판결 등 참조).

기간의 정함이 없는 근로자로의 전환을 거절한 데에 합리적 이유가 있는지가 문제 될 때에는 사용자의 사업 목적과 성격, 사업장 여건, 근로자의 지위 및 담당 직무의 내용, 근로계약 체결 경위, 기간의 정함이 없는 근로자로의 전환에 관한 요건이나 절차의 설정 여부와 운용 실태, 근로자에게 책임 있는 사유가 있는지 등 당해 근로관계를 둘러싼 여러 사정을 종합하여 전환 거절의 사유와 절차가 사회통념에 비추어 볼 때 객관적이고 합리적이며 공정한지를 기준으로 판단하여야 하고, 그러한 사정에 관한 증명책임은 사용자가 부담한다(대법원 2017. 10. 12. 선고 2015두44493 판결 등 참조).

패소 이유 (사실관계에 관한 인정 차이)

중노위는 '① 원고 근로자는 '직무평가'에서 합격점수인 60점에 미달하는 점수를 받았고, 평가

표의 평가기준이 특별히 불공정하다고 보기 어려우며, 근로자의 실적이 저조하다는 취지의 사실 확인서 등에 비추어 볼 때 낮은 평가점수를 받은 것이 객관성이 결여되었다고 볼 수 없는 점, ② 평가결과에 대하여 최종적으로 ‘공무직인사위원회’를 거치도록 하여 평가의 공정성 내지 객관성을 검증할 수 있는 장치를 두고 있다고 보이는 점, ③ 근로자는 ‘직무평가’에서 낮은 점수를 받은 이유가 근무했던 부서의 상급자와의 갈등이 평가에 영향을 미친 것이라고 주장만 할 뿐 이에 대한 입증자료를 제출하지 못하고 있는 점 등’을 근거로, 정규직 전환 거절에 합리적인 이유가 있다고 판정하였다.

그러나 법원은 참가인에게는 원고를 정규직으로 전환시키지 아니할 만한 합리적 이유가 없었으므로 재심판정은 위법하여 취소되어야 한다고 판시하였다.

정규직 전환 거절에 합리적 이유가 있었는지 여부를 판단함에 있어, 우선 <정규직 전환 과정에서의 평가기준이 지나치게 엄격한 것이었는지> 검토하였는데, “계약직 근로자의 정규직 전환은 근로계약 갱신 등과 달리 근로관계의 질적인 측면에서 차이를 발생시키는바, 사용자는 ‘어떠한 사람을 정규직으로 전환시킬 것인지’를 결정함에 있어 상당한 인사재량을 가진다고 보아야 한다. 사용자가 세운 정규직 전환 기준이 객관적·합리적이고, 그에 따라 공정하게 점수가 부여되어 정규직전환대상자가 선발되었다면, 이는 정당한 인사재량의 행사에 해당할 것이다. 이러한 전제에서 이 사건의 정규직 전환 절차가 지나치게 엄격한 기준 하에 시행되어 재량권을 일탈·남용하였는지 여부를 보건대, 참가인은 정규직 전환 대상자에게 직무심사 평가, 인성검사, 면접시험 등 세 차례의 평가를 거치게 하고, 직무심사 평가에서는 100점 만점에 평균 60점 이상의 득점을 하도록 요구하였는바, 이러한 내용만으로는 평가기준이 지나치게 엄격했다고 보이지 아니하여, 참가인의 재량권 일탈·남용을 인정하기에 무리가 있다”고 보았다.

그리고 <‘직무심사 평가’에서 활용된 평가기준이 객관적·합리적인 것이었는지> 여부를 검토하였는데, “평가표를 보면, 업무실적(30점), 직무수행능력(60점), 직무수행태도(10점), 자격증(가점 3점)의 평가항목 아래, 업무실적의 세부항목으로 ㉠ 업무량, ㉡ 완성도, ㉢ 적시성이, 직무수행능력의 세부항목으로 ㉣ 업무이해도, ㉤ 의사소통, ㉥ 책임·성실성, ㉦ 고객지향이 포함되었음을 알 수 있고, 해당 세부항목에는 ‘담당업무 기간 내 처리 정도’ 등과 같은 세부 내용이 포함되었음을 알 수 있다. … 정성적 평가항목이 있다고 하여 곧바로 ‘평가기준이 객관적이지 아니하다’거나, ‘합리적이지 아니하다’고 단정할 것은 아니다. 그러나 정성적 평가항목의 비중이 지나치게 높거나, 최소한의 판단기준조차 제시되지 아니하여 자의적 평가가 이루어질 위험성이 높다고 볼 수 있는 경우에는 평가항목 자체에 재량권 일탈·남용의 위법이 있다고 봄이 상당할 것이다. 이 사건의 평가항목에 관하여 보건대, 정성평가항목으로 구성된 ‘직무수행능력’의 배점이 100점 만점(가점 3점) 중 60점을 차지하고 있어 그 비중이 지나치게 높은 것이 아닌가 하는 의문이 들기는 한다. 그러나 원고가 수행하는 통합사례관리 업무의 내용·특성을 보면, 해당 업무는 숫자로 드러나는 정량적 업무수행의 결과물도 중요하지만, 지원대상자에 대한 태도, 업무에 대한 책임감, 주변 동료들과의 화합 등 요소 또한 매우 중요함을 알 수 있다. 이러한 사정을 고려해보면, 앞서 본 정성평가의 비중이 재량을 일탈·남용한 정도에까지는 이르지 아니하였다고 보인다”고 판단하였다.

반면 <직무심사 평가 과정에서의 점수부여가 공정하게 이루어졌는지>에 관해 법원은 “직무심사 평가의 합격요건은 ‘㉧ 평균 점수가 60점을 넘을 것, ㉨ 개별 평가점수가 40점 미만이 되지 아니할 것’이다. … 원고가 오로지 위 표 순번 2 기재 평가위원의 점수부여로 인해 불합격하게 되었음을 알 수 있다. … 즉, 원고의 합격 여부는 오직 1명의 평가위원에 의해 좌우된 것인데, 위 표 순번 2 기재 평가위원이 원고에게 부여한 점수의 내용을 보면, 유독 ‘직무수행능력’ 항목에서 낮은 점수가 부여되었음을 알 수 있다. 특히 ‘업무이해도’, ‘의사소통’, ‘고객지향성’ 항목에서는 최저점이 부여되었는데, ‘이 사건 정규직 전환 대상자 중 원고를 제외한 나머지 12명’ 중 그 누구도 그러한 점수를 받은 바 없었다. 그런데 위 표 순번 3 기재 평가위원은 … 위 표 순번 2 기재 평가위원과 정반대의 평가를 한 바 있다. 이렇게 유독 1명의 평가위원이 특정 인물의 정성적 평가항목에 최하점을 부여함으로써 다른 평가위원들의 평가결과를 뒤집고 해당 인물을 불합격시킨 상황이라면, 이러한 상황을 설득력 있게 설명할 만한 객관적인 추가 정황이 필요하다고 보아야 할 것이다”고 하면서, “순번 2 기재 평가위원의 원고에 대한 점수 부여가 객관적이고 합리적인 근거에 터 잡아 공정하게 이루어졌다고 볼 만한 사정을 전혀 찾아 볼 수 없다 … 원고에 대한 직무심사 평가 과정에서의 점수부여는 공정하게 이루어지지 아니하였다고 봄이 상당하다”고 결론 내렸다.

부록.1. 주요 사건 경과 및 패소 원인 분석

중노위와 법원은 공통적으로 이 사건 정규직 전환 평가기준을 합리적이라 인정하였지만, 법원이 평가과정에서 점수 부여가 공정하였는지에 관해 사용자측에 객관적인 입증을 요구한 것이 중노위와 법원의 결론을 가르는 결정적 요인이 되었다. 이 사건에서 법원이 정규직 전환 거절의 합리성 유무를 판단함에 있어 보다 자세하게 판단요소들을 실시한 점은 향후 중노위의 판정 단계에서 판정의 정확성을 높이는 데 좋은 참고자료가 될 것으로 보인다.

일련번호	2020-56					
판결번호	대법원 2020. 12.10. 선고 2020두00000					
중노위판정번호	중노위 2019. 1. 23. 2018부해1211					
사건 종류	부당해고					
세부 쟁점	사직서 제출 및 철회의 효력					
심급별 소송결과	1심 법원	재심 유지	2심 법원	1심 취소	대법원	상고기각 (심리불속행)
상 고 인	중앙노동위원회위원장		참 가 인		○○○주택관리 주식회사	
피상고인	윤○○		피고측 대리인 선임 여부		선임 안 함	
노동조합 지원 여부	없음		원고측 대리인 선임 여부		선임 함	
재심 결과	초심유지					
초심의 대법원 판례 일치여부	불일치		재심의 대법원 판례 일치여부		불일치	
기타 특이사항						

주요 사실관계

<사실관계>

참가인 회사는 2017. 7. 1. 이 사건 아파트 입주자대표회의와 계약기간 2년의 위·수탁계약을 체결하였고, 참가인의 근로자인 원고는 2018. 1. 22.부터 이 사건 아파트의 관리소장으로 파견 근무를 하였다. 원고는 입주자대표회의 회장과의 사이에 명절 격려금 지급에 관한 지출결의서 결재 등과 관련하여 갈등이 있었고, 입주자대표회의는 2018. 3. 30. 참가인에게 원고의 부적합한 근무 태도 등을 이유로 2018. 4. 30.자로 이 사건 위·수탁계약을 해지하겠다고 통보하고, 2018. 5. 2. 원고에게 관리사무소에 출근하지 말라고 요구하였다.

한편 원고는 2018. 5. 17. 퇴사예정일을 6월 30일로, 퇴직사유란에 “아파트 관리 단지 사정으로 인해 퇴사코자 하오니 조치하여 주시기 바랍니다”라고 기재한 사직서를 참가인에게 제출하였다. 참가인은 입주자대표회의에게 ‘인사위원회가 원고를 2018. 6. 30.자로 해고하기로 의결하였다’고 통지하였으나, 원고에게는 통보하지 아니하던 중, 원고가 참가인에게 사직서를 없던 일로

하겠다는 의사를 수차례 표시하였다. 그럼에도 퇴직처리가 되자 원고가 부당해고 구제신청을 하였다.

<심급별 결과>

[서울지노위] 근로자가 스스로 사용자에게 사직서를 작성, 제출한 것으로 해고는 존재하지 않는다는 이유로, 원고의 구제신청 기각

[중노위] 초심유지

[1심 법원] 재심판정 유지

[2심 법원] 근로자가 사직의사를 유효하게 철회하였음에도 사용자가 정당한 이유 없이 일방적으로 근로관계를 종료시킨 것으로 부당해고라며, 1심 판결을 취소 (재심 취소)

[대법원] 심리불속행기각

판결 요지

사용자가 근로자로부터 사직서를 제출받고 이를 수리하는 의원면직의 형식을 취하여 근로계약 관계를 종료시킨 경우, 사직의 의사 없는 근로자로 하여금 어쩔 수 없이 사직서를 작성·제출하게 하였다면 실질적으로 사용자의 일방적인 의사에 의하여 근로계약관계를 종료시키는 것이어서 해고에 해당한다 할 것이나, 그렇지 않은 경우에는 사용자가 사직서 제출에 따른 사직의 의사표시를 수락함으로써 사용자와 근로자의 근로계약관계는 해지되어 종료되는 것이므로 사용자의 의원면직처분을 해고라고는 볼 수 없다(대법원 2003. 4. 11. 선고 2002다60528 판결, 대법원 2015. 8. 27. 선고 2015다 211630 판결 등 참조).

진의 아닌 의사표시에 있어서의 '진의'란 특정한 내용의 의사표시를 하고자 하는 표의자의 생각을 말하는 것이지 표의자가 진정으로 마음속에서 바라는 사항을 뜻하는 것은 아니므로 표의자가 의사표시의 내용을 진정으로 마음속에서 바라지는 아니하였다고 하더라도 당시의 상황에서는 그것이 최선이라고 판단하여 그 의사표시를 하였을 경우에는 이를 내심의 효과의사가 결여된 진의 아닌 의사표시라고 할 수 없다(대법원 2003. 4. 25. 선고 2002다11458 판결, 대법원 2015. 8. 27. 선고 2015다211630 판결 등 참조).

통정허위표시가 성립하기 위해서는 의사표시의 진의와 표시가 일치하지 아니하고 그 불일치에 관하여 상대방과 사이에 합의가 있어야 한다(대법원 2007. 6. 14. 선고 2006다53290 판결 참조).

한편 사직의 의사표시는 특별한 사정이 없는 한 당해 근로계약을 종료시키는 취지의 해약고지로 볼 것인 바, 사직 의사표시가 해약의 고지라고 인정되는 경우에는 그 의사표시가 사용자에게 도달한 이상 근로자로서는 사용자의 동의 없이 이를 철회할 수 없다. 그러나 근로자가 사직원을 제출하여 근로계약관계의 합의해지를 청약하는 경우에는 그에 대한 사용자의 승낙의사가 형성되어 그 승낙의 의사표시가 근로자에게 도달하기 이전에는 그 의사표시를 철회할 수 있고, 다만 근로자의 사직 의사표시 철회가 사용자에게 예측할 수 없는 손해를 주는 등 신의칙에 반한다고 인정되는 특별한 사정이 있는 경우에 한하여 그 철회가 허용되지 않는다. 근로자의 사직 의사표시가 당해 근로계약을 종료시키는 취지의 해약고지인지 아니면 사용자에게 대한 근로계약관계 합의해지의 청약인지 여부는 그 의사표시가 기재된 사직서의 구체적인 내용, 사직서 작성·제출의 동기 및 경위, 사직서 제출 이후의 상황 등 제반 사정을 참작하여 판단해야 할 것이다(대법원 2000. 9. 5. 선고 99두8657 판결, 대법원 2007. 10. 11. 선고 2007다11668 판결 등 참조).

패소 이유 (주요 법리에 대한 판단 차이)

이 사건의 경우, 중노위와 대법원의 입장이 상반되게 된 것은 사실관계 인정에 관한 관점의 차이보다, 근로자의 사직서 제출 및 철회의 효력에 관한 법리의 해석, 적용에 있어 다른 입장을 취한 것이 중요하게 작용한 것으로 보인다.

중노위는 '① 근로자가 사직서를 작성, 제출한 사실을 인정하는 점, ② 근로자는 사용자가 일방적으로 근로관계를 종료하였다고 주장하면서도 입증자료를 제출하지 못하고 있는 점, ③ 근로자의 근무 경력 등을 볼 때 사직서 제출의 의미를 충분히 알고 있었던 것으로 보이므로 진의 아

닌 의사표시라는 주장을 받아들이기 어려운 점, ④ 사용자가 사직서가 제출 되자마자 수리하였는데도 이후 전화를 걸어 사직서 제출을 철회하였다는 주장을 받아들이기 어려운 점 등'을 이유로 근로자 스스로 사직한 것이지 해고는 존재하지 않는다고 판정하였다. 아울러 사직서 제출은 해약의 고지에 해당하므로, 그 의사표시가 사용자에게 도달한 이상 철회할 수도 없다고 보았다.

그러나 법원은 <사직서 제출에 의한 사직의 의사표시가 비진의 의사표시 또는 통정허위 의사표시인지 여부>에 관해 법원은 “① 2018. 4. 30.자로 이 사건 위·수탁계약이 해지됨에 따라 이 사건 아파트의 관리소장이었던 원고는 더 이상 담당할 보직이 없었다. ② 이 사건 아파트 관리소장으로 근무하면서 발생한 문제로 인해 원고는 참가인 인사위원회에 회부되어 해고의 징계를 받을 수 있는 상황에 직면해 있었다. ③ 일반적으로 징계해고보다는 자진 사직이 재취업에 있어 더 유리할 것으로 보인다. 원고로서는 사직서를 제출할 경우와 그렇지 않은 경우의 득실 등을 고려하여 당시 상황에 비추어 징계해고를 당하기보다는 스스로 사직하여 다른 아파트 관리소장으로 재취업을 하는 것이 최선이라고 판단하여 본인의 의지로 사직의 의사표시를 하였다고 볼 수 있다. ④ 원고는 이전에 두 군데 업체에서 관리소장으로 근무한 경력이 있다. 원고의 경력, 지위 등에 비추어 원고는 이 사건 사직서 제출 당시 사직의 의미를 이해하고 있었다고 보아야 한다. 이 사건 사직서 제출에 따른 사직의 의사표시는 내심의 효과의사에 따라 표시되었다고 할 것이다”며, 사직의 의사가 없는 원고가 어쩔 수 없이 이 사건 사직서를 작성·제출하였다고 보아는 이 사건 사직서를 작성하여 제출하는 것이 당시 상황에서 최선이라고 판단하여 사직의 의사표시를 하였다고 봄이 상당하므로, 사직의 의사표시가 ‘진의 아닌 의사표시’나 ‘통정허위표시’에 해당하지 않는다고 판단하였다.

<사직의 의사표시가 근로관계를 종료시키는 해약의 고지인지, 근로계약의 합의해지를 청약한 것인지 여부>에 관해서는 ‘① 참가인의 취업규칙은 “직원이 퇴직코자 할 때에는 적어도 30일 전에 퇴직사유를 기재한 사직원을 제출하여 퇴직 승인을 득해야 한다. 승인 없이 결근할 경우 무단 결근으로 처리한다.”… 고 규정하고 있다. … 사직원을 제출하더라도 퇴직의 승인을 받아야 사직의 효력이 생긴다 … 참가인의 취업규칙은 사직의 의사표시를 근로계약의 합의해지 청약으로 파악하고 있다고 볼 수 있다. ② … 이 사건 사직서 하단에는 “주의) 사직원은 퇴사예정일 15일 이전에 제출(도착) 하여야 하고 승인 시까지 근무에 지장이 없어야 합니다.”라는 문구가 부동문자로 기재되어 있다 … 사직서는 참가인이 마련한 양식에 따른 것이다 … 사직서는 취업규칙 규정에 근거하여 원고의 사직의사표시에 대한 참가인의 ‘조치’를 예정하고 있고, 주의 문구에서 ‘참가인의 승인’이라는 별도의 조치가 있어야 근로관계가 종료됨을 언급하고 있다’는 점 등을 들어, 이 사건 사직서 제출은 근로계약에 대한 합의해지를 청약한 것으로 봄이 상당하다고 판단하였다.

<사직의 의사표시가 유효하게 철회되었는지 여부>에 관해, ‘① 참가인의 인사업무는 이○○ 과장 → 황○○ 본부장 → 최○○ 상무 → 대표이사의 결재를 거치도록 되어 있다. 이 사건 사직서 제출 시 위와 같은 결재과정을 거쳤다. ② 참가인은 원고가 이 사건 사직서를 제출한 2018. 5. 17. 이후에 이를 수리하는 내부결재 절차를 거친 것으로 보이나, 원고에게 … 수리되었음을 통지하지 않았다. … ③ 원고는 2018. 5. 29. 서울지방노동위원회를 방문하여 부당해고 구제신청과 관련하여 빨리 사직서를 철회하라는 상담을 받고 황○○ 본부장에게 전화를 걸어 여러 차례 반복하여 “그 사직서는 철회하는 걸로 없는 것으로 해요”, “아예 없는 걸로 해요” … 라고 말하였다. 당시 황○○는 … 원고에 대한 인사 관련 조치를 책임지고 처리하는 지위에 있어 참가인을 대표하여 위 철회의 의사표시를 유효하게 수령할 만한 권한이 있었다고 볼 수 있다. 원고가 철회의 의사표시를 반드시 서면에 의하여 하여야 하는 것은 아니므로, 구두 철회의 효력을 부정할 수 없다’는 점을 고려할 때, 원고는 사직서가 수리되었음을 통지받은 아니한 상태에서 참가인에게 사직의 의사표시를 유효하게 철회하였다고 봄이 상당하다고 판단하였다.

이에 법원은 참가인 회사가 원고의 사직서 제출을 이유로 원고를 퇴직처리한 것은 부당해고에 해당하고, 근로계약관계가 원고의 일방적 사직 의사표시에 따라 종료되었음을 이유로 한 이 사건 재심 판정은 위법하다고 결론 내렸다.

생각건대 중노위가 근로자가 스스로 사직서를 제출하였고 그 과정에서 사용자로부터 중대한 부당한 압력이나 회유가 있었던 것으로 보이는 사정이 없는 본 사안의 사실관계의 특성상, 사직의 의사표시 및 철회의 효력에 관한 법리 검토에 다소 미진함이 있었던 것으로 보인다.

일련번호	2020-57					
판결번호	대법원 2019. 10. 17. 선고 2020두00000					
중노위판정번호	중노위 2018. 2. 26. 2017부해1283					
사건 종류	부당해고					
세부 쟁점	갱신거절의 합리적 이유 존부					
심급별 소송결과	1심 법원	재심 취소	2심 법원	항소 기각	대법원	상고기각 (심리불속행)
상 고 인	합자회사 ○○○운수		참 가 인		합자회사 ○○○운수	
피상고인	주○○		피고측 대리인 선임 여부		선임 안 함	
노동조합 지원 여부	없음		원고측 대리인 선임 여부		선임 함	
재심 결과	초심유지					
초심의 대법원 판례 일치여부			재심의 대법원 판례 일치여부			
기타 특이사항						

주요 사실관계
<사실관계> 참가인 회사는 상시 26명의 근로자를 고용하여 시내버스 운수사업 등을 하는 합자회사이다. 원고 근로자는 정년이 지난 2015. 8. 17. 참가인 회사와 근로계약 기간 1년의 기간제 근로계약을 체결하고 입사하여 운전기사로 근무하다가 2015. 11.경부터는 관리부장으로 근무하였다. 원고는 2016. 8. 17.경 별도의 근로계약서를 작성하지 않고 위 근로계약을 갱신하고, 2016. 12. 12.부터는 다시 운전기사로 근무하였는데, 참가인은 2017. 7. 11.경 및 2017. 7. 15.경 원고에게 이 사건 근로계약의 기간 만료로 근로관계가 종료된다는 취지의 통보를 하였다. 이에 원고가 부당해고 구제신청을 하자, 참가인 회사는 '원고가 회사 돈을 횡령하고, 회사 명의의 차용증과 근저당권 설정계약서를 위조하였으며, 참가인 회사에 1억 원을 빌려준 적이 없음에도 이를 빌려주었다고 주장하면서 법원에 참가인을 상대로 지급명령을 신청하기도 하는 등 원고와 참가인 사이에 법적 분쟁이 지속되어 신뢰관계 회복 및 근로관계 유지가 어렵다'고 항변하였다. <심급별 결과> [강원지노위] 갱신거절에 합리적 이유가 있어 부당해고가 아니라며 구제신청 기각 [중노위] 초심유지 [1심 법원] 근로계약 갱신거절은 합리적인 이유를 인정할 수 없어 부당해고와 마찬가지로 무효이므로, 재심판정 취소 [2심 법원] 항소 기각 [대법원] 심리불속행 기각

판결 요지

기간을 정하여 근로계약을 체결한 근로자의 경우, 그 기간이 만료됨으로써 근로자로서의 신분 관계는 당연히 종료되고, 근로계약을 갱신하지 못하면 갱신거절의 의사표시가 없어도 그 근로자는 당연퇴직하는 것이 원칙이다. 그러나 근로계약, 취업규칙, 단체협약 등에서 기간이 만료되더라도 일정한 요건이 충족되면 당해 근로계약이 갱신된다는 취지의 규정을 두고 있거나, 그러한 규정이 없더라도 근로계약의 내용과 근로계약이 이루어지게 된 동기 및 경위, 계약 갱신의 기준 등 갱신에 관한 요건이나 절차의 설정 여부 및 그 실태, 근로자가 수행하는 업무의 내용 등 당해 근로관계를 둘러싼 여러 사정을 종합하여 볼 때, 근로계약 당사자 사이에 일정한 요건이 충족되면 근로계약이 갱신된다는 신뢰관계가 형성되어 있어 근로자에게 그에 따라 근로계약이 갱신될 수 있으리라는 정당한 기대권이 인정되는 경우에는, 사용자가 이에 위반하여 부당하게 근로계약의 갱신을 거절하는 것은 부당해고와 마찬가지로 아무런 효력이 없다. 이때 기간 만료 후의 근로관계는 종전의 근로계약이 갱신된 것과 동일하다(대법원 2011. 4. 14. 선고 2007두1729 판결, 대법원 2014. 2. 13. 선고 2011두12528 판결 등 참조).

그리고 기간제 및 단시간근로자 보호 등에 관한 법률(이하 '기간제법')은 같은 법 제4조 제1항 단서의 예외 사유에 해당하지 않는 한 2년을 초과하여 기간제근로자로 사용하는 경우 기간의 정함이 없는 근로계약을 체결한 것으로 간주하고 있으나, 기간제법의 입법 취지가 기간제근로자 및 단시간근로자에 대한 불합리한 차별을 시정하고 근로조건 보호를 강화하기 위한 것임을 고려하면, 기간제법 제4조 제1항 단서의 예외 사유에 해당한다는 이유만으로 갱신기대권에 관한 위 법리의 적용이 배제된다고 볼 수는 없다. 이러한 갱신기대권 법리와 함께 기간제법 등의 입법 취지, 사업장 내에서 정한 정년의 의미, 정년 이후에 기간제 근로계약을 체결하는 근로계약 당사자의 일반적인 의사 등을 모두 고려하면, 정년을 이미 경과한 상태에서 기간제 근로계약을 체결한 경우에는, 앞서 본 제반 사정 외에 해당 직무의 성격에 의하여 요구되는 직무수행 능력과 당해 근로자의 업무수행 적격성, 연령에 따른 작업능률 저하나 위험성 증대의 정도, 해당 사업장에서 정년을 경과한 고령자가 근무하는 실태 및 계약이 갱신되어 온 사례 등을 종합적으로 고려하여 근로계약 갱신에 관한 정당한 기대권이 인정되는지 여부를 판단 하여야 한다(대법원 2017. 2. 3. 선고 2016두50563 판결 참조). 이때 갱신거절의 사유와 절차가 사회통념에 비추어 객관적이고 합리적이며 공정한지 여부에 관한 사정의 증명책임은 사용자가 부담한다(대법원 2017. 10. 12. 선고 2015두44493 판결 참조).

패소 이유 (사실관계에 관한 인정 차이)

이 사건에서 중노위와 법원 모두 원고 근로자의 근로계약 갱신기대권이 존재한다고 보았으나, 참가인 회사의 갱신거절에 합리적 이유가 있는지 여부에 있어 상반된 결론을 내렸다.

중노위는 ① 재직 중 업무 수행과 직·간접적으로 관련하여 사문서위조 및 위조사문서행사죄에 대하여 일부 기소유예 처분을 받은 점, ② 업무상횡령죄에 대하여 참고인증지를 받은 점 등에 비추어 볼 때, 사용자와의 신뢰관계 회복이 어려워 보이므로 갱신 거절의 합리적 이유가 있다고 판정하였다.

그러나 법원은 '① 원고가 ... 참가인 회사의 돈을 횡령하였다거나 참가인 회사 및 대표명의로 차용증과 근저당권설정계약을 위조하였다는 사실을 인정할 만한 아무런 증거가 없다. 오히려 춘천지방검찰청 검사는 모두 혐의없음(증거불충분) 처분을 하고 ... 모두 참가인의 오해에서 비롯된 것일 뿐, 그것에 원고가 책임질 만한 부분이 있다고 보기 어려우므로, 원고와 참가인 사이의 법적 분쟁은 근로계약 갱신거절의 합리적 사유로 볼 수 없다. ② 춘천지방검찰청 검사는 이 사건 고소사실 가운데 원고의 전 배우자 명의 차용증 위조 부분에 대하여는 기소유예 처분을 하였으나, 이는 ... 참가인 회사와 무관하므로, 근로계약의 갱신을 거절할 만한 정당한 사유로 보기 어렵다. ③ 원고가 수원지방법원 안산지원에 참가인을 상대로 100,094,900원의 지급명령을 신청한 것은 원고의 참가인 회사에 대한 권리의 행사에 해당하고, 그것이 존재하지 않는 권리를 행사하는 것이라는 사실을 인정할 아무런 증거가 없다. ... 원고가 참가인 회사를 상대로 자신의 권리를 적법하게 행사한 것은 근로계약 갱신거절의 정당한 사유로 볼 수 없다. ④ 정○○도 취업규칙

상 정년이 지난 후 기간제 근로계약을 체결하여 참가인에 입사한 후 4회에 걸쳐 근로계약을 갱신하였고, 박○○은 원고보다 나이가 많지만, 여전히 근무하고 있다. 원고가 특별히 운전기사 업무를 할 수 없는 상태라고 볼 만한 사정도 보이지 않는다'는 등에 비추어 근로계약 갱신거절의 사유가 사회통념에 비추어 객관적이고 합리적이며 공정하다고 보기 어렵다고 보았다.

갱신거절에 합리적 이유가 있는지 여부에 관한 판단은 결국 사실관계 인정 및 그에 대한 법적 평가를 어떻게 하느냐에 달린 문제이다. 이 사건에서도 중노위와 법원이 인정한 객관적 사실관계에는 큰 차이가 없으나, 드러난 사실을 어떤 관점에서 볼 것인지, 어떤 사실을 보다 중요하게 취급할 것인지에 있어 법원이 중노위와 다른 관점을 취한 것이 다른 결론에 이른 결정적 요인으로 보인다.

일련번호	2021-1					
판결번호	대법원 2020. 12. 30. 선고 2020두00000 판결					
중노위판정번호	중노위 2019. 2. 19. 2018부해1326 판정					
사건 종류	부당해고					
세부 쟁점	갱신기대권, 갱신거절에 대한 합리적 이유					
심급별 소송결과	1심 법원	재심판정취소	2심 법원	1심판결 유지	대법원	원심판결 유지
상 고 인	중앙노동위원회위원장		참 가 인		○○○○ 주식회사 ⁶⁵⁾	
피상고인	신○○(원고) ⁶⁶⁾		피고측 대리인 선임 여부		선임 안 함	
노동조합 지원 여부	없음		원고측 대리인 선임 여부		선임	
재심 결과	초심유지					
초심의 대법원 판례 일치여부	불일치		재심의 대법원 판례 일치여부		불일치	
기타 특이사항	- 사용자가 인사고과평가를 이유로 갱신거절을 한 사건 - 대법원 심리불속행 기각					

주요 사실관계

<사실관계>

근로자 신○○(이하 '이 사건 근로자'라 한다)은 2014. 9. 1. ○○○○ 주식회사에 계약직(촉

65) 1심 : 법무법인 린 / 2심 : 법무법인 린 / 3심 : 선임 안 함

66) 1심 : 개인변호사 / 2심 : 개인변호사 / 3심 : 법무법인 남현(*심급의 변화로 대리인이 변동되었으나 변호사의 소속 변경에 따른 대리인 변화로 추정됨)

탁)으로 입사 후 2015. 3. 24.부터 2018. 8. 31.까지 대구 ○○동 소재 ‘○○○○파크드림(이하 ‘이 사건 아파트’라 한다)에서 경비원으로 근무하였던 자이고, 위 기간 동안 1~8개월의 근로계약 기간으로 총 15회(최종 근로계약기간 2018. 2. 1.~8. 31.) 계약갱신을 통해 근무하였다.

사용자 ○○○○ 주식회사(이하 ‘이 사건 사용자’ 또는 ‘이 사건 사업장’)는 1999. 2. 2. 설립되어 상시 근로자 2,100여 명을 사용하여 근로자 파견 및 시설경비업 등을 영위하는 법인이고, 2018. 8. 17. 이 사건 근로자에게 ‘이 사건 근로계약이 2019. 8. 31.자로 종료된다’는 취지의 근로계약 종료 통보서를 내용증명으로 발송하였다.

이 사건 근로자는 위 내용증명으로 인한 통보는 부당해고에 해당한다고 주장하면서 경북지노위에 구제신청을 하였다.

<심급별 결과>

[경북지노위] ‘원고(근로자)에게 이 사건 근로계약에 관한 갱신기대권은 인정되나, 참가인(사용자)의 이 사건 갱신거절에 합리적인 이유가 있다’는 이유로 원고(근로자)의 신청 기각

[중노위] 위 초심판정과 같은 이유로 원고(근로자)의 재심신청 기각

[1심 법원] ① 이 사건 근로자와 사용자의 근로계약은 기간의 정함이 있는 근로계약이고 계약기간의 만료로 당연퇴직 되는 것이 원칙이므로, 사용자가 갱신거절의 과정에서 그 사유를 서면으로 통지할 필요는 없다고 판시하였다. ② 다만 당해 근로관계를 둘러싼 여러 사정을 종합하여 볼 때 근로자에게는 계약갱신에 대한 기대권이 발생하였고, 사용자가 갱신거절의 이유로 삼은 인사고과 평가는 객관성, 합리성, 공정성을 갖추었다고 보기 어렵다는 점 등을 이유로 이 사건 갱신거절의 정당한 사유가 인정된다고 보기 어렵다는 이유로 중노위의 재심판정을 취소

[2심 법원] 1심법원의 판결과 같은 판결

[대법원] 역시 원심법원의 판결을 그대로 인정

판결 요지

가. 이 사건 근로자가 기간의 정함이 없는 근로자인지 여부

근로자와 사용자가 체결한 근로계약서, 사용자의 취업규칙상 정년 규정, 근로자가 자필로 이 사건 근로계약이 기간을 정한 근로계약이라는 확인 각서에 서명하여 근로자 스스로 기간을 정한 근로계약임을 분명히 인식하고 있었던 점, 사용자의 업무특성상 근로자인 경비원들과 단기로 계약기간을 정하여 계약을 체결해 온 관행이 있었다는 점을 볼 때 이 사건 근로자는 기간의 정함이 있는 근로자이다.

나. 이 사건 갱신거절이 근로계약법 제27조를 위반하여 무효인지 여부

기간을 정하여 근로계약을 체결한 근로자는 계약기간이 만료되는 경우 사용자측의 갱신거절의 사표시가 없어도 당연퇴직되는 것이 원칙이므로(대법원 2014. 2. 13. 선고 2011두12528 판결 등 참조), 사용자가 갱신거절 과정에서 그 사유를 서면으로 통지하는 등 근로기준법 제27조 제1항에서 정한 해고의 절차를 준수하여야 한다고 볼 수는 없다.

다. 갱신거절의 합리적 사유가 있는지 여부

기간을 정하여 근로계약을 체결한 근로자의 경우 그 기간이 만료됨으로써 근로자로서의 신분관계는 당연히 종료되는 것이 원칙이다. 그러나 근로계약, 취업규칙, 단체협약 등에서 기간만료에도 불구하고 일정한 요건이 충족되면 당해 근로계약이 갱신된다는 취지의 규정을 두고 있거나, 그러한 규정이 없더라도 당해 근로관계를 둘러싼 여러 사정을 종합하여 볼 때 근로계약 당사자 사이에 일정한 요건이 충족되면 근로계약이 갱신된다는 신뢰관계가 형성되어 있어 근로자에게

그에 따라 근로계약이 갱신될 수 있으리라는 정당한 기대권이 인정되는 경우에는 사용자가 이에 위반하여 부당하게 근로계약의 갱신을 거절하는 것은 부당해고와 마찬가지로 아무런 효력이 없고, 이 경우 기간만료 후의 근로관계는 종전의 근로계약이 갱신된 것과 동일하다고 보아야 한다(대법원 2011. 4. 14. 선고 2007두1729 판결, 대법원 2016. 11. 10. 선고 2014두457765 판결 등 참조)

근로자에게 이미 형성된 갱신에 대한 정당한 기대권이 있음에도 불구하고 사용자가 이를 배제하고 근로계약의 갱신을 거절한 데에 합리적 이유가 있는지가 문제될 때에는 사용자의 사업 목적과 성격, 사업장 여건, 근로자의 지위 및 담당 직무의 내용, 근로계약 체결 경위, 근로계약의 갱신에 관한 요건이나 절차의 설정 여부와 그 운용 실태, 근로자에게 책임 있는 사유가 있는지 여부 등 당해 근로관계를 둘러싼 여러 사정을 종합하여 갱신 거부의 사유와 그 절차가 사회통념에 비추어 볼 때 객관적으로 합리적이고 공정한지를 기준으로 판단하여야 하고, 그러한 사정에 대한 증명책임은 사용자가 부담한다(대법원 2017. 10. 12. 선고 2015두44493 판결 등 참조)

갱신거절 전 근로자는 전임 관리소장을 내부고발하였고, 갱신거절과 이러한 내부고발과의 사이에 연관이 있는 것으로 합리적인 의심이 드는 점, 사용자의 주장처럼 인사사고평가를 실시하고 이를 기준으로 갱신여부를 결정하였다는 관행이 존재하였다고 볼 수 없는 점, 가사 이러한 관행이 존재하였다고 하더라도 인사사고평가 자체가 객관성, 합리성, 공정성을 갖추었다고 보기 어렵다는 점에서 사용자가 이 사건 근로계약의 갱신을 거절할 만한 합리적인 이유가 있다고 볼 수 없다.

따라서 이와 다른 전제에서 내려진 이 사건 재심판정은 위법하다.

패소 이유 (사실관계에 관한 인정 차이)

기간제 근로계약을 체결한 경우, 갱신기대권이 인정된다는 점에 있어서는 노동위원회, 법원 모두 같은 결론을 도출하였다.

다만, 갱신거절의 합리적 이유가 있는지 여부에 관하여는 노동위원회와 법원의 판단이 반대되었는데, 이는 사용자가 갱신거절의 주된 이유로 밝힌 ① 인사사고평가를 근거로 갱신을 거절해 온 관행이 있는지 여부, ② 인사사고평가 자체의 공정성, 합리성 등에 대한 사실관계 인정에 차이가 있었다.

인사사고평가 자체는 근로자에게 불리한 것은 사실이나 법원은 그러한 인사사고평가 자체가 합리성에 의심이 들고, 인사사고평가라는 근거로 근로자와의 갱신을 거절하였다는 관행이 있었다고 보기 어렵다고 판단한 반면, 중노위는 인사사고평가의 결과를 이유로 합리적으로 갱신거절이 있었다고 판단하였다.

사실관계에 대한 충분한 조사는 있었으나 각 당사자가 주장 중 어느 쪽의 주장이 합리적인지에 관한 판단이고, 수치화, 정량화하기는 곤란한 사항에 대한 판단을 달리한 것이므로 중노위의 대응 자체가 합리성을 결여했다고 보기는 어려울 것으로 판단된다.

한편, 이 사건은 초심, 재심 노동위원회, 사실심인 1심 판결과 2심 판결이 모두 동일한 법적 기준을 인정하되 사실관계의 해석만을 달리한 사건이고, 그 결과 법원이 노동위원회의 결정을 정반대로 뒤집는 결론을 내린 사건이지만, 중노위가 대법원에 상고한 것은 일응 타당성이 있다고 볼 여지가 있다.

부록.1. 주요 사건 경과 및 패소 원인 분석

일련번호	2021-2					
판결번호	대법원 2020. 12. 30. 선고 2020두00000					
중노위판정번호	중노위 2018. 6. 12. 중앙2018부해400					
사건 종류	부당해고					
세부 쟁점	시용근로관계 판단, 징계양정					
심급별 소송결과	1심 법원	재심판정취소	2심 법원	1심판결 유지	대법원	원심판결 유지
상 고 인	중앙노동위원회위원장		참 가 인		이○○ ⁶⁷⁾	
피상고인	○○○○코리아 유한회사		피고측 대리인 선임 여부		선임 안 함	
노동조합 지원 여부	없음		원고측 대리인 선임 여부		선임 ⁶⁸⁾	
재심 결과	초심유지					
초심의 대법원 판례 일치여부	불일치		재심의 대법원 판례 일치여부		불일치	
기타 특이사항	- 이 사건 근로계약이 시용계약인지 본계약인지 근로계약서의 해석과 관련하여 노동위원회와 법원의 판단이 정반대로 엇갈린 사건 - 이 사건 근로자는 고액 연봉을 받는자였음 - 대법원 심리불속행 기각					

주요 사실관계
<사실관계> 근로자 이○○(이하 ‘이 사건 근로자’라 한다)은 2017. 6. 26. ○○○○코리아 유한회사에 인사 총무 부장으로 입사하여 근무하던 중 2017. 9. 22. 사용자로부터 수습기간의 만료 및 수습평가 결과 본채용이 부적절하다고 판단된다는 이유로 한 본채용 거부통지를 받고, 이에 이의를 한 징계위원회에서도 역시 본채용 거부 의결 통지를 받은 자이다. 사용자 ○○○○코리아 유한회사(이하 ‘이 사건 사용자’ 또는 ‘이 사건 회사’라 한다)는 상시 약 80명의 근로자를 사용하여 식품 및 건강기능식품의 도·소매, 수입 및 다단계판매업 등을 영위하는 법인으로, 본사는 미합중국에 있다. 이 사건 근로자는 이 사건 사용자가 2017. 9. 25. 행한 해고가 부당하다며 2017. 11. 22. 서울지노위에 구제를 신청하였다. <심급별 결과> [서울지노위] 2018. 3. 15. ‘이 사건 본채용 거부’는 해고에 해당하고, 원고 회사(사용자)가 주장하는 해고사유는 사회통념상 고용관계를 계속할 수 없을 정도로 참가인(근로자)에게 책임 있는

67) 1심 : 선임 안 함 / 2심 : 개인변호사 / 3심 : 개인변호사

68) 1심 : 법무법인(유한) 광장 / 2심 : 법무법인(유한) 광장 / 3심 : 법무법인(유한) 광장

사유가 아니다'라는 이유로 참가인(근로자)의 신청 인용
[중노위] 위 초심판정과 같은 이유로 원고(근로자)의 재심신청 기각

[1심 법원] ① 이 사건 근로자와 사용자의 근로계약은 시용계약이고, ② 시용기간 만료시 본계약의 체결을 거부하는 것은 사용자에게 유보된 해약권의 행사로서, 당해 근로자의 업무능력, 자질, 인품, 성실성 등 업무적격성을 관찰·판단하려는 시용제도의 취지·목적에 비추어 볼 때 보통의 해고보다는 넓게 인정되나 이 경우에도 객관적으로 합리적인 이유가 존재하여 사회통념상 상당하다고 인정되어야 한다는 점을 고려하더라도 이 사건 본계약 체결 거부는 정당하다고 판단

[2심 법원] 1심법원의 판결과 같은 판결
[대법원] 원심법원의 판결을 그대로 인정

판결 요지

가. 이 사건 근로관계가 시용근로관계에 해당하는지 여부

처분문서 성립의 진정함이 인정되는 이상, 법원은 그 기재 내용을 부인할 만한 분명하고도 수긍할 수 있는 반증이 없는 한 그 처분문서에 기재되어 있는 문언대로의 의사표시의 존재 및 내용을 진정하여야 한다(대법원 2002. 6. 11. 선고 2002다6753 판결 등 참조).

근로자는 '수습기간' 등이 명시되어 있는 근로계약서를 작성하였고, 근로자가 사용자에게 보낸 메일 등으로 살펴보면 근로자 스스로 이 사건 근로관계가 시용근로관계에 해당한다는 점을 알고 있었으며, 기타 다른 근로자의 주장에 의하더라도 처분문서에 기재된 내용을 부인하기 위한 분명하고도 수긍할 수 있는 반증이 없으므로 이 사건 근로관계는 처분문서의 내용대로 시용근로관계에 해당한다.

나. 이 사건 본채용 거부가 정당한지 여부

시용기간 중에 있는 근로자를 해고하거나 시용기간 만료시 본계약의 체결을 거부하는 것은 사용자에게 유보된 해약권의 행사로서, 당해 근로자의 업무능력, 자질, 인품, 성실성 등 업무적격성을 관찰·판단하려는 시용제도의 취지·목적에 비추어 볼 때 보통의 해고보다는 넓게 인정되나, 이 경우에도 객관적으로 합리적인 이유가 존재하여 사회통념상 상당하다고 인정되어야 한다(대법원 2006. 2. 24. 선고 2002다62432 판결 등 참조).

사용자는 ① 출근기록의무 6회 불이행, ② 사전보고 없는 지각, ③ 업무관련성 없는 대리운전 서비스 7회 이용, ④ 퇴직연금 제도에 관한 충분한 조사없이 행한 보고로 본채용을 거부하였는데, 시용제도의 취지·목적에 비추어 가장 큰 사유로 고려되어야 할 것은 업무능력, 자질, 성실성과 관련된 ④항목이고, 근로자는 고액 연봉을 받으면서 부서상 직책을 수행하고 있는 자였으므로, 자신이 부서장으로 있는 부서의 주요 현안을 정확히 검토하여 회사의 의사결정과정에 참여하여 할 의무를 부담함에도 불확실한 보고를 함으로써 회사에 손해를 끼치게 될 위험을 발생시켰으므로 이를 이유로 본계약 체결 거부는 정당하다.

따라서 이와 다른 전제에서 이루어진 이 사건 재심판정은 위법하여 취소되어야 한다.

패소 이유 (사실관계에 관한 인정 차이)

이 사건은 근로자와 사용자가 작성한 근로계약서의 해석에 관한 문제이다.

노동위원회와 법원 양자 모두 처분문서의 해석에 대한 기본 논리를 가지고 판단하였고, 본계약이라고 볼만한 사정, 시용계약이라고 볼만한 사정 중 어느 부분에 강점을 두어 해석하였는지 여

부에 따라 판단의 방향이 결정되었다고 판단된다.

노동위원회는 다음과 같은 점을 근거로 이 사건 근로계약은 채용이 확정된 본계약이라고 판단하였다.

① 취업규칙 제7조는 “근로계약서를 작성하면 채용이 확정된다.”라고 규정하고 있는 점, ② 취업규칙 제45조는 수습기간 중 급여의 80%를 지급하도록 규정하고 있으나, 근로자는 급여의 100%를 지급받았다는 점

법원은 다음과 같은 점을 근거로 이 사건 근로계약은 시용계약이라고 판단하였다.

① 처분문서인 근로계약서의 기재(이 사건 근로관계의 수습기간은 고용개시일로부터 3개월까지이고, 원고 회사가 참가인의 채용이 부적합하다고 판단할 경우에는 재량에 따라 사전예고 없이 사직을 권할 수 있으며, 이에 응하지 않을 경우 징계 조치를 할 수 있다는 취지의 기재), ② 근로자가 사용자에게 보낸 메일(취지는 ‘근로자의 수습기간이 2017. 9. 26. 만료되고, 첨부파일 기재 평가표에 의하여 근로자에 대한 수습평가가 이루어져야 한다’ 즉, 근로자 스스로 ‘이 사건 근로관계가 시용근로관계에 해당한다’는 전제에서 업무를 처리하였다고 판단할 수 있음) 등으로 살펴보면 근로자 스스로 이 사건 근로관계가 시용근로관계에 대항한다는 점을 알고 있었다고 판단되는 점

한편, 법원은 노동위원회의 판단처럼 해석될 가능성이 존재하기는 하나, 처분문서에 기재된 내용을 부인하기 위해서는 분명하고도 수긍할 수 있는 반증이 있어야 할 것인데 이러한 반증이 없다고 판단하였다.

이 사건은 행정심판과 사법소송 단계에서 특별히 새롭게 제시된 증거나 사실관계는 없었으나 제시된 사실관계를 조사하는 등의 시간적 한계, 동일한 사실관계를 해석하는 관점의 차이 등으로 결과가 바뀌게 된 것으로 판단된다. 또한 법원에서 인정된 사실관계에 따르면 근로자는 취업규칙 등 사규 위반이 종종 있었는데, 노동위원회를 이것이 해고에 이르는 정도까지의 문제는 아니라고 판단하였으나 법원은 업무능력, 자질, 인품, 성실성 등 업무적격성을 의심할만한 사유라고 보았고, 이것이 불과 3개월의 시용기간 중에 발생하였다는 점을 주요한 판단요소로 고려한 것으로 보인다.

결과론적으로 처분문서인 이 사건 근로계약서의 해석을 어떤 관점에서 해석하느냐가 사건의 결과를 좌우하였다고 판단한다. 한편, 이 사건은 초심, 재심 노동위원회, 사실심인 1심 판결과 2심 판결이 모두 동일한 법적 기준을 인정하되 사실관계의 해석만을 달리한 사건이고, 그 결과 법원이 노동위원회의 결정을 정반대로 뒤집는 결론을 내린 사건임에도 중노위가 상고한 것은 무리한 절차진행으로 사료된다.

일련번호	2021-3
판결번호	대법원 2020. 12. 30. 선고 2020두00000
중노위판정번호	중노위 2019. 7. 3. 중양2019부해516
사건 종류	부당해고
세부 쟁점	(시용, 인턴) 본채용 거부의 정당성

심급별 소송결과	1심 법원	재심판정취소	2심 법원	1심판결 유지	대법원	원심판결 유지
상 고 인	중앙노동위원회위원장		참 가 인		김○○69)	
피상고인	○○○○공사		피고측 대리인 선임 여부		선임 안 함	
노동조합 지원 여부	없음		원고측 대리인 선임 여부		선임70)	
재심 결과	초심유지					
초심의 대법원 판례 일치여부	불일치		재심의 대법원 판례 일치여부		불일치	
기타 특이사항	대법원 심리불속행 기각					

주요 사실관계 <사실관계> 근로자 김○○(이하 ‘이 사건 근로자’라 한다)은 2018. 9. 17. ○○○○에 입사하여 ‘도로관리원’으로 근무하던 중 2019. 1. 27. 자로 부당하게 해고되었다고 주장하는 사람이다. 사용자 ○○○○공사(이하 ‘이 사건 사용자’ 또는 ‘이 사건 회사’라 한다)는 1969. 1. 17. ○○ ○○공사법에 따라 설립되어 상시 5,900여 명의 근로자를 사용하여 고속국도의 신설·개축·유지 및 수선에 관한 공사의 시행과 관리, 그 밖에 이와 관련된 사업을 시행하는 공기업이다. 이 사건 사용자는 2019. 1. 24. 인사위원회를 개최하여 근로자에 대하여 ‘계약종료’를 의결하였고, 2019. 1. 25. 근로자에게 근무평정 결과를 이유로 ‘2019. 1. 27.자 근로계약 종료’를 통보하였다. 이 사건 근로자는 2019. 1. 30. 경기지노위에 ‘이 사건 본채용 거부가 부당하다’고 주장하면서 구제신청을 하였다. <심급별 결과> [경기지노위] ‘본채용 여부를 결정하기 위한 근무평정이 객관적으로 공정하게 이루어졌다고 보이지 않아 이 사건 본채용 거부는 부당하다’는 이유로 구제신청 인용 [중노위] 초심판정과 동일한 이유로 이 사건 사용자의 재심신청 기각 [1심 법원] 이 사건 사용자의 이 사건 근로자에 대한 최초평정과 재평정 결과가 객관성이나 공정성을 잃었다고 보기 어렵고, 이 사건 사용자가 이러한 평정결과를 이유로 이 사건 근로자에 대한 본채용을 거절한 것은 합리적 이유가 있으며 사회통념상 상당하다고 인정된다고 판시 [2심 법원] 1심법원의 판결과 같은 판결 [대법원] 원심법원의 판결을 그대로 인정
--

69) 1심, 2심 : 소송구조 / 3심 : 선임 안 함

70) 1심 : 법무법인 나라, 개인변호사 공동대리 / 2심, 3심 : 법무법인 안심, 개인변호사 공동대리 (* 1심과 상급심의 사용자측 소송대리인 법무법인이 변경되었으나 담당 변호사 이름은 동일한 것으로 보아 담당변호사의 소속 변경에 따른 소송대리인 법인의 변화로 보이고, 1,2,3심 모두 실질 담당한 변호사는 동일한 것으로 추측됨)

판결 요지

가. 이 사건 본채용 거절에 합리적 이유가 있는지 여부

시용기간 중에 있는 근로자를 해고하거나 시용기간 만료시 본계약의 체결을 거부하는 것은 사용자에게 유보된 해약권의 행사로서, 당해 근로자의 업무능력, 자질, 인품, 성실성 등 업무적격성을 관찰·판단하려는 시용제도의 취지·목적에 비추어 볼 때 보통의 해고보다는 넓게 인정되나, 이 경우에도 객관적으로 합리적인 이유가 존재하여 사회통념상 상당하다고 인정되어야 한다(대법원 1994. 1. 11. 선고 92다44695판결, 대법원 2015. 11. 27. 선고 2015두48136 판결 등 참조).

① 사용자 회사의 인턴제도 운영취지, ② 평정방법 및 평정 요소의 객관성·공정성, ③ 업무 관계인들의 의견, ④ 근로자와 사용자의 면담과 재평정 상황, ⑤ 이 사건 근로자와 갈등이 있었다는 다른 근로자와의 분쟁에 대한 사용자의 조치 상황 등을 종합하여 보면 사용자가 근로자에 대한 본채용을 거절한 것은 합리적 이유가 있고, 사회통념상 상당한 것으로 보인다.

나. 그렇기 때문에 본채용 거부가 부당하다는 전제에서 내려진 중노위의 재심판정은 위법하다.

패소 이유 (사실관계에 관한 인정 차이)

이 사건 근로자는 사용자의 본채용 거부 근거는 형식적으로 인사평정이지만 실질적으로는 근로자 개인간 갈등 혹은 이 사건 근로자의 공익신고이므로 이 사건 본채용 거부가 정당하지 않다고 주장하였고, 노동위원회는 이에 대해 근로자의 주장을 인정하였다.

여기에 대해 사용자는 소송을 수행하면서 이 사건 근로자와 같이 근무했던 다른 근로자를 증인으로 신청하여 근로자의 주장과는 반대되는 증언을 이끌어내었고, 법원은 ① 이 사건 근로자가 정당한 업무상황에 대하여도 문제제기가 잦았다는 점, ② 이 사건 근로자의 문제제기는 통상적인 수준을 넘어 동료 작업원, 운전원 등을 위축시키는 정도에 이르렀던 점, ③ 이 사건 근로자가 주장하는 ‘공익신고’는 공익신고자 보호법상 공익신고가 아니라는 점(이 사건 근로자가 갈등이 있는 다른 근로자가 불리한 인사처분을 받게 할 목적으로 신고를 한 것으로 공익신고자 보호법 제2조 제2호 나목의 ‘그 밖에 부정한 목적으로 공익신고를 한 경우’에 해당한다고 판시함)을 근거로 이 사건 재심판정이 위법하다고 결론내렸다.

행정심판과 사법소송 단계에서 특별히 새롭게 제시된 증거나 사실관계는 없었으나 제시된 사실관계를 조사하는 등의 시간적 한계, 동일한 사실관계를 해석하는 관점의 차이 등으로 결과가 바뀌게 된 것으로 판단된다.

이 사건에서 중노위는 시용계약에서의 본채용 거절의 합리적 사유를 상대적으로 엄격하게 보았고, 법원은 상대적으로 완화된 입장에서 판단한 것으로 보인다.

한편, 이 사건은 초심, 재심 노동위원회, 사실심인 1심 판결과 2심 판결이 모두 동일한 법적 기준을 인정하되 사실관계의 해석만을 달리한 사건이고, 그 결과 노동위원회의 결정을 법원이 정반대로 뒤집는 결론을 내린 사건임에도 중노위가 상고한 것은 무리한 절차진행으로 사료된다.

일련번호	2021-7					
판결번호	서울행정법원 2020. 12. 17. 선고 2019구합00000 판결					
중노위판정번호	중노위 2019. 8. 30. 중앙2019부해792					
사건 종류	부당노동행위					
세부 쟁점	단체교섭 거부, 해태					
심급별 소송결과	1심 법원	청구 기각	2심 법원		대법원	
원 고	○○○		참 가 인		전국민주연합노동조합	
피 고	중앙노동위원회위원장		피고측 대리인 선임 여부		선임	
노동조합 지원 여부	있음		원고측 대리인 선임 여부		선임	
재심 결과	초심 유지					
초심의 대법원 판례 일치여부	불일치		재심의 대법원 판례 일치여부		불일치	
기타 특이사항						

주요 사실관계 <사건 개요> 가. 피고보조참가인인 전국민주연합노동조합(이하 '참가인')은 그 산하에 'D 지부'를 두고 있다. 나. 참가인은 '2017년도 임금 및 단체협약 체결'을 위해 원고에게 2017. 3. 23. 교섭요구를 하였고, 2017. 6. 15. 교섭대표노동조합 통보와 함께 교섭요구를 하였다. 이에 원고와 참가인은 2017. 7. 16.부터 2017. 11. 24.까지 6회에 걸쳐 교섭을 진행하였으나 합의에 이르지 못하였다. 다. 참가인은 2017. 11. 6. 서울지방법노동위원회에 부당노동행위 구제신청을 하였고, 2018. 1. 11. 화해가 성립되었다. 라. 원고와 참가인은 앞선 6회에 걸친 교섭에 이어 2018. 1. 19.부터 2018. 5. 11.까지 9회에 걸쳐 교섭하였고, 2018. 6. 8.부터 2018. 11. 9.까지 2주에 1회 정도의 빈도로 총 11회 교섭하였는데, 2018. 7. 6.자 교섭에서 '2017년 임금은 회사가 기 인상한 인상분 이외에는 동결하는 것으로 한다'는 내용으로 합의서를 작성하였다. 마. 참가인 외 1명은 U(원고 대표이사)을 구 노동조합법위반 혐의로 고소하였고, 서울동부지방법 검찰 검사는 2020. 8. 25. U에 대하여 혐의없음(증거불충분)처분을 하였다. 바. 참가인은 서울지방법노동위원회에 부당노동행위 구제신청을 하였다. <심급별 결과> [서울지노위] 취업규칙 변경절차를 진행한 행위와, 수정안을 제시하지 않고 단협 요구안을 수용하지 않은 행위에 대하여 단체교섭 거부의 부당노동행위를 인정하고 구제명령을 내림
--

[중노위] 취업규칙 변경절차를 진행한 행위에 대한 부당노동행위 성립을 부인하는 초심 일부 취소 판정

[1심 법원] 단체교섭 거부의 합리적 이유가 있었음을 인정하여 재심판정 취소

판결 요지

단체교섭에 대한 사용자의 거부나 해태에 정당한 이유가 있는지 여부는 노동조합측의 교섭권자, 노동조합 측이 요구하는 교섭시간, 교섭장소 및 그의 교섭태도 등을 종합하여 사회통념상 사용자에게 단체교섭의무의 이행을 기대하는 것이 어렵다고 인정되는지 여부에 따라 판단하여야 할 것이다(대법원 2010. 4. 29. 선고 2007두11542 판결 등 참조).

원고가 2018. 1. 19.부터 2018. 5. 11.까지 단체교섭을 정당한 이유 없이 해태하였다고 볼 수 없다. 따라서 이와 다른 전제에서 이루어진 이 사건 재심판정은 위법하여 취소되어야 한다.

① 원고와 참가인은 2018. 1. 11. 단체교섭 실시 관련 합의(화해)를 하였는데, 그 요지는 '각자 교섭위원을 5명 뽑아 2018. 1. 19.부터 대전역 인근 회의실에서 격주 1회의 빈도로 15:00부터 21:00까지 교섭한다'는 것이었다. 원고와 참가인은 2018. 1. 19.부터 2018. 5. 11.까지 사이에 총 9회 교섭하였는데, 교섭주기 · 장소 · 시간 및 교섭위원의 숫자 등이 모두 위 합의의 내용에 거의 부합한다.

② 원고 측은 2018. 1. 19.부터 2018. 5. 11.까지 사이에 개최된 아홉 차례의 단체교섭에 모두 참석하였고, 교섭위원도 대부분 전부 출석하였다(그에 반해 참가인 측은 교섭위원이 교체되거나 출석하지 아니하는 일이 잦았다).

③ 원고 측은 교섭장소 섭외 역할을 맡았는데, 참가인 측이 '장소확정이 늦다'며 이의제기를 한 적이 있기는 하지만, 교섭장소로 인해 단체교섭에 지장이 생긴 적은 없었다.

④ 2018. 1. 19.부터 2018. 5. 11.까지 사이에 개최된 단체교섭의 내용을 전체적으로 보면, 원고와 참가인 사이에 감정적인 다툼이 있기도 하였고, 참가인이 원고에게 한 자료 제공 요구가 모두 받아들여진 것도 아니었다. 그러나 감정적인 다툼이 심각한 수준에 이르렀다거나, 해당 다툼의 원인이 오로지 원고 측에 있다거나, 원고가 참가인의 자료 제공 요구를 모두 거부하였던 것도 아니었다. 이상의 사정들이 '원고가 교섭을 해태하였다'는 결론에 이르게 하지는 못한다.

⑤ 원고 측이 위 기간에 단체교섭에서 보인 태도를 전체적으로 보면, 참가인이 제시한 안을 받아들인다거나, 참가인이 제시한 안을 보고 한 발 물러나 양보한 적이 없다고 보아지는 한다. 그러나 위 기간은 4개월에조차 미치지 못하는 짧은 기간이었다. 참가인이 교섭대표노동조합 통보와 함께 교섭요구를 하였던 것은 2017. 6. 15.이고, 최초로 교섭이 시작된 것은 2017. 7. 16.이었으며, 최초 교섭일부터 2018. 1. 11.자 합의가 이루어지기까지는 노동위원회의 조정, 원고와 참가인 사이의 크고 작은 갈등 등 여러 일들이 있었다. 더구나 원고와 참가인은 이번에 최초로 단체교섭을 하게 된 것이었다. 참가인이 제시한 단체협약안은 본문 79개조, 부칙 7개조로 이루어져 양이 적지 않은데다 양자의 입장은 작은 부분 하나하나에서부터 첨예하게 대립하였고, 종전에 단체교섭을 하였던적이 없어 구체화된 단체교섭방식이 확립되어 있지 아니한 상황이었다. 이러한 사정들을 보면, '원고 측이 자신의 안을 완강하게 고집하는 모습을 보였다'는 것만으로 '교섭을 해태하였다'고 단정하기는 어렵다. 더구나 원고는 그로부터 불과 두 달 가량 지난 2018. 7. 6. 참가인과 사이에 '2017년 임금은 회사가 기 인상한 인상분 이외에는 동결하는 것으로 한다'는 내용으로 합의를 한 바 있고, 원고 대표이사는 2020. 8. 25. 구 노동조합법위반 혐의에 관하여 혐의없음(증거불충분)처분을 받은 바 있다.

⑥ 참가인은 원고가 2018. 1. 2. 취업규칙을 변경하였다거나, 원고 측이 교섭 중 지난 교섭에서 하였던 말을 반복하였다는 점도 문제 삼고 있으나, 이러한 사정들만으로 앞서 내린 판단을 달리하기는 어렵다.

패소 이유 (동일한 사실관계에 관하여 기존 대법원 판례 법리와 다른 결론)

단체교섭 거부의 합리적인 이유가 있다고 볼 수 있는지 여부가 쟁점이 된 사안이다. 단체교섭 거부의 부당노동행위는 주관적인 부당노동행위 의사를 요구하지 않고 객관적인 행위의 존재만으로 부당노동행위의 성립을 인정하기 때문에, 사실관계의 확인과 판단이 매우 중요한 부당노동행위 요소라고 할 수 있다.

사안에서 법원이 제시한 판단요소들을 보면, 그 동안 대법원이 일관되게 유지해왔던 단체교섭 거부의 합리적인 이유들이 두루 불건된다. 따라서 노동위원회의 사실관계 판단에 미흡함이 있었다고 볼 수 있다. 이는 역시 공익위원의 전문성 부족의 문제로 귀결된다. 다만, 노동위원회가 항소하지 않고 사건을 종결한 것은 합리적인 판단이었다고 평가할 수 있다.

일련번호	2021-8					
판결번호	대법원 2021. 2. 4. 선고 2020두00000					
중노위판정번호	중노위 2019. 4. 29. 중앙2019부해238, 241 병합					
사건 종류	부당해고					
세부 쟁점	아파트 입주자 대표회의가 사용자인지 여부, 갱신기대권					
심급별 소송결과	1심 법원	재심판정취소	2심 법원	1심판결 유지	대법원	원심판결 유지
상 고 인	중앙노동위원회위원장		참 가 인		배○○ ⁷¹⁾	
피상고인	주식회사 ○○○○		피고측 대리인 선임 여부		선임 안 함	
노동조합 지원 여부	없음		원고측 대리인 선임 여부		선임 ⁷²⁾	
재심 결과	초심유지					
초심의 대법원 판례 일치여부	불일치		재심의 대법원 판례 일치여부		불일치	
기타 특이사항	대법원 심리불속행 기각					

주요 사실관계

<사실관계>

근로자 배○○(이하 ‘이 사건 근로자’라 한다)는 2016. 8. 9.부터 경기 ○○시에 있는 ◇◇마을 7단지 ○○○○ 아파트(이하 ‘이 사건 아파트’라 한다)에서 기전반장으로 근무하던 중 2018. 9. 1. 부당하게 근로관계가 종료되었다고 주장하는 사람이다.

71) 1심, 2심, 3심 : 선임 안 함

72) 1심, 2심, 3심 : 개인변호사

◇◇마을 7단지 ○○○○ 아파트 입주자대표회의(이하 ‘이 사건 입주자대표회의’라 한다)는 이 사건 아파트의 입주자, 사용자(이하 ‘입주자 등’)를 대표하여 관리에 관한 주요사항을 결정하기 위해 구성된 자치 의결기구이고, 주식회사 ○○○○은 사업시설 유지관리 서비스업을 영위하는 법인이다.

이 사건 입주자대표회의는 2015. 7. 2. □□종합관리 주식회사(이하 ‘□□종합관리’라 한다)와 사이에 ‘이 사건 입주자대표회의가 □□종합관리에게 이 사건 아파트의 관리를 2015. 7. 1.부터 2018. 6. 30까지 위탁하는 내용의 계약’을 체결하였는데, 계약 내용 중에는 ‘관리주체가 변경되거나 계약이 만료되는 경우, 관리사무소에 근무하는 □□종합관리의 직원은 공동주택관리업무의 계속성 등을 위하여 이 사건 입주자대표회의가 새로운 관리주체에게 그 고용을 승계할 수 있다’는 내용이 포함되었다. 또한 이 사건 입주자대표회의는 2018. 6. 28. 주식회사 ○○개발 사이에, ‘이 사건 입주자대표회의가 주식회사 ○○개발에게 이 사건 아파트의 관리를 2018. 7. 1.부터 2021. 6. 30.까지 위탁하는 내용의 계약(이하 ‘이 사건 위탁관리계약’)을 체결하였다.

이후 주식회사 ○○○○은 2018. 6. 13. 이 사건 아파트 관리사무소에서 근무하던 직원 15명에 대하여 면접을 실시하였고, 근로자 배○○와 2018. 8. 31.까지 근무하기로 하는 계약을 체결하였으며, 이후 2018. 8. 30. 근로자 배○○에게 ‘근로계약이 2018. 8. 31.부로 만료(종료)됨을 알려드립니다’라는 내용의 통보서를 교부하였다. 결국 근로자 배○○는 2018. 11. 27. 경기도노위에 ‘주식회사 ○○○○, 이 사건 입주자대표회의가 근로자 배○○를 2018. 9. 1. 부당해고하였다’면서 구제신청을 하였다.

<심급별 결과>

[경기도지노위] ‘이 사건 입주자대표회의는 근로자 배○○의 사용자가 아니므로 당사자 적격이 없다’, ‘주식회사 ○○○○은 근로자 배○○의 사용자이다’, ‘주식회사 ○○○○이 갱신기대권을 갖고 있는 근로자 배○○에 대하여 합리적 이유 없이 근로계약의 갱신을 거절하고 근로관계를 종료한 것은 부당하다’는 취지의 이유를 들어 주식회사 ○○○○을 상대로 한 구제신청을 인용 [중노위] 초심판정과 동일한 이유로 이 사건 사용자의 재심신청 기각. 초심 유지

[1심 법원] 갱신기대권 부정

[2심 법원] 1심법원의 판결과 같은 판결

[대법원] 원심법원의 판결을 그대로 인정

판결 요지

가. 이 사건 입주자대표회의가 사용자인지 여부

아파트 입주자대표회의와 사이에 위수탁관리계약을 체결한 아파트 관리업자의 대리인인 관리소장이 관리사무소에서 근무하게 된 직원들과 근로계약을 체결하였다면 그 직원들은 아파트 관리업자의 피용인이라고 할 것이다. 아파트 관리업자와 위수탁관리계약을 체결하였을 뿐인 아파트 입주자대표회의가 직원들에 대하여 임금지급의무가 있는 사용자로 인정되기 위하여는, 그 직원들이 관리사무소장을 상대방으로 하여 체결한 근로계약이 형식적이고 명목적인 것에 지나지 않고, 직원들이 사실상 입주자 대표회의와 종속적인 관계에서 그에게 근로를 제공하며, 입주자대표회의는 그 대가로 임금을 지급하는 사정 등이 존재하여 관리사무소 직원들과 입주자대표회의와 사이에 적어도 묵시적인 근로계약관계가 성립되어 있다고 평가되어야 한다(대법원 1999. 7. 12.자 99마628 결정 등 참조).

① 이 사건 입주자대표회의는 이 사건 아파트에 관하여 주식회사 ○○○○과 사이에 이 사건 위탁관리계약을 체결하였고, 이후 이 사건 근로자의 채용이나 근로계약 종료에 관여하였다는 객관적인 사정이 없다는 점.

② 이 사건 위탁관리계약에서 정한 직원인사·노무관리권한 보유주체는 주식회사 ○○○○이라는 점.

③ 또한 이 사건 입주자대표회의가 주식회사 ○○○○에게 관리비 등의 부과, 징수 외에 이 사건 아파트의 관리에 필요한 비용의 지출도 위탁하였다는 점을 보면 근로자들의 임금 및 퇴직금이 이 사건 입주자대표회의 계좌에서 지급되고, 고용보험 등 4대 보험도 이 사건 입주자대표회의 명의로 가입되어 있다는 점만으로는 이 사건 근로자와 이 사건 입주자대표회의와의 사이에 근로관계가 성립되었다고 볼 수는 없다.

나. 이 사건 근로자에게 갱신기대권이 인정되는지 여부

① 근로계약, 취업규칙, 단체협약 등에 ‘기간만료에도 일정한 요건이 충족되면 당해 근로계약이 갱신된다’는 취지의 내용이 존재하지 않는 점, ② 이 사건 근로자가 □□종합관리와 두 차례에 걸쳐 근로계약을 갱신한 뒤 주식회사 ○○○○과의 사이에 근로계약을 체결하였으나 두 회사는 다른 회사이므로 □□종합관리에서 있었던 근로계약 갱신의 전례가 주식회사 ○○○○ 사이에서 ‘근로계약이 갱신된다는 신뢰관계’를 형성하게 하지는 않는 점,

③ 비록 ‘이 사건 근로자가 주식회사 ○○○○과 근로계약을 체결하면서 □□종합관리에서 일하던 기간에 상응하는 퇴직금을 정산하지 아니한 점’, ‘이 사건 근로자는 주식회사 ○○○○과 근로계약을 체결한 이후에도 종건과 같은 근무지에서 같은 업무를 수행한 것으로 보이는 점’은 특별한 사정으로 보이기는 하나 ㉔ 주식회사 ○○○○과 이 사건 근로자 사이에 체결된 근로계약에서 정한 근로계약기간이 2개월에 불과한 점, ㉕ 이 사건 근로자와 □□종합관리 사이의 근로계약 갱신은 별도의 심사절차 없이 이루어졌지만, 이 사건 근로자와 주식회사 ○○○○ 사이의 근로계약 체결은 면접 절차 등을 거쳐 이루어졌고, 이 사건 근로자외의 직원들 중에는 위 면접절차에서 탈락한 자들이 여럿 있을 정도로 주식회사 ○○○○의 면접절차는 실제 의미를 갖고 있었던 점에 비추어보면 근로계약이 갱신된다는 신뢰관계를 인정하기는 어렵다.

다. 사용자의 근로계약 갱신 거절에 합리적 이유가 있는지 여부

이 사건 근로자가 근로기간 동안 보인 근무태도에 비추어 보면 근로계약의 갱신을 거부할 합리적인 이유가 있고, 이 사건 근로자의 근무태도와 관련하여 □□종합관리나 주식회사 ○○○○로부터 징계를 받은 적이 없다고 하더라도 달리 보기 어렵다.

라. 그렇기 때문에 중노위의 재심판정은 위법하다.

패소 이유 (사실관계에 관한 인정 차이)

이 사건 근로자는 관리사무소에서 근무하는 직원으로서 소속이 □□종합관리 주식회사에서 ○○○○로 변경되며 같은 아파트 관리사무소에서 근무하였다.

다만 이 사건 근로자의 소속이 변경될 당시 주식회사 ○○○○은 기존에 일하던 직원 15명을 그대로 승계한 것이 아니고, 별도의 면접절차를 거쳤으며, 그 중에서 9명을 제외하고 6명만을 채용하였다.

결국 위와 같은 사실관계에 대해 노동위원회와 법원의 판단이 달랐기 때문에 결론이 달라진 사건이다.

즉, 노동위원회는 위 사실관계의 해석에 있어 기존 사용자와 새로운 사용자의 근로계약을 연속성이 있다고 보고 이미 기존 사용자와 2차례 근로계약을 갱신했던 사정을 고려하여 근로계약 갱

부록.1. 주요 사건 경과 및 패소 원인 분석

신의 기대권이 있다고 판단하였고, 법원은 두 사용자의 연속성을 부인하고 새로운 사용자와는 갱신기대권이 인정되지 않는다고 보았다.

한편, 이 사건은 초심, 재심 노동위원회, 사실심인 1심 판결과 2심 판결이 모두 동일한 법적 기준을 인정하되 사실관계의 해석만을 달리한 사건이고, 그 결과 노동위원회의 결정을 법원이 정반대로 뒤집는 결론을 내린 사건임에도 중노위가 상고⁷³⁾한 것은 무리한 절차진행으로 사료된다.

일련번호	2021-9					
판결번호	서울고등법원 2021. 1. 13. 선고 2020누00000 판결					
중노위판정번호	중노위 2019. 8. 16. 중양2019부노114					
사건 종류	부당노동행위					
세부 쟁점	불이익 취급, 인사평가, 성과급, 차별					
심급별 소송결과	1심 법원	재심판정취소	2심 법원	1심 유지	대법원	
항 소 인	중앙노동위원회위원장		참 가 인		박○○	
피항소인	○○○코리아(주)		피고측 대리인 선임 여부		선임 안 함	
노동조합 지원 여부	있음		원고측 대리인 선임 여부		선임 함	
재심 결과	초심취소					
초심의 대법원 판례 일치여부	불일치		재심의 대법원 판례 일치여부		불일치	
기타 특이사항						

주요 사실관계

<사건 개요>

가. 원고 ○○○코리아(주)는 화학제품(플라스틱첨가제) 제조업을 영위하는 법인이다. 피고보조참가인(이하 '참가인')은 2001. 10. 4. 원고에 입사한 기능직 근로자이다. 참가인은 2018년 당시 제조1부 분체공장에서 근무하였다.

나. 참가인은 D노동조합(이하 '이 사건 노동조합') E 지회의 지회장이다. 원고에는 이 사건 노동조합 외에도 'F 노동조합'이 존재한다. 이 사건 노동조합 E 지회의 조합원은 10여 명이고, F 노동조합의 조합원은 110여 명이다.

다. 원고는 단체협약에 따라 근로자에게 임금의 일종으로 '상여금'을 지급하는데, 기능직 근로자에게 연간 월 고정급의 750%에 해당하는 금액이 지급되었다. 위 비율은 기능직 근로자 모두에게 동일하게 적용되었다. 원고는 취업규칙 제31조에 따라 근로자에게 '경영성과급'을 지급하기도

73) 2020. 10. 26. 중앙노동위원회 상고

하는데, 그 지급시기나 방법이 취업규칙, 단체협약에 명시되어 있지는 아니하다. '출근정지 이상의 징계를 받은 자', '최하의 평가등급을 받은 자'를 지급대상에서 제외한다는 내용만 취업규칙 제31조 단서에 명시되어 있을 뿐이다.

라. 원고의 2018년 근무평가 및 경영성과급 지급

① G 부장은 2018. 11. 9. 공장 근로자들에게 '전 직원을 대상으로 하여 2018년도 근무평가를 시행할 예정이다', '근무평가는 상급자가 "근무평가기준"을 참고하여 "근무평가표"에 따라 평가하는 방식으로 이루어진다'는 취지의 전자우편을 발송하였다.

② 원고는 2018. 11. 26.부터 2018. 12. 7.까지 참가인에 대한 근무평가를 시행하였고, 원고는 2018. 12. 21. 참가인에게 최하의 평가등급을 부여하였고, 2018년 경영성과급을 지급하지 아니하였다.

마. 참가인은 2019. 3. 18. 전북지방노동위원회에 '이 사건 경영성과급 미지급이 부당노동행위에 해당한다'면서 구제신청을 하였다.

마. 참가인의 근태 등

① 참가인은 2018년 한 해 동안 다음 표 기재와 같이 연차휴가를 사용하였는데, 그중 당일 또는 사후 신청과 관련하여 증빙서류가 제출된 것은 2018. 5. 17.자 연차휴가뿐이다

② 참가인은 2018. 1. 4. 전자결재 시스템을 이용하여 '2018. 1. 3.자 휴가'를 사후 신청하는 내용의 결재를 상신하였는데, 이에 관하여 상급자드른 사전 승인이나 증빙서류 제출을 요구하는 의견을 남겼다. 참가인은 연차휴가 당일에 '몸살로 휴가낼게요'라는 문자메시지를 원고 측 담당자에게 보낸 적도 여러 번 있는데, 이에 대하여 원고 측 담당자가 '증빙서류 제출하십시오'라는 답장을 보냈음에도, 참가인은 증빙자료를 제출하지 아니하였다. 기능직 사원 51명 중 참가인을 제외한 나머지 50명은 2018년 한 해 동안 연차휴가를 신청하기 위한 결재 상신을 357회 하였는데, 그중 사전 결재 상신을 한 경우는 332회이고, 당일 또는 사후 결재 상신을 한 경우는 25회이다. 참가인은 2018년 한 해 동안 연차휴가를 신청하기 위한 결재 상신을 20회 하였는데, 그중 사전 결재 상신을 한 경우는 3회(15%)이고, 당일 또는 사후 결재 상신을 한 경우는 17회(85%)이다.

③ 참가인은 2016년 한 해 동안 연차휴가를 신청하기 위한 30회의 연차휴가를 사용하였는데, 그중 사전 결재 상신을 한 경우는 6회(20%)이고, 당일 또는 사후 결재상신을 한 경우는 24회(80%)이다. 참가인은 2017년 26회의 연차휴가를 사용하였는데, 그중 사전 결재 상신을 한 경우는 4회(15.38%)이고, 당일 또는 사후 결재 상신을 한 경우는 22회(84.61%)이다.

바. 원고와 이 사건 노동조합 사이의 분쟁

① J 전무는 2012. 2. 15. 신입사원들을 대상으로 한 교육에서 지배개입의 부당노동행위에 해당하는 발언을 하였고, 전주지방법원은 2013. 7. 16. J 전무에 대하여 벌금 700만 원의 약식명령을 발령하였고, 위 약식명령은 정식재판청구 취하로 확정되었다.

② 참가인에 대한 1차 근무 평가자였던 H 대리는 ① 2016. 12. 20., ② 2017. 1. 5., ③ 2017. 5. 17. 지배개입의 부당노동행위에 해당하는 발언을 하였다.

③ 이 사건 노동조합 및 그 조합원은 2011년경부터 부당징계 및 부당노동행위 구제신청을 하거나, 부당노동행위 진정 · 고소 · 고발을 하거나, 민사소송을 제기하는 등 2020년에 들어서까지도 법률분쟁을 이어왔다.

<심급별 결과>

[전북지노위] 참가인의 구제신청을 기각

[중노위] 참가인의 구제신청 인용. 초심 취소

[1심 법원] 부당노동행위 성립 부인. 재심판정 취소

[2심 법원] 1심 판결 유지

판결 요지

가. 근로자에 대한 인사고과가 상여금의 지급기준이 되는 사업장에서, 사용자가 특정 노동조합의 조합원이라는 이유로 다른 노동조합의 조합원 또는 비조합원보다 불리하게 인사고과를 하여 상여금을 적게 지급하는 불이익을 주었다면, 그러한 사용자의 행위도 부당노동행위에 해당할 수 있다. 이 경우 사용자의 행위가 부당노동행위에 해당하는지 여부는, ① 특정 노동조합의 조합원 집단과 다른 노동조합의 조합원 또는 비조합원 집단을 전체적으로 비교하여 양 집단이 서로 동질의 균등한 근로자 집단임에도 불구하고 인사고과에 양 집단 사이에 통계적으로 유의미한 격차가 있었는지, ② 인사고과의 그러한 격차가 특정 노동조합의 조합원임을 이유로 불이익취급을 하려는 사용자의 반조합적 의사에 기인한다고 볼 수 있는 객관적인 사정이 있었는지, ③ 인사고과에서의 그러한 차별이 없었다면 동등한 수준의 상여금이 지급되었을 것은 아닌지 등을 심리하여 판단하여야 한다(대법원 2018. 12. 27. 선고 2017두37031 판결 등 참조).

나. 앞서 인정한 사실들 중 2016년부터 2018년까지의 근무평가 결과를 보면, 이 사건 노동조합의 조합원들이 다른 근로자들보다 평균적으로 더 낮은 근무평가를 받아왔다는 점을 알 수 있고, 원고와 이 사건 노동조합 사이의 분쟁 과정을 보면, 원고와 이 사건 노동조합 사이의 관계가 좋지 아니하다는 점을 알 수 있다. 이러한 사정들에, 이 사건 노동조합의 지회장인 참가인만 51명의 기능직 사원 중 유일하게 최하위 평가등급을 받아 경영성과급을 전혀 지급받지 못하게 된 것을 보면, 이러한 결과가 원고의 부당노동행위의 의사에 기인한 불이익취급의 부당노동행위로서 발생된 것이 아닌가 하는 의심이 들기는 한다.

다. 그러나 다음과 같은 사정에 비추어 보건대, 제출된 증거들만으로는 이러한 근무평가의 격차가 이 사건 노동조합의 조합원임을 이유로 불이익취급을 하려는 원고의 반조합적 의사에 기인한 것이었다고 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 만한 증거가 없다.

① 참가인의 2018년 연차휴가 사용에 관한 사항

단체협약 제30조 제6항, 제34조는 '연차유급휴가를 사용하고자 하는 자는 소정의 절차에 의하여 7일 이전에 이를 청구하여야 한다', '휴가를 얻고자 하는 조합원은 특별한 사정이 없는 한 휴가 개시 7일 전까지 회사에 휴가원을 제출하여야 한다'고 정하고 있고, 취업규칙 제50조 제6항도 '연차유급휴가를 사용하고자 하는 자는 소정의 절차에 의하여 7일 이전에 이를 청구하여야 한다'고 정하고 있다. 즉, 연차휴가를 사용함에 있어 당일 또는 사후 신청을 하는 행위는 단체협약, 취업규칙을 위반하는 행위인 것이다. 참가인의 상급자들은 참가인에게 여러 차례에 걸쳐 '연차휴가를 사전에 신청하라'는 취지의 지시를 하였다고 보이는데, 그럼에도 참가인의 행동에는 별다른 변화가 없었다.

근무평가가 낮아진 이유는 연차휴가를 사용하였기 때문이 아니라, 사전신청을 하지 아니한 데에 기인하는 것이며, 제조공정을 수행하는 공장에서 연차휴가를 당일 신청하거나 사후 신청하게 되면 사실상 무단결근을 한 것과 다를 바 없는 결과가 벌어지게 된다는 점을 고려해 보았을 때, 십여 차례의 당일 또는 사후 신청을 한 참가인이 신입사원이나 무단결근을 한 근로자보다 낮은 근무평가를 받은 것이 부당한 것이었다고 단정하기는 어렵다.

② 근무평가에 관한 사항

2018년 근무평가의 기준을 보면, 수치로 계량화할 수 있을 만한 객관적인 기준이 포함되지 아니하였음을 알 수 있기는 하다. 그러나 앞서 본 참가인의 연차휴가 사용 방식을 보면, 참가인은 단체협약, 취업규칙을 계속하여 어겨왔고, 이로 인해 업무에도 지장을 초래하기도 하였던 점을 알 수 있는바, 크게는 '근무태도' 및 '업무능력'을, 작게는 협조성, 규율성, 적극성, 책임감, 애사심, 업무지식, 업무수행능력, 판단이해력을 평가하는 근무평가에서 낮은 점수를 받는다는 것이 특별

히 이상하다고 보이지 아니한다. 특히 참가인이 개별 평가항목에서 받았던 구체적인 점수를 보면 보통 4~5점 정도에 머물렀음을 알 수 있는데, 근무평가의 중간 지점이 되는 점수가 6점이고, 최하점이 2점이었던 점을 고려해본다면, 이러한 평가가 자의적이었다거나, 반조합적 의사에 기인하였던 것이라고 단정하기는 어렵다. 원고와 이 사건 노동조합 사이의 관계가 좋지 아니하였다는 등의 앞서 본 사실관계 등을 모두 고려하더라도 마찬가지이다.

③ 최하위 근무평가를 받은 자에 대한 경영성과급 미지급

'최하위 근무평가를 받은 자에게 경영성과급을 지급하지 아니한다'는 취지의 내용은 취업규칙 제 31조에 명시되어 있다.

패소 이유 (사실관계에 관한 인정 차이)

이 사건은 사실관계는 동일하게 주장되었으나, 그에 관한 법리적 판단의 결과가 달라진 사건이다. 쟁점은 사용자의 부당노동행위 의사의 입증에 있었다고 할 수 있다.

정당한 징계 사유가 있는 경우 다소 부당노동행위 의사가 추정된다고 하더라도 부당노동행위 성립을 인정하지 않는 것이 대법원의 확립된 판례의 경향이라고 볼 수 있다. 즉, ② 적법한 해고 사유가 있는 경우에는 사용자가 조합활동을 못마땅하게 여긴 흔적이 있다고 하더라도 부당노동행위에 해당하지 않는 정당사유설에 가까운 태도를 보이고 있다(대법원 1994. 12. 23. 선고 94누3001 판결). 이러한 대법원의 태도를 인식하고 이었다면, 이 사건에서 청구인의 사규 위반과 근무태도 불량 등이 인사평거나 성과평가 결과에 반영되는 것이 정당하며, 부당노동행위 의사를 적극적으로 입증할 수 없다는 사실이 파악될 수 있었을 것으로 판단된다.

초심 지노위 판정을 보면 오히려 이러한 대법원 법리에 오히려 충실한 것을 알 수 있다. 그러나 중노위가 대법원 판례와 전혀 다른 판단을 내리고, 신청인의 근무태도 불량과 사규 위반 행위들을 고려하지 않은 채 부당노동행위 성립을 긍정하는 설부른 판단을 내리고 있다. 이는 중앙노동위원회 공익위원의 전문성이 오히려 지노위보다 낮았다는 것을 보여주는 매우 우려스러운 결과라 하지 않을 수 없다.

일련번호	2021-14					
판결번호	서울행정법원 2021. 1. 21. 2019구합00000 판결					
중노위판정번호	중노위 2019. 10. 24. 중앙2019부해1042					
사건 종류	부당해고					
세부 쟁점	기간제 근로자, 계속근로기간, 갱신기대권					
심급별 소송결과	1심 법원	재심판정취소	2심 법원		대법원	
원 고	○○시설공단		참 가 인		김○○	
피 고	중앙노동위원회위원장		피고측 대리인 선임 여부		선임 안 함	

부록.1. 주요 사건 경과 및 패소 원인 분석

노동조합 지원 여부	있음	원고측 대리인 선임 여부	선임 함
재심 결과	초심취소		
초심의 대법원 판례 일치여부	일치	재심의 대법원 판례 일치여부	불일치
기타 특이사항			

주요 사실관계

<사건 개요>

가. 원고는 공공시설물의 관리.운영과 국가, 지방자치단체 및 공공단체가 위탁하는 사업 등을 행하는 지방공기업에 따라 설립된 법인이다. 피고보조참가인(이하 '참가인')은 2016. 1. 1.부터 2019. 4. 28.까지(2019. 1. 1. 제외) 원고가 ○○광역시로부터 위탁받아 운영하는 '○○광역시 여성인력개발센터' 산하 '○○여성새로일하기센터'에서 근무한 사람이다.

① 원고는 2014. 2. 27. 이 사건 센터에서 근무할 직업상담원, 취업설계사, 보육교사의 채용공고를 한 후 공개채용 절차를 거쳐 같은 해 말까지를 계약기간으로 하여 채용한 이래, 매년 초 공개채용 절차를 거쳐 이 사건 센터의 전체 직원을 채용하되, 계약기간 중 퇴사 등으로 결원이 발생할 때는 수시로 채용하기도 하였다. 원고는 2015. 12. 4. 아래와 같이 이 사건 센터의 직업상담원, 취업설계사, 보육교사를 채용하기 위한 채용공고를 하였다

② 참가인은 이 사건 센터의 2015. 12. 4.자 채용공고의 취업설계사 모집에 지원하여 채용되었고, 그 후로도 2016. 12. 2.자 채용공고의 직업상담원 모집에, 2017. 12. 7.자 채용공고의 직업상담원 모집에, 2018. 12. 20.자 채용공고의 직업상담원 모집에 각 지원하여 채용되었다. 이에 따라 원고는 이 사건 센터에서 2016. 1. 1.부터 2017. 12. 31.까지는 취업설계사로, 2018. 1. 1.부터 2018. 12. 31.까지 및 2019. 1. 2.부터 2019. 4. 28.까지는 직업상담사로 각 근무하였다.

③ 원고는 2018년경부터 이 사건 센터의 직원들을 정규직으로 전환하는 방안을 검토하였고, 2018. 12. 20.경에는 2019년 이 사건 센터에서 근무할 직업상담원과 취업설계사를 채용하면서 정규직 전환계획의 미확정에 따라 1개월 정도만 근무할 인원을 채용할 것을 계획하였다. 원고는 2019. 1.경까지도 정규직 전환계획에 따른 채용이 완료되지 아니하자, 2019. 1. 2.자로 채용한 이 사건 센터의 직업상담원과 취업설계사의 계약기간을 2019. 4. 28.까지 약 1개월 단위로 연장하였다.

④ 원고는 2019. 3. 11. '○○시설공단 정규직 전환 공개채용 모집 공고'를 하였고, 위 채용공고에는 이 사건 센터의 정규직 직원의 채용이 포함되어 있다. 위 채용절차의 서류전형에서 직업상담사 지원자의 경우 7명이, 취업상담사 지원자의 경우 30명이 각 합격하였고, 필기시험 전형에서는 직업상담사 지원자의 경우 5명이, 취업상담사 지원자의 경우 18명이 각 합격하였으며, 면접시험 전형에서는 직업상담사 지원자의 경우 2명이, 취업상담사 지원자의 경우 6명이 각 합격하였다. 참가인은 2019. 4. 6. 위 채용공고에서 직업상담사 전형에 지원하여 필기시험에 응시하였으나 합격 기준점수인 60점에 미치지 못하는 57.5점을 취득하여 탈락하였다. 6) 2016년경부터 2019년경까지 이 사건 센터의 직업상담원과 취업설계사는 거의 같은 금액의 보수를 받았다. 또한, 직업상담사는 '집단상담프로그램 운영', '구인.구직 상담, 발굴', '취업연계 및 사후관리사업' 등의 업무를, 취업설계사는 '구인.구직 상담, 발굴', '취업알선(동행면접 등)', '직업교육훈련 운영', '취업연계 및 사후관리사업' 등의 업무를 각 담당하였다.

나. 원고는 참가인에게 2019. 4. 28.자로 계약관계가 만료됨을 통보(이하 '이 사건 통보')하였다.

다. 참가인은 2019. 5. 9. ○○지방노동위원회에 이 사건 통보에 관한 부당해고 구제신청을 하였다.

<심급별 결과>

[○○지노위] ‘원고와 참가인 사이에는 기간의 정함이 있는 근로계약이 체결된 것으로 볼 수 있고, 근로계약이 실질적인 공개채용 절차를 통해 매년 새롭게 체결되었기 때문에 참가인은 구 기간제법상 기간의 정함이 없는 근로자가 아니며, 참가인에게는 갱신기대권이 있다고 볼 수도 없다’는 이유로 참가인의 구제신청을 기각

[중노위] 참가인의 계속 근로기간이 2년을 초과하였고, 구 기간제법상 예외사유도 없기 때문에 참가인은 계속 근로기간이 2년이 초과한 시점에 사실상 기간의 정함이 없는 근로계약을 체결한 근로자로 전환되었다는 이유로 부당해고를 인정하여 구제신청을 인용. 초심 취소

[1심 법원] 부당노동행위는 인정하지 않았으나, 감봉이 부당징계에 해당함을 인정하여 재심판정 내용을 일부 취소

[2심 법원] 1심 판결 유지

판결 요지

(1)기간의 정함이 없는 근로계약으로 전환되었는지 여부

기간제 근로계약이 반복하여 체결되거나 갱신되어 일정한 공백기 없이 기간제근로자가 계속적으로 근로한 경우라면, 특별한 사정이 없는 한 최초 기간제 근로계약에서부터 최종 기간제 근로계약에 이르기까지 기간 전체가 구 기간제법 제4조에서 말하는 기간제근로자의 사용기간으로서 ‘계속 근로한 총기간’에 포함되어야 한다. 다만 기간제 근로계약의 대상이 되는 업무의 성격, 기간제 근로계약의 반복 또는 갱신과 관련한 당사자들의 의사, 반복 또는 갱신된 기간제 근로계약을 전후한 기간제근로자의 업무 내용·장소와 근로조건의 유사성, 기간제 근로계약의 종료와 반복 또는 갱신 과정에서 이루어진 절차나 그 경위 등을 종합적으로 고려할 때 당사자 사이에 기존 기간제 근로계약의 단순한 반복 또는 갱신이 아닌 새로운 근로관계가 형성되었다고 평가할 수 있는 특별한 사정이 있는 경우에는 기간제근로자의 계속된 근로에도 불구하고 그 시점에 근로관계가 단절되었다고 보아야 하고, 그 결과 구 기간제법 제4조에서 말하는 ‘계속 근로한 총기간’을 산정할 때 그 시점을 전후한 기간제 근로계약기간을 합산할 수는 없다(대법원 2020. 8. 20. 선고 2017두52153 판결의 취지 참조).

비록 이 사건 센터의 취업상담사와 직업상담사가 거의 같은 보수를 받는 등 근로조건이 유사하였던 것으로 보이기는 하나, 원고는 2016년경부터 2018년경까지 매년 말 다음 해부터의 재계약 체결에 대한 기대권을 배제하려는 의사를 근로계약 만료통보를 통해 객관적으로 명백하게 표시하였고, 그에 기해 별도의 채용절차를 마쳤던 이상 참가인이 공개채용 절차에서 채용된 2017. 1. 1., 2018. 1. 1., 2019. 1. 2.을 각 기준으로 원고와 참가인 사이의 근로관계는 이전과 단절되었다고 봄이 타당하다.

가) 원고는 참가인과 2016년부터 2018년까지 1년 단위로 기간의 정함이 있는 근로계약을 체결한 후 매 1년마다 계약기간이 만료되었고, 참가인은 계약기간이 만료되기 전에 원고가 시행하는 별도의 공개채용 절차에 응시하여 최종 선발됨으로써 그 다음 해에도 이 사건 센터에서 근무하게 되었다. 만약 위와 같은 채용절차가 형식적인 것이었다면 기존의 근로관계가 단절되었다고 볼 수 없을 것이나, ① 2016년부터 2018년까지 매년 초 또는 수시로 채용된 이 사건 센터의 직업상담사, 취업상담사 대부분이 그 전년도에 근무한 사람과는 다른 사람이었던 점, ② 이 사건 센터에서 근무하던 사람이 공개채용 절차에 지원할 경우 최종합격이 보장되었다고 볼만한 자료가 없는 점, ③ 서류전형에서 채용예정인원보다 더 많은 사람을 합격시킨 후 면접절차에서 채용예정에 해당하는 인원을 합격시키는 것을 원칙으로 하되, 2016년경의 경우 적격자가 채용예정인원에 미치지 못하자 채용예정인원보다도 적은 인원만을 채용하기도 한 점 등에 비추어 원고가 시행한 공개채용 절차는 객관적인 기준에 따라 이루어지는 실질적인 경쟁을 거쳐 우수한 지원자

를 선발하는 절차였던 것으로 보이고, 피고 및 참가인의 주장처럼 구 기간제법을 회피하기 위하여 형식적으로 실시된 것으로 보기 어렵다.

나) 원고는 이 사건 협약에 따라 이 사건 센터를 수탁 운영하였는데, 이 사건 협약에 따르면 위수탁기간은 2014. 1. 14.경부터 1년 단위로 연장된 것으로 보이고, ○○광역시장은 위수탁기간 중이라도 원고가 이 사건 협약에 따른 의무를 이행하지 않거나 ○○광역시장의 공익상 위탁운영을 계속할 수 없는 사유가 발생한 경우 등에 이 사건 협약을 해지할 수 있다. 이 사건 협약이 해지되면 원고는 이 사건 센터를 운영할 수 없게 되므로 채용절차에서의 비용 부담, 숙련된 인원에 대한 고용유지의 어려움 등의 문제가 발생할 수 있음에도 이 사건 협약이 갱신되는 1년 단위로 이 사건 센터의 근로자들에 대한 근로계약 해지 및 공개채용 절차를 통한 신규채용을 반복한 것으로 보인다.

다) 참가인이 매년 이 사건 센터의 공개채용 절차에 지원하였음에도 불구하고, 이전의 기간제 근로계약을 반복 또는 갱신한다는 인식이나 의사가 있었던 것으로 볼 만한 객관적인 사정을 찾아볼 수 없다. 오히려 매년 참가인을 제외한 이 사건 센터의 나머지 직원 대부분은 이 사건 센터에 신규 채용된 인원이었기 때문에 참가인으로서도 공개채용 절차가 새로운 직원을 채용하기 위한 절차임을 알고 있었던 것으로 보인다. 라) 참가인은 2016. 1. 1.부터 2017. 12. 31.까지는 취업상담사로, 2018. 1. 1.부터 2018. 12. 31.까지 및 2019. 1. 2.부터 2019. 4. 28.까지는 직업상담사로 이 사건 센터에서 근무하였는데, 참가인의 직종은 참가인이 공개채용 절차에서 지원하여 합격한 대로 결정된 것이다.

(2) 참가인에게 갱신기대권이 인정되는지 여부

기간을 정하여 근로계약을 체결한 근로자의 경우, 그 기간이 만료됨으로써 근로자로서의 신분관계는 당연히 종료되고, 근로계약을 갱신하지 못하면 갱신 거절의 의사표시가 없어도 그 근로자는 당연 퇴직되는 것이 원칙이다. 그러나 근로계약, 취업규칙, 단체협약 등에서 기간이 만료되더라도 일정한 요건이 충족되면 당해 근로계약이 갱신된다는 취지의 규정을 두고 있거나, 그러한 규정이 없더라도 근로계약의 내용과 근로계약이 이루어지게 된 동기 및 경위, 계약갱신의 기준 등 갱신에 관한 요건이나 절차의 설정 여부 및 그 실태, 근로자가 수행하는 업무의 내용 등 당해 근로관계를 둘러싼 여러 사정을 종합하여 볼 때, 근로계약 당사자 사이에 일정한 요건이 충족되면 근로계약이 갱신된다는 신뢰관계가 형성되어 있어 근로자에게 그에 따라 근로계약이 갱신될 수 있으리라는 정당한 기대권이 인정되는 경우에는, 사용자가 이에 위반하여 부당하게 근로계약의 갱신을 거절하는 것은 부당해고와 마찬가지로 아무런 효력이 없고, 이 경우 기간만료 후의 근로관계는 종전의 근로계약이 갱신된 것과 동일하다(대법원 2011. 4. 14. 선고 2007두1729 판결, 대법원 2014. 2. 13. 선고 2011두12528 판결 등 참조)

다음과 같은 사실 및 사정을 앞서 든 법리에 비추어 보면, 참가인에게 갱신기대권이 인정된다고 볼 수 없으므로 원고와 참가인 사이의 근로계약 관계는 2019. 4. 28.자 계약기간 만료로 유효하게 종료되었다. 따라서 원고의 이 부분 주장도 이유 있다.

가) 원고와 참가인이 작성한 각 근로계약서, 원고의 취업규칙에는 기간제 근로계약의 기간만료에도 불구하고 일정한 요건이 충족되면 당해 근로계약이 갱신된다는 취지의 규정이나 기간제 근로계약의 갱신 기준이나 요건, 절차 등에 관한 규정이 존재하지 않는다. 오히려 원고와 참가인이 작성한 2017. 1. 1.자 근로계약서에는 계약기간 만료시 근로관계가 자동 종료됨을 명확히 하고 있고, 그 이후로 작성된 근로계약서에도 모두 같은 취지의 규정이 있다.

나) 원고는 2016년경부터 2018년경까지 매년 11월 말경 참가인에게 계약만료를 통보하였고, 참가인은 그 후 진행된 공개채용 절차에 지원하여 채용되었다. 달리 원고와 참가인이 근로계약을 체결할 당시 원고와 참가인 사이에 근로계약의 갱신에 관한 어떤 신뢰가 형성되었다고 볼만한 사정이 없다.

다) 이 사건 센터에 근로계약 갱신의 관행이 있었다고 볼만한 사정도 없다. 앞서 보았듯이 원고가 2016년경부터 2018년경까지 매년 계약해지 후 공개채용 절차를 통해 직원을 채용하면서 이 사건 센터에는 매년 신규 채용된 직원들이 다수 근무한 사실이 인정될 뿐이다.

패소 이유 (사실관계에 관한 인정 차이)

기간제근로자의 계속근로기간 산정에 있어서, 기간제근로자를 계속 채용하게 된 원인이 되는 신규채용절차에 의한 계속근로기간의 단절을 인정할 것인지가 쟁점이 된 사안이다. 신규채용절차가 실질적 경쟁이 있고, 구제신청 근로자가 탈락할 수 있는 전형절차로서 객관적으로 진행된 절차라면, 그러한 절차를 거쳐 채용이 지속되었다 하더라도 신규채용으로 인정할 수 없다는 것이 법원의 판단 근거이다. 또한, 그러한 신규채용 절차는 갱신기대권을 차단하는 효과가 인정된다.

이와 관련해서는 이미 대법원의 확립된 판결이 있고, 그 내용은 판결 이유에도 인용되어 있다. 따라서, 대법원 판례 경향에 대한 인식의 부족과, 동일한 사실관계에 대한 법리 적용과 관련된 판단의 차이가 패소의 원인이라고 보인다. 따라서 노동위원회가 항소하지 않고 패소 확정을 수인한 것은 합리적인 판단이었다고 보인다. 다만, 중노위의 판정이 하고 있으므로, 충분히 다른 판단이 가능했던 사안이라고 이해할 수도 있다. 다만, 초심 지노위 판정이 오히려 타당한 결론을 내리고 있음에도 불구하고, 매우 무리한 판정을 내려 당사자의 취소소송 제기와 패소를 초래한 중노위 판정의 문제점은 지적하지 않을 수 없다.

일련번호	2021-21					
판결번호	서울고등법원 2020. 11. 27. 선고 2020누0000074)					
중노위판정번호	중노위 2019. 6. 18. 중양2019부해466					
사건 종류	부당해고					
세부 쟁점	해고의 정당성, 해고의 절차, 이중징계					
심급별 소송결과	1심 법원	재심판정취소	2심 법원	1심판결 유지	대법원	원심유지
원고, 피항소인	○○농업협동조합		피고보조참가인, 항소인		강○75)	
피고	중양노동위원회위원장		피고측 대리인 선임 여부		선임 안 함	
노동조합 지원 여부	없음		원고측 대리인 선임 여부		선임76)	
재심 결과	초심 취소					
초심의 대법원 판례 일치여부	일치		재심의 대법원 판례 일치여부		불일치	
기타 특이사항	중노위는 상고하지 않았고, 피고보조참가인이 상고하였으며, 대법원 심리불속행 기각으로 완결됨					

주요 사실관계

<사실관계>

근로자 ○○(이하 ‘이 사건 근로자’라 한다)은 1997. 4. 1. □□농업협동조합에 입사하여 약 20년간 근무하다, 2016. 7. 12. ○○농업협동조합으로 인사발령을 받아 근무하던 중 2018. 11. 19. 부당하게 해고되었다고 주장하는 사람이다.

사용자 ○○농업협동조합(이하 ‘이 사건 사용자’ 또는 ‘이 사건 조합’)은 1970. 5. 13. 설립되어 상시 약 120명의 근로자를 사용하여 농산물 생산·유통 및 금융서비스업 등을 행하는 법인이다.

이 사건 사용자는 2018. 11. 23. 이 사건 근로자에 대하여 ‘복무규정위반(무단결근, 근태기록 임의삭제)’를 사유로 정식 6개월의 징계처분(이하 ‘선행 징계처분’)을 하였으나 이후 2018. 12. 7. 선행 징계처분을 취소하고 이 사건 근로자에게 2018. 12. 10.자로 해고통지문을 보내기로 결정하였으며, 2018. 12. 13. 이 사건 근로자에게 해고통지문을 내용증명우편으로 발송하였고(이하 ‘이 사건 해고통지문’ 또는 ‘이 사건 해고통지’라 한다) 이 사건 근로자는 2018. 12. 14. 이를 수령하였다(이하 ‘이 사건 직권면직 처분’ 또는 ‘이 사건 해고’라고 한다). 이 사건 근로자는 2019. 1. 14. 경기도지노위에 ‘이 사건 직권면직 처분은 부당해고에 해당한다’고 주장하면서 구제신청을 하였다.

<심급별 결과>

[경기도지노위] ‘이 사건 직권면직 처분은 징계처분이 아니고 선행 정직처분 취소 후 이루어진 것이므로 이중징계에 해당하지 않고, 이 사건 직권면직 처분을 함에 있어 징계절차를 거치지 않은 것을 절차적으로 위법하다고 볼 수 없다’는 이유로 이 사건 근로자의 구제신청 기각

[중노위] ‘이 사건 직권면직 처분은 이중징계에 해당하지 않으나, 해고의 시기는 해고처분 이후 장래의 일자를 정하는 것이 원칙인데, 이 사건 직권면직 처분은 해고의 시기를 해고처분 이전으로 소급 적용하여 이미 유효하게 존재하고 있는 근로관계를 부정하는 것으로서 해고의 기본 성질에 위배되어 효력이 없다’는 이유로 이 사건 초심판정을 취소하고 이 사건 근로자의 구제신청 인용

[1심 법원] 이 사건 직권면직은 이중징계에 해당하지 않고, 해고의 시기 역시 소급되지 않았으므로 이 사건 직권면직 처분이 해고의 효력발생시기를 해고통지 이전으로 소급하여 위법함을 전제로 한 재심판정은 위법하다고 판시

[2심 법원] 1심법원의 판결과 같은 판결

[대법원] 원심법원의 판결을 그대로 인정

판결 요지

가. 이중징계에 해당하는지 여부

사용자가 근로자에 대하여 이중징계를 한 경우 일사부재리의 원칙이나 이중처벌금지의 원칙에 위배되어 그 징계처분은 무효이나, 이와 같이 이중징계에 해당하려면 선행 처분과 후행 처분이 모두 법적 성질상 징계처분이어야 하고, 선행 징계처분이 취소됨이 없이 유효하게 확정되어야 하며, 선행 징계처분과 후행 징계처분의 징계혐의사실이 동일하여야 한다(대법원 2000.9. 29. 선고

74) 피고 보조참가인이 상고한 뒤(중노위는 상고하지 않음) 대법원 심리불속행 기각으로 완결(대법원 2020두 00000)

75) 1심, 2심, 3심 : 법무법인 와이케이

76) 1심, 2심, 3심 : 법무법인 정세

99두109902 판결 참조)

다음과 같은 사정들에 비추어 보면, 이 사건 직권면직 처분은 징계처분에 해당하지 않고, 이 사건 사용자는 선행 정직처분을 적법하게 취소한 후 이 사건 직권면직 처분을 하였으므로 이 사건 직권면직 처분은 이중징계에 해당하지 않는다.

① 이 사건 사용자의 징계변상규정, 인사규정에서는 ‘7일 이상 연속 무단결근’에 해당하는 경우는 복무 위반의 정도가 중한 점을 감안하여 징계사유와 구별되는 별개의 직권면직 사유로 규정하고 있어, 이 사건 직권면직 처분은 징계처분에 해당한다고 볼 수 없다.

② 이 사건 사용자의 선행 정직처분은 인사규정 제9조 제3항에서 인사발령 취소사유로 정한 “사무상의 착오” 또는 “제규정 위반”에 해당하는 것이므로, 이 사건 사용자가 인사규정 제9조 제3항에 근거하여 선행 정직처분을 취소한 것은 위법하다고 할 수 없다.

③ 이 사건 사용자의 계약에는 징계처분을 취소하는 경우에도 서면으로 통보하도록 규정하고 있지는 않다. 따라서 징계처분의 취소를 반드시 서면으로 통보하여야 한다고 볼 수는 없으므로, 선행 정직처분은 이 사건 사용자가 이 사건 근로자에게 구두로 선행 정직처분의 취소를 통보함으로써 적법하게 취소되었다고 할 것이다.

나. 징계절차를 거치지 않은 것이 절차적으로 위법한지 여부

취업규칙에서는 해고와는 별도로 면직을 규정하면서 “월 7일 이상 무단 결근”을 면직사유의 하나로 들고 있고, 한편 징계해고 등에 관한 징계사유, 징계기준, 징계절차 등을 정한 징계규정에서는 징계사유의 하나로 일반의 “무단결근”(1 내지 6일 및 7일 이상으로 구분되어 있다)을 규정하고 있는 경우, 위 무단결근에 관한 두 개의 사유는 복무질서를 해하는 정도를 달리하는 것으로서 별개의 사유임이 분명하므로, 사용자는 전자의 사유에 의하여 징계규정과는 관계없이 취업규칙에 따라 면직처분을 할 수 있다. 그리고 면직처분과 징계처분이 따로 규정되어 있으면서도 면직처분에 관하여는 일반의 징계처분과 달리 아무런 절차규정도 두고 있지 아니하고, 그 면직사유가 동일하게 징계사유로 규정되어 있는 것도 아니라면, 사용자가 면직처분을 함에 있어 일반의 징계절차를 거쳐야 한다고 할 수 없고, 면직처분에 있어 징계규정이 정한 징계기준에 구속받으리도 없으니, 징계규정을 따르지 아니하였다고 하여 위법하다고 할 수 없다(대법원 1995. 6. 30. 선고 94다35350 판결 참조)

다. 신의칙 위반 여부

신의성실의 원칙은 법률관계의 당사자가 상대방의 이익을 배려하여 형평에 어긋나거나 신뢰를 저버리는 내용 또는 방법으로 권리를 행사하거나 의무를 이행하여서는 아니 된다는 추상적 규범을 말한다. 신의칙에 위배된다는 이유로 그 권리행사를 부정하기 위해서는 상대방에게 신의를 공여하였거나 객관적으로 보아 상대방이 신의를 가지는 것이 정당한 상태에 이르러야 하고, 이와 같은 상대방의 신의에 반하여 권리를 행사하는 것이 정의관념에 비추어 용인될 수 없는 정도의 상태에 이르러야 한다(대법원 2018. 6. 15. 선고 2016두62795 판결 등 참조).

라. 근로기준법 제27조 위반 여부

근로기준법 제27조는 사용자가 근로자를 해고하려면 해고사유와 해고시기를 서면으로 통지하여야 효력이 있다고 규정하고 있는데, 이는 해고사유 등의 서면 통지를 통해 사용자로 하여금 근로자를 해고근로자를 해고하는 데 신중을 기하게 함과 아울러, 해고의 존부 및 시기와 그 사유를 명확하게 하여 사후에 이를 둘러싼 분쟁이 적정하고 용이하게 해결될 수 있도록 하고, 근로자에게도 해고에 적절히 대응할 수 있게 하기 위한 취지이다(대법원 2011. 10. 27. 선고 2011다42324 판결 참조).

이 사건 사용자는 이 사건 해고통지문의 말미에 기재된 “2018. 12. 10.”을 해고시기로 특정하

였다고 할 것이고, 위 해고시기의 기재로 인하여 이 사건 근로자가 이 사건 해고에 대처하는 데 어려움을 겪었다고 볼 수 없으므로, 이 사건 해고는 근로기준법 제27조에 반하여 위법하다고 볼 수 없다.

① 이 사건 사용자는 이 사건 해고통지문의 하단에 기재된 2018. 12. 10.을 해고시기로 특정하였다고 할 것이고, 이 사건 근로자도 이 사건 사용자로부터 선행 정직처분을 취소하고 이 사건 해고통지문을 발송하게 된 경위에 대하여 들은 내용과 2018. 12. 14. 수령한 이 사건 해고통지문의 기재내용에 의하여 2018. 12. 10.이 해고시기였음을 충분히 알 수 있었던 것으로 보인다.

② 이 사건 사용자는 이 사건 근로자를 2018. 12. 10.자로 해고하기로 결정하고 이 사건 해고통지문의 하단에 “2018. 12. 10.”이라고 기재하였던 점 등을 고려하면, 이 사건 해고통지문에 직권면직 처분일자로 기재된 2019. 11. 19.을 해고시기의 기재로 볼 수는 없다.

③ 이 사건 사용자가 직권면직 처분일자를 변경한 해고통지문을 다시 보냈다는 사정만으로 이 사건 해고통지문에 기재된 해고시기가 특정되어 있지 아니하다고 볼 수 없다.

④ ㉠ 이 사건 사용자가 이 사건 해고통지문의 해고시기 기재로 인하여 구제신청기간이 단축되는 불이익을 겪었다고 볼 수 없는 점, ㉡ 이 사건 근로자는 이 사건 사용자에게 이 사건 해고에 대처할 수 있도록 해고통지문의 발송일을 2~3일 연기해달라고 요청하였고, 이에 원고는 이 사건 해고통지문의 발송일을 당초 예정된 2018. 12. 10.에서 2018. 12. 13.로 연기하였던 점, ㉢ 이 사건 근로자는 이 사건 해고통지문을 2018. 12. 14. 수령한 후 2019. 1. 14. 경기지노위에 구제신청을 하였던 점 등을 고려하면 이 사건 근로자가 이 사건 해고통지문에 해고일을 2018. 12. 10.로 기재한 것으로 인하여 이 사건 근로자가 이 사건 해고에 대처하는 데 불이익을 입었다고 볼 수 없다.

마. 해고의 시기를 소급하여 위법한지 여부

근로기준법상의 해고는 그것이 징계해고이든 직권면직이든 본질적으로는 고용계약의 해지로서 그 법적 성질은 상대방 있는 단독행위라고 할 것이며, 상대방있는 단독행위는 그 의사표시가 상대방에게 도달하는 때에 효력이 발생한다(대법원 1997. 9. 26. 선고 97누1600 판결).

사용자는 해고의 효력발생시기를 해고의 의사표시가 근로자에게 도달하기 이전 시점으로 일방적으로 소급시킬 수 없으므로, 사용자가 해고통지문에 기재한 해고일이 해고통지가 근로자에게 도달하기 이전 시점이라고 하더라도 해고의 효력이 발생하는 시기는 해고통지가 근로자에게 도달하는 때라고 할 것이고, 해고통지문에 기재된 해고일로 그 효력발생시기가 소급한다고 볼 수 없다.

따라서 이 사건 사용자가 이 사건 해고통지문에 해고시기를 2018. 12. 10.로 기재한 것으로 인하여 이 사건 해고의 효력발생시기가 2018. 12. 10.로 소급되었다거나 2018. 11. 19.부터 2018. 12. 14.이전까지 유효하게 존재한 근로관계가 소급적으로 부정되었다고 볼 수 없으므로, 이 사건 해고가 해고의 기본성질에 반하여 무효라고 볼 수 없다.

그렇기 때문에 이 사건 직권면직 처분이 해고의 효력발생시기를 해고통지 이전으로 소급하여 위법함을 전제로 한 이 사건 재심판정은 위법하다.

패소 이유 (사실관계 조사 미비, 확립된 법리 간과)

이 사건은 초심판정과 재심판정이 엇갈린 경우이고, 초심판정과 같은 법원의 판단이 3심까지 쫓 이어진 사건이다. 판단이 엇갈린 지점은 해고통지문에 기재된 해고일과 실제 해고의 효력 발

생시기와 관련한 쟁점이다.

재심은 상대방 있는 단독행위는 그 의사표시가 상대방에게 도달하는 때에 효력이 발생한다는 법리에 따라 해고통지의 효력 발생시기도 해고통지가 근로자에게 도달하는 시점이라는 점을 간과하고 “해고 시기는 해고처분 이후로 장래의 일자를 정하는 것이 원칙이며 이미 내려진 종전의 해고처분의 효력을 다투는 등 별도의 특별한 사정이 없는 한 해고시기를 해고처분 이전으로 소급적용하는 것은 이미 유효하게 존재하고 있는 근로관계의 실체적 사실관계를 별도의 특별한 이유 없이 부정하고 있는 것으로서 그 효력이 없다고 판단된다”는 판시를 내렸다.

더욱이 법원에서 인정된 사실관계에 따르면 사용자는 해고통지문이 근로자에게 도달한 시점을 기준으로 퇴직일자를 계산하였고, 이를 기준으로 급여, 해고예고수당, 퇴직급여 등을 처리한 바 법리상, 사실상 모두 문제가 없는 상황임에도 이를 모두 간과한 판단을 내린 문제점이 있다.

결국 이 사건은 사실관계의 조사 미비, 공익위원의 전문성 미비 양자 모두가 문제되어 법원에서 결론이 뒤집힌 사건으로 판단된다.

일련번호	2021-22					
판결번호	서울고등법원 2020. 12. 23. 선고 2019누00000					
중노위판정번호	중노위 2019. 1. 30. 중앙2018부해1095					
사건 종류	부당정직					
세부 쟁점	징계(정직2월) 정당성 - 사유, 양정, 절차					
심급별 소송결과	1심 법원	재심판정취소	2심 법원	1심판결 유지	대법원	-
원고, 피항소인	대한민국(소관:○○○○○)		피고보조참가인		김○○ ⁷⁷⁾	
피고,항소인	중앙노동위원회위원장		피고측 대리인 선임 여부		선임 안 함	
노동조합 지원 여부	없음		원고측 대리인 선임 여부		선임 안 함	
재심 결과	초심 취소					
초심의 대법원 판례 일치여부	일치		재심의 대법원 판례 일치여부		불일치	
기타 특이사항						

주요 사실관계

<사실관계>

77) 1심, 2심 : 개인번호사

가. ○○○○○은 국방부 산하 직할부대로서 상시근로자 1,700여명을 고용하여 전국 군부대 마트, 기숙사, 휴양시설 등을 운영하고 그중 군부대 마트 운영을 위하여 전국에 10개의 지원본부를 두고 있다.

나. 근로자는 2004. 2. 1. ○○○○○(이하 ‘이 사건 사용자’)과 고용계약을 체결하고 ○○○○○의 지원본부 중 ○○지원본부 소속 마트팀장으로서 ○○지원본부가 관리하는 5개 마트(영외 마트1곳, 위탁마두 4곳)를 관리하는 업무를 수행하는 근무원이다. 근무원은 ○○○○○과 고용계약을 체결하여 노무를 제공하는 공무원 근로자이고 근무원과 달리 민간인 신분을 유지한다.

다. 이 사건 사용자는 2018. 3. 20. 이 사건 근로자에게 상급도박, 무단결근, 무단조퇴 등을 이유로 정직 2월의 처분을 하였다.(이하 ‘이 사건 정직처분’)

라. 이 사건 근로자는 2018. 6. 19. 이 사건 정직처분이 부당정직에 해당한다고 주장하면서 강원지노위에 구제를 신청하였다.

<심급별 결과>

[강원지노위] ‘이 사건 근로자의 출근기록이 없다는 사실과 근무시간 중 근무지 외에서 사용한 카드내역이 있다는 사실만으로는 무단결근·무단조퇴·무단외출로 볼 수 없으므로 성실의무 위반(무단결근, 무단조퇴 등)을 원인으로 하는 징계사유는 인정되지 않고, 이 사건 근로자가 포커게임에 참여한 행위는 도박성과 상습성이 인정된다고 볼 사정이 충분하므로 이 사건 징계사유는 인정된다. 이 사건 징계사유를 바탕으로 정직 2월을 명한 이 사건 정직처분의 징계양정이 과하다고 볼 수 없다’는 취지의 이유로 이 사건 근로자의 구제신청 기각

[중노위] ‘성실의무 위반(무단결근, 무단조퇴 등)을 원인으로 하는 징계사유는 인정되지 않고, 도박일로부터 상당 기간이 지났고 도박장부 등 명시적인 자료도 없어 도박혐의자들의 진술에 신빙성이 있다고 단정하기 어려우며 이 사건 근로자 명의의 현금인출내역은 이 사건 근로자의 배우자가 인출한 내역일 가능성도 배제하기 어려우므로 이 사건 징계사유 중 이 사건 근로자가 최초 감사절차에서 인정한 5-6회의 도박만을 인정할 수 있다. 인정되는 이 사건 징계사유의 일부만으로는 이 사건 근로자에게 도박의 습벽을 인정하기 부족하고, 도박행위가 근무시간이나 영내에서 이루어지지 않는 점 등을 종합하면 정직 2개월의 징계양정은 과다하다’는 취지의 사유로 이 사건 초심판정 취소.구제신청 인용

[1심 법원] 이 사건 징계사유 중 일부는 인정되지 아니하나 인정되는 나머지 징계사유만으로도 이 사건 정직처분의 타당성을 인정하기 충분하다는 이유로 재심판정은 위법하다고 판시하였다.

[2심 법원] 1심법원의 판결과 같은 판결

판결 요지

가. 절차적 위법 인정 여부

이 사건 근로자는 ‘민간인인 근로자는 원칙적으로 군사법원의 재판을 받지 않으므로 군검사의 수사대상이 아니고, 군검사가 이 사건 근로자의 금융거래정보를 압수할 권한이 없음에도 이 사건 금융정보를 취득한 것은 불법이다. 이 사건 금융정보는 위법수집증거고 군검사가 아무런 근거 없이 이를 국군복지단에 징계목적으로 제공할 수도 없다. 이 사건 정직처분은 위법수집증거를 기초로 한 절차적 하자가 있어 위법하다’고 주장한다.

그러나 행정소송법에는 위법하게 수집한 증거의 증거능력 배제에 관한 규정이 없고, 행정소송법 제8조 제2항에 의해 준용되는 민사소송법에도 그에 관한 규정이 없다. 검사에게 진실의무를 부여하고 피고인에게 변호인의 조력을 받을 권리를 보장함으로써 실질적 무기대등을 통해 피고인의 공정한 재판을 받을 권리를 보장하는 것을 목표로 하는 형사소송과 대등한 당사자 사이의

공방을 전제로 하는 민사소송이나 행정소송을 동일하게 취급할 수 없다.

따라서 형사소송절차에서의 위법수집증거배제법칙이 행정소송에 당연히 그대로 적용된다고 볼 수는 없고 이 사건 근로자의 주장만으로는 근로자에 대한 금융거래정보를 이 사건 징계사유의 인정근거로 삼는 것이 현저히 반사회적이거나 당사자의 권리를 중대하게 침해하는 것으로서 이 사건 정직처분을 위법하게 할 정도의 절차적 하자에 해당한다고 볼 수도 없다.

나. 실제적 위법 인정 여부

징계처분의 당부를 다투는 행정소송에서 징계사유에 대한 증명책임은 그 처분의 적법성을 주장하는 징계권자에게 증명책임이 있다. 다만 민사소송이나 행정소송에서 사실의 증명은 추호의 의혹도 없어야 한다는 자연과학적 증명이 아니고, 특별한 사정이 없는 한 경험칙에 비추어 모든 증거를 종합적으로 검토하여 볼 때 어떤 사정이 있었다는 점을 시인할 수 있는 고도의 개연성을 증명하는 것이면 충분하다(대법원 2010. 10. 28. 선고 2008다6755 판결 등 참조).

민사책임과 형사책임은 그 지도이념과 증명책임, 증명의 정도 등에서 서로 다른 원리가 적용되고 검찰의 무혐의결정에 대해 확정된 형사판결과 동일한 증거가치를 부여할 수 없으므로, 관련 형사재판에서 공소사실에 관하여 무죄가 선고되거나 검찰이 무혐의 결정을 하였다는 사정만으로 행정소송에서 징계사유의 존재를 부정할 것은 아니다(대법원 1995. 12. 26. 선고 95다21884 판결, 대법원 2015. 3. 12. 선고 2012다117492 판결, 대법원 2018. 4. 12. 선고 2017두74702 판결 등 취지 참조).

상습도박죄에 있어서의 상습성이라 함은 반복하여 도박행위를 하는 습벽으로서 행위자의 속성을 말하는데, 이러한 습벽의 유무를 판단함에 있어서는 도박의 전과나 도박 횟수 등이 중요한 판단자료가 되나, 도박전과가 없다 하더라도 도박의 성질과 방법, 도금의 규모, 도박에 가담하게 된 태양 등의 제반사정을 참작하여 도박의 습벽이 인정되는 경우에는 상습성을 인정할 수 있다(대법원 2017. 4. 13. 선고 2017도953 판결 참조).

이 사건 근로자의 급여(약 250만 원 내지 300만 원)에 비추어 회당 지출된 도금의 규모, 도박이 이루어진 기간, 횟수 등에 비추어 보면, 이 사건 도박행위는 이 사건 취업규칙 제149조 제1항 제6호에 위배되는 행위로서 적법한 징계사유이다.

한편 수 개의 징계사유 중 일부가 인정되지 않더라도 인정되는 다른 일부 징계사유만으로 당해 징계처분의 타당성을 인정하기 충분한 경우에는 그 징계처분을 유지하여도 위법하지 않다(대법원 2014. 5. 15. 선고 2012두11966 판결 참조).

패소 이유 (사실관계에 관한 인정 차이)

도박의 횟수 금액 등에 관한 근로자의 주장과 실제 도박을 더 많이 하였을 것이라는 간접적인 사실관계가 달랐던 사안이고, 상습적으로 도박을 하였는지에 대해서 얼마만큼의 증명이 필요한가가 판단을 다르게 만들었던 사안이다.

또한 이 사건 근로자의 경우 군인이 아니었고, 같이 도박을 하였던 군인들의 경우 정직 1월의 징계처분을 받아 이 사건 근로자가 받은 정직 2월의 처분과 비교하는 것이 징계양정 중 하나의 쟁점이 되었는데, 중노위는 이를 일률적으로 비교하여 인정되는 비위행위에 비해 정직 2월의 처분은 과하다고 판단하였다.

그러나 법원은 군인과 민간인의 신분의 차이에 따른 실질적 불이익의 정도를 비교형량하였고, 그 결과 이 사건 근로자에 대한 징계양정기준이 사회통념상 현저히 부당하다거나 근무자인 이 사건 근로자에게 육군 징계기준에 따른 징계양정이 이루어져야 한다고 볼 수는 없다고 판단하였다.

부록.1. 주요 사건 경과 및 패소 원인 분석

일련번호	2021-24					
판결번호	대법원 2021. 4. 29. 선고 2020두00000					
중노위판정번호	중노위 2018. 10. 15. 중앙2018부해809					
사건 종류	부당해고					
세부 쟁점	기간제 근로자, 갱신거절의 합리적 이유					
심급별 소송결과	1심 법원	재심판정취소	2심 법원	1심판결 유지	대법원	원심유지
항소인	중앙노동위원회위원장(피고)			피고보조참가인, 상고인 ⁷⁸⁾		학교법인 ○○대학교 ⁷⁹⁾
피상고인	신○○(원고) ⁸⁰⁾			피고측 대리인 선임 여부		선임
노동조합 지원 여부	없음			원고측 대리인 선임 여부		선임
재심 결과	초심 유지					
초심의 대법원 판례 일치여부	불일치			재심의 대법원 판례 일치여부		불일치
기타 특이사항	대법원 심리불속행 기각					

주요 사실관계
<사실관계> 가. 근로자(이하 ‘이 사건 근로자’라 한다)는 2013. 4. 1. 학교법인 ○○대학교에 군사와 조교수로 임용된 후, 2014. 6. 26. 초빙교원으로 전환되어 근무하였고, 재임용 심사 절차를 거쳐 학교법인 ○○대학교와 초빙교원 임용계약(계약기간 1년)을 3차례 갱신하여 근무하던 중 2018. 2. 28. 부당하게 해고되었다고 주장하는 사람이다. 나. 사용자 학교법인 ○○대학교(이하 ‘이 사건 사용자’ 또는 ‘이 사건 학교’라 한다)는 상시근로자 60여 명을 사용하여 대학교를 설치하여 운영하는 법인이다. 다. 이 사건 사용자는 2018. 1. 29. 교원인사위원회를 개최하여 ‘이 사건 근로자의 2017년도 재임용평가 결과가 67점에 불과하여 재임용 기준 점수인 70점에 미달하였다.’라는 이유로 이 사건 근로자를 재임용하지 않기로 결정하였고, 그 다음날 이를 이 사건 근로자에게 통지하였다.(위와 같은 재임용 거절을 이하 ‘이 사건 재임용 거절’) 라. 이 사건 근로자는 경기지노위에 ‘이 사건 사용자의 이 사건 재임용 거절은 부당해고에 해당한다.’라고 주장하며 부당해고 구제신청(이하 ‘이 사건 구제신청’)을 하였다.

78) 중노위는 상고하지 않고, 피고보조참가인이 상고를 한 사건임.

79) 1심 : 범우법인 지후, 2심 : 범무법인(유한) 강남, 3심 : 범무법인 양현

80) 1심, 2심, 3심 : 개인변호사

<심급별 결과>

[경기지노위] '이 사건 근로자는 기간의 정함이 있는 근로계약을 체결한 자에 해당하고, 갱신기대권이 인정된다. 그러나 이 사건 사용자가 평가기준에 따라 재임용을 거부한 것이므로, 갱신 거절에 합리적 이유가 있다.'라는 이유로 이 사건 구제신청 기각

[중노위] 초심판정과 같은 이유로 이 사건 근로자의 재심신청 기각

[1심 법원] 징계사유 중 일부는 인정되지 아니하나 인정되는 나머지 징계사유만으로도 이 사건 정직처분의 타당성을 인정하기 충분하다는 이유로 재심판정은 위법하다고 판시하였다.

[2심 법원] 1심법원의 판결과 같은 판결

[대법원] 심리불속행기각

판결 요지

가. 갱신기대권의 인정 여부

기간을 정하여 근로계약을 체결한 근로자의 경우 그 기간이 만료됨으로써 근로자로서의 신분관계는 당연히 종료되고 근로계약을 갱신하지 못하면 갱신거절의 의사표시가 없어도 그 근로자는 당연히 종료되고 근로계약을 갱신하지 못하면 갱신거절의 의사표시가 없어도 그 근로자는 당연히 퇴직되는 것이 원칙이다.

그러나 근로계약, 취업규칙, 단체협약 등에서 기간만료에도 불구하고 일정한 요건이 충족되면 당해 근로계약이 갱신된다는 취지의 규정을 두고 있거나, 그러한 규정이 없더라도 근로계약의 내용과 근로계약이 이루어지게 된 동기 및 경위, 계약 갱신의 기준 등 갱신에 관한 요건이나 절차의 설정 여부 및 그 실태, 근로자가 수행하는 업무의 내용 등 당해 근로관계를 둘러싼 여러 사정을 종합하여 볼 때 근로계약 당사자 사이에 일정한 요건이 충족되면 근로계약이 갱신된다는 신뢰관계가 형성되어 있어 근로자에게 그에 따라 근로계약이 갱신될 수 있으리라는 정당한 기대권이 인정되는 경우에는 사용자가 이에 위반하여 부당하게 근로계약의 갱신을 거절하는 것은 부당해고와 마찬가지로 아무런 효력이 없고, 이 경우 기간만료 후의 근로관계는 종전의 근로계약이 갱신된 것과 동일하다고 할 것이다(대법원 2011. 4. 14. 선고 2007두1729 판결 등 참조).

그리고 기간제 및 단시간근로자 보호 등에 관한 법률(이하 '기간제법')은 같은 법 제4조 제1항 단서의 예외 사유에 해당하지 않는 한 2년을 초과하여 기간제 근로자로 사용하는 경우 기간의 정함이 없는 근로계약을 체결한 것으로 간주하고 있으나, 기간제법의 입법취지가 기간제근로자 및 단시간근로자에 대한 불합리한 차별을 시정하고 근로조건 보호를 강화하기 위한 것임을 고려하며, 기간제법 제4조 제1항 단서의 예외 사유에 해당한다는 이유만으로 갱신기대권에 관한 위법리의 적용이 배제된다고 볼 수는 없다(대법원 2017. 2. 3. 선고 2016두50563 판결 참조).

결국 이 사건 근로자는 기간제법 제4조 제1항 단서 제6호, 같은 법 시행령 제3조 제3항 제4호에 나목에 따른 기간제근로자(기간의 정함이 있는 근로자)인데, 이 사건 사용자의 비전임교원 인사규정 및 위 인사규정이 제정되기 전에 적용되던 종전 초빙교원규정에 재임용 및 그 평가기준에 관한 규정이 존재하고, 매년 초빙교원에 대한 재임용 평가에 따라 임용계약을 갱신하여 왔으므로 원고에게는 재임용 평가 결과 일정 점수 이상을 받으면 재임용될 수 있으리라는 정당한 기대권이 인정된다.

나. 갱신거절에 합리적인 이유가 존재하는지 여부

기간제 근로계약을 체결한 근로자에게 근로계약 갱신에 대한 정당한 기대권을 인정하는 취지는 기간제 근로계약의 남용을 방지함으로써 기간제근로자에 대한 불합리한 차별을 시정하고 기간제 근로자의 근로조건 보호를 강화하려는 데에 있다. 그러므로 근로자에게 이미 형성된 갱신에 대한

정당한 기대권이 있음에도 불구하고 사용자가 이를 배제하고 근로계약의 갱신을 거절한 데에 합리적 이유가 있는지가 문제 될 때에는 사용자의 사업 목적과 성격, 사업장 여건, 근로자의 지위 및 담당 직무의 내용, 근로계약 체결 경위, 근로계약의 갱신에 관한 요건이나 절차의 설정 여부와 그 운용실태, 근로자에게 책임 있는 사유가 있는지 여부 등 당해 근로관계를 둘러싼 여러 사정을 종합하여 갱신 거부의 사유와 그 절차가 사회통념에 비추어 볼 때 객관적이고 합리적이고 공정한지를 기준으로 판단하여야 하고, 그러한 사정에 대한 증명책임은 사용자가 부담한다(대법원 2017. 10. 12. 선고 2015두44493 판결 등 참조).

판결 요지

이 사건 근로자는 2017년도 재임용 평가에서 67점을 받아 재임용 기준 점수인 70점에 단 3점이 부족하였는데, 이 사건 근로자가 학과장 평가의 3개 항목에서 모두 최저 등급인 미흡(5점) 평가를 받고, 추상적인 평가기준조차 존재하지 아니하여 평가의 정당성을 전혀 확인할 수 없는 교무처장, 총장 평가에서 모두 10점 만점에 5점을 받은 것이 객관성·합리성·공정성을 갖춘 평가 결과라고 인정하기 어려운 이상, 이 사건 근로자에 대한 2017년도 재임용 평가 및 이를 근거로 한 이 사건 재임용 거절에 합리적 이유가 있다고 보기 어렵다.

결국 합리적 이유 없이 부당하게 이루어진 이 사건 재임용 거절은 부당해고와 마찬가지로 효력이 없으므로, 이와 다른 전제에 선 이 사건 재심판정은 위법하여 취소되어야 한다.

패소 이유 (사실관계에 관한 인정 차이)

이 사건 근로자에게 갱신기대권이 인정되는지 여부에 관하여는 노동위원회, 법원의 판단이 모두 동일하였다.

다만 갱신거절에 합리적인 이유가 있는지 여부에서 결론이 달라진 사안인데, 중노위의 경우,

“근무평가·인사평가는 평가항목과 평가방법에서 다소 추상성을 띠 수밖에 없고, 평가자의 주관적 의견이 반영되기 마련이며, 점수부여 방식으로 충분히 이루어질 수 있는 점 등을 고려하면, 평가항목과 평가방법에 관하여 참가인 주장과 같은 세세한 기준이 마련되어 있어야 한다거나 점수부여의 이유를 기재하여야 한다고 볼 수는 없다(서울고등법원 2012. 9. 5. 선고 2012누1282 판결 참조, 대법원 2013. 1. 24. 선고 2012두21710 판결(심리불속행 기각) 참조).

근로의 양과 질에 대한 평가에는 수치로 계량되는 객관적인 실적뿐만 아니라 기업조직에의 융화 정도 등 수치로 계량할 수 없는 부분에 대한 주관적인 평가도 포함되는 것이므로, 일부 평가 항목에 관하여 객관적인 판단 기준이 마련되어 있지 않아 상급자의 주관적인 평가에 좌우될 우려가 있다는 사정만으로 근무평정기준이 부당하다고 보기 어렵다(대법원 2012. 7. 12. 선고 2012다31949 판결 참조).”

이와 같은 판결을 판단근거로 삼아 판단을 하여 합리적인 기준으로 이 사건을 판단하였던 것으로 보인다. 다만 구체적인 사실관계를 어떤 관점에서 바라보느냐, 혹은 어떻게 분석하느냐에 따라서 결론이 달라진 것으로 보이고, ‘합리적인 이유’라는 기준 자체를 정형화, 도식화 할 수 없는 한계 때문에 발생한 것으로 판단된다.

일련번호	2021-25					
판결번호	서울고등법원 2021. 4. 9. 선고 2020누00000					
중노위판정번호	중노위 2019. 6. 3. 중앙2019부해348					
사건 종류	부당정직					
세부 쟁점	징계의 정당성 - 절차					
심급별 소송결과	1심 법원	재심판정취소	2심 법원	1심판결 유지	대법원	-
원고, 항소인	고○○			피고보조참가인	사회복지법인 대한불교○○○ 사회복지재단	
피고, 피항소인	중앙노동위원회위원장			피고측 대리인 선임 여부	선임 안 함	
노동조합 지원 여부	없음			원고측 대리인 선임 여부	선임	
재심 결과	초심 유지					
초심의 대법원 판례 일치여부	불일치			재심의 대법원 판례 일치여부	불일치	
기타 특이사항	1심 판결이 취소된 사례					

주요 사실관계 <사실관계> 가. 사회복지법인 대한불교○○○사회복지재단(이하 ‘이 사건 복지재단’)은 ○○시장애인종합복지관(이하 ‘이 사건 복지관’) 등 다수의 사회복지시설을 운영하는 법인이다. 나. 고○○은 2006. 8. 7. 이 사건 복지재단에 입사하여 이 사건 복지관에서 사회복지사로 근무하여 왔다. 다. 이 사건 복지관은 2018. 12. 28. 인사위원회를 개최하여 고○○의 미승인결근, 직장이탈금지 위반 등을 이유로 고○○에 대한 정직 1개월(정직기간 : 2019. 1. 1. ~ 2019. 1. 31.)의 징계처분을 의결하고 같은날 이를 고○○에게 통지하였다(이하 ‘이 사건 정직처분’). 라. 고○○은 이 사건 정직처분의 징계양정이 부당하다고 주장하며 경기지노위에 구제신청을 하였다. <심급별 결과> [경기지노위] 정직처분은 징계양정이 적정하여 사용자의 징계재량권을 남용한 것으로 보기 어렵다.’라는 이유로 고○○의 구제신청을 기각(경기2019부해102). [중노위] 초심판정과 같은 이유로 고○○의 재심신청을 기각 [1심 법원] 이 사건 정직처분은 정당하고, 이와 같은 전제에서 판단한 이 사건 재심판정은 적법

하다고 판시

[2심 법원] 1심 판결을 뒤집고 재심판정이 위법하다고 판시하였다. 이 사건 복지재단에서 서울고등법원 판결 선고 이후 항고하였으나 바로 취하함으로써 확정

판결 요지

가. 인사위원회 구성의 위법 여부

고〇〇은 이 사건 정직처분을 의결한 인사위원회는 이 사건 복지관 인사규정에 위반하여 ‘운영위원회 위원’이 아니라 ‘운영위원장’인 〇〇스님을 인사위원회 위원으로 포함하는 등의 인사위원회 구성에 위법이 있다고 주장한다.

그러나 이 사건 복지관 인사위원회는 위원장을 포함하여 5인으로 구성되어 있고, 인사위원중 정엄 위원은 운영위원회 위원 중에서 호선된 운영위원장으로써 운영위원회 위원에도 해당된다. 기타 인사위원회 구성 및 의결에 어떠한 위법이 인정되지 않는다.

나. 2018. 10. 23. 인사위원회 임시회의 의결의 위법 여부

인사위원회는 2018. 10. 23. 임시회의를 개최하여, 고〇〇의 무급휴가 또는 결근계 사용을 승인하지 않고 정상근무를 명하는 의결을 하였는데, 고〇〇은 이에 대하여 인사위원회 임시회의에 관한 문서들은 위조된 문서이고, 회의록에 기재된 회의 시간과(2019. 10. 23. 09:10~10:30) 심의의 결서에 기재된 의결 시간(2019. 10. 23. 09:00)에 비추어 이미 인사위원회 의결 결과가 회의 전에 결정되어 있었으므로 2018. 10. 23. 인사위원회 임시회의 의결은 위법하다고 주장한다.

그러나 제출된 증거들 및 변론 전체의 취지에 의해서 알 수 있는 사정들 즉, 문서번호의 중복된 사례가 종종 있었고, 이러한 사정 때문에 문서번호가 누락되었다거나 문서번호가 잘못 부여되었다는 사정만으로는 위조되었다고 볼 수 없는 점, 회의의 실제 시간과 기재된 시간이 다르기는 하지만 이런 기재만으로는 고〇〇의 주장과 같이 인사위원회 의결 결과가 이미 결정되어 있는 등 임시회의 의결에 어떠한 위법이 있다고 인정하기 부족하다.

다. 기타 고〇〇은 인사위원회 출석통지서를 받지 못하였고, 인사위원회에서 소명할 수 있는 기회를 박탈당한 채 이 사건 정직처분 의결 결과만을 통지받았으므로 이 사건 정직처분은 이 사건 복지관 인사규정 제42조 제4항을 위반하여 위법하다고 주장한다.

인정사실에 의하면 이 사건 복지재단은 2018. 11. 30. 고〇〇에게 2018. 12. 5.자 인사위원회에 대한 출석통지서를 송달하였으나 고〇〇이 해당 기일에 출석하지 않았고 그 상태에서 징계의 종류만을 정하고 그 기간에 관하여는 최종 결정을 보류한 채 이를 한 번 더 논의하기 위하여 인사위원회 기일을 속행하기로 하면서, 기존의 징계사유 외에 새로운 징계사유를 추가하고, 징계사유에 대한 사실 확인을 위하여 증인까지 소환하기로 하였음에도 그에 따라 속행되는 2018. 12. 20.자 인사위원회에 대하여 고〇〇에게 출석 통지를 하지 않았고, 소명의 기회를 부여하지도 않았다.

이후 2018. 12. 20.자 인사위원회에서도 징계의결을 보류한 채 그 기일이 2018. 12. 28.로 속행되었는데 이때에도 이 사건 복지재단은 2018. 12. 28.자 인사위원회에 대해서도 고〇〇에게 출석통지를 하지 않았고, 소명의 기회를 부여하지도 않았다.

결국 이 사건 정직처분에는 추가된 징계 안건에 대한 고〇〇의 방어권 행사 및 증인에 대한 반대신문권 등 징계절차상 권리 행사가 전면적으로 차단되었으므로 중대한 절차적 위법이 있다.

패소 이유 (근로자측의 쟁점 파악이 늦어짐, 전문적인 법적 조력의 여부)

이 사건은 당초 부당징계를 주장했던 근로자측에서 법적 쟁점 파악을 잘못했기에 이를 근거로 노동위원회, 1심 법원의 판단이 내려졌고, 2심에 가서야 구체적으로 통지를 받지 못한 이유를 구체적으로 주장하여 근로자측이 승소했던 사건이다.

즉, 근로자측은 처음부터 징계양정을 다투는데 집중하였고, 1심 소송에 이르러서야 비로소 절차적 하자에 대해 주장하기 시작했으며, 1심까지 패소하고 나서야 변호사를 선임(1심 판결 선고 뒤 항소를 위해 변호인 선임함)하여 징계위원회 소집통지가 없었다는 점을 집중적으로 다투기 시작하였는데 그 때문에 결과가 달라졌다고 볼 수 있다.

결국 징계사유를 추가했을 뿐만 아니라 증인을 불러 신문을 열었음에도 불구하고 이러한 절차에 대한 출석통지를 전혀 하지 않은 이 사건 징계는 위법하다는 법리를 확인한 사건이되, 다만 이러한 추가 징계사유에 대한 절차적 하자가 있었는지가 2심에서야 비로소 쟁점이 되었기에 법원의 판단이 달라진 사건으로써 근로자측이 처음부터 전문적인 대리인을 선임하여 사건을 대응하였다면 간명하고 신속하게 사건이 마무리될 수 있었을 것이라고 판단된다.

일련번호	2021-27					
판결번호	대법원 2021. 4. 15. 선고 2021두00000 판결					
중노위판정번호	중노위 2021. 3. 3. 중앙2018부해1019					
사건 종류	부당해고					
세부 쟁점	징계, 징계사유, 징계절차, 징계양정					
심급별 소송결과	1심 법원	재심판정취소	2심 법원	1심 유지	대법원	심리불속행기각
상 고 인	중앙노동위원회		참 가 인		이○○	
피상고인	(주)○○방송		피고측 대리인 선임 여부		선임 안 함	
노동조합 지원 여부	있음		원고측 대리인 선임 여부		선임 함	
재심 결과	초심유지					
초심의 대법원 판례 일치여부	불일치		재심의 대법원 판례 일치여부		불일치	
기타 특이사항						

주요 사실관계

<사건 개요>

가. 원고(○○방송)는 상시 약 1,900명을 고용하여 방송사업 및 문화서비스업 등을 영위하는 법인이다. 피고보조참가인(이하 ‘참가인’)은 1984. 1. 1. 원고에 입사하여 2014. 3. 3.부터 ‘○○○

○○ ○'이라는 프로그램(이하 '이 사건 프로그램')의 책임 프로듀서로 근무하던 자이다.

나. 시사프로그램인 이 사건 프로그램은 원고의 내부 직원과 다수의 외주제작사가 공동 협업하는 방식으로 제작되었는데, 한국독립PD협회 등에서 참가인의 외주제작사 측에 대한 욕설, 폭언 등을 문제 삼고 성명을 발표하자, 원고는 2018. 1. 2.부터 같은 달 31.까지 참가인을 대상으로 특별감사를 실시하였다. 참가인의 욕설 및 폭언의 내용은 상세하게 공개되었으며, 사실로 인정되었다. 그 내용이 언론에 보도되기도 하였다.

다. 참가인은 자신이 제작하는 프로그램의 외주 제작사들이 교정시설, 모 연예인 배우자 장례식장 등지에서 몰래카메라 사용한 것을 알면서도 이 사건 프로그램에서 방송한 사실을 특별 감사과정에서 인정하였다. 위 몰래카메라 사용 촬영에 대해서 일부는 사법처리되기도 했고, 일부로 인해서는 기자회견까지 열렸다.

라. 참가인은 여러차례에 걸쳐서 방송통신위원회의 제재조치를 받거나 원고의 자체 심의에 따라 지적을 받기도 했다.

마. 이 사건 특별감사 결과 등을 바탕으로, 원고는 2018. 3. 5. 인사위원회를 개최하여 참가인을 징계하고 하기로 의결하고, 2018. 3. 7. 참가인에게 이를 통지하였다. 감사 실시 사실은 참가인에게 통보되었고, 감사 결과 대부분 사실이 인정되었다. 인사위원회 개최도 취업규칙 규정에 따라 정당하게 이루어졌다.

바. 참가인은 원고에 재심을 신청하였고, 원고는 2018. 3. 26. 재심 인사위원회를 개최하여 참가인에 대한 징계해고를 유지하기로 의결한 다음 2018. 3. 30. 참가인에게 이를 통지하였다. 원고 재심 인사위원회를 거쳐 최종적으로 통지된 이 사건 징계통지서의 주요 내용은 아래와 같다.

사. 참가인은 2018. 6. 5. 이 사건 징계가 부당해고에 해당한다며 서울지방법노동위원회에 구제신청을 하였다(이하 '이 사건 구제신청'이라 한다).

<심급별 결과>

[서울지노위] '이 사건 징계사유 중 일부만이 인정되나, 인정되는 징계사유의 비위 정도에 비해 징계양정이 과중하다고 볼 수 없고, 징계절차도 적법하다.'라는 이유로 구제신청 기각

[중노위] 징계사유에 비해 징계양정이 과중하므로, 이 사건 징계는 부당해고에 해당한다.'라는 이유로 구제신청 인용. 초심판정 취소

[1심 법원] 징계의 정당성을 인정하여 재심판정 취소

[2심 법원] 징계의 정당성을 인정하여 재심판정 취소

[대법원] 심리불속행기각

판결 요지

(1) 징계절차상 하자에 관한 판단

가) 위 인정사실에 의하면, 참가인은 이 사건 특별감사 보고서를 열람하여 확인한 바 있고 이 사건 2018. 3. 5.자 인사위원회 개최 통지서에 이 사건 2018. 3. 5.자 인사위원회 부의사유가 이 사건 특별감사 조치인 것을 명시하고 있으므로, 참가인으로서 이 사건 2018. 3. 5.자 인사위원회의 징계회부사유를 충분히 알 수 있었을 것으로 보인다. 따라서 이 사건 징계에 원고 취업규칙 제68조 제3항 등을 위반하여 참가인의 방어권을 침해한 절차상 하자가 존재한다고 볼 수 없다.

나) 참가인은 원고 측이 이 사건 특별감사 결과에 대한 이의신청 절차를 안내하지 않은 점도

지적하고 있으나, 이 사건 특별감사 결과에 대한 이의신청 절차는 이 사건 징계와는 별도의 절차로서 이를 이 사건 징계절차의 하자로 보기는 다소 어려운 점, 원고 감사3부의 기획편성본부에 대한 이 사건 특별감사 결과 통보 내용과 기획편성본부장 이정식 작성의 진술서 내용 등에 비추어 볼 때 원고 측은 참가인에게 이 사건 특별감사 결과에 대한 이의신청 절차를 안내한 것으로 보이는 점 등을 고려하면, 참가인의 이 부분 주장 역시 받아들이기 어렵다.

다) 따라서 참가인이 주장하는 이 사건 징계절차상 하자를 인정하기 어렵다.

(2) 징계사유에 관한 판단

가) (징계사유 1) 이 사건 각 욕설과 폭언 등은 이 사건 프로그램의 외주제작사 제작진들에 대한 언어폭력으로 인정하기에 충분하고, 이 사건 기자회견문의 내용, 이 사건 특별감사 당시 최○○의 진술 내용 등에 비추어 볼 때 참가인의 외주제작사 제작진들에 대한 언어폭력은 상시적으로 이루어진 것으로 판단되며, 이러한 언어폭력 내용이 이 사건 기자회견, 인터넷 게시물, 이 사건 보도 등을 통해 외부에 알려지면서 원고의 명예와 이미지도 크게 훼손되었으므로, 정당한 징계사유로 인정된다.

나) (징계사유 2-1) 원고 방송제작가이드라인에서는 몰래카메라 사용을 원칙적으로 금지하고 있음에도 참가인은 이 사건 프로그램 제작·방송 과정에서 교정시설과 모 배우 배우자의 장례식장 내에서 몰래카메라를 각 사용하였고, 원고 방송제작가이드라인에서 정한 예외적 허용사유(취재하는 정보가 국가의 안전보장, 질서유지, 공공복리, 또는 국민의 알권리 충족 등 중대한 공익을 위해서 반드시 필요하고, 그러한 정보를 얻을 수 있는 다른 대체 수단이 없을 경우, 몰래카메라 기법의 취재로 침해되는 프라이버시 정도보다 몰래카메라로 얻을 수 있는 정보나 뉴스의 가치가 현저히 클 경우)에 해당한다고 볼만한 사정도 보이지 않는다. 결국 교정시설 내 몰래카메라 사용 등이 형사처벌 대상이 되는지를 불문하고 원고 방송제작가이드라인에 어긋난 몰래카메라 사용 행위를 징계사유로 삼는데 아무런 문제가 없다. (나) 여기에 ① 참가인은 이전에도 교정시설 내 몰래카메라 사용과 관련하여 원고 심의담당부서로부터 지적을 받은 바도 있음에도 재차 외주제작사의 교정시설 내 몰래카메라 사용을 묵인하여 이 사건 프로그램에서 해당 영상을 방송하였으며, 결국 외주제작사 제작진들이 형사재판을 받기에까지 이른 점, ② 참가인이 외부적으로 문제가 될 수 있음을 알고 있음에도 배우 배우자의 장례식장을 몰래카메라로 촬영한 영상을 이 사건 프로그램에서 방송한 점, ③ 이와 같은 몰래카메라 사용이 이 사건 성명서, 이 사건 기자회견문으로까지 이어진 점 등에 비추어 보면, 참가인이 이 사건 프로그램 제작 과정에서 몰래카메라 사용을 묵인하고 해당 영상을 방송함으로써4) 원고에 손실을 끼친 사실이 인정되므로, 징계사유로 인정된다.

다) (징계사유 2-2) 이 사건 프로그램의 책임 프로듀서인 참가인이 시사 후 외주제작자에게 해당 편집본에 대한 추가 촬영, 재촬영, 재편집을 요구하는 것 자체를 부당한 행위로 볼 수는 없고, 예정된 방송일시에 맞춰 편집을 완료해야 하는 방송의 특성상 외주제작사에게 다소 급박하고 신속하게 편집을 해줄 것을 요구하는 상황도 부득이하게 발생할 수 있다. 참가인의 외주제작사에 대한 추가촬영, 재촬영, 재편집 요구가 방송 제작 과정에서 통상적으로 허용되는 범위를 넘어서 현저하게 부당하다거나 과도한 요구였다는 점이 증명되어야 이 사건 제2-2징계사유를 정당한 징계사유로 인정할 수 있을 것이나, 이를 인정할만한 구체적·직접적인 증거가 없다. 따라서 이 사건 제2-2징계사유는 정당한 징계사유로 인정되지 않는다.

라) (징계사유 3-1) ① 원고 심의담당부서의 자체심의를 해당 프로그램에 부적절한 내용이나 오류가 있는지 여부 등을 확인하기 위한 원고 내부 절차에 불과하고, 원고 방송심의규정 제14조 제1항에 의하면 심의위원이 수정하도록 요구한 프로그램을 상당한 이유 없이 수정하지 아니하고 방송한 경우 등만을 심의 관련 징계사유로 삼고 있을 뿐 단순히 심의지적횟수가 많은 경우를 징계사유로 규정하고 있지 않은 점, ② 형식적이고 경미한 심의지적사항들도 존재하는 점, ③ 동일한 시사프로그램인 PD수첩의 2017년도 자체심의 내역을 살펴보면, 총 29회의 방송분 모두 심의지적사항이 존재하나, 이를 이유로 PD수첩 제작진에게 인사상 불이익을 주지는 않은 것으로 보이는 점, ④ 원고 심의담당부서의 자체심의에서 심의지적사항이 있다는 사실만으로 이를 징계사

유로 삼을 수 있다고 한다면 방송제작자의 방송의 자유가 위축되는 결과가 초래될 수도 있는 점 등에 비추어 볼 때, 단순히 자체심의에서 다수의 심의지적사항이 있다는 사실만으로는 징계사유로 삼을 수는 없고, 심의지적을 받은 해당 프로그램의 구체적인 내용 등에 비추어 제작진이 심의 기준을 의도적으로 반복하여 현저하게 위반한 경우, 원고 방송심의규정 각 호의 징계사유에 해당한 경우 등에만 이를 심의 관련 징계사유로 삼을 수 있다고 봄이 상당하다. 그렇다면 이 사건 제3-1징계사유는 정당한 징계사유로 인정되지 않는다

마) (징계사유 3-2) 살피건대, 방송통신위원회의 경고 조치, 방송통신심의위원회의 권고 내지 의견제시 조치는 모두 방송법상 심의규정 등 위반을 이유로 한 것이므로, 그 위반 정도를 불문하고 이를 징계사유로 삼는 것이 부당하다고 볼 수 없는 점, 원고는 방송제작자가 위와 같은 제재 조치 등을 받은 경우 징계를 한 전력도 있는 점 등을 고려하면, 참가인이 이 사건 제재조치 등 내역표 기재와 같이 제재조치 등을 받은 부분을 징계사유로 삼는데 아무런 문제가 없고, 참가인이 주장하는 바와 같은 방송통신심의위원회의 권고 내지 의견제시 조치만으로는 원고에게 별다른 불이익이 없는 사정, 원고가 방송통신위원회의 경고 조치 이후 3년여가 지나서야 이를 징계사유로 삼은 사정 등은 징계양정사유에 불과할 뿐이다. 따라서 이 사건 제3-2징계사유는 정당한 징계사유로 인정된다.

사) (징계사유 3-3) ① 시사프로그램은 그 특성상 법적 분쟁이 발생할 가능성이 상당하고, 그러한 사유만으로 징계를 한다면 언론 및 방송의 자유가 위축되는 결과가 초래될 가능성이 있는 점, ② 이 사건 프로그램의 경우 다른 시사프로그램인 ○○수첩이나 시사매거진○○과 비교하여 보아도 ‘방송 횟수’ 대비 ‘언론중재위원회 제소 내지 관련 소송의 제기 횟수’가 결코 많지 않음에도 이 사건 프로그램의 경우에만 유독 이를 징계사유로 삼고 있는 점 등을 고려하면, 단순히 언론중재위원회 제소 내지 관련 소송의 제기 사실만으로 이를 징계사유로 삼을 수는 없고, 참가인이 관련 방송 지침 등을 현저히 위반하여 이 사건 프로그램을 제작·방송함으로써 언론중재위원회 제소 내지 관련 소송의 제기에 이르게 된 경우, 해당 프로그램의 내용이 지나치게 부적절하거나 공정성·객관성을 잃어 언론중재위원회 제소 내지 관련 소송의 제기에 이르게 된 경우 등에만 이를 징계사유로 삼을 수 있다고 봄이 상당하다. 그렇다면 정당한 징계사유로 인정되지 않는다.

(3) 징계양정에 관한 판단

해고처분은 사회통념상 고용관계를 계속할 수 없을 정도로 근로자에게 책임있는 사유가 있는 경우에 정당성이 인정되고, 사회통념상 근로자와 고용관계를 계속할 수 없을 정도인지는 사용자의 사업 목적과 성격, 사업장의 여건, 근로자의 지위와 담당 직무의 내용, 비위행위의 동기와 경위, 근로자의 행위로 기업의 위계질서가 문란하게 될 위험성 등 기업질서에 미칠 영향, 과거의 근무태도 등 여러 가지 사정을 종합적으로 검토하여 판단하여야 한다(대법원 2002. 5. 28. 선고 2001두10455 판결, 대법원 2017. 3. 15. 선고 2013두26750 판결 등 참조). 한편, 수 개의 징계사유 중 일부가 인정되지 않더라도 인정되는 다른 일부 징계사유만으로도 당해 징계처분의 타당성을 인정하기에 충분한 경우에는 그 징계처분을 유지하여도 위법하지 아니하다(대법원 1991. 11. 22. 선고 91누4102 판결, 대법원 2002. 9. 24. 선고 2002두6620 판결 등 참조).

이 사건 제1징계사유, 이 사건 제2-1징계사유, 이 사건 제3-2징계사유로 인해 원고와 참가인 간의 고용관계는 계속 유지할 수 없을 정도에 이르렀다고 봄이 타당하므로, 참가인을 징계해고한 이 사건 징계가 원고의 징계재량권을 벗어나 이를 남용한 것이라고 보기 어렵다.

또한, 방송 종사자의 직업적 특수성에 비추어 볼 때, 징계권자인 원고의 이 사건 징계가 사회통념상 현저하게 타당성을 잃어 징계권자에게 맡겨진 재량권을 남용한 것으로 보기는 어렵고, 참가인이 주장하는 여러 유리한 징계양정사유(참가인이 이 사건 프로그램을 성공적으로 이끌어왔고 여러 차례 포상을 받은 바도 있는 점, 외주제작사 대표 일부가 이 사건 제1징계사유와 관련하여 참가인에 우호적인 진술을 한 점 등)를 고려하더라도 참가인의 귀책사유로 인해 사회통념상 더 이상 원고와 참가인 간의 고용관계를 계속할 수 없는 상태에 이른 것으로 봄이 타당하다.

패소 이유 (사실관계에 관한 법리적용의 차이)

이 사건은 판단의 대상이 된 사실관계는 동일하지만, 그에 대한 판단이 달라져 중노위가 패소한 사건이다. 징계사유의 정당성과 징계절차의 정당성, 징계양정의 정당성이 모두 쟁점이 되었다. 참가인의 행위와 여러 입증자료들에 비추어볼 때 징계사유 인정에 이의가 있기 어려움에도 불구하고, 초심 판정과 다르게 중노위가 양정 과다를 이유로 초심을 취소했다. 이 사건은 1심 법원, 2심 법원에서 모두 초심 지노위 판정과 같은 논거를 택한 법원의 판결에 의해 중노위가 패소했으며, 대법원은 심리불속행기각으로 사건을 종결했다는 점에서, 중노위의 항소와 상고가 무리하게 이루어진 것임을 알 수 있다. 중노위 공익위원이 사건에 치우치지 않고 공정하고 전문적인 관점에서 사건을 판정하여야 한다는 점을 지적하지 않을 수 없다.
--

일련번호	2021-36					
판결번호	대법원 2020. 11. 26. 선고 2020두00000					
중노위판정번호	중노위 2017. 3. 17. 중앙2017부해15					
사건 종류	부당해고					
세부 쟁점	징계해고-절차(재심징계위원회 구성 하자 존부)					
심급별 소송결과	1심 법원	재심판정유지	2심 법원	1심판결 유지	대법원	파기환송
원고, 상고인	이○○○			피고보조참가인	○○○○ 주식회사	
피고, 피상고인	중앙노동위원회위원장			피고측 대리인 선임 여부	선임 안 함	
노동조합 지원 여부	없음			원고측 대리인 선임 여부	선임	
재심 결과	초심 유지					
초심의 대법원 판례 일치여부	불일치			재심의 대법원 판례 일치여부	불일치	
기타 특이사항	대법원에서 파기환송된 사건임					

주요 사실관계
<사실관계> 가. ○○○○ 주식회사(이하 ‘이 사건 회사’)는 음료판매 등을 주된 영업으로 하는 회사로서 1997. 12. 1. 운전면허증을 소지한 원고와 근로계약을 체결하고 원고로 하여금 업무용 차량을 운전하여 제품을 배송하는 등의 업무를 수행하게 하였다. 나. 이○○(이하 ‘이 사건 근로자’)는 2008. 1. 27. 음주운전으로 적발되어 운전면허정지처분(정

지기간 2008. 3. 7.부터 2008. 4. 25.까지)을 받은 전력이 있다(이하 ‘제1차 음주운전’).

다. 이 사건 근로자는 2016. 1. 19. 00:14경 혈중알콜농도 0.107%의 술에 취한 상태에서 업무용 차량을 운전하다 적발되어 2016. 1. 28. 대구지방법경찰청장으로부터 운전면허취소처분을 받았다(이하 ‘제2차 음주운전’).

라. 이 사건 근로자는 운전면허취소처분에 불복하여 2016. 2. 3. 중앙행정심판위원회에 행정심판을 청구하였고, 같은 달 19. 대구지방법원 2016구단303호로 항고소송을 제기하였다. 대구지방법원은 2016. 3. 7. 위 항고소송사건에서 운전면허취소처분을 운전면허정기107일 처분(정지기간 2016. 3. 30.부터 2016. 7. 14.까지)으로 변경하도록 하는 내용의 조정을 권고하였고, 대구지방법경찰청장이 그에 따라 기존의 운전면허취소처분을 운전면허정지처분으로 변경함으로써 위 항소소송 사건은 2016. 3. 31. 소취하로 종국되었다. 한편, 중앙행정심판위원회는 2016. 3. 25. 이 사건 근로자의 행정심판청구를 기각하였다.

마. 이 사건 근로자는 운전면허정지기간 중인 2016. 4. 8. 다시 술에 취한 상태에서 업무용 차량을 운전하다 적발되어 도로교통법위반(음주운전)죄와 도로교통법위반(무면허운전)죄로 입건되었다(이하 위 음주운전행위와 무면허운전행위를 통틀어 ‘제3차 음주운전’)

바. 이 사건 근로자는 2016. 4. 12. 이 사건 회사에게 “이 사건 근로자는 2016. 1. 19. 제2차 음주운전으로 적발되어 운전면허취소처분을 받았고, 그 동안 행정심판 등을 통하여 운전면허취소처분의 집행이 정지되는 등으로 운전을 할 수 있었으나, 2016. 4.초경 행정심판 기각결정을 고지 받았으므로 이를 보고한다.”는 내용의 ‘경위서’를 제출하였다.

사. 이 사건 근로자는 제3차 음주운전과 관련하여 대구지방법원 2016고약6669호로 공소제기되어 2016. 5. 20.경 위 법원으로부터 벌금 5,000,000원의 약식명령을 고지받았고, 2016. 5. 24. 대구지방법경찰청장으로부터 운전면허취소처분을 받았다.

아. 이 사건 근로자는 2016. 6. 10. 이 사건 사용자에게 기존의 ‘경위서’에 “제3차 음주운전으로 인하여 운전면허취소처분을 받아 향후 2년간 운전면허를 취득할 수 없게 되었다”는 내용이 추가된 ‘경위서(수정)’을 제출하였다.

자. 이 사건 사용자는 위와 관련한 이 사건 근로자의 각 비위행위에 관하여 징계절차를 개시하기로 하였다. 이 사건 사용자의 취업규칙상 징계의결기구인 인사위원회에서 2016. 7. 11. 징계해고를 의결하였고, 이에 따라 이 사건 사용자는 2016. 7. 25. 이 사건 근로자에게 2016. 8. 1. 이 사건 근로자를 징계해고한다고 통지(이하 ‘이 사건 징계해고’라 한다)하였다.

차. 이 사건 사용자의 취업규칙상 징계처분에 대하여 징계대상자는 재심을 청구할 수 있도록 규정하고 있다. 이에 근거하여 이 사건 근로자는 이 사건 사용자에게 이 사건 징계해고에 대한 재심을 청구하였다.

카. 이 사건 사용자는 상무 서○○을 인사위원회 위원장으로, 상무 이○○, 부문장 황○○, 부문장 권○○을 각 위원으로 재심을 위한 인사위원회를 구성한 뒤 그 인사위원회로 하여금 이 사건 근로자의 재심청구를 심의하게 하였다. 위 인사위원회는 2016. 8. 2. 이 사건 근로자의 재심청구를 받아들이지 아니한 채 기존의 인사위원회 의결인 징계해고를 그대로 유지하는 내용의 의결을 하였다.

타. 이 사건 근로자는 이 사건 징계해고가 위법하다고 주장하면서 경북지노위에 구제신청을 하였다.

<심급별 경과>

[경북지노위] 구제신청 기각

[중노위] 이 사건 근로자의 재심신청 기각

[1심 법원] 이 사건 징계절차에 중대한 위법이 있다고 할 수 없고, 이 사건 징계해고는 사회통념상 고용관계를 계속할 수 없을 정도로 근로자에게 책임 있는 사유가 있는 경우로서 정당성이 인정되므로 이 사건 근로자의 청구는 이유 없다고 판시

[2심 법원] 1심법원의 판결과 같은 판결

[대법원] 이 사건 재심위원회의 구성에 하자가 있으므로 이 사건 징계해고는 재심절차의 중대한 하자에 해당하여 재심의 효력을 인정할 수 없으며, 징계해고 또한 현저히 절차적 정의에 반하는 것으로서 무효라고 판시하며 파기환송

판결 요지

가. 징계처분에 대한 재심절차는 징계처분에 대한 구제 내지 확정절차로서 원래의 징계절차와 함께 전부가 하나의 징계처분절차를 이루는 것으로서 그 절차의 정당성도 징계과정 전부에 관하여 판단되어야 한다. 따라서 원래의 징계처분이 그 요건을 갖추었더라도 재심절차를 전혀 이행하지 않거나 재심절차에 중대한 하자가 있어 재심의 효력을 인정할 수 없는 경우에는 그 징계처분은 현저히 절차적 정의에 반하는 것으로서 무효이다(대법원 1994. 1. 14. 선고 93다978 판결, 대법원 1998. 12. 8. 선고 98다31171 판결, 대법원 2010. 5. 27. 선고 2010두1743 판결 등 참조)

나. 단체협약이나 취업규칙 또는 이에 근거를 둔 징계규정에서 징계위원회의 구성에 관하여 정하고 있는 경우 이를 위배하여 징계위원회를 구성한 다음 그 결의를 거쳐 징계처분을 하였다면, 그 징계처분은 징계사유가 인정되는지 여부와 관계없이 원칙적으로 절차상 중대한 하자가 있어 무효라고 보아야 한다(대법원 1995. 5. 23. 선고 94다24763 판결, 대법원 2009. 3. 12. 선고 2008두2088 판결 등 참조).

다. 취업규칙은 사용자가 그 근로자의 복무규율이나 근로조건의 기준을 정립하기 위하여 작성한 것으로서 노사 간의 집단적인 법률관계를 규정하는 법규범의 성격을 가지는데, 이러한 취업규칙의 성격에 비추어 취업규칙은 원칙적으로 그 객관적인 의미에 따라 해석하여야 하고, 문언의 객관적 의미를 벗어나는 해석은 신중하고 엄격하여야 한다(대법원 2003. 3. 14. 선고 2002다69631 판결, 대법원 2016. 1. 28. 선고 2014두12765 판결 등 참조).

라. 원심은 이 사건 사용자의 인사위원회 규정의 문언과 체계의 조화로운 해석을 고려할 때 징계재심위원회는 가급적 총괄임원으로 구성하되, 기능별 총괄임원의 수가 3인 미만이어서 총괄임원만으로 재심위원회를 구성하는 것이 곤란한 경우에는 위원장이 위촉하는 자가 재심위원회의 위원이 되는 것도 가능하다고 전제한 다음, 이 사건 재심위원회 개최 당시 이 사건 사용자에게 기능별 총괄임원은 서○○과 이○○뿐이었으므로, 서○○이 대표이사(사업부장)의 위임을 받아 재심위원회의 위원장으로, 이○○가 재심위원회 위원으로 각 참여하고, 인원이 부족한 기능별 총괄임원 대신 황○○ 부문장과 권○○ 부문장을 위원으로 위촉한 이상, 이 사건 재심위원회의 구성에 하자가 있다고 보기 어렵다고 판단하였다.

마. 그러나 원심의 이러한 판단은 다음과 같은 이유로 그대로 수긍하기 어렵다.

① 이 사건 사용자의 인사위원회 규정상 근로자에 대한 징계재심은 전사 인사위원회가 사업부 인사위원회에 그 권한을 위임하지 않은 이상 원칙적으로 전사 인사위원회의 심의에 의하여야 하고, 전사 인사위원회 위원은 각 기능별 총괄임원으로서 위원장(대표이사)이 위촉하는 3~5인으로 구성되어야 한다.

② 이 사건 재심위원회 개최 당시 이 사건 사용자의 업무를 담당하는 총괄임원은 이 사건 사용자 소속의 생산총괄 서○○ 상무, 영업총괄 이○○ 상무 외에도 ○○생활건강 소속의 HG/음료 CBD총괄 이○○ 상무와 물류총괄 권○○ 상무, 사업혁신총괄 김○○ 전무가 있었는데, 이 사건 사용자의 인사위원회 규정상 이들도 기능별 총괄임원으로서 재심위원회 위원의 구성에서 제외할 이유가 없으므로 이들을 포함하면 인사위원회 규정에서 정한대로 총괄임원만으로 이 사건 재심위원회 위원을 구성할 수 있었다.

부록.1. 주요 사건 경과 및 패소 원인 분석

③ 원심은 이와 달리 이 사건 사용자와 ○○생활건강이 별개의 법인이고, 이 사건 사용자의 인사위원회 규정 등 취업규칙이 이 사건 사용자 소속 직원들에게만 적용되므로 인사위원회 구성 위원은 이 사건 사용자에 소속된 임직원들로 이루어져야 한다는 전제에서 ○○생활건강 소속 임직원이 이 사건 사용자의 업무를 일부 겸임하고 있더라도 이 사건 사용자의 인사위원회 위원이 될 수 없다고 보았으나, 이는 앞서 본 인사위원회 규정상 문언의 객관적 의미를 벗어나는 해석으로서 합리적인 근거가 있다고 보기 어렵다.

④ 그렇다면 이 사건 사용자가 취업규칙에 따라 징계위원회의 구성에 관하여 정하고 있는 인사위원회 규정을 위반하여 HG/음료CBD총괄 이○○ 상무와 물류총괄 권○○ 상무, 사업혁신총괄 김○○ 전무를 제외한 채 총괄임원이 아닌 황○○ 부문장과 권○○ 부분장을 위원으로 포함시켜 이 사건 재심위원회를 구성한 다음 그 결의를 거쳐 이 사건 징계해고를 한 것은 재심절차의 중대한 하자에 해당하여 재심의 효력을 인정할 수 없고, 위 징계해고 또한 현저히 절차적 정의에 반하는 것으로서 무효라고 보아야 한다.

패소 이유 (재심위원회 구성에 관한 인사위원회 규정 해석)

이 사건은 재심절차의 하자 여부에 따라 결론이 달라진 사건이다.

특이하게도 이 사건은 근로자에게 초심단계에서부터 노무사와 함께 사건을 수행하였으나 노동위원회 단계에서는 재심절차의 하자는 쟁점으로 부각된 바 없고, 행정소송에 이르러서야 비로소 재심위원회 구성에 관한 쟁점이 부각된 사례이다.

한편, 1심 법원에서 재심위원회의 구성에 관하여 본격적으로 쟁점으로 부각되기 시작했으나, 1심, 2심 법원은 인사위원회 규정을 완화하여 해석하여 재심위원회의 구성에 회사의 재량권 일탈·남용이 없다고 보았고, 대법원은 인사위원회 규정을 엄격하게 해석하여 재심위원회 구성에 문제가 있음을 확인하였다.

이 사건은 노동위원회 단계에서는 쟁점이 된 바 없는 문제로 판단이 갈렸던 사안이므로 패소이유에 있어 노동위원회의 귀책은 찾아보기 어려운 사건으로 판단된다.

일련번호	2021-37					
판결번호	서울고등법원 2021. 5. 20. 선고 2020누00000					
중노위판정번호	중노위 2019. 6. 25. 중앙2019부해466					
사건 종류	부당해고					
세부 쟁점	근로기준법상 근로자성					
심급별 소송결과	1심 법원	재심취소	2심 법원	원심유지	대법원	상고안함
항 소 인 (피고)	중앙노동위원회위원장		피고 항소인의 보조참가인		박○○ ⁸¹⁾	
피항소인 (원고)	주식회사 ○○○○ ⁸²⁾		피고측 대리인 선임 여부		선임안함	

노동조합 지원 여부	없음	원고측 대리인 선임 여부	선임
재심 결과	초심유지		
초심의 대법원 판례 일치여부	불일치	재심의 대법원 판례 일치여부	불일치
기타 특이사항	노동위원회의 판정이 1심에서 뒤집혔고, 2심에서도 같은 결론이 나자 노동위원 회측에서 상고를 하지 않음.		

주요 사실관계 <사실관계> 가. 박○○(이하 ‘참가인’)은 2018. 6. 5. 주식회사 ○○○○와 Rich Planner(보험설계사) 위촉계약을 체결하였고, 2018. 8. 17. Super Branch Manager(사업단장) 위임계약을 체결하여 근무하던 중 2018. 10. 23. 부당하게 해고되었다고 주장하는 사람이다. 나. 주식회사 ○○○○(이하 ‘원고’)는 다수의 생명보험회사 및 손해보험회사로부터 그 회사 보험상품판매를 위탁 받아 보험대리업 등을 영위하는 회사이다. 다. 원고는 2018. 10. 23. 영업윤리위원회를 개최하여 참가인이 ‘기타 회사의 평판을 해치는 행위(허위 모집광고)’를 하였다는 사유로 참가인에 대한 보험설계사 해촉 및 사업단장 해임을 결정하고, 2018. 10. 25. 참가인에게 위 결정 내용을 문자메시지로 통지하였다. 라. 참가인은 원고의 위 통지가 부당해고에 해당한다고 주장하며 2019. 1. 21. 서울지노위에 구제신청을 하였다. <심급별 결과> [서울지노위] ‘참가인은 근로기준법에서 정한 근로자에 해당하고, 원고가 한 해촉 및 해임은 해고에 해당하며, 원고가 참가인을 해고하면서 해고사유와 해고시기를 서면으로 통지하지 아니하여 해고절차가 적법하지 않다.’라는 이유로 참가인의 구제신청을 인용 [중노위] 위 초심판정과 동일한 이유로 원고의 재심신청을 기각 [1심 법원] 참가인은 근로기준법상 근로자에 해당하지 않으므로 원고가 참가인에게 한 보험설계사 해촉 및 사업단장 해임이 해고에 해당할 수 없으니 이 사건 재심판정은 위법하여 취소되어야 한다고 판시 [2심 법원] 1심법원의 판결과 같은 판결을 내렸고, 이대로 확정
--

판결 요지 가. 참가인이 근로기준법상의 근로자인지 여부에 관한 일반법리 근로기준법상의 근로자에 해당하는지 여부는 계약의 형식이 고용계약인지 도급계약인지보다 그 실질에 있어 근로자가 사업 또는 사업장에 임금을 목적으로 종속적인 관계에서 사용자에게 근로를 제공하였는지 여부에 따라 판단하여야 하고, 위에서 말하는 종속적인 관계가 있는지 여부는,
--

- 81) 1심 : 법무법인 진성, 2심 : 법무법인 진성, 다만 소 중간에 사임
82) 1심,2심 : 법무법인(유한) 지평

업무 내용을 사용자가 정하고 취업규칙 또는 복무(인사)규정 등의 적용을 받으며 업무 수행 과정에서 사용자가 상당한 지휘·감독을 하는지, 사용자가 근무시간과 근무장소를 지정하고 근로자에게 구속을 받는지, 노무제공자가 스스로 비품·원자재나 작업도구 등을 소유하거나 제3자를 고용하여 업무를 대행하게 하는 등 독립하여 자신의 계산으로 사업을 영위할 수 있는지, 노무제공을 통한 이윤의 창출과 손실의 초래 등 위험을 스스로 안고 있는지, 보수의 성격이 근로 자체의 대상적(대상적) 성격인지, 기본급이나 고정급이 정하여졌는지 및 근로소득세의 원천징수 여부 등 보수에 관한 사항, 근로 제공 관계의 계속성과 사용자에게 대한 전속성의 유무와 그 정도, 사회보장제도에 관한 법령에서 근로자로서 지위를 인정받는지 등의 경제적·사회적 여러 조건을 종합하여 판단하여야 한다.

다만, 기본급이나 고정급이 정하여졌는지, 근로소득세를 원천징수하였는지, 사회보장제도에 관하여 근로자로 인정받는지 등의 사정은 사용자가 경제적으로 우월한 지위를 이용하여 임의로 정할 여지가 크다는 점에서, 그러한 점들이 인정되지 않는다는 것만으로 근로자성을 쉽게 부정하여서는 안 된다(대법원 2006. 12. 7. 선고 2004다29736 판결, 대법원 2007. 9. 7. 선고 2006도 777 판결, 대법원 2010. 4. 15. 선고 2009다99396 판결 등 참조).

나. 이 사건에 관한 판단

1) 업무의 내용

원고가 사업단장 위임계약에 따라 참가인에게 위탁한 업무는 보험계약 체결의 중개 등의 업무도 일부 수행하였으나, 실질적으로 주로 수행한 업무는 사업단장으로서 산하 조직을 구성하기 위한 지점장과 보험설계사의 리크루팅 업무였다. 이러한 리크루팅 업무는 참가인의 직위와 소득을 유지하는데 직접적인 필요가 있었던 것으로 판단된다.

2) 업무수행 과정에서 원고의 지휘·감독 여부

원고의 계약 내용을 살필 때 ① 원고가 사업단장의 업무수행에 관하여 구체적인 지침을 제시하였다거나 업무상 재량을 상당부분 제한한 것이라고 판단하기 어렵고, ② 참가인으로부터 업무수행 내역을 보고할 것을 지시하였다고 보기도 어렵다.

③ 또한 원고는 참가인이 구인사이트에 올린 채용공고의 내용을 확인하거나 감독하지 아니하였고, 이에 관하여 지원자가 항의하고 SBS CNBC에서 민원을 제기하자 사후에 참가인의 문제행위를 인지하였다.

3) 근무시간·장소 등의 지정여부와 구속력의 정도

① 참가인은 원고의 취업규칙에서 정한 채용서류를 구비하거나 근로계약서를 작성하지 않았고, 수습기간도 거치지 않았다. ② 또한 참가인이 취업규칙에서 정한 근로시간 및 출퇴근 시각을 준수하였다고 볼 근거도 없다.

4) 수당 및 지원금 등 소득

참가인에게는 기본급이나 고정급이 정해져 있지 않아 매월 소득금액에 상당한 차이가 있었고, 기본적으로 산하 조직에서 소속 보험설계사들이 달성한 실적에 연동하여 수당 및 수수료, 운영비 등이 지급되는 것으로 약정되어 있었다.

또한 참가인이 원고로부터 실제 지급받은 소득은 주로 사업단장에 대하여 초기 정착을 지원하기 위해 일정 자금을 보장해주는 취지의 지원금이었고, 이 지급에는 일정한 목표를 달성할 것이 조건으로 부가되어 있었으며, 그 지원 기간도 기간이 한정되어 있다.

더욱이 원고는 사업단장이 약정된 목표를 달성하지 못하여 조건에 미달할 경우 지원금을 환수

하고, 사업단장이 1년 이내에 해임될 경우 지급받은 수당 중 한 항목인 오버라이드를 초과하는 금액을 환수하므로 위와 같은 조기 보장 지원금을 기본급의 성격을 가지고 일정하게 지급되었다거나, 근로에 대한 대상적 성격이 있는 것으로 보기는 어렵다.

5) 해촉 및 해임사유

참가인이 원고와 업무제휴 관계에 있는 방송국의 브랜드를 사용하여 허위의 공고를 게재한 행위는 위 각 계약서에 정한 사업단장 해임사유 및 보험설계사 해촉 사유에 해당할 수 있고 이는 원고와 참가인이 체결한 계약의 내용에 따른 결과이므로 그와 같은 조치가 참가인에게 불리한 것이라거나, 원고가 해촉 및 해임 과정에서 '징계'라는 표현을 사용하였다는 사정만으로는 이를 원고가 사용자로서 근로자인 참가인에게 한 '징계조치'에 해당한다고 평가할 수 없다.

6) 기타 사항

참가인이 사업단장 업무를 수행함에 있어 원고의 지휘·감독을 받는 종속적인 관계에 있었다고 보기 어려운 것으로 평가되는 이상, 참가인이 수입을 사업소득으로 신고하고 사업소득세를 납부하여 온 점, 참가인이 고용보험 등 4대 보험에 가입되어 있지 않은 점 등은 원고가 경제적으로 우월한 지위를 이용하여 계약 내용과 무관하게 임의로 정한 것이 아니라 참가인의 노무제공의 실질을 반영한 것으로 볼 여지가 크다.

다. 결국 참가인은 근로기준법상 근로자에 해당하지 않고, 원고가 참가인에게 한 보험설계사 해촉 및 사업단장 해임이 해고에 해당한다고 볼 수 없다.

패소 이유 (사실관계에 관한 인정 차이)

이 사건의 주된 쟁점은 근로계약을 체결하지 아니하고 위촉 계약을 체결한 자의 근로자성이고, 근로기준법상 근로자 판단에 대한 이미 많은 판례군이 존재하여 연구가 많이 이루어져있는 사안이다. 다만, 근로계약을 체결하지 않은 자의 경우 그 계약의 내용 및 실제 업무가 이루어진 행태 등에 따라 구체적인 사실관계 판단이 달라지는 경우가 많다.

이 사건 역시 이 경우 얼마나 정교한 사실관계 조사가 이루어졌는지 당사자들이 충실하게 소명한 정도에 따라 노동위원회와 법원의 판단이 엇갈리게 나온 것으로 판단된다. 즉, 사실관계의 기본 조사 내용은 동일하였으나, 실제 근태관리가 이루어졌는지 여부, 회사가 보험설계사에게 지급한 금액이 지급되는 경위 및 그 성격 등에 대해 법원은 조금 더 구체적으로 살피며 판단할 기회가 있었던 것으로 보이며, 결국 근로자성에 대한 기준 자체를 정형화, 도식화 할 수 없다는 한계에서 발생하는 문제라고 평가된다.

한편, 사실관계를 다룰 수 있는 2심에서도 1심 법원과 같은 판단이 내려졌으므로 무의미한 대법원 항고를 하지 않은 중노위의 결정은 합리적으로 보인다.

일련번호	2021-41
판결번호	서울고등법원 2021. 7. 22. 선고 2020누00000 판결
중노위판정번호	중노위 2019. 9. 26. 2019부해883

부록.1. 주요 사건 경과 및 패소 원인 분석

사건 종류	부당정직					
세부 쟁점	징계, 징계사유, 양정					
심급별 소송결과	1심 법원	재심판정취소	2심 법원	1심 유지	대법원	
상 고 인			참 가 인	(주)○○○씨앤아이		
피상고인			피고측 대리인 선임 여부	선임 안 함		
노동조합 지원 여부	없음		원고측 대리인 선임 여부	선임 함		
재심 결과	초심유지					
초심의 대법원 판례 일치여부	불일치		재심의 대법원 판례 일치여부	불일치		
기타 특이사항						

주요 사실관계
<사건 개요> 가. 원고는 방송프로그램 제작 및 광고 대행업 등 방송 관련 사업을 영위하는 법인이다. 피고보조참가인(이하 '참가인')은 1994. 9. 5. 원고에 입사하였고 2012. 8. 2.부터 2015. 10. 5.까지, 2016. 3. 11.부터 2018. 2. 28.까지 기간 동안 경영기획부 부서장으로 근무하였다. 1) 원고는 2018. 4.경 전임 H 사장 재직 당시 업무직 채용과 관련한 부적절한 채용 지시가 있었다는 의혹이 사내에 확산되고 2018. 2.경 I언론 본사 감사실로 해당 의혹과 관련한 제보가 접수되어, H 사장 취임 이후 입사한 업무직 직원 중 F, G 등 5명에 대한 부적절 채용 의혹 조사를 실시하였다. 2) F은 2012. 8. 28. 계약직 근로자로 원고에 입사하여 전임 대표이사 H의 비서로 근무하다 2014. 8.경 원고의 콘텐츠사업부 '기념품샵 매장 판매관리 업무 책임총괄' 업무직(정규직) 채용절차에 지원하여 2014. 9. 1. 콘텐츠사업부 업무직으로 채용되었다. F은 2014. 11. 7. 경영기획부로 인사이동 발령이 났고 2015. 12. 21. 콘텐츠사업부로 인사이동 발령이 났다. 3) G은 2015. 5. 11. 파견직으로 원고에 입사하여 전임 대표이사 H의 비서로 근무하다 2016. 1. 25. 계약직으로 고용형태가 전환되었고 2017. 2.경 원고의 콘텐츠사업부 '케이블 채널 프로그램 판매' 업무직(정규직) 채용절차에 지원하여 2017. 3. 1. 콘텐츠사업부 업무직으로 채용되었다. G은 2017. 12. 중순 콘텐츠사업부로 자리 이동하여 근무 중에 있다. 4) N은 2014. 8.경 원고의 당시 부사장 V으로부터 D의 이력서를 전달받았고 종전까지 파견근로자가 수행하던 '해외판매 편집' 업무를 계약직 공채로 전환하여 2014. 8.경 D를 계약직 근로자로 선발하였다. D는 2014. 8. 18. 원고에 입사하여 콘텐츠사업부에서 근무하였고, 2015. 8.경 '해외수출지원 편집업무' 업무직(정규직) 경력 공채에 지원하여 2015. 9. 1. 업무직(해외판매)으로 채용되었다. 5) 참가인은 F, G, D의 채용절차에 면접위원으로 참석하여 F, G, D에게 최고점수를 부여하였다. 6) H 전임 대표이사는 N과 참가인에게 E의 이력서를 전달하였고, N과 참가인은 면접을 거쳐

2014. 5.경 '기념품 관련 신상품 개발 계약직 특별채용'으로 E을 선발하였다. E은 콘텐츠사업부에서 2014. 5. 14.부터 2016. 5. 13.까지 근무한 후 계약 만료로 퇴직하였으나, 2016. 5. 23. 마케팅사업부(W 부장)에 프로젝트 계약직으로 특채되어 2017. 5. 22.까지 근무하였다.

7) N은 채용비리 등을 이유로 정직 6개월의 징계처분을 받았다.

8) 참가인은 원고의 행사, 명절 선물, 영업 및 접대 등의 사유로 구매한 상품권 등 유가증권을 비서 F, G의 책상 서랍에 보관하도록 하고 임원, 부서장 등에게 상품권을 지급할 때마다 관리대장을 작성하도록 하였다.

나. 원고 인사위원회는 2019. 1. 8. 참가인에 대한 아래와 같은 징계사유를 심의한 후 '정직 6개월'을 의결하였고, 원고는 2019. 1. 16. 참가인에게 2019. 1. 17.자 '정직 6개월'의 징계처분을 통보하였다.

다. 참가인은 위 정직 6개월의 징계처분에 불복하여 재심신청을 하였고, 원고 재심인사위원회는 2019. 1. 28. 초심 인사위원회의 '정직 6개월'보다 감경된 '정직 4개월'의 징계처분을 의결하고, 원고는 2019. 1. 31. 참가인에게 '정직 4개월' 징계처분을 통보하였다.

라. 참가인은 2019. 4. 2. 경기지방노동위원회에 '이 사건 정직 처분은 부당하다'고 주장하면서 구제신청을 하였다.

<심급별 결과>

[경기지노위] '참가인에 대한 징계사유가 일부 인정되나 그 양정이 과도하여 부당하다'는 이유로 참가인의 구제신청 인용

[중노위] 초심판정과 같은 이유로 재심신청 기각. 초심 유지

[1심 법원] 징계 양정이 과다하지 않고, 징계 사유 중 일부만 인정되는 경우에도 해고가 가능하다는 점을 들어 재심판정

[2심 법원] 1심 판결 유지

판결 요지

(1) 징계사유의 인정 여부

1) 참가인은 부정 채용이 의심됨에도 충분한 검토 없이 F, G, D, E의 채용 절차를 진행하였고 이는 채용 담당 부서장으로서 직무상 관리·감독을 소홀히 한 것으로 징계사유에 해당한다.

가) ① F, G은 전임 대표이사 H의 비서로 근무하던 직원이었다는 점, ② 콘텐츠사업부에서 직원 채용 요청을 하였으나 실제 해당 직무의 추가 채용의 필요성에 대해 의구심이 드는 상황이었었고, 특히 F의 업무직 채용 당시 채용 요청의 근거 중 하나는 '현 기념품샵 판매 인력의 계약이 만료될 예정'이라는 것이었으나 이미 그 후임을 총원하여 업무 인수인계 중이었으며, 이는 직원 채용·인사 관리 등 업무를 관장하는 참가인도 당연히 알고 있었을 것으로 보이는 점, ③ 실제로 F, G은 정규직으로 채용된 후 F은 1년 3개월, G은 9개월 동안 대표이사의 비서 업무를 계속 수행한 점 등에 비추어 보면, 해당 분야에 신규 인력이 필요하여 채용절차를 진행한 것으로 보이지 않고 참가인도 이를 알 수 있었을 것으로 보인다.

나) 원고는 2014년 이후 업무직을 공개채용하면서 일정한 경력을 요구하였는데 F, G을 채용할 때는 경력을 요구하지 않았다. 또한 콘텐츠사업부에서 채용 요청의 근거로 삼은 '지속적인 상품 개발 및 마케팅을 통한 매출 확대를 위한 안정적이고 책임 있는 관리 필요', '영업력 강화를 위한 인력 확충'을 위해서는 경력직 채용을 함이 자연스러운데도 참가인은 아무런 검토 없이 신규

채용을 실시하였다.

다) N은 원고의 2018. 4.경 자체 조사 과정에서 F, G의 채용에 대하여 "H사장이 시키는대로 했다", "(채용에 관한) 모든 것을 경영기획부장(참가인)과 협의하여 진행하였다"고 진술하였다. 경영기획부는 대표이사의 직속 기구로 대표이사를 보좌하는 기능을 하고 있으며 직원의 채용·인사 관리 등에 대한 실무 업무를 담당하고 있다. N이 콘텐츠사업부장으로 H 사장의 지시에 따라 F, G를 채용하기 위해서는 경영기획부장인 참가인의 협조 없이는 불가능하였을 것으로 보이고, 참가인과 대표이사의 지위 및 그 관계에 비추어 참가인은 H, N의 F, G에 대한 채용 계획을 알고 있었을 것으로 보인다.

라) D의 채용 당시 다른 업무직 채용공고에서는 3년의 경력을 요구한 데 반해 N의 요청으로 해외편집 업무만 1년의 경력을 요구하였고, 과거 전공을 우대하여 모집한 적이 없음에도 N의 요청으로 '이공계 우대' 조건을 명시하여 공고하였다. N은 계약직 1년 근무경력이 있고 컴퓨터공학을 전공한 D를 채용하기 위하여 위와 같은 요청을 한 것으로 보이고, 채용 담당 부서장인 참가인은 아무런 검토 없이 다른 업무직 채용공고와 다른 채용 조건을 공고하고 채용절차를 진행하였다.

마) 인사규정 제7조, 제8조 제1항은 직원의 신규채용은 공개경쟁시험에 의하여 채용함을 원칙으로 하면서 '법령에 의한 경우, 임용예정 직무에 관련된 자격증이나 면허증 소지자 기타 해당직무 관련 분야 3년 이상 경력자로서 회사가 필요로 하는 특수직무에 종사할 자를 채용하는 경우, 계약직으로 일정기간 이상 근무한 자 중 근무성적이 우수한 자를 채용하는 경우, 기타 특별채용이 필요한 경우'에 서류심사 등 특별전형에 의하여 채용할 수 있도록 정하고 있다. E은 '관련 자격증이나 면허증 소지자', '해당직무 관련 분야 3년 이상 경력자'에 해당하지 않고 특별채용이 필요한 특별한 사정을 찾을 수 없음에도 특별채용 절차를 통하여 채용되었다.

바) 참가인은 H 전임 대표이사로부터 E의 이력서를 전달받고 2014. 5.경 '기념품 관련 신상품 개발 계약직 특별채용'으로 E을 선발한 전적이 있으므로, 이후 마케팅사업부에서 프로젝트 계약직으로 특별채용을 진행할 때에도 부정 채용을 의심하였을 것으로 보임에도 아무런 검토 없이 E을 채용하였다.

사) 그 외에도 F 등의 채용 과정에서는 모집공고기간이 통상의 경우보다 짧거나 임직원의 추천이 개입되거나 실무면접(또는 실기테스트) 없이 서류전형과 임원 면접만으로 진행되는 등 부정 채용을 의심할 만한 사정이 다수 엿보인다.

2) 참가인이 임원 비서에게 상품권 등 유가증권을 비서의 서랍에 보관하게 한 사실은 당사자 사이에 다툼이 없다.

그러나 ① 원고는 유가증권 관리에 대한 회계규정을 두고 있다고 주장하나 회계규정(갑 제3호증)에는 유가증권의 '보관 방법'에 관한 규정이 없고, 제18조 제1항으로 "출납담당자는 그 취급하는 금전에 대하여 일체의 책임을 진다."고 정하고 있으나 참가인이 관리하는 상품권 등 유가증권의 분실 또는 사고로 인하여 손실이 발생한 적이 없는 점, ② 취업규칙 제71조 제8호는 "직무상 감독 및 관리책임이 있는 자가 필요한 지휘·감독을 소홀히 하여 회사에 손해를 끼치거나 부하의 부정행위를 은폐 또는 묵인하였을 때"를 징계사유로 들고 있는데, 참가인이 상품권 등을 비서의 서랍에 보관하게 한 것을 필요한 지휘·감독을 소홀히 한 것으로 판단하더라도 그 자체로 회사에 손해를 발생시키거나 부하의 부정행위를 은폐 또는 묵인하였다고 볼 수 없는 점, ③ 원고는 참가인이 관리대장을 부실하게 관리하였다는 취지로도 주장하나 원고가 이 사건 정직 처분의 징계사유로 삼은 행위는 '유가증권(상품권)을 임원비서 개인서랍에 보관하게 한 행위'로 관리대장 부실 관리는 포함되지 않는 점 등에 비추어 보면, 참가인이 상품권을 임원비서 서랍에 보관하게 한 것만으로는 징계사유에 해당한다고 보기 어렵다.

(2) 징계양정의 적정 여부

수 개의 징계사유 중 일부가 인정되지 않더라도 인정되는 다른 일부 징계사유만으로도 당해 징계처분의 타당성을 인정하기 충분한 경우에는 그 징계처분을 유지하여도 위법하지 아니하다(대법원 2002. 9. 24. 선고 2002두6620 판결, 대법원 2004. 11. 12. 선고 2002두11813 판결 등).

이 사건 정직 처분의 징계사유 중 제1, 2 사유만 인정된다고 하더라도, 이 사건 정직 처분이 객관적으로 명백히 부당하여 사회통념상 현저하게 타당성을 잃어 징계재량권을 일탈·남용하였다고 보기 어렵다.

가) 참가인은 경영기획부장으로 직원 채용 및 인사사고와 관련 제업무, 자금관리 업무 등을 총괄하여 관장하는 지위에 있다. 부서별 분장업무의 최종결정권자는 원고의 대표이사이고 직원의 채용기준과 방법, 절차 및 채용인원 등 채용에 관한 구체적인 사항은 대표이사가 정하도록 되어 있으나, 경영기획부는 대표이사 보좌 및 경영전략기능의 원활한 수행을 위한 사장 직속기구이고 직원 채용 등에 관한 실무 업무를 담당하는 것은 경영기획부이다. 경영기획부장인 참가인은 채용에 관한 구체적인 사항을 기획하고 채용절차를 진행함에 있어 공정성 및 객관성을 준수하여야 하고 부정 채용이 의심될 경우에는 검토를 거쳐 채용 실시 여부에 대한 의견을 개진하여야 한다.

나) 참가인은 전임 대표이사의 지시로 인한 F, G의 채용 계획을 알고 있었던 것으로 보이고 전임 대표이사로부터 E의 이력서를 직접 전달받은 적도 있었으며 그 외에도 F 등의 채용 과정에서 부정 채용을 의심할 만한 사정이 많았음에도 아무런 검토를 거치지 않고 채용을 실시하였다. 이는 원고의 명예와 대외적 신뢰도의 훼손으로 이어지고 다수의 채용 지원자에게 불신과 좌절감을 주는 행위로 그 비위의 도가 중하다.

다) 참가인의 위와 같은 행위는 F 채용 시인 2014. 9.경부터 G 채용 시인 2017. 3.경까지 지속되었고, 모집공고기간이 통상의 경우보다 짧거나 실무면접(또는 실기테스트)을 생략하는 등 기존의 원고의 채용 관행과 다른 행태로 진행되었으며, 참가인이 직접 면접에 참석하여 부정 채용이 의심되는 지원자들에게 최고 점수를 부여함으로써 채용에 상당한 영향력을 행사하였다는 점에서 비난가능성이 크다.

라) N은 F, G이 채용된 콘텐츠사업부의 부서장으로 F 등에 대한 부정채용에 관여하였다는 징계사유로 정직 6개월의 징계처분을 받았다. 참가인은 직원 채용 전반을 총괄하는 경영기획부장으로 사업부서의 장인 N의 지위와 비교할 때 결코 낮지 않고, H, N의 F 등에 대한 채용 계획을 알고 있었거나 알 수 있었음에도 위 계획에 적극 협조하고 아무런 검토 없이 F 등의 채용 절차를 진행하였다는 점에서 그 가담정도도 가볍지 않다.

패소 이유 (사실관계에 관한 인정 차이)

이 사건은 사실관계는 동일하지만, 그에 대한 법리적 판단의 결과가 달라진 사건이다. 노동위원회는 징계의 사유가 일부 인정되지만, 양정 결과 해고에 이를 정도의 비위행위는 아니라고 판단하여 징계가 부당하다고 판정했다.

그러나, 법원은 징계사유의 정당성을 인정했다. 특히, 징계 사유 중 일부만 인정된 경우에도 그것만으로 징계해고 결정을 할 수 있다는 이전 판례의 견해를 재확인했다. 새롭게 제시된 사실관계나 증거는 없으나, 그에 대한 판단이 달라진 것은 사실관계에 대한 법리적용에 있어 공익위원의 전문성이 문제가 있다는 것을 나타낸다고 볼 수 있다. 새롭게 제시된 사실관계가 없음에도 불구하고 참가인에 대한 징계사유가 충분히 인정될 수 있었기 때문이다.

1심 법원 판결 이후 중노위가 항소했으나, 2심 법원 판결을 통해 패소한 이후 상고하지 않은 것은 합리적인 결정이었다고 사료된다.

부록.1. 주요 사건 경과 및 패소 원인 분석

일련번호	2021-42					
판결번호	서울행정법원 2021. 7. 22. 선고 2019구합0000					
중노위판정번호	중노위 2019. 8. 7. 중앙2019부해670					
사건 종류	부당해고					
세부 쟁점	근로기준법상 근로자성					
심급별 소송결과	1심 법원	재심취소	2심 법원	-	대법원	-
피고	중앙노동위원회위원장		피고 보조참가인		○○○○○경매 주식회사 ⁸³⁾	
원고	1. 박○○ / 정○○		피고측 대리인 선임 여부		선임안 함	
노동조합 지원 여부	없음		원고측 대리인 선임 여부		선임안 함	
재심 결과	초심유지					
초심의 대법원 판례 일치여부	불일치		재심의 대법원 판례 일치여부		불일치	
기타 특이사항	1심에서 확정된 사건임.					

주요 사실관계 <사실관계> 가. 피고보조참가인(이하 ‘참가인’)은 부동산 매매 및 분양대행업 등을 영위하는 회사이다. 나. 원고 박○○은 2018. 1. 5. 원고 정○○은 2018. 2. 6. 각 참가인과 사이에 ‘업무 위탁 계약’이라는 제목의 계약(이하 ‘이 사건 계약’이라고 한다)을 체결하고, 그때부터 참가인의 영업부 담당자로서 부동산 판매 영업 업무를 하였다. 다. 참가인은 2018. 11. 8.경 원고들에게 근무태만 등을 이유로 해고통지(이하 ‘이 사건 통지’라고 한다)를 보냈다. 라. 참가인은 원고의 위 통지가 부당해고에 해당한다고 주장하며 2019. 3. 7. 서울지노위에 구제신청을 하였다. <심급별 결과> [서울지노위] ‘원고들은 참가인의 근로자에 해당하지 않는다’는 이유로 원고들의 구제신청을 각하 [중노위] 위 초심판정과 동일한 이유로 원고의 재심신청을 기각 [1심 법원] 참가인은 근로기준법상 근로자에 해당하고, 이 사건 통지는 참가인이 원고들과 사이

83) 1심 : 법무법인 일호

의 근로관계를 정당한 사유 없이 일방적으로 종료시킨 부당해고에 해당하므로 이 사건 재심판정은 위법하여 취소되어야 한다고 판시, 이대로 확정

판결 요지

가. 원고들이 근로기준법상의 근로자인지 여부에 관한 일반법리

근로기준법상의 근로자에 해당하는지 여부는 계약의 형식이 고용계약인지 도급계약인지보다 그 실질에 있어 근로자가 사업 또는 사업장에 임금을 목적으로 종속적인 관계에서 사용자에게 근로를 제공하였는지 여부에 따라 판단하여야 한다.

여기에서 종속적인 관계가 있는지 여부는, ① 업무 내용을 사용자가 정하고 ② 취업규칙 또는 복무(인사)규정 등의 적용을 받으며 ③ 업무 수행 과정에서 사용자가 상당한 지휘·감독을 하는지, ④ 사용자가 근무시간과 근무장소를 지정하고 근로자가 이에 구속을 받는지, ⑤ 노무제공자가 스스로 비품·원자재나 작업도구 등을 소유하거나 제3자를 고용하여 업무를 대행하게 하는 등 독립하여 자신의 계산으로 사업을 영위할 수 있는지, ⑥ 노무제공을 통한 이윤의 창출과 손실의 초래 등 위험을 스스로 안고 있는지, ⑦ 보수의 성격이 근로 자체의 대상적(대상적) 성격인지, ⑧ 기본급이나 고정급이 정하여졌는지 및 ⑨ 근로소득세의 원천징수 여부 등 보수에 관한 사항, ⑩ 근로 제공 관계의 계속성과 사용자에게 대한 전속성의 유무와 그 정도, ⑪ 사회보장제도에 관한 법령에서 근로자로서 지위를 인정받는지 등의 경제적·사회적 여러 조건을 종합하여 판단하여야 한다.

다만, 기본급이나 고정급이 정하여졌는지, 근로소득세를 원천징수하였는지, 사회보장제도에 관하여 근로자로 인정받는지 등의 사정은 사용자가 경제적으로 우월한 지위를 이용하여 임의로 정할 여지가 크다는 점에서, 그러한 점들이 인정되지 않는다는 것만으로 근로자성을 쉽게 부정하여서는 안 된다(대법원 2006. 12. 7. 선고 2004다29736 판결, 대법원 2007. 9. 7. 선고 2006도 777 판결, 대법원 2010. 4. 15. 선고 2009다99396 판결 등 참조).

나. 이 사건에 관한 판단

다음과 같은 점을 고려해볼 때 원고들은 참가인의 근로자라고 봄이 상당하다.

① 참가인은 원고들의 근무장소를 지정하였고, 원고들이 사무실 밖으로 출장 또는 외출을 할 때에는 참가인에게 외출신청서를 제출하여 허가를 받아야 하였다.

② 참가인은 원고들의 근무일 및 근무시간도 지정하였고, 원고들이 사무실에 나올 때마다 출근부에 서명하라고 하는 등 업무시간을 통제하였으며, 사무실에 원고들이 불출석하는 경우 1인당 벌금을 징수하되 3회 불출석시에는 퇴사조치를 취하겠다고 공고하는 등으로 근태관리를 하였다.

③ 참가인은 원고들에게 업무 진행 상황에 대하여 일일 업무일지를 작성하여 보고하도록 함으로써 단순히 '위임사무의 처리상황을 파악'하는 것에서 나아가 '원고들의 업무 수행을 지속적으로 감독'하였다.

④ 이 사건 계약에 따르면 참가인은 원고들에게 부동산 판매에 관한 업무 일체를 위임한 것으로 보이나 정작 판매 대상이 되는 부동산의 주소지를 모두 가르쳐 주지 않아 사실상 원고들은 참가인이 제공한 시나리오의 내용대로 고객들에게 전화하여 참가인의 영업을 홍보하는 등의 기계적인 업무를 수행하였다고 보인다.

⑤ 이 사건 계약 기간 동안 원고들은 매달 판매실적의 증감과는 무관하게 근무일수에 비례하여 금원을 지급받은 바 이 금원은 근로의 대가인 보수의 성격을 띠고 있다.

⑥ 참가인은 성과급의 액수가 기본급에 비하여 압도적으로 많으므로 전체적으로 보아 원고들

은 근로에 대한 보수를 받은 것이 아니라 업무의 결과에 따라 이윤을 창출하였다고 보아야 한다고 주장하나, 원고들의 받는 성과급의 액수는 ㉔ 부동산 계약 체결 건수, ㉕ 부동산의 계약 대금, ㉖ 수수료율의 3가지 요인으로 결정되는데, 그 중 원고들이 좌우할 수 있는 것은 오직 부동산 계약 체결 건수에 불과하였다는 점에서도 실제 원고들이 여느 사업자처럼 이윤을 조절하거나 창출하는 지위에 있었다고 평가할 수는 없다.

㉗ 피고는 원고들이 이 사건 계약 기간 동안 참가인 뿐 아니라 제이경매 주식회사로부터도 보수를 지급받았다는 점을 들어 원고들이 특정 회사에 전속되어 있지 않았다고 보았으나, 제이경매 주식회사는 법인별 매출액을 분산시켜 세금 부담을 줄이려는 목적으로 설립된 회사들로서 실적으로 동일한 사업체를 구성하고 있다고 보이므로, 피고가 들고 있는 근거로는 원고의 전속성을 부정하기 어렵다.

㉘ 이 사건 통지의 제목이 ‘해고통지서’라는 점 등 해고통지서의 형식과 내용 및 발송 시점에서 ‘원고들은 실적을 올리는 것 뿐 아니라 사내 규율과 질서에 따라야 할 의무까지 있고, 그 대신 계약의 해소 과정에서 근로기준법의 두터운 보호를 받는 근로자에 해당한다’는 참가인의 인식이 고스란히 드러났다고 보인다.

다. 결국 원고들은 근로기준법상 근로자에 해당하고, 참가인이 원고들에게 한 통지가 해고로서 정당한 사유가 없는 이상 부당해고에 해당하므로 이와 다른 결론을 내린 이 사건 재심판정은 위법하므로 취소되어야 한다.

패소 이유 (사실관계에 관한 인정 차이)

이 사건의 주된 쟁점은 근로계약을 체결하지 아니하고 위탁 계약을 체결한 자의 근로자성 인정 여부이다.

중노위는 다음과 같은 점을 들어 원고들의 근로자성을 인정하지 않았는데, 근거로 드는 내용들을 살펴볼 때 동일한 사실관계를 어떻게 해석하느냐에 따라서 결과가 엇갈린 전형적인 사례라고 판단된다.

“① 매각할 부동산을 정해진 금액에 따라 매각하면 되었을 뿐, 부동산 매각 업무와 관련하여 사용자로부터 구체적인 지시를 받지 않고 부동산 매각 대금의 일부를 지급 받았다는 점, ② 복무에 관한 규정이 없고 사용자가 근로자들의 복무관리 등을 하지 않았다는 점, ③ 근로자들이 영업지원비 명목으로 매월 고정적으로 받던 금원이 판매 위탁 보수에 비해 기본 영업활동비 수준에 불과하다는 점, ④ 부동산 매각 업무를 수행하면서 부동산 소유자인 두 개의 법인으로부터 사업소득을 수령 받는 등 특정 법인에 전속되지 않았다는 점, ⑤ 근로자들은 고용보험 등 4대 보험 피보험자로 되어있지 않았고, 4대 보험에 가입되어 있지 않은 것과 업무 위탁계약에 따라 사업소득 형태로 수령 하는 것에 대하여 사용자에게 아무런 이의를 제기하지 않았다는 점 등”

다만 판결문에 따르면 노동위원회의 사실관계 파악이 미진한 점이 있었다는 것을 알 수 있는바, 위 ④ 특정법인에 전속되지 않았다는 점에 대해서는 실제로 해당 법인이 소득의 분산을 위해 만든 법인이라는 사정이 있었고, 법원은 이를 지적하며 이러한 점에서도 원고들의 근로자성을 인정하였다. 즉, 판단 주체에 따라 동일한 사실관계를 해석하는 관점이 달라지는 점뿐만 아니라, 실제 판단을 위한 정교한 사실관계의 조사가 미흡했음이 드러나는 사건이라고 생각된다.

일련번호	2021-44					
판결번호	서울고등법원 2021. 7. 22. 선고 2021누00000					
중노위판정번호	중노위 2020. 1. 6. 중앙2019부해1461					
사건 종류	부당해고					
세부 쟁점	징계해고-절차					
심급별 소송결과	1심 법원	재심판정취소	2심 법원	1심판결 유지	대법원	-
원고, 피항소인	충청남도 ○○의료원		피고보조참가인		1. 류○○ / 이○○	
피고, 항소인	중앙노동위원회위원장		피고측 대리인 선임 여부		선임 안 함	
노동조합 지원 여부	없음		원고측 대리인 선임 여부		선임	
재심 결과	초심 유지					
초심의 대법원 판례 일치여부	불일치		재심의 대법원 판례 일치여부		불일치	
기타 특이사항						

주요 사실관계 <사실관계> 가. 충청남도 ○○의료원(이하 ‘○○의료원’)은 공공보건의료를 담당하는 공공병원으로 장례식장을 운영하고 있다. 나. 류○○은 2013. 1. 2. ○○의료원에 입사하여 2016. 9. 28.부터 장례식장 실장으로 근무해 온 기술직 6급 직원이고, 이□□는 2016. 12. 22. ○○의료원에 입사하여 장례식장 장례지도사로 근무해 온 기능직 9급 직원이다. 다. 충청남도 ○○의료원장은 2019. 3. 19. 징계위원회에 류○○은 금품 등의 수수금지 의무 위반으로, 이□□는 임직원 행동강령 위반으로 각 징계의결을 요구하였고, ○○의료원은 2019. 5. 31.자 류○○과 이□□에게 해임(이하 ‘이 사건 해임’) 및 징계부가금 310만 원을 의결하였으며, 2019. 4. 29. 류○○, 이□□에게 각 징계처분을 통지하였다. 라. 류○○과 이□□는 2019. 5. 31. 이 사건 해임이 부당해고에 해당한다고 주장하며 충남지노위에 구제신청을 하였다. <심급별 결과> [충남지노위] 이 사건 해임은 재심절차에서 단체협약이 정한 징계위원회 구성 규정을 준수하지 아니하여 징계절차에 중대한 하자가 있다는 이유로 참가인들의 구제신청을 인용 [중노위] 재심 신청 기각
--

[1심 법원] 이 사건 해임의 징계절차에 위법이 인정되지 아니하고, 징계재량권의 일탈·남용이 인정되지 않아 징계양정도 적정하므로 이 사건 재심판정은 위법하여 취소되어야 한다고 판시
 [2심 법원] 1심 판결과 같은 결론으로 이 사건 재심판정은 위법하여 취소되어야 한다고 판시하였다.

판결 요지

가. 징계사유의 인정여부

류○○, 이□□가 장례식장의 실장과 장례지도사로 근무하면서 공모하여 장례식장에 떡을 납품하는 업체로부터 매출액의 일부를 정기적으로 지급받아 합계 300만 원을 초과하는 금품을 교부받은 행위는 부정청탁 및 금품 등 수수의 금지에 관한 법률 제8조 제1항, ○○의료원의 임직원 행동강령 제37조 제1항을 위반하여 ○○의료원 인사규정 제55조 제1호, 제4호에 해당한다. 따라서 이 사건 해임의 징계사유가 인정된다.

나. 징계절차의 적법 여부

단체협약은 노사 간의 집단적인 법률관계를 규정하는 성격을 지니고 있으므로 명확한 증거가 없는 한 그 문언의 객관적 의미를 존중하여 해석하여야 한다(취업규칙에 관한 대법원 2003. 3. 14. 선고 2002다69631 판결 취지 참조). 원고의 인사규정에서 징계위원회와 재심위원회의 구성방법에 관하여 명시적으로 달리 규정하고 있고, 노사간 작성된 1995년 공동합의서와 2002년 단체협약에서도 징계위원회에 관하여만 정하면서 그 내용도 징계위원회에 관한 인사규정 조항과 거의 동일하게 규정하였다. 만일 이 사건 노사합의서 조항을 둔 이유가 인사규정보다 근로자에게 유리하게 재심위원회에도 징계위원회와 같은 구성방법을 적용하기 위함이었다면 그러한 취지가 분명하게 드러나도록 조항 문구를 마련하였을 것이나, 그렇지 않았다는 점에서 이 사건 노사합의 조항의 목적이 재심위원회의 구성을 인사규정과 달리 정하려는 취지였다고 보기 어렵다.

그런데도 이 사건 노사합의서 조항에서 정한 징계위원회의 구성방법이 인사규정의 내용보다 우선하여 재심위원회의 구성에도 적용된다고 해석하는 것은 문언의 객관적 의미를 벗어나는 해석이라고 보이고, 달리 ○○의료원도 이 사건 산변로조의 의사가 그와 같은 내용으로 합치되었다거나 징계절차의 재심위원회 구성에 관하여 그러한 관행이 원고에게 존재하여 왔다고 볼 만한 사정도 찾아볼 수 없다. 재심 징계절차가 초심 징계절차와 같은 사안에 대한 일련의 징계절차 진행 과정에 있다는 사정만으로는, 불명확한 노사합의서 및 단체협약의 규정을 징계위원회와 재심위원회 구성에 관하여 연속적으로 동일한 방식이 적용되는 방향으로 해석해야 할 논리적 필연성을 인정하기 어렵다.

따라서 이 사건 노사합의서 조항 및 그와 동일한 내용의 이 사건 단체협약 조항은 재심위원회의 구성에 관하여 정한 것이라고 볼 수 없으므로, 원고가 참가인들에 대한 재심위원회를 사측 위원 5인, 노측 위원 2인으로 구성한 것이 이 사건 노사합의서 조항 및 이 사건 단체협약 조항을 위반한 것이라고 볼 수 없다.

한편, 근로자들에 대한 재심위원회가 인사규정이 정하고 있는 5인의 위원보다 많은 7인으로 구성되기는 하였으나, ①인사규정에서는 재심위원회에 노측 위원의 참여에 관하여 정하고 있지 않음에도 공주의료원이 노측 위원 2인을 재심위원회 위원으로 추가 선임한 것은 근로자에게 유리하게 재심을 시행하려 한 것이라고 보이는 점, ② ○○의료원지부의 불참으로 인하여 결과적으로 재심위원회의 구성대로 개최된 점을 고려하며, 재심의 효력을 인정할 수 없을 정도로 재심절차에 중대한 하자가 있다고 보기는 어렵다(대법원 1998. 12. 8. 선고 98다31172 판결 참조).

다. 징계양정의 적정 여부

피징계자에게 징계사유가 있어서 징계처분을 하는 경우, 어떠한 처분을 할 것인지는 징계권자의 재량에 맡겨져 있다. 다만 징계권자의 징계처분이 사회통념상 현저하게 타당성을 잃어 징계권자에게 맡겨진 재량권을 남용하였다고 인정되는 경우에 한하여 그 처분이 위법하다고 할 수 있다(대법원 2005. 4. 29. 선고 2004두10852 판결 등 참조). 한편 해고처분은 사회통념상 고용관계를 계속할 수 없을 정도로 근로자에게 책임 있는 사유가 있는 경우에 정당성이 인정되고, 사회통념상 근로자와 고용관계를 계속할 수 없을 정도인지는 사용자의 사업 목적과 성격, 사업장의 여건, 근로자의 지위와 담당직무의 내용, 비위행위의 동기와 경위, 근로자의 행위로 기업의 위계질서가 문란하게 될 위험성 등 기업질서에 미칠 영향, 과거의 근무태도 등 여러 가지 사정을 종합적으로 검토하여 판단하여야 한다(대법원 2002. 5. 28. 선고 2001두10455 판결 등 참조).

① ○○의료원의 직원들은 공직유관단체의 직원으로서 부패 방지를 위해 공정하고 청렴하게 직무를 수행하여야 할 책임이 있음에도 류○○은 장례식장 실장으로서 장례식장에 납품되는 각종 물품을 관리하는 지위에 있음을 이용하여 납품업체에게 적극적으로 금품의 지급을 요구하였고, 이□□는 장부를 작성하며 수수한 금품을 관리하였으며, 약 6개월 간 지속적으로 납품 매출액의 일정 비율을 수수하며 수수한 금품의 금액도 합계 300만 원 이상으로 적지 않다는 점, ② 류○○의 경우 2018. 2. 19. 공주의료원으로부터 주의 처분을 받은 전력이 있고, 이 사건 해임의 징계사유에 관한 조사 및 수사 과정에서 2017년에 떡집 외에도 예복, 꽃, 과일 등의 장례식장 납품업체에서 각 2-3회에 걸쳐 각 업체당 합계 40만 원에서 80만 원의 금품을 수수한 사실을 자인한 바 있다는 점, ③ ○○의료원의 징계양정에 관한 규칙 등에 따르면 청렴의무 위반 행위에 관하여 비위의 도가 중하고 고의가 있는 경우 ‘파면’의 징계를, 비위의 정도가 경하고 고의가 있는 경우 ‘해임’의 징계를 규정하고 있는 등으로 살펴보면 근로자들에 대하여 해임의 징계를 한 것은 ○○의료원이 정한 징계양정기준에 부합하거나 오히려 더 경한 수준의 징계에 해당한다는 점 등을 고려해보면 이 사건 해임의 징계재량권의 일탈이나 남용이 인정되지 않는다.

결국 이 사건 해임의 징계절차에 위법이 인정되지 아니하고, 징계재량권의 일탈·남용이 인정되지 않아 징계양정도 적정하므로 이와 달리 판단한 이 사건 재심판정은 위법하여 취소되어야 한다.

패소 이유 (단체협약 해석의 차이)

이 사건은 같은 단체협약의 해석에 있어 노동위원회와 법원의 판단이 정반대로 달랐기 때문에 이로 인해 결과가 뒤바뀐 사안이다.

노동위원회와 법원 모두 사실관계에 있어서는 크게 차이점이 없으나 그 사실관계를 어떻게 판단하였는가, 해석의 정도와 입증의 정도 등에서 차이가 발생하였다. 법원은 단체협약의 해석에 있어 그 간 단체협약이 개정된 연혁과 과정, 관련한 인사규정등의 변화 등을 종합적으로 고려하여 문언 그대로의 해석 방식을 취하였고, 또한 각 당사자가 주장한 사실관계에 관한 입증에 있어서도 객관적인 입증이 되었는가를 기준으로 판단하였다고 볼 수 있다.

즉, 재심판정은 징계절차도 위법할 뿐만 아니라 징계양정에서도 과하다고 판단하여 법원의 판단과 다른 태도를 취하고 있는데, 그 이유로 “근로자들의 비위행위가 본인들의 사익을 추구하기보다는 회사의 관행에 따라 장례식장 매출 신장을 위해 노력하는 과정에서 발생한 것이므로 비위행위의 동기와 경위”를 들고 있으나 법원은 이에 대해 객관적으로 인정하기 부족하다는 이유로 징계 양정 역시 적정하다고 판단하였다.

이와 같은 차이점은 판단주체의 역량, 절차에 소요되는 절대적인 기간의 차이 및 도식과 객관화하기 힘든 판단 기준 등에 기인한 것으로 판단된다.

부록.1. 주요 사건 경과 및 패소 원인 분석

일련번호	2021-49					
판결번호	서울고등법원 2021. 9. 1. 선고 2021누00000 부당해고구제재심판정취소					
중노위판정번호	중노위 2020. 1. 13. 2019부해1473					
사건 종류	기간제					
세부 쟁점	기간제, 갱신기대권					
심급별 소송결과	1심 법원	재심판정취소	2심 법원	1심판결 유지	대법원	-
원고, 피항소인	○○시		피고보조참가인		박○○, 이○○	
피고, 항소인	중앙노동위원회위원장		피고측 대리인 선임 여부		선임 안 함	
노동조합 지원 여부	없음		원고측 대리인 선임 여부		선임	
재심 결과	초심 유지					
초심의 대법원 판례 일치여부	불일치		재심의 대법원 판례 일치여부		불일치	
기타 특이사항	2017. 공공부문 비정규직 근로자 정규직 전환 가이드라인 해석이 쟁점임					

주요 사실관계
<사실관계> 가. ○○시는 2016. 6. 1. 관내 CCTV를 통합 관리하기 위하여 ○○시 통합관제센터(이하 ‘이 사건 센터’라 한다)를 설치하였고, 근로계약기간을 1년으로 하여 이 사건 센터에 근무할 36명의 관제요원을 채용하였다. 나. 근로자 박○○, 이○○(이하 ‘이 사건 근로자들’)이 사건 근로자들은 ○○시와 사이에 이 사건 센터의 방범·어린이보호 등 CCTV 모니터링 등 상황보고 업무에 관하여, 근로자 박○○(이하 ‘이 사건 근로자1’)은 계약기간을 2017. 6. 1.부터 2018. 5. 31.까지 및 2018. 6. 1.부터 2019. 5. 31.까지, 근로자 이○○(이하 ‘이 사건 근로자2’)은 계약기간을 2017. 7. 17.부터 2018. 7. 16.까지 및 2018. 7. 17.부터 2019. 7. 16.까지로 한 각 근로계약을 체결하였다(이하 ‘이 사건 각 근로계약’). 다. ○○시는 2019. 4. 26. 이 사건 근로자1에게 2019. 5. 31.자로 이 사건 센터에서의 근로계약이 2년 계약만료로 종료된다고 통보하였고, 2019. 6. 11. 이 사건 근로자2에게 2019. 7. 16.자로 이 사건 센터에서의 근로계약이 2년 계약만료로 종료된다고 통보하였다(이하 각 근로계약 종료를 통틀어 ‘이 사건 각 근로계약 종료’라 한다). 라. 이 사건 근로자들은 경북지노위에 이 사건 각 근로계약에 대한 갱신기대권이 있고, 이 사건 근로자들의 업무는 정규직으로 전환되어야 하므로 ○○시가 이 사건 각 근로계약을 종료한 것은 부당해고에 해당한다고 주장하며 구제를 신청하였다.

<심급별 결과>

[경북지노위] 이 사건 근로자들에게 이 사건 각 근로계약의 갱신기대권과 정규직 전환기대권이 있고, ○○시가 이 사건 근로자들의 근로계약 갱신 및 정규직 전환을 거절한 데 합리적인 이유가 없다는 전제 하에 ‘이 사건 각 근로계약 종료는 부당해고임을 인정하고, 이 사건 근로자들을 원직에 복직시키고 해고기간에 정상적으로 근로하였다면 받을 수 있었던 임금상당액을 지급하라’구 제신청 인용

[중노위] 초심판정과 같은 취지로 원고의 재심신청을 기각

[1심 법원] 이 사건 근로자들에게 근로계약 갱신 또는 정규직 전환 기대권이 있다거나, 그 갱신 거절에 합리적 이유가 없다고 보기 어려우므로, 기간제근로자인 이 사건 근로자들에 대한 근로관계 종료는 부당해고에 해당하지 않는다고 판시

[2심 법원] 1심 법원과 같은 판단을 하였고 이대로 확정

판결 요지

가. 이 사건 근로자들에게 근로계약 갱신에 대한 정당한 기대권이 인정되는지 여부

기간을 정하여 근로계약을 체결한 근로자의 경우 그 기간이 만료됨으로써 근로자로서의 신분관계는 당연히 종료되는 것이 원칙이다. 그러나 근로계약, 취업규칙, 단체협약 등에서 기간만료에도 불구하고 일정한 요건이 충족되면 당해 근로계약이 갱신된다는 취지의 규정을 두고 있거나, 그러한 규정이 없더라도 당해 근로관계를 둘러싼 여러 사정을 종합하여 볼 때 근로계약 당사자 사이에 일정한 요건이 충족되면 근로계약이 갱신된다는 신뢰관계가 형성되어 있어 근로자에게 그에 따라 근로계약이 갱신될 수 있으리라는 정당한 기대권이 인정되는 경우에는 사용자가 이에 위반하여 부당하게 근로계약의 갱신을 거절하는 것은 부당해고와 마찬가지로 아무런 효력이 없고, 이 경우 기간만료 후의 근로관계는 종전의 근로계약이 갱신된 것과 동일하다. 마찬가지로 근로계약, 취업규칙, 단체협약 등에서 기간제근로자의 계약기간이 만료될 무렵 인사평가 등을 거쳐 일정한 요건이 충족되면 기간의 정함이 없는 근로자로 전환된다는 취지의 규정을 두고 있거나, 그러한 규정이 없더라도 근로계약의 내용과 근로계약이 이루어지게 된 동기와 경위, 기간의 정함이 없는 근로자로의 전환에 관한 기준 등 그에 관한 요건이나 절차의 설정 여부 및 그 실태, 근로자가 수행하는 업무의 내용 등 당해 근로관계를 둘러싼 여러 사정을 종합하여 볼 때, 근로계약 당사자 사이에 일정한 요건이 충족되면 기간의 정함이 없는 근로자로 전환된다는 신뢰관계가 형성되어 있어 근로자에게 기간의 정함이 없는 근로자로 전환될 수 있으리라는 정당한 기대권이 인정되는 경우에는 사용자가 이를 위반하여 합리적 이유 없이 기간의 정함이 없는 근로자로의 전환을 거절하며 근로계약의 종료를 통보하더라도 부당해고와 마찬가지로 효력이 없고, 그 이후의 근로관계는 기간의 정함이 없는 근로자로 전환된 것과 동일하다고 보아야 한다(대법원 2016. 11. 10. 선고 2014두45765 판결 등 참조).

다음과 같은 사정을 위 법리에 비추어 보면, 이 사건 근로자들에게 ○○시와 사이에 일정한 요건이 충족되면 근로계약이 갱신된다는 신뢰관계가 형성되어 있었다고 볼 수 없으므로, 이 사건 근로자들에게 근로계약이 갱신에 대한 정당한 기대권이 인정되지 아니한다.

① ○○시는 이 사건 센터의 관제요원이 기간제법 제4조 제1항 단서 각 호의 예외에 해당하지 않는다는 전제 하에, 관제요원을 2년을 초과하여 근로하게 하는 경우 기간의 정함이 없는 근로자로 전환되는 부담이 있는 등의 이유로 이 사건 센터의 관제인력운영 계획수립단계부터 채용공고 초안, 실제 채용공고, 근로계약체결에 이르기까지 2년을 관제요원 근로계약기간의 상한으로 하고 있다는 점,

② ○○시는 이 사건 센터 관제요원의 채용공고 제목 및 내용에 관제요원을 ‘기간제근로자’로 채용한다고 기재하고, 근로계약기간을 1년으로 정하였는데 기간제근로자로 근로 가능한 기간의

상한이 2년이므로, ○○시는 이 사건 센터가 아니더라도 과거 ○○시와 1년 이상의 근로계약관계에 있었던 사람은 응시할 수 없다는 문구도 기재하였다. 즉, 비록 기간제법 제4조 제1항에서 '계속근로한 총기간'이 2년을 초과할 수 없다고 규정하고 있기는 하나, ○○시는 이와 관련된 문제 발생을 미연에 방지하기 위하여 계속근로 여부를 불문하고 원고와 근로계약을 체결한 기간의 합계가 2년을 초과하지 않도록 한 것으로 보인다는 점,

③ 이 사건 각 채용공고에 '계약연장가능' 또는 '1년 연장가능'이라는 문구가 기재되어 있기는 하나, 이는 근로자에게 계약연장을 보장한 경우와는 내용을 달리하는 것이고, 연장의 구체적 기준에 관한 언급이 없는 점을 고려하여 보면 ○○시의 연장의사에 따라 계약연장이 가능하다고 해석되므로, 결국 ○○시의 계약갱신 내지 재계약의무를 규정한 것이 아니라 계약갱신 여부에 관한 ○○시의 재량을 규정한 것이라고 보아야 한다. 이에 더하여 위 채용공고에서 '기간제근로자'를 채용한다고 명시한 점 등에 비추어 보면, 위 계약연장은 기간제근로자로서 근로가능한 기간의 상한인 2년의 범위 안에서 최초 1년 계약 후 추가 1년 연장이 가능하다는 취지로 해석함이 타당하다. 따라서 위 문구는 근로계약 갱신에 대한 신뢰관계 형성의 기초가 될 수 없다는 점,

④ ○○시는 이 사건 각 근로계약 종료 이전에 이 사건 센터 관제요원과 계약연장을 포함하여 2년을 초과하여 근로계약을 체결하거나, 이들을 정규직 근로자로 전환시킨 사례가 없고, 특히 이 사건 센터에서 관제요원으로 근무하기 전 ○○시 소속 주민센터에서 9개월 동안 기간제근로자로 근무한 이력이 있던 윤○○과는 1년 3개월만에 이 사건 센터 관제요원으로서의 근로계약을 종료하여 총 근로기간이 2년을 넘지 않도록 하였다. 이 사건 근로자들 또한 기간제법 시행 이후 기간제근로자 근로계약을 체결하였으므로, 2년을 초과하는 근로계약 갱신이 당연히 가능하다고 기대하였다고 보기 어렵다는 점 등

나. 이 사건 근로자들에게 기간의 정함이 없는 근로자로의 전환에 대한 정당한 기대권이 인정되는지 여부

다음과 같은 사정을 고려해본다면, 이 사건 근로자들에게 ○○시와 사이에 일정한 요건이 충족되면 기간의 정함이 없는 근로자(정규직 또는 공무원근로자)로 전환된다는 신뢰관계가 형성되어 있었다고 볼 수 없으므로 이 사건 근로자들에게 정규직 전환에 대한 정당한 기대권이 인정되지 아니한다.

① 이 사건 지침은 상시·지속적 업무를 수행하는 기간제근로자는 원칙적으로 정규직 전환 대상에 해당한다고 규정하고 있고, 이 사건 센터의 관제요원은 상시·지속적 업무를 수행하는 기간제근로자에 해당하지만, 이 사건 정부 지침은 지방자치단체에 대하여 비정규직의 정규직 전환에 대하여 전환을 적극적으로 권고하면서 전환범위, 전환방식, 채용방법을 자율적으로 결정하도록 재량을 부여하고 있다고 봄이 상당하고, 위 지침만으로 위 지침 발표 당시 기간제근로자였던 이 사건 근로자들에게 정규직 전환에 대한 정당한 기대권이 부여된다고 보기는 어렵다는 점,

② 또한 이 사건 센터의 관제요원이 정규직 전환 대상으로 분류되는 직무에 해당한다 하더라도, 그 직무에 종사하는 개별 기간제근로자로서는 경쟁채용 등의 과정에서 탈락할 가능성이 있으므로, 이 사건 지침 및 조치요령으로 인하여 이 사건 근로자들에게 정규직 전환에 대한 신뢰가 부여된다고 보기는 어렵다는 점,

③ 더욱이 이후 나온 추가 정부지침에 의하더라도 ○○시에게 정규직 전환의무를 지우고 있지 않고, 지방자치단체의 재정상황, 인력수요 등에 비추어 정규직 전환 심의위원회를 통해 자율적으로 전환 여부, 전환대상 및 전환시기를 정하도록 재량을 부여하고 있다는 점,

④ ○○시와 기간제근로계약을 체결한 이 사건 근로자들로서는 이 사건 정부 지침 및 추가지침에 따라 지방자치단체의 재량적 판단에 따라 정규직 전환 심의위원회의 심의·의결을 거쳐 공무원근로자로 전환될 수 있다고 사실상의 기대를 가질 수는 있으나, 이를 두고 이 사건 정부 지침 및 추가지침이 기간제근로자의 공무원근로자 전환에 대한 기대권을 부여한다고 보기 어렵다. 이 사건 정부지침 및 추가지침은 기간만료와 동시이든 기간이 만료된 후이든 재정상황, 인력수요 등

이 허락되면 공무원근로자로 전환시켜 줄 것을 권고하는 효과를 가지고 사용자인 ○○시에게 전환 여부, 전환대상, 전환시기, 채용방법(전환 채용, 경쟁채용, 제한경쟁채용, 가점부여 등)에 대한 재량을 부여할 뿐이다라는 점 등

다. ○○시가 계약갱신을 거절한 데 합리적 이유가 있는지 여부

근로자에게 이미 형성된 갱신에 대한 정당한 기대권이 있음에도 불구하고 사용자가 이를 배제하고 근로계약의 갱신을 거절한 데에 합리적 이유가 있는지가 문제될 때에는 사용자의 사업 목적과 성격, 사업장 여건, 근로자의 지위 및 담당 직무의 내용, 근로계약 체결 경위, 근로계약의 갱신에 관한 요건이나 절차의 설정 여부와 그 운용 실태, 근로자에게 책임 있는 사유가 있는지 여부 등 당해 근로관계를 둘러싼 여러 사정을 종합하여 갱신 거부의 사유와 그 절차가 사회통념에 비추어 볼 때 객관적이고 합리적이고 공정한지를 기준으로 판단하여야 하고, 그러한 사정에 대한 증명책임은 사용자가 부담한다(대법원 2014. 12. 24. 선고 2012다17035 판결, 대법원 2017. 10. 12. 선고 2015두44493 판결 등 참조).

위와 같이 이 사건 근로자들에게 계약갱신에 대한 기대권이 있다고 볼 수 없을 뿐만 아니라, 앞서 인정한 사실로부터 알 수 있는 다음과 같은 사정을 위 법리에 비추어 보면, 이 사건 센터의 경우 스마트 관제 시스템의 도입이라는 사정변경으로 인해 인력을 탄력적으로 조절할 필요성이 있었으므로, ○○시가 이 사건 근로자들의 근로계약을 갱신하지 아니한 데에 합리적인 이유가 있다고 봄이 상당하다.

① ○○시는 2019. 10. 31.경 스마트 관제 시스템 구축을 완료하여 2019. 11.경부터 본격적으로 스마트 관제 시스템을 운영하고 있다. ○○시의 2018. 10. 31.자 정규직 전환 계획에 의하면 2019년 스마트 관제 시스템 도입으로 운영인력이 36명에서 20명 정도로 축소된다고 되어 있는 바, 원고는 이 사건 센터에서 필요한 관제요원의 인원이 감소할 것으로 예상하고 2019. 5. 31. 및 같은 해 7. 16. 참가인들과의 근로계약을 종료하였다는 점,

② 스마트 관제 시스템이 설치되더라도 이 사건 센터가 범죄자 검거 및 주민 안전보호 등 업무를 수행하기 위해서는 최종적으로 관제 영상의 내용을 분석·판단할 수 있는 관제요원의 역할이 필수적이기는 하나, 이 사건 센터에 설치된 스마트 관제 시스템의 경우 관제대상 객체의 움직임이 있는 CCTV 영상만 노란색 사각형 모양을 표시하여 화면에 송출되므로 모든 화면을 관제하여야 하는 기존 시스템과 비교하여 관제요원들의 업무강도가 낮아질 수밖에 없고, 이러한 스마트 관제 시스템 구축으로 인하여 관제 효율이 향상되어 관제요원의 인력수요가 기존보다 줄어든다고 보는 것이 합리적이라는 점,

③ ○○시가 2018. 8. 수립한 지능형 스마트 관제 시스템 구축계획은 당시 지방자치단체의 1인당 평균 관제 CCTV 수를 기준으로 추산된 것으로 보여 관제요원의 업무강도가 다소 높게 설정된 것으로 보이기는 하나, 관제요원이 감당할 수 없을 정도의 업무수준이라고 보기 어려워 한정된 예산과 인력하에 시스템을 운영할 수밖에 없는 계획의 현실성이라는 측면에서 불합리하다고 단정하기 어렵다는 점,

④ 이 사건 센터의 관제요원은 2016. 6. 1. 개소 당시 36명으로 시작하여 2019. 1. 1. 29명, 2019. 6. 1. 18명으로 감소하였고 2019. 8. 1.경에는 역대 최소인원인 14명이 근무하였다가, 스마트 관제가 시작된 2019. 11. 1. 17명, 공무원근로자로 전환된 2020. 1. 6. 이래 28명이 근무하고 있는바, ○○시는 스마트 관제 시스템 구축으로 인하여 관제요원의 인력수요가 감소하는 것을 감안하여 일정 기간 동안은 기간만료로 발생한 결원에 대한 추가채용을 하지 않았던 것으로 보이고, ○○시는 2018. 8. 수립한 계획의 테두리 내에서 계획을 이행하였다고 볼 수 있는 점 등.

패소 이유 (공공부문 비정규직 근로자 가이드 라인에 대한 확립된 해석례가 없는 시점 혼란)

부록.1. 주요 사건 경과 및 패소 원인 분석

법원은 모든 경우에 근로계약의 갱신이나 기간의 정함이 없는 근로자의 전환에 대한 정당한 기대권을 인정하지 않고, 관련 법리를 마련해두되 구체적인 사실관계에 따라 구체적 타당성을 고려하여 판단하고 있는바, 이번 사건은 이러한 관련법리를 적용하고자 하는 구체적인 사실관계를 어떻게 정리하고 해석하는지에 따라 판단이 엇갈렸던 사건으로 판단된다.

이 사건이 문제될 당시 쟁점으로 떠올랐던 정부지침, ○○시라는 지방자치단체의 특성, ○○시의 인사관리 규정 등을 어떻게 해석할 것인지에 대해 노동위원회와 법원의 판단이 엇갈렸고 이는 각 분쟁해결 시스템이 진행되는 절대적인 소요시간의 차이, 당사자들의 절차 적극성, 전문가의 숙련도 등으로 인해 노동위원회에서와는 달리 재판부에 얼마나 충실한 자료가 제공되었는지, 유사한 시기 공공기관에서 벌어지는 비슷한 사건의 진행 상황 등에 따라 상대적으로 풍부한 경험과 전문성을 가지고 있는 법관의 판단에 따라 결과가 달라졌다고 보는 것이 타당하다고 생각된다.

일련번호	2021-51					
판결번호	대법원 2021. 4. 29. 선고 2020두00000					
중노위판정번호	중노위 2019. 5. 24. 중앙2019부해343					
사건 종류	기간제					
세부 쟁점	갱신기대권 존부					
심급별 소송결과	1심 법원	재심판정유지	2심 법원	1심판결 취소	대법원	원심유지
원고, 피상고인	○○시		피고보조참가인, 상고인		황○○, 이○○	
피고, 상고인	중앙노동위원회위원장		피고측 대리인 선임 여부		없음	
노동조합 지원 여부	없음		원고측 대리인 선임 여부		선임	
재심 결과	초심 유지					
초심의 대법원 판례 일치여부	불일치		재심의 대법원 판례 일치여부		불일치	
기타 특이사항	2021_49번 사건과 거의 유사한 사실관계 사안이고, 각 사건의 항소심 재판부의 판사 3명 중 2명이 동일한 사안임. 2017. 공공부문 비정규직 근로자 정규직 전환 가이드라인 해석이 쟁점임					

주요 사실관계
<사실관계> 가. ○○시는 2016. 6. 1. ○○시 관내 CCTV를 관리하기 위하여 ○○시 통합관제센터를 개소하였고, 2016. 3.경 근로계약을 1년으로 하여 36명의 관제요원을 채용하였다. 그러던 중 위 관제요

원 일부가 더는 근무할 수 없게 되자, ○○시는 2016. 12. 1. 근로자 황○○, 이○○과(이하 ‘이 사건 근로자들’)과 근로계약을 체결하고 위 통합관제센터에서 근무하게 하였고, 이 사건 근로자들은 근로계약을 갱신하여 2018. 11. 30.까지 관제요원으로 근무하였다.

나. 대한민국정부는 2017. 7. 20. ‘공공부문 비정규직 근로자 정규직 전환 가이드라인’(이하 ‘이 사건 정부 지침’)을 발표하였는데, 위 지침은 비정규직 근로자의 악한 고용 상황에도 불구하고 최대의 사용자인 공공부문 또한 비정규직 확산에 책임이 있다는 문제의식 아래 상시·지속적 업무, 생명·안전 관련 업무에 종사하는 공공부문 비정규직 근로자를 원칙적으로 정규직으로 전환한다는 내용을 포함하고 있다.

다. 이 사건 사용자는 이 사건 정부 지침에 따라 2017. 7. 28. 정규직 전환 관련 특별실태조사를 실시하고, 2017. 8. 23. 정규직 전환 심의위원회를 구성하였다.

라. 이 사건 사용자는 2017. 12. 20. 정규직 전환 심의위원회를 거쳐 심의대상자 260명 중 36명을 정규직으로 전환하기로 의결하였는데, 그중에는 위 통합관제센터의 관제요원은 포함되지 아니하였으며, 2018. 10. 23. 이 사건 근로자들에게 근로계약이 2018. 11. 30. 종료되고, 이를 갱신하지 아니할 것임을 통보하였다(이하 ‘이 사건 통보’라 한다).

이 사건 근로자들은 2018. 12. 12. 경북지노위에 이 사건 통보가 부당하다고 주장하며 구제를 신청하였다.

<심급별 결과>

[경북지노위] 이 사건 근로자들에게 근로계약의 갱신에 대한 기대권이 인정되고, 원고가 근로계약 갱신을 거절한 데 합리적 이유가 없다는 취지로 구제신청 인용

[중노위] 초심판정과 같은 취지로 이 사건 사용자의 재심신청 기각

[1심 법원] 이 사건 사용자와 근로자들 사이의 고용관계를 둘러싼 여러 사정을 고려하면 보면 이 사건 근로자들에게는 기간의 정함이 없는 근로자로 전환된다는 데 대한 정당한 기대권이 인정된다고 판시하며 재심판정이 적법하다고 판단

[2심 법원] 1심법원의 판단을 뒤집고 이 사건 근로자들에게 계약 갱신에 대한 기대권이 있다고 볼 수 없을 뿐만 아니라, 이 사건 사용자가 이 사건 근로자들의 근로계약을 갱신하지 아니한 데에 합리적인 이유가 있다고 봄이 상당하다고 판시하여 계약갱신거절에 합리적 이유가 없다고 인정한 이 사건 재심판정은 부당하다고 판결

[대법원] 심리불속행기각

판결 요지

정규직 전환에 대한 정당한 기대권이 인정되는지 여부와 갱신 거절의 합리적 이유 존부

근로자에게 이미 형성된 갱신에 대한 정당한 기대권이 있음에도 불구하고 사용자가 이를 배제하고 근로계약의 갱신을 거절한 데에 합리적 이유가 있는지가 문제될 때에는 사용자의 사업 목적과 성격, 사업장 여건, 근로자의 지위 및 담당 직무의 내용, 근로계약 체결 경위, 근로계약의 갱신에 관한 요건이나 절차의 설정 여부와 그 운용 실태, 근로자에게 책임 있는 사유가 있는지 여부 등 당해 근로관계를 둘러싼 여러 사정을 종합하여 갱신 거부의 사유와 그 절차가 사회통념에 비추어 볼 때 객관적이고 합리적이며 공정한지를 기준으로 판단하여야 하고, 그러한 사정에 대한 증명책임은 사용자가 부담한다(대법원 2014. 12. 24. 선고 2012다17035 판결, 대법원 2017. 10. 12. 선고 2015두44493 판결 등 참조).

다음과 같은 사정을 위 법리에 비추어 보면, 이 사건 근로자들에 계약갱신에 대한 기대권이 있

다고 볼 수 없을 뿐만 아니라, 이 사건 관제센터의 경우 스마트 관제 시스템의 도입이라는 사정 변경으로 인해 인력을 탄력적으로 조절할 필요성이 있었으므로, ○○시가 이 사건 근로자들의 근로계약을 갱신하지 아니한 데에 합리적인 이유가 있다고 봄이 상당하다. 이와 달리 계약갱신거절에 합리적 이유가 없다고 인정한 이 사건 재심판정은 부당하다.

① 행정안전부의 2018. 2. 12.자 안내 공문에 따르면 지능형 CCTV 기술은 1세대 객체인식 및 추적 기술, 2세대 객체행위 분석 기술, 3세대 객체행위 분석 AI 적용 기술로 발전하고 있으나, 2세대 이후로는 아직 기술적 성숙도가 미흡하여 정확도가 낮아 움직이는 사람이나 사물 등의 객체만을 선별 관제하는 객체인식 및 추적 기술만 도입 대상이 되고 있다는 점,

② ○○시는 2018. 8. 3. 기존에는 관제요원 1인당 CCTV 수가 140대였으나, 스마트 관제 시스템 구축 후 350-400대가 가능한 것을 전제로 관제요원 인력을 총 20-24명으로 축소 운영하는 내용으로 지능형 스마트 관제 시스템 구축 계획을 수립한 후, 2019. 8. 2.경 주식회사 ○○정보통신과 스마트 관제 시스템 구축 계약을 체결하고 2019. 10. 31. 스마트 관제 시스템 구축을 완료하였으며, 2019. 11.부터 본격적으로 스마트 관제 시스템을 운영하고 있다. 또한 ○○시의 2018. 10. 31.자 정규직 전환 계획에 의하면 2019년 스마트 관제 시스템 도입으로 운영인력이 36명에서 20명 정도로 축소된다고 되어 있고, 실제 ○○시는 관제요원의 인원이 감축할 것으로 예상하고 2018. 11. 30. 참가인들과의 근로계약을 종료하였다는 점,

③ 이 사건 센터에 설치된 스마트 관제 시스템의 경우 인공지능을 통해 관제대상 객체의 움직임이 있는 CCTV 영상만 노란색 사각형 모양을 표시하여 화면에 송출되므로, 모든 화면을 관제하여야 하는 기존 시스템과 비교하여 관제요원들의 업무강도가 낮아질 수밖에 없다. 스마트 관제 시스템이 설치되더라도 이 사건 센터가 범죄자 검거 및 주민 안전보호 등 업무를 수행하기 위해서는 최종적으로 관제 영상의 내용을 분석·판단할 수 있는 관제요원의 역할이 필수적이나, 이를 감안하더라도 스마트 관제 시스템 구축으로 인하여 관제 효율이 향상되어 관제요원의 인력수요가 기존보다 줄어든 수 있다고 합리적으로 추론할 수 있다는 점,

④ ○○시는 2019. 11. 이 사건 센터에서 감축된 17명의 관제요원으로 관제업무를 하였고 2019. 11. 29. 채용공고를 거쳐 2020. 1. 26. 이 사건 근로자들을 포함한 28명을 공무원근로자로 채용하여 큰 무리 없이 관제업무를 수행하였으며, 이는 결국 ○○시가 2018. 8. 수립한 계획의 테두리 내에서 계획을 이행하였다고 볼 수 있다는 점,

⑤ 실제로 경상북도 내 스마트관제시스템을 도입한 시·군의 경우 관제요원을 감축한 경우도 많다는 점,

⑥ ○○시가 2019. 5. 관제요원들에게 기간제법에 따라 기간제근로자와 2년을 초과하는 근로계약을 체결하지 않겠다고 통보하였으나, 그 통보 시점은 이 사건 근로자들과의 근로계약 기간만료 이후 시점이고, 이는 ○○시가 당시 기간제법에 따라 계약연장을 포함하여 최대 2년의 범위 내에서 근로계약을 유지한다는 의사를 확인하는 내용에 불과하므로 기간제법을 회피하기 위한 목적으로 보기 어렵다는 점,

⑦ 이 사건 정부 지침 및 추가지침과 이 사건 인사관리 규정 제12조는 계약갱신과 필연적으로 결부되지 아니하고 그 내용도 달리하므로, 계약갱신 거절에 합리적인 이유가 있는지 여부를 판단하는 논거로 삼기에 적절하지 않다는 점 등

패소 이유 (공공부문 비정규직 근로자 가이드 라인에 대한 확립된 해석례가 없는 시점 혼란)

법원은 모든 경우에 근로계약의 갱신이나 기간의 정함이 없는 근로자의 전환에 대한 정당한 기대권을 인정하지 않고, 관련 법리를 마련해두되 구체적인 사실관계에 따라 구체적 타당성을 고려하여 판단하고 있는바, 이번 사건은 이러한 관련법리를 적용하고자 하는 구체적인 사실관계를 어

떻게 정리하고 해석하는지에 따라 판단이 엇갈렸던 사건으로 판단된다.

이 사건이 문제될 당시 쟁점으로 떠올랐던 정부지침, ○○시라는 지방자치단체의 특성, ○○시의 인사관리 규정 등을 어떻게 해석할 것인지에 대해 노동위원회와 법원의 판단이 엇갈렸고 이는 각 분쟁해결 시스템이 진행되는 절대적인 소요시간의 차이, 당사자들의 절차 적극성, 전문가의 숙련도 등으로 인해 노동위원회에서와는 달리 재판부에 얼마나 충실한 자료가 제공되었는지, 유사한 시기 공공기관에서 벌어지는 비슷한 사건의 진행 상황 등에 따라 상대적으로 풍부한 경험과 전문성을 가지고 있는 법관의 판단에 따라 결과가 달라졌다고 보는 것이 타당하다고 생각된다.

특히 ○○시와 근로계약을 맺었던 다른 기간제 근로자의 분쟁에 있어서도 법원은 당시 정부지침을 정규직 전환 결정기구가 정규직 전환범위, 전환방식, 채용방법을 결정하도록 하고 전환 채용 대상자에게 어떠한 평가절차를 거칠 것인지에 기관이 자율적으로 결정하도록 하고 있다고 해석하는 태도를 취한 바 있었으므로 2017. 7. 20.자로 발표된 정부의 지침(공공부문 비정규직 근로자 전환 가이드라인)이 나온 초기 그 해석을 어떻게 해야 할지에 대한 확립된 해석이 정립되지 않은 상황에서 노동위원회와 법원의 엇갈리는 판단이 나왔던 것으로 보인다.

일련번호	2021-52					
판결번호	대법원 2021. 9. 9. 선고 2021두00000					
중노위판정번호	중노위 2019. 8. 1. 중양2019부해663					
사건 종류	기간제 근로자 해당 여부					
세부 쟁점	기간제 근로자 해당 여부, 갱신기대권 존부					
심급별 소송결과	1심 법원	재심판정취소	2심 법원	1심판결 유지	대법원	원심유지
원고, 피상고인	○○○○공단		피고보조참가인, 상고인		안○○	
피고	중양노동위원회위원장		피고측 대리인 선임 여부		없음	
노동조합 지원 여부	없음		원고측 대리인 선임 여부		없음	
재심 결과	초심 유지					
초심의 대법원 판례 일치여부	불일치		재심의 대법원 판례 일치여부		불일치	
기타 특이사항						

주요 사실관계

<사실관계>

가. 근로복지공단은 산업재해보상보험법에 따라 1995. 5. 1. 설립된 공공기관으로 상시 약 6,680명의 근로자를 사용하여 산업재해보상보험업무 등을 수행하는 법인이고, 근로복지공단 ○○병원(이하 '이 사건 병원')은 근로복지공단의 산하 기관으로 상시 근로자 약 330명을 사용하여 운영하는 종합병원이다.

나. 안○○(이하 '이 사건 근로자')은 2017. 1. 1. 이 사건 병원에 정형외과 의사로 입사하여 근무하였다.

다. 근로복지공단은 2018. 12. 3. 이 사건 근로자에게 근로계약이 2018. 12. 31.자로 만료됨을 통보하는 내용의 계약기간 만료 통보를 하였다(이하 '이 사건 계약기간 만료 통보'라 한다)

라. 이 사건 근로자는 2019. 3. 5. 이 사건 해고는 부당하다고 주장하면서 전남지노위에 구제신청을 하였다.

<심급별 결과>

[전남지노위] '이 사건 근로자는 기간의 정함이 없는 근로계약을 체결한 근로자이므로 이 사건 계약기간 만료 통보는 해고에 해당하고, 근로복지공단은 해고사유를 서면으로 통지하지 아니하여 근로기준법 제27조를 위반하였으므로, 위 해고는 부당해고에 해당한다'는 이유로 구제신청 인용 [중노위] 위 초심판정과 같은 이유로 재심신청 기각

[1심 법원] 이 사건 근로자는 기간제 근로자에 해당하고, 이 사건 근로자에게 이 사건 근로계약 갱신에 대한 정당한 기대권이 인정된다고 볼 수 없으므로, 이 사건 근로계약은 이 사건 계약 만료 통보로 종료되었다고 판시

[2심 법원] 1심과 같은 판단

[대법원] 심리불속행기각

판결 요지

가. 이 사건 근로계약이 기간의 정함이 없는 근로계약인지 여부

처분문서는 그 진정성립이 인정되면 특별한 사정이 없는 한 그 처분문서에 기재되어 있는 문언의 내용에 따라 당사자의 의사표시가 있었던 것으로 객관적으로 해석하여야 하고, 당사자 사이에 계약의 해석을 둘러싸고 이견이 있어 처분문서에 나타난 당사자의 의사해석이 문제되는 경우에는 문언의 내용, 그와 같은 약정이 이루어진 동기와 경위, 약정에 의하여 달성하려는 목적, 당사자의 진정한 의사 등을 종합적으로 고찰하여 논리와 경험칙에 따라 합리적으로 해석하여야 한다 (대법원 2001. 2. 27. 선고 99다23574 판결 등 참조)

다음과 같은 사정을 위 법리에 비추어 보면, 이 사건 근로계약은 기간의 정함이 있는 근로계약이라고 봄이 타당하다.

① 증인에 따르면, 근로복지공단 측은 이 사건 근로자에게 계약직으로 채용한다는 점과 계약기간이 1년이라는 점에 대하여 설명하였고 이 사건 근로자는 자신을 계약직이 아닌 정규직으로 채용해 달라고 요구하지 않았으며, 오히려 주 4회 근무를 하고 싶다고 한 바 있는 등 당사자와 대면하여 근로조건을 이미 구두로 협의하였고, 근로계약서는 통상 이 사건 병원의 표준양식을 사용하기 때문에 계약기간 관련한 부분을 별도로 확인하지 않았다는 점,

② 이 사건 근로계약서에는 계약기간에 관하여 “기간의 약정이 없는 근로계약으로 한다”라고

기재되어 있으나, 실제 이 사건 병원은 정형외과장을 특정업무직으로 채용하기로 결정하고 대외적인 채용광고에도 특정업무직(계약직)으로 채용한다는 점을 명시하는 등, 채용 당시부터 특정업무직과 계약기간을 명시하였고, 실제 증인들의 증언에 따라 이러한 내용을 모두 설명하였다는 점이 인정되는 등에 비추어 보면, 이 사건 근로계약서의 계약기간 관련 문구는 담당자의 부주의로 인한 오기로 보인다는 점,

③ 실제 이 사건 근로자도 이 사건 근로계약 체결 당시 자신이 계약직으로 채용된다는 사실을 충분히 인식하고 있었던 것으로 보인다는 점 등.

나. 이 사건 근로자에게 갱신기대권이 인정되는지 여부

이 사건 근로자는 본인과 관련한 여러 문제점들의 지적을 받으며 그 개선사항 이행 여부에 따라 2018. 10.경 재계약 체결 여부를 결정하겠다는 이야기를 들었고, 2018. 10.말경 면담을 통해 재계약이 불가능함을 구두로 통보받으며 스스로 이를 받아들이면서 연말까지 충실하게 환자들을 진료하겠다고 하겠다고 진술한 것이 인정되는 점 등을 고려한다면, 이 사건 근로자에게 이 사건 근로계약 갱신에 관한 정당한 기대권이 인정된다고 보기 어렵다.

다. 결국, 이 사건 근로자는 기간제 근로자에 해당하고, 이 사건 근로자에게 이 사건 근로계약 갱신에 대한 정당한 기대권이 인정된다고 볼 수 없으므로, 이 사건 근로계약은 이 사건 계약기간 만료 통보로 종료되었다. 이와 다른 전제에서 내려진 이 사건 재심판정은 위법하다.

패소 이유 (구체적인 사실관계 파악의 차이)

법원은 이 사건에서 근로복지공단의 주장을 들어주는 증거로써 근로복지공단측의 증인들의 증언을 다수 증거로 채택하였는데 이러한 점을 고려한다면 계약서 작성 당시 실제 담당하였던 담당자들의 진술 즉, 사실관계의 파악 정도에 따라 결론이 달라진 사건으로 판단된다.

특히 법관은 재판 절차를 통하여 증인들의 실제 증언을 들을 수 있고, 반대되는 신문을 하며 사실관계를 파악하고 심증을 형성하는 등 노동위원회 판정 보다 폭 넓고 조금더 구체화된 사실관계를 파악할 수 있는 기회가 있는데 절차의 이러한 사실상의 한계 때문에 결론이 달라진 사례라고 생각된다.

일련번호	2021-53					
판결번호	대법원 2021. 6. 10. 선고 2021두00000					
중노위판정번호	중노위 2019. 9. 2. 중앙2019부해821					
사건 종류	기간제					
세부 쟁점	갱신기대권 존부					
심급별 소송결과	1심 법원	재심판정유지	2심 법원	1심판결 취소	대법원	원심유지

부록.1. 주요 사건 경과 및 패소 원인 분석

원고, 피상고인	○○시	피고보조참가인, 상고인	김○○
피고, 상고인	중앙노동위원회위원장	피고측 대리인 선임 여부	없음
노동조합 지원 여부	없음	원고측 대리인 선임 여부	선임
재심 결과	초심 유지		
초심의 대법원 판례 일치여부	불일치	재심의 대법원 판례 일치여부	불일치
기타 특이사항	2021_49, 51번 사건과 거의 유사한 사실관계 사안이고, 서울고등법원, 대법원이 51번 사건과 같은 재판부인 사건임(서울고등법원의 2심 판결은 51번과 53번 사건 모두 동일한 날 이루어짐) 2017. 공공부문 비정규직 근로자 정규직 전환 가이드라인 해석이 쟁점임		

주요 사실관계
<사실관계> 가. ○○시는 2016. 6. 1. ○○시 관내 CCTV를 관리하기 위하여 ○○시 통합관제센터(이하 ‘이 사건 센터’))를 개소하였고, 근로계약기간을 1년으로 하여 이 사건 센터에 근무할 36명의 관제요원을 채용하였다. 나. ○○시는 2016. 10. 28.자로 관제요원 결원 채용공고를 하였고, 이에 응시한 최○○와 2016. 12. 28. 계약기간을 2017. 1. 1.부터 2017. 12. 31.까지로 정하여 근로계약을 체결하였으며, 2017. 12. 31. 계약기간을 2018. 1. 1.부터 2018. 12. 31.까지로 하여 재차 근로계약을 체결하였다. 그 후 ○○시는 2017. 3. 7.자로 관제요원 결원 채용공고를 하였고, 이에 응시한 김경희(이하 ‘이 사건 근로자’)과 2017. 3. 15. 계약기간을 2017. 3. 15.부터 2018. 3. 14.까지로 정하여 근로계약을 체결하였으며, 2018. 3. 15. 계약기간을 2018. 3. 15.부터 2019. 3. 14.까지로 하여 재차 근로계약을 체결하였다. 다. ○○시는 2018. 11. 21. 최○○에게 근로계약이 2018. 12. 31. 종료된다고 통보하였고, 2019. 2. 11. 이 사건 근로자에게 근로계약이 2019. 3. 14. 종료된다고 통보하였다(이하 각 근로계약 종료를 통틀어 ‘이 사건 근로계약 종료’라 한다). 라. 최○○와 이 사건 근로자는 경북지노위에 이 사건 근로계약 종료가 부당해고에 해당한다고 주장하며 구제를 신청하였다. <심급별 결과> [경북지노위] 최○○와 이 사건 근로자에게 근로계약 갱신에 대한 기대권이 인정되고 원고가 근로계약 갱신을 거절한 데 합리적 이유가 없다는 취지로 구제신청 인용 [중노위] 초심판정과 같은 취지로 원고의 재심신청 기각 [1심 법원] ○○시와 최○○, 이 사건 근로자에게는 기간의 정함이 없는 근로자로 전환된다는 데 대한 정당한 기대권이 인정되고, ○○시가 최○○와 이 사건 근로자에 대한 정규직 전환을 거절하여 이 사건 근로관계 종료에 이른 것은 합리적 이유가 없으므로, 부당해고에 대항하여 그 효력이 없으며, 재심판정이 적법하다고 판단 [2심 법원] 1심법원의 판단을 뒤집고 이 사건 근로자들에게 계약 갱신에 대한 기대권이 있다고 볼 수 없을 뿐만 아니라, 이 사건 사용자가 이 사건 근로자들의 근로계약을 갱신하지 아니한 데

에 합리적인 이유가 있다고 봄이 상당하다고 판시하여 계약갱신거절에 합리적 이유가 없다고 인정한 이 사건 재심판정은 부당하다고 판결
[대법원] 심리불속행기각

판결 요지

정규직 전환에 대한 정당한 기대권이 인정되는지 여부와 갱신 거절의 합리적 이유 존부

이 사건 근로자들에 계약갱신에 대한 기대권이 있다고 볼 수 없을 뿐만 아니라, 이 사건 관제 센터의 경우 스마트 관제 시스템의 도입이라는 사정변경으로 인해 인력을 탄력적으로 조절할 필요성이 있었으므로, ○○시가 이 사건 근로자들의 근로계약을 갱신하지 아니한 데에 합리적인 이유가 있다고 봄이 상당하다. 이와 달리 계약갱신거절에 합리적 이유가 없다고 인정한 이 사건 재심판정은 부당하다.

(51번 사건과 같은 내용의 판시임)

패소 이유 (공공부문 비정규직 근로자 가이드 라인에 대한 확립된 해석례가 없는 시점 혼란)

법원은 모든 경우에 근로계약의 갱신이나 기간의 정함이 없는 근로자의 전환에 대한 정당한 기대권을 인정하지 않고, 관련 법리를 마련해두되 구체적인 사실관계에 따라 구체적 타당성을 고려하여 판단하고 있는바, 이번 사건은 이러한 관련법리를 적용하고자 하는 구체적인 사실관계를 어떻게 정리하고 해석하는지에 따라 판단이 엇갈렸던 사건으로 판단된다.

이 사건이 문제될 당시 쟁점으로 떠올랐던 정부지침, ○○시라는 지방자치단체의 특성, ○○시의 인사관리 규정 등을 어떻게 해석할 것인지에 대해 노동위원회와 법원의 판단이 엇갈렸고 이는 각 분쟁해결 시스템이 진행되는 절대적인 소요시간의 차이, 당사자들의 절차 적극성, 전문가의 숙련도 등으로 인해 노동위원회에서와는 달리 재판부에 얼마나 충실한 자료가 제공되었는지, 유사한 시기 공공기관에서 벌어지는 비슷한 사건의 진행 상황 등에 따라 상대적으로 풍부한 경험과 전문성을 가지고 있는 법관의 판단에 따라 결과가 달라졌다고 보는 것이 타당하다고 생각된다.

특히 ○○시와 근로계약을 맺었던 다른 기간제 근로자의 분쟁에 있어서도 법원은 당시 정부지침을 정규직 전환 결정기구가 정규직 전환범위, 전환방식, 채용방법을 결정하도록 하고 전환 채용 대상자에게 어떠한 평가절차를 거칠 것인지는 기관이 자율적으로 결정하도록 하고 있다고 해석하는 태도를 취한 바 있었으므로 2017. 7. 20.자로 발표된 정부의 지침(공공부문 비정규직 근로자 전환 가이드라인)이 나온 초기 그 해석을 어떻게 해야 할지에 대한 확립된 해석이 정립되지 않은 상황에서 노동위원회와 법원의 엇갈리는 판단이 나왔던 것으로 보인다.

일련번호	2021-55
판결번호	대법원 2021. 9. 30. 선고 2021두00000
중노위판정번호	중노위 2019. 4. 10. 중양2019부해120/부노20호(병합)

부록.1. 주요 사건 경과 및 패소 원인 분석

사건 종류	기간제					
세부 쟁점	갱신거절 합리적 이유 존부					
심급별 소송결과	1심 법원	재심취소	2심 법원	1심 유지	대법원	원심유지
원고, 피상고인	○○실업 주식회사		피고보조참가인, 상고인		홍○○	
피고	중앙노동위원회위원장		피고측 대리인 선임 여부		없음	
노동조합 지원 여부	간접적으로 있음		원고측 대리인 선임 여부		선임	
재심 결과	초심 유지					
초심의 대법원 판례 일치여부	불일치		재심의 대법원 판례 일치여부		불일치	
기타 특이사항	노동위원회 단계에서는 근로자의 신분상 부당노동행위도 쟁점이 되었던 사건이라 노동조합도 당사자가 되었으나, 소송 단계에서는 노동조합이 참가하지 않아서 근로자 개인의 부당해고 쟁점만 문제되었던 사안임.					

주요 사실관계
<사실관계> 가. ○○실업 주식회사는 2002. 8. 1. 설립되어 택시 운송사업을 영위하는 법인이고, 홍○○(이하 ‘이 사건 근로자’)은 2017. 9. 12. 원고에 입사하여 택시 운전업무를 수행하던 사람이다. ○○실업 주식회사와 이 사건 근로자가 체결한 근로계약은 “① 고용근로계약기간: 2017. 9. 12.부터 2018. 9. 11.까지 1년간으로 한다(다만, 계속 근무 시 자동 연장한다). ② 고용근로계약기간이 만료되면 계약은 자동해지처리되며, 계약만료 근로자는 계약만료일자로 사용자와 근로자 간의 신분이 청산 정리처리되어 근무에 임할 수 없으며, 자동적으로 퇴사보고 및 가입자, 피보험자자격 상실신고처리된다. 다만, 재계약은 계약만료 30일 전부터 사용자와 근로자 간에 협의한다. 재계약은 사용자와 근로자 간에 쌍방 합의하에 의하여 체결되며 합의가 이루어지지 않을 경우에는 자동해지된다.”는 내용을 포함하고 있다. 나. 이 사건 근로자는 2017. 12. 13. 민주○○실업노동조합을 설립하여 그 대표로 활동하였다. ○○실업 주식회사 사업장에는 그에 앞서 2005. 10. 25. 한국노동조합총연맹 전국택시노동조합연맹 전국택시산업노동조합 경기북부지역본부 ○○실업분회가 조직되어 있었다 다. ○○실업 주식회사는 2018. 9. 4. 및 2018. 9. 11. 이 사건 근로자에게 2018. 9. 11. 근로계약이 만료되고, 계약을 갱신하지 않을 것임을 통보하였다(이하 ‘이 사건 통보’라 한다). 라. 이 사건 근로자와 민주○○실업노동조합은 2018. 10. 31. 경기도지노위에 경기2018부해1930/부노70호(병합)로 이 사건 통보가 합리적 이유가 없으므로 부당하고, 민주○○실업노동조합 활동을 이유로 한 불이익 취급으로서 부당노동행위에 해당한다고 주장하며 구제를 신청하였다. <심급별 결과> [경기도지노위] 이 사건 통보가 부당하지만, 부당노동행위 성립은 부정 [중노위] 초심판정과 같은 이유로 각 재심신청을 모두 기각

[1심 법원] 이 사건 근로자에게는 ○○실업 주식회사와 체결한 근로계약이 갱신될 수 있다는 데 대한 정당한 기대권이 인정되나 ○○실업 주식회사가 이 사건 근로자와 체결한 근로계약의 갱신을 거절한 데에는 합리적 이유가 있으므로 이 사건 재심판정은 위법하므로 취소되어야 한다고 판시

[2심 법원, 대법원] 1심 법원과 같은 판단

판결 요지

1. 근로계약 갱신에 대한 정당한 기대권이 있는지 여부

기간을 정하여 근로계약을 체결한 근로자의 경우 기간이 만료됨으로써 근로자로서의 신분관계는 종료되고 근로계약을 갱신하지 못하면 갱신 거절의 의사표시가 없어도 당연 퇴직되는 것이 원칙이다. 그러나 근로계약, 취업규칙, 단체협약 등에서 기간만료에도 일정한 요건이 충족되면 당해 근로계약이 갱신된다는 취지의 규정을 두고 있거나, 그러한 규정이 없더라도 근로계약의 내용과 근로계약이 이루어지게 된 동기 및 경위, 계약 갱신의 기준 등 갱신에 관한 요건이나 절차의 설정 여부 및 실태, 근로자가 수행하는 업무의 내용 등 당해 근로관계를 둘러싼 여러 사정을 종합할 때 근로계약 당사자 사이에 일정한 요건이 충족되면 근로계약이 갱신된다는 신뢰관계가 형성되어 있어 근로자에게 근로계약이 갱신될 수 있으리라는 정당한 기대권이 인정되는 경우에는, 사용자가 이를 위반하여 부당하게 근로계약의 갱신을 거절하는 것은 부당해고와 마찬가지로 아무런 효력이 없다(대법원 2017. 10. 12. 선고 2015두59907 판결 등 참조).

다음과 같은 사정을 고려하여 보면 이 사건 근로자에게는 ○○실업 주식회사와 체결한 근로계약이 갱신될 수 있으리라는 정당한 기대권이 인정된다.

① ○○실업 주식회사 취업규칙과 ○○실업 주식회사와 이 사건 근로자 사이의 근로계약은 모두 계약기간이 종료된 후 갱신될 수 있다는 가능성을 인정하고 있을 뿐만 아니라, 사용자와 근로자가 서로 이의를 제기하지 아니하면 근로계약이 당연히 갱신된다고 정하였다는 점,

② ○○실업 주식회사는 이 사건 통보 이전까지 1년 단위로 근로계약을 체결한 대부분의 근로자들과 묵시적으로 근로계약을 갱신하면서 계속 근무하게 하였고, 일부 업무태도가 불량하거나, 업무능력이 부족하여 반복적으로 사고를 일으키는 경우에만 근로계약을 갱신하지 아니하였던 점,

③ ○○실업 주식회사는 이 사건 통보 이전 오랜 기간에 걸쳐 근로계약이 갱신된 근로자와도 근로계약서를 작성하지 아니한 업무관행이 있었던 것으로 보이므로 묵시적으로 근로계약이 갱신되는 관행이 없었다고 단정할 수 없다는 점 등.

2. 근로계약 갱신 거절에 합리적 이유가 있는지 여부

근로자에게 이미 형성된 갱신에 대한 정당한 기대권이 있는데도 사용자가 이를 배제하고 근로계약의 갱신을 거절한 데에 합리적 이유가 있는지가 문제될 때에는 사용자의 사업 목적과 성격, 사업장 여건, 근로자의 지위와 담당 직무의 내용, 근로계약 체결 경위, 근로계약의 갱신 요건이나 절차의 설정 여부와 운용 실태, 근로자에게 책임 있는 사유가 있는지 등 근로관계를 둘러싼 여러 사정을 종합하여 갱신 거부의 사유와 절차가 사회통념에 비추어 볼 때 객관적이고 합리적이며 공정한지를 기준으로 판단하여야 하고, 그러한 사정에 관한 증명책임은 사용자가 부담한다(대법원 2019. 10. 31. 선고 2019두45647 판결 등 참조).

다음과 같은 사정을 고려해 보면, ○○실업 주식회사가 이 사건 근로자와 체결한 근로계약의 갱신을 거절한 데에는 합리적 이유가 있다.

부록.1. 주요 사건 경과 및 패소 원인 분석

① 이 사건 근로자는 운휴일인 2018. 3. 29. 29분 동안 운휴일인 차량을 운행하였는데, 이는 원고 재산인 영업용 차량을 권한 없이 운행한 것으로서 운전업무에 종사하는 근로자로서 준수하여야 할 가장 기초적인 사항을 위반한 경우에 해당한다는 점,

② ○○실업 주식회사는 병가기간이 끝난 이 사건 근로자에게 출근을 명령한 것으로 보이는데 그럼에도 이 사건 근로자는 이에 전혀 응답하지 아니한 채 출근조차 하지 아니하였는데, 이는 취업규칙 제21조 제3호에서 해고사유로 정한 월 3일 이상 무단결근을 한 경우에도 해당한다는 점,

③ 이 사건 근로자는 그에 앞서 이미 2018. 5. 8. 출근하지 아니하고도 이를 위하여 진단서 등 증빙서류를 제출하지 아니한 적이 있는바, 반복적으로 무단결근하는 점에서 결코 근무태도가 양호하지 못하다는 점,

④ 이 사건 근로자는 중부지방고용노동청 의정부지청에 ○○실업 주식회사 대표이사를 상대로 2회에 걸쳐 정당한 임금을 받지 못하였다는 이유로 고소하였는데, 근로감독관의 연락에도 제대로 응하지 아니하거나, 그 조사에 대하여 고소사실조차 제대로 알지 못한다고 불성실하게 응한 적이 있고, 특히 자신이 지급받지 못하였다고 주장하는 정당한 임금상당액의 구체적인 액수를 명시하거나 이를 특정할 수 있는 증거를 제출하지도 못하였다. 결국 이 사건 근로자는 합리적인 근거 없이 원고 대표이사를 상대로 고소를 반복하고 있다고 보인다는 점 등.

3. 결국, 이 사건 근로자에게는 ○○실업 주식회사와 체결한 근로계약이 갱신될 수 있다는 데 대한 정당한 기대권이 인정된다. 그러나 ○○실업 주식회사가 이 사건 근로자와 체결한 근로계약의 갱신을 거절한 데에는 합리적 이유가 있다. 이와 다른 전제에서 내려진 이 사건 재심판정은 위법하므로 취소되어야 한다.

패소 이유 (사실관계에 관한 인정차이)

이 사건은 노동위원회 단계에서는 근로자의 신분상 부당노동행위도 쟁점이 되었던 사건이라 노동조합도 당사자가 되었으나, 소송 단계에서는 노동조합이 참가하지 않아서 근로자 개인의 부당해고 쟁점만 문제되었던 사안이다.

즉, 노동위원회 단계에서 근로자는 노동조합과 함께 이 사건 사용자가 노동조합을 혐오하여 이 사건 근로자를 대상으로 승무정지, 고정기차 배제 등 끊임없이 징계하다가 갱신키대권이 형성되어 있는 이 사건 근로자의 근로계약기간 만료를 빌미로 근로계약을 해지한 것으로 이는 부당한 해고라고 주장하였고 이러한 배경 하에서 사실관계를 근로자쪽에 유리하게 해석하여 근로자의 손을 들어주었다.

그러나 법원은

“피고 및 참가인은 참가인이 2018. 7. 하순경 이래 출근하지 아니한 것은 당시 참가인이 원고로부터 고정배제 처분을 받아 경기지노위에 그 정당성을 다투며 구제를 신청하였고, 경기지노위가 참가인의 주장을 인정하여 고정배제 처분이 부당하다는 초심판정 및 구제명령을 내렸음에도 원고가 참가인을 원직복직시키지 않았기 때문이므로 이는 근로계약 갱신 거절의 합리적 이유가 될 수 없다는 취지로 주장한다.

그러나 당초 원고가 참가인에게 내린 고정배제 처분의 내용은 참가인에게 고정배차를 하지 아니한다는 내용에 지나지 아니하므로 그 처분의 정당성 여부나, 경기지노위의 구제명령 이행 여부와 무관하게 참가인은 여전히 원고와 체결한 근로계약에 따라 출근할 의무가 있다. 그럼에도 앞서 본 대로 참가인은 2018. 7. 11. 이래 원고에게 아무런 의사도 밝히지 아니한 채 계속하여 출근하지 아니하였으므로 달리 원고 단체협약 또는 취업규칙 등에 고정배차를 받지 못하는 운행기사는 출근의무가 없음을 정하였다는 등의 사정이 없는 이상, 참가인이 여러 달에 걸쳐 출근하지

아니한 것이 정당하다고 보기 어렵다.”라고 판시함으로써 동일한 사실관계에 대해 달리 판단하였고, 특히 이 사건 근로자가 대표이사를 2번 이상 고소할 당시 그의 태도를 들어 사실상 이 사건 근로자가 노동조합을 핑계로 근무를 태만하게 하였다는 점(근로감독관의 연락에도 제대로 응하지 아니하거나, 그 조사에 대하여 고소사실조차 제대로 알지 못한다고 불성실하게 응한 적이 있고, 특히 자신이 지급받지 못하였다고 주장하는 정당한 임금상당액의 구체적인 액수를 명시하거나 이를 특정할 수 있는 증거를 제출하지도 못하였다)을 지적하여 사용자의 손을 들어주었다.

법원이 인정한 사실관계와 노동위원회의 조사보고서 등을 비교하여 살펴보면, 노동위원회의 인력 부족, 당사자들의 입증 정도 등으로 인한 판단의 기초를 위한 사실관계를 얼마나 구체적으로 파악할 수 있었는지 여부로 판단이 달라진 사건으로 판단된다.

일련번호	2021-56					
판결번호	대법원 2021. 9. 16. 선고 2021두00000					
중노위판정번호	중노위 2015. 11. 18. 중앙2015부해794					
사건 종류	기간제					
세부 쟁점	무기계약근로자 전환 여부					
심급별 소송결과	1심 법원	재심취소	2심 법원	1심 취소	대법원	원심파기환송
원고, 피상고인	○○광역시		피고보조참가인		임○○, 윤○○	
피고, 상고인	중앙노동위원회위원장		피고측 대리인 선임 여부		없음	
노동조합 지원 여부	없음		원고측 대리인 선임 여부		있음	
재심 결과	초심 취소					
초심의 대법원 판례 일치여부	일치		재심의 대법원 판례 일치여부		불일치	
기타 특이사항						

주요 사실관계

<사실관계>

가. 근로자 임○○는 ○○○○초등학교에서, 근로자 윤○○는 ○○초등학교에서 2010. 3. 1.부터 2014. 2. 28.까지 4년 동안 1년 단위로 근로계약을 반복 갱신하면서 초·중등교육법령에 따른 영어회화 전문강사로 근무하였다.

나. ○○○○초등학교장은 2014. 2. 3. 임○○에게, ○○초등학교장은 2014. 1. 17. 윤○○에게

‘2014. 2. 28.자로 근로관계가 종료된다’는 사실을 각각 통보하였고, 그 계약기간 종료에 따라 퇴직금을 정산·지급하였다.

다. ○○광역시는 소속 학교별로 2014년도 영어회화 전문강사 공개채용 절차를 진행하였고(이하 ‘이 사건 공개채용 절차’라고 한다), 이 사건 공개채용 절차를 통해 임○○는 ○○○○초등학교에서, 윤○○는 ○○초등학교에서 각각 최종 합격하였다. 이에 임○○는 ○○○○초등학교장과, 윤○○는 ○○초등학교장과 계약기간을 2014. 3. 1.부터 2015. 2. 28.까지로 하는 근로계약을 새로이 체결하고 영어회화 전문강사로 계속 근무하였다.

라. 이후 ○○○○초등학교장과 ○○초등학교장은 근로자들에게 2015. 2. 28.자로 기간제 근로계약이 만료한다는 통보를 각각 하였다(이하 ‘이 사건 기간만료 통보’라고 한다).

마. 근로자들은 이 사건 기간만료 통보가 부당해고에 해당한다고 주장하며 지노위에 원고를 피신청인으로 한 부당해고 구제신청을 하였다.

<심급별 결과>

[전남지노위] 근로계약기간 만료로 근로관계가 정당하게 종료된 것으로 판정

[중노위] 근로자들을 기간제법 제4조 제2항에 따라 기간의 정함이 없는 근로계약을 체결한 근로자로 보아야 한다는 이유를 들어 구제신청을 인용

[1심 법원] 이 사건 근로자들은 기간의 정함이 없는 근로자가 아니라고 판시하며 재심판정을 취소한다고 판시

[2심 법원] 1심 법원의 판단과는 달리 이 사건 근로자들은 기간제근로자로서 수차례의 계약갱신 및 재채용 절차를 반복하면서 2010. 3. 1.부터 2015. 2. 28.까지 4년을 초과하여 계속 근로하였다고 봄이 타당하고, 이에 따라 이 사건 근로자들은 기간제법 제4조 제2항의 무기계약근로자로 전환되었으므로 이 사건 근로자들에게 대한 2015. 2. 28.자 계약기간 만료 통보는 부당해고에 해당한다고 판시

[대법원] 대전고등법원의 판단을 뒤집고, 파기환송 하였으며 이후 이 사건 근로자들은 기간의 정함이 없는 근로자가 아니라는 취지로 확정

판결 요지

기간제법 규정 내용과 기간제 근로계약의 남용을 방지함으로써 근로자의 지위를 보장하려는 입법 취지 등을 고려하면, 기간제 근로계약이 반복하여 체결되거나 갱신되어 일정한 공백기 없이 기간제근로자가 계속적으로 근로한 경우라면, 특별한 사정이 없는 한 최초 기간제 근로계약에서부터 최종 기간제 근로계약에 이르기까지 기간 전체가 기간제법 제4조에서 말하는 기간제근로자의 사용 기간으로서 ‘계속 근로한 총기간’에 포함되어야 한다. 다만 기간제 근로계약의 대상이 되는 업무의 성격, 기간제 근로계약의 반복 또는 갱신과 관련한 당사자들의 의사, 반복 또는 갱신된 기간제 근로계약을 전후한 기간제근로자의 업무 내용·장소와 근로조건 유사성, 기간제 근로계약의 종료와 반복 또는 갱신 과정에서 이루어진 절차나 그 경위 등을 종합적으로 고려할 때 당사자 사이에 기존 기간제 근로계약의 단순한 반복 또는 갱신이 아닌 새로운 근로관계가 형성되었다고 평가할 수 있는 특별한 사정이 있는 경우에는 기간제근로자의 계속된 근로에도 불구하고 그 시점에 근로관계가 단절되었다고 보아야 하고, 그 결과 기간제법 제4조에서 말하는 ‘계속 근로한 총기간’을 산정할 때 그 시점을 전후한 기간제 근로계약기간을 합산할 수는 없다(대법원 2020. 8. 20. 선고 2017두52153, 대법원 2020. 8. 20. 선고 2018두51201 판결 등 참조).

다음과 같은 사정을 고려하여 보면 2014. 3. 1.을 전후하여 이 사건 근로자들에 대해 이루어진 종전 기간제 근로계약의 종료 절차 및 이 사건 공개채용 절차가 기간제법 제4조 제2항 적용을 회피하기 위한 의도로 이루어진 형식적인 절차에 불과하다고 할 수 없다.

① 기간제 근로계약을 1년 단위로 갱신하여 온 이 사건 근로자들은 초·중등교육법 시행령에서 정한 근무기간 4년이 지난 후에는 기존 기간제 근로계약을 종료하는 절차를 거친 후 별도의 이 사건 공개채용 절차를 거쳐 2014. 3. 1.부터 새로이 영어회화 전문강사로 근무하게 되었다는 점.

② 이 사건 공개채용 절차는 자격증 유무, 교육 경력 등을 평가기준으로 삼아 1차 서류심사를 통해 합격 인원의 2배수를 선발하고, 1차 서류심사 합격자들을 대상으로 교수·학습과정안 작성 및 이에 따른 영어수업 실연 및 영어 심층면접이라는 2차 심사를 거쳐 최종 합격자를 선발하는 방식이었으며 이러한 이 사건 공개채용 절차는 객관적이고 합리적인 기준에 따라 실질적인 경쟁이 이루어진 신규 채용 절차로 평가할 수 있다는 점.

③ 한편 ○○광역시에는 이 사건 공개채용 절차에서의 1차 서류심사와 관련하여 종전과 비교하여 볼 때 교원 자격 및 교육 경력 여부를 주요한 평가 기준으로 변경하였으나 그 변경된 기준의 내용이나 같은 시기 다른 교육청이 제시한 신규 채용 기준의 내용, 초·중등교육법령에서 요구하는 영어회화 전문강사의 자격 기준 및 영어회화 전문강사 업무의 특성에 따른 교육 경력의중요성, 그 밖에 기존 영어회화 전문강사 중에도 일정한 교원 자격을 갖추지 못한 사람이 있었던 점 등 여러 사정을 고려하면, 광주광역시가 기존 영어회화 전문강사들을 계속 채용하겠다는 의사를 가지고 그 기준을 변경한 것이라고 보기 어렵다는 점.

④ 이 사건 공개채용 절차 진행 당시 기존 영어회화 전문강사들 중 일부는 자신이 기간제 근로계약을 체결하여 근무하고 있던 학교 이외의 다른 학교에 응시하기도 하였으며, 이 사건 근로자들을 포함한 기존 영어회화 전문강사에게 이 사건 공개채용 절차에도 불구하고 이전의 기간제 근로계약을 반복 또는 갱신한다는 인식이나 의사가 있었던 것으로 보이지 않는다는 점 등.

그렇다면 이 사건 공개채용 절차를 거쳐 2014. 3. 1. 새로운 기간제 근로계약이 체결됨으로써 이 사건 근로자들과 광주광역시 사이에 기존 기간제 근로계약의 단순한 반복 또는 갱신이 아닌 새로운 근로관계가 형성되었다고 평가할 수 있어 그 시점에 근로관계는 단절되었다. 결국 기간제법 제4조에서 말하는 계속 근로한 총기간을 산정할 때 2014. 3. 1.을 전후한 기간제 근로계약기간을 합산할 수 없어 이 사건 근로자들의 계속 근로한 총기간이 4년을 초과하지 않으므로, 이 사건 근로자들을 기간제법 제4조 제2항에 따라 기간의 정함이 없는 근로계약을 체결한 근로자라고 할 수 없다.

패소 이유 (사실관계 인정에 관한 관점 차이)

이 사건은 계약기간 만료에 따라 유효하게 근로관계가 단절된 후 신규 채용절차를 거쳐 새로운 근로계약을 체결하는 경우, 이러한 신규 채용절차가 「기간제 및 단시간근로자 보호 등에 관한 법률」 등의 회피를 목적으로 이루어진 형식적인 절차에 불과하다고 볼 만한 사정이 없는 이상 각 근로계약은 단절된 것으로 보아야 할 것인데 이러한 신규 채용절차가 형식적인지 아닌지에 대한 사실관계의 판단으로 결과가 달라진 사건이다.

구체적으로 이 사건은 초심과 법원의 판단이 일치하되 재심의 판단이 다른 경우이고, 사실상 재심의 판단으로 분쟁이 길어진 경우라 판단할 수 있으므로 추후 중노위에서 재심을 거치는 경우 초심을 뒤집기 위해서는 초심에서 판단한 사실관계에 대한 보다 정교하고 구체적인 조사가 뒷받침되어야 한다고 판단된다. 다만 이 사건은 새로운 제도의 시행으로 법원의 법 해석에 관한 일관된 태도가 확정되어 가는 과도기적 사례라는 특수성이 있는 경우이다.

즉, 유사한 사실관계가 문제된 2021_56,57,68 각 사례의 경우 각기 초심지노위, 중노위, 1심법원, 2심법원이 각기 동일한 사실관계, 동일한 법의 적용과 해석을 달리하며 대법원의 판단이 내려질 때까지 혼란스러운 상황이 전개되었던바 이러한 과도기적 상황의 경우에는 중노위로써도 별다른 대안 없이 끝까지 다투며 판례군이 형성되기를 기다리는 것이 최선의 대응이었다고 판단된다.

부록.1. 주요 사건 경과 및 패소 원인 분석

일련번호	2021-57					
판결번호	대법원 2021. 9. 16. 선고 2021두00000					
중노위판정번호	중노위 2018. 12. 17. 중앙2018부해1038					
사건 종류	기간제					
세부 쟁점	무기계약근로자 전환 여부					
심급별 소송결과	1심 법원	재심유지	2심 법원	1심 유지	대법원	원심파기환송
원고, 피상고인	○○광역시		피고보조참가인		이○○	
피고, 상고인	중앙노동위원회위원장		피고측 대리인 선임 여부		없음	
노동조합 지원 여부	없음		원고측 대리인 선임 여부		있음	
재심 결과	초심 유지					
초심의 대법원 판례 일치여부	불일치		재심의 대법원 판례 일치여부		불일치	
기타 특이사항						

주요 사실관계
<사실관계> 가. 지방자치단체인 ○○광역시(이하 ‘○○시’)의 교육·과학·기술·체육 그 밖의 학예(이하 "교육·학예"라 한다)에 관한 사무는 ○○시의 사무로서, 그 교육감은 교육·학예에 관한 소관 사무로 인한 소송에 대하여 당해 시·도에 해당하는 ○○시를 대표한다(지방교육자치에 관한 법률 제2, 18조 참조). ○○초등학교는 원고 시 교육감의 지도·감독을 받는 초·중등교육법 제3, 6조가 정한 공립학교이다. 나. 이○○(이하 ‘이 사건 근로자’)는 2010. 3. 1. ○○시 산하 위 ○○초등학교장과 사이에, 이 사건 근로자가 위 ○○초등학교에서 초등학교 영어 수업시수 확대에 따라 추가되는 수업을 분담하여 기존 교사의 수업 부담을 경감하면서 추가로 영어교육 관련 업무와 원어민 보조교사 관리 업무를 담당·지원하는 것을 내용으로 하는 초·중등교육법 제22조1), 같은 법 시행령 제42조2)가 정한 ‘영어회화 전문강사’로서 계약기간 1년 동안 일하기로 하는 근로계약을 체결하고 위 ‘영어회화 전문강사’로 채용된 바 있다. 다. 이후 이 사건 근로자는 위 ○○초등학교장과 사이에 2010. 3. 1.자 근로계약 체결 이후 2014. 2. 28.까지 1년마다 3. 1.자로 근로계약을 새로이 체결하면서 3회에 걸쳐 4년간 위 근로계약을 갱신해왔었고, 위 ○○초등학교장은 2014. 1. 14. 이 사건 근로자에게, 2014. 2. 28.부로 2013. 3. 1.자 근로계약(근로기간: 2013. 3. 1.부터 2014. 2. 28.까지)이 기간만료로 종료한다는 통보를 하였다. 라. 이후 이 사건 근로자는 새로운 채용절차를 통해 2014. 1. 23. ○○초등학교 2014년도 영어

회화 전문강사로 선발되었고, 2014. 3. 1. 위 ○○초등학교장과 사이에 위와 같은 내용의 계약기간 1년인 근로계약을 다시 체결하며 그때부터 2018. 2. 28.까지 1년마다 3. 1.자로 근로계약을 새로이 체결하면서 3회에 걸쳐 4년간 위 근로계약을 다시 갱신해왔다.

마. 위 ○○초등학교장은 2018. 1. 10. 이 사건 근로자가 2014. 3. 1.자 근로계약을 체결하였던 데에 관하여 2018. 2. 28. 계약기간이 만료함을 통보한다는 ‘계약 만료 통보’를 하였고, 이후 새롭게 계약을 체결하지 않았으며 그에 따라 이 사건 근로자는 ‘2018. 2. 28.자 근로계약 기간 만료 즉 해고가 부당해고임을 인정해 달라.’는 구제 신청을 하였다.

<심급별 결과>

[부산지노위] 부당해고임을 인정하여 구제신청 인용

[중노위] 부산시의 청구 기각. 초심 유지

[1심 법원, 2심 법원] 이 사건 근로자에 대한 ○○시의 해고는 부당해고로서 효력이 없고, 따라서 재심판정은 적법하다고 판시

[대법원] 이 사건 근로자는 기간의 정함이 없는 근로계약을 체결한 근로자가 아니라고 판시하여 사건을 대전고등법원으로 돌려보냈고, 이후 확정

판결 요지

기간제법 규정 내용과 기간제 근로계약의 남용을 방지함으로써 근로자의 지위를 보장하려는 입법 취지 등을 고려하면, 기간제 근로계약이 반복하여 체결되거나 갱신되어 일정한 공백기 없이 기간제근로자가 계속적으로 근로한 경우라면, 특별한 사정이 없는 한 최초 기간제 근로계약에서부터 최종 기간제 근로계약에 이르기까지 기간 전체가 기간제법 제4조에서 말하는 기간제근로자의 사용 기간으로서 ‘계속 근로한 총기간’에 포함되어야 한다. 다만 기간제 근로계약의 대상이 되는 업무의 성격, 기간제 근로계약의 반복 또는 갱신과 관련한 당사자들의 의사, 반복 또는 갱신된 기간제 근로계약을 전후한 기간제근로자의 업무 내용·장소와 근로조건 유사성, 기간제 근로계약의 종료와 반복 또는 갱신 과정에서 이루어진 절차나 그 경위 등을 종합적으로 고려할 때 당사자 사이에 기존 기간제 근로계약의 단순한 반복 또는 갱신이 아닌 새로운 근로관계가 형성되었다고 평가할 수 있는 특별한 사정이 있는 경우에는 기간제근로자의 계속된 근로에도 불구하고 그 시점에 근로관계가 단절되었다고 보아야 하고, 그 결과 기간제법 제4조에서 말하는 ‘계속 근로한 총기간’을 산정할 때 그 시점을 전후한 기간제 근로계약기간을 합산할 수는 없다(대법원 2020. 8. 20. 선고 2017두52153, 대법원 2020. 8. 20. 선고 2018두51201 판결 등 참조).

다음과 같은 사정을 고려하여 보면 이 사건 근로자를 기간제법 제4조 제2항에 따라 기간의 정함이 없는 근로계약을 체결한 근로자라고 할 수 없다

① 기간제 근로계약을 1년 단위로 갱신하여 온 이 사건 근로자는 초.중등교육법 시행령에서 정한 근무기간 4년이 지난 후에는 기존 기간제 근로계약을 종료하는 절차를 거친 후 별도의 이 사건 공개채용 절차를 거쳐 2014. 3. 1.부터 새로이 영어회화 전문강사로 근무하게 되었다는 점,

② ○○시 소속 학교별로 진행한 2014년도 영어회화 전문강사 공개채용 절차(이하 ‘이 사건 공개채용 절차’라고 한다)는 자격증 유무, 교육 경력 등을 평가기준으로 삼아 1차 서류심사를 통해 합격 인원의 2배수를 선발하고, 1차 서류심사 합격자들을 대상으로 교수.학습과정안 작성 및 이에 따른 영어수업 실연 및 영어 심층면접이라는 2차 심사를 거쳐 최종 합격자를 선발하는 방식이었다. 참가인이 응시한 ○○초등학교에는 이 사건 공개채용 절차에 3명이 응시하였고, 이 사건 근로자는 1차 서류심사 및 2차 심사를 거쳐 최종 합격자로 선발되었으며, 위와 같은 평가항목이나 평가방법 등에 비추어 볼 때 이 사건 근로자가 응시한 이 사건 공개채용 절차는 객관적이고 합리적인 기준에 따라 실질적인 경쟁이 이루어진 신규 채용 절차로 평가할 수 있다는 점,

부록.1. 주요 사건 경과 및 패소 원인 분석

③ 2014. 3. 1.을 전후하여 이 사건 근로자에 대해 이루어진 종전 기간제 근로계약의 종료 절차 및 이 사건 공개채용 절차가 기간제법 제4조 제2항 적용을 회피하기 위한 의도로 이루어진 형식적인 절차에 불과하다고 볼 만한 사정이 있다고 보이지 않는다는 점 등.

이러한 사정들을 앞에서 본 법리에 비추어 살펴보면, 이 사건 공개채용 절차를 거쳐 2014. 3. 1. 새로운 기간제 근로계약이 체결됨으로써 이 사건 근로자와 ○○시 사이에 기존 기간제 근로계약의 단순한 반복 또는 갱신이 아닌 새로운 근로관계가 형성되었다고 평가할 수 있어 그 시점에 근로관계는 단절되었다. 결국 기간제법 제4조에서 말하는 계속 근로한 총기간을 산정할 때 2014. 3. 1.을 전후한 기간제 근로계약기간을 합산할 수 없어 참가인의 계속 근로한 총기간이 4년을 초과하지 않으므로, 이 사건 근로자를 기간제법 제4조 제2항에 따라 기간의 정함이 없는 근로계약을 체결한 근로자라고 할 수 없다.

패소 이유 (사실관계 인정에 관한 관점 차이)

이 사건은 계약기간 만료에 따라 유효하게 근로관계가 단절된 후 신규 채용절차를 거쳐 새로운 근로계약을 체결하는 경우, 이러한 신규 채용절차가 「기간제 및 단시간근로자 보호 등에 관한 법률」 등의 회피를 목적으로 이루어진 형식적인 절차에 불과하다고 볼 만한 사정이 없는 이상 각 근로계약은 단절된 것으로 보아야 할 것인데 이러한 신규 채용절차가 형식적인지 아닌지에 대한 사실관계의 판단으로 결과가 달라진 사건이다.

구체적으로 이 사건은 초심과 법원의 판단이 일치하되 재심의 판단이 다른 경우이고, 사실상 재심의 판단으로 분쟁이 길어진 경우라 판단할 수 있으므로 추후 중노위에서 재심을 거치는 경우 초심을 뒤집기 위해서는 초심에서 판단한 사실관계에 대한 보다 정교하고 구체적인 조사가 뒷받침되어야 한다고 판단된다. 다만 이 사건은 새로운 제도의 시행으로 법원의 법 해석에 관한 일관된 태도가 확정되어 가는 과도기적 사례라는 특수성이 있는 경우이다.

즉, 유사한 사실관계가 문제된 2021_56,57,68 각 사례의 경우 초심지노위, 중노위, 1심법원, 2심법원이 각기 동일한 사실관계, 동일한 법의 적용과 해석을 달리하며 대법원의 판단이 내려질 때까지 혼란스러운 상황이 전개되었던바 이러한 과도기적 상황의 경우에는 중노위로써도 별다른 대안 없이 끝까지 다투며 판례군이 형성되기를 기다리는 것이 최선의 대응이었다고 판단된다.

일련번호	2021-62					
판결번호	대전고등법원 2021. 9. 30. 선고 2021누00000 판결					
중노위판정번호	중노위 2019. 7. 3. 중양2019부해476					
사건 종류	부당해고					
세부 쟁점	부당해고, 구제이익, 상시근로자수					
심급별 소송결과	1심 법원	재심판정취소	2심 법원	재심판정취소	대법원	
원 고	의료법인 ○○의료재단		피고보조참가인		남○○	
피 고	중앙노동위원회위원장		피고측 대리인 선임 여부		선임 안 함	

노동조합 지원 여부	있음	원고측 대리인 선임 여부	선임 함
재심 결과	초심유지		
초심의 대법원 판례 일치여부	불일치	재심의 대법원 판례 일치여부	불일치
기타 특이사항			

주요 사실관계

<사건 개요>

가. 원고는 2016. 1. 19. 의료기관의 설치 및 운영 등을 목적으로 설립된 법인으로 2019. 4. 6. 부산 북구 E에서 F병원(이하 '이 사건 병원')을 개원하였다.

나. 피고보조참가인(이하 '참가인')은 2018. 10. 21. G병원 원장 H(원고의 이사장인 I의 남편)로부터 면접을 본 후 2018. 12. 10.부터 이 사건 병원의 행정원장으로 근무하기로 하고, 2018. 10. 29. 원고와 사이에 근로계약을 체결하였다.

다. H는 2018. 11. 5. 참가인에게 전화로 참가인에 대한 채용내정을 취소한다고 통보하였다.

라. F병원 측은 참가인과의 근로계약은 2019. 12. 10.자로 이미 만료되었으므로, 참가인의 구제이익도 소멸되었다고 주장하나, 참가인은 정규직 근로계약이므로 구제이익이 소멸되지 않았다고 주장하였다.

마. F병원 측은 이 사건 채용내정 취소 당시 원고는 설립등기만을 마쳤을 뿐 상근하는 직원이 없었고, H이 원장으로 있었던 G병원은 H의 개인병원으로 법인인 원고 및 원고가 운영하는 이 사건 병원과는 독립된 별개의 사업장이므로, 당시 원고는 상시 5명 이상의 근로자를 사용하는 사업장이 아니어서 이 사건 채용내정 취소에는 근로기준법상 해고의 방법에 관한 규정이 적용되지 않는다고 주장한다. 또한, 근로기준법이 적용된다 하더라도, 참가인은 채용내정 상태에 불과하고 입사지원서에 중요한 학력사항을 누락하거나 근무경력을 사실과 다르게 기재하였는바, 참가인에 대하여 이 사건 채용내정 취소를 할 만한 정당한 사유가 있었다고 주장한다.

바. 반면 피고인 중노위는 I은 명목만 원고의 이사장일 뿐 원고나 이 사건 병원의 설립 및 운영에 있어서 실질적이고 최종적인 권한을 갖고 있었던 사람은 G병원 원장 H인 점, H은 이 사건 병원 부지 및 그 지상 건물을 원고에 출연하였고 G병원 기획실장이자 H의 아들인 J이 이 사건 병원의 원장으로 부임한 점, G병원의 직원들이 이 사건 병원으로 이직하였고 이 사건 병원 직원들에 대한 채용공고 등도 G병원 홈페이지에서 한 점, 참가인에 대한 채용면접 내지 채용취소 과정을 모두 H이 주도한 점 등에 비추어 원고와 G병원은 실질적으로 하나의 사업장이므로 정당하게 근로기준법 적용 대상 사업장이었다고 주장했다. 그런데, 참가인에 대한 이 사건 채용내정 취소를 하면서 그 사유와 시기를 서면으로 통지하지 아니하여 근로기준법 제27조를 위반하였고, 참가인이 제출한 입사지원서의 기재 등에 비추어 보면 원고가 주장하는 이 사건 채용내정 취소의 사유도 정당하다고 볼 수 없다고 주장했다.

사. 참가인은 2019. 1. 30. 이 사건 해고가 부당해고라고 주장하며 부산지노위에 구제신청을 하였다.

<심급별 결과>

[부산지노위] '원고는 상시 5명 이상의 근로자를 사용하는 근로기준법 적용대상 사업장에 해당하

고, 이 사건 채용내정 취소를 구두로 한 것은 근로기준법 제27조의 서면통지 의무를 위반한 것이므로 부당해고에 해당한다'는 이유로 참가인의 구제신청을 인용
[중노위] 초심판정과 동일한 이유로 원고의 재심신청 기각

[1심 법원] 원고 사업장은 사실상 독립된 사업장으로 채용당시 근로자가 없는 사업장이었으므로 근로기준법상 해고 관련 규정의 적용이 없다는 이유로 재심판정 취소
[2심 법원] 1심 판결 유지

판결 요지

가. 참가인의 구제이익이 소멸하였는지 여부

이 사건 근로계약 제1조에는 '본 근로계약은 기간의 정함이 없는 정규직 근로계약이다'라고 기재되어 있고, 제2조 제2항에는 '정규직 근로자인 경우는 계약기간의 종료 후에도 별도의 계약이 없는 경우 1년 단위로 계약을 자동연장한 것으로 본다'고 기재되어 있는 사실은 앞서 본 바와 같다. 위 각 문언에 의하면, 원고와 참가인은 기간의 정함이 없는 정규직 근로계약을 체결한 것으로서, 제2조 제2항 규정은 별도의 계약이 없는 한 1년 단위로 근로계약 기간이 자동연장 된다는 점을 확인, 강조한 것에 불과하다고 할 것이다. 따라서 이 사건 근로계약이 참가인의 입사일(2018. 12. 10.)로부터 1년이 경과한 2019. 12. 10. 만료되었다고 보기 어려우므로, 참가인의 구제이익이 소멸하였다는 원고의 이 부분 주장은 이유 없다.

나. 원고가 상시 5명 이상의 근로자를 사용하는 사업장에 해당하는지 여부

참가인에 대한 이 사건 채용내정 취소 이전까지 원고에 소속된 직원이 1명도 없었던 사실은 앞서 본 바와 같다. 나아가 이 사건 근로계약 체결 및 이 사건 채용내정 취소 당시 원고는 G병원과 독립되어 독자적인 사업을 영위하고 있었던 것으로 보이고, 원고와 G병원이 경영상 일체를 이루고 있다거나 원고와 G병원이 실질적으로 동일한 하나의 사업장에 불과하였다고 볼 수 없다. 결국 원고의 근로자 수에 G병원의 근로자 수를 합산하여 산정할 수 없는바, 원고는 상시 5명 이상의 근로자를 사용하는 사업장에 해당하지 아니한다.

가) H가 운영하는 G병원은 원고 및 원고가 운영하는 이 사건 병원과는 그 재정, 회계, 인적·물적 자원 등이 서로 명확히 분리되어 있다.

나) H가 원고의 설립 시 H 소유의 이 사건 병원 부지 등을 기본재산을 출연한 것에 어떠한 위법사유가 있다고 볼 수 없고, 위와 같은 사정만으로 당시 원고와 G병원이 경영상 일체를 이루면서 유기적으로 운영되고 있었다고 보이지는 아니한다.

다) 원고는 이 사건 병원 건물이 준공되기 전 개원 준비를 하는 과정에서 별다른 인적·물적 자원이 없는 특수한 상태였는바, 원고가 대표자 I의 남편 H가 운영하던 G병원의 일시적인 지원 및 협조를 받았던 것으로 보이고, G병원의 직원들은 H의 지시에 따라 원고 직원들이 수행하여야 할 업무를 대행한 것으로 보인다. 따라서 앞서 본 사정만으로 곧바로 원고의 인적·물적 자원이 독립되어 있지 않다거나 사실상 원고와 G병원이 하나의 사업장에 해당하였다고 단정할 수 없다.

라) 더욱이 원고가 G병원의 홈페이지 등을 통하여 그 소속 직원에 대한 채용공고를 하기는 하였으나, 그 채용공고상 G병원이 아닌 이 사건 병원의 경력 및 신규직원 채용임을 명확히 기재하거나 원고(이 사건 병원) 및 G병원 소속 직원을 구분하여 채용하였던 것으로 보인다. 또한 원고는 직원채용 이후에도 소속 직원에 대한 지휘·감독 및 임금 지급 등을 독자적으로 하였던 것으로 보인다.

마) 비록 참가인이 I이 아닌 H에게 면접을 보고 원고에게 채용되었고, H로부터 전화로 이 사건 채용내정 취소 통보를 받기는 하였다. 그러나 이는 이 사건 병원 개원 전에 일시적으로 행해

진 것으로 보이고, H가 원고의 직원 채용 과정에 직접적, 계속적으로 관여하거나 실질적인 지휘·감독권을 행사하였다고 볼 만한 자료는 없다. 따라서 참가인에 대한 특수한 채용 과정 자체만으로 원고의 독립성, 독자성을 부정할 수는 없다.

패소 이유

첫번째 쟁점인 구제이익에 관한 주장은 법원에서 최종적으로 중노위의 판단이 옳은 것으로 결정되었다. 그러나 패소 여부를 가르는 중요한 쟁점은 구제이익이 아닌 상시 근로자수 산정을 위한 사업의 독립성 판단에 관한 것이었다. 원고인 사용자는 참가인에 대한 채용내정 당시에 근로기준법 적용 대상인 5인 이상 사업장에 해당하지 않는다고 주장한 반면, 노동위원회는 초심과 재심 모두 근로자 채용 과정에서 인적, 물적 지원을 제공한 원고의 배우자 소유의 병원과 원소 소유의 병원이 처음부터 독립된 것이 아닌 “실질적으로 동일한 하나의 사업장에 불과”하다고 주장하였다. 원고소유의 병원과 원고 배우자 소유의 병원이 실질적으로 동일한 하나의 사업장에 해당하는지가 쟁점인 것이다.

이에 대하여 법원은, 통상적인 사업장의 독립성 판단 기준인, 회계와 인사의 구별성 내지 독립성, 사용자의 실질적인 근로자 채용 권한 및 규정 제정 권한 행사 여부 등을 기준으로 적용하고 그 결과 양 병원이 서로 독립된 사업장이라고 판단하였다. 그리고 그 판단을 기초로 원고의 사업장은 참가인을 채용할 당시 근로자가 없는 사업장이었다고 판단하여 원고의 주장을 인용하였다. 완전히 동일한 사실관계를 두고 그에 관한 법리적 판단이 달라진 것으로서, 중노위로서는 1심 법원의 판단에 대하여 항소하여 법원이 어떤 결론을 내릴 것인지를 다시 한 번 확인하는 것이 불가피했을 것으로 판단된다. 또한 1심 법원의 판단과 고등법원의 판단이 일치한 점, 사업장의 독립성 판단에 대한 법원의 법리구성에 결정적인 위법요소를 찾을 수 없다는 점을 고려할 때, 중노위가 대법원에 상고하지 않은 것은 적절한 판단이었다고 사료된다.

일련번호	2021-64					
판결번호	서울고등법원 2021. 10. 6. 선고 2020누00000					
중노위판정번호	중노위 2019. 7. 22. 중앙2019부해489					
사건 종류	부당해고					
세부 쟁점	근로기준법상 근로자성					
심급별 소송결과	1심 법원	재심취소	2심 법원	원심유지	대법원	상고안함
항 소 인 (피고)	중앙노동위원회위원장		피고 항소인의 보조참가인		이○○ ⁸⁴⁾	
피항소인 (원고)	주식회사 ○○○ ⁸⁵⁾		피고측 대리인 선임 여부		선임안함	
노동조합 지원 여부	없음		원고측 대리인 선임 여부		선임	
재심 결과	초심유지					

부록.1. 주요 사건 경과 및 패소 원인 분석

초심의 대법원 판례 일치여부	불일치	재심의 대법원 판례 일치여부	불일치
기타 특이사항	노동위원회의 판정이 1심에서 뒤집혔고, 2심에서도 같은 결론이 나자 노동위원 회측에서 상고를 하지 않음.		

주요 사실관계

<사실관계>

가. 주식회사 ○○은 2015. 3. 25. 설립되어 개인간 대출 서비스를 제공하는 회사이고, 이○○는 2016. 4. 11.부터 원고 기획팀 팀장으로 일하던 사람이며, 2016. 7. 5. 주식회사 ○○의 사내이사로 등기되었다.

나. 주식회사 ○○은 2018. 2.경 설립 이래 그때까지 임직원들에게 주식매수선택권을 부여하면서 단 한 번도 주주총회 특별결의를 거치지 않았음을 발견하고, 2018. 11. 1. 임시주주총회를 개최하여 임직원들의 인사 및 기획·투자 업무를 담당하는 이○○를 이사에서 해임한다는 결의를 하였다. 주식회사 ○○은 2018. 11. 16. 이○○에게 위 주주총회 결의를 통보하였다(이하 ‘이 사건 통보’).

다. 이○○는 2018. 12. 21. 서울지노위에 서울 2018부해2971호로 이 사건 통보가 부당해고에 해당한다고 주장하며 구제를 신청하였다.

<심급별 결과>

[서울지노위] 이○○가 근로기준법상 근로자에 해당하고, 이 사건 통보는 근로자에 대한 해고인데 정당한 해고사유가 없을 뿐만 아니라, 서면으로 통지되지 아니하였다는 이유로 이 사건 통보가 부당해고라는 취지의 초심판정을 내렸다. 주식회사 ○○은 이에 불복하였다.

[중노위] 초심판정과 같은 취지로 주식회사 ○○의 재심신청 기각

[1심 법원] 이○○가 근로기준법에서 말하는 근로자에 해당하지 않으므로 이○○를 근로자로 보아 그에 대한 이 사건 통보가 부당해고라고 판단한 이 사건 재심판정은 위법하다고 판시

[2심 법원] 1심법원의 판결과 같은 판결, 이대로 확정

판결 요지

가. 이○○가 근로기준법상의 근로자인지 여부

1) ① 주식회사 ○○의 이○○에 대한 처우, ② 주식회사 ○○ 임직원 인사 업무에 대한 이○○의 관여, ③ 주식회사 ○○ 내부 의사결정 과정에 대한 이○○의 관여에 관한 객관적인 인정사실 및 다음과 같은 사정을 고려하여 보면 이○○는 업무집행권을 가지는 대표이사 등의 지휘·감독 아래 일정한 노무를 담당하면서 그 노무에 대한 대가로 일정한 보수를 지급받았다고 보기 어렵고, 오히려 주식회사 ○○의 다른 일반 직원과는 차별화된 처우를 받았을 뿐만 아니라, 주식회사 ○○에 필요한 의사결정에 참여하면서 위임받은 사무를 처리하는 지위의 임원에 해당하였던 것으로 보인다.

2) 주식회사 ○○이 이○○를 영입할 당시 그에게 제공한 주식매수선택권은 그 무렵 함께 영입된 나머지 11명의 임직원에게 제공한 것과 비교하면 현저히 많은 양에 해당하고, 이렇게 현저히

84) 1심, 2심 : 법무법인(유한) 바른

85) 1심 ,2심 : 법무법인(유한) 태평양

많은 양의 주식매수선택권을 부여한 것은 단순히 성실한 근로를 장려하기보다는 적극적으로 경영에 관여할 것을 예상하고 이루어진 일이라고 봄이 상당하다.

3) 이○○는 주식회사 ○○ 임직원의 인사 업무에 대하여 주식회사 ○○ 대표이사로부터 상당한 결정권을 위임받고, 실제로 행사하였던 것으로 보인다.

4) 이○○는 임직원의 인사 업무 이외에도 주식회사 ○○의 주 영업인 개인간 대출 업무에도 상당한 의견을 개진하면서 주식회사 ○○의 경영에 참여한 것으로 보인다.

5) 주식회사 ○○은 모든 임직원들과 실질적인 관계를 불문하고 형식상으로는 일괄적으로 근로계약을 체결하고, 그에 따라 근로소득세를 원천징수하고 있으며, 개별적인 연봉 협상을 거쳐 해당 지급할 급여를 확정하므로 이○○가 주식회사 ○○과 근로계약을 체결하였다는 형식만으로는 해당 임직원이 근로기준법상 근로자인지를 판단하는 데 핵심적인 징표가 되기 어렵다.

나. 결국 이○○는 근로기준법상 근로자에 해당하지 아니함에도 이○○를 근로자로 보아 그에 대한 이 사건 통보가 부당해고라고 판단한 이 사건 재심판정은 위법하므로 취소되어야 한다.

패소 이유 (사실관계에 관한 인정 차이)

이 사건의 주된 쟁점은 형식상 근로계약을 체결하였으나 등기이사인 자의 근로자성이고 계약의 형식이 근로계약임에도 실질적인 지시·종속 관계가 인정되지 않은 사건이다.

형식적으로 계약의 형태가 근로계약임에도 근로자성이 문제된 사건이기 때문에 근로자임을 주장하는 측과 회사의 격렬한 공방이 있었고, 그 과정에서 과연 근로자라고 주장하는 자가 어떠한 업무를 수행하였는지, 그의 고용 조건은 어떠했는지에 대한 사실관계의 조사 및 그 판단이 중요했던 사건이라고 판단된다.

중노위는 “① 팀장 입사시 작성한 근로계약서가 이사로 등재된 이후에도 동일하게 적용되었고 근로조건이 차이가 없는 점, ② 근로자가 이사회 의사결정에 참여하는 등 이사로서 권한을 행사하였다는 구체적인 입증자료가 없는 점, ③ 근로자가 지급받은 스톡옵션은 이전 직장에서 받던 보수를 보전하는 차원에서 부여된 것으로 볼 수 있는 점, ④ 4대 사회보험에 계속 가입된 점 등을 종합하면 근로자는 근로기준법상 근로자에 해당함”이라고 판단하였으나,

법원은 다른 임직원들과의 근로조건에서 현저한 차이가 있다고 판시하는 등 사실관계를 해석하고 이를 판단의 근거로 활용함에 있어서 노동위원회의 판단과는 전혀 다른 판단을 내렸고, 이는 동일한 사실관계를 어떠한 관점으로 해석하느냐에 따른 차이에서 기인한 것으로 보인다.

한편, 사실관계를 다룰 수 있는 2심에서도 1심 법원과 같은 판단이 내려졌으므로 무의미한 대법원 항고를 하지 않은 중노위의 결정은 합리적으로 보인다.

일련번호	2021-65
판결번호	대법원 2021. 10. 28. 선고 2021두00000
중노위판정번호	중노위 2019. 8. 19. 중양2019부해769

부록.1. 주요 사건 경과 및 패소 원인 분석

사건 종류	기간제					
세부 쟁점	갱신거절 합리적 이유 존부					
심급별 소송결과	1심 법원	재심취소	2심 법원	1심 유지	대법원	원심유지
원고, 피상고인	주식회사 ○○종합관리		피고보조참가인		주○○, 한○○	
피고, 상고인	중앙노동위원회위원장		피고측 대리인 선임 여부		없음	
노동조합 지원 여부	없음		원고측 대리인 선임 여부		선임	
재심 결과	초심 유지					
초심의 대법원 판례 일치여부	불일치		재심의 대법원 판례 일치여부		불일치	
기타 특이사항						

주요 사실관계 <사실관계> 가. 주식회사 ○○종합관리는 공동주택 관리업 등을 목적으로 1996. 7. 9. 설립된 주식회사이다. 근로자 주○○은 2018. 8. 14., 참가인 한○○는 2015. 1. 10. 주식회사 ○○종합관리에 각 입사하여 ○○시 소재 ○○하이빌1차아파트(이하 ‘이 사건 아파트’라 한다)에서 경비원으로 근무하였다. 나. 주식회사 ○○종합관리는 2018. 12. 30. 이 사건 근로자들에게 2018. 12. 31.자로 근로계약이 만료됨을 각 통지하였다. 다. 이 사건 근로자들은 주식회사 ○○종합관리들의 기간만료 통지가 부당해고에 해당한다고 주장하며 2019. 3. 22. 경기지노위에 구제신청을 하였다. <심급별 결과> [경기지노위] 이 사건 근로자들에게 각 근로계약의 갱신기대권이 인정되고 원고에게는 각 근로계약의 갱신을 거절할 합리적 이유가 없다고 판정하여 구제신청 인용. [중노위] 초심 유지 [1심 법원] 이 사건 재심판정은 이 사건 근로자들에게 갱신기대권을 인정한 점에서는 적법하나, 갱신 거절의 합리적 이유는 존재하지 않는다고 본 점에서는 위법하므로 취소되어야 한다고 판시 [2심 법원] 1심 법원과 같은 판단 [대법원] 근로기준법 제27조의 내용과 취지에 비추어 볼 때 기간제 근로계약이 종료된 후 갱신 거절의 통보를 하는 경우에까지 근로기준법 제27조를 준수하도록 예정하였다고 보기 어렵다고 해석하면서 기간제 근로계약이 종료된 후 사용자가 갱신 거절의 통보를 하는 경우에는 근로기준법 제27조가 적용되지 않는다고 판시

판결 요지

1. 갱신기대권의 인정 여부

기간을 정하여 근로계약을 체결한 근로자의 경우 기간이 만료됨으로써 근로자로서의 신분관계는 종료되고 근로계약을 갱신하지 못하면 갱신 거절의 의사표시가 없어도 당연 퇴직되는 것이 원칙이다. 그러나 근로계약, 취업규칙, 단체협약 등에서 기간만료에도 일정한 요건이 충족되면 당해 근로계약이 갱신된다는 취지의 규정을 두고 있거나, 그러한 규정이 없더라도 근로계약의 내용과 근로계약이 이루어지게 된 동기 및 경위, 계약 갱신의 기준 등 갱신에 관한 요건이나 절차의 설정 여부 및 실태, 근로자가 수행하는 업무의 내용 등 당해 근로관계를 둘러싼 여러 사정을 종합할 때 근로계약 당사자 사이에 일정한 요건이 충족되면 근로계약이 갱신된다는 신뢰관계가 형성되어 있어 근로자에게 근로계약이 갱신될 수 있으리라는 정당한 기대권이 인정되는 경우에는, 사용자가 이를 위반하여 부당하게 근로계약의 갱신을 거절하는 것은 부당해고와 마찬가지로 아무런 효력이 없고, 이 경우 기간만료 후의 근로관계는 종전의 근로계약이 갱신된 것과 동일하다(대법원 2011. 4. 14. 선고 2007두1729 판결, 대법원 2014. 2. 13. 선고 2011두12528 판결 등 참조).

그리고 정년이 지난 상태에서 기간제 근로계약을 체결한 경우에는 위에서 본 여러 사정 외에 해당 직무의 성격에서 요구되는 직무수행 능력과 근로자의 업무수행 적격성, 연령에 따른 작업능률 저하나 위험성 증대의 정도, 해당 사업장에서 정년이 지난 고령자가 근무하는 실태와 계약이 갱신된 사례 등을 종합적으로 고려하여 근로계약 갱신에 관한 정당한 기대권이 인정되는지를 판단하여야 한다(대법원 2017. 2. 3. 선고 2016두50563 판결 참조, 대법원 2019. 10. 31. 선고 2019두45647 판결).

다음과 같은 사정을 고려하여 보면 원고와 참가인들 사이에는 근로계약기간이 만료되더라도 근무평가 등의 일정한 요건이 충족되면 근로계약이 갱신된다는 신뢰관계가 형성되어 있어 참가인들에게는 근무평가에 따라 원고와의 근로계약이 갱신될 수 있으리라는 정당한 기대권이 인정된다.

① 주식회사 ○○종합관리의 취업규칙 제11조 제3호는 근로의 재계약은 근무평가에 따르며 근무평가 점수가 기준에 미달하는 경우에는 재계약하지 아니한다는 취지로 규정되어 있고, 제12조제1호는 근로계약은 원칙적으로 1년 이하의 기간제로 체결하되, 필요에 따라 갱신 체결할 수 있다고 규정하고 있다. 위와 같은 취업규칙의 각 규정의 취지는 근로자들의 근무평가를 요건으로 근로계약이 갱신될 수 있다는 의미로 해석된다는 점,

② 주식회사 ○○종합관리는 근로자 주○○과의 근로계약을 1달의 시용기간을 거친 후 갱신한 바 있고, 근로자 한○○와의 근로계약을 11차례에 걸쳐 갱신하기도 하였다는 점,

③ 이 사건 재심판정 절차에서 원고는 ‘근무평가 점수가 70점 이상인 경비원에 대하여 재계약을 하였고, 경비원 10명 중에 1명 정도 근무평가 점수가 좋지 않을때 재계약이 되지 않는다’는 취지로 진술하였는바, 원고의 진술에 의하더라도 상위 90%에 해당하는 대다수의 경비원들이 재계약을 체결하고, 하위 10%에 해당하는 예외적 경우에만 재계약을 체결하지 않았던 것으로 보인다는 점,

④ 근로계약 종료 예고통보서의 수령을 확인하는 ‘근로계약 종료 예고통보서 수령증’ 하단에는 ‘기간 중 근무실태, 경비원 근무평가, 업무수행능력 및 지시사항 이행, 민원발생, 동료평가, 건강상태 등 전반적인 내용을 종합평가하여 재계약된다’고 기재되어 있었고, 근로자들이 수행하던 경비업무는 상시적 업무로서 근로계약 종료 예고통보서의 내용대로 2018. 12. 31.까지 이 사건 아파트 소속 경비원 전원이 기간만료되면 원고가 이 사건 아파트와 체결한 경비용역계약의 종기인 2018. 2. 28.까지 이 사건 아파트의 경비업무를 수행할 경비원이 없게 되므로, 위 근로계약 종료 예고통보서를 받은 경비원들은 근무평가에 따라 일응 근로계약이 갱신될 것으로 예상하였을 것으로 보인다는 점,

⑤ 경비업무는 고령의 연령층에서도 널리 수행하고 있는 업무의 하나로서 이 사건에서도 참가인들의 연령에 따른 작업 능률 저하나 위험성이 증대되었다는 사정은 보이지 않는다는 점.

⑥ 한편 주식회사 ○○종합관리가 근로자들과 체결한 근로계약에는 ‘재계약 등에 갱신기대권이 없는 것에 동의한다’는 내용이 존재하기는 하나, 앞서 살핀 법리에 의할 때 갱신기대권의 존재여부는 근로계약의 내용 뿐 아니라 취업규칙의 내용 및 근로계약을 둘러싼 제반사정을 종합해서 판단하는 것이므로, 단순히 원고가 갱신기대권을 배제하고자 하여 근로계약의 내용으로 삼은 것만으로는 참가인들의 갱신기대권을 부인할 수는 없다는 점 등.

2. 갱신 거절의 합리적 이유의 존부

근로자에게 이미 형성된 갱신에 대한 정당한 기대권이 있는데도 사용자가 이를 배제하고 근로계약의 갱신을 거절한 데에 합리적 이유가 있는지가 문제 될 때에는 사용자의 사업 목적과 성격, 사업장 여건, 근로자의 지위와 담당 직무의 내용, 근로계약 체결 경위, 근로계약의 갱신 요건이나 절차의 설정 여부와 운용 실태, 근로자에게 책임 있는 사유가 있는지 등 근로관계를 둘러싼 여러 사정을 종합하여 갱신 거부의 사유와 절차가 사회통념에 비추어 볼 때 객관적이고 합리적이며 공정한지를 기준으로 판단하여야 하고, 그러한 사정에 관한 증명책임은 사용자가 부담한다(대법원 2017. 10. 12. 선고 2015두44493 판결 참조).

다음과 같은 사실을 고려해보면, 주식회사 ○○종합관리가 근로자들에 대하여 실시한 근무평가에 객관성 및 합리성이 인정되므로, 그러한 평가에 근거하여 근로자들에 대하여 근로계약의 갱신을 거절한 데에는 합리적 이유가 인정된다.

① 주식회사 ○○종합관리는 아파트 단지와 경비용역계약을 체결하여 용역을 공급하는 지위에 있으므로 원고의 이와 같은 사업구조상 아파트 단지 내지 입주민의 민원은 재계약에 영향을 미치는 요소일 수밖에 없다. 따라서 주식회사 ○○종합관리가 근로자들의 언행이나 성실도에 대하여 근무평가를 하는 것에는 합리성이 인정되는 점.

② 주식회사 ○○종합관리는 취업규칙에 별첨3으로 근무평가표를 규정하여 근로자들에게 평가기준을 사전에 공개하였고, 취업규칙의 개정으로 배점이 일부 변경된 점이 근로자들의 근무평가 시에 반영되지 않기는 하였으나 평가항목에는 변동이 없었고, 세부 평가 항목에도 일응 합리성이 인정된다는 점.

③ 복무규정 항목과 관련하여, 근로자들은 반복적·지속적으로 순찰 경로를 누락하는 등 임의로 순찰을 단축해서 실시하였던 사실이 인정되는바, 이 사건 근로자들이 순찰을 생략한 구간에 대하여는 순찰이 실시되지 않은 것으로서 근무평가표에서 정한 ‘순찰 미실시’에 해당하거나 이에 준하는 것으로 볼 수 있고, 근로자 한○○는 근무지 이탈이 종종 있었고, 근로자 주○○은 보청기 배터리의 고장 내지 방전 등으로 근무지를 이탈했던 점을 고려하면 주식회사 ○○종합관리가 이 사건 근로자들에 대한 평정을 하면서 복무규정 항목에서 하(30점)로 부여한 것에 수긍이 간다는 점 등 이 사건 근로자들에 대한 근무평점에 합리적인 근거가 있으므로 주식회사 ○○종합관리가 근로계약의 종료 전에 참가인들에게 경위서나 시말서를 징구한 적이 없다는 사실만으로 주식회사 ○○종합관리의 근무평가의 공정성이나 합리성, 객관성이 결여된다고 보기는 어렵다.

3. (2심에서 추가된 쟁점) 이 사건 근로자들에 대한 근로계약 만료 통지에 근로기준법 제27조를 위반한 절차상 하자가 인정되는지 여부

기간의 정함이 있는 근로계약은 그 계약기간이 만료됨으로서 근로자와 사용자 사이의 법률관계가 원칙적으로 종료되고, 다만 갱신기대권이 인정되고 갱신의 거절에 합리적인 이유가 없는 경우 예외적으로 종래의 근로계약과 동일한 내용으로 근로계약의 갱신이 인정되는 것이다. 이러한 경우 근로자는 갱신에 의한 근로관계의 지속에 관하여 ‘예외적·추가적’인 기대와 신뢰를 가지고 있을 뿐이다. 반면 해고는 존재하던 근로관계가 사용자에게 의해 일방적으로 단절되는 것이므로, 이

경우 사용자는 근로자가 ‘원칙적·기본적’으로 가지고 있던 근로관계의 지속에 관한 기대나 신뢰를 침해하게 된다.

이러한 기대나 신뢰는 사용자가 애초에 근로계약의 체결을 통해 근로자에게 약속하고 보장한 것이므로 그 보호가치가 크다. 근로기준법 제27조에서 해고사유와 해고시기를 서면으로 통지하여야 효력이 있다고 규정하고 있는 것은 해고사유 등을 서면으로 통지하도록 함으로써 사용자가 해고 여부를 더 신중하게 결정하도록 하고, 해고의 존부 및 시기와 사유를 명확히 하여 사후에 이를 둘러싼 분쟁이 적정하고 용이하게 해결되고 근로자도 해고에 적절히 대응할 수 있게 하기 위한 취지이다(대법원 2015. 9. 10. 선고 2015두41401 판결 등 참조).

이를 고려할 때, 근로자의 보호 필요성 및 정도가 해고에 비해 낮은 갱신기대권이 인정되는 근로계약의 갱신 거절의 경우에도 위 법리가 그대로 적용된다고 보기 어렵다.

한편, 이 사건은 앞서 본 바와 같이 주식회사 ○○종합관리와 이 사건 근로자들간의 최종 근로계약의 내용 등에 비추어 그 자체로 갱신기대권 인정 여부가 명확하지는 않으나, 취업규칙의 해석, 이 사건 근로자들이 담당한 업무의 성격 및 근로계약이 갱신되어 온 관행 등을 종합하여 갱신기대권이 인정되는 경우이다.

만약 이와 같은 경우에도 근로기준법 제27조가 적용된다면 이는 갱신기대권의 인정 여부조차 불분명한 상태에서 사용자에게 과도한 의무를 부담시키게 되고, 결과적으로 사용자에게 기간만으로 인한 근로계약의 종료시 언제나 근로기준법 제27조의 규정을 준수하도록 사실상 강제하는 결과를 낳을 위험성이 높아 부당하다.

4. 결국, 이 사건 재심판정은 이 사건 근로자들에게 갱신기대권을 인정한 점에서는 위 판단과 같으나, 갱신 거절의 합리적 이유는 존재하지 않는다고 본 점에서는 위 판단과 결론을 달리 달리하므로 위법하여 취소되어야 한다.

패소 이유 (재량권 인정 범위 판단 차이)

이 사건은 사용자에게 부여된 재량권에 대한 해석을 어떻게 하나에 따라 판단이 갈린 사건이고, 판단의 주체가 누구인가, 판단기관에 부여된 권한, 판단에 소요되는 시간, 당사자들이 조력을 받은 전문가가 누구인가에 따라 결과가 나뉘는 사건으로 판단된다.

일련번호	2021-66					
판결번호	대법원 2021. 10. 28. 선고 2021두00000 부당정직구제재심판정취소					
중노위판정번호	중노위 2019. 11. 29. 중앙2019부해1118					
사건 종류	부당정직					
세부 쟁점	징계의 정당성 -사유, 양정, 절차					
심급별 소송결과	1심 법원	재심판정취소	2심 법원	1심판결 유지	대법원	원심유지

부록.1. 주요 사건 경과 및 패소 원인 분석

원고, 피상고인	김○○	피고보조참가인	사단법인 ○○금융센터
피고, 상고인	중앙노동위원회위원장	피고측 대리인 선임 여부	선임 안 함
노동조합 지원 여부	없음	원고측 대리인 선임 여부	선임
재심 결과	초심 유지		
초심의 대법원 판례 일치여부	불일치	재심의 대법원 판례 일치여부	불일치
기타 특이사항	중노위가 상고하였고, 대법원 심리불속행 기각으로 완결됨		

주요 사실관계 <사실관계> 가. 사단법인 ○○금융센터(이하 ‘이 사건 사용자’)는 1999. 4. 1. 결성된 이래 2007. 11. 27. 사단법인 설립인가를 받아 상시 47명의 근로자를 사용하여 외환시장 및 국제금융 시장 감시 등을 주요사업으로 하는 비영리법인이다. 김○○(이하 ‘이 사건 근로자’)는 2001. 3. 12. 이 사건 사용자에 입사하여 연구분석실 ○○팀 팀장으로 근무하였다. 나. 이 사건 사용자는 2019. 3. 8. 이 사건 근로자가 ○○팀 소속 팀원 신○○(2018. 1. 2. 입사)에게 ‘홍대클럽’, ‘버닝썬’ 등 피해자로 하여금 언저적 성희롱을 느낄 수 있는 부적절한 언행을 지속·반복한 사실 등 성희롱을 하였다는 사유로 정직 2개월일 징계(이하 ‘이 사건 정직처분’)을 하였다. 다. 이 사건 근로자는 이 사건 정직처분이 부당하다고 주장하며 2019. 5. 20. 서울지노위에 구제신청을 하였다. <심급별 결과> [서울지노위] 위 징계혐의사실을 징계사유로 인정하고 징계양정이 적정하며 징계절차상 위법도 없다고 판단하여 이 사건 근로자의 구제신청을 기각 [중노위] 초심 유지. 재심 신청 기각 ※ 한편, 이 사건 근로자는 2019. 4. 4. 서울중앙지방법원 2019가합000000호로 이 사건 사용자를 상대로 하여 이 사건 정직처분의 무효확인을 구하는 소를 제기하였다. 서울중앙지방법원은 2019. 10. 18. 이 사건 징계혐의 사실 중 일부만을 징계사유로 인정하였으나 징계양정이 적정하고 징계절차에 위법이 없다고 판단하여 이 사건 근로자의 청구를 기각하였다. 이 사건 근로자가 위 판결에 대하여 항소하여 현재 항소심 소송이 계속 중이다(서울고등법원 2019나 0000000). [1심 법원] 이 사건 정직처분은 징계절차상의 하자가 있고, 징계혐의사실에 비해 징계양정은 재량권을 일탈·남용에 해당하여 위법하므로 이 사건 재심판정은 위법하여 취소되어야 한다고 판시 [2심 법원] 1심 법원의 판결과 같은 판결 [대법원] 원심법원의 판결을 그대로 인정
--

판결 요지

가. 징계절차의 위법 여부

이 사건 징계기준 제2조는 ‘원장은 임직원이 성폭력, 성희롱 또는 성매매 등의 위법행위를 한 경우에는 징계위원회에 징계의 의결을 서면으로 요구하여야 하고 그 징계의결의 결과에 따라 징계처분을 하여야 한다’고 정하고 있으므로 징계권자는 이 사건 사용자의 원장이라고 할 것인데, 실제 이 사건 사용자의 경영관리부문장 권용일이 2019. 3. 8. 전 직원에게 이메일로 이 사건 근조라를 정직 2개월에 처한다는 내용의 2019. 3. 11.자 인사발령을 송부하였을 뿐 징계권자인 원장이 자신의 명의로 이 사건 근로자에 대하여 이 사건 정직처분을 발령하였다는 점을 인정할 만한 아무런 증거가 없다. 따라 이 사건 정직처분에는 이 사건 징계기준 제2조에 위반하여 징계권자에 의하여 이루어지지 않은 위법이 있다.

나아 이 사건 징계기준 제9조는 ‘징계위원회는 내부규칙에 따라 의결을 거친 후 징계의결서를 첨부하여 징계의결 요구자, 징계처분 대상자 등에게 징계심의 결과를 알려야 하고(제1항), 징계의결 통보시 당사자에게 그 처분에 관하여 불복을 할 수 있는지 여부, 청구절차 및 청구기간, 그 밖에 필요한 사항을 알려야 한다(제2항)’고 정하고 있으므로 이 사건 사용자가 위 징계기준에 따라 그 임직원을 징계하기 위해서는 징계위원회가 그 의결을 거친 후 징계의결 요구권자인 원장과 징계대상자에게 징계의결서를 첨부하여 징계심의 결과를 알려야 하고, 원장은 징계권자로서 위 징계의결 결과에 따라 징계대상자에게 징계처분을 하여야 하는데, 권용일은 징계위원회의 징계의결 다음날인 2019. 3. 8. 이 사건 근로자에게 전화로 징계결과를 통보하면서 특별히 불복절차 등에 대하여 알리지 않았고, 이 사건 사용자는 이 사건 근로자가 2019. 4. 4. 제기한 관련 민사소송의 소장 부분을 송달받은 이후인 2019. 4. 19.에야 비로소 이 사건 근로자에게 이 사건 정직처분에 관한 징계의결서를 첨부하여 징계심의 결과를 발송하였는바, 이 사건 정직처분의 절차에는 이 사건 징계기준 제9조를 위반한 위법이 있다.

나. 징계사유의 존부

성희롱이란 업무, 고용, 그 밖의 관계에서 국가기관·지방자치단체, 각급 학교, 공직유관단체 등 공공단체의 종사자, 직장의 사업주·상급자 또는 근로자가 ① 지위를 이용하거나 업무 등과 관련하여 성적 언동 또는 성적 요구 등으로 상대방에게 성적 굴욕감이나 혐오감을 느끼게 하는 행위, ② 상대방이 성적 언동 또는 요구 등에 따르지 아니한다는 이유로 불이익을 주거나 그에 따르는 것을 조건으로 이익 공여의 의사표시를 하는 행위를 하는 것을 말한다(양성평등기본법 제3조 제2호, 남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률 제2조 제2호, 국가인권위원회법 제2조 제3호 라목 등 참조). 여기에서 ‘성적 언동’이란 남녀 간의 육체적 관계나 남성 또는 여성의 신체적 특징과 관련된 육체적, 언어적, 시각적 행위로서 사회공동체의 건전한 상식과 관행에 비추어 볼 때, 객관적으로 상대방과 같은 처지에 있는 일반적이고도 평균적인 사람으로 하여금 성적 굴욕감이나 혐오감을 느끼게 할 수 있는 행위를 의미한다. 성희롱이 성립하기 위해서는 행위자에게 반드시 성적 동기나 의도가 있어야 하는 것은 아니지만, 당사자의 관계, 행위가 행해진 장소 및 상황, 행위에 대한 상대방의 명시적 또는 추정적인 반응의 내용, 행위의 내용 및 정도, 행위가 일회적 또는 단기간의 것인지 아니면 계속적인 것인지 등의 구체적 사정을 참작하여 볼 때, 객관적으로 상대방과 같은 처지에 있는 일반적이고도 평균적인 사람으로 하여금 성적 굴욕감이나 혐오감을 느낄 수 있게 하는 행위가 있고, 그로 인하여 행위의 상대방이 성적 굴욕감이나 혐오감을 느꼈음이 인정되어야 한다. (대법원 2018. 4. 12. 선고 2017두74702 판결 참조)

위와 같은 법리에 따라 이 사건 증거사실을 살펴보면, 이 사건 근로자가 신○○에게 한 각 발언은 신○○을 포함한 일반적이고 평균적인 사람에게 성적 굴욕감이나 혐오감을 줄 수 있는 성적 언동으로 평가할 수 있고, 이로 인하여 실제로 신○○에게 성적 굴욕감을 일으켰음이 인정되므로, 징계사유인 성희롱에 해당한다.

다. 징계양정의 적정

피징계자에게 징계사유가 있어서 징계처분을 하는 경우, 어떠한 처분을 할 것인가 하는 것은 징계권자의 재량에 맡겨진 것이고, 다만, 징계권자가 재량권의 행사로서 한 징계처분이 사회통념상

현저하게 타당성을 잃어 징계권자에게 맡겨진 재량권을 남용한 것이라고 인정되는 경우에 한하여 그 처분을 위법하다고 할 수 있고, 그 징계처분이 사회통념상 현저하게 타당성을 잃어 재량권의 범위를 벗어난 위법한 처분이라고 할 수 있으려면 구체적인 사례에 따라 징계의 원인이 된 비위사실의 내용과 성질, 징계에 의하여 달성하려고 하는 목적, 징계양정의 기준 등 여러 요소를 종합하여 판단할 때에 그 징계 내용이 객관적으로 명백히 부당하다고 인정할 수 있는 경우라야 한다(대법원 2002. 8. 23. 선고 2000다60890 판결 참조).

여러 개의 징계사유 중 일부가 인정되지 않더라도 인정되는 다른 일부 징계사유만으로 해당 징계처분의 타당성을 인정하기에 충분한 경우에는 그 징계처분을 유지하여도 위법하지 아니하다(대법원 2014. 11. 27. 선고 2011다41420 판결 참조). 다만 여러 개의 징계사유 중 일부 징계사유만으로 근로자에 대한 해당 징계처분의 타당성을 인정하기에 충분한지는 해당 기업의 구체적인 상황에 따라 다를 수 있으므로, 사용자가 징계처분에 이르게 된 경위와 주된 징계사유, 전체 징계사유 중 인정된 징계사유의 내용과 비중, 징계사유 중 일부가 인정되는 많은 이유, 해당 징계처분의 종류, 해당 기업이 정하고 있는 징계처분 결정 절차, 해당 기업의 규모·사업 성격 및 징계에 관한 기준과 관행 등에 비추어 인정된 징계사유만으로 동일한 징계처분을 할 가능성이 있는 지를 고려하여 해당 징계처분을 유지하는 것이 근로자에게 예측하지 못한 불이익이 되지 않도록 신중하게 판단하여야 한다(대법원 2019. 11. 28. 선고 2017두57318 판결 등 참조).

근로기준법 제31조에 의하여 부당해고구제재심판정을 다투는 소송에서 해고의 정당성에 관한 증명책임을 이를 주장하는 사용자가 부담하므로(대법원 1999. 4. 27. 선고 99두202 판결 참조), 인정되는 일부 징계사유만으로 해당 징계처분의 타당성을 인정하기에 충분한지에 대한 증명책임도 사용자가 부담한다(대법원 2019. 11. 28. 선고 2017두57318 판결 등 참조).

이 사건 징계기준 제3조는 징계를 파면, 정직, 감봉, 경고로 구분하고, 중징계를 파면 또는 정직으로, 경징계를 감봉 또는 경고로 정하고 있다. 한편 이 사건 징계기준을 살펴보면, 비위의 유형이 성희롱인 경우 ‘비위의 정도가 심하고 고의가 있는 경우’파면을, ‘비위의 정도가 심하고 중과실이거나 비위의 정도가 약하고 고의가 있는 경우’파면 내지 정직을, ‘비위의 정도가 심하고 경과실이거나 비위의 정도가 약하고 중과실인 경우’ 정직 내지 감봉을, ‘비위의 정도가 약하고 경과실인 경우’ 감봉 내지 경고를 징계양정의 기준으로 정하고 있다.

위와 같은 점을 고려해 볼 때 이 사건 정직처분은 징계의 양정이 사회통념상 현저하게 타당성을 잃어 재량권을 벗어난 위법한 처분에 해당하냐고 봄이 상당하다.

라. 결국 이 사건 정직처분은 절차상의 하자가 있고, 그 징계양정은 재량권을 일탈·남용에 해당하여 위법하다.

패소 이유 (사실관계 조사 미비)

이 사건은 징계절차의 하자와 관련한 쟁점으로 노동위원회와 법원의 판단이 뒤바뀐 사안으로 판단된다. 근로자는 징계절차의 하자를 입증하기 위해 통보절차의 미비, 징계권자에 의한 징계가 이루어지지 않은 점 등 다양한 사실관계를 주장하였는데, 분쟁의 처음부터 모든 사실관계가 드러난 것이 아니고, 소송의 진행과정에 따라 절차의 하자와 관련한 사실관계가 구체화되었으며, 결국 징계절차 중 일부에 있어 하자가 발견되어 징계절차가 위법하다고 판단이 되었다.

분쟁의 각 단계마다 이를 다루는 기관에서 적극적으로 증거를 찾아 수사하는 것이 아니기 때문에 각 당사자들이 제출하는 증거, 주장하는 사실관계에 맞추어 판단이 이루어지게 되고, 판단을 위한 사실관계가 얼마나 구체화되어 있는가, 이를 뒷받침하는 증거가 제출되어 있는가 등 사실상의 문제로 법원에서 결론이 뒤집힌 사건으로 판단된다.

일련번호	2021-68					
판결번호	대법원 2021. 10. 28. 선고 2021두00000					
중노위판정번호	중노위 2017. 4. 4. 중앙2017부해114					
사건 종류	기간제					
세부 쟁점	무기계약관로자 전환 여부					
심급별 소송결과	1심 법원	재심취소	2심 법원	1심 유지	대법원	원심유지
원고, 피상고인	학교법인 조선대학교		피고보조참가인		-	
피고, 상고인	중앙노동위원회위원장		피고측 대리인 선임 여부		없음	
노동조합 지원 여부	없음		원고측 대리인 선임 여부		없음	
재심 결과	초심 취소					
초심의 대법원 판례 일치여부	일치		재심의 대법원 판례 일치여부		불일치	
기타 특이사항						

주요 사실관계 <사실관계> 가. 노○○(이하 ‘이 사건 근로자’)는 ○○대학교 부속중학교에서 2009. 9. 1.부터 2013. 8. 31. 까지 4년 동안 1년 단위로 근로계약을 반복·갱신하면서 초·중등교육법령에 따른 영어회화 전문강사로 근무하였고, 학교법인 ○○대학교(이하 ‘○○대학교’)는 계약기간이 만료될 때마다 연가보상비, 퇴직금을 정산지급하였다. 나. ○○대학교는 2013. 8. 7. 영어회화 전문강사 공개채용 절차를 진행하였고(이하 ‘이 사건 공개채용 절차’라 한다), 이 사건 근로자는 위 절차에 지원하여 최종 합격해 2013. 9. 1. 원고와 사이에 새로운 근로계약을 체결하고 2013. 9. 1.부터 2016. 8. 31.까지 3년 동안 1년 단위로 근로계약을 반복·갱신하면서 영어회화 전문강사로 근무하였다. ○○대학교는 계약기간이 만료될 때마다 연가보상비와 퇴직금을 정산지급하였다. 다. ○○대학교는 2016. 7. 8. 이 사건 근로자에게 기간제 근로계약이 2016. 8. 31.자로 만료된다는 통보(이하 ‘이 사건 기간만료 통보’라 한다)를 하였다. 라. 이 사건 근로자는 이 사건 기간만료 통보가 부당하다며 전남지노위에 구제신청을 하였다. <심급별 결과> [전남지노위] 구제신청 기각 [중노위] 이 사건 근로자가 2013. 9. 1. 기간의 정함이 없는 근로자로 전환되었다’는 이유를 들
--

어 재심신청을 인용. 초심 취소

[1심 법원] 이 사건 근로자는 기간의 정함이 없는 근로계약을 체결한 근로자에 해당하지 아니하고, 근로계약이 갱신될 수 있으리라는 정당한 기대권도 인정되지 아니하는바, ○○대학교와 이 사건 근로자 사이의 근로관계는 계약기간 종기의 도래로써 정당하게 종료되었다고 할 것이고, 따라서 이 사건 재심판정은 위법하여 취소되어야 한다고 판시

[2심 법원, 대법원] 1심 법원과 같은 판단

판결 요지

1. 이 사건 근로자가 기간의 정함이 없는 근로계약을 체결한 근로자인지 여부에 관한 판단

기간제법 규정 내용과 기간제 근로계약의 남용을 방지함으로써 근로자의 지위를 보장하려는 입법 취지 등을 고려하면, 기간제 근로계약이 반복하여 체결되거나 갱신되어 일정한 공백기 없이 기간제근로자가 계속적으로 근로한 경우라면, 특별한 사정이 없는 한 최초 기간제 근로계약에서부터 최종 기간제 근로계약에 이르기까지 기간 전체가 기간제법 제4조에서 말하는 기간제근로자의 사용 기간으로서 ‘계속 근로한 총기간’에 포함되어야 한다. 다만 기간제 근로계약의 대상이 되는 업무의 성격, 기간제 근로계약의 반복 또는 갱신과 관련한 당사자들의 의사, 반복 또는 갱신된 기간제 근로계약을 전후한 기간제근로자의 업무 내용·장소와 근로조건 유사성, 기간제 근로계약의 종료와 반복 또는 갱신 과정에서 이루어진 절차나 그 경위 등을 종합적으로 고려할 때 당사자 사이에 기존 기간제 근로계약의 단순한 반복 또는 갱신이 아닌 새로운 근로관계가 형성되었다고 평가할 수 있는 특별한 사정이 있는 경우에는 기간제근로자의 계속된 근로에도 불구하고 그 시점에 근로관계가 단절되었다고 보아야 하고, 그 결과 기간제법 제4조에서 말하는 ‘계속 근로한 총기간’을 산정할 때 그 시점을 전후한 기간제 근로계약기간을 합산할 수는 없다(대법원 2020. 8. 20. 선고 2017두52153, 대법원 2020. 8. 20. 선고 2018두51201 판결 등 참조).

다음과 같은 사정을 고려하여 보면 이 사건 공개채용 절차를 거쳐 2013. 9. 1. 새로운 기간제 근로계약이 체결됨으로써 이 사건 근로자와 ○○대학교 사이에 기존 기간제 근로계약의 단순한 반복 또는 갱신이 아닌 새로운 근로관계가 형성되었다고 평가할 수 있어 그 시점에 근로관계는 단절되었다. 결국 기간제법 제4조에서 말하는 계속 근로한 총기간을 산정할 때 2013. 9. 1.을 전후한 기간제 근로계약기간을 합산할 수 없어 이 사건 근로자의 계속 근로한 총기간이 4년을 초과하지 않으므로, 이 사건 근로자를 기간제법 제4조 제2항에 따라 기간의 정함이 없는 근로계약을 체결한 근로자라고 할 수 없다

① 기간제 근로계약을 1년 단위로 갱신하여 온 이 사건 근로자는 초·중등교육법 시행령에서 정한 근무기간 4년이 지난 후에는 기존 기간제 근로계약을 종료하는 절차를 거친 후 별도의 이 사건 공개채용 절차를 거쳐 2014. 3. 1.부터 새로이 영어회화 전문강사로 근무하게 되었다는 점,

② 이 사건 공개채용 절차는 서류전형을 통해 합격 인원의 2배수를 선발하고, 그들을 대상으로 교수·학습과정안 작성 및 이에 따른 수업실연 및 면접을 실시해 최종 합격자를 선발하는 방식으로 이루어졌다는 점,

③ 이 사건 공개채용 절차에는 5명이 응시하였고, 이 사건 근로자는 모든 심사절차를 거쳐 최종 합격자로 선발되었으며, 서류전형의 구체적 요건을 살펴봐도 특별히 이 사건 근로자에게 편파적이었거나 형식적인 기준이었다고 볼 수는 없다는 점,

④ 위와 같은 사정을 보면, 이 사건 공개채용 절차가 그저 형식적인 절차에 불과했다고 볼 수는 없고 이 사건 근로자가 미리 내정자로 정하여져 있었다고 볼 만한 객관적 사정도 찾아보기 어려우며 오히려 이 사건 공개채용 절차는 객관적이고 합리적인 기준에 따라 실질적인 경쟁이 이루어진 신규 채용 절차였다고 보인다는 점 등.

2. 이 사건 근로자에게 갱신기대권이 인정되는지 여부에 관한 판단

근로자에게 이미 형성된 갱신에 대한 정당한 기대권이 있는데도 사용자가 이를 배제하고 근로계약의 갱신을 거절한 데에 합리적 이유가 있는지가 문제 될 때에는 사용자의 사업 목적과 성격, 사업장 여건, 근로자의 지위와 담당 직무의 내용, 근로계약 체결 경위, 근로계약의 갱신 요건이나 절차의 설정 여부와 운용 실태, 근로자에게 책임 있는 사유가 있는지 등 근로관계를 둘러싼 여러 사정을 종합하여 갱신 거부의 사유와 절차가 사회통념에 비추어 볼 때 객관적이고 합리적이며 공정한지를 기준으로 판단하여야 하고, 그러한 사정에 관한 증명책임은 사용자가 부담한다(대법원 2017. 10. 12. 선고 2015두44493 판결 참조).

다음과 같은 사정을 앞서 본 관련 법리에 비추어 보면, 이 사건 근로자에게는 ‘근로계약이 갱신될 수 있으리라는 정당한 기대권’이 인정되지 아니한다고 봄이 상당하다.

① 근로계약서나 채용광고에는 ‘기간만료에도 일정한 요건이 충족되면 당해 근로계약이 갱신된다’는 취지의 규정이 없고, 그저 근무평가를 한다는 사실만으로 ‘일정한 요건이 충족되면 당해 근로계약이 갱신된다’고 추론하기에는 어려움이 있다는 점,

② 이 사건 근로자는 계약기간의 종기가 도래할 때마다 퇴직금과 연차수당을 지급받았고, 영어회사 전문강사 제도는 정규 교사만으로 영어수업이 가능할 시점까지의 공백을 메우기 위한 한시적 제도였다는 점 등.

패소 이유 (사실관계 인정에 관한 관점 차이)

이 사건은 계약기간 만료에 따라 유효하게 근로관계가 단절된 후 신규 채용절차를 거쳐 새로운 근로계약을 체결하는 경우, 이러한 신규 채용절차가 「기간제 및 단시간근로자 보호 등에 관한 법률」 등의 회피를 목적으로 이루어진 형식적인 절차에 불과하다고 볼 만한 사정이 없는 이상 각 근로계약은 단절된 것으로 보아야 할 것인데 이러한 신규 채용절차가 형식적인지 아닌지에 대한 사실관계의 판단으로 결과가 달라진 사건이다.

구체적으로 이 사건은 초심과 법원의 판단이 일치하되 재심의 판단이 다른 경우이고, 사실상 재심의 판단으로 분쟁이 길어진 경우라 판단할 수 있으므로 추후 중노위에서 재심을 거치는 경우 초심을 뒤집기 위해서는 초심에서 판단한 사실관계에 대한 보다 정교하고 구체적인 조사가 뒷받침되어야 한다고 판단된다. 다만 이 사건은 새로운 제도의 시행으로 법원의 법 해석에 관한 일관된 태도가 확정되어 가는 과도기적 사례라는 특수성이 있는 경우이다.

즉, 유사한 사실관계가 문제된 2021_56,57,68 각 사례의 경우 초심지노위, 중노위, 1심법원, 2심법원이 각기 동일한 사실관계, 동일한 법의 적용과 해석을 달리하며 대법원의 판단이 내려질 때까지 혼란스러운 상황이 전개되었던바 이러한 과도기적 상황의 경우에는 중노위로써도 별다른 대안 없이 끝까지 다투며 판례군이 형성되기를 기다리는 것이 최선의 대응이었다고 판단된다.

일련번호	2021-70
판결번호	대법원 2021. 9. 30. 선고 2021두00000 판결
중노위판정번호	중노위 2019. 7. 24. 2019부해636

부록.1. 주요 사건 경과 및 패소 원인 분석

사건 종류	부당해고					
세부 쟁점	징계, 감봉, 부당노동행위, 불이익취급, 근로시간면제					
심급별 소송결과	1심 법원	재심판정취소	2심 법원	1심 유지	대법원	심리불속행기각
상 고 인	중앙노동위원회		참 가 인		송○○	
피상고인	○○○○해양(주)		피고측 대리인 선임 여부		선임 안 함	
노동조합 지원 여부	없음		원고측 대리인 선임 여부		선임 함	
재심 결과	초심유지					
초심의 대법원 판례 일치여부	불일치		재심의 대법원 판례 일치여부		불일치	
기타 특이사항						

주요 사실관계
<사건 개요> 가. 원고는 2000. 10. 23. 설립되어 상시 약 10,000명의 근로자를 사용하여 선박의 건조, 개조, 수리, 해체 및 판매업, 선박건조 도면의 판매, 선박건조 계약 거래의 중개 조선업을 영위하는 법인이고, 피고보조참가인(이하 ‘참가인’)은 2006. 7. 10. 원고에 입사하여 특수선 의장부에서 전기 공사 업무를 담당하던 사람이다. 나. 원고 인사위원회는 2018. 12. 12. 참가인에 대한 “회사물품 절도 및 횡령 등, 성추행” 징계 사유를 심의한 후 ‘해고’를 의결하였고, 원고는 2018. 12. 14. 참가인에게 2018. 12. 15.자 해고를 통보하였다. 징계사유는 주로 박○○ 등의 제보로 알려졌다. 가) 참가인은 2015. 2. 초순경부터 사내 협력업체인 (주)○○ 소속 근로자 박○○과 교제하면서 불륜관계를 유지하다 2018. 5. 초순경 결별하였다. 나) 박○○은 2018. 5. 하순경 거제경찰서에 참가인을 ‘특수협박, 폭행, 강간, 강간미수, 유사강간, 강간상해, 성폭력범죄의처벌등에관한특례법위반(카메라 등 이용 촬영)방조’ 등의 혐의로 고소하였다. 이 중 특수협박은 벌금 200만원의 유죄판결이 선고되었으나, 나머지는 혐의없음(증거불충분) 처분이 이루어졌다. 다) 박○○은 2018. 10. 26. 원고에 ‘참가인이 사내 물품을 무단으로 반출하거나 협력사 직원과 사내 물품을 거래하는 등의 비위행위를 하였다.’는 취지로 제보하였다. 원고는 박○○의 동행하에 박○○의 자택에서 별지 1 회수 물품 목록 기재 38종의 물품들을 회수한 후 박○○과 (주)○○의 직원들 및 참가인을 상대로 조사를 진행하였다. 별지 1 회수 물품 목록 기재 순번 1 내지 5번은 원고가 참가인에게 지급한 공구 목록과 일치하는 물품이고, 순번 6 내지 33번은 원고가 취급하는 물품이며, 순번 34 내지 38번은 원고가 취급하지 않는 물품이다. 참가인은 원고의 자체 조사 과정에서 별지 1 회수 물품 목록 기재 순번 1, 2, 4 내지 7, 12 내지 14, 21 내지 23, 25, 26, 28, 32번 물품에 대하여 ‘본인이 박○○에게 사내에서 주었다.’는 취지로 답하였다. 참가인은 2018. 12. 12. 인사소위원회 심의에서 ‘청소를 하다 보면 일주일에 5~6개의 공구를 주었는데 이름이 적혀 있는 것은 돌려주고 이름이 안 적혀 있는 것은 가지고 있다가 없다고 하는 사람에게 주었다.’는 취지로 진술하였다.

라) 원고의 직장부 소속 기선 김○○은 2018. 11. 19.경 원고에게 ‘참가인이 약 10년 전에 자신에게 성추행을 하였다.’는 제보를 하였다.

다. 참가인은 원고에 재심을 신청하였고, 원고는 2019. 1. 10. 재심인사소위원회를 개최하여 심의한 결과 참가인에 대한 해고를 확정하고 2019. 1. 11. 참가인에게 이를 통보하였다.

라. 참가인은 2019. 3. 8. 경남지방노동위원회에 부당해고 구제를 신청하였다.

<심급별 결과>

[경남지노위] ‘징계사유가 일부만 인정되고 양정도 과하여 부당하다’는 이유로 구제신청 인용
[중노위] 재심신청 기각. 초심 유지

[1심 법원] 부당노동행위는 인정하지 않았으나, 감봉이 부당징계에 해당함을 인정하여 재심판정 내용을 일부 취소

[2심 법원] 1심 판결 유지

판결 요지

(1) 징계사유의 인정 여부

1) (제1 사유) 참가인은 원고 소유의 K-50 터미널압착기 4개를 정○○, 백○○, 이영○에게 판매하고 원고 소유의 멀티테스트기를 정성○에게 빌려주었다가 분실로 인한 보상금 명목으로 금품을 지급받아 임의로 소비 사실이 추인된다. 원고 소유의 공구를 임의로 판매한 것은 단체협약, 부가협약서, 취업규칙에서 해고사유로 정한 ‘원고에 대한 횡령’에 해당하고, 원고 소유의 공구를 대여해 주었다가 분실로 인한 보상금을 지급받아 임의로 소비한 행위도 원고 소유의 공구를 임의로 판매한 것과 다를 바가 없으므로, 원고의 이 부분 행위는 모두 징계사유로 인정된다.

2) (제2 사유) 회수 물품 목록 기재 38종의 물품들 중 순번 34 내지 38번은 원고가 취급하지 않는 물품으로 원고 소유의 물품이라고 인정할 증거가 없으므로 제2 사유 중 이 부분은 징계사유로 인정되지 않는다. 회수 물품 목록 기재 38종의 물품들 중 나머지 물품들의 경우, 원고가 사업장 내에서의 작업을 위하여 사업장 내에 비치하거나 직원들에게 제공한 물품으로 참가인이 이를 무단으로 반출한 사실이 추인되므로, 이 부분 징계사유가 인정된다.

(2) 징계양정의 적정 여부

다음과 같은 사정들을 종합하여 보면, 이 사건 해고는 사회통념상 징계처분의 타당성을 인정하기에 충분하고 징계권자에게 맡겨진 재량권을 일탈·남용하였다고 볼 수 없다. 이 사건 해고의 징계사유 중 일부를 제외한 모든 징계사유가 인정되고, 인정되는 징계사유만으로도 이 사건 해고의 징계양정은 적정하므로, 이 사건 해고가 부당하다는 전제에서 내려진 이 사건 재심판정은 위법하다.

가) 이 사건 해고의 징계사유 중 무단반출 부분을 제외한 나머지 부분이 모두 징계사유로 인정된다. 참가인이 사내물품을 횡령하거나 무단 반출한 물품의 종류만 약 34종에 이르고 그 수량은 100개를 넘으며, 참가인의 위와 같은 행위는 장기간 지속되어 온 것으로 보인다. 참가인이 무단 반출하여 보관하고 있던 사내물품의 규모와 사내물품을 사적으로 판매하거나 나누어 주기도 한 점 등에 비추어 보면, 참가인이 사내물품을 무단 반출한 것은 업무상 과실에 의한 것으로 보기 어렵고 사적 이익을 얻기 위한 목적도 일부 있었던 것으로 보인다.

나) 참가인은 협력업체 직원이었던 박○○과 불륜관계를 유지하다 특수협박죄가 유죄로 인정되어 벌금을 선고받기도 하였다. 이는 사내·외에서의 부정한 행위로 회사나 종업원으로서의 명예를

부록.1. 주요 사건 경과 및 패소 원인 분석

손상시키는 행위로 독자적인 해고사유에 해당하고 박○○은 참가인과 같은 사업장에서 근무하는 협력업체의 직원이었다는 점에서 단순히 사적 영역에서의 부정행위로 보아 원고의 명예, 회사 내 질서유지에 영향이 없다고 보기 어렵다.

다) 성추행 건은 약 10년 전에 발생한 일이고 참가인은 상호 장난으로 이루어진 것이라고 주장하나, 피해자는 당시 신입사원이었고 설령 참가인은 장난을 치려는 의도로 한 행위였다고 하더라도 참가인의 행위는 객관적으로 장난으로 받아들이기 어려운 행위로 보이고, 피해자도 “그때 당시에는 화도 나고 부끄러웠지만 신입사원이다보니 화를 낼 수 없는 상황이었다.”고 하고 있어 참가인의 행위로 인하여 성적 수치심을 느꼈던 것으로 보인다.

라) 원고는 2015. 11.경 사내물품 총 45여종을 무단 반출하여 개인적으로 사용하거나 가족에게 나누어 준 직원에 대하여 권고사직을 한 사례가 있다.

패소 이유 (사실관계에 관한 인정 차이)

이 사건은 사실관계는 동일하게 주장되었으나, 그에 관한 법리적 판단의 결과가 달라진 사건이다. 쟁점은 참가인(신청인)의 행위들에 대하여 어떤 행위들을 징계사유로 인정할 것인지, 인정할 경우 양정은 정당한지 등이 문제가 주로 문제가 된다.

노동위원회는 징계의 사유가 일부 인정되지만, 양정 결과 해고에 이를 정도의 비위행위는 아니라고 판단하여 징계가 부당하다고 판정했다. 그러나, 법원은 대부분 징계사유의 정당성을 인정했다. 특히, 징계 사유 중 일부만 인정된 경우에도 그것만으로 징계해고 결정을 할 수 있다는 이전 판례의 견해를 재확인하면서, 해고처분의 징계가 정당하다고 판단했다. 새롭게 제시된 사실관계나 증거는 없으나, 그에 대한 판단이 달라진 것은 사실관계에 대한 법리적용에 있어 공익위원의 전문성이 문제가 있다는 것을 나타낸다고 볼 수 있다. 새롭게 제시된 사실관계가 없음에도 불구하고 참가인에 대한 징계사유가 충분히 인정될 수 있었기 때문이다.

1심 법원 판결 이후 중노위가 항소했으나, 2심 법원 판결을 통해 다시 한 번 패소했음에도 불구하고 대법원에 상고를 결정한 것은 유감이라고 하지 않을 수 없다. 중노위의 상고가 법무부의 소송지휘에 따른 결론이라는 것을 인정한다면, 권리구제형 행정심판이라는 노동위원회 제도의 특수성을 고려하여 노동위원회는 소송 수행에 있어서 법무부의 지휘를 받지 않도록 예외를 인정하는 방안을 적극적으로 고려해야 할 필요가 있다고 사료된다.

일련번호	2021-71					
판결번호	대법원 2021. 10. 14. 선고 2021두00000 부당해고구제재심판정취소					
중노위판정번호	중노위 2013. 11. 21. 중앙2013부해807					
사건 종류	부당해고					
세부 쟁점	징계해고 - 사유, 양정, 절차					
심급별 소송결과	1심 법원	재심판정취소	2심 법원	1심판결 유지 (환송전 1심판결 파기)	대법원	원심유지 (환송전 2심 법원에서 올라온 사건은 파기환송)

원고, 피상고인	○○공제회	피고보조참가인	심○○, 이○○
피고, 상고인	중앙노동위원회위원장	피고측 대리인 선임 여부	선임 안 함
노동조합 지원 여부	없음	원고측 대리인 선임 여부	선임
재심 결과	초심 유지		
초심의 대법원 판례 일치여부	불일치	재심의 대법원 판례 일치여부	불일치
기타 특이사항	파기환송된 사건임		

주요 사실관계 <사실관계> 가. 심○○(이하 ‘이 사건 근로자1’)은 2009. 1. 2., 이○○(이하 ‘이 사건 근로자2’, 모두를 통칭할 때에는 ‘이 사건 근로자들’)는 1988. 12. 15. ○○공제회에 입사하여 회계팀 등에서 각 출납 업무와 계약업무 담당자로 근무하던 중 2013. 5. 9.자로 징계해임되었다고 주장하는 사람들이다. 나. ○○공제회(이하 ‘이 사건 사용자’)는 1984. 2. 1. 설립하여 위 주소지에 본점을 두고 상시근로자 190명을 고용하여 무역업, 각종 제조업 및 도소매업, 전문건설업 등을 영위하는 법인이다. <심급별 결과> [1심 법원] 사용자는 중노위위원장을 상대로 이 사건 근로자들의 구제신청을 인용한 중노위의 재심판정을 취소해달라는 소를 제기하면서, 이 사건 근로자들에 대해서 ① ○○원의 개인 비밀이 수록된 USB의 불법 취득 및 전산보안 관련 규정 등 위반, ② ○○원에 대한 집단 괴롭힘 및 따돌림, 사생활 유포, ③ ○○원의 업무에 대한 월권행위 등의 징계사유가 있고, 이 사건 근로자들에 대한 해임처분이 징계양정도도 부합한다고 주장하였고, 제1심 법원은 이 사건 사용자의 청구를 인용하여 중노위의 재심판정을 취소하는 판결을 선고 [2심 법원] ① ○○원의 개인 비밀이 수록된 USB에 관하여 이 사건 근로자들에게 인정되는 징계사유는, 일부 USB의 무단 사용 및 ○○원 개인자료 무단 열람, 복사 행위에 따른 윤리강령 제4장 제4의 가. 호 위반, 이 사건 사용자 직원의 급여내역 등 비밀자료 무단 열람 행위에 따른 사무관리규칙 제72조 제1항 위반, 이 사건 근로자1의 경우 ○○원 개인자료 파일들이 저장된 174번 USB를 회사 밖으로 유출한 행위에 따른 보조기억매체 관리지침 제4조, 제5조 위반으로서 각 인사와 근무에 관한 규정 제54조 제2호, 제1호 라.목이 정하는 ‘규정을 위배한 행위를 한 자’의 징계사유에 해당할 뿐이고, 이외의 다른 USB에 관한 절취하거나 점유이탈물을 횡령하였다고는 볼 수 없으며, ② 이 사건 근로자들의 비위행동들이 ○○원에 대한 집단 괴롭힘이나 따돌림, 사생활 유포라고 보기 어렵고, ③ 이 사건 근로자 1의 행위를 월권행위로 보기 어려우며, ④ 이 사건 사용자가 이 사건 근로자들에게 ‘집단 괴롭힘’이라는 포괄적인 징계사유를 통지하고, 그로부터 일주일 만에 인사위원회를 개최하였는데, ‘집단 괴롭힘’에 사생활 유포와 월권행위가 포함되어 있다고 보기도 어렵고, 징계대상자의 충분히 진술하거나 방어할 권리를 보장한 원고의 징계에 관련된 규정을 위반한 것으로서 징계절차에 하자가 있고, ⑤ 이 사건 근로자들에게 인정되는 징계사유들을 양정기준에 비추어 보더라도 해임처분은 재량권을 일탈·남용하였다는 이유로 제1심판결을 취소하고 원고의 청구를 기각하는 판결을 선고 [대법원] ① 이 사건 근로자들의 비위행동들이 집단 괴롭힘이나 따돌림, 사생활유포에 관한 개념에 포함되는지를 기준으로 징계사유에 해당하는지 여부를 판단할 것이 아니라 이 사건 사용자의 윤리강령 위배 여부를 기준으로 판단하여야 하는데, 이 사건 근로자들의 비위행위들은 명백히 이

사건 사용자의 윤리강령 제4장 제4의 가.호를 위배한 것에 해당하고, ② 이 사건 사용자가 이 사건 근로자들에게 징계사유를 ‘개인정보 불법 취득, 침해 및 유출, 집단 괴롭힘, 전산업무 운영규칙 등 위반’으로 통지하였다고 하여 징계혐의사실의 사전통지의무를 규정하지 않은 이 사건 사용자의 인사와 근무에 관한 규정을 위반하였다고 보기 어려우며, 이 사건 근로자들은 인사위원회 당시 이미 징계혐의 사실이 무엇인지 구체적으로 알고 있었고, 그에 대해 충분히 대응할 수 있는 상황이었으며, 인사위원회에서 징계혐의 사실에 관하여 진술 및 소명기회를 부여받았다고 봄이 타당하여 이 사건 근로자들에 대한 해임처분에 절차상 하자가 있다고 볼 수 없다는 이유로 위 환송전 판결을 파기환송

[파기환송심 대전고등법원] 이 사건 해임처분은 정당하다고 판시하였고, 이 사건 재심판정은 위법하여 취소되어야 한다고 판시

[대법원] 원심법원의 판결을 그대로 인정

판결 요지

가. 징계사유의 존재 여부

이 사건 근로자들의 USB 무단 사용, ○○원 개인자료 무단열람, 복사 행위는 윤리강령 제4장 제4의 가.호를 위반한 것이고, 이 사건 근로자들의 이 사건 사용자의 직원의 급여내역 등 비밀자료 무단 열람 행위는 사무관리규칙 제72조 제1항을 위반한 것이며, 이 사건 근로자1이 ○○원 개인자료인 이 사건 파일들이 저장된 USB를 회사 밖으로 유출한 행위는 보조기억매체 관리지침 제4조, 제5조를 위반한 것으로서 각 인사와 근무에 관한 규정 제54조 제2호, 제1호 라.목이 정하는 ‘규정을 위배한 행위를 한 자’의 징계사유에 해당한다.

또한 이 사건 근로자들은 ○○원과 같은 회계팀 내의 상위 직급자이자 재직기간 및 나이 등이 더 많은 사람들과, 신규 전입한 ○○원에 대하여 약 1년에 걸쳐 지속적으로 공개 질책 또는 무시하는 언동을 하거나, 사생활에 관하여 확인되지 않은 사실을 유포하여 비방하고, 인간관계에서의 분리 및 신상 침해를 의도하는 등 지위 또는 관계의 우위 및 다수의 우월성 등을 이용하여 업무상 적정 범위를 넘어서는 행위를 하였으며, 이 사건 근로자들의 행위로 ○○원은 이 사건 근로자들의 하급자로서 상당한 정신적 고통을 받았고, 근무환경의 악화로 사직까지 하게 된 것으로 보이므로 위 비위행위는 이 사건 사용자의 윤리강령 제4장 제4의 가.호를 위배한 것으로 징계사유에 해당한다.

나. 징계사유의 일탈·남용 여부

피징계자에게 징계사유가 있어서 징계처분을 하는 경우 어떠한 처분을 할 것인지는 징계권자의 재량에 맡겨져 있으므로, 징계권자의 징계처분이 사회통념상 현저하게 타당성을 잃어 징계권자에게 맡겨진 재량권을 남용하였다고 인정되는 경우에 한하여 그 처분이 위법하다고 할 수 있다. 징계처분이 사회통념상 현저하게 타당성을 잃어 재량권의 범위를 벗어난 위법한 처분이라고 할 수 있으려면 구체적인 사례에 따라 징계의 원인인 비위사실의 내용과 성질, 징계로 달성하려는 목적, 징계양정의 기준 등 여러 요소를 종합하여 판단할 때에 징계 내용이 객관적으로 명백히 부당하다고 인정되어야 한다(대법원 2002. 8. 23. 선고 2000다60890, 60906 판결, 대법원 2017. 3. 15. 선고 2013두26750 판결 등 참조).

한편 해고처분은 사회통념상 고용관계를 계속할 수 없을 정도로 근로자에게 책임 있는 사유가 있는 경우에 행하여져야 그 정당성이 인정된다. 사회통념상 당해 근로자와 고용관계를 계속할 수 없을 정도에 이르렀는지 여부는 당해 사용자의 사업 목적과 성격, 사업장의 여건, 당해 근로자의 지위 및 담당 직무의 내용, 비위행위의 동기와 경위, 이로 인하여 사업주의 위계질서가 문란하게 될 위험성 등 질서에 미칠 영향, 과거의 근무태도 등 여러 가지 사정을 종합적으로 검토하여 판단하여야 한다(대법원 1995. 4. 25. 선고 94누13053 판결, 대법원 2017. 3. 15. 선고 2013두

26750 판결 등 참조). 여러 개의 징계사유 중 일부가 인정되지 않더라도 인정되는 다른 일부 징계사유만으로 해당 징계처분의 타당성을 인정하기에 충분한 경우에는 그 징계처분을 유지하여도 위법하지 아니하다(대법원 2014. 11. 27. 선고 2011다41420 판결, 대법원 2019. 11. 28. 선고 2017두57318 판결 등 참조)

위에서 본 법리에 비추어 보면, 이 사건 근로자들이 USB를 절취하거나 점유이탈물을 횡령하였다는 징계사유와 이 사건 근로자2가 174번 USB를 회사 밖으로 유출하였다는 징계사유, 이 사건 근로자1의 월권행위에 관한 징계사유를 제외한 나머지 징계사유들이 모두 인정되고, 위와 같이 인정되는 징계사유만으로도 이 사건 해임처분을 하는 것이 사회통념상 현저하게 타당성을 잃었다고 보기 어렵다.

패소 이유 (징계양정의 적정성에 관한 법관의 판단)

이 사건은 비위행위의 종류가 USB를 활용한 정보의 취득, 집단 괴롭힘 등 당사자의 주장과 사실관계의 파악이 굉장히 복잡하게 꼬여 있는 사안이고, 이로 인해 환송전 2심 법원에서 이 사건 근로자들의 비위행위가 이 사건 사용자의 윤리강령에 위배되는지 여부를 판단하지 않고, 이 사건 근로자들의 비위행위가 집단괴롭힘에 해당되는지, 사생활 유포에 해당되는지 등으로 사건의 쟁점이 흐려지며 대법원까지 가게 된 사건으로 판단된다.

다만, 위와 같은 사실관계를 제외하면 이 사건은 각종 비위행위를 저지른 자에 대한 징계해고가 쟁점이고, 노동위원회 단계에서는 징계양정을 문제삼아 부당해고라고 판정하였으나, 법원에서 구체적인 사실관계의 파악에 따라 징계양정 역시 적정하다고 판시한 단순한 사건이므로 파기환송 자체에 주목할 만한 사건은 아니라고 생각된다.

일련번호	2021-73					
판결번호	서울행정법원 2021. 9. 16. 선고 2019구합00000 부당해고구제재심판정취소					
중노위판정번호	중노위 2018. 1. 28. 중앙2018부해1256					
사건 종류	부당해고					
세부 쟁점	징계해고 - 사유, 양정, 절차					
심급별 소송결과	1심 법원	재심판정취소	2심 법원		대법원	
원고	이○○		피고보조참가인	사단법인 ○○○○○연맹		
피고	중앙노동위원회위원장		피고측 대리인 선임 여부	선임 안 함		
노동조합 지원 여부	없음		원고측 대리인 선임 여부	선임		
재심 결과	초심 취소					

부록.1. 주요 사건 경과 및 패소 원인 분석

초심의 대법원 판례 일치여부		재심의 대법원 판례 일치여부	
기타 특이사항	초심 판정이 재심에서 취소되었으나 다시 1심 법원에 의해 뒤집힌 사건, 노동위원회에서 1심 판결 선고 후 항소하였으나 항소취하하여 그대로 확정됨. 노동위원회를 상대로 한 행정 소송 이외에 근로자가 사용자를 상대로 이미 해고무효확인 소송을 제기한 상황이었고, 서울행정법원의 판단 전 관련 민사사건은 대법원에 계류중인 상황이었음(관련 민사사건에서 1심, 2심 법원 모두 부당해고를 인정함).		

주요 사실관계
<사실관계> 가. 이 사건 사용자는 1978. 1. 30. 설립되어 상시 약 30명의 근로자를 사용하여 ○○○○○선수권대회 주관, 경기규칙 개발 등 사업을 영위하는 비영리 사단법인이고, 이 사건 근로자는 2009. 5. 4. 입사하여 2013. 10. 28.부터 마케팅부장, 2015. 6. 13.부터 총무부장, 2018. 1. 4.부터 다시 마케팅부장으로 근무한 근로자이다. 나. 이 사건 사용자는 2018. 6. 8., 2018. 6. 20., 2018. 6. 25. 및 2018. 7. 4. 총 4회에 걸쳐 인사위원회(이하 ‘이 사건 인사위원회’라고 한다)를 개최하여 논문의 표절 등 비위사실을 징계사유로 이 사건 근로자에 대한 해고(효력발생일 2018. 7. 11., 이하 ‘이 사건 해고’라 한다)를 의결하였다 다. 이 사건 근로자는 2018. 7. 9. 이 사건 사용자에게 ‘이 사건 해고의 징계의결사유에 사실관계가 다르게 적시되어 있고 인사위원회 구성에 객관성 및 전문성이 없으며, 징계양정이 과다하다’는 이유로 이 사건 해고를 취소하여 달라는 내용의 재심신청을 하였다. 라. 이 사건 사용자는 2018. 7. 11. 원고에게 재심인사위원회가 2018. 7. 18. 개최될 예정임을 알렸고, 2018. 7. 18. 재심인사위원회를 개최하여 이 사건 근로자의 재심신청을 기각하였으며, 같은 달 20. 이 사건 근로자에게 위 결과를 통보하였다. 마. 이 사건 근로자는 2018. 8. 7. 서울지노위에 이 사건 해고에 대하여 부당해고 구제를 신청하였다. <심급별 결과> [서울지노위] 징계사유에 비하여 양정이 과도하다는 이유로 원고의 구제신청을 인용 [중노위] 이 사건 사용자의 재심신청을 인용하고 이 사건 근로자의 구제신청을 기각 ※ 한편, 이 사건 근로자는 이 사건 사용자를 피고로 하여 서울중앙지방법원에 해고무효확인소송을 제기하였는데, 2020. 5. 8. 이 사건 해고 절차가 적법하고 해고 사유가 인정되나 징계양정이 과다하다는 이유로 이 사건 근로자의 청구를 인용하는 내용의 1심 판결이 선고되었고(서울중앙지방법원 2019가합000000), 이에 이 사건 사용자가 항소하였으나 항소심도 2021. 5. 14. 같은 취지로 이 사건 사용자의 항소를 기각하는 내용의 판결을 선고하였으며(서울고등법원 2020나0000000), 이에 이 사건 사용자가 상고하였으나 대법원에서 심리불속행 기각되었다(대법원 2021다000000). [1심 법원] 이 사건 해고는 그 절차를 준수하였고 징계사유도 인정되나 징계재량권을 일탈·남용한 것으로 위법하고, 따라서 이 사건 해고가 정당하다고 판단한 이 사건 재심판정은 위법하다고 판시

판결 요지

가. 징계절차의 위법 여부

이 사건 근로자는 인사위원회의 구성에 있어 이 사건 근로자에게 적대적인 이해관계인이고, 징계혐의를 조사했던 조사위원회의 위원들을 인사위원회 위원으로 삼아 공정성을 담보하기 어렵다는 주장을 하였으나 이 사건 사용자의 취업규칙을 살펴볼 때 이 사건 근로자가 주장하는 자들을 배제하는 규정은 존재하지 않는다.

또한 이 사건 근로자는 재심위원회 출석권 및 진술권이 침해되었다고 주장하나 취업규칙 등에 징계처분에 대한 재심절차에서 징계대상자에게 진술의 기회를 부여한다는 규정이 없는 이상 재심의 절차가 징계대상자에게 진술의 기회를 부여하지 않고 진행되었다고 하여 무효라고 할 수 없고(대법원 1995. 7. 14. 선고 94누11491 판결 등 참조), 실제 이 사건 사용자의 취업규칙 등에 징계처분에 대한 재심절차에서 징계대상자에게 출석 및 진술의 기회를 부여한다는 규정이 없는 이상, 설령 이 사건 해고에 대한 재심의 절차에서 징계대상자인 이 사건 근로자에게 출석 및 진술의 기회를 부여하지 아니하였다고 하더라도, 이 사건 해고가 무효라고 볼 수 없다.

나. 징계사유의 존재 여부

이 사건 근로자는 이 사건 사용자의 자산을 무단으로 도용하지 않았고, 이 사건 근로자의 행위로 이 사건 사용자의 대외신인도 및 명예가 훼손되지 않았다고 주장한다.

관련 증거들을 살펴보면, 이 사건 사용자는 이 사건 박사학위 논문을 작성하기 위해 참가인의 보관 문서이자 물품인 이 사건 연구 용역 보고서 초안 내지 그 최종본을 무단으로 도용하였다고 볼 수 있고, 이 사건 근로자의 위와 같은 행위는 신의성실의 의무 및 참가인의 비밀을 준수할 의무 내지 이 사건 사용자의 보관 문서 반출 시 참가인의 허가를 받아야 할 의무를 위반한 것임과 동시에 이 사건 사용자의 물품을 유용한 것으로서, 인사규정이 정한 징계사유에 해당한다.

또한 외부기관인 연구진실성검증센터에서 ○○대학교에 이 사건 박사학위 논문의 표절 의혹을 제보한 결과 ○○대학교에서 위 논문에 대하여 표절 판정을 내렸고, 일부 언론사에서 이 사건 근로자의 이 사건 박사학위 논문의 표절 논란에 관한 기사를 보도함에 따라 이 사건 사용자의 대외신인도 및 명예가 훼손되었다고 볼 수 있으므로, 이는 이 사건 사용자의 인사규정이 정한 징계사유에 해당한다.

다. 징계재량권의 일탈·남용 여부

다음과 같은 점을 고려한다면, 사회통념상 이 사건 근로자와 사용자 사이의 관계가 고용관계를 계속할 수 없을 정도에 이르렀다고 보기 어렵다.

① 원칙적으로 사용자는 근로자의 사생활 영역에 관하여는 지휘명령권을 가지지 않고, 근로자의 사생활에서의 비행은 근로의 제공과 직접 관련되는 것이 아니므로 해고사유가 되지 않는다. 다만 근로자의 사생활에서의 비행이 사업활동에 직접 관련이 있거나 기업의 사회적 평가를 훼손할 염려가 있는 경우에 한하여 징계사유가 될 수 있는데(대법원 1994. 12. 13. 선고 93누23275 판결 참조), 여기서 기업의 사회적 평가를 훼손할 염려가 있는지 여부는 당해 행위의 성질과 정상, 기업의 목적과 경영방침, 사업의 종류와 규모 및 그 근로자의 기업에 있어서의 지위와 담당 업무 등 제반 사정을 종합적으로 고려하여 객관적으로 평가해야 할 것이다(대법원 2001. 12. 14. 선고 2000두3689 판결 참조). 이 사건 근로자의 비위행위는 인정되나, 이 사건 사용자 내부에서 이 사건 근로자의 지위 등에 어떠한 영향을 미친 것으로 보이지 않는 점, 이 사건 근로자가 이 사건 박사학위 논문을 작성하거나 박사학위를 취득하는 것은 참가인의 마케팅부장 또는 총무부장으로서 수행하는 업무와 아무런 관계가 없는 개인적인 활동에 불과하여, 그 과정에서 타인의 학위논문을 표절한 행위가 참가인의 원활한 사업활동을 수행하고 규율과 질서를 유지하는 데 별다른 영향을 미칠 것으로 보이지 않는 점 등에 비추어 보면, 이 사건 연구 용역 보고서를 무단

으로 이용한 것을 논외로 한다면, 이 사건 근로자가 타인의 학위논문을 표절하여 이 사건 박사학위 논문을 작성한 행위만으로는 참가인의 명예나 사회적 평가에 중대한 악영향을 미쳤다고 평가하기 어렵다는 점

② 이 사건 근로자가 이 사건 사용자의 자산인 이 사건 연구 용역 보고서 중 일부를 무단으로 도용하여 이 사건 박사학위 논문을 작성하기는 하였으나 이 사건 연구 용역 보고서의 주된 취지와 위 논문 최종본의 각 주된 취지가 본질적으로 동일 내지 유사하다고 보기 어렵다는 점

③ 이 사건 근로자가 위 보고서 중 이 사건 표절 부분을 도용하였다고 하여 위 보고서에 내재된 고유의 가치를 현저히 훼손하였거나, 이 사건 사용자의 태권도용품 공인 업무에 지장을 초래하였다고 보기 어렵다는 점

④ 이 사건 근로자가 이 사건 박사학위 논문을 수정하여 최종적으로 박사학위를 취득하게 된 경위 및 위 논문의 심사를 맡았던 교수진의 입장 등을 고려할 때, ○○대학교 연구윤리진실성위원회에서 이 사건 박사학위 논문에 관하여 표절 판정을 내린 바 있음을 감안하더라도, 이 사건 근로자의 위 논문 표절 논란으로 인해 ○○대학교와의 사이에 참가인의 대외신인도 및 명예가 중대하게 훼손되었다고 보기 어렵다는 점

⑤ 인터넷신문 ○○○○○뉴스에서 2018. 6. 17. 이 사건 박사학위 논문의 표절 논란에 관한 기사를 보도한 이후, 위 논란에 관한 후속 보도가 있었음을 뒷받침할 만한 아무런 증거가 없다. 이에 비추어 볼 때, 이 사건 박사학위 논문의 표절 논란에 관한 언론 보도로 이 사건 사용자의 대외신인도 및 명예가 중대하게 훼손되었다고 보기 어렵다는 점

⑥ 기타 논문 표절로 인해 박사학위가 취소되었다는 것은 이 사건 사용자의 사업활동이나 이 사건 근로자의 업무와 직접적인 관련이 없는 개인적인 비위에 해당하고, 공금 유용 의혹은 사실로 밝혀진 바가 없으므로, 위와 같은 언론보도로 인해 이 사건 사용자의 명예나 사회적 신용이 심각하게 훼손되었다거나 그 책임이 전적으로 이 사건 근로자에게 있다고 할 수는 없고, 이 사건 근로자는 재직하면서 이 사건 이전까지 별다른 징계 이력 없이 성실하게 근무하여 왔던 것으로 보인다라는 점 등.

패소 이유 (징계양정의 적정성에 관한 가치 판단)

이 사건은 노동위원회의 판정을 다투는 사건과 병행하여 이미 해고무효확인소송이라는 민사소송이 병행되는 중이었고, 1심, 2심 법원이 부당해고라는 판단을 내린 상황에서 판결이 내려졌던 사건이다.

즉, 관련사건이 있고, 이미 법원에서 부당해고라고 판단을 받았기 때문에 사실상 행정소송으로 노동위원회의 재심판정을 취소해달라는 소송은 사실상 방향이 정해진 소송이라고 볼 수 있다.

이 사건은 논문의 표절로 인한 근로자의 비위사실이 언론에도 보도되는 등 대외적으로 사용자가 불미스러운 일로 언급되었을 때 그 원인이 된 근로자를 해고하는 과정에서 그 해고가 정당한지에 관한 사용자의 징계 재량권이 쟁점이었고, 재량에 대한 도식화된 기준이 없는 상황에서 판정하는 사람의 경험칙에 의존할 수 밖에 없었기에 초심, 재심 판정, 법원의 판단이 달랐던 사안이라고 생각된다.

일련번호	2022-4					
판결번호	서울고등법원 2021. 12. 3. 선고 2021누00000					
중노위판정번호	중노위 2020. 2. 20. 중앙2019부해1659					
사건 종류	징계해고					
세부 쟁점	징계의 정당성 - 절차					
심급별 소송결과	1심 법원	재심판정취소	2심 법원	1심판결 유지	대법원	-
원고, 피항소인	신○○			피고보조참가인	주식회사 ○○컨트리클럽	
피고, 항소인	중앙노동위원회위원장			피고측 대리인 선임 여부	선임 안 함	
노동조합 지원 여부	없음			원고측 대리인 선임 여부	선임	
재심 결과	초심 취소					
초심의 대법원 판례 일치여부	일치			재심의 대법원 판례 일치여부	불일치	
기타 특이사항						

주요 사실관계 <사실관계> 가. 주식회사 ○○컨트리클럽(이하 '이 사건 회사')은 2002. 1. 14. 설립되어 상시 근로자 약 110명을 사용하여 골프장업을 영위하는 법인이다. 나. 신○○(이하 '이 사건 근로자')는 2005. 8. 1. 이 사건 회사에 입사하여 경리·회계 팀장으로 근무하였다. 다. 이 사건 회사의 인사위원회는 2019. 8. 8. ① 종업원의 명령복종 의무 위반, ② 종업원의 비밀유지의무 위반 및 명예훼손, ③ 서류 위·변조까지 하면서 종업원의 신의성실의 원칙 위반, ④ 한양CC 대표이사의 접대비 지출 근거와 기밀성, ⑤ 내부자료 유출 금지 교육의 징계사유로 이 사건 근로자에 대한 정직 3개월을 의결하였다. 이에 대하여 이 사건 회사의 대표이사는 2019. 8. 9. 인사위원회에 재심의를 요청하였고, 인사위원회는 2019. 8. 10. 원고에 대한 해고를 의결하였다. 이 사건 회사는 2019. 8. 12. 이 사건 근로자에게 해고를 통보하였다(이하 '이 사건 해고'). 라. 이 사건 근로자는 '이 사건 해고는 부당하다'고 주장하면서 2019. 9. 20. 경기지노위에 구제를 신청하였다. <심급별 결과> [경기지노위] 2019. 11. 15. '이 사건 해고는 징계사유가 일부 인정되지 않고 징계양정이 과중하

여 부당하다'는 이유로 이 사건 근로자의 구제신청을 인용. 이 사건 회사는 이에 불복하여 2019. 12. 23. 중노위에 재심을 신청
[중노위] 2020. 2. 20. '이 사건 해고는 징계사유가 일부 인정되지 않으나 징계양정이 적정하므로 정당하다'는 이유로 초심 취소

[1심 법원] 이 사건 해고는 징계사유가 일부 인정되나 징계양정이 과중하여 부당하므로 이 사건 재심판정은 위법하다고 판시

[2심 법원] 1심 판결과 같은 결론을 내렸고 이대로 확정

판결 요지

가. 절차적 위법 여부

단체협약이나 취업규칙 또는 이에 근거를 둔 징계규정에서 징계위원회의 구성에 관하여 정하고 있는 경우 이와 다르게 징계위원회를 구성한 다음 그 결의를 거쳐 징계처분을 하였다면, 그 징계처분은 징계사유가 인정되는지 여부와 관계없이 원칙적으로 절차상 중대한 하자가 있어 무효이다. 취업규칙은 사용자가 그 근로자의 복무규율이나 근로조건의 기준을 정립하기 위하여 작성한 것으로서 노사 간의 집단적인 법률관계를 규정하는 법규범의 성격을 가지는데, 이러한 취업규칙의 성격에 비추어 취업규칙은 원칙적으로 그 객관적인 의미에 따라 해석하여야 하고, 문언의 객관적 의미를 벗어나는 해석은 신중하고 엄격하여야 한다(대법원 2020. 11. 26. 선고 2017두 70793 판결 등 참조).

① 인사위원회의 구성에 관한 규정은 징계의결의 공정성 확보를 위해 엄격하게 해석할 필요성이 있는 점, ② 인사위원회규정 제2조는 “위원회는 부장 및 과장, 노조대표와 여직원대표로 구성한다.”고 규정하여 징계대상자의 성별이나 징계사유의 내용에 따라 위원회 구성을 달리할 수 있는 단서 또는 예외를 두고 있지 않은 점, ③ 취업규칙 제60조 및 이에 근거를 둔 인사위원회규정 제1조는 징계의 공정을 기하기 위하여 인사위원회를 두도록 규정하고 있고, 단체협약 제20조 제4호는 “징계위원회에 노조위원장 1명, 여직원대표 1명을 인사 처리의 공정성을 기하기 위하여 배석”하도록 규정하고 있는 것에 비추어 볼 때 인사위원회의 구성에 여직원대표를 포함시키도록 규정한 취지는 여성근로자의 인권 보호에 국한되는 것이 아니라 인사위원회 구성의 다양성을 보장함으로써 징계 등 인사 관련 논의에 다양한 관점 및 가치관이 반영될 수 있도록 하여 인사 처리의 공정을 기하기 위한 것으로 보이는 점 등을 고려하면, 이 사건 회사가 이 사건 근로자에 대한 인사위원회를 구성하면서 여직원대표를 포함시키지 않은 것은 절차상 하자에 해당한다고 봄이 타당하다.

나. 징계사유의 인정 여부

이 사건 근로자가 대표이사의 승인을 받지 아니하고 김○○에게 이 사건 자료를 제출한 행위는 명령복종의무 위반, 내부자료 유출금지 교육 위반, 비밀유지의무 위반, 대표이사의 접대비 지출 근거와 기밀성 위반에 해당하나 명예훼손에는 해당하지 않는다고 봄이 타당하다. 따라서 이 부분 징계사유는 위 인정범위 내에서 이유 있다.

다. 징계양정의 적정 여부

피징계자에게 징계사유가 있어서 징계처분을 하는 경우, 어떠한 처분을 할 것인지는 징계권자의 재량에 맡겨져 있다. 다만 징계권자의 징계처분이 사회통념상 현저하게 타당성을 잃어 징계권자에게 맡겨진 재량권을 남용하였다고 인정되는 경우에 한하여 그 처분이 위법하다고 할 수 있다. 징계처분이 사회통념상 현저하게 타당성을 잃어 재량권의 범위를 벗어난 위법한 처분이라고 할 수 있으려면 구체적인 사례에 따라 징계의 원인인 비위사실의 내용과 성질, 징계로 달성하려는 목적, 징계양정의 기준 등 여러 요소를 종합하여 판단할 때에 징계 내용이 객관적으로 명백히 부당하다고 인정되어야 한다. 한편 해고처분은 사회통념상 고용관계를 계속할 수 없을 정도로 근로

자에게 책임 있는 사유가 있는 경우에 정당성이 인정되고, 사회통념상 근로자와 고용관계를 계속 할 수 없을 정도인지는 사용자의 사업 목적과 성격, 사업장의 여건, 근로자의 지위와 담당직무의 내용, 비위행위의 동기와 경위, 근로자의 행위로 기업의 위계질서가 문란하게 될 위험성 등 기업 질서에 미칠 영향, 과거의 근무태도 등 여러 가지 사정을 종합적으로 검토하여 판단하여야 한다 (대법원 2017. 3. 15. 선고 2013두26750 판결 등 참조).

다음과 같은 사정들을 위 법리에 비추어 보면, 이 사건 해고는 사회통념상 현저하게 타당성을 잃어 징계재량권의 범위를 일탈하거나 그 권한을 남용한 경우에 해당한다고 봄이 타당하다. 따라서 이 사건 근로자의 이 부분 주장은 이유 있다.

① 이 사건 근로자에 대한 징계사유 중 대표이사에 대한 명예훼손, 추가 경위서 작성 지시 불이행으로 인한 명령복종업무 위반, 서류 위.변조로 인한 신의성실의 원칙 위반은 정당한 징계사유로 인정되지 않는다.

② 이 사건 근로자는 이 사건 자료를 자발적으로 제출한 것이 아니라 이 사건 회사의 1인 주주이자 지주회사인 서울컨트리클럽 부이사장의 지시에 따라 제출하였다. 이 사건 근로자가 이 사건 자료를 작성하여 제출하게 된 경위에 비추어 볼 때 이 사건 근로자가 대표이사를 음해할 목적으로 이 사건 자료를 작성하여 제출한 것으로는 보이지 않는다.

③ 이 사건 근로자가 ○○컨트리클럽의 예.결산 총괄관리자 지위를 겸하였던 점을 고려하면, 이 사건 근로자의 입장에서 ○○컨트리클럽 부이사장의 지시를 거부하는 것은 현실적으로 쉽지 않았을 것으로 보인다[이 사건 회사는 김○○이 2019. 3. 1. ○○컨트리클럽 총회에서 부이사장으로 선출되었으나 이사로 등기되지 않은 상태에서 2019. 3. 14. 사임하였으므로 부이사장의 지위에 있지 않았다고 주장한다. 그러나 ○○컨트리클럽의 정관에는 임원의 취임절차와 관련한 규정이 존재하지 않는 점, 민법 제54조 제1항에 의하면 이사 변경 등기에는 실체적 효력이 없는 점 등을 고려하면, 김○○은 2019. 3. 1. 총회에서 부이사장으로 선출됨과 동시에 부이사장의 지위에 있었다고 봄이 타당하다].

④ 이 사건 근로자는 약 14년 동안 참가인 회사에서 근무하면서 징계처분을 받은 전력이 없고, 2013. 2. 28. 이 사건 회사에 기여한 공로를 인정받아 공로패를 받는 등 성실하게 근무하여 온 것으로 보인다.

패소 이유 (재량의 여지, 취업규칙, 단체협약, 인사위원회규정 등 근거 규정들의 통일적인 해석 권한)

이 사건은 노동위원회 초심판정은 징계양정을 문제삼아 징계해고가 부당하다고 판정하였고(초심에서는 양정을 문제삼아 절차위반 부분은 아예 판단하지 않았음), 재심에서는 양정의 절차는 물론 위법 문제가 없다고 판단한 사건이고, 법원에 와서 절차적인 위법사항, 양정이 과중하다는 두 가지의 쟁점에 대해 모두 문제가 있다고 판단한 사건이다.

징계양정에 관한 재량의 판단은 그 판단주체가 누구인지, 절차에 소요되는 시간, 노력 등에 따라 구체적이고 명확한 기준 마련이 쉽지 않고 그렇기에 이에 따른 각 기관의 판단이 다른 점은 다른 사건의 패소이유와 같다. 다만 이 사건은 추가적으로 법원의 역할인 규범의 해석이라는 점에 있어서 중노위의 결론과 달라진 근본적인 부분이 있었고, 그렇기에 결과가 달라진 것으로 판단된다.

즉, 법원은 인사위원회의 구성에 관한 근거 규정 즉, 인사위원회규정과 단체협약, 취업규칙을 전체적으로 통일적으로 해석하여 ‘인사위원회를 구성할 때 여직원대표를 포함시켜야 한다는’ 기준에 따라 절차적 위반 사항을 검토하였다.

부록.1. 주요 사건 경과 및 패소 원인 분석

일련번호	2022-5					
판결번호	서울고등법원 2021. 10. 20. 선고 2020누00000 판결					
중노위판정번호	중노위 2019. 8. 30. 중양2019부해792					
사건 종류	부당해고					
세부 쟁점	취업규칙 개정, 정년, 부당해고					
심급별 소송결과	1심 법원	청구 기각	2심 법원	1심 취소	대법원	
원 고	신○○		참 가 인		○○○요양병원	
피 고	중양노동위원회위원장		피고측 대리인 선임 여부		선임	
노동조합 지원 여부	없음		원고측 대리인 선임 여부		선임	
재심 결과	초심 유지					
초심의 대법원 판례 일치여부	불일치		재심의 대법원 판례 일치여부		불일치	
기타 특이사항						

주요 사실관계

<사건 개요>

가. 피고보조참가인(이하 '참가인')은 D요양병원을 운영하는 사람이고, 원고(E)는 위 요양병원에서 근무하던 사람이다. 원고는 2015. 9. 14. I요양병원(의료기관 개설일은 2015. 7. 13.)을 운영하던 J과 기간의 정함이 없는 근로계약을 체결하였고, 위 근로계약에는 원고의 정년이 명시되어 있지 않다. 그 후 I요양병원은 2017. 2. 17. G요양병원으로 명칭이 변경되었다. 참가인은 2018. 4. 26. K으로부터 G요양병원을 인수한 후, 2018. 5. 31. D요양병원으로 명칭을 바꾸고 상시 근로자 약 100명을 사용하며 병원 영업을 계속하였다.

나. 참가인은 2019. 2. 7. 원고에게 '취업규칙 제51조에 따라 원고가 정년인 60세에 도달한 2019. 2. 28. 근로관계가 종료된다.'라고 통보하였다. 개정 전 취업규칙 부칙에는 2005. 11. 30. 위 취업규칙이 처음 제정되어 시행된 것으로 기재되어 있고, 2015. 9. 25. 개정된 취업규칙은 2016. 1. 1.부터 시행한다고 정하고 있으며, 2018. 5. 16. 마지막으로 개정된 내용의 시행일은 2018. 5. 29.로 기재되어 있다. 원고는 광주지방고용노동청장의 변경 요청에 따라 내용을 개정하여, 시행일을 '2019. 4. 1.'로 정하여 신고하였다. 2019. 4. 신고 취업규칙의 신고 시 D요양병원의 근로자 중 과반수 근로자들이 서명한 동의서가 첨부되었다.

다. 원고는 2019. 4. 11. 전남지방노동위원회에 F로 '참가인은 G요양병원을 인수하여 D요양병원을 개원하였는데, 원고는 G요양병원에서 근무하던 중 참가인에게 그 고용이 승계되었다. 참가인은 원고에게 정년 규정에 대해 말하거나 제시하지 않았고, 참가인이 작성한 취업규칙의 시행일은 2019. 4. 1.이어서 정년 규정 또한 그 이후부터 적용되므로 원고에게 불리한 내용으로 일방적으로 취업규칙을 작성하여 적용한 것은 그 이전부터 근무하여 온 원고에게는 효력이 없다.'라고 주장하며 구제를 신청하였다.

<심급별 결과>

[전남지노위] '원고와 참가인 사이의 근로관계는 참가인 요양병원의 취업규칙에서 정한 정년에 도달하여 종료되었으므로 해고가 존재하지 않는다.'라는 이유로 원고의 구제신청을 기각
[중노위] 초심판정과 같은 이유로 원고의 재심신청을 기각

[1심 법원] 취업규칙의 유효성을 인정하여 원고의 청구를 기각

[2심 법원] 취업규칙의 유효성을 부정하여 원고의 청구를 인용. 1심판결과 재심판정을 취소

판결 요지

취업규칙의 작성·변경의 권한은 원칙적으로 사용자에게 있으므로 사용자는 그 의사에 따라 취업규칙을 작성·변경할 수 있으나, 취업규칙의 작성·변경이 근로자가 가지고 있는 기득의 권리나 이익을 박탈하여 불이익한 근로조건을 부과하는 내용일 때에는 종전 근로조건 또는 취업규칙의 적용을 받고 있던 근로자의 집단적 의사결정방법에 의한 동의, 즉 당해 사업장에 근로자의 과반수로 조직된 노동조합이 있는 경우에는 노동조합, 근로자의 과반수로 조직된 노동조합이 없는 경우에는 근로자의 과반수의 동의를 요한다(대법원 1997. 5. 16. 선고 96다2507 판결 등 참조). 그리고 이러한 동의를 얻지 못한 취업규칙의 변경은 효력이 없다(대법원 1992. 12. 22. 선고 91다45165 판결 등 참조).

또한 취업규칙에 정년규정이 없던 회사에서 정년제 규정을 신설하는 것은, 근로자가 가지고 있는 기득의 권리나 이익을 박탈하는 불이익한 근로조건을 부과하는 것에 해당한다(대법원 1997. 5. 16. 선고 96다2507 판결 등 참조).

개정 전 취업규칙은 적어도 2018. 5. 16. 이후로부터 2018. 7. 6. 사이에 N 주식회사(이하 'N'라 한다)의 취업규칙을 베껴서 형식적으로 작성된 것으로서 참가인이 운영하던 위 요양병원에 적용되던 유효한 취업규칙이라고 보기 어려우므로 이 사건 통보에 적용되는 취업규칙이라고 할 수 없다. 개정 전 취업규칙과 N 취업규칙의 각 조항들과 2018. 5. 16.까지의 개정일 및 2018. 5. 29.까지의 시행일이 모두 동일하고, 위 각 취업규칙 모두 요양병원이나 의사, 간호사, 간병인이라는 명칭 없이 회사, 사장, 직원이라는 명칭을 사용하고 있다. N의 취업규칙과 개정 전 취업규칙은 모두 2005. 11. 30. 처음 제정되어 시행된 것으로 기재되어 있는데, 참가인의 요양병원은 위 제정일로부터 약 10년 후인 2015. 7. 13. I요양병원이라는 명칭으로 처음 설립되었다.

참가인의 요양병원에서 근무하였던 간호사 및 조무사들은 그 사실확인서에서 'G요양병원에서 근무할 당시(위 간호사 등이 근무하였던 2015. 12.경 내지 2018. 8.경이다) 직장 내 취업규칙이 게시된 사실이 없었으며 취업규칙이 존재한다는 사실도 들어본 적이 없었다.'고 진술하였다.

사용자는 그 의사에 따라 취업규칙을 작성할 수 있는 것이므로, 비록 다른 사업장의 취업규칙을 베낀 것이라고 하더라도, 개정 전 취업규칙 등을 참가인이 그 요양병원에 적용하기 위하여 위 2018. 5. 16.부터 2018. 7. 6. 사이에 새로 작성한 취업규칙이라고 볼 수도 있다.

위와 같이 본다고 하더라도, ... D요양병원에서는 그 특성상 만 60세가 넘는 경우에도 근로자들이 별다른 제한 없이 계속 근무하여 온 사실을 인정할 수 있고(원고가 이 사건 통보에 관하여 부당해고구제신청을 한 F 사건에서 참가인은 D요양병원에서 정년을 이유로 근로관계가 종료된 사람은 원고가 유일하다고 진술하였다), 한편 원고가 개정 전 취업규칙 작성 전부터 근무를 하여 온 것은 위 인정사실에서 본 바와 같은바, 개정 전 취업규칙이 위와 같이 작성되기 전에 G요양병원이나 D요양병원에 별개의 다른 취업규칙이 존재하였다고 볼 만한 사정이 없는 이 사건에서 개정 전 취업규칙 제59조에서 새로이 근로자의 정년을 규정한 것은 불이익한 근로조건을 부과하는 것에 해당하므로, 개정 전 취업규칙에 관하여 근로자의 집단적 동의가 있어야 한다. 그런데 G요양병원이나 D요양병원에서 그에 관한 근로자의 집단적 동의가 있었다고 인정할 증거가 없으므로 개정 전 취업규칙 제59조는 그 효력이 없다고 할 것이다.

이 사건 통보 당시 원고에게 2019. 3. 신고 취업규칙의 정년에 관한 제51조 등이 적용된다고 할 수 없으므로 위 취업규칙 제51조 등을 이 사건 통보의 근거로 삼을 수 없다고 봄이 타당하다. ... 근로계약 체결 시 사용자는 근로자에게 '퇴직에 관한 사항'을 명시하여야 하는데 참가인은 2018. 9. 3. 원고와 근로계약을 작성하면서 원고가 당시 만 59세 6월 남짓한 나이였음에도 정년에 관하여 어떠한 말을 하거나 계약서에도 아무런 기재도 하지 않은 채 계약기간의 만료일을 정하지 않았다. "정년은 만 60세에 도달한 날로 한다."는 내용의 제51조가 포함된 2019. 3. 신고 취업규칙이 2018년에 적용되는 진정한 취업규칙이었다면 원고와의 위 근로계약 체결 시 아무런 언급이 없었다는 것은 쉽게 납득하기 어렵다. 더욱이 참가인은 원고와의 직전 분쟁(H, M)에서도 정년에 관하여 아무런 언급을 하지 않았던 것으로 보인다.

참가인이 2019. 3. 신고 취업규칙을 신고하면서 그 신고서의 '의견청취일 또는 동의일'란에 '2018. 6. 18.'이라고 기재한 사실, 위 신고서에 과반수인 근로자 94명의 연명부를 첨부하여 제출한 사실은 인정된다. 그러나 참가인이 2018. 7. 6. H 부당해고 구제신청 사건에서 제출한 취업규칙은 2019. 3. 신고 취업규칙이 아닌 개정 전 취업규칙임은 앞서 본 바와 같은바, 만일 2019. 3. 신고 취업규칙이 2018. 7. 무렵 존재하고 있었다거나 이에 대하여 참가인이 2018. 6. 8. 그 근로자들의 동의 등을 얻은 것이라면 위와 같이 개정 전 취업규칙을 제출할 리 없었을 것으로 보이는 점, 나아가 위 연명부에는 취업규칙에 대한 동의 등 여부나 그 작성일 등을 알 수 있는 아무런 기재가 없고, 참가인도 2021. 7. 14.자 준비서면에서 '광주지방고용노동청에 2019. 3. 신고 취업규칙을 신고하면서 서면 형식의 근로자들의 동의서가 함께 제출되어야 한다는 사실을 비로소 알았고, 근로자들의 동의를 받았음을 확인할 수 있는 서면을 구비하고자 하여 당시 재직하고 있던 근로자들이 100명이 넘어서 10여 일 이상 소요되어 취업규칙 동의서가 2019. 4. 초에야 완성되어 이를 제출하였다.'고 진술하였으며, 위 취업규칙 동의서에 비로소 근로자들이 '2019. 4.에 취업규칙을 열람하였다.'고 기재되어 있는 점 등에 비추어 위와 같이 2019. 3. 신고 취업규칙에 관한 신고서의 '의견청취일 또는 동의일'란에 기재된 날짜는 그대로 믿기 어렵고, 연명부 또한 위 취업규칙에 대한 동의서로 보기 어려우며, 달리 참가인이 이 사건 통보 전에 2019. 3. 신고 취업규칙에 대하여 근로자의 집단적 동의를 받았다고 인정할 증거가 없으므로 정년에 관하여 규정한 위 취업규칙 제51조 등은 역시 그 효력이 없다고 할 것이다.

2019. 4. 신고 취업규칙은 이 사건 통보 이후이자 2019. 3. 신고 취업규칙 작성 이후에 수정, 작성된 것으로서 이에 대한 근로자들의 동의도 그 후 받은 것으로 보이며, 그 부칙에서 시행일을 2019. 4. 1.로 정하고 있으므로 2019. 4. 신고 취업규칙의 정년에 관한 제51조 등을 그 전에 행해진 이 사건 통보의 근거규정으로 삼기 어렵다.

패소 이유 (동일한 사실관계에 관하여 기존 대법원 판례 법리와 다른 결론)

불이익한 취업규칙의 소급 적용 가능성에 대해서는 기존 대법원 판례 법리를 살펴봐도 불명확한 부분이 있는 것은 사실이다. 그러나, 정년 규정 신설이나, 정년 연령 하향조정은 불이익 변경으로서 동의를 얻어야 한다는 점은 기존 판례 법리를 통해 확인할 수 있으며, 불이익하게 변경된 취업규칙을 당사자의 의사에 반하여 소급적용할 수 있는지 여부는 적법한 권한 있는 동의권자의 동의가 있었는가에 따라 달라질 수 있다. 사용자 측은 적법한 취업규칙 변경절차 이행 여부에 대해서도 충분히 소명하고 있지 못했음에도 불구하고, 중노위가 취업규칙이 적법하게 변경됐다는 사용자의 주장을 수용한 것은 대법원 판례 법리에 대한 충분한 이해가 부족했던 것으로 판단할 수 있을 것이다. 따라서 당 사건에서 중앙노동위원회가 대법원에 상고하지 않은 것은 합리적인 결정이었다고 판단된다.

판례에 대하여 피상적인 결론뿐만 아니라, 판례 법리 안에 담긴 실질적 의미를 입체적으로 이해해야 이와 같은 해석상 오류를 최소화할 수 있을 것이다. 조사관과 공익위원의 전문성과 업무 수행 역량을 더욱 강화해야 한다.

일련번호	2022-10					
판결번호	대법원 2022. 1. 27. 선고 2021두00000					
중노위판정번호	중노위 2019. 5. 27. 중앙2019부해309					
사건 종류	부당해고					
세부 쟁점	징계해고-절차					
심급별 소송결과	1심 법원	재심취소	2심 법원	1심판결 유지	대법원	원심유지
원고, 피상고인	이○○		피고보조참가인, 상고인		주식회사 ○○○	
피고, 상고인	중앙노동위원회위원장		피고측 대리인 선임 여부		선임	
노동조합 지원 여부	없음		원고측 대리인 선임 여부		선임 안 함	
재심 결과	초심 유지					
초심의 대법원 판례 일치여부	불일치		재심의 대법원 판례 일치여부		불일치	
기타 특이사항						

주요 사실관계 <사실관계> 가. 주식회사○○○(이하 ‘이 사건 회사’)은 2013. 12. 27. 설립되어 철도운송업 등을 영위하는 공기업이다. 이○○(이하 ‘이 사건 근로자’)는 2016. 8. 22. ‘개통준비 7단계 공개채용 절차’ 중 ‘신입직 ○○○’ 채용절차(이하 ‘이 사건 채용절차’)를 통해 이 사건 회사에 입사하여 2018. 9. 22.까지 ○○ 등으로 근무한 사람이다. 나. 이 사건 회사는 2018. 6. 15. 이 사건 근로자에 대하여 2018. 6. 18.자로 직위해제하는 처분을 하였고, 2018. 9. 20. 이 사건 근로자에 대한 인사위원회를 개최하여 아래와 같은 사유가 인사규정 제54조 제1항 제6호에서 정한 직권면직 사유인 ‘채용결격사유가 발견되었거나 사기 또는 부정한 방법으로 채용된 사실이 발견되었을 때’에 해당한다는 이유로 직권면직을 의결한 후, 2018. 9. 22. 인사발령하였다(이하 ‘이 사건 직권면직’). 다. 이 사건 근로자는 2018. 12. 18. 이 사건 직권면직이 부당해고라고 주장하며 서울지노위에 구제신청을 하였다. <심급별 결과> [서울지노위] 2019. 2. 18. ‘채용청탁을 받은 차○○ 등이 이 사건 근로자 등의 점수와 순위를 조작하여 이 사건 근로자가 이 사건 회사에 입사한 사실이 인정되고, 이는 인사규정 제54조 제1항 제6호의 부정한 방법으로 채용된 사실이 발견된 때에 해당하므로 이 사건 직권면직의 사유는 정당하다. 또한, 이 사건 회사는 적법하게 소집된 인사위원회에서 이 사건 근로자에게 소명기회
--

를 부여하였기 때문에 절차적으로도 적법하다’는 이유로 구제신청을 기각. 이 사건 근로자는 이에 불복하여 2019. 3. 25. 중노위에 위 초심판정의 취소를 구하는 재심을 신청
[중노위] 2019. 5. 27. 위 초심판정과 같은 취지의 이유로 이 사건 근로자의 재심신청을 기각하는 판정(이하 ‘이 사건 재심판정’)

[1심 법원] 이 사건 직권면직은 절차적 위법을 이유로 효력이 없다고 판시
[2심 법원, 대법원] 1심법원의 판결과 같은 판결

판결 요지

1. 절차적 하자의 존부

가. 근로기준법 제27조 제1항 위반 여부

근로기준법 제27조는 사용자가 근로자를 해고하려면 해고사유와 해고시기를 서면으로 통지하여야 효력이 있다고 규정하고 있는바, 이는 해고사유 등의 서면통지를 통해 사용자로 하여금 근로자를 해고하는 데 신중을 기하게 함과 아울러 해고의 존부 및 시기와 그 사유를 명확하게 하여 사후에 이를 둘러싼 분쟁이 적정하고 쉽게 해결될 수 있도록 하고, 근로자에게도 해고에 적절히 대응할 수 있게 하기 위한 취지이므로, 사용자가 해고사유 등을 서면으로 통지할 때는 근로자의 처지에서 해고사유가 무엇인지를 구체적으로 알 수 있어야 하고, 특히 징계해고의 경우에는 해고의 실질적 사유가 되는 구체적 사실 또는 비위내용을 기재하여야 하지만, 해고 대상자가 이미 해고사유가 무엇인지 구체적으로 알고 있고 그에 대해 충분히 대응할 수 있는 상황이었다고 하면 해고통지서에 징계사유를 축약해 기재하는 등 징계사유를 상세하게 기재하지 않았더라도 위 조항에 위반한 해고통지라고 할 수는 없다(대법원 2014. 12. 24. 선고 2012다81609 판결, 대법원 2015. 7. 9. 선고 2014다76434 판결 등 참조).

근로기준법 제27조 제1항의 ‘서면’이란 일정한 내용을 적은 문서를 의미하고 이메일 등 전자문서와는 구별되지만, 전자문서 및 전자거래 기본법 제3조는 “이 법은 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고 모든 전자문서 및 전자거래에 적용한다”고 규정하고 있고, 같은 법 제4조 제1항은 “전자문서는 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 전자적 형태로 되어 있다는 이유로 문서로서의 효력이 부인되지 아니한다”고 규정하고 있는 점, 출력이 즉시 가능한 상태의 전자문서는 사실상 종이 형태의 서면과 다를 바 없고 저장과 보관에서 지속성이나 정확성이 더 보장될 수도 있는 점 등을 고려하면, 근로자가 전자문서를 수신하는 등으로 내용을 알고 있는 이상, 전자문서에 의한 해고통지도 해고사유 등을 서면 통지하도록 규정한 근로기준법 제27조의 입법 취지를 해치지 아니하는 범위 내에서 구체적 사안에 따라 서면에 의한 해고통지로서 유효하다고 보아야 할 경우가 있다(대법원 2015. 9. 10. 선고 2015두41401 판결의 취지 참조).

비록 이 사건 사용자가 이 사건 근로자에게 교부한 이 사건 직권면직 관련 인사발령문에는 이 사건 직권면직의 사유가 구체적으로 기재되어 있지 않지만, 인정되는 사실관계를 앞서 든 법리에 비추어 보면, 이 사건 근로자는 이 사건 직권면직 사유가 ‘이 사건 채용절차에 따른 이 사건 근로자의 채용과 관련하여 이 사건 공소사실 기재와 같이 이○○이 이 사건 근로자의 OPIc 증빙서류를 서류접수 마감일 후에 접수하고 이 사건 근로자를 서류전형에서 합격시키기 위해 이 사건 근로자보다 점수가 높은 28명을 합격자 명단에서 삭제함으로써 이 사건 근로자를 서류전형에 합격하도록 하는 부정행위가 있었다’라는 것임을 충분히 알고 있었다고 할 것이고, 그에 대해 충분히 대응할 수 있는 상황이었다고 봄이 타당하므로, 이 사건 사용자가 이 이 사건 직권면직 관련 인사발령문에 징계사유를 상세하게 기재하지 않았더라도 근로기준법 제27조 제1항을 위반하였다고 볼 수 없다.

나. 징계절차를 거치지 아니한 위법 여부

통상해고는 일반적으로 근로자의 일신상 사유를 원인으로 하는 해고로서 근로자의 비위행위를

원인으로 하는 징계해고와 구분된다. 따라서 면직처분과 징계처분이 따로 규정되어 있고 면직처분에 관하여는 일반의 징계처분과 달리 아무런 절차규정도 두고 있지 않으며, 그 면직사유가 동일하게 징계사유로 규정되어 있는 것도 아니라면, 사용자가 면직처분을 함에 있어 일반의 징계절차를 거쳐야 한다고 할 수 없고, 징계규정을 따르지 아니하였다고 하여 위법하다고 할 수 없다(대법원 1995. 6. 30. 선고 94다35350 판결 참조). 그러나 특정사유가 징계해고사유와 통상해고사유의 양쪽에 모두 해당하는 경우에는 징계해고에 따른 소정의 절차를 거쳐야 하고 징계해고사유로 통상해고를 한다는 구실로 징계절차를 생략할 수 없다(대법원 1994. 10. 25. 선고 94다25889 판결 등 참조). 이는 사용자가 근로자를 해고함에 있어 '징계사유'를 이유로 해고를 하면서도 징계 이외의 절차에 의하는 경우, 근로자의 절차적 지위 보장이 약화되는 결과가 초래될 수 있으므로, 징계에 관한 절차 회피를 방지하기 위한 것이다.

앞서 든 법리에 의하면, 이 사건 직권면직에 징계절차가 적용되어야 하는지 여부는 직권면직 사유를 정하고 있는 인사규정 제54조 제1항 제6호가 징계사유를 정하고 있는 인사규정 제59조 제1호와 '동일하게 징계사유로도 규정되어 있는 경우'로 해석되는지에 따라 판단하여야 한다. 여기서 '직권면직 사유가 동일하게 징계사유로도 규정되어 있는 경우'라 함은, 원칙적으로 통상해고의 원인이 되는 사유가 근로자의 일신상 사유로서 근로계약상의 급부 의무 이행에 필요한 정신적, 육체적 기타 노무수행상의 적격성을 현저하게 저해하는 사정 등으로 해석된다는 점을 고려하여, 직권면직 사유와 징계사유의 내용이 실질적 동일성이 인정되는지에 따라 판단함이 타당하다.

그러나 이 사건 직권면직 사유는 근로관계의 자동소멸사유에 해당하지 않기 때문에 이 사건 직권면직은 근로기준법 제23조의 제한을 받는 해고에 해당한다.

한편, 이 사건 사용자가 이 사건 근로자에 대하여 이 사건 직권면직을 하면서 인사위원회의 심의를 거쳤음은 앞서 본 바와 같다(참가인이 2018. 9. 6. 원고에게 인사위원회 소집을 통보하면서 징계위원회라는 표현을 사용하였으나, 실제로는 인사위원회를 개최한 것으로 보인다). 다만 이 사건 사용자가 인사위원회를 거친 것만으로 이 사건 근로자에게 징계절차에 준하는 절차적 권리가 보장된 것으로 볼 수 있는 경우 등 특별한 사정이 있는 경우에는 위법하지 않다고 볼 여지도 있으나, 아래와 같은 사정에 비추어 보면 이 사건 직권면직 과정에서 이 사건 근로자에게 징계절차에 준하는 절차적 권리가 보장되었다고 볼 수 없다.

① 징계위원회의 경우 인사위원회와는 구성에 있어서 큰 차이가 있는 점, ② 징계위원회의 경우 출석위원 과반수에 달하지 못하는 경우 출석위원 과반수에 이르기까지 징계혐의자에게 가장 불리한 의견에 차례로 유리한 의견을 더하여 과반수에 도달한 의견을 합의된 의견으로 함으로써 징계대상자에게 보다 유리한 방식으로 합의된 의견을 강제하고 있다는 점, ③ 징계위원회는 재심을 청구할 수 있는 절차적 권리를 인정하고 있으나 인사위원회는 그렇지 않다는 점 등.

패소 이유 (재심위원회 구성에 관한 인사위원회 규정 해석)

이 사건은 근로자가 부정한 채용청탁을 한 사실이 확인되어 이를 이유로 직권면직한 사건이고, 이에 징계해고를 거치지 않은 경우에 대한 판단이 엇갈린 사건이다.

초심, 재심 판정에 있어 노동위원회는 직권면직이라는 점에 집중하여 징계해고와 관련한 절차를 거치지 않아도 절차의 하자가 없다고 판단하였으나, 법원은 징계절차에 관한 절차 회피 방지의 목적을 근거로 구체적인 사실관계를 면밀히 파악하여 직권면직 사유와 징계사유의 내용이 실질적 동일성이 인정되는지에 따라 이 사건 근로자의 직권면직에는 징계해고와 관련한 절차를 거쳐야 한다고 판시하였다.

결국, 구체적인 사실관계를 어떤 관점에서 바라보느냐, 혹은 어떻게 분석하느냐, 절차에 소요되는 시간, 법관의 전문성에 따라서 결론이 달라진 것으로 판단된다.

부록.1. 주요 사건 경과 및 패소 원인 분석

일련번호	2022-12					
판결번호	서울행정법원 2021. 5. 27. 선고 2020구합0000 판결					
중노위판정번호	중노위 2020. 2. 17. 중앙2019부해1522					
사건 종류	부당전보					
세부 쟁점	인사명령, 배치전환, 생활상 불이익, 성실한 협의, 업무상의 필요성					
심급별 소송결과	1심 법원	피고 패	2심 법원	항소취하	대법원	
원 고	김○○, 임○○		참 가 인		○○푸드(주)	
피 고	중앙노동위원회위원장		피고측 대리인 선임 여부		선임	
노동조합 지원 여부	없음		원고측 대리인 선임 여부		선임	
재심 결과	초심 일부 취소					
초심의 대법원 판례 일치여부	불일치		재심의 대법원 판례 일치여부		불일치	
기타 특이사항						

주요 사실관계

<사건 개요>

가. 피고보조참가인(이하 ‘참가인 회사’)는 사업본부와 생산본부 등으로 구성되고, 그중 사업본부는 푸드서비스 사업본부, 파스퇴르 사업본부, 홈푸드 사업본부로 나뉘어 독립적으로 사업을 운영하고 있다. 원고 김○○, 임○○은 홈푸드 사업본부에서 근무하던 사람이다.

나. 참가인 회사는 2019. 6. 1.자로 홈푸드 KAM팀 MD담당 매니저인 원고 김○○을 본사 총무팀으로 보직변경하고, 홈푸드 영업팀 수원지점에서 파견 근무 중이던 원고 임○○을 본사 총무팀으로 파견해제 및 부서변경하는 내용의 인사발령(이하 ‘1차 전보’라고 한다)을 하였다.

다. 그 후 참가인 회사는 2019. 6. 12. 원고 김○○을 OO 소재 생산공장으로, 2019. 6. 14. 원고 임○○을 OO 소재 생산공장으로 각 전보하는 인사발령(이하 ‘2차 전보’라고 한다)을 하였다.

마. 원고들은 1차 및 2차 전보가 모두 부당하다고 주장하며 서울지방노동위원회에 부당전보 구제신청을 하였다(서울2019부해2100호).

<심급별 결과>

[서울지노위] ‘2차 전보는 업무상 필요성이 인정되지 않고 그로 인한 원고들의 생활상 불이익이 현저하므로 부당하다. 1차 전보는 2차 전보를 위한 예비적·부속적 인사에 불과하므로, 2차 전보가 부당한 이상 1차 전보의 정당성도 인정할 수 없다’는 이유로 원고들의 구제신청을 인용

[중노위] 2차 전보는 부당하지만, 1차 전보는 업무상 필요성이 인정될 뿐 아니라 그 대기발령 기간 또한 적정하므로 정당하다’는 이유로 위 초심판정 중 1차 전보에 관한 부분을 취소하고, 원고들의 초심 구제신청 중 1차 전보에 관한 부분과 참가인 회사의 나머지 재심신청을 기각

[1심 법원] 1차 전보는 성실한 협의 절차를 위반하여 위법하고, 2차 전보도 업무상 필요성은 인정되지만, 당사자에게 미치는 생활상 불이익이 크고 성실한 협의도 진행하지 않았다는 점 등을 이유로 부당하다고판다하여, 원고의 청구를 인용하고 재심판정을 취소
[2심 법원] 중노위 항소 취하

판결 요지

대기발령이나 전보처분이 정당한 인사권의 범위 내에 속하는지 여부는 ① 해당 인사명령의 업무상의 필요성과 ② 그에 따른 근로자의 생활상의 불이익과의 비교교량, ③ 근로자와의 협의 등 인사명령을 하는 과정에서 신의칙상 요구되는 절차를 거쳤는지의 여부 등에 의하여 결정되어야 하며, 근로자 본인과 성실한 협의절차를 거쳤는지의 여부는 정당한 인사권의 행사인지의 여부를 판단하는 하나의 요소라고는 할 수 있으나 그러한 절차를 거치지 아니하였다는 사정만으로 인사명령이 권리남용에 해당되어 당연히 무효가 된다고는 볼 수 없다(대법원 2000. 4. 11. 선고 99두2963 판결, 2005. 2. 18. 선고 2003다63029 판결 등 참조)

그리고 사용자가 전직처분 등을 할 때 요구되는 업무상의 필요란 인원 배치를 변경할 필요성이 있고 그 변경에 어떠한 근로자를 포함시키는 것이 적절할 것인가 하는 인원선택의 합리성을 의미하는데, 여기에는 업무능률의 증진, 직장질서의 유지나 회복, 근로자 간의 인화 등의 사정도 포함된다(대법원 2018. 10. 25. 선고 2016두44162 판결 등 참조).

위에서 살핀 바와 같이 1차 전보는 2차 전보를 목적으로 하는 대기발령 조치이므로, 2차 전보가 부당전보에 해당한다면 그에 앞서 1차 전보를 실시하여야 할 정당한 업무상 필요가 있다고 할 수 없다. 그런데 2차 전보는 정당한 인사권의 범위를 벗어난 부당전보에 해당한다 할 것이므로, 결국 1차 전보는 업무상의 필요성이 없어 위법하다.

(1) 참가인 회사의 생산공장은 상시적인 인력 부족에 시달리고 있었던 것으로 보이는 만큼, 이에 대응하여 참가인 회사가 생산직 인력을 증원할 필요가 있었던 점은 수긍할 수 있다. 그런데 원고들은 참가인 회사에 입사한 이래로 약 30년 동안 관리직으로만 근무하여 1차 전보 무렵에는 만 50세가 넘었는바, 이들이 생산직 업무를 효율적으로 수행할 수 있을 정도의 육체노동능력을 갖추었다고 볼만한 근거가 없다. 설령 원고들이 다른 관리직 직원들에 비하여 인사고과가 저조하였다고 하더라도, 이러한 사정만으로 원고들이 관리직보다 생산직에 더욱 적합한 사람들이었다거나, 이들을 생산직에 투입함으로써 업무능률이 한층 증진된다고는 보기 어렵다. 그러므로 2차 전보의 업무상 필요는 상대적으로 크다고 보이지 않는다.

(2) 반면 2차 전보로 인하여 ① 원고들은 수십 년간 지속하여 온 업무에서 강제로 이탈된 데에 따른 심리적인 박탈감이 클 것으로 보이는 점, ② 더구나 원고들은 기존의 관리직 업무와는 별다른 연관성이 없는 생산직 업무를 맡게 됨에 따라, 기존의 업무에서 쌓은 경험과 노하우 등을 활용할 기회조차 상실한 점, ③ 생산공장이 원고들의 생활근거지와 멀리 떨어져 있는 탓에 출퇴근에 소요되는 시간과 교통비까지 모두 증가된 점, ④ 원고들이 출퇴근 시간과 교통비를 절약하려면 가족들과 떨어져 사택에서 생활할 수밖에 없게 된 점 등을 감안하면, 2차 전보에 따른 원고들의 생활상 불이익은 상당히 크다고 보인다.

(3) 한편 참가인 회사는 2차 전보에 앞서 원고들과 면담을 하는 과정에서, 원고들에게 ‘생산공장 이동’ 또는 ‘퇴직’ 중 하나를 선택하도록 요구하였을 뿐, 생산공장 외의 다른 보직으로 이동하는 방안은 언급한 바 없고, 부득이하게 원고들이 생산공장으로 전보될 경우에 구체적으로 어느 위치의 공장에서 어떤 조건으로 근무하게 될 것인지 여부에 관하여도 별다른 논의가 없었다고 보인다. 따라서 참가인 회사가 2차 전보에 관하여 원고들과 사이에 협의절차를 성실하게 이행하였다고 볼 수 없다.

참가인 회사는 원고들에게 아무런 사전 예고 없이 1차 전보를 하였다고 보이므로, 1차 전보에

부록.1. 주요 사건 경과 및 패소 원인 분석

앞서 신의칙상 요구되는 성실한 협의절차를 거쳤다고 볼 수도 없다. 이 점에서도 1차 전보는 위법하다. 그렇다면 1차 전보는 구제의 대상이 되는 부당전보에 해당하므로, 이와 결론을 달리한 이 사건 재심판정은 위법하여 취소되어야 한다

패소 이유 (동일한 사실관계에 관하여 기존 대법원 판례 법리와 다른 결론)

전보발령 내지 배치전환에 있어서 그 정당성 인정 요건으로 대법원이 확립하여 온 법리는 근로기준법 제23조 제1항의 ‘정당한 이유’를 요구하는 것으로서, 그 정당한 이유를 판단함에 있어서 ① 업무상의 필요성이 있을 것, ② 생활상 불이익이 크지 않을 것, ③ 성실한 협의를 거쳤을 것 등을 요구한다. 대상 사건에서 1차 전보와 2차 전보의 과정과 내용에 이 요건을 적용하면 대상 전보발령처분 등의 정당성을 판단할 수 있는데도 불구하고 초심 지노위 판정과 재심 중노위 판정은 다른 결론에 이르고 있다.

이는 기본적인 대법원 판례 법리의 적용에 문제가 있다는 것을 나타내며, 공익위원의 전문성을 제고하여 판례 법리에 따라 정당한 결론을 내릴 수 있도록 하여야 할 것이다. 그러한 관점에서 노동위원회가 1심 법원 패소 이후 항소 취하를 결정한 것은 합리적인 결정이었다고 평가할 수 있다.

일련번호	2022-17					
판결번호	대전고등법원 2022. 2. 10. 선고 2021누00000					
중노위판정번호	중노위 2019. 12. 10. 중앙2019부해1256					
사건 종류	징계해고					
세부 쟁점	징계의 정당성 - 절차					
심급별 소송결과	1심 법원	재심판정취소	2심 법원	1심판결 유지	대법원	-
원고, 피항소인	전○○		피고보조참가인, 항소인		○○신용협동조합	
피고, 항소인	중앙노동위원회위원장		피고측 대리인 선임 여부		선임 안 함	
노동조합 지원 여부	없음		원고측 대리인 선임 여부		선임	
재심 결과	초심 유지					
초심의 대법원 판례 일치여부	불일치		재심의 대법원 판례 일치여부		불일치	
기타 특이사항						

주요 사실관계

<사실관계>

가. ○○신용협동조합(이하 '이 사건 회사')은 1996. 1. 17. 설립되어 18 명의 상시근 로자를 사용하여 신용사업 , 복지사업 , 조합원을 위한 공제사업 등을 하는 법인이다. 전○○(이하 '이 사건 근로자')는 1996. 4. 27. 이 사건 회사와 근로계약을 체결하고 2017. 10. 경부터 상무로 근무해 온 사람이다.

나. 이 사건 회사의 이사회는 2019. 5. 30. 차 임시이사회에서 조합 기밀보존의무 위반 등과 같은 징계사유를 이유로 이 사건 근로자에 대한 징계면직을 의결하였고(이하 '이 사건 해고 라 한다') , 이 사건 회사는 2019. 5. 31. 이 사건 근로자에게 위 징계처분을 통지 하였다.

다. 이 사건 근로자는 2019. 6. 28. 경북지노위에 이 사건 해고가 부당하다며 부당해고 구제신청을 하였다(경북2019부해 396).

<심급별 결과>

[경북지노위] 2019. 8. 22. '징계절차상의 하자는 없고 3 징계사유를 제외한 나머지 징계사유들이 모두 인정되며 , 인정된 징계사유만으로도 징계양정이 적정해 보이므로 원고에 대한 해고처분은 정당하다'는 이유 로 원고의 구제신청을 기각. 이 사건 근로자가 이에 불복하여 재심 신청 [중노위] 2019. 12. 10. 위 초심판정과 같은 이유를 들어 이 사건 근로자의 재심신청 기각

[1심 법원] 이 사건 해고는 징계의결 과정에 중대한 절차상 하자가 존재하고, 징계사유 중 일부를 제외한 나머지 징계사유가 모두 정당한 징계사유로 인정되지 않으며, 그 징계양정도 지나치게 과중하므로 부당해고라고 판시

[2심 법원] 1심 판결과 같은 결론을 내렸고 이대로 확정

판결 요지

가. 절차적 위법 여부

단체협약에 조합원을 징계하고자 할 때에는 5일 전에 해당 조합원에게 서면으로 통보하여야 한다고 규정한 경우 , 그 서면이 5일 전에 해당 조합원에게 도달되어야 함을 의미하는 것으로 보는 것이 당연하다. 그러므로 징계를 받을 조합원에게 일의 여유를 두지 아니하고 징계에 회부된 사실이 통보되었을 경우 해당 조합원이 이에 대하여 이의 를 제기하지 않고 소명을 하고 이를 문제삼지 아니한 경우라면 몰라도 , 그렇지 아니하고 일의 여유를 두지 아니하고 통보되었다고 이의를 제기한 경우 이를 묵살하고 징계를 강행하는 것은 위의 단체협약에 위배되는 것으로서 그 절차가 위법하다고 보아야 한다(대법원 1991. 11. 26. 선고 91 22070 판결 등 참조).

단체협약 , 취업규칙 또는 징계규정에서 징계대상자에게 징계위원회에 출석하여 변명과 소명자료를 제출할 수 있는 기회를 부여한 경우 그 통보의 시기와 방법에 관하여 특별히 규정한 바가 없다고 하여도 변명과 소명자료를 준비할 만한 상당한 기간을 두고 개최일시와 장소를 통보하여야 하며 , 이러한 변명과 소명자료를 준비할 만한 시간적 여유를 주지 않고 촉박하게 이루어진 통보는 실질적으로 변명과 소명자료 제출의 기회를 박탈하는 것과 다를 바 없어 부적법하다고 보아야 한다. 설사 징계대상자가 그 징계위원회에 출석하여 진술을 하였다 하여도 스스로 징계에 순응하는 것이 아닌 한 그 징계위원회의 의결에 터잡은 징계해고는 징계절차에 위배한 부적법한 징계권의 행사라 할 것이다(대법원 2004. 6. 25. 선고 2003 15317 판결 등 참조).

이 사건 회사의 취업규칙 93조 항에는 '징계대상자에게 회의 개최 일 전까지 출석요구서를 통보하여야 한다'라고 규정되어 있고 , 신용협동조합 검사 및 제재에 관한 규정 시행규칙 42조의 2 항에도 '위원회 개최 전에 10 일 이상의 기간을 정하여 제재대상자에게 서면에 의한 의견진술 기회를 주어야 한다'고 규정되어 있다. 그리고 이는 이사회 개최 일 전과 10일 전까 지 그러한 내용이 기재된 서면이 원고에게 도달하여야 함을 의미한다.

부록.1. 주요 사건 경과 및 패소 원인 분석

그럼에도 불구하고 이 사건 근로자는 징계의결 과정에서 실질적인 소명기회를 보장받지 못했고 그러한 절차하자가 치유되었다고 하기도 어려워보이므로, 이 사건 근로자에 대한 징계의결에는 징계절차상 중대한 하자가 존재한다고 판단된다.

나. 징계사유의 인정 여부

사실관계를 근거로 판단하였을 때 이 사건 회사가 주장하는 징계사유 중 일부는 인정되나 일부는 인정되지 않는다.

다. 징계양정의 적정 여부

이 사건 근로자가 이사회 결의 없이 부당하게 전체 직원의 연봉을 인상하는 조정안을 작성하여 시행한 것은 사실이나 이는 이사장의 최종 결재를 받았던 점 등 이 사건 근로자의 경위에 어느 정도 참작할 여지가 있다는 점 등 사정들을 종합할 때, 위 징계사유들만으로는 사회통념상 고용 관계를 계속할 수 없을 정도로 이 사건 근로자에게 책임있는 사유가 있다고 하기 어려우므로 이 사건 해고는 재량권을 일탈·남용한 것으로서 위법하다.

패소 이유 (사실관계의 인정과 판례의 적용)

이 사건에서 노동위원회는 징계절차의 하자를 판단할 때 “근로자가 징계위원회에 출석하여 그 징계사유에 대한 소명을 하였으므로 사용자의 징계처분이 절차상 부당하다고 볼 수 없다.”라고 판단하며, 서울행정법원 2013. 4. 18. 선고 2012구합24931 판결을 근거로 들었는 이 사건에서 법원은 “징계대상자가 그 징계위원회에 출석하여 진술을 하였다 하여도 스스로 징계에 순응하는 것이 아닌 한 그 징계위원회의 의결에 터잡은 징계해고는 징계절차에 위배한 부적법한 징계권의 행사라 할 것이다(대법원 2004. 6. 25. 선고 2003 15317 판결 등 참조).” 판결을 근거로 동일한 사안에 대해 징계절차가 하자가 있다고 판시하였다.

즉, 노동위원회는 구체적인 사실을 파악하고 그러한 사실관계에 맞는 판례를 적용함에 있어서 정교함이 떨어졌고 기타 징계양정에 관한 재량 인정여지까지 더해져 법원과 판단이 달라지게 되었다고 판단된다.

일련번호	2022-18					
판결번호	서울행정법원 2021. 10. 21. 선고 2021구합00000					
중노위판정번호	중노위 2020. 12. 15. 중양2020부해1481					
사건 종류	부당해고					
세부 쟁점	해고, 해고 사유, 해고 시기, 업무상 재해					
심급별 소송결과	1심 법원	재심판정취소	2심 법원	항소취하	대법원	
원 고	박○○		참 가 인		○○농업협동조합	

피 고	중앙노동위원회위원장	피고측 대리인 선임 여부	선임 안 함
노동조합 지원 여부	없음	원고측 대리인 선임 여부	선임 함
재심 결과	초심 유지		
초심의 대법원 판례 일치여부	불일치	재심의 대법원 판례 일치여부	불일치
기타 특이사항			

주요 사실관계

<사건 개요>

가. 피고보조참가인(이하 ‘참가인’이라 한다)은 하나로마트 ○○농협이며, 원고는 2010. 4. 1. 참가인에게 입사한 이후 하나로마트 ○○농협 본점에서 수산물코너의 운영 및 순회판매 업무를 하다가 2020. 4. 13. 하나로마트 ○○농협 ○○지점으로 전보되었다.

나. 원고는 2020. 3. 2. 참가인의 사업장에서 상추를 진열하기 위하여 냉동고에서 상추박스를 들고 나오다 왼쪽 발을 빠긋하면서 주저 앉았다. 원고는 같은 날 보건소에 방문하였고, 다음날인 2020. 3. 3. 병원에 방문하여 엑스레이를 찍고 왼쪽 발에 반깁스 형태의 보형장치를 착용하였다. 이후 원고는 위와 같은 보형장치를 착용한 상태에서 근무하였는데, ○○농협 ○○지점 전보일인 2020. 4. 13. 참가인에게 참가인의 복무규정에 따른 심신단련을 이유로 한 휴가신청을 하였고, 참가인은 2020. 4. 14.부터 2020. 5. 4.까지 12일간의 휴가를 승인하였다. 원고는 2020. 4. 20. 병원에 입원하여 MRI 촬영을 한 결과 왼쪽 발목의 인대 파열이 확인되었고 2020. 4. 22. 퇴원하였다. 원고는 2020. 4. 27.부터 2020. 5. 26.까지 입원하여 2020. 4. 28. 좌측 족관절 외측 다발성 인대 파열 등의 상병에 대하여 수술(변형된 Brostrom 인대봉합술)을 받았다.

다. 참가인은 2020. 5. 19. 원고에게 ‘2020. 5. 6.부터 2020. 5. 19.까지 10일간 무단결근하였으므로 인사규정에 따라 2020. 6. 25.자로 면직됨을 알린다’고 통보하였고, 원고는 2020. 5. 21. 이를 수령하였다. 이후 원고는 2020. 8. 19.부터 2020. 8. 25.까지 위와 같은 상병으로 다시 입원하였다.

라. 원고는 2020. 8. 26. 근로복지공단에 업무상 재해 인정 및 요양급여를 신청하였고, 근로복지공단은 원고의 위 2020. 3. 2.자 재해를 승인하여 2020. 11. 10. 참가인에게 통지하였다.

마. 원고는 참가인으로부터 부당해고를 당했다면서 전남지방노동위원회에 구제를 신청하였다.

<심급별 결과>

[전남지노위] ‘원고가 2020. 5. 6.부터 2020. 5. 19.까지 무단결근을 한 사실이 인정되고, 이 사건 해고는 휴업기간 중의 해고라고 볼 수 없으므로 정당한 사유가 인정되며, 그 절차도 정당하다’는 이유로 원고의 구제신청을 기각

[중노위] 초심판정과 같은 취지로 원고의 재심신청을 기각

[1심 법원] 업무상 재해로 인한 요양기간에는 해고를 할 수 없으며, 당연면직도 해고에 해당한다고 보아 재심판정 취소

[2심 법원] 중앙노동위원회 항소취하

판결 요지

피고나 참가인이 제출한 증거만으로는 원고가 무단결근하였음을 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다. 따라서 이 사건 해고에 관한 면직사유가 인정되지 아니한다.

① 원고가 당시 참가인에게 병가가 아닌 심신단련 휴가를 신청하기는 하였으나, 원고의 상해 사실은 참가인의 다른 직원들에 의하여 목격되었고, 이로 인한 원고의 입원 내지 수술 무렵 직원들이 원고를 병문안 하였으며, 원고의 상해로 인한 불출근 기간도 1달여나 되었으므로, 원고가 상해로 인하여 출근할 수 없다는 사실은 참가인 내에서 널리 인식되었던 것으로 보인다. ② 참가인은, ○○지점 지점장이 원고에게 전화로 연락하여 ‘현재 무단결근으로 처리되고 있으니, 진단서 등을 첨부하여 추가 휴가를 신청하라’고 권유했다고 주장하나, 이를 뒷받침할 만한 자료는 없다. ③ 원고의 상병을 업무상 재해로 인정한 근로복지공단의 결정에 잘못이 있음을 인정할 자료가 없는바, 이 사건 해고에서 무단결근 기간으로 본 2020. 5. 6.부터 2020. 5. 19.까지 원고는 업무상 재해로 인한 입원 중이어서 출근할 수 없었고, 원고가 위 기간을 포함하여 상당 기간 불출근할 당시 참가인으로부터 출근 독촉 내지 병가 신청의 요청 등이 있었다고 보기 어려우므로, 원고가 위 기간에 무단결근하였다고 단정하기 어렵다.

사용자가 어떤 사유의 발생을 당연퇴직사유로 규정하고 그 절차를 통상의 해고나 징계해고와 달리 한 경우에 그 당연퇴직사유가 근로자의 사망이나 정년, 근로계약기간의 만료 등 근로관계의 자동소멸사유로 보여지는 경우를 제외하고는 이에 따른 당연퇴직처분은 근로기준법 제23조가 정한 제한을 받는 해고에 해당한다(대법원 1995. 3. 24. 선고 94다42082 판결 참조). 따라서 설령 이 사건 해고가 당연면직사유에 기한 것이라고 하더라도 근로기준법 제23조 제2항의 적용 대상이 된다.

근로기준법 제23조 제2항은, 사용자는 근로자가 업무상 부상 또는 질병의 요양을 위하여 휴업한 기간과 그 후 30일 동안은 해고하지 못한다고 규정하여 해고를 제한하고 있다. 이는 근로자가 업무상의 재해로 인하여 노동력을 상실하고 있는 기간과 노동력을 회복하는 데 필요한 그 후의 30일간은 근로자를 실직의 위협으로부터 절대적으로 보호하기 위한 것이다.

이와 같은 규정의 내용과 입법 목적에 비추어 보면, 요양을 위하여 필요한 휴업에는 정상적인 노동력을 상실하여 출근을 전혀 할 수 없는 경우뿐만 아니라, 노동력을 일부 상실하여 정상적인 노동력으로 근로를 제공하기 곤란한 상태에서 치료 등 요양을 계속하면서 부분적으로 근로를 제공하는 부분휴업도 포함된다. 이 경우 요양을 위하여 휴업이 필요한지는 업무상 부상 등의 정도, 치료 과정 및 치료 방법, 업무의 내용과 강도, 근로자의 용태 등 객관적인 사정을 종합하여 판단하여야 한다(대법원 2021. 4. 29. 선고 2018두43958 판결 등 참조).

원고는 이 사건 해고 당시 업무상 재해로 인한 휴업기간 중에 있었으므로, 이 사건 해고는 근로기준법 제23조 제2항을 위반하였다고 봄이 타당하다.

패소 이유 (새로운 증거의 제출로 인해 판단이 달라진 경우)

이 사건은 전형적으로, 당사자가 노동위원회 심판 기간에 제시하지 않았던 새로운 사실관계를 제시하여 판단이 전혀 달라진 경우에 해당함. 당사자의 이와 같은 행위는 현재로서는 회피하기 어려운 패소사유이다. 이는 노동위원회의 초심 또는 재심 판정 단계에서 사건조사가 잘못된 것과는 전혀 다른 경우이기 때문이다. 당사자가 노동위원회 심판 단계에서 제출하지 않았던 새로운 증거를 제출하거나, 주장하지 않았던 새로운 사실관계를 주장하면서 행정심판의 위법·부당을 다투는 것은 현재로서는 금지되는 것은 아니지만, 타당하지 않다. 따라서, 행정심판에 대한 취소소송에서 새로운 증거 제출이나 새로운 사실관계의 주장을 허용하지 않아야 한다는 주장도 제기되고 있다. 조사관의 실질적 조사권을 더욱 강화하고 당사자가 모든 사항을 되도록 빠짐없이 주장할 수 있도록 노력하는 외에는 현재로서는 방법이 없다고 할 수 있다.

노동위원회가 항소 취하를 선택한 것도, 새로운 사실관계와 증거가 제출되었기 때문에 2심 소송에 승산이 없다고 판단했기 때문이라 짐작된다. 불가피한 선택이라고 볼 수 있다.

일련번호	2022-31					
판결번호	대법원 2022. 3. 11. 선고 2021두00000					
중노위판정번호	중노위 2018. 12. 10. 중앙2018부해1042					
사건 종류	기간제					
세부 쟁점	갱신거절의 합리적인 이유					
심급별 소송결과	1심 법원	재심취소	2심 법원	1심유지	대법원	원심유지
원고, 피상고인	재단법인 ○○연구원		피고보조참가인, 상고인		정○○	
피고, 상고인	중앙노동위원회위원장		피고측 대리인 선임 여부		선인 안 함	
노동조합 지원 여부	없음		원고측 대리인 선임 여부		선임	
재심 결과	초심 유지					
초심의 대법원 판례 일치여부	불일치		재심의 대법원 판례 일치여부		불일치	
기타 특이사항						

주요 사실관계 <사실관계> 가. 재단법인 ○○연구원(이하 ‘이 사건 사용자’)는 ○○광역시 시정에 관한 각종 과제의 연구·조사·분석과 지역 현안에 관한 정책의 개발 및 수립 등을 목적으로 하는 지방자치단체출연 연구원이다. 정○○(이하 ‘이 사건 근로자’)는 2014. 9. 11. 입사하여 연구위원으로 근무하여 온 사람이다. 나. 이 사건 사용자와 근로자는 2014. 9. 11. 임용기간을 2014. 9. 11. ~ 2016. 1. 24.로 정하여 임용계약을 체결하였고, 2016. 1. 25. 임용기간을 2016. 1. 25. ~ 2017. 1. 24.로 정하여 임용계약을 체결하였으며, 2017. 3. 2. 임용기간을 2017. 1. 25. ~ 2018. 1. 24.로 정하여 임용계약을 체결하였다. 다. 이 사건 사용자는 2018. 1. 23. 이 사건 근로자에게, 2018. 1. 19.자 제1차 인사위원회의 심사결과에 따라 재계약을 체결하지 않기로 결정하였다고 통보하였다(이하 ‘이 사건 재임용 거부’라 한다). 이에 대하여 이 사건 근로자는 재심청구를 하였으나, 이 사건 사용자는 2018. 2. 12.자 제2차 인사위원회의 심사를 거쳐 2018. 2. 19. 재심청구 기각 결정을 통보하였다. 라. 이 사건 근로자는 이 사건 재임용 거부가 부당해고에 해당한다고 주장하며 인천지노위에 구제를 신청하였다. <심급별 결과>

[인천지노위] 2018. 8. 10. ‘이 사건 사용자와 근로자는 기간의 정함이 없는 근로계약을 체결하였고, 일방적인 이 사건 재임용 거부는 해고에 해당하며, 정당한 해고사유가 인정되지 않는다.’라는 이유로 이 사건 근로자의 구제신청을 인용. 마. 이 사건 사용자는 이에 불복하여 재심 신청
[중노위] 2018. 12. 10. ‘이 사건 사용자와 근로자는 기간제 근로계약을 체결하였고 이 사건 근로자에게는 근로계약 갱신기대권이 인정되며, 이 사건 근로자에 대한 갱신거절에 합리적 이유가 없다.’라는 이유로 이 사건 사용자의 재심신청을 기각(중양2018부해1042).

[1심 법원] 이 사건 사용자의 정규직 전환 거절은 합리적인 이유가 있으므로 이 사건 재심판정이 위법하다고 판시

[2심 법원] 1심판결과 같이 판시

[대법원] 원심판결 그대로 인정

판결 요지

1. 기간의 정함이 있는 근로자인지 여부

이 사건 사용자와 근로자가 체결한 각 임용계약서에는 임용기간을 명시하고 있고, 매년 인사위원회의 재임용 심의를 거쳐 재임용 계약을 체결하여 왔다는 점에서 이 사건 근로자는 기간의 정함이 있는 근로자에 해당한다.

2. 갱신 기대권이 있는지 여부

① 이 사건 사용자의 인사관리 규정에 따른 직원의 재임용에 관한 세부사항을 규정하기 위해 직원재임용규칙이 마련되어 있는 점, ② 근무성적평정 결과에 따른 재임용 요건을 구체적으로 정하고 있는 점, ③ 이 사건 사용자의 인사위원회에서는 매년 재임용 심의를 실시하면서, 직원재임용규칙에서 정한 재임용 기준을 충족한 대상 직원들에 대하여는 모두 재계약을 체결하기로 하는 결정을 해왔다는 점을 고려하면 이 사건 근로자에게 임용계약의 갱신기대권이 인정된다.

3. 재임용 거부의 합리적 이유 인정 여부

① 이 사건 사용자는 이 사건 근로자에게 성과를 향상하고 부족한 부분을 개선할 기회를 여러 차례 준 후에 부득이 하게 재임용 거부를 하였다고 보여지는 점, ② 이 사건 사용자의 이 사건 근로자의 업무능력에 관한 평가결과가 객관적이고 공정한 평가 평가라고 볼 수 있는 점, ③ 이 사건 사용자는 연구직과 관리직을 포함한 전체직원을 대상으로 매년 근무성적평정과 재임용심사를 실시하여 왔고, 재계약 불가 결정을 한 사례가 존재한다는 점 등을 고려하면 이 사건 재임용 거부의 사유와 절차가 객관적이고 합리적이며 공정하다고 볼 수 있으므로 이 사건 재임용 거부에 합리적 이유가 인정된다.

패소 이유 (사실관계에 관한 인정)

이 사건은 계약갱신 거절의 합리적 이유가 주된 쟁점이고, 구체적인 사실관계를 어떤 관점에서 바라보느냐, 혹은 어떻게 분석하느냐에 따라서 결론이 달라진 것으로 보이며, ‘합리적인 이유’라는 기준 자체를 정형화, 도식화 할 수 없는 한계 때문에 노동위원회와 법원의 판단이 달라진 사건으로 판단된다.

특히 법원은 재판 절차를 통하여 증인들의 실제 증언을 들을 수 있고, 반대되는 신문을 하며 사실관계를 파악하고 심증을 형성하는 등 노동위원회 판정 보다 폭 넓고 조금더 구체화된 사실관계를 파악할 수 있는 기회가 있는데 절차의 이러한 사실상의 한계 때문에 결론이 달라진 사례라고 생각된다.

일련번호	2022-34					
판결번호	대법원 2022. 4. 14. 선고 2022두00000					
중노위판정번호	중노위 2019. 8. 1. 중앙2019부해552					
사건 종류	당사자적격					
세부 쟁점	휴대전화 단말기 배송자 근로자성					
심급별 소송결과	1심 법원	재심취소	2심 법원	원심유지	대법원	원심유지
원고, 피상고인	최○○		피고보조참가인, 상고인		○○○○○○ 주식회사	
피고	중앙노동위원회위원장		피고측 대리인 선임 여부		선임안함	
노동조합 지원 여부	없음		원고측 대리인 선임 여부		선임	
재심 결과	초심취소					
초심의 대법원 판례 일치여부	일치		재심의 대법원 판례 일치여부		불일치	
기타 특이사항						

주요 사실관계
<사실관계> 가. ○○○○○○ 주식회사(이하 ‘이 사건 회사’)은 1988. 8. 1. 설립되어 공중전화 사업, 물류 운송업, 통신 단말기 유통업 등을 영위하는 회사이다. 이 사건 회사는 2013. 1.경부터 주식회사 ○○로부터 휴대전화 단말기 수배송 업무 등 물류용역업무를 위탁받았고, 전국에 6개의 물류센터를 두고 권역별로 이른바 ‘모바일서포터’라고 불리는 수탁사업자들과 물류용역계약을 체결하여 휴대전화 단말기 수배송 업무를 수행하도록 하고 있다. 나. 주식회사 ○○○은 2012. 12.경까지 ○○로부터 휴대전화 단말기 수배송 업무를 위탁받아 수행하였고, 최○○은 2010. 11.경 주식회사 모비션과 물류용역계약을 체결하고 휴대전화 단말기 수배송 업무를 수행하였다. 다. 주식회사 ○○○은 2013. 1. 1.부터는 이 사건 회사로부터 휴대전화 단말기 수배송 업무를 위탁받아 수행하였다. 이에 따라 최○○은 2013. 1.경 이 사건 회사와 물류용역계약을 체결하고 모바일서포터로서 A/S 수배송, 방문서비스, 중고 휴대전화 단말기 수배송, 기타 물품 수배송 등의 업무를 계속 수행하였다. 라. 이 사건 회사는 2019. 1. 31. 최○○에게 ‘최○○은 2019년 물류용역 계약대상자로 선정되지 아니하였으므로 계약을 해지한다.’라고 통지하였다(이하 ‘이 사건 통지’라 한다). 마. 최○○은 2019. 2. 7. 경기지노위에 경기2019부해273호로 이 사건 통지가 부당해고라고 주장하며 구제를 신청하였다.

<심급별 결과>

[경기지노위] 최○○이 기간의 정함이 없는 근로자에 해당함에도 계약기간 만료라는 이유로 근로 관계가 종료하였다고 통보한 이 사건 통지는 부당해고라고 판정. 이 사건 회사는 이에 불복하여 재심 신청

[중노위] 초심판정 취소

1심 법원] 최○○은 임금을 목적으로 이 사건 회사와 사용종속관계에서 노무를 제공하는 근로기 준법상 근로자에 해당하고, 이 사건 회사를 위하여 2년을 초과하여 계속 일하였으므로 최○○과 이 사건 회사 사이의 근로계약은 기간의 정함이 없는 것으로 의제된다. 그럼에도 계약기간이 만료되었음을 이유로 이루어진 이 사건 통지는 부당해고에 대항한다며 재심판정을 취소

[2심 법원] 최○○의 근로자성을 인정하였고, 대법원에서 확정

판결 요지

가. 최○○이 근로기준법상 근로자에 해당하는지 여부

1) 이 사건 회사의 사업목적과 서포터 업무의 관계

이 사건 회사는 모회사인 ○○로부터 휴대전화 단말기 수배송 등 물류용역업무를 위탁받아 이 를 주요 사업분야로 하고 있다. 서포터는 이 사건 회사의 물류용역 업무(A/S 수배송, 방문서비 스, 그린폰 수배송, 기타물품 수배송 등)를 수행하는 데 상시적으로 필요한 인력이다.

2) 업무수행상 지휘·감독

① 최○○이 PDA를 통하여 ○○전산시스템에서 A/S 수배송 건이나 방문서비스 건 등을 자동 으로 배정받았는데, 이 사건 회사는 ○○와의 약정 및 ○○의 과업내역서에 따라 ○○전산시스템을 이용하여 최○○에게 업무를 자동 배정한 것이고, 배정내역을 확인하기 위한 PDA를 최○○에게 교부하였으며, 방문서비스 건의 경우 엔젤센터를 통하여 최○○에게 수시로 PDA를 확인하도록 휴대전화 문자메시지를 보내는 등 이 사건 회사는 최○○에게 업무수행내역을 보고하도록 하였 고, 공지사항을 전달하거나 성과 달성을 독려하는 등의 방법으로 구체적인 업무 처리 방식이나 내용에 관하여 상당한 지휘·감독을 하였다고 볼 수 있다.

또한 ② 최○○은 이 사건 계약 및 용역비 정산 기준에 따라 업무수행 결과를 평가받고, 그에 따라 성과급의 성질이 있는 평가용역비를 지급받았으며 이 사건 회사는 최○○의 업무 내용을 직접 정하고 평가를 하는 방법을 통하여 원고의 업무수행과정에 대하여 상당한 지휘·감독을 하였다고 볼 수 있다.

③ 이 사건 회사는 최○○에게 일정한 복장을 갖추어 것을 요구하고, 그 이행 여부를 확인하고, 서 비스 품질을 관리하도록 하기 위한 교육을 실시하였으며 이를 따르지 않는 경우 일정한 불이익 이 가해질 수 있음을 고지하기도 하였다.

④ 이 사건 계약은 최○○에게 일정한 의무를 부과하고, 최○○이 본 계약 조항을 위배하였을 경우나 정당한 업무상 요청에 불응하는 경우 이 사건 회사가 계약을 해지할 수 있도록 정하고 있으므로 이 사건 회사는 최○○에게 상당한 지휘·감독을 할 수 있는 권한이 있었다고 봄이 타 당하다.

3) 근무시간과 장소

최○○은 일정한 사업장에 출퇴근한 것은 아니고 근무시간이나 근무장소에 대한 구속이 엄격 하지 않으나, 수행하는 업무내용 및 특성상 어느 정도 정형화된 근무시간과 근무장소가 정해진 채로 업무를 수행한 것으로 평가할 수 있다.

4) 작업도구·수단의 제공

최○○은 이 사건 회사로부터 업무 수행에 필요한 작업 도구를 제공받았다. 이 사건 회사는 최○○에게 업무에 필요한 PDA 단말기를 제공하고, 에어캡, 박스, OO 로고가 새겨진 테이프, 커터 칼 등 비품을 무상으로 제공하였다.

5) 업무대행의 자율성 유무

최○○은 임의로 제3자로 하여금 업무를 대행하게 하거나 하도급을 줄 수 없었고 실제 제3자에게 자신의 업무를 대행하게 한 경우는 없었던 것으로 보인다.

6) 용역비의 성질

이 사건 회사가 최○○에게 지급하는 용역비에는 업무수행 실적과 무관하게 매월 고정적으로 지급되는 기본용역비가 포함되어 있는데, 업무 처리 건수가 상이하더라도 기본용역비의 액수는 동일하고, 그 금액이 전체 용역비 총액에서 가장 큰 비중을 차지한다. 이는 최○○이 제공한 노무 자체의 대가로서 지급되는 임금의 성질을 가진 것으로 봄이 타당하다.

7) 독자적인 이윤창출이나 손실 등 위험 부담 여부

최○○은 PDA 등으로 배정된 업무만을 수행하였을 뿐이고, 이와 별도로 이 사건 회사를 통하지 않고 독자적으로 고객과 접촉하여 A/S 수배송, 방문서비스 등 영업을 수행할 수 없었다.

8) 전속성

최○○은 이 사건 회사와 최초로 계약을 체결한 2013. 1. 1. 이래 매년 계약을 갱신하면서 약 6년여의 상당한 기간 동안 계속하여 근무하였고, 최○○이 다른 업무에 종사한 것으로 보이는 사정도 없어 상당한 정도의 전속성을 가지고 이 사건 회사에게 근로를 제공한 것으로 보인다.

9) 기타 사정

이 사건 회사가 정한 취업규칙이나 복무규칙은 최○○을 비롯한 서포터들에게 적용되지 않고, 최○○은 개인사업자로 등록하여 정기적으로 사업소득세와 부가가치세를 납부하며, 근로소득세 원천징수도 이루어지지 않고 있다. 그러나 이는 모두 사용자인 이 사건 회사가 경제적으로 우월한 지위를 이용하여 임의로 정할 수 있는 사항들이므로, 이를 들어 최○○의 근로기준법상 근로자성을 부정할 수는 없다.

나. 이 사건 통보가 부당해고에 해당하는지

최○○은 임금을 목적으로 이 사건 회사와 사용종속관계에서 노무를 제공하는 근로기준법상 근로자에 해당하고, 이 사건 회사를 위하여 근로를 시작한 때로부터 2년이 넘은 2015. 1. 1.부터 이 사건 회사와 기간의 정함이 없는 근로계약을 체결한 것으로 의제된다(기간제 및 단시간근로자 보호 등에 관한 법률 제4조 제2항).

그럼에도 이 사건 회사는 2019. 1. 23. 최○○에게 ‘최○○은 2019년 물류용역 계약대상자로 선정되지 않았으므로, 계약해지를 통보한다’는 내용의 이 사건 통보를 하기에 이르렀다. 이 사건 통보는 최○○의 의사에 반하여 근로계약을 종료하는 이 사건 회사의 일방적 의사표시로서 해고에 해당하고, 최○○에게 이 사건 회사와 고용관계를 계속할 수 없을 정도로 책임 있는 사유가 있다는 데 대하여 아무런 주장과 증거가 없으므로, 이 사건 해고는 부당해고에 해당한다.

패소 이유 (사실관계에 관한 인정 차이)

이 사건의 주된 쟁점은 근로계약을 체결하지 아니하고 개인사업자로 등록하여 업무를 한 자의 근로자성이고, 근로기준법상 근로자 판단에 대한 이미 많은 판례군이 존재하여 연구가 많이 이루어져있는 사안이다. 다만, 근로계약을 체결하지 않은 자의 경우 그 계약의 내용 및 실제 업무가 이루어진 행태 등에 따라 구체적인 사실관계 판단이 달라지는 경우가 많다.

이 사건 역시 이 경우 얼마나 정교한 사실관계 조사가 이루어졌는지 당사자들이 충실하게 소명

부록.1. 주요 사건 경과 및 패소 원인 분석

한 정도에 따라 판단이 엇갈리게 나온 것으로 판단된다. 즉 근로자성에 대한 기준 자체를 정형화, 도식화 할 수 없다는 한계에서 발생하는 문제라고 평가된다.

특히 이 사건의 근로자로 판단받은 최○○은 이 사건 회사를 상대로 퇴직금 등 금품채불로 신고한 바 있고 성남고용노동지청 및 수원지방검찰청 성남지청에서는 근로기준법상 근로자에 해당하지 않는다는 이유로 행정종결된 바 이와 같은 점을 보더라도 근로자성 판단이 어렵다는 점을 시사한다고 생각된다.

일련번호	2022-37					
판결번호	대법원 2022. 3. 31. 선고 2021두00000					
중노위판정번호	중노위 2019. 5. 1. 중앙2019부해107					
사건 종류	징계해고					
세부 쟁점	징계해고 - 재량에 관한 판단					
심급별 소송결과	1심 법원	재심유지	2심 법원	1심파기	대법원	원심유지
원고, 피상고인	사회복지법인 ○○가톨릭사회복지회			피고보조참가인	강명○, 강라○	
피고, 상고인	중앙노동위원회위원장			피고측 대리인 선임 여부	선인 안 함	
노동조합 지원 여부	없음			원고측 대리인 선임 여부	선임	
재심 결과	초심 취소					
초심의 대법원 판례 일치여부	일치			재심의 대법원 판례 일치여부	불일치	
기타 특이사항						

주요 사실관계

<사실관계>

가. 사회복지법인 ○○가톨릭사회복지회(이하 ‘이 사건 사회복지법인’)은 1994. 3. 24. 설립되어 상시 약 50명의 근로자를 사용하여 사회복지업을 경영하는 법인으로, ○○군복합노인복지타운 노인요양원(이하 ‘이 사건 요양원’)을 ○○군으로부터 위탁받아 운영하고 있다. 강명○은 2008. 12. 1., 강라○은 2010. 2. 1. 이 사건 사회복지법인에 각 입사하여 이 사건 요양원에서 요양보호사로 근무하던 사람들이다.

나. 이 사건 요양원(원장 유○○)은 2018. 10. 15. 요양환자인 방○○의 보호자로부터 강라○에 대한 민원을 접수받고 CCTV 영상을 확인하던 중 근로자들이 환자의 기저귀를 갈아주는 업무를 하던 도중 성기를 노출시키거나, 주먹을 들어 위협하는 행위를 한 사실을 확인하였다.

다. 이 사건 사회복지법인은 2018. 10. 16. 전라북도노인보호전문기관에 참가인들을 신고한 후 감독기관인 ○○군청에 이를 보고하였다.

라. 전라북도노인보호전문기관장은 2018. 10. 19. 노인학대판정위원회를 개최하여 이 사건 근로자들에 대한 신고 사건을 심의한 후 2018. 10. 22. ○○군수에게 이 사건 학대행위와 관련하여 '노인복지 생활시설 학대 판정지표에 따른 신체적 학대(발로 몸을 밟아 누른다. 손이나 발로 툭툭치며 다룬다), 정서적 학대(때리는 시늉을 한다. 주먹을 들이대며 위협한다)로 판정하였다'는 취지의 학대사례 판정(이하 '이 사건 학대사례 판정'이라 한다) 결과를 통보하였다

마. 이 사건 사회복지법인은 2018. 10. 22. 16:00 이 사건 근로자들을 참석하게 한 상태에서 인사위원회를 개최하여 이들에 대한 해고를 의결하였다. 이 사건 사회복지법인은 2018. 10. 29. 위 인사위원회 심의결과에 따라 이들에 대하여 해고 통보를 하였다(이하 '이 사건 해고'라 한다).

바. 이 사건 근로자들은 2018. 11. 2. 전북지노위에 이 사건 해고에 대한 부당해고 구제신청을 하였다.

<심급별 결과>

[전북지노위] 2018. 12. 26. '이 사건 근로자들에 대한 징계사유가 인정되고 징계양정이 적정하며, 이들이 인사위원회에 참석하여 충분한 소명의 기회를 가졌는바 징계절차상의 하자도 없으므로, 이 사건 해고는 적법하다'는 이유로 이 사건 근로자들의 구제신청을 기각. 이에 불복하여 이 사건 근로자들은 2019. 1. 30. 중노위에 재심을 신청

[중노위] 2019. 4. 3. '이 사건 근로자들에 대한 징계사유는 인정되나, 피해자가 폭행당했다는 점이 확인되지 않고 이 사건 근로자들에게 징계전력이 없는 점 등에 비추어 징계양정이 과하며, 이 사건 근로자들은 인사위원회 개최와 관련하여 정당한 절차에 따른 사전 통보를 받지 못함에 따라 충분한 소명 기회를 부여받지 못하는 등 징계절차도 적법하지 않으므로 이 사건 해고는 부당하다'는 이유로 이 사건 초심판정을 취소하고 참가인들의 재심신청을 인용. 초심 취소

[1심 법원] 이 사건 해고는 그 징계사유가 인정되고 징계양정이 적정하나, 인사위원회 징계의결 과정에 절차적 하자가 있어 위법하므로 이 사건 재심판정은 적법하다고 판시

[2심 법원] 이 사건 해고의 징계절차의 하자가 치유되었고, 정당한 징계사유가 존재하며 징계양정 또한 적정하므로 이와 다른 전제에선 이 사건 재심판정은 위법하다고 판시

[대법원] 원심판결 그대로 인정

판결 요지

1. 절차적 하자 여부

이 사건 근로자들은 인사위원회에 출석하여 출석통지절차에 대한 이의를 제기함이 없이 충분한 소명을 하였으므로, 인사규정 제53조 제3항을 위반한 절차상의 하자는 치유되었다고 봄이 타당하다.

2. 징계양정의 적정성 여부

이 사건 학대사례 판정결과와 같은 내용의 범죄사실로 관련 형사사건이 확정되었고, 관련 형사사건의 사실판단을 채용하기 어렵다고 인정할 만한 특별한 사정은 보이지 않으므로 이 사건 해고의 징계사유가 넉넉히 인정된다. 또한 이 사건 근로자들의 주장과 같이 이 사건 사용자가 노동조합 간부인 이 사건 근로자들을 퇴사시킬 목적으로 이 사건 해고를 하였다는 증거가 없고, 이 사건 사용자가 이 사건 해고의 징계사유와 동정의 비위행위를 한 다른 근로자들에 대하여 가벼운 징계를 하였다는 점 역시 인정할 수 없다. 따라서 이 사건 해고의 징계양정 또한 적정하다.

패소 이유 (사실관계에 관한 인정)

이 사건은 동일한 사실관계를 어떻게 바라보느냐, 재량이 인정되는 영역에서 이를 어떻게 판단하느냐에 따라 결론이 달라진 것으로 보이며, 재량이 인정되는 분야의 기준 자체를 정형화, 도식화 할 수 없는 한계 때문에 판단이 엇갈린 것 판단된다.

특히 법관은 재판 절차를 통하여 증인들의 실제 증언을 들을 수 있고, 반대되는 신문을 하며 사실관계를 파악하고 심증을 형성하는 등 노동위원회 판정 보다 폭 넓고 조금더 구체화된 사실관계를 파악할 수 있는 기회가 있는데 절차의 이러한 사실상의 한계 때문에 결론이 달라진 사례라고 생각된다.

일련번호	2022-39					
판결번호	대법원 2022. 3. 11. 선고 2021두00000					
중노위판정번호	중노위 2020. 4. 7. 중양2020부해22					
사건 종류	기간제					
세부 쟁점	갱신거절의 합리적인 이유					
심급별 소송결과	1심 법원	재심취소	2심 법원	1심유지	대법원	원심유지
원고, 피상고인	○○과학기술원		피고보조참가인		김○○	
피고, 상고인	중앙노동위원회위원장		피고측 대리인 선임 여부		선인 안 함	
노동조합 지원 여부	없음		원고측 대리인 선임 여부		선임	
재심 결과	초심 취소					
초심의 대법원 판례 일치여부	일치		재심의 대법원 판례 일치여부		불일치	
기타 특이사항						

주요 사실관계

<사실관계>

가. ○○과학기술원(이하 ‘이 사건 사용자’)는 2014. 1.경 박사학위 소지자 또는 석사학위 소지자를 대상으로 기초교육 학부 및 전공과정 각 분야에서 실험교과목 운영 및 지원 업무를 수행할 위촉연구원(실험조교)를 모집한다고 공고하였고, 2014. 2.경 위 공고에 따라 지원한 사람들 중

물리, 화학, 생물분야의 실험조교를 각 2명씩 채용하였으나, 물리 분야 실험조교가 4개월만에 그 만듬에 따라 2014. 6.경 추가 채용공고를 하였다.

나. 김○○(이하 ‘이 사건 근로자’)은 박사학위 소지자로서 위 추가 채용공고에 따라 지원하여 2014. 7. 1.부터 이 사건 사용자와 계약기간을 1년으로 정한 근로계약을 체결한 뒤, 물리 분야 실험조교로 근무하였고, 이후 해마다 계약을 갱신하여 2019. 6.경까지 같은 업무를 계속 수행하였다.

다. 이 사건 사용자는 2019. 5. 22. 이 사건 근로자에게 전자우편으로 ‘학생조교 활용제도가 정착됨에 따라 한시적으로 실시하였던 실험조교 기간제근로자 운영을 중단하고자 한다. 이에 따라 2019. 6.경 이 사건 근로자의 계약만료 시 고용관계가 종료됨을 미리 알려드린다.’라는 내용으로 2019. 6. 30.부로 이 사건 근로자와 체결한 근로계약이 종료됨을 통보하였다(이하 ‘이 사건 통보’라 한다).

라. 이 사건 근로자는 이 사건 통보가 부당해고에 해당한다고 주장하면서 2019. 9. 27. 전남지노위에 전남2019부해425호로 구제를 신청하였다.

<심급별 결과>

[전남지노위] 2019. 11. 20. 참가인에게 근로계약 갱신에 대한 정당한 기대권이 인정되지 아니한다는 이유로 참가인의 구제신청을 기각. 이 사건 근로자는 이에 불복하여 재심 신청

[중노위] 2020. 4. 7. 참가인에게 근로계약 갱신에 대한 정당한 기대권이 인정되고, 이 사건 사용자가 근로계약 갱신을 거절한 데 합리적 이유가 없다고 보아 이 사건 통보가 부당해고에 해당한다는 취지로 판정. 초심 취소

[1심 법원] 이 사건 근로자에게는 근로계약 갱신에 대한 정당한 기대권이 인정되지 아니하므로 이 사건 사용자와의 사이의 근로계약에서 정한 기간이 지남에 따라 고용관계는 당연히 종료되었으므로 이와 다른 전제에서 내려진 이 사건 재심판정은 위법하다고 판시

[2심 법원] 1심판결과는 결론을 같이 하나 정당한 갱신 기대권은 인정되나 거절에 대한 합리적인 이유가 있다고 보아 정당하다고 판시

[대법원] 원심판결 그대로 인정

판결 요지

1. 갱신기대권 인정여부

기간을 정하여 근로계약을 체결한 근로자의 경우 기간이 지나면 근로자로서의 신분관계는 당연히 종료되고 근로계약을 갱신하지 못하면 갱신거절의 의사표시가 없어도 근로자는 당연히 퇴직하는 것이 원칙이다. 그러나 근로계약, 취업규칙, 단체협약 등에서 기간만료에도 불구하고 일정한 요건을 갖추면 근로계약이 갱신된다는 규정을 두고 있거나, 그러한 규정이 없더라도 근로계약의 내용과 근로계약이 이루어지게 된 동기와 경위, 계약 갱신의 기준 등 갱신 요건이나 절차의 설정 여부와 그 실태, 근로자가 수행하는 업무의 내용 등 근로관계를 둘러싼 여러 사정을 종합해 볼 때 근로계약 당사자 사이에 일정한 요건을 충족하면 근로계약이 갱신된다는 신뢰관계가 형성되어 있어 근로자에게 그에 따라 근로계약이 갱신될 수 있으리라는 정당한 기대권이 인정되는 경우에는 사용자가 이를 위반하여 부당하게 근로계약의 갱신을 거절하는 것은 부당해고와 마찬가지로 아무런 효력이 없다. 이 경우 기간만료 후의 근로관계는 종전의 근로계약이 갱신된 것과 동일하다(대법원 2017. 10. 12. 선고 2015두44493 판결, 대법원 2019. 10. 31. 선고 2019두45647 판결 등 참조)

이 사건 사용자는 이 사건 근로자에게 정당한 갱신기대권이 인정되지 않는다고 주장하나 여러 가지 사실관계를 통해 판단하건데 이 사건 근로자의 갱신기대권을 인정하는 데 장애가 되지 않

는다고 봄이 타당하다.

2. 갱신거절의 합리적 이유

기간제 근로자에게 이미 형성된 갱신에 대한 정당한 기대권이 있는데도 사용자가 이를 배제하고 근로계약의 갱신을 거절한 데에 합리적 이유가 있는지가 문제될 때에는 사용자의 사업 목적과 성격, 사업장 여건, 근로자의 지위와 담당 직무의 내용, 근로계약 체결 경위, 근로계약의 갱신 요건이나 절차의 설정 여부와 운용 실태, 근로자에게 책임 있는 사유가 있는지 등 근로관계를 둘러싼 여러 사정을 종합하여 갱신 거부의 사유와 절차가 사회통념에 비추어 볼 때 객관적이고 합리적이며 공정한지를 기준으로 판단하여야 한다(대법원 2017. 10. 12. 선고 2015두44493 판결, 대법원 2019. 10. 31. 선고 2019두45647 판결 등 참조).

인력수급이나 배치형태 변경은 사용자로서 결정할 수 있는 인사재량권이라는 점, 이 사건 사용자의 기간제 근로자 인사관리지침 역시 재계약 거부가 가능하다는 점 등을 살펴보면 이 사건 사용자의 갱신거절에는 합리적인 이유가 있다.

패소 이유 (사실관계에 관한 인정)

이 사건은 계약갱신 거절의 합리적 이유가 주된 쟁점이고, 구체적인 사실관계를 어떤 관점에서 바라보느냐, 혹은 어떻게 분석하느냐에 따라서 결론이 달라진 것으로 보이며, ‘합리적인 이유’라는 기준 자체를 정형화, 도식화 할 수 없는 한계 때문에 노동위원회와 법원의 판단이 달라진 사건으로 판단된다.

특히 법관은 재판 절차를 통하여 증인들의 실제 증언을 들을 수 있고, 반대되는 신문을 하며 사실관계를 파악하고 심증을 형성하는 등 노동위원회 판정 보다 폭 넓고 조금더 구체화된 사실관계를 파악할 수 있는 기회가 있는데 절차의 이러한 사실상의 한계 때문에 결론이 달라진 사례라고 생각된다.

일련번호	2022-40					
판결번호	서울행정법원 2022. 4. 21. 선고 2020구합00000					
중노위판정번호	중노위 2020. 6. 4. 중양2019부해426					
사건 종류	기간제					
세부 쟁점	갱신거절의 합리적인 이유					
심급별 소송결과	1심 법원	재심취소	2심 법원	-	대법원	-
원고	김○○		피고보조참가인		대한민국	
피고	중양노동위원회위원장		피고측 대리인 선임 여부		선인 안 함	

노동조합 지원 여부	없음	원고측 대리인 선임 여부	선임
재심 결과	초심 유지		
초심의 대법원 판례 일치여부	불일치	재심의 대법원 판례 일치여부	불일치
기타 특이사항			

주요 사실관계

<사실관계>

가. 대한민국(이하 ‘대한민국’)은 정부조직법 제33조에 따라 국방에 관련된 군정 및 군령과 그 밖에 군사에 관한 사무를 관장하는 국방부를 통해 상시근로자 약 120명을 고용하여 육군본부 교육사령부 하위조직으로 ○○대 근무지원단(이하 ‘이 사건 지원단’)을 운영하고 있다.

나. 대한민국은 2012. 2.경부터 ○○이엔씨 주식회사와 1년 단위로 이 사건 지원단의 시설관리 용역계약을 체결하여 오다가, 2017. 11. 9.자 ‘각급부대 비정규직 근로자의 정규직 전환 실시지침’에 따라 2018. 2. 1. 원고를 포함한 이 사건 지원단의 용역업체 소속 근로자 120명과 근로계약을 체결하여 그들을 직접 채용하였다.

다. 한편, 대한민국은 2019. 2. 12. 김○○(이하 ‘이 사건 근로자’)이 가입해 있는 전국공공운수노동조합과 유효기간을 2018. 1. 1.부터 2019. 12. 31.까지로 하는 단체협약(이하 ‘이 사건 단체협약’)을 체결하였다. 이 사건 단체협약 제31조는 “정년은 상반기 생일자의 경우에는 만 60세가 되는 해의 6월 말일로, 하반기 생일자의 경우에는 만 60세가 되는 해의 12월 말일로 한다. 단, 2018년 정규직 전환자에 대하여 결격사유가 없는 자에 한해 1년 단위로 평가를 하여 최대 65세까지 근무를 할 수 있다.”고 규정하고 있다.

라. 이 사건 근로자(1958. 10. 1.생)는 위 근로계약에 따라 이 사건 지원단에서 근무하던 중 2018. 12. 31.자로 이 사건 단체협약 제31조 본문에서 정한 정년에 도달하게 되었는데, 2018. 12. 12. 대한민국과 계약기간을 2019. 1. 1.부터 1년으로 하는 근로계약(이하 ‘이 사건 근로계약’)을 체결하였다.

마. 대한민국은 2019. 11. 13. 이 사건 근로자를 비롯한 기간제근로자의 계약 연장 검토를 위한 인사위원회를 개최하였고, 기간제근로자 15명 중 이 사건 근로자를 포함한 2명에 대해 계약 연장을 승인하지 않기로 결정하였다. 이에 따라 대한민국은 2019. 11. 25. 이 사건 근로자에게 이 사건 근로계약이 2019. 12. 31.자로 종료된다고 통보하였다.

바. 이 사건 근로자는 위 계약연장 미승인 결정에 대해 재심의를 요청하였고, 대한민국은 2019. 12. 27. 인사위원회를 개최하여 계약 연장 승인 여부를 표결에 붙인 결과 재계약 승인 2표, 미승인 4표로 계약 연장을 승인하지 않기로 결정하였다. 이에 따라 대한민국은 2019. 12. 31. 이 사건 근로자에게 인사위원회 결과 통보서 및 고용계약만료 통보서를 전달하였다(이하 ‘이 사건 통보’라 한다).

사. 이 사건 근로자는 2020. 1. 17. 이 사건 통보가 부당하다며 전남지노위에 구제신청

<심급별 결과>

[전남지노위] 2020. 3. 9. ‘이 사건 근로자에게 이 사건 근로계약에 대한 갱신기대권은 인정되나, 이 사건 통보에 하자가 존재한다고 볼 수 없으므로 이 사건 사용자가 이 사건 통보로써 이 사건

근로자에 대하여 이 사건 근로계약의 갱신을 거절한 것에 합리적인 이유가 있다.’는 이유로 이 사건 근로자의 구제신청을 기각. 이 사건 근로자는 이에 불복하여 재심 신청 [중노위] 2020. 6. 4. 초심판정과 같은 취지로 재심신청을 기각(중앙2020부해426). 초심 유지

판결 요지

기간을 정하여 근로계약을 체결한 근로자의 경우 기간이 지나면 근로자로서의 신분관계는 당연히 종료되고 근로계약을 갱신하지 못하면 갱신거절의 의사표시가 없어도 근로자는 당연히 퇴직하는 것이 원칙이다. 그러나 근로계약, 취업규칙, 단체협약 등에서 기간만료에도 불구하고 일정한 요건을 갖추면 근로계약이 갱신된다는 규정을 두고 있거나, 그러한 규정이 없더라도 근로계약의 내용과 근로계약이 이루어지게 된 동기와 경위, 계약 갱신의 기준 등 갱신 요건이나 절차의 설정 여부와 그 실태, 근로자가 수행하는 업무의 내용 등 근로관계를 둘러싼 여러 사정을 종합해 볼 때 근로계약 당사자 사이에 일정한 요건을 충족하면 근로계약이 갱신된다는 신뢰관계가 형성되어 있어 근로자에게 그에 따라 근로계약이 갱신될 수 있으리라는 정당한 기대권이 인정되는 경우에는 사용자가 이를 위반하여 부당하게 근로계약의 갱신을 거절하는 것은 부당해고와 마찬가지로 아무런 효력이 없다. 이 경우 기간만료 후의 근로관계는 종전의 근로계약이 갱신된 것과 동일하다. 그리고 정년이 지난 상태에서 기간제 근로계약을 체결한 경우에는 위에서 본 여러 사정 외에 해당 직무의 성격에서 요구되는 직무수행 능력과 근로자의 업무수행 적격성, 연령에 따른 작업능률 저하나 위험성 증대의 정도, 해당 사업장에서 정년이 지난 고령자가 근무하는 실태와 계약이 갱신된 사례 등을 종합적으로 고려하여 근로계약 갱신에 관한 정당한 기대권이 인정되는지를 판단하여야 한다. 근로자에게 이미 형성된 갱신에 대한 정당한 기대권이 있는데도 사용자가 이를 배제하고 근로계약의 갱신을 거절한 데에 합리적 이유가 있는지가 문제 될 때에는 사용자의 사업 목적과 성격, 사업장 여건, 근로자의 지위와 담당 직무의 내용, 근로계약 체결 경위, 근로계약의 갱신 요건이나 절차의 설정 여부와 운용 실태, 근로자에게 책임 있는 사유가 있는지 등 근로관계를 둘러싼 여러 사정을 종합하여 갱신 거부의 사유와 절차가 사회통념에 비추어 볼 때 객관적이고 합리적이며 공정한지를 기준으로 판단하여야 하고, 그러한 사정에 관한 증명책임은 사용자가 부담한다(대법원 2019. 10. 31. 선고 2019두45647 판결, 대법원 2021. 10. 28. 선고 2021두45114 판결 등 참조).

다음과 같은 사정들에 비추어 보면, 대한민국이 이 사건 근로계약의 갱신을 거절한 것에는 합리적인 이유가 있다고 보기 어렵다.

① 이 사건 근로계약등은 근무성적을 평가하여 재계약 여부 등 인사, 노무관리에 반영한다는 취지로 규정하고 있다는 점, ② 이 사건 취업규칙등을 살펴보면 부득이한 경영상의 필요가 있는 경우라면 근로계약 갱신을 거절할 수 있다고 해석되나, 이 사건 근로자의 근무성적이나 근무능력이 사회통념상 근로계약을 유지할 수 없을 정도에 이른다고 단정하기 어렵다는 점, ③ 이 사건 근로계약, 취업규칙 등 관련 규정에 근로계약 갱신 거절의 기준이 되는 근무성적 평정 점수가 구체적으로 규정되어 있지 않고, 이 사건을 제외하면 상대평가 결과 하위에 속하는 근무성적 평정 점수를 받은 기간제근로자에 대하여 근로계약 갱신을 거절한 예도 없다는 점 등.

패소 이유 (사실관계에 관한 인정)

이 사건은 계약갱신 거절의 합리적 이유가 주된 쟁점이고, 구체적인 사실관계를 어떤 관점에서 바라보느냐, 혹은 어떻게 분석하느냐에 따라서 결론이 달라진 것으로 보이며, ‘합리적인 이유’라는 기준 자체를 정형화, 도식화 할 수 없는 한계 때문에 노동위원회와 법원의 판단이 달라진 사건으로 판단된다.

특히 법관은 재판 절차를 통하여 증인들의 실제 증언을 들을 수 있고, 반대되는 신문을 하며

사실관계를 파악하고 심증을 형성하는 등 노동위원회 판정 보다 폭 넓고 조금더 구체화된 사실 관계를 파악할 수 있는 기회가 있는데 절차의 이러한 사실상의 한계 때문에 결론이 달라진 사례 라고 생각된다.

일련번호	2022-41					
판결번호	대법원 2022. 5. 26. 선고 2022두00000					
중노위판정번호	중노위 2020. 5. 12. 중앙2020부해283					
사건 종류	기간제					
세부 쟁점	갱신거절의 합리적인 이유					
심급별 소송결과	1심 법원	재심취소	2심 법원	1심유지	대법원	원심유지
원고, 피상고인	○○○○공사		피고보조참가인, 상고인		김○○	
피고, 상고인	중앙노동위원회위원장		피고측 대리인 선임 여부		선임 안 함	
노동조합 지원 여부	없음		원고측 대리인 선임 여부		선임	
재심 결과	초심 유지					
초심의 대법원 판례 일치여부	불일치		재심의 대법원 판례 일치여부		불일치	
기타 특이사항						

주요 사실관계
<사실관계> 가. ○○○○공사(이하 ‘이 사건 사용자’)는 1983. 8. 18. ○○○○공사법에 따라 설립된 회사로 상시 근로자 4,100여 명을 사용하여 천연가스의 개발, 제조, 공급 등의 사업을 하는 공기업이다. 김○○(이하 ‘이 사건 근로자’)은 2017. 11. 1. 이 사건 사용자에게 기간제근로자로 입사한 후 원고의 가스연구원 ○○분원에서 근무하다가, 2019. 10. 31.까지 계약기간이 갱신되었다. 나. 이 사건 사용자는 이 사건 근로자에 대한 전문직(정규직) 전환심의를 하였으나, 전환을 하지 않기로 결정하고 2019. 10. 29. 근로계약이 만료됨을 통지하였다. 다. 이 사건 근로자는 2019. 11. 22. 인천지노위에 부당해고 구제신청을 하였다. <심급별 결과> [인천지노위] 이 사건 근로자에게 정규직 전환기대권이 인정됨에도 이 사건 사용자가 합리적 이

유 없이 정규직 전환을 거절한 것은 부당해고에 해당한다는 이유로 ‘이 사건 사용자가 2019. 10. 31. 계약기간 만료를 이유로 한 근로관계종료는 부당해고임을 인정하고, 이 사건 근로자를 즉시 원직에 복직시키고 해고기간에 정상적으로 근로하였다면 받을 수 있었던 임금 상당액의 지급’을 명함. 이 사건 사용자가 2020. 3. 4. 위 판정에 불복하여 재심 신청
[중노위] 정규직전환의 기대권이 있고, 전환거절에 합리적 이유가 없음을 이유로 재심신청을 기각. 초심 유지

[1심 법원] 이 사건 사용자의 정규직 전환 거절은 합리적인 이유가 있으므로 이 사건 재심판정이 위법하다고 판시

[2심 법원] 1심판결과 같이 판시

[대법원] 원심판결 그대로 인정

판결 요지

1. 정규직 전환 기대권 인정여부

기간제 및 단시간근로자 보호 등에 관한 법률은 제5조에서 “사용자는 기간의 정함이 없는 근로계약을 체결하고자 하는 경우에는 당해 사업 또는 사업장의 동종 또는 유사한 업무에 종사하는 기간제근로자를 우선적으로 고용하도록 노력하여야 한다.”라고 규정하고, 제8조 제1항에서 “사용자는 기간제근로자임을 이유로 당해 사업 또는 사업장에서 동종 또는 유사한 업무에 종사하는 기간의 정함이 없는 근로계약을 체결한 근로자에 비하여 차별적 처우를 하여서는 아니 된다.”라고 규정하고, 제9조 제1항에서 “기간제근로자 또는 단시간근로자는 차별적 처우를 받은 경우 노동위원회법 제1조의 규정에 따른 노동위원회에 그 시정을 신청할 수 있다.”라고 규정하고 있다. 위 각 규정의 내용 및 입법 취지에 앞서 본 기간제근로자의 기대권에 관한 법리를 더하여 살펴보면, 근로계약, 취업규칙, 단체협약 등에서 기간제근로자의 계약기간이 만료될 무렵 인사평가 등을 거쳐 일정한 요건이 충족되면 기간의 정함이 없는 근로자로 전환된다는 취지의 규정을 두고 있거나, 그러한 규정이 없더라도 근로계약의 내용과 근로계약이 이루어지게 된 동기와 경위, 기간의 정함이 없는 근로자로의 전환에 관한 기준 등 그에 관한 요건이나 절차의 설정 여부 및 그 실태, 근로자가 수행하는 업무의 내용 등 당해 근로관계를 둘러싼 여러 사정을 종합하여 볼 때, 근로계약 당사자 사이에 일정한 요건이 충족되면 기간의 정함이 없는 근로자로 전환된다는 신뢰관계가 형성되어 있어 근로자에게 기간의 정함이 없는 근로자로 전환될 수 있으리라는 정당한 기대권이 인정되는 경우에는 사용자가 이를 위반하여 합리적 이유 없이 기간의 정함이 없는 근로자로의 전환을 거절하며 근로계약의 종료를 통보하더라도 부당해고와 마찬가지로 효력이 없고, 그 이후의 근로관계는 기간의 정함이 없는 근로자로 전환된 것과 동일하다고 보아야 한다(대법원 2016. 11. 10. 선고 2014두45765 판결).

다음의 사정을 종합하여 보면, 이 사건 근로자로서는 정규직 전환에 대한 기대권이 있다고 봄이 타당하다.

① 이 사건 사용자는 원고는 2017. 12. 27. 별정직 관리규정 및 인사규정 시행세칙을 개정하여 전문직이라는 직군을 두고 계약직원의 전문직 직원 전환에 관한 근거를 두었고, 이를 상임인사위원회에서 심의하도록 하였다는 점, ② 정부는 2017. 7. 20. ‘공공부문 비정규직 근로자 정규직 전환 가이드라인’(이하 ‘이 사건 정부지침’)을 발표하여 일정한 요건을 충족하는 경우 정규직 전환 가능성이 생긴 점, ③ 이 사건 사용자는 필요한 경우 전문직 전환절차를 진행하였다는 점 등.

2. 갱신거절의 합리적 이유

① 이 사건 정부지침에 따르더라도 이 사건 사용자에게는 정규직 전환을 위한 상당한 재량이 있는 점, ② 이 사건 사용자의 인사규정 시행세칙에 따라 이 사건 사용자는 절차를 모두 거쳤다는 점, ③ 이 사건 사용자는 공기업으로 많은 지원들이 선호하는 직장이고, 경쟁률이 높다는 점을 고려한다면 채용과정에서의 공정성이 강조되어 기간제 근로자의 전환에 신중할 수 밖에 없다

는 점 등을 고려하면 이 사건 사용자의 갱신거절에는 합리적인 이유가 있다.

패소 이유 (사실관계에 관한 인정)

이 사건은 계약갱신 거절의 합리적 이유가 주된 쟁점이고, 구체적인 사실관계를 어떤 관점에서 바라보느냐, 혹은 어떻게 분석하느냐에 따라서 결론이 달라진 것으로 보이며, ‘합리적인 이유’라는 기준 자체를 정형화, 도식화 할 수 없는 한계 때문에 노동위원회와 법원의 판단이 달라진 사건으로 판단된다.

특히 법관은 재판 절차를 통하여 증인들의 실제 증언을 들을 수 있고, 반대되는 신문을 하며 사실관계를 파악하고 심증을 형성하는 등 노동위원회 판정 보다 폭 넓고 조금더 구체화된 사실관계를 파악할 수 있는 기회가 있는데 절차의 이러한 사실상의 한계 때문에 결론이 달라진 사례라고 생각된다.

일련번호	2022-42					
판결번호	대법원 2022. 4. 28. 선고 2022두00000					
중노위판정번호	중노위 2019. 9. 23. 중양2019부해919					
사건 종류	기간제					
세부 쟁점	갱신거절의 합리적인 이유					
심급별 소송결과	1심 법원	재심취소	2심 법원	1심유지	대법원	원심유지
원고, 피상고인	○○과학기술원		피고보조참가인		김○○	
피고, 상고인	중양노동위원회위원장		피고측 대리인 선임 여부		선인 안 함	
노동조합 지원 여부	없음		원고측 대리인 선임 여부		선임	
재심 결과	초심 취소					
초심의 대법원 판례 일치여부	불일치		재심의 대법원 판례 일치여부		불일치	
기타 특이사항						

주요 사실관계

<사실관계>

가. ○○과학기술원(이하 ‘이 사건 사용자’)는 첨단과학기술의 혁신을 선도할 고급과학기술인재를 양성하고 산업계와의 협동연구 및 외국과의 교육·연구교류를 촉진함으로써 국가과학기술발전에 이바지할 목적으로 ○○과학기술원법에 기하여 1993. 10. 11. 설립된 특수목적법인으로, 연구원, 대학원 및 ○○ 대학 등을 운영하고 있다.

나. 김○○(이하 ‘이 사건 근로자’)은 화학분야 박사학위 소지자로서, 2014. 2. 3. 이 사건 사용자와 사이에 근로계약(계약기간: 2014. 2. 1. ~ 2015. 1. 31.)을 체결하고 ○○대학의 ‘위촉연구원(실험조교)’(이하 ‘위촉실험조교’라 한다)로 근무하면서, 화학분야 기초학부 및 전공과정 실험 교과목 운영 및 지원, 실험실 운영관리, 학부생 실험 지도 등 업무를 담당하였다. 이후 이 사건 사용자와의 근로계약은 1년 단위로 네 차례 갱신되었는데, 각 계약기간 사이에 공백기가 없었고, 이 사건 근로자의 담당업무도 동일하였다.

다. 이 사건 사용자는 이 사건 근로자와 사이에 마지막으로 체결된 2018. 2. 1.자 근로계약의 계약기간 종기인 2019. 1. 31.을 앞두고, 2018. 12. 19. 이메일로 ‘2019. 1. 이 사건 근로자의 계약 만료 시 고용관계가 종료된다’고 통지하였고, 2019. 1. 31. 이후 근로계약을 갱신하여 체결하지 아니하였다(이하 ‘이 사건 근로계약 종료’라 한다).

라. 이 사건 근로자는 2019. 4. 22. 전남지노위에 이 사건 근로계약 종료가 부당해고에 해당한다는 취지로 주장하면서 부당해고 구제신청(전남2019부해186)을 하였다.

<심급별 결과>

[전남지노위] ‘참가인에게 근로계약 갱신에 대한 기대권이 형성되어 있다고 보기 어렵다’는 이유로 참가인의 구제신청을 기각. 이에 이 사건 근로자는 2019. 7. 22. 재심 신청

[중노위] ‘참가인의 갱신기대권이 존재하고, 이 사건 사용자의 갱신거절에 합리적 이유가 존재한다고 보기 어려워, 이 사건 근로관계 종료는 부당해고에 해당한다’는 이유로 초심판정을 취소, 참가인의 구제신청을 인용

[1심 법원] 이 사건 사용자의 정규직 전환 거절은 합리적인 이유가 있으므로 이 사건 재심판정이 위법하다고 판시

[2심 법원] 1심판결과 같이 판시

[대법원] 원심판결 그대로 인정

판결 요지

1. 갱신기대권 인정여부

기간을 정하여 근로계약을 체결한 근로자의 경우 기간이 지나면 근로자로서의 신분관계는 당연히 종료되고 근로계약을 갱신하지 못하면 갱신거절의 의사표시가 없어도 근로자는 당연히 퇴직하는 것이 원칙이다. 그러나 근로계약, 취업규칙, 단체협약 등에서 기간만료에도 불구하고 일정한 요건을 갖추면 근로계약이 갱신된다는 규정을 두고 있거나, 그러한 규정이 없더라도 근로계약의 내용과 근로계약이 이루어지게 된 동기와 경위, 계약 갱신의 기준 등 갱신 요건이나 절차의 설정 여부와 그 실태, 근로자가 수행하는 업무의 내용 등 근로관계를 둘러싼 여러 사정을 종합해 볼 때 근로계약 당사자 사이에 일정한 요건을 충족하면 근로계약이 갱신된다는 신뢰관계가 형성되어 있어 근로자에게 그에 따라 근로계약이 갱신될 수 있으리라는 정당한 기대권이 인정되는 경우에는 사용자가 이를 위반하여 부당하게 근로계약의 갱신을 거절하는 것은 부당해고와 마찬가지로 아무런 효력이 없다. 이 경우 기간만료 후의 근로관계는 종전의 근로계약이 갱신된 것과 동일하다(대법원 2017. 10. 12. 선고 2015두44493 판결, 대법원 2019. 10. 31. 선고 2019두45647 판결 등 참조)

이 사건 사용자는 이 사건 근로자에게 정당한 갱신기대권이 인정되지 않는다고 주장하나 여러

가지 사실관계를 통해 판단하건데 이 사건 근로자의 갱신기대권을 인정하는 데 장애가 되지 않는다고 봄이 타당하다.

2. 갱신거절의 합리적 이유

기간제 근로자에게 이미 형성된 갱신에 대한 정당한 기대권이 있는데도 사용자가 이를 배제하고 근로계약의 갱신을 거절한 데에 합리적 이유가 있는지가 문제될 때에는 사용자의 사업 목적과 성격, 사업장 여건, 근로자의 지위와 담당 직무의 내용, 근로계약 체결 경위, 근로계약의 갱신 요건이나 절차의 설정 여부와 운용 실태, 근로자에게 책임 있는 사유가 있는지 등 근로관계를 둘러싼 여러 사정을 종합하여 갱신 거부의 사유와 절차가 사회통념에 비추어 볼 때 객관적이고 합리적이며 공정한지를 기준으로 판단하여야 한다(대법원 2017. 10. 12. 선고 2015두44493 판결, 대법원 2019. 10. 31. 선고 2019두45647 판결 등 참조).

인력수급이나 배치형태 변경은 사용자로서 결정할 수 있는 인사재량권이라는 점, 이 사건 사용자의 기간제 근로자 인사관리지침 역시 재계약 거부가 가능하다는 점 등을 살펴보면 이 사건 사용자의 갱신거절에는 합리적인 이유가 있다.

패소 이유 (사실관계에 관한 인정)

이 사건은 계약갱신 거절의 합리적 이유가 주된 쟁점이고, 구체적인 사실관계를 어떤 관점에서 바라보느냐, 혹은 어떻게 분석하느냐에 따라서 결론이 달라진 것으로 보이며, ‘합리적인 이유’라는 기준 자체를 정형화, 도식화 할 수 없는 한계 때문에 노동위원회와 법원의 판단이 달라진 사건으로 판단된다.

특히 법관은 재판 절차를 통하여 증인들의 실제 증언을 들을 수 있고, 반대되는 신문을 하며 사실관계를 파악하고 심증을 형성하는 등 노동위원회 판정 보다 폭 넓고 조금더 구체화된 사실관계를 파악할 수 있는 기회가 있는데 절차의 이러한 사실상의 한계 때문에 결론이 달라진 사례라고 생각된다.

일련번호	2022-47					
판결번호	대법원 2022. 6. 16. 선고 2022두00000					
중노위판정번호	중노위 2019. 11. 4. 2019부해1098					
사건 종류	부당해고					
세부 쟁점	징계위원회 의결정족수 충족 여부					
심급별 소송결과	1심 법원	재심 유지	2심 법원	1심 취소	대법원	상고기각 (심리불속행)
상 고 인	○○○○정책연구원		참 가 인		○○○○정책연구원	
피상고인	안○○(원고)		피고측 대리인 선임 여부		선임 안 함	
노동조합 지원 여부	없음		원고측 대리인 선임 여부		선임 함	

부록.1. 주요 사건 경과 및 패소 원인 분석

재심 결과	초심유지		
초심의 대법원 판례 일치여부	불일치	재심의 대법원 판례 일치여부	불일치
기타 특이사항			

주요 사실관계

<사실관계>

참가인 회사(연구기관)는 종전에 징계위원회를 별도로 설치하지 않고 인사위원회에서 징계 사항까지 의결하다가, 2016년에 인사관리규정 조항을 신설하여 징계위원회를 별도로 설치하고 여기서 징계에 관한 사항을 의결하게 되었는데, 징계위원회의 의결에 관하여는 별도 규정을 마련하지 않았다(종전 인사위원회는 재적위원 3분의 2이상 출석으로 성립하고, 출석위원 3분의 2이상의 찬성으로 의결). 한편 위 규정 신설 당시 노사는 징계대상이 조합원인 경우 인사위원회 위원 중 노조대표 1인과 노조에서 추천한 외부위원 중 1인을 징계위원으로 선임하기로 합의하였다.

원고 근로자는 참가인 노조의 조합원으로, 회사의 복무규정, 연구윤리규칙 등 위반을 이유로 징계위원회에 회부되었고, 참가인은 2018. 12. 24. 징계위원회를 열어 원고에 대한 해임을 의결하였다. 당시 징계위원회에는 재적위원 5인이 모두 출석하였는데, 출석위원 5인 중 3인은은 표결에 참여하여 원고의 해임에 찬성한 반면 2인은 해임에 반대하는 의사를 표시하고 표결에 불참하였다. 이에 원고가 의결정족수 미달 등을 이유로 부당해고 구제신청을 하였다.

<심급별 결과>

[서울지노위] 징계위원회에 출석한 5명의 위원 중 2명이 해임결정에 반대하며 표결절차 참여를 거부하였으므로 2명을 의결정족수 총원에서 제외하면, 의결정족수 총원 3명 중에서 3명이 해임에 찬성하였으므로 의결요건을 갖춘 것으로 판단된다며, 원고의 신청을 기각

[중노위] 초심유지

[1심 법원] 재심유지

[2심 법원] 징계위원회의 해고 의결정족수를 충족하지 못한 중대한 절차상 하자가 인정되므로 재심판정 및 1심 판결을 취소하였다.

[대법원] 심리불속행 기각

판결 요지

참가인은 종전에 징계위원회를 별도로 설치하지 않고 인사위원회에서 징계에 관한 사항까지 의결하다가, 2016. 12. 29. 인사관리규정 조항을 신설하여 징계위원회를 별도로 설치하고 징계위원회에서 징계에 관한 사항을 의결하게 되었으므로, 징계위원회는 기본적으로 인사위원회의 권한 중 징계에 관한 권한을 분장하게 된 것인데, ... 징계위원회의 의결에 관하여는 별도의 규정을 마련하지 않은 이상, 인사위원회와 동일한 의결정족수 규정이 적용된다고 해석함이 상당하다. ... 징계위원회가 의사에 관한 일반관례에 따라 재적 위원 과반수의 출석과 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다고 해석할 경우, 징계위원회의 징계의결 요건이 종전보다 완화되는 결과가 되어 징계의 공정성과 객관성 확보라는 위 취지에도 반하고, 나아가 인사위원회에서 직원의 채용 및 승진계획, 포상에 관한 사항 등을 의결하기 위한 요건은 재적위원 3분의 2 이상의 출석과 출석위원 3분의 2 이상의 찬성인 반면, 징계위원회에서 징계에 관한 사항을 의결하기 위한 요건은 재적위원 과반수의 출석과 출석위원 과반수의 찬성이 되어, 징계라는 불이익한 조치를 취하는 것인데도 징계의결 요건이 오히려 완화되는 부당한 결과가 발생한다.

패소 이유 (사실관계에 관한 인정 차이)

본 사건의 경우, 해고의 의결에 의결정족수를 충족하지 못한 중대한 절차상 하자가 있다고 볼 것인지 여부가 핵심 쟁점이었다.

중노위는 “징계위원회 5명이 출석하여 의결절차에 참여를 거부한 2명은 의결정족수 총원에서 제외되므로 의결정족수는 3명인데, 3명이 ‘해임’의 결정에 찬성하였으므로 의결요건을 갖춘 것으로 판단”된다며, 해고에 절차상의 하자가 존재하지 않는 것으로 판정하였다.

그러나 2심 법원은 “① 참가인은 종전에 징계위원회를 별도로 설치하지 않고 인사위원회에서 징계에 관한 사항까지 의결하다가, 2016. 12. 29. 인사관리규정 조항을 신설하여 징계위원회를 별도로 설치하고 징계위원회에서 징계에 관한 사항을 의결하게 되었으므로, 징계위원회는 기본적으로 인사위원회의 권한 중 징계에 관한 권한을 분장하게 된 것인데, … 징계위원회의 의결에 관하여는 별도의 규정을 마련하지 않은 이상, 인사위원회와 동일한 의결정족수 규정이 적용된다고 해석함이 상당하다 ② 인사위원회와 달리 외부위원까지 선임하여 징계위원회를 구성하고, 참가인의 노사가 징계대상이 조합원인 경우 인사위원회 위원 중 노조대표 1인과 노조에서 복수로 추천한 외부위원 중 1인을 원장이 징계위원으로 선임하기로 합의한 취지는 근로자에 대한 징계의 공정성과 객관성을 확보하기 위한 것인데, … 징계위원회가 의사에 관한 일반관례에 따라 재적위원 과반수의 출석과 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다고 해석할 경우, 징계위원회의 징계의결요건이 종전보다 완화되는 결과가 되어 징계의 공정성과 객관성 확보라는 취지에도 반하고, 나아가 인사위원회에서 직원의 채용 및 승진계획, 포상에 관한 사항 등을 의결하기 위한 요건은 재적위원 3분의 2이상의 출석과 출석위원 3분의 2이상의 찬성인 반면, 징계위원회에서 징계에 관한 사항을 의결하기 위한 요건은 재적위원 과반수의 출석과 출석위원 과반수의 찬성이 되어, 징계라는 불이익한 조치를 취하는 것인데도 징계의결 요건이 오히려 완화되는 부당한 결과가 발생한다”는 등의 이유로, 징계위원회의 의결은 인사위원회의 의결과 마찬가지로 재적위원 3분의 2 이상의 출석과 출석위원 3분의 2 이상의 찬성으로 이루어진다고 봄이 타당하므로, 이 사건 해고는 징계위원회 재적위원 5인이 출석하였으나 출석위원 5인 중 3인만이 찬성하여 의결정족수를 충족하지 못하였다고 보아, 중노위 판정을 뒤집었다.

중노위는 판정의 근거로, “이 사건 결의의 의결정족수를 정하는 출석조합원은 2차 성원보고시 출석조합원이 아니라 위 결의 당시 회의장에 남아있던 조합원만을 의미한다고 할 것이고, 투표에 불참한 원고의 조합원 소외인 등 19명은 이 사건 결의 당시 회의장을 퇴장하였다고 봄이 상당하다(대법원 2010. 4. 29. 선고 2008두5568 판결 참조)”는 대법원 판례를 들었고, 1심 법원도 “의결정족수를 정하는 기준이 되는 출석회원이라 함은 당초 회의에 참석한 모든 회원을 의미하는 것이 아니라 문제가 된 결의 당시 회의장에 남아 있던 회원만을 의미한다고 할 것이므로 회의 도중 스스로 회의장에서 퇴장한 회원들은 이에 포함되지 않는다(대법원 2001. 7. 27. 선고 2000다56037 판결 등 참조)”는 유사한 취지의 판례 법리 인용하였으나, 2심 법원 및 대법원은 재심 판정의 논리대로라면, ‘징계의결 요건을 노사합의 없이 사실상 완화하게 되는 결과 초래, 징계의 공정성과 객관성 확보라는 징계위원회의 취지 등’을 고려하여, 이들 판례를 인용하지 않았다. 중노위가 기존 대법원 판결례를 다소 형식적으로 적용하여, 절차의 정당성을 요구하는 징계법리의 기본 취지에 충실하지 못한 해석을 한 것으로 보인다.

일련번호	2022-50
판결번호	대법원 2022. 6. 16. 선고 2022두00000
중노위판정번호	중노위 2020. 2. 12. 2019부해1639

부록.1. 주요 사건 경과 및 패소 원인 분석

사건 종류	부당해고					
세부 쟁점	촉탁직 근로자, 갱신기대권					
심급별 소송결과	1심 법원	재심 유지	2심 법원	1심 취소	대법원	상고 기각 (심리불속행)
상 고 인	중앙노동위원회위원장		참 가 인		강○○	
피상고인	○○운수 주식회사		피고측 대리인 선임 여부		선임 안 함	
노동조합 지원 여부	없음		원고측 대리인 선임 여부		선임 함	
재심 결과	초심유지					
초심의 대법원 판례 일치여부	불일치		재심의 대법원 판례 일치여부		불일치	
기타 특이사항						

주요 사실관계
<사실관계> 원고 회사(시내버스업)의 단체협약은 ‘정년 60세, 정년 이후 5년차까지 1년 단위로 노사협의회 의 적격심사를 거쳐 재고용하는 것을 원칙으로 한다’고 규정되어 있다. 그리고 원고가 2017년 개최한 노사협의회에서 ‘고령운전자가 겪는 운전 중 사고가 언론에 종종 보도되므로 66세 이상 근로자의 재입사 조건으로 개별 정밀건강검진을 실시하고 건강 이상 유무를 확인하여 채용한다’, ‘65세 이상 근로자는 각자 비용으로 MRA 검사 및 심장초음파 검사를 거쳐 검진 결과 이상이 없 을 때 근로계약 갱신 여부를 결정한다’라는 내용이 의결되었다. 이후 촉탁직 근로자이던 참가인 은 위 노사협의회 결정에 반발하는 내용의 글을 인터넷에 게시하였다. 원고 회사는 2019. 3. 15. 회사 게시판에 ‘사고를 예방하고 운전기사의 건강상태를 확인하고자 MRA 검사를 반드시 시행할 것이다. 불만이 있는 사람은 근로계약 갱신의 의사가 없는 것으로 간주하고 갱신 여부를 재고하 겠다. 반드시 검사받고 결과를 제출하라’는 공고문을 게시하였다. 원고는 2019. 6. 3. 참가인에게 근로계약기간 만료를 이유로 2019. 6. 30.자로 근로계약이 종 료됨을 통보하였는데, 원고가 교부한 ‘근로계약 만료 예고 통보서’에는 근로계약 종료 취지와 함 께 ‘제출서류 : 건강검진 개인검진표(촉탁재고용 적격심사 필요 서류)’라고 기재되어 있었다. 참가인은 2019. 6. 30. 이전에는 원고에게 MRA 검사 및 심장초음파 검사 결과를 제출하거나 갱신회망 의사를 표시하지 않았다가, 2019. 8. 1. 및 8. 22. 자신의 재고용을 촉구하는 내용증명 우편을 발송하고, 이후 부당해고 구제신청을 하였다. <심급별 결과> [경기지노위] 촉탁직 재고용에 대한 기대권이 인정되고, 재고용 거절에 합리적인 이유가 없다며 부당해고로 판정 [중노위] 초심유지 [1심 법원] 재심유지 [2심 법원] 갱신거절에 합리적 이유가 있어 부당해고가 아니라며 재심판정 및 1심 판결을 취소 [대법원] 심리불속행 기각

판결 요지

기간을 정하여 근로계약을 체결한 근로자의 경우 기간이 지나면 근로자로서의 신분관계는 당연히 종료되고 근로계약을 갱신하지 못하면 갱신거절의 의사표시가 없어도 근로자는 당연히 퇴직하는 것이 원칙이다. 그러나 근로계약, 취업규칙, 단체협약 등에서 기간만료에도 불구하고 일정한 요건을 갖추면 근로계약이 갱신된다는 규정을 두고 있거나, 그러한 규정이 없더라도 근로계약의 내용과 근로계약이 이루어지게 된 동기와 경위, 계약 갱신의 기준 등 갱신 요건이나 절차의 설정 여부와 그 실태, 근로자가 수행하는 업무의 내용 등 근로관계를 둘러싼 여러 사정을 종합해 볼 때 근로계약 당사자 사이에 일정한 요건을 충족하면 근로계약이 갱신된다는 신뢰관계가 형성되어 있어 근로자에게 그에 따라 근로계약이 갱신될 수 있으리라는 정당한 기대권이 인정되는 경우에는 사용자가 이를 위반하여 부당하게 근로계약의 갱신을 거절하는 것은 부당해고와 마찬가지로 아무런 효력이 없다. 이 경우 기간만료 후의 근로관계는 종전의 근로계약이 갱신된 것과 동일하다(대법원 2011. 4. 14. 선고 2007두1729 판결 참조).

그리고 정년이 지난 상태에서 기간제 근로계약을 체결한 경우에는 위에서 본 여러 사정 외에 해당 직무의 성격에서 요구되는 직무수행 능력과 근로자의 업무수행 적격성, 연령에 따른 작업능률 저하나 위험성 증대의 정도, 해당 사업장에서 정년이 지난 고령자가 근무하는 실태와 계약이 갱신된 사례 등을 종합적으로 고려하여 근로계약 갱신에 관한 정당한 기대권이 인정되는지를 판단하여야 한다(대법원 2017. 2. 3. 선고 2016두 50563 판결 참조).

근로자에게 이미 형성된 갱신에 대한 정당한 기대권이 있는데도 사용자가 이를 배제하고 근로계약의 갱신을 거절한 데에 합리적 이유가 있는지가 문제될 때에는 사용자의 사업 목적과 성격, 사업장 여건, 근로자의 지위와 담당 직무의 내용, 근로계약 체결 경위, 근로계약의 갱신 요건이나 절차의 설정 여부와 운용 실태, 근로자에게 책임 있는 사유가 있는지 등 근로관계를 둘러싼 여러 사정을 종합하여 갱신 거부의 사유와 절차가 사회통념에 비추어 볼 때 객관적이고 합리적이며 공정한지를 기준으로 판단하여야 하고, 그러한 사정에 관한 증명책임은 사용자가 부담한다(대법원 2019. 10. 31. 선고 2019두45647 판결 참조).

패소 이유 (사실관계에 관한 인정 차이)

이 사건은 고령근로자의 갱신기대권에 관한 것으로, 특히 갱신거절에 합리적 이유가 있는지 여부에 관해 중노위의 결론을 2심 법원이 뒤집었다는 것이 핵심이다. 즉 지노위, 중노위, 1심 법원은 갱신거절에 합리적 이유가 없다고 보아 부당해고로 본 반면, 2심 법원은 합리적 이유가 있다며 부당해고가 아니라고 판결하였고 대법원 심리불속행 기각 판결을 내리며 이대로 확정되었다.

중노위는 “▲이 사건 근로자가 노사협의회회 재고용에 관한 결정사항과 관련하여 고액의 검사비용을 근로자가 부담하는 것에 대해 이의를 제기한 사실은 있으나 재고용에 대해 거부한 것으로 보이지는 않는다 ▲ 사용자가 이 사건 근로자의 건강검진에 대해 이의 제기를 이유로 재고용 절차를 진행하지 않은 것은 합리적 이유가 있다고 볼 수 없다 ▲ 사용자는 근로자가 재고용 의사를 밝히지 않아 재고용 절차를 안내하지 않았다고 하나, 근로자의 2019. 8. 1.과 8. 22. 두 번에 걸친 재고용 요구가 있었음에도 재고용 절차를 진행하지 않았다”는 점에 주목하여, 갱신거절에 합리적 이유가 없어 부당해고라고 판정하였다.

그러나 2심 법원은 ‘▲단체협약이 1~5년차 촉탁직 근로계약에 관해서는 ‘재고용을 원칙으로 한다’라고 규정하고 있는 것과 달리, 6년차 이후의 촉탁직 근로계약에 관해서는 아무런 내용도 규정하지 않았고, 취업규칙에도 규정이 없다. 오직 2017년 12월의 노사협의회 결정만이 이에 관하여 정하고 있는데, 그 내용은 ‘근로자 부담으로 MRA 검사 및 심장초음파 검사를 하고 검진 결과표에 이상이 없을 시 재고용여부를 결정한다’는 것이다. 이에 의하면 6년차 촉탁직으로 근무하기 위해서는 건강 상태가 양호할 것이 가장 중요한 조건이 되고, 특히 MRA 검사와 심장초음파 검사 결과에서 아무런 이상이 없을 것이 요구되므로, 이러한 요건을 충족하였는지 여부는 갱신거절의 합리성 유무를 판단하는 데에 가장 중요한 기준이 된다. ▲“㉠ 참가인은 MRA 등 검사

부록.1. 주요 사건 경과 및 패소 원인 분석

를 의무화한 2017. 12월의 노사협의회 결정에 반발하며 SNS에 반대 글을 올린 사실이 있으므로 위 결정에 관하여 상세히 알고 있었다고 보인다. ㉠ 원고는 2019. 3. 15. 6년차 근로계약 체결을 위해서는 MRA 등 검사 결과 제출이 반드시 필요함을 공고하였다. ㉡ 참가인과 갱신 불희망자를 제외한 5년 만료자들은 모두 MRA 검사 및 심장초음파 검사 결과를 제출하였다. 참가인은 2019. 6. 30.까지 정상적으로 출근하였고, 회사나 주변 동료들 통해 6년차 근로계약 체결에 필요한 서류가 무엇인지 쉽게 확인할 수 있는 상황에 있었다고 보인다. ㉢ 원고가 2019. 6. 3. 이 사건 통보를 하며 참가인에게 교부한 통보서에는 재고용을 위해서는 건강에 관한 서류를 제출해야 함이 명시되어 있다”는 등의 사정을 종합하면, 참가인은 6년차 근로계약 체결을 위해서는 MRA 검사와 심장초음파 검사 결과를 제출해야 한다는 점을 충분히 알고 있었다고 인정되는데도, 5년차 근로계약 만료일까지 이를 제출하지 않았으므로, 6년차 근로계약 체결의 가장 중요한 요건을 충족하지 못하였다. ▲ 참가인은 5년차 근로계약이 만료된 이후 두 차례에 걸쳐 원고에게 재고용 희망 의사를 표시하였으나, MRA 등 검사 결과를 함께 제출하지 않았을 뿐만 아니라 이는 근로계약기간이 만료된 후의 사정에 불과하여 갱신거절의 합리성 판단에 고려할 사정이 되지 않는다. ▲ 고령운전자의 건강상의 문제에 따른 사고 위험을 예방하기 위하여 건강상태를 갱신 기준으로 삼는 것은 타당성이 인정되고, MRA 검사와 장초음파 검사는 높은 비용에도 불구하고 고령운전자에게 특히 문제되는 뇌혈관이나 심장 질환을 파악하는 데 기여하는 검사 방법에 해당한다. … 비록 회사가 요구하는 검사 비용을 근로자에게 부담하도록 하는 것이 바람직하지는 않으나 위 검사 비용의 근로자 부담은 근무기간 연장을 얻기 위해 근로자 측이 먼저 요청한 사항으로 보인다. … 근로자 비용으로 MRA 검사와 심장초음파 검사를 받을 것을 갱신의 요건으로 삼은 것이 불합리하다고 볼 수는 없다”는 점 등을 이유로, 회사의 갱신거절에 합리적 이유가 있어 부당해고가 아니라며 재심판정 및 1심 판결을 취소하였다.

대법원은 여러 판결을 통해, 정년이 지난 기간제 근로자, 소위 ‘촉탁직 근로자’의 근로계약 갱신기대권 존부 및 갱신거절의 합리성 여부와 관련하여, 일반적인 기간제 근로자와 약간 다른(내지 다소 완화된) 판단기준을 적용하여 왔다. 중노위가 이 사건 판정에 있어 대법원의 판례 법리에 관한 검토가 충분히 이루어지지 못한 것으로 보인다. 더욱이 이 사건 근로자가 공중의 안전과 직결되는 시내버스 기사였다는 점에서 대법원이 제시하는 판단 요소들 - 목적과 성격, 사업장 여건, 근로자의 지위와 담당 직무의 내용 등 - 에 관한 고려가 다소 미흡했던 것으로 보인다.

일련번호	2022-59					
판결번호	대법원 4. 14. 선고 2022두00000 판결					
중노위판정번호	중노위 2019. 4. 22. 중앙2019부해202					
사건 종류	부당해고					
세부 쟁점	기간제근로자, 계속근로기간, 무기계약근로자 전환					
심급별 소송결과	1심 법원	재심판정유지	2심 법원	항소 인용	대법원	심리불속행기각
상 고 인	중앙노동위원회위원장		참 가 인		목○○	
피상고인	경기도(경기도교육청)		피고측 대리인 선임 여부		선임 안 함	
노동조합 지원 여부	없음		원고측 대리인 선임 여부		선임 함	
재심 결과	초심 유지					

초심의 대법원 판례 일치여부	불일치	재심의 대법원 판례 일치여부	불일치
기타 특이사항			

주요 사실관계 <사건 개요> 가. 참가인은 원고(경기도교육청)의 관할 아래에 있는 □□초등학교에서 2011. 3. 1.부터 2012. 2. 28.까지 영어회화 전문강사로 근무하다가, 2012. 3. 1. 같은 관할 아래의 ○○초등학교(이하 '이 사건 학교'라고 한다)에서 영어회화 전문강사로 채용되었고, 그때부터 1년 단위로 재계약을 체결하면서 근무를 계속하였다. 나. 이 사건 학교는 참가인의 근무기간이 4년이 다 되어갈 무렵에 2016학년도 영어회화 전문강사 신규채용절차를 실시하였고, 2015. 12. 22.경 참가인을 최종합격자로 선발하였다. 그러나 원고가 2016. 1.경 '2016년 영어회화 전문강사 운영계획'을 통하여 영어회화 전문강사의 영어공인 인증시험 자격 기준을 '토익 스피킹 시험 150점'으로 상향함에 따라 참가인이 위 자격 기준에 미달하는 문제가 발생하였다. 다. 그러자 이 사건 학교는 참가인의 채용을 일단 보류하고 다시금 신규채용절차를 진행하되, 만일 참가인이 2016. 2. 26.까지 위 자격 기준에 부합하는 영어시험 점수를 취득하고 위 신규채용절차에 지원자가 아무도 없는 경우에는 앞서 선발된 참가인을 그대로 채용하기로 결정하였다. 이에 참가인은 2016. 2. 20.자 토익 스피킹 시험에서 150점을 취득하여 2016. 2. 26.경 이 사건 학교에 통보하였고, 이 사건 학교는 진행 중이던 신규채용절차를 중단하고 참가인을 2016. 3. 1.자로 다시 채용하였다. 그 뒤로 참가인은 이 사건 학교에서 재계약을 거듭하여 2018. 2. 28.까지 계속 근무하였다. 라. 그 사이에 원고는 2018. 1. 4. '2018학년도 영어회화 전문강사 자격 기준 변경 안내'를 통하여 '토익 스피킹 시험 점수가 150점 이상 160점 미만인 사람은 일단 2018. 8.까지만 채용하고, 위 기간 동안 토익 스피킹 시험 점수를 160점 이상 취득하였을 시에 2018. 9.부터 재계약한다'는 취지로 자격 기준을 상향 조정하였다. 마. 이에 따라 이 사건 학교는 2018. 2. 13. 참가인과 사이에 계약기간을 2018. 3. 1.부터 2018. 8. 31.까지로 정한 근로계약을 체결하였으나, 참가인은 위 계약기간 동안에 토익 스피킹 시험 점수를 160점 이상 획득하지 못하였다. 그러자 이 사건 학교는 참가인에게 이 사건 근로계약의 계약기간이 2018. 8. 31.자로 만료되었으니 계약관계를 종료한다는 취지의 통보를 하였다. 바. 참가인은 이 사건 통보가 부당한 해고라고 주장하며 경기지방노동위원회에 구제 신청을 하였다. <심급별 결과> [경기지노위] '참가인은 원고의 관할 아래에 있는 각 초등학교에서 2011. 3. 1.부터 근로의 단절 없이 영어회화 전문강사로서 동일한 업무를 수행하였고, 도중에 신규채용절차를 거쳤다는 사정만으로 채용 전·후의 근로관계가 단절되었다고 보기 어렵다. 따라서 4년이 경과한 2015. 3. 1. 이 미 기간제법 제4조 제2항에 따라 기간의 정함이 없는 근로계약을 체결한 근로자의 지위로 전환되었다'는 것을 이유로 이 사건 통보가 부당해고에 해당한다는 취지로 구제신청을 인용 [중노위] 초심판정과 같은 이유로 원고의 재심신청을 기각. 초심 유지 [1심 법원] 재심판정의 정당성 인정 [2심 법원] 신규채용 절차를 통해 계속근로기간이 단절되었으므로, 원고가 기간제법에 따른 무기

계약직 전환 대상이 아니라는 이유로 1심 법원 판단 취소.
[대법원] 심리불속행기각(2심 법원 판단 유지)

판결 요지

가. 1차 신규채용절차에 의하여 계속근로기간이 단절되는지 여부

1차 신규채용절차는 사전에 일반에 공고되었고, 1차 서류심사와 2차 교수·학습과정안 작성, 수업실연, 면접 등의 절차를 거쳐 최고 득점자를 선발하는 방식으로 이루어진 점, 참가인은 광정초등학교의 영어회화 전문강사로 근무하다 이 사건 학교의 위 채용절차에 지원하여 선발된 것인 점 등을 고려하면, 1차 신규채용절차에서 객관적이고 합리적인 기준에 따라 실질적인 경쟁이 이루어졌다고 평가할 수 있다. 따라서 원고와 참가인 사이에는 2012. 3. 1.자로 새로운 근로관계가 형성되었고, 종전에 참가인이 광정초등학교에서 근무한 기간(2011. 3. 1. ~ 2012. 2. 28.)은 참가인의 계속근로기간에서 제외된다.

나. 2차 신규채용절차에 의하여 계속근로기간이 단절되는지 여부

2차 신규채용절차에서도 객관적이고 합리적인 기준에 따라 실질적인 경쟁이 이루어졌다고 평가할 수 있고(홈페이지를 통한 공개 채용 공고, 시험과 공개시연 등 전형 절차, 실질적인 경쟁 존재, 채점위원들의 평가점수를 반영한 객관적 최종 합격자 결정,), 참가인이 주장하는 사정만으로는 2차 신규채용절차가 기간제법 제4조 제2항의 적용을 회피하기 위한 의도로 이루어진 형식적인 절차에 불과하다고 할 수 없으므로 이로 인하여 원고와 참가인 사이에는 새로운 근로관계가 형성되었다고 보아야 한다. 결국 참가인의 계속근로기간은 2016. 3. 1.자로 단절되었고, 그 전의 계속근로기간(2012. 3. 1. ~ 2016. 2. 29.)과 그 후의 계속근로기간(2016. 3. 1. ~ 2018. 8. 31.) 모두 4년을 초과하지 아니하므로 참가인에게는 일정한 기간을 초과하여 계속 근로한 근로자를 기간의 정함이 없는 근로자로 간주하는 기간제법 제4조 제2항이 적용되지 아니한다.

다. 이 사건 통보 당시 참가인의 계속근로기간은 4년을 초과하지 아니하므로 이 사건 통보는 해고에 해당하지 않는데도, 이 사건 통보가 해고에 해당한다고 본 이 사건 재심판정은 위법하다.

패소 이유 (동일한 사실관계에 대한 법리 적용과 관련된 판단의 차이)

기간제근로자의 계속근로기간 산정에 있어서, 기간제근로자를 계속 채용하게 된 원인이 되는 신규채용절차에 의한 계속근로기간의 단절을 인정할 것인가가 쟁점이 된 사안이다. 신규채용절차가 실질적 경쟁이 있고, 구제신청 근로자가 탈락할 수 있는 전형절차로서 객관적으로 진행된 절차라면, 그러한 절차를 거쳐 채용이 지속되었다 하더라도 신규채용으로 인정할 수 없다는 것이 법원의 판단 근거이다.

이와 관련해서는 이미 “기간제 근로계약의 대상이 되는 업무의 성격, 기간제 근로계약의 반복 또는 갱신과 관련한 당사자들의 의사, 반복 또는 갱신된 기간제 근로계약을 전후한 기간제근로자의 업무 내용·장소와 근로조건의 유사성, 기간제 근로계약의 종료와 반복 또는 갱신 과정에서 이루어진 절차나 그 경위 등을 종합적으로 고려할 때 당사자 사이에 기존 기간제 근로계약의 단순한 반복 또는 갱신이 아닌 새로운 근로관계가 형성되었다고 평가할 수 있는 특별한 사정이 있는 경우에는 기간제근로자의 계속된 근로에도 불구하고 그 시점에 근로관계가 단절되었다고 보아야 하고, 그 결과 기간제법 제4조에서 말하는 ‘계속 근로한 총기간’을 산정할 때 그 시점을 전후한 기간제 근로계약기간을 합산할 수 없다(대법원 2020. 8. 20. 선고 2018두51201 판결)”는 기본 법리가 형성되어 있었으므로, 동일한 사실관계에 대한 법리 적용과 관련된 판단의 차이가 패소의 원인이라고 보인다.

다만, 1심 법원도 노동위원회와 같은 판단을 하고 있으므로, 충분히 다른 판단이 가능했던 사안이라고 이해할 수도 있다. 다만, 항소심 패소 이후 대법원에 상고할 이유는 없었다고 판단된다. 2심 법원의 판결문을 통해 대법원에 상고하는 경우에도 승소 가능성이 크지 않다는 점을 확인할 수 있기 때문이다. 상고 여부에 대한 전문적이고 신중한 판단이 선행되어야 한다는 지적이 가능할 것이다.

일련번호	2022-61					
판결번호	서울행정법원 2022. 7. 22. 선고 2020구합00000 판결					
중노위판정번호	중노위 2020. 9. 29. 2020차별14					
사건 종류	차별, 기간제, 비교대상					
세부 쟁점	기간제근로자의 계속근로기간 산정, 갱신기대권					
심급별 소송결과	1심 법원	재심판정취소	2심 법원		대법원	
원 고	한국○○○○서비스(주)		참 가 인		박○○	
피 고	중앙노동위원회위원장		피고측 대리인 선임 여부		선임 안 함	
노동조합 지원 여부	없음		원고측 대리인 선임 여부		선임 함	
재심 결과	초심 유지					
초심의 대법원 판례 일치여부	불일치		재심의 대법원 판례 일치여부		불일치	
기타 특이사항						

주요 사실관계

<사건 개요>

가. 원고는 한국○○○○와 통행료 수납 업무 도급계약을 체결한 용역업체 소속 요금수납원들을 정규직으로 고용하기 위한 목적으로 설립되어 유료도로 및 관련 시설 이용료의 수납업, 도로 및 관련 시설 운영업 등을 영위하는 회사이며, 피고보조참가인(이하 '참가인')은 2019. 7. 1. 원고 회사에 기간제 근로자로 입사하여 2020. 1. 31.까지 D영업소에서 요금수납원으로 근무하였다.

나. 원고는 한국○○○○의 자회사로서 정부의 공공부문 비정규직 근로자 정규직 전환가이드라인 발표에 따른 정규직 채용을 시도했는데, 정규직 전환 대상자 1,425명이 입사를 거부하여 통행료 수납업무에 지장이 발생하자, 정원 미충원으로 부족해진 인력을 임시로 대체하기 위하여 기간제 근로자를 채용하여 요금수납원으로 근무하게 하였다.

다. 참가인은 2019. 6. 28. 원고와 계약기간이 3개월(2019. 7. 1. ~ 2019. 9. 30.)인 근로계약을 체결하였고, 그 후 근로계약을 2차례 갱신하여 2020. 1. 31.까지 근무하였다.

라. 참가인은 한국○○○○의 용역업체인 G에서 2009. 1. 1.부터 2010. 12. 31.까지, 주식회사 H에서 2018. 10. 1.부터 2018. 12. 31.까지, 주식회사 I에서 2019. 1. 1.부터 2019. 6. 30.까지 합계 33개월 동안 요금수납원으로 근무하였다. 참가인은 2019. 7.부터 2019. 12.까지 기본급 2,006,400원을, 2020. 1. 기본급 2,072,610원을 각 지급받았다.

마. 정규직 전환 대상자 F은 한국○○○○의 용역업체인 주식회사 J에서 2015. 3. 23.부터 2017. 12. 31.까지, K에서 2019. 3. 22.부터 2019. 6. 30.까지 요금수납원으로 근무하였다. F은 입사 전 용역업체 근무기간 약 3년을 경력으로 인정받아 2019. 7. 1. 7급 2단계(2020. 1. 29. 보수 및 복리후생 규정 개정 전, 이하 승급단계를 위 규정의 개정 전 · 후에 따라 '개정 전' 또는 '개정 후'라고 한다) 정규직 근로자로 전환되었다.

바. F은 2019. 7.부터 2019. 12.까지 기본급 2,043,000원, 상여수당 170,250원을, 2020. 1. 7급 3단계(개정 후) 기본급 2,110,410원, 상여수당 175,860원을 각 지급받았다.

사. 정규직 전환 대상자 E은 입사 전 용역업체 근무기간 10개월 29일을 경력으로 인정받았으나 기간이 2년 미만이었어서 2019. 7. 1.부터 7급 1단계(개정 전) 정규직근로자로 전환되었다. E은 2019. 7.부터 2019. 12.까지 기본급 2,003,000원, 상여수당 166,910원을, 2020. 1. 7급 2단계(개정 후) 기본급 2,069,090원, 상여수당 172,420원을 각 지급받았다.

아. 참가인은 원고가 비교대상 근로자와 달리 자신에게 상여수당과 복지포인트를 지급하지 않은 것은 차별적 처우에 해당한다고 주장하면서 2020. 2. 18. 부산지방법노동위원회에 시정을 신청하였다.

<심급별 결과>

[부산지노위] 원고가 참가인에게 상여수당을 지급하지 않은 것은 차별적 처우임을 인정하고 원고에게 상여수당에 상당하는 손해액 1,175,910원을 배상하도록 명하였으나, 복지포인트의 차별에 대한 시정신청은 제척기간이 도과하였다는 이유로 각하

[중노위] 재심신청 기각

[1심 법원] 이 사건 재심판정 중 상여수당에 관한 부분은 비교대상 근로자를 E가 아닌 F으로 선정하고 F의 상여수당을 기준으로 손해액을 1,175,901원으로 산정한 이 사건 초심판정의 배상명령을 유지하여 위법하다는 이유로 취소함

판결 요지

1) 비교대상 근로자

비교대상 근로자로 선정된 근로자의 업무가 기간제 근로자의 업무와 동종 또는 유사한 업무에 해당하는지 여부는 취업규칙이나 근로계약 등에 명시된 업무내용이 아니라 근로자가 실제 수행하여 온 업무를 기준으로 판단하되, 이들이 수행하는 업무가 서로 완전히 일치하지 아니하고 업무의 범위 또는 책임과 권한 등에서 다소 차이가 있다고 하더라도 주된 업무의 내용에 본질적인 차이가 없다면 특별한 사정이 없는 이상 이들은 동종 또는 유사한 업무에 종사한다고 보아야 할 것이다(대법원 2014. 11. 27. 선고 2011두5391 판결 등 참조).

(1) 이 사건 재심판정이 기간제 요금수납원인 참가인의 비교대상 근로자로 정규직 요금수납원이 존재한다고 본 것은 타당하다.

(가) 정규직 요금수납원과 기간제 요금수납원의 주된 업무는 통행료수납 업무로서 동일하다.

(나) 원고는 기간제 근로자는 정규직 근로자와 달리 통행료 수납 업무만 담당하고 추가적인 행

정 업무는 수행하지 않았다는 취지로 주장한다. 그러나 참가인을 비롯한 기간제 근로자도 통행료 수납 업무 외에 제한차량 단속 업무, 민원 처리 업무, 미납 안내 업무 등을 추가로 수행한 사실이 인정된다.

(다) 정규직 근로자인 E이 기간제 근로자와 달리 주임(6급) 업무대행자로 지정되어 주임 업무 공백 시 주임이 하는 업무를 대신 수행한 사실은 인정된다. 그러나 주임 업무대행자로서의 업무는 주임 업무공백 시에만 일시적·부수적으로 수행하는 업무에 불과하므로 이러한 사정만으로 기간제 근로자와 정규직 근로자의 주된 업무에 본질적인 차이가 있다고 할 수 없다.

(라) 원고는 정부의 공공부문 비정규직 근로자 정규직 전환 가이드라인에 따라 용역업체 소속 요금수납원들 중 정규직 전환 대상에 해당하는 근로자들은 정규직으로 전환하고, 정규직 전환 대상에 해당하지 않는 근로자들은 기간제로 채용하였는바, 정규직 전환 이후 요금수납원들이 담당하는 업무가 본질적으로 변화하였을 것으로는 보이지 않는다. 한편 기간제 요금수납원들은 정규직 전환 대상자 중 입사 거부자들의 업무를 임시로 대체하기 위하여 채용된 점에 비추어 보더라도 정규직 근로자와 담당 업무가 본질적으로 다르다고 보기 어렵다.

(2) 참가인의 비교대상 근로자는 7급 2단계 정규직 근로자 F이 아니라 7급 1단계 정규직 근로자 E이라고 봄이 타당하다.

(가) 참가인의 입사 전 용역업체 근무기간은 비교대상 근로자 선정 시 고려대상이 될 수 없다. 따라서 참가인의 비교대상 근로자는 정규직 근로자 중 초임에 해당하는 7급 1단계(개정 전) 근로자로 선정함이 타당하다.

(나) 상여수당은 직급 및 승급단계별 기본급을 12개월로 나눈 금액으로 지급되어 7급 2단계인 F은 7급 1단계인 E보다 상여수당을 더 많이 지급받았다. F을 참가인의 비교대상 근로자로 선정할 경우 동종의 업무를 하는 정규직 근로자인 E이 기간제 근로자인 참가인보다 불이익을 받게 되는 역차별이 발생할 우려가 있으므로, 이 사건 재심판정이 F을 참가인의 비교대상 근로자로 선정한 것은 부당하다.

(다) 이에 대하여 참가인은, E의 급여명세서(갑 제9호증)에 직급이 '사원'이 아닌 '주임(7급)'으로 기재되어 있는 점, E은 주임이나 팀장에게만 부여되는 고유ID를 부여받은 점 등에 비추어 볼 때, E은 현장 근로자가 아니라 사무직 근로자이므로 참가인의 비교대상 근로자가 될 수 없다고 주장한다. 그러나 ... 사무직 근로자가 아닌 요금수납원도 주임 업무대행자로 지정되고 고유 ID를 부여받은 것으로 보인다. 이에 비추어 보면, 참가인이 주장하는 위와 같은 사정만으로 E이 사무직 근로자에 대하여 비교대상 근로자가 될 수 없다고 볼 수 없다.

2) 불리한 처우의 존재 여부

기간제 근로자가 기간제 근로자임을 이유로 임금에서 비교대상 근로자에 비하여 차별적 처우를 받았다고 주장하며 차별 시정을 신청하는 경우, 원칙적으로 기간제 근로자가 불리한 처우라고 주장하는 임금의 세부 항목별로 비교대상 근로자와 비교하여 불리한 처우가 존재하는지를 판단하여야 한다. ... 이러한 경우 임금의 세부 항목이 어떤 범주에 속하는지는, 비교대상 근로자가 받은 항목별임금의 지급 근거, 대상과 그 성격, 기간제 근로자가 받은 임금의 세부 항목 구성과 산정 기준, 특정 항목의 임금이 기간제 근로자에게 지급되지 않거나 적게 지급된 이유나 경위, 임금 지급 관행 등을 종합하여 합리적이고 객관적으로 판단하여야 한다(대법원 2019. 9. 26. 선고 2016두47857 판결 참조).

다음과 같은 사정들을 종합하여 보면, 참가인에게 불리한 처우가 존재한다고 봄이 타당하다.

(1) 참가인과 비교대상 근로자인 E에게 2019. 7.부터 2020. 1.까지 지급된 임금의 세부 항목을 비교하면, 기본급, 연장수당, 야간수당, 휴일수당, 특별성과금은 양쪽 모두 지급되었고, 상여수당은 비교대상 근로자에게만 지급되었다. 참가인은 비교대상 근로자와 비교할 때 상여수당을 지급받지 못하여 상여수당 항목에서는 불리한 처우를 받았으나, 기본급은 비교대상 근로자 보다 높게 설정되어 있어 기본급 항목에서는 유리한 대우를 받았다. 따라서 이 사안은 임금의 세부 항목별로 비교하는 것이 곤란하거나 적정하지 않은 경우에 해당하므로, 참가인에게 불리한 처우가 존재하는지 여부는 임금의 세부 항목들을 범주별로 구분하고 각 범주별로 참가인이 받은 임금 액수

와 비교대상 근로자가 받은 임금 액수를 비교하여 판단하여야 한다.

(2) 참가인이 매월 지급받은 기본급은 2019. 7.부터 2019. 12.까지는 2,006,400원이고, 2020. 1.은 2,072,610원이다. 반면 비교대상 근로자인 E이 매월 지급받은 기본급과 상여수당의 합산액은 2019. 7.부터 2019. 12.까지는 2,169,910원(= 기본급 2,003,000원 + 상여수당 166,910원)이고, 2020. 1.은 2,241,510원(= 기본급 2,069,090원 + 상여수당 172,420원)이다. 이처럼 참가인이 지급받은 기본급과 비교대상근로자가 지급받은 기본급 및 상여수당을 합한 금액을 비교해 보면, 참가인에게 불리한 처우가 존재한다.

3) 합리적인 이유가 있는지 여부

합리적인 이유가 없는 경우란 기간제 근로자를 달리 처우할 필요성이 인정되지 않거나, 달리 처우할 필요성이 인정되더라도 그 방법·정도 등이 적정하지 않은 것을 뜻한다. 합리적인 이유가 있는지는 개별 사안에서 문제가 된 불리한 처우의 내용과 사용자가 불리한 처우의 사유로 삼은 사정을 기준으로, 급부의 실제 목적, 고용형태의 속성과 관련성, 업무의 내용과 범위·권한·책임, 노동의 강도·양과 질, 임금이나 그 밖의 근로조건 등의 결정요소 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다(대법원 2019. 9. 26. 선고 2016두47857 판결 참조).

다음과 같은 사정들을 종합하여 보면, 원고가 참가인이 지급받은 기본급과 그에 대응하여 비교대상 근로자가 지급받은 기본급과 상여수당을 합한 금액에 차이를 둔 것은 합리적인 이유가 있다고 볼 수 없다.

(1) 참가인과 비교대상 근로자 사이에 업무의 내용, 업무량, 업무강도 등에 본질적인 차이가 없음은 앞에서 판단하였으므로, 소정 근로의 대가로서 지급되는 기본급 및 상여수당의 지급에 있어서 양자를 달리 취급할 특별한 이유를 찾기 어렵다.

(2) 상여수당은 정규직 전환 대상자의 입사 유인 필요성이 있던 시기에만 한시적으로 지급된 것이 아니라 2019. 7.부터 모든 정규직 근로자에게 일괄하여 지속적으로 지급된 점, 원고는 공개채용 절차를 통해 채용되어 입사 유인의 필요성이 없는 정규직 근로자들에게도 상여수당을 지급한 점 등에 비추어 보면, 정규직 전환 대상자의 입사 유인 필요성과 상여수당의 지급 사이에 직접적인 관련성이 있다고 보기 어렵다. 설령 상여수당이 입사 거부자들에 대한 입사 유인책으로 신설되었다고 하더라도 이후 상여수당이 정규 수당화가 된 이상 이를 기간제 근로자와의 차별을 합리화할 수 있는 사유가 된다고 보기 어렵다. 따라서 정규직 전환 대상자에 대한 입사 유인의 필요성이 있었다는 사정은 차별의 합리적 이유가 된다고 보기 어렵다.

패소 이유 (동일한 사실관계에 대한 법리 적용과 관련된 판단의 차이)

기간제근로자에 대한 기본급, 상여금 등에 대한 차별이 다루어진 사건으로서 비교대상 근로자 선정, 차별적 처우의 합리적 이유 등에 대한 법리 판단에서 노동위원회와 법원 사이에 견해가 갈렸던 사건이다. 특히 가장 주된 쟁점은 비교대상 근로자의 선정이라고 보인다. 비교대상 근로자 선정에 있어서도 경력 반영 여부에 대한 판단이 주된 쟁점이 되었다.

최근 ○○의료원 사건(대법원 2023.11.30. 선고 2019두00000 판결)에서 대법원은 당사자의 주장에도 불구하고 노동위원회가 비교대상 근로자를 직권으로 변경할 수 있다고 판단했다. 이 사건에서는 법원이 노동위원회와 당사자의 비교대상 근로자 선정이 잘못되었다는 판단을 하고 있다. 비교대상 근로자 선정은 객관적 법원칙에 따라 판단되어야 할 문제라는 것을 우리 법원이 분명히 하고 있다는 의미로 이해할 수 있을 것이다.

이 사안은 차별 판단의 기본적인 법논리적 체계에 대한 이해의 부족에서 비롯된 것으로 보이며, 역시 공익위원의 전문성을 강화하는 것이 시급하다는 사실을 보여준다. 노동위원회가 항소하지 않고 그대로 패소 확정된 것은 합리적인 판단이라고 생각된다.

일련번호	2022-63					
판결번호	서울고등법원 2022. 7. 14. 선고 2022누00000					
중노위판정번호	중노위 2020. 12. 16. 2020부해1475					
사건 종류	부당징계(강등)					
세부 쟁점	징계사유 존부, 징계시효, 징계 양정의 적정성					
심급별 소송결과	1심 법원	재심 취소	2심 법원	항소 기각	대법원	-
항 소 인	중앙노동위원회위원장		참 가 인		김○○	
피항소인	사단법인 한국○○○○○협회		피고측 대리인 선임 여부		선임 안 함	
노동조합 지원 여부	없음		원고측 대리인 선임 여부		선임 함	
재심 결과	초심취소					
초심의 대법원 판례 일치여부	일치		재심의 대법원 판례 일치여부		불일치	
기타 특이사항						

주요 사실관계 <사실관계> 참가인 근로자는 2017. 6. 27. 당시 원고 협회의 대표자이던 윤○○ 전 회장을 폭행 및 모욕 혐의로 형사고소 하였는데, 모욕사실에 대해서는 혐의 없음(범죄인정안됨)의 불기소처분이 내려졌고, 나머지 폭행에 대해서는 벌금 50만 원의 약식명령이 내려졌다. 2017. 11. 26.에는 연합뉴스에 ‘윤○○ 회장이 폭행 혐의로 벌금 50만 원에 약식기소 되었고, 일부 직원들은 회장이 직원들에게 상습적으로 폭언 하고 부당한 인사명령을 내리는 등 갑질을 했다고 감독기관에 탄원서를 제출하여 원고 협회가 업무점검을 받았다.’는 내용의 기사가 게재되기도 하였다. 이후 윤○○ 회장의 정식재판청구에 의한 정식재판 절차에서 제1심법원은 폭행 공소사실에 대하여 무죄를 선고하였고 판결이 그대로 확정되었다. 또한 참가인은 2019. 11.경 원고 협회의 현 대표자인 홍○○과 윤○○ 전 회장 및 법무전략국장, 사무총장, 사업본부장을 업무상 배임으로 고발하였는데, 2020. 2. 28. 이에 대하여 모두 혐의 없음의 불기소처분이 내려졌다. 그런데 참가인은 위 불기소처분에 불복하여 항고를 제기하였으나 2020. 4. 21. 항고기각 결정이 내려졌고, 자신에 대한 징계절차 개시 후인 2020. 5. 20. 고등법원에 재정신청까지 하였으나, 2020. 6. 26. 기각하는 결정이 내려졌다. 원고 회사는 2020. 5. 8. 참가인에게 인사위원회 출석하여 소명할 것을 통지하는 등 징계절차에 돌입하였고, 2020. 6. 5. 강등처분을 하였다. 참가인은 부당징계라며 구제신청을 하였다. <심급별 결과> [경북지노위] 근로자의 수차례 고소·고발이 모두 무죄, 무혐의 처분이 내려진 점, 징계전력이 있고 개전의 정이 보이지 않는 점 등에 비추어, 징계양정이 적정하다며 구제신청을 기각 [중노위] 징계 양정이 과하여 부당징계라며 초심을 취소

[1심 법원] 징계사유가 인정되고, 징계양정도 적정하다고 보아, 재심판정을 취소
[2심 법원] 항소 기각 ※ 상고하지 않음.

판결 요지

피징계자에게 징계사유가 있어서 징계처분을 하는 경우, 어떠한 처분을 할 것인 지는 징계권자의 재량에 맡겨져 있다. 다만 징계권자의 징계처분이 사회통념상 현저하게 타당성을 잃어 징계권자에게 맡겨진 재량권을 남용하였다고 인정되는 경우에 한하여 그 처분이 위법하다고 할 수 있다. 징계처분이 사회통념상 현저하게 타당성을 잃어 재량권의 범위를 벗어난 위법한 처분이라고 할 수 있으면 구체적인 사례에 따라 징계의 원인인 비위사실의 내용과 성질, 징계로 달성하려는 목적, 징계양정의 기준 등 여러 요소를 종합하여 판단할 때에 징계 내용이 객관적으로 명백히 부당하다고 인정되어야 한다(대법원 2017. 3. 15. 선고 2013두26750 판결 등 참조). 한편 징계처분이 재량권의 한계를 벗어난 것인지 여부를 판단함에 있어서는 피징계자의 평소의 소행, 근무성적, 징계처분 전력 이외에도 당해 징계처분사유 전후에 저지른 징계사유로 되지 아니한 비위사실도 징계양정에 있어서의 참고자료가 될 수 있으며(대법원 2004. 6. 25. 선고 2002다51555 판결 참조), 징계시효가 지난 비위행위도 징계양정에 있어서 참작자료로 할 수 있다(대법원 1999. 11. 26. 선고 98두10424 판결 등 참조)

패소 이유 (사실관계에 관한 인정 차이)

이 사건은 뚜렷한 증거 없이 직장 동료들을 계속적으로 고소, 고발하고, 민원을 제기하는 등의 행동을 한 근로자에 대해 ‘강등’의 징계처분을 한 회사의 조치가 ‘징계양정의 적정성’이 결여된 것인지가 쟁점이 된 사건이다.

중노위는 “폭행관련 고소는 검찰에서 구약식 벌금 처분을 하였고, 법원은 적어도 대표의 손이 근로자에게 닿았다고 판단한 점, 업무상 배임관련 고발은 협회의 부정한 운영을 시정하고 그에 대한 책임을 명확히 하여 향후 재발방지의 계기로 삼고자 하는 의도로 해석될 여지도 있는 점” 등의 사정에 주목하여, 강등은 해고 다음으로 무거운 징계로 사용자에게 맡겨진 징계재량권을 남용한 부당징계에 해당한다고 판단하였다.

그러나 법원은 근로자의 비위행위를 중노위보다 심각한 수준의 행위로 보았다. 법원은 “▲참가인은 뚜렷한 자료 없이 약 2년 5개월 동안 무려 5회나 임직원들을 상대로 고소·고발 또는 진정을 남발하였고, 모두 무죄 판결이 확정되거나 무혐의 처분이 내려졌다. 특히 이미 혐의 없음의 불기소처분이 내려진 상태에서 참가인에 대한 징계절차가 개시되었음에도 불구하고 위 불기소처분을 다투는 재정신청을 제기하기까지 하였다. 고소·고발 등 횡수와 그 내용, 원고와 임직원들이 위 고소·고발 사건에 대응하는 과정에서 소요된 비용과 시간 등 제반사정을 고려할 때, 원고의 비위행위는 고의 또는 아무리 가볍게 보아도 중과실에 의한 행위로서 그 비위정도도 매우 중한 것으로 판단된다. ▲참가인의 고소·고발 등 횡수와 그 내용, 무죄 판결 및 불기소처분의 이유를 면밀히 살펴볼 때, 참가인은 적법한 권리행사 내지 공익적인 목적에서 위와 같은 고소·고발 등 행위를 한 것으로 보기 어렵고, 원고 협회와 임직원들을 괴롭히고자 하는 의도가 다분히 엿보인다. ▲인사규정은 ‘인사위원회는 징계 혐의자의 비위의 유형, 비위의 정도 및 과실의 경중과 평소의 행실, 근무성적, 공적 등 관련 업무 처리의 적극성, 뉘우치는 정도 또는 그 밖의 정상 등을 참작하여 징계기준에 따라 징계사건을 의결하여야 한다.’고 규정하고 있다. 그런데 … 참가인은 자신의 잘못을 뉘우치는 것으로 보이지 않는다. … 참가인은 2018. 7. 3. ‘견책’의 징계처분을 받은 전력이 있는 반면, 장기근속상 외에 징계의 감경 사유로 인정될 만한 상을 받은 것으로 보이지 않는다. ▲인사규정 징계기준은 ‘4. 직장 질서유지 및 상호존중 위반’ 중 ‘다. 근거 없이 중상모략, 유언비어 등 유포한 때’의 징계사유인 경우 비위의 정도가 중하고 고의가 있는 경우에는 ‘해고’를, 비위의 도가 중하고 중과실인 경우는 ‘해고~강등’을 징계기준으로 정하고 있고, ‘12. 재산상 손해 및 협회 명예실추’ 중 ‘다. 협회의 신용과 명예를 실추시켰을 때’의 징계사유인 경우

비위의 정도가 중하고 고의가 있는 경우 ‘강등’을, 비위의 정도가 중하고 중과실인 경우 ‘정직~승급정지’를 징계기준으로 정하고 있다. … ‘인사위원회는 서로 관련 없는 둘 이상의 비위가 결합될 경우에는 그중 책임이 무거운 비위에 해당하는 징계보다 1단계 위의 징계로 의결할 수 있다.’고 규정하고 있다. … 징계기준에 따르면 참가인에 대해서는 ‘해고’까지 가능하였는바, 이 사건 강등 처분은 위 인사규정이 정한 징계양정기준에 부합한다”는 등의 이유로, 강등 처분이 사회통념상 현저하게 타당성을 잃어 징계권자에게 맡겨진 재량권을 남용한 경우에 해당하지 않는다”고 판단하였다.

이 사건은 강등이라는 조치가 참가인 근로자의 비위행위에 비해 과도한 것인지에 대한 사실관계 인정이 중요한 사건이었던 것으로 보인다. 근로자가 수년에 걸쳐 회사 동료들을 고소, 고발하였고, 그런데 이 것들이 대부분 법원 및 수사기관으로부터 무혐의, 무죄 처분을 받고 특별히 중한 처벌을 받지 않았다는 사실에 비추어, 중노위처럼 강등 조치를 위법한 것으로 평가하기에는 다소 무리가 있어 보인다.

일련번호	2022-70					
판결번호	대전고등법원 2022. 6. 10. 선고 2021누00000, 2021누00000					
중노위판정번호	중노위 2020. 9. 21. 중앙2015단위15					
사건 종류	교섭단위 분리					
세부 쟁점	고용형태, 근로조건, 교섭관행					
심급별 소송결과	1심 법원	재심판정취소	2심 법원	1심 유지	대법원	
원고, 피항소인	○○○도교육청		참 가 인		전국공립학교호봉제회계직노동조합	
피고, 항소인	중앙노동위원회위원장		피고측 대리인 선임 여부		선임 안 함	
노동조합 지원 여부	있음		원고측 대리인 선임 여부		선임 함	
재심 결과	초심취소					
초심의 대법원 판례 일치여부	일치		재심의 대법원 판례 일치여부		불일치	
기타 특이사항						

주요 사실관계

<사건 개요>

가. 참가인 노동조합은 2019. 10. 7. 설립되어 전국 교육청 산하 각급 학교에 근무하는 C 근로자를 조직대상으로 하여 설립된 전국공공운수사회서비스노동조합(이하 ‘참가인 노동조합’)이다. 원고는 ○○○도교육청(이하 ‘교육청’)이다. 현재 원고 교육청 소속 C 근로자 중 31명이 참가인 노동조합에 가입하여 활동하고 있다.

나. 2020. 5.경을 기준으로 원고와 근로계약을 체결하고 원고 교육청 산하 각급 학교에서 근무하

는 교육공무직 근로자는 6,099명으로, 그중 C 근로자는 70명이다. 원고 소속 교육공무직 근로자들은 참가인 노동조합과 전국공립학교호봉제회계직노동조합 등 3개 노동조합에 가입하여 활동하고 있다.

다. 참가인 노동조합은 2020. 5. 15. 충북지방노동위원회에 C 근로자를 별도의 교섭단위로 분리해 달라고 신청하였다.

<심급별 결과>

[충북지노위] 근로조건과 고용형태 등의 현격한 차이가 없고, 이들을 분리하여 교섭한 관행도 존재하지 않으며, 교섭단위를 분리하여야 할 필요성이 인정되지 않는다는 이유로 분리신청 기각

[중노위] 근로조건과 고용형태의 현격한 차이가 있고, 별도의 교섭단위로 분리할 필요성이 인정된다는 이유로 교섭단위 분리 결정. 초심취소

[1심 법원] 근로조건과 고용형태 등의 현격한 차이가 없고, 이들을 분리하여 교섭한 관행도 존재하지 않으며, 교섭단위를 분리하여야 할 필요성이 인정되지 않는다는 이유로 교섭단위 분리 불인정. 재심판정 취소

[2심 법원] 1심 판결과 같은 결론의 판결. 교섭단위 분리필요성 부인

판결 요지

노동조합법 제29조의3 제2항에서 규정하고 있는 '교섭단위를 분리할 필요가 있다고 인정되는 경우'란 하나의 사업 또는 사업장에서 별도로 분리된 교섭단위에 의하여 단체교섭을 진행하는 것을 정당화할 만한 현격한 근로조건의 차이, 고용형태, 교섭 관행 등의 사정이 있고, 이로 인하여 교섭대표노동조합을 통하여 교섭창구를 단일화하는 것이 오히려 근로조건의 통일적 형성을 통해 안정적인 교섭체계를 구축하고자 하는 교섭창구 단일화 제도의 취지에도 부합하지 않는 결과를 발생시킬 수 있는 예외적인 경우를 의미한다(대법원 2018. 9. 13. 선고 2015두39361 판결 등 참조).

다음과 같은 사정들을 종합하면, 원고 소속 교육공무직 근로자들 중 C 근로자들을 다른 근로자들(G)과 별도의 교섭단위로 분리할 필요성이 인정되지 않는다. 이와 다른 전제에서 내려진 이 사건 재심결정은 위법하므로 취소되어야 한다.

C 근로자들의 근로조건이 그들을 별도의 교섭단위로 분리하여 단체교섭을 진행하여야 할 만큼 다른 교육공무직 근로자들의 근로조건과 현격히 다르다고 보기 어렵다. 구체적인 이유는 다음과 같다.

① 모두 기본급과 수당으로 구성된 임금체계를 가지고 있는데, 기본급의 액수가 다소 차이 나는 것은 사실이다. 그러나 C 근로자들이 근속연수에 따른 호봉 승급으로 기본급이 증가하는데 갈음하여 다른 교육공무직 근로자들은 근속연수에 따라 최대 월 700,000원의 근속수당을 지급받으므로, 비슷한 경력의 근로자들 사이에서는 월 평균 임금 수준에서 현격한 차이가 나타나지 않는다. ② C 근로자들과 다른 교육공무직 근로자들 모두 동일한 연장·야간·휴일근로수당, 가족수당, 자녀학비보조수당, 정기상여금 및 비슷한 수준의 정액급식비, 맞춤형복지비를 지급받는다. C 근로자들만 지급받는 수당과 다른 교육공무직 근로자들만 지급받는 수당이 일부 존재하기는 하나 그 명목이나 금액이 유사해 전체적인 임금체계에 현저한 차이가 있다고 보기는 어렵다. ③ C 근로자들과 다른 교육공무직 근로자들 모두 동일한 방식의 퇴직금 제도를 적용받고, 근로시간 및 휴게시간, 휴일, 휴가, 정년 등 복무와 관련된 근로조건도 동일하다.

2) C 근로자들의 고용형태 또한 그들을 별도의 교섭단위로 분리하여 단체교섭을 진행하여야 할 만큼 다른 교육공무직 근로자들의 고용형태와 현격히 다르다고 보기 어렵다. 구체적인 이유는 다

음과 같다. ① C 근로자들은 모두 무기계약직으로 행정실무사 직종에서 근무하고 있는 반면, 다른 교육공무직 근로자들은 무기계약직, 기간제, 시간제의 다양한 형태로, 행정실무사를 포함한 43개 직종에서 근무하고 있기는 하다. 그런데 2005년 이후 C 근로자의 신규 채용이 중단되면서 다른 교육공무직 근로자가 C 근로자의 업무를 대체해 왔고, C 근로자를 채용하던 때와 비교하여 공립학교의 교육 여건 변화 등으로 새로운 업무를 수행할 다양한 직종이 필요하였기 때문에 교육공무직 근로자들의 직종이 43개로 늘어나게 된 것인 점에 비추어, 호봉계획계직 근로자들의 고용형태나 직종은 다른 교육공무직 근로자들의 고용형태나 직종과 구분되는 것이 아니라 후자의 일부를 구성할 뿐이라고 할 것이다. 그렇다면 교섭단위를 분리하지 않더라도 전체 교육공무직 근로자들의 단체교섭 과정에서 C 근로자들의 고용형태와 직종에 따른 특성이 충분히 고려될 수 있다. ② C 근로자들과 다른 교육공무직 근로자들은 모두 학교장으로부터 복무관리 및 지휘감독을 받고, 정년이 만 60세로 동일하다. 특히 동일한 행정실무사 직종에 속하는 교육공무직 근로자라면 동일·유사한 업무를 수행할 뿐만 아니라, 상시 전일 근무하고 특별한 자격·면허가 요구되지 않는다는 점에서도 동일하며, 인사교류 역시 C인지 여부와 무관하게 이루어지고 있는 것으로 보인다.

C 근로자들이 2019. 10. 7. 참가인 노동조합을 설립하여 교섭단위 분리를 신청하기 전까지 C 근로자들만 별도로 분리하여 단체교섭을 진행하는 관행이 존재하였다고 볼 증거가 없다.

원고 산하 각급 학교에서 근무하는 교육공무직 근로자들은 참가인 노동조합, 원고공동소송참가인, D노동조합에 가입하여 활동 중이다. 그런데 참가인 노동조합만 별도의 교섭단위로 분리할 경우, 동일한 학교에서 근무하는 C 근로자들과 다른 교육공무직근로자들 사이에 서로 다른 단체협약이 체결될 수 있고, 이로 인해 노동조합 상호간 또는 노동조합과 사용자 사이의 갈등, 교섭효율성의 저하, 교섭비용 증대, 노무관리의 어려움 등이 초래될 우려가 있다.

참가인 노동조합의 교섭단위를 분리하지 않더라도 각 노동조합들이 교섭창구 단일화 절차를 거쳐 C 근로자의 의견을 수렴하여 단체교섭에 나선다면, 교섭대표노동조합은 노동조합법 제29조의4에 따라 공정대표의무를 부담하게 되므로 C 근로자들의 근로조건이 부당하게 악화될 것으로는 보이지 않는다. 실제로 C 근로자들 중 일부가 원고공동소송참가인과 D노동조합이 구성한 공동교섭대표단의 교섭위원으로서 단체교섭에 참여하는 등 C 근로자들의 이익을 대변하여 왔던 것으로 보인다.

동일한 사업장 소속 근로자라도 담당하는 업무의 특성에 따라 근로조건과 고용형태가 조금씩 다르게 나타날 수 있다. 그런데 근로조건과 고용형태에 다소간의 차이가 있다는 이유만으로 교섭단위 분리를 허용하게 되면, 복수 노동조합이 독자적인 단체교섭권을 행사할 경우에 발생할 수도 있는 문제점을 해결하고자 하는 교섭창구 단일화 제도가 사실상 형해화 될 위험이 있다.

폐소 이유 (사실관계에 관한 인정 차이)

동일한 사실관계에 대하여 판단이 서로 달랐던 사건이다. 교섭단위 분리 필요성 판단 요건으로 노동조합법 제29조의3 제2항에 규정되어 있는 하나의 사업 또는 사업장에서 별도로 분리된 교섭단위에 의하여 단체교섭을 진행하는 것을 정당화할 만한 현격한 근로조건 차이, 고용형태, 교섭 관행 등에 대하여 동일한 사실관계가 제시되었으나, 초심 판정, 재심판정의 판단이 각각 달라졌다. 초심 판정의 판단이 오히려 그간 대법원의 판단과 일치하였다고 볼 수 있으며, 중노위 재심판정 과정에서 기존 대법원의 판단과 다른 결론이 도출되었다.

이는 공익위원의 전문성에 상당부분 기인한다고 볼 수 있다. 대법원은 교섭단위 분리 요건을 판단함에 있어, 노동조합법 제29조의3 규정 문구에 충실하게 판단하면서도 해당 사업 또는 사업장 노사관계 전체에 미치는 영향, 기존 노사관계의 특질 등을 종합적으로 고려하고 있는바 매우 전문적인 판단이 요구된다.

부록.1. 주요 사건 경과 및 패소 원인 분석

일련번호	2022-71					
판결번호	서울고등법원 2022. 8. 17. 선고 2022누00000					
중노위판정번호	중노위 2020. 11. 16. 2020부해1062					
사건 종류	부당해고					
세부 쟁점	당사자적격(근로기준법상 근로자에 해당하는지)					
심급별 소송결과	1심 법원	재심 취소	2심 법원	항소 기각	대법원	-
항 소 인	중앙노동위원회위원장		참 가 인		황○○	
피항소인	○○모터스 주식회사		피고측 대리인 선임 여부		선임 안 함	
노동조합 지원 여부	없음		원고측 대리인 선임 여부		선임 함	
재심 결과	초심유지					
초심의 대법원 판례 일치여부	불일치		재심의 대법원 판례 일치여부		불일치	
기타 특이사항						

주요 사실관계

<사실관계>

원고 회사는 ○○코리아로부터 국내의 자동차 판매 대리권을 위탁받아 자동차 판매업을 영위하는 법인인데, 참가인 근로자는 원고와 2017. 10. 23. '자동차 판매중개업무 위.수탁 계약을 체결하고, 이 사건 계약에 따라 2019. 12. 1.까지는 중랑 지점에서, 2019. 12. 2.부터는 동대문 지점에서 각 자동차 판매중개업무를 수행하였다.

원고는 2020. 3. 9.경 참가인에게 구두로 이 사건 계약을 해지하는 통보를 하였고, 이에 참가인은 이 사건 통보가 부당해고에 해당한다고 주장하며 구제신청을 하였다.

<심급별 결과>

[서울지노위] 근로자가 사용자와 자동차 판매 위·수탁계약을 체결하였으나 실질적으로 사용자의 상당한 지휘·감독을 받으면서 근로를 제공하여 근로기준법상 근로자에 해당하고, 사용자가 해고의 서면통지 의무를 위반하여 부당해고라고 판정

[중노위] 초심 유지

[1심 법원] 형식상 위임계약을 체결하였을 뿐 아니라, 실질적으로도 위임받은 사무를 상당한 재량을 발휘하여 처리하는 지위에 있었다고 판단되므로, 근로자로 보기 어렵다며, 재심판정 취소

[2심 법원] 항소 기각 ※ 상고하지 않음.

판결 요지

근로기준법상 근로자에 해당하는지는 계약의 형식이 고용계약, 도급계약 또는 위임계약인지 여부보다 근로제공 관계의 실질이 근로제공자가 사업 또는 사업장에 임금을 목적으로 종속적인 관계에서 사용자에게 근로를 제공하였는지 여부에 따라 판단하여야 한다. 여기에서 종속적인 관계가 있는지 여부는 ① 업무내용을 사용자가 정하고, ② 취업규칙 또는 복무(인사)규정 등의 적용을 받으며, ③ 업무수행 과정에서 사용자가 상당한 지휘·감독을 하는지, ④ 사용자가 근무시간과 근무장소를 지정하고 근로자가 이에 구속을 받는지, ⑤ 노무제공자가 스스로 비품·원자재나 작업도구 등을 소유하거나 제3자를 고용하여 업무를 대행케 하는 등 독립하여 자신의 계산으로 사업을 영위할 수 있는지, ⑥ 노무제공을 통한 이윤의 창출과 손실의 초래 등 위험을 스스로 안고 있는지, ⑦ 보수의 성격이 근로 자체의 대상적 성격인지, ⑧ 기본급이나 고정급이 정하여졌는지, ⑨ 근로소득세의 원천징수 여부 등 보수에 관한 사항, ⑩ 근로제공 관계의 계속성과 사용자에게 대한 전속성의 유무와 그 정도, ⑪ 사회보장제도에 관한 법령에서 근로자로서 지위를 인정받는지 등의 경제적·사회적 여러 조건을 종합하여 판단하여야 한다. 다만 기본급이나 고정급이 정하여졌는지, 근로소득세를 원천징수하였는지, 사회보장제도에 관하여 근로자로 인정받는지 등과 같은 사정은 사용자가 경제적으로 우월한 지위를 이용하여 임의로 정할 여지가 크다는 점에서 그러한 점들이 인정되지 않는다는 것만으로 근로자성을 쉽게 부정하여서는 안 된다(대법원 2006. 12. 7. 선고 2004다29736 판결, 2017. 9. 7. 선고 2017두46899 판결 등 참조).

패소 이유 (사실관계에 관한 인정 차이)

이 사건의 쟁점은 구제신청을 한 신청인이 근로기준법상 근로자에 해당하는지, 즉 노동위원회 구제신청의 당사자적격이 있는지 여부였다.

중노위는 “① 근로자가 지점장이나 인사팀 직원에 의해 구체적인 업무지시를 받은 사실이 인정되는 점, ② 위·수탁계약서상 권한 없는 팀장이 특별한 지위에서 실질적인 지휘·감독을 한 점, ③ 근로자가 받은 판매수수료의 성격이 전시장 운영 및 판촉 행사 등에 필요한 노무를 제공하고 그 대가로 받은 임금의 실질에 부합하는 점, ④ 근로자가 사용자에게 전속되어 사실상 검직이 불가능한 점” 등을 들어, 참가인이 근로기준법상 근로자에 해당하고, 서면통지의무 위반의 부당해고라고 보았다.

그러나 법원은 중노위와 다른 관점에서 사실관계를 평가하였다. 법원은 “▲채용공고의 근무형태란에 ‘정규직(근로자)’로 기재되어 있는 것 … 이러한 채용공고는 이 사건 계약의 체결을 위한 ‘청약의 유인’에 불과하고, 얼마든지 채용공고와 다른 내용의 약정을 체결할 수 있는 것이므로, 위 채용공고의 내용만으로 이 사건 계약의 성질을 단정할 수 없다. ▲원고는 영업지원팀, 경영지원팀, 마케팅팀 등 직원들과 달리, 참가인을 비롯하여 판매중개업무를 담당한 영업팀 소속 인원(이하 ‘판매중개인’이라고 한다)을 채용할 때에는 근로계약이 아닌 위·수탁 계약의 형식을 사용하였고, 판매중개인을 취업규칙이나 복무규정의 적용 대상에서도 제외시켰다. … 당해 위·수탁 계약을 해지할 수 있을 뿐, 나아가 판매중개인에게 취업규칙과 복무규정에 정한 정직, 감봉 등의 징계처분을 내릴 수는 없다. ▲판매중개인은 원고가 각 지점에 설치한 자동차 전시장에서 주로 근무하기는 하나, ① 원고는 판매중개인의 출·퇴근 시간을 기록하지 않고, ② 판매중개인이 결근을 하더라도 별도의 인사상 불이익을 가하지 않으며, ③ 근무 중에 원고에게 보고를 하지 않고도 외출할 수 있고, ④ 정해진 실적을 달성하기만 하면 결근일수와 관계없이 보수를 전액 지급받는다. 그렇다면 원고가 근무시간과 근무장소를 특별히 지정하였다거나, 이에 판매중개인이 구속되었다고 보기는 어렵다. ▲원고의 회계 담당 직원이 참가인과 통화하는 과정에서 ‘참가인의 수수료 4,727,000원 중 기본급이 1,200,000원’이라는 취지의 말을 한 사실은 인정되나 … 위 기본급 명목의 보수는 판매중개인의 보수에서 차지하는 비중이 그다지 크지 않을 뿐 아니라 해당 월의 판매실적이 없으면 다음 달에 기본급의 50%가 삭감되고 2개월 연속 판매실적이 없으면 지급되지 아니한 점 등에 비추어 판매를 촉진하기 위하여 지급되는 성과보수의 일종이라고 봄이 타당하다. ▲참가인은 2018. 1.부터 2019. 12.까지 2년 동안 적게는 600,000원부터 많게는 23,409,000원까지 매월 보수를 받아왔는데, 이는 참가인의 보수가 판매실적에 따른 것임을 보여준다”는 점 등에 비추어, 참가인은 형식상 위임계약을 체결하였을 뿐 아니라, 실질적으로도 원고의 사무를 상당한 재량을 발휘하여 처리하는 지위에 있었다고 판단되므로 참가인을 근로자로 보

부록.1. 주요 사건 경과 및 패소 원인 분석

기 어렵다고 판단하였다. 결론적으로 참가인은 근로자에 해당하지 아니하므로, 근로기준법 제28조 제1항에 따라 노동위원회에 구제신청을 할 수 있는 적격을 갖추지 못하였고, 이 사건 통보는 근로기준법 제27조의 적용을 받지 않는 위임계약의 해지에 불과하므로 서면에 의하지 않았더라도 적법하다며 재심 판정을 취소하였다.

중노위와 법원이 파악한 객관적 사실관계는 공통적이나, 그 사실들에 대한 법적 판단 즉 근로기본법상 근로자로 인정되기 위한 종속성 인정에 있어 서로 상반되게 관련 법리를 적용한 사건이다. 특히 법원은 중노위와 달리 참가인이 근무기간 동안 지급받은 보수가 명목상 기본급 항목이 존재하나 실제로 성과보수 성격으로 지급된 사정에 주목하였던 것으로 보인다.

일련번호	2022-73					
판결번호	대법원 2022. 9. 1. 선고 2022두00000					
중노위판정번호	중노위 2018. 12. 4. 2018부해983					
사건 종류	부당해고					
세부 쟁점	기간제법 제4조 계속근로 총기간 산정					
심급별 소송결과	1심 법원	재심 취소	2심 법원	항소 기각	대법원	심리불속행 기각
상 고 인	중앙노동위원회위원장		참 가 인		한○○, 홍○○	
피상고인	경기도		피고측 대리인 선임 여부		선임 안 함	
노동조합 지원 여부	없음		원고측 대리인 선임 여부		선임 함	
재심 결과	초심유지					
초심의 대법원 판례 일치여부	불일치		재심의 대법원 판례 일치여부		불일치	
기타 특이사항						

주요 사실관계

<사실관계>

원고(경기도)는 지방자치단체로서 교육·과학·기술·체육 그 밖의 학예에 관한 사무는 원고의 사무이다. 참가인들은 2010. 3. 1.부터 원고 교육청 소속 공립 초등학교에서 영어회화 전문강사로 근무하였다. 각 학교는 공통적으로 근무평가에 대한 근거규정을 두고 있었고, 근로계약서에 ‘근로계약기간 만료 시 당연퇴직하며, 자동적으로 기간이 연장되지 아니한다’, ‘학교장이 임용할 때 그 기간은 1년 이내로 하되, 필요한 경우 계속 근무기간이 4년을 초과하지 아니하는 범위에서 그 기간을 연장할 수 있다. 단, 이 범위에서는 2년을 초과하더라도 무기계약으로 간주하지 않

는다’는 조항을 두고 있었다.

한편 참가인들은 2014년 등에 걸쳐 각 공개채용 절차를 거쳐 새로운 기간제 계약을 체결한 바 있는데 이후 2018. 3. 1. 계약기간이 만료되자, 참가인들은 계약만료가 부당해고라며 구제신청을 하였다.

<심급별 결과>

[경기지노위] 공개채용 전후의 근로관계가 단절되었다고 할 수 없어 기간제근로자인 참가인들이 4년을 초과하여 계속 근로함으로써 기간제법 제4조 제2항에 따라 기간의 정함이 없는 근로계약을 체결한 근로자이므로, 근로계약만료가 부당해고에 해당한다고 판정

[중노위] 초심유지

[1심 법원] 공개채용 전후의 근로관계는 단절되었으므로 계속근로한 총기간이 4년을 초과하지 않는다며, 재심판정을 취소

[2심 법원] 항소 기각

[대법원] 심리불속행 기각

판결 요지

기간제법 규정 내용과 기간제 근로계약의 남용을 방지함으로써 근로자의 지위를 보장하려는 입법 취지 등을 고려하면, 기간제 근로계약이 반복하여 체결되거나 갱신되어 일정한 공백기 없이 기간제근로자가 계속적으로 근로한 경우라면, 특별한 사정이 없는 한 최초 기간제 근로계약에서부터 최종 기간제 근로계약에 이르기까지 기간 전체가 기간제법 제4조에서 말하는 기간제근로자의 사용기간으로서 ‘계속 근로한 총기간’에 포함되어야 한다. 다만 기간제 근로계약의 대상이 되는 업무의 성격, 기간제 근로계약의 반복 또는 갱신과 관련한 당사자들의 의사, 반복 또는 갱신된 기간제 근로계약을 전후한 기간제근로자의 업무 내용·장소와 근로조건 유사성, 기간제 근로계약의 종료와 반복 또는 갱신 과정에서 이루어진 절차나 그 경위 등을 종합적으로 고려할 때 당사자 사이에 기존 기간제 근로계약의 단순한 반복 또는 갱신이 아닌 새로운 근로관계가 형성되었다고 평가할 수 있는 특별한 사정이 있는 경우에는 기간제근로자의 계속된 근로에도 불구하고 그 시점에 근로관계가 단절되었다고 보아야 하고, 그 결과 기간제법 제4조에서 말하는 ‘계속 근로한 총기간’을 산정할 때 그 시점을 전후한 기간제 근로계약기간을 합산할 수는 없다(대법원 2020. 8. 20. 선고 2017두52153 판결 참조).

패소 이유 (사실관계에 관한 인정 차이)

이 사건은 기간제법 제4조의 무기계약 전환이 이루어지기 위한 요건인 총근로기간 산정에 관한 것이 쟁점이었다.

중노위는 “① 근로자들이 사용자의 소속 공립학교에서 기간의 단절 없이 동일업무를 수행하면서 근로계약을 1년 단위로 반복·갱신하여 근무한 점, ② 사용자가 신규채용절차를 거쳤다는 사정은 근로계약 체결에 이르게 된 경위에 불과한 것으로, 이러한 사정으로 신규채용 전·후의 근로관계가 단절되었다고 볼 수 없는 점 등”을 들어, 근로자들은 기간제근로자 사용기간 제한의 예외기간이 종료된 4년을 초과한 시점에 무기계약직 근로자로 전환되었다고 보아, 부당해고로 판정하였다.

그러나 법원은 “▲기간제 근로계약을 1년 단위로 갱신하여 온 참가인들은 초·중등교육법 시행령에서 정한 근무기간 4년이 지난 후에는 기존 기간제 근로계약을 종료하는 절차를 거친 후 별도의 공개채용 절차를 거쳐 2014. 3. 1.부터 새로이 영어회화 전문강사로 근무하게 되었다. ▲각 초등학교가 진행한 2014년도 영어회화 전문강사 각 공개채용 절차는 자격증 유무, 교육경력, 영어공인인증시험 점수 등을 평가기준으로 삼아 1차 서류심사를 통해 선발예정인원의 5배수 또는 2배수를 선발하고, 1차 서류심사 합격자들을 대상으로 교수·학습과정안 작성 및 이에 따른 영어 수업 실연 및 영어 심층면접이라는 2차 심사를 거쳐 최종 합격자를 선발하는 방식이었다. … 위

부록.1. 주요 사건 경과 및 패소 원인 분석

각 공개채용 절차에서 작성된 채점표에는 채점기준에 따른 채점위원들의 채점 결과가 기록되어 있다. 위와 같은 평가항목이나 평가방법 등에 비추어 볼 때 참가인들이 응시한 위 각 공개채용 절차는 객관적이고 합리적인 기준에 따라 실질적인 경쟁이 이루어진 신규 채용 절차로 평가할 수 있다. ▲나아가 공개채용 시점을 전후하여 참가인들에 대해 이루어진 종전 기간제 근로계약의 종료 절차 및 2014년의 각 공개채용 절차가 기간제법 제4조 제2항 적용을 회피하기 위한 의도로 이루어진 형식적인 절차에 불과하다고 볼 만한 사정이 있다고 보이지 않는다.”는 등의 이유로, 참가인들이 각 공개채용 절차를 거쳐 새로운 기간제 근로계약을 각 체결함으로써 원고와의 사이에 기존 기간제 근로계약의 단순한 반복 또는 갱신이 아닌 새로운 근로관계가 각 형성되었다고 평가할 수 있으므로 그 각 시점에 근로관계는 단절되었다고 보고, 결국 기간제법 제4조에서 말하는 계속 근로한 총기간을 산정할 때 공개채용된 시점 전후한 기간제 근로계약기간을 합산할 수 없어 계속 근로한 총기간이 4년을 초과하지 않으므로, 기간제법 제4조 제2항에 따라 기간의 정함이 없는 근로계약을 체결한 근로자라고 할 수 없다고 판결하였다.

법원이 중노위와 달리 주목한 부분은 각 공개채용 절차가 객관적이고 합리적인 기준에 따라 실질적인 경쟁이 이루어진 신규 채용 절차였다는 점이다. 법원은 이런 전제하에 공개채용 절차가 기간제법 제4조 제2항 적용을 회피하기 위한 의도로 이루어진 형식적인 절차가 아니라고 봄으로써, 원고와 참가인들 간 공개채용 절차를 거쳐 새로운 근로관계가 형성되었다고 평가하고 공개채용 전후 시점에 근로관계가 단절된 것으로 평가하면서, 결국 재심판정을 취소하기에 이르렀다.

일련번호	2022-74					
판결번호	대법원 2022. 9. 29. 선고 2022두00000					
중노위판정번호	중노위 2019. 6. 13. 2019부해347, 부노59 병합					
사건 종류	부당해고, 부당노동행위					
세부 쟁점	갱신기대권의 인정 여부, 불이익 취급의 부당노동행위					
심급별 소송결과	1심 법원	재심 취소	2심 법원	항소 기각	대법원	심리불속행 기각
상 고 인	중앙노동위원회위원장		참 가 인		김○○, 박○○, 이○○	
피상고인	사단법인 ○○○○○○		피고측 대리인 선임 여부		선임 안 함	
노동조합 지원 여부	없음		원고측 대리인 선임 여부		선임 함	
재심 결과	(부당해고)초심취소 / (부당노동행위)초심유지					
초심의 대법원 판례 일치여부	일치		재심의 대법원 판례 일치여부		불일치	
기타 특이사항						

주요 사실관계

<사실관계>

원고는 약 20명의 상시근로자를 사용하여 아동복지 조사 연구 및 정책개발, 지역아동센터 설치 및 운영 등을 하는 사단법인이다. ◎◎복지재단은 '여성긴급전화1366 ○○센터'를 ○○광역시로부터 수탁받아 2010. 4. 1.부터 2017. 12. 31.까지 이를 운영하였는데, 참가인들은 각 2010. 4.~ 2017. 12. 31. 사이에 ◎◎복지재단에 채용되어 이 사건 센터에서 근무하였다. ◎◎복지재단은 2017. 12. 31.자로 센터의 운영권을 포기하였는데, 그 후 원고는 새로운 수탁기관으로 선정되어 ○○광역시와 사이에 2018. 4. 1.부터 2022. 12. 31.까지 센터를 운영하는 내용의 위·수탁 협약을 체결하였다. 원고는 참가인들을 2018. 3. 말경 채용하였고, 참가인들과 사이에 근로계약기간을 2018. 4. 1.부터 2018. 12. 31.까지로 정하여 근로계약을 체결하였다. 원고는 2018. 11. 28. 참가인들에게 근로계약기간 만료를 이유로 근로계약이 2018. 12. 31.자로 종료된다고 통보하였고, 이에 참가인들이 원고가 이 사건 근로계약을 갱신하지 아니한 것은 부당해고이자 불이익 취급의 부당노동행위에 해당한다고 주장하며 구제신청을 하였다.

<심급별 결과>

[○○지노위] 이 사건 근로자들은 기간의 정함이 있는 근로계약서에 자의로 서명하여 근로계약을 체결하였고, 근로계약의 갱신 기대권을 인정할 만한 사정이 없다고 판정

[중노위] 근로계약 갱신기대권이 인정되고 갱신거절에 합리적인 이유가 없어 부당해고로서 초심을 취소하나, 불이익 취급의 부당노동행위는 아니라고 보아 이 부분은 초심 유지

[1심 법원] 근로계약의 갱신 기대권을 인정할 수 없다며 재심판정을 취소

[2심 법원] 항소 기각

[대법원] 심리불속행 기각

판결 요지

기간을 정하여 근로계약을 체결한 근로자의 경우 그 기간이 만료됨으로써 근로자로서의 신분관계는 당연히 종료되고 근로계약을 갱신하지 못하면 갱신거절의 의사표시가 없어도 그 근로자는 당연 퇴직되는 것이 원칙이다. 그러나 근로계약, 취업규칙, 단체협약 등에서 기간만료에도 불구하고 일정한 요건이 충족되면 당해 근로계약이 갱신된다는 취지의 규정을 두고 있거나, 그러한 규정이 없더라도 근로계약의 내용과 근로계약이 이루어지게 된 동기 및 경위, 계약 갱신의 기준 등 갱신에 관한 요건이나 절차의 설정 여부 및 그 실태, 근로자가 수행하는 업무의 내용 등 당해 근로관계를 둘러싼 여러 사정을 종합하여 볼 때 근로계약 당사자 사이에 일정한 요건이 충족되면 근로계약이 갱신된다는 신뢰관계가 형성되어 있어 근로자에게 그에 따라 근로계약이 갱신될 수 있으리라는 정당한 기대권이 인정되는 경우에는 사용자가 이에 위반하여 부당하게 근로계약의 갱신을 거절하는 것은 부당해고와 마찬가지로 아무런 효력이 없고, 이 경우 기간만료 후의 근로관계는 종전의 근로계약이 갱신된 것과 동일하다고 할 것이다(대법원 2011. 4. 14. 선고 2007두1729 판결 등 참조).

근로자에게 이미 형성된 갱신에 대한 정당한 기대권이 있음에도 불구하고 사용자가 이를 배제하고 근로계약의 갱신을 거절한 데에 합리적 이유가 있는지가 문제 될 때에는 사용자의 사업 목적과 성격, 사업장 여건, 근로자의 지위 및 담당 직무의 내용, 근로계약 체결 경위, 근로계약의 갱신에 관한 요건이나 절차의 설정 여부와 그 운용 실태, 근로자에게 책임 있는 사유가 있는지 여부 등 당해 근로관계를 둘러싼 여러 사정을 종합하여 갱신 거부의 사유와 그 절차가 사회통념에 비추어 볼 때 객관적이고 합리적이며 공정한지를 기준으로 판단하여야 하고, 그러한 사정에 대한 증명책임은 사용자가 부담한다(대법원 2017. 10. 12. 선고 2015두44493 판결 등 참조)

패소 이유 (사실관계에 관한 인정 차이)

이 사건에서 중노위와 법원은 참가인 근로자들에게 ‘근로계약 갱신기대권이 존재하는가’에 관해 의견이 상반되면서, 결론이 엇갈리게 되었다.

중노위는 “▲원고 법인이 이 사건 센터를 수탁받으면서 ‘○○복지재단 소속으로 이 사건 센터에 근무하던 직원이 계속 근무를 희망하는 경우에는 고용을 승계하겠다’는 의사를 밝힌 것으로 보이는 점, ▲이 사건 센터 종사자 9명에 대한 채용 면접을 하면서 “연말에 근무평정, 실적, 업무 태도 등을 고려하여 계속 채용 여부를 결정하겠다”고 고지한 점, ▲인사위원회를 개최하여 이 사건 센터 전체 직원 15명의 재계약 여부에 대한 직무평가를 실시한 점 등”에 주목하여, 참가인들에게는 근로계약 갱신기대권이 인정된다고 전제한 후, 갱신거절에 합리적인 이유가 없어 부당해고라고 판정하였다. 다만 이 사건 노동조합의 조합원만 특정하여 갱신거절하였다고 볼만한 근거가 없으므로 불이익 취급의 부당노동행위에 해당하지는 않는다고 보았다.

그러나 법원은 “▲이 사건 복지재단은 2017. 12. 31.자로 이 사건 센터의 운영권을 포기하기로 하면서 참가인들을 포함한 이 사건 센터의 전 직원들에 대하여 2017. 12. 31.자로 근로계약을 해지한다고 통보하였고, 2018. 1.경 직원들의 퇴직금을 모두 정산한 것으로 인다. ▲이후 원고가 2018. 3. 30. ○○광역시와 사이에 이 사건 위·수탁 협약을 체결한 다음 2018. 3. 말경 채용공고 및 면접을 거쳐 참가인들을 포함하여 총 15명의 근로자를 이 사건 센터의 직원으로 새로 채용하였다. 원고는 2018. 4. 1. 참가인들과 사이에 이 사건 근로계약을 체결하면서 그 근로계약기간을 ‘2018. 4. 1.부터 2018. 12. 31.까지(9개월)’로 명확히 정하였다. ▲① ○○광역시는 이 사건 센터에서 근무한 근로자들의 고용을 승계하는 것을 조건으로 하여 운영기관 공모를 3차례 하였으나 수탁기관이 정해지지 않았고, 4. 5차 공고부터는 ‘이 사건 센터 종사자에 대한 고용승계를 이행하는 수탁 법인·단체에 대하여 가산점 부여’라는 내용만을 명시하여 고용승계를 의무화하지 않았던 점, ② 원고는 위 공고 중 5차 공고에 참여하였는데, 이 사건 위·수탁 협약 협상과정에서 ○○광역시에 ‘고용승계는 하지 않고 다만 채용과정에서 기존 경력자를 우대하겠다’는 의사를 명시적으로 표시하였던 점, ③ 결국 ○○광역시는 이러한 원고의 의사를 수용하여 이 사건 위·수탁 협약에 고용승계와 관련한 조건을 명시하지 않은 것으로 보이고, 원고도 채용면접 과정에서 지원자들에게 신규채용의 형태로 근로계약을 체결하게 된다고 설명하였던 것으로 보이는 점, ④ 설령 원고가 이 사건 센터에서 근무하였던 근로자들의 고용을 승계하기로 한 것이라고 보더라도, 이는 이 사건 센터에서 계속 근무하기를 원하는 근로자들에 대하여 이 사건 센터의 직원으로 계속 고용한다는 의미일 뿐이고, 나아가 원고와 체결한 근로계약기간이 만료되더라도 이 사건 위·수탁 협약이 종료될 때까지 당연히 그 근로계약의 갱신을 인정의 갱신을 인정해 주겠다는 의사까지 포함된 것이라고 보기는 어려운 점 ▲원고의 인사관리규정 제19조 제4호는 ‘근로계약기간이 만료된 경우를 당연 퇴직으로 본다’는 규정을 두고 있을 뿐 일정한 요건이 충족되면 당해 근로계약이 갱신된다는 취지의 규정을 두고 있지 아니하고, 이 사건 센터의 직원들에 대한 직무평가를 위하여 2018. 11. 26. 개최한 원고의 인사위원회에서는 ‘위 직무평가는 재계약 여부를 결정하기 위한 참고자료일 뿐이며, 근본적으로는 이 사건 센터 15명의 직원들 모두 9개월 계약직이다’라는 점을 명확히 밝히기도 하였던 점 등”을 이유로, 원고와 참가인들 사이에 근로계약 갱신의 신뢰관계가 형성되어 있었다고 볼 수 없으므로, 참가인들에게 이 사건 근로계약이 갱신될 수 있으리라는 정당한 기대권이 인정되지 않는다고 결론 내렸다. (그러면서 법원은 설령 근로계약 갱신기대권이 인정된다고 가정하더라도 “참가인들은 원고의 근로자였음에도 불구하고 ○○복지회 추진위원회와 사이에 이 사건 이면계약을 체결하여 원고를 이 사건 센터의 운영사업에서 배제하고, ○○복지회를 통하여 이 사건 센터의 운영권한을 취득하려 하였다. 이러한 참가인들의 행위는 그 비위의 정도가 매우 중하고, 원고와 사이에 더 이상 근로관계를 지속할 수 없을 정도로 신뢰관계를 심각하게 훼손하는 행위에 해당한다”면서, 갱신을 거절한 데에 합리적인 이유가 있다고 판단하였다.)

법원은 중노위와 달리 ‘근로계약 체결 당시 기간의 정함이 있음을 명확히 한 점, 기간 만료 시 갱신기대권 인정할만한 인사규정 등 근거규정이 없는 점 등’ 외견상 드러난 객관적 사정과 다른 계약당사자 의사를 추정할만한 근거가 없다는 점에 주목하여, 문언상 계약 의사를 존중한 것으로 보인다.

일련번호	2022-75					
판결번호	서울고등법원 2022. 9. 1. 선고 2022누00000 판결					
중노위판정번호	중노위 2021. 3. 3. 2020부해1778					
사건 종류	부당징계, 부당노동행위					
세부 쟁점	징계, 감봉, 부당노동행위, 불이익취급, 근로시간면제					
심급별 소송결과	1심 법원	재심판정취소	2심 법원	1심 유지	대법원	
원고, 피항소인	김○○		참 가 인		○○군	
피고, 항소인	중앙노동위원회위원장		피고측 대리인 선임 여부		선임 안 함	
노동조합 지원 여부	있음		원고측 대리인 선임 여부		선임 함	
재심 결과	초심유지					
초심의 대법원 판례 일치여부	불일치		재심의 대법원 판례 일치여부		불일치	
기타 특이사항						

주요 사실관계 <사건 개요> 가. 피고보조참가인(이하 '참가인'이라 한다)은 상시근로자 약 1,330명을 사용하여 지방행정 사무를 처리하는 지방자치단체(○○군)이다. 원고는 2008. 3. 8. 참가인에 환경미화원으로 입사하여 현재 불법투기 생활폐기물 수거·운반 업무를 담당하고 있고, 2016. 9. 22.부터 E노동조합(이하 '이 사건 노동조합'이라 한다) F지회의 지회장으로 활동하고 있다. 나. 참가인은 2020. 8. 4. 징계위원회를 개최하여 '원고가 2020. 3. 4. ~ 2020. 4. 9. 총 13일(104시간)을 부서장의 승인 없이 무단결근함으로써 「B자치단체 환경미화원 및 운전원 임용·복무규칙」 제14조(환경미화원 및 운전원의 의무) 및 제24조(결근신고 등)을 위반하였다'는 이유로 원고에 대하여 감봉 1월을 의결하였고, 2020. 8. 6. 이를 원고에게 통지하였다. 다. 원고는 다음과 같은 이유로 근로시간면제한도 사용을 주장한다. ① 이 사건 노동조합은 2020. 3. 2. 참가인에게 '원고가 2020. 3. 4. 근로시간면제한도를 8시간 사용하겠다'는 취지를 통보하였는데, 참가인은 같은 날 이 사건 노동조합에 '단체협약 제13조에 의하면, 근로시간면제를 사용하고자 할 경우 조합대표자는 3명의 근로시간면제자를 지명해야 하고, 조합간의 합의를 전제로 한 근로시간면제자 지명이 선행되지 않는 근로시간면제는 공정대표의무 위반의 여지가 있어 허용할 수 없다'는 취지로 회신하였다. ② 이에 이 사건 노동조합은 2020. 3. 3. 참가인에게 '단체협약에 명시된 근로시간 면제 한도를 넘지 않는 범위 내에서 근로시간면제 시간을 사용하는 것은 참가인이 관여할 사항이 아니다'라는 공문을 발송하였고, 원고는 2020. 3. 4. 근로시간면제 한도를 사용하였다. ③ 이 사건 노동조합과 참가인은 2020. 3. 2. ~ 4. 7. 근로시간면제 한도 사용과 관련하여 각각 11회 공문을 주고받았는데, 위 기간 동안 원고는 총 13일(합계 104시간)에 해당하는 근로시간면제 한도를 사용하였다.
--

부록.1. 주요 사건 경과 및 패소 원인 분석

④ 참가인은 2020. 3. 9. 전남지방노동위원회에 단체협약 제13조의 해석에 관한 견해 제시를 요청하였는데, 전남지방노동위원회는 2020. 4. 23. '단체협약 제13조(근로시간면제자) 규정은 이 사건 노동조합이 근로시간면제 한도 연간 사용인원 3명을 참가인에게 통보해야 하는 것으로 해석된다. 다만 참가인이 동의하는 경우 연간 상한 인원과시간을 달리 정하는 것도 가능하다'고 결정하였다(전남2020단협1).

⑤ 한편, 이 사건 노동조합이 2020. 2. 19. 소외 노동조합에 근로시간면제자와 면제한도 사용시간을 '이 사건 노동조합 3명/1,380시간, 소외 노동조합 1명/200시간'으로 배분하는 잠정합의안을 전달하자, 소외 노동조합은 2020. 3. 3. 이 사건 노동조합에 대하여 공정대표의무 위반을 이유로 전남지방노동위원회에 시정 신청을 하였다(전남2020공정6). 위 시정 신청사건에서 2020. 5. 8. 이 사건 노동조합과 소외 노동조합 사이에 '근로시간면제 한도 배분을 이 사건 노동조합 1,180시간, 소외 노동조합 400시간으로 한다'는 내용으로 화해가 성립되었다.

⑥ 이 사건 노동조합은 2020. 4. 22. 근로시간면제자를 원고, P(이상 이 사건 노동조합 소속), M(소외 노동조합 소속)으로 결정하여 참가인에게 통보하였고, 2020. 5. 11. 근로시간면제 시간을 '이 사건 노동조합 1,180시간, 소외 노동조합 400시간으로 배분하는 데 합의하였다'고 참가인에게 통보하였다.

⑦ 참가인은 원고에게 이 사건 감봉을 통보한 후, 2020. 8. 14. 원고의 무단결근 13일에 해당하는 임금 1,827,290원을 환수조치(6개월 분할납부)할 예정임을 아울러 통보하였다.

라. 원고는 이 사건 감봉이 부당징계 및 불이익 취급의 부당노동행위에 해당한다며 2020. 9. 2. 전남지방노동위원회에 구제신청을 하였다.

<심급별 결과>

[전남지노위] 원고의 구제신청을 기각

[중노위] 재심신청 기각. 초심 유지

[1심 법원] 부당노동행위는 인정하지 않았으나, 감봉이 부당징계에 해당함을 인정하여 재심판정 내용을 일부 취소

[2심 법원] 1심 판결 유지

판결 요지

(1) 부당징계 해당 여부에 관한 판단

구 노동조합 및 노동관계조정법 제24조에 의하면, 노동조합의 업무에만 종사하는 근로자(이하 '노조전임자'라 한다)는 그 전임기간 동안 사용자로부터 어떠한 급여도 지급받아서는 아니되지만(제2항), 제2항에도 불구하고 근로시간 면제 대상으로 지정된 근로자(이하 '근로시간면제자'라 한다)는 근로시간 면제 한도를 초과하지 아니하는 범위에서 임금의 손실 없이 사용자와의 협의·교섭, 고충처리, 산업안전 활동 등의 일정한 업무와 건전한 노사관계의 발전을 위한 노동조합의 유지·관리업무를 할 수 있다(제4항).

다음과 같은 사정들을 앞서 본 근로시간면제제도의 규정 및 취지에 비추어 보면, 원고가 단체협약 체결 이후 새롭게 근로시간면제자를 지정하지 않은 채 근로시간면제 시간을 사용하였다고 하더라도, 이를 원고가 무단결근하였다고 평가할 수는 없다. 따라서 이와 다른 전제에서 피고가 한 이 사건 감봉은 징계사유가 인정되지 아니하므로 위법하다.

① 단체협약서와 같은 처분문서는 특별한 사정이 없는 한 그 기재 내용에 의하여 그 문서에 표시된 의사표시의 존재 및 내용을 인정하여야 하고, 한편 단체협약은 근로자의 근로조건을 유지 개선하고 복지를 증진하여 근로자의 경제적, 사회적 지위를 향상시킬 목적으로 노동자의 자주적 단체인 노동조합이 사용자와 사이에 근로조건에 관하여 단체교섭을 통하여 체결하는 것이므로 그 명문의 규정을 근로자에게 불리하게 해석할 수는 없다(대법원 1996. 9. 20. 선고 95다20454

판결, 2014. 2. 13. 선고 2011다86287 판결, 2019. 11. 28. 선고 2017다257869 판결 등 참조). 단체협약 제13조는 '군청은 조합대표자가 지명한 3명의 조합원에 대해서 연 1,580시간 조합활동을 보장한다'고 규정하고 있을 뿐, 근로시간 면제자를 통보하여야 하는 구체적 시기 또는 새로운 단체협약이 체결되었을 경우 기존 근로시간면제자 통보의 효력 여하에 관하여는 아무런 규정도 하고 있지 않다. 나아가 이 사건 노동조합과 참가인 사이에 새로운 단체협약 체결 시 근로시간면제자를 새로 통보하는 노동관행이 존재한다고 인정할 아무런 근거도 없다. 그럼에도 단체협약 제 13조를 '새로운 단체협약이 체결되면 기존 근로시간면제자통보의 효력이 자동적으로 소멸하고, 조합대표자가 새로 근로시간면제자를 통보하지 않는 이상 근로시간면제 시간을 사용할 수 없다'고 해석할 경우, 복수노조 사업장에서 각 노동조합 사이의 의견 대립으로 인하여 근로시간면제에 관한 합의가 지연될 시, 어느 노동조합도 정당한 노동조합 활동을 위해 근로시간면제 시간을 전혀 사용할 수 없다는 부당한 결론에 이르게 된다. 이는 단체협약의 명문 규정을 특별한 이유 없이 근로자에게 불리하게 해석하는 것으로서 부당하다.

② 이 사건 노동조합은 2019. 12. 11. 원고를 포함한 이 사건 노동조합 소속 근로자 3명을 근로시간면제자로 지정하여 참가인에게 통보하였는바, 단체협약 체결 이후 새로운 근로시간면제자가 지정·통보되지 않은 이상, 위 3명이 단체협약 제13조의 '조합 대표자가 지명한 3인의 조합원'에 해당한다고 봄이 상당하다. 이와 같이 보는 경우 다수 노조인 이 사건 노동조합이 근로시간면제자 및 면제 시간을 과다하게 차지함으로써 공정대표의무를 위반할 우려가 있는 것은 사실이다. 그러나 이를 구 노동조합법 제29조의4 제2항 이하에서 정하고 있는 노동위원회에 대한 시정 요청 및 그에 따른 구제명령으로 해결하는 것은 별론으로 하고, 이 사건 노동조합이 소외 노동조합과의 근로시간면제자의 수와 면제시간에 관한 협의에 시간이 필요한 점, 새로운 단체협약이 체결된 직후 근로시간면제 시간을 일부 사용한다고 하여 소외 노동조합의 권리를 침해할 여지가 있다고 보기 어려운 점 등에 비추어 보면, 공정대표의무 위반의 우려만으로 기존 근로시간면제자의 한도 내에서의 면제시간 사용을 불허하는 것은 정당화되기 어렵다.

③ 이 사건 노동조합이 단체협약 체결 이전에 소외 노동조합에게 근로시간면제자 및 면제 시간 배분에 관한 잠정합의안을 전달하였고, 소외 노동조합이 노동위원회에 제기한 공정대표의무 위반 시정 신청사건에서도 적극적으로 협의에 임하여 비교적 이른 시점에 소외 노동조합과 원만한 합의에 이르렀는바, 이 사건 노동조합이 공정대표의무를 위반하려는 의도에서 참가인에게 새로 근로시간면제자 통보를 하지 않았다고 보기 어렵다.

④ 원고가 단체협약이 체결된 후 얼마 지나지 않은 시기에 근로시간면제 시간을 사용한 점, 단체협약에서 정한 참가인 사업장에서의 근로시간면제 한도 총 1,580시간 중 원고가 사용한 104시간이 차지하는 비율은 10%에도 미치지 못하는 점, 원고가 이 사건 노동조합의 지회장으로서 정당한 조합활동을 위하여 근로시간면제 시간을 사용한 것으로 보이는 점 등에 비추어 볼 때, 원고의 근로시간면제 시간 사용으로 인하여 이 사건 노동조합이 공정대표의무를 위반하였다고 볼 수 없다.

(2) 부당노동행위 해당 여부에 관한 판단

사용자가 근로자에게 불이익한 조치를 함에 있어서 표면적으로 내세우는 불이익조치 사유와는 달리 실질적으로는 근로자의 정당한 노동조합 가입·활동을 이유로 불이익조치를 한 것으로 인정되는 경우 그 불이익조치는 부당노동행위라고 보아야 한다. 근로자의 노동조합 업무를 위한 정당한 행위를 실질적인 불이익조치 사유로 한 것인지의 여부는 사용자측이 내세우는 불이익조치 사유와 근로자가 한 노동조합 업무를 위한 정당한 행위의 내용, 불이익조치를 한 시기, 사용자와 노동조합과의 관계, 동종의 사례에 있어서 조합원과 비조합원에 대한 제재의 불균형 여부, 종래 관행에의 부합 여부, 사용자의 조합원에 대한 언동이나 태도, 기타 부당노동행위 의사의 존재를 추정할 수 있는 제반 사정 등을 비교 검토하여 판단하여야 한다(대법원 2000. 4. 11. 선고 99두 2963 판결의 취지 참조).

다음과 같은 사정들을 종합하면, 원고가 제출한 증거만으로는 참가인의 이 사건 감봉이 원고가 정당한 조합 활동을 하였음을 이유로 원고에게 불이익을 주는 행위로서 구 노동조합법 제81조 제1항 제1호에서 정한 불이익 취급의 부당노동행위라고 보기 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다. 따라서 원고의 이 부분 주장은 이유 없다.

부록.1. 주요 사건 경과 및 패소 원인 분석

① 참가인은 2019년 소외 노동조합이 설립되었고, 2020. 3. 2. 단체협약이 새로 체결됨으로써 종전의 단체협약의 효력이 소멸되었으므로, 교섭대표노동조합인 이 사건 노동조합이 소외 노동조합과 협의하여 새로운 근로시간면제자를 지정하여야 한다고 판단하였고, 이러한 판단에 기초하여 원고의 근로시간면제 시간 임의사용을 무단결근으로 평가한 것으로 보인다.

② 결국 참가인은 단체협약 제13조에 관한 해석상의 오류나 법리오해 등으로 인하여 원고에 대한 징계절차에 나아간 것으로 보일 뿐이고, 당시 참가인이 원고가 정당하게 근로시간면제를 사용할 수 있다는 점을 충분히 알고 있었음에도 고의적인 부당노동행위의 의사로 원고에 대한 징계절차를 개시하였다고 보기 어렵다.

패소 이유 (사실관계에 관한 인정 차이)

이 사건은 사실관계는 동일하게 주장되었으나, 그에 관한 법리적 판단의 결과가 달라진 사건이다. 쟁점은 사용자의 부당노동행위 의사의 입증에 있었다고 할 수 있다.

사용자는, 원고의 주장을 받아들이는 것이 공정대표의무 위반에 해당할 수 있고, 단체협약의 규정에 위배될 수 있다는 판단에 따라 근로시간면제자 지위 인정을 거부하고 사규 위반으로 징계한 것이므로 불이익취급의 부당노동행위에 해당하지 않는다고 본 것이다.

반면 징계의 경우에는 행위자의 비위행위가 존재하여야 하고(사유), 그 비위행위와 징계의 종류 사이에 균성성이 확보되어야 하며(양정), 정당한 절차를 거쳐야 하는데, 원고의 근로시간면제자 지위 주장이 부당하다고 볼 수 없다는 것을 이유로 사유를 부정하였다.

이 사안은 단체협약의 해석과 적용, 관행에 관한 것으로서 다소간 해석의 여지가 있으나, 기존 대법원 판단 경향을 충분히 인식하고 있었다면 초심판정 및 재심판정과 같은 결론에는 이르지 않을 수 있었을 것으로 보이는바, 결국 공익위원의 전문성 확보가 이와 같은 사례의 반복을 막을 수 있는 방안이라고 사료된다.

일련번호	2022-76					
판결번호	서울행정법원 2022. 8. 18. 선고 2020구합00000					
중노위판정번호	중노위 2020. 11. 17. 2020부해1326					
사건 종류	부당해고					
세부 쟁점	갱신기대권 존부, 갱신 거절의 합리적 이유					
심급별 소송결과	1심 법원	재심 취소	2심 법원	(항소 취하)	대법원	-
원고, 피항소인	주식회사 ○○○○○○		참가인, 항소인		강○○	
피 고	중앙노동위원회위원장		피고측 대리인 선임 여부		선임 안 함	
노동조합 지원 여부	없음		원고측 대리인 선임 여부		선임 함	

재심 결과	초심취소		
초심의 대법원 판례 일치여부	일부 불일치	재심의 대법원 판례 일치여부	불일치
기타 특이사항			

주요 사실관계

<사실관계>

원고(초소량 즉시 배달업체 'B마트')는 참가인 근로자와 2020. 3. 17. '계약기간 2020. 3. 13.부터 2020. 6. 4.까지, 본 계약은 근로계약기간의 만료로 자동 종료된다'로 명시하여 근로계약을 체결하고, 원고가 운영하는 B마트 강동점에서 주문된 상품을 창고에서 가져오는 업무(피킹 업무)와 배송될 상품을 포장하는 업무(패킹 업무)를 담당하는 직원으로 근무하였다.

원고 회사는 계약기간 만료가 도래하자 '근태입력 소홀, 업무 중 실수가 잦고 이를 지적하면 화를 내거나 인정하지 않음, 점장의 업무 지시 불이행, 이상한 행동이나 말을 하거나 과격한 모습을 보여 불안감 조성' 등을 들어 갱신을 거절하였고, 이에 참가인이 부당해고 구제신청을 하였다.

<심급별 결과>

[서울지노위] 근로계약 갱신에 대한 기대권이 존재한다고 볼만한 규정이나 관행이 없어 사용자가 근로계약기간 만료로 근로관계를 종료한 것은 정당하다고 판정

[중노위] 근로계약 갱신에 대한 기대권이 있고, 갱신 거절의 합리적인 이유가 있다고 볼 수 없어 부당해고라며 초심 취소

[1심 법원] 근로계약 갱신 거절의 합리적인 이유가 있다며 재심판정 취소

[2심 법원] 항소 취하

판결 요지

기간을 정하여 근로계약을 체결한 근로자의 경우 기간이 만료됨으로써 근로자로서 신분관계는 당연히 종료되고, 근로계약을 갱신하지 못하면 갱신 거절의 의사표시가 없어도 당연히 퇴직되는 것이 원칙이다. 그러나 근로계약, 취업규칙, 단체협약 등에서 기간이 만료되더라도 일정한 요건이 충족되면 당해 근로계약이 갱신된다는 취지의 규정을 두고 있거나, 그러한 규정이 없더라도 근로계약의 내용과 근로계약이 이루어지게 된 동기 및 경위, 계약 갱신의 기준 등 갱신에 관한 요건이나 절차의 설정 여부 및 실태, 근로자가 수행하는 업무의 내용 등 당해 근로관계를 둘러싼 여러 사정을 종합하여 볼 때 근로계약 당사자 사이에 일정한 요건이 충족되면 근로계약이 갱신된다는 신뢰관계가 형성되어 있어 근로자에게 근로계약이 갱신될 수 있으리라는 정당한 기대권이 인정되는 경우에는, 사용자가 이를 위반하여 부당하게 근로계약의 갱신을 거절하는 것은 부당해고와 마찬가지로 아무런 효력이 없고, 기간만료 후의 근로관계는 종전의 근로계약이 갱신된 것과 동일하다(대법원 2017. 10. 12. 선고 2015두44493 판결 등 참조).

근로자에게 이미 형성된 갱신에 대한 정당한 기대권이 있는데도 사용자가 이를 배제하고 근로계약의 갱신을 거절한 데에 합리적 이유가 있는지가 문제 될 때에는 사용자의 사업 목적과 성격, 사업장 여건, 근로자의 지위와 담당 직무의 내용, 근로계약 체결 경위, 근로계약의 갱신 요건이나 절차의 설정 여부와 운용 실태, 근로자에게 책임 있는 사유가 있는지 등 근로관계를 둘러싼 여러 사정을 종합하여 갱신 거부의 사유와 절차가 사회통념에 비추어 볼 때 객관적이고 합리적

이며 공정한지를 기준으로 판단하여야 하고, 그러한 사정에 관한 증명책임은 사용자가 부담한다 (대법원 2021. 10. 28. 선고 2021두45114 판결 등 참조).

패소 이유 (사실관계에 관한 인정 차이)

중노위와 법원은 공통적으로 ‘근로계약, 취업규칙에 크루들의 계약 갱신에 관한 요건을 구체적으로 규정하지는 않았지만, 나름의 내부적인 기준을 설정하고 그에 따라 계약 갱신 여부를 결정해왔던 점, 근로자의 업무는 회사에서 필수적이고, 상시·계속적인 업무인 점 등’을 인정하여 참가인 근로자의 근로계약 갱신기대권이 있다고 보았다. 그러나 근로계약 갱신 거절의 합리적 이유 존부에 관해, 중노위는 합리적 이유가 없다고 본 반면 법원은 합리적 이유가 있다고 판단하였다.

중노위는 ‘① 12주 단위로 근로계약을 반복 체결하면서 근로계약 갱신에 관한 기준이 없어 고용 안정성을 심각하게 훼손한 점, ② 근태 입력을 늦게 하거나 누락하였으나, 지각은 1회에 불과하여 근태가 불성실하였다고 보기 어려운 점, ③ 업무수행능력 부족에 대한 객관적인 근거가 없는 점, ④ 점장, 부점장, 다른 근로자의 진술서가 근로자 퇴직 이후 작성되어 신뢰하기 어려운 점 등’에 주목하여 근로계약 갱신 거절의 합리적인 이유가 없다며 부당해고로 판정하였다.

그러나 법원은 ▲원고 회사는 ‘근태입력 소홀, 업무 중 실수가 잦고 이를 지적하면 화를 내거나 인정하지 않음, 점장의 업무 지시 불이행, 이상한 행동이나 말을 하거나 과격한 모습을 보여 불안감 조성’을 참가인에 대한 갱신 거절 사유로 들었는데, 이 사건 지점에서 함께 근무하던 동료들의 진술 및 참가인 출퇴근 기록 일정노트 등에 비추어 보면, 갱신 거절 사유는 모두 사실로 인정 된다. ▲참가인이 반복적으로 근태 입력을 소홀히 함으로 인하여 이 사건 지점의 크루 관리에 상당한 지장이 초래되었던 것으로 보인다. 원고는 크루가 입력한 출퇴근시간에 따라 시급을 지급하므로 크루가 출퇴근시간을 정확히 입력하는 것이 매우 중요함에도, 참가인은 상사의 주의에도 불구하고 12주 동안 무려 16회나 반복적으로 근태 입력을 잘못하거나 누락하였는바, 고의에 가까울 정도로 근태 입력에 관한 주의를 현저히 결여한 것으로 볼 수 있다. … 수차례 공지된 변경된 스케줄표를 제대로 확인하지 않은 결과 오픈조로 출근하여야 한다는 점을 인식하지 못한 채 마감조로 출근하기도 하였다. ▲퇴근하다가 고성을 지르며 발을 동동 구르고, 업무 실수를 지적하면 동료 크루에게 화를 내며, 피킹 업무 및 패킹 업무를 수행하는 과정에서 물건을 던지고, ‘다른 근무자의 마음의 소리가 들린다.’고 이야기하는 등의 비상식적인 언행으로 인하여 이 사건 지점의 크루들은 상당한 불안감을 느꼈던 것으로 보인다’는 등의 사정을 중시하여, 갱신 거절에 합리적 이유가 있어 부당해고가 아니라고 판결하였다.

이 건의 경우 중노위와 법원이 인정한 객관적 사실관계에 특별한 차이가 없음에도, 각 사실에 대한 경중 및 평가를 달리함으로써 상반되는 결론에 이른 것으로 보인다.

일련번호	2022-79
판결번호	대법원 2022. 10. 27. 선고 2022두00000
중노위판정번호	중노위 2019. 4. 22. 2019부해178
사건 종류	부당해고
세부 쟁점	당사자적격(근로기준법상 근로자에 해당하는지 여부)

심급별 소송결과	1심 법원	재심 유지	2심 법원	1심 취소	대법원	심리불속행 기각
상 고 인	중앙노동위원회위원장		참 가 인		이○○	
피상고인	○○○신용정보 주식회사		피고측 대리인 선임 여부		선임 안 함	
노동조합 지원 여부	없음		원고측 대리인 선임 여부		선임 함	
재심 결과	초심유지					
초심의 대법원 판례 일치여부	불일치		재심의 대법원 판례 일치여부		불일치	
기타 특이사항						

주요 사실관계 <사실관계> 참가인은 2000. 3. 2. 원고와 신용조사업무 위임계약을 체결하고 위탁직으로 임대차조사업무를 수행하면서, 6개월 단위로 계약을 갱신하면서 임대차조사업무를 수행하였다. 원고는 2015. 1. 29. 위임계약 양식을 전면 수정하여 시행하였고, 참가인은 2015. 2. 1. 수정된 위임계약서에 따라 원고와 계약 체결하면서, 계약서 말미의 확인 부분에 원고로부터 ‘충분히 설명받고 동의’라고 자필로 기재하였다. 이후 참가인은 6개월 단위로 계약을 갱신하며 임대차조사 업무를 수행하다가, 2018. 10. 31. 계약기간 만료 후 더 이상 계약이 되지 않자, 부당해고 구제신청을 하였다. 원고는 그동안 임대차조사원들에게 제공된 업무용 태블릿 PC와 전산 프로그램 접속 아이디를 통해 원고의 전산 프로그램에 접속하여 배정된 업무 내용을 파악한 후 현장조사업무를 수행하였다. 규칙적으로 본사나 지점 사무실에 출퇴근을 하지 않았으며, 원고는 참가인에게 지점사무실 내 책상이나 좌석을 제공하지 않았다. 임대차조사원은 자신이 배정받은 업무를 다른 임대차조사원에게 재배정하고자 하는 경우, 원고의 승인 없이 전산 프로그램을 통해 재배정할 수 있었고, 휴업하고자 할 경우 반드시 원고의 승인을 받아야 하는 것도 아니었다. 한편 원고는 1년에 2회 정도 업무처리 방법, 사무기기 관리방법, 개인정보보호 교육 등 교육 프로그램을 운영하였으며, 2015년 이후 임대차조사원들을 대상으로 별도의 업무평가를 실시하지 않았다. 원고는 임대차조사원들에게 기본급이나 고정급 없이 조사업무 실적 등에 따라 산정된 수수료를 매월 지급하였다. <심급별 결과> [부산지노위] 근로기준법상 근로자에 해당하고, 계약만료를 이유로 서면통지 없이 근로관계를 종료한 것은 부당하다고 판정 [중노위] 초심유지 [1심 법원] 재심판정 유지 [2심 법원] 근로자가 아니라며, 근로자임을 전제로 한 1심판결 및 재심판정 취소 [대법원] 심리불속행 기각
--

판결 요지 근로기준법상의 근로자에 해당하는지는 계약의 형식이 고용계약인지 도급계약인지 위임계약인지보다 근로제공 관계의 실질이 근로제공자가 사업 또는 사업장에 임금을 목적으로 종속적인 관
--

계에서 사용자에게 근로를 제공하였는지 여부에 따라 판단하여야 한다. 여기에서 종속적인 관계가 있는지 여부는 업무 내용을 사용자가 정하고 취업규칙 또는 복무규정 등의 적용을 받으며 업무수행과정에서 사용자가 상당한 지휘·감독을 하는지, 사용자가 근무시간과 근무장소를 지정하고 근로제공자가 이에 구속을 받는지, 근로제공자가 스스로 비품·원자재나 작업도구 등을 소유하거나 제3자를 고용하여 업무를 대행하게 하는 등 독립하여 자신의 계산으로 사업을 영위할 수 있는지, 근로제공을 통한 이윤의 창출과 손실의 초래 등 위험을 스스로 안고 있는지, 보수의 성격이 근로 자체의 대상적 성격인지, 기본급이나 고정급이 정하여졌고 근로소득세를 원천징수하였는지, 그리고 근로제공관계의 계속성과 사용자에 대한 전속성의 유무와 그 정도, 사회보장제도에 관한 법령에서 근로자로서 지위를 인정받는지 등의 경제적·사회적 여러 조건을 종합하여 판단하여야 한다. 다만 기본급이나 고정급이 정하여졌는지, 근로소득세를 원천징수하였는지, 사회보장제도에 관하여 근로자로 인정받는지 등의 사정은 사용자가 경제적으로 우월한 지위를 이용하여 임의로 정할 여지가 크다는 점에서 그러한 점들이 인정되지 않는다는 것만으로 근로자성을 쉽게 부정하여서는 안 된다(대법원 2006. 12. 7. 선고 2004다29736 판결, 대법원 2010. 4. 15. 선고 2009다99396 판결 등 참조).

패소 이유 (사실관계에 관한 인정 차이)

이 사건은 금융기관과 현장 조사업무 위임계약을 맺은 ‘임대차조사원’이 근로기준법상 근로자에 해당하는지 여부가 문제가 된 사안이다.

중노위는 ‘① 사용자로부터 업무를 배정받아 조사업무를 수행한 점, ② 사용자가 업무의 처리기준과 방식을 세부적으로 정하고 근로자가 이를 따르고 있는 점, ③ 사용자가 태블릿PC 및 업무수행과정에서 지출한 비용 중 일부를 지원한 점, ④ 연수교육을 분기별로 실시하고 있는 점, ⑤ 평가 결과를 계약갱신의 사유로 삼는 점, ⑥ 임대차조사원들의 실적과 업무수행 태도를 상시로 관리·감독한 점, ⑦ 근로자가 이윤 창출과 손실 부담의 위험을 스스로 안고 있다고 볼 수 없는 점, ⑧ 수수료가 근로자체에 대한 대가의 성격을 가지는 점 등’에 주목하여 임대차조사원은 근로자에 해당하고, 근로관계를 종료하면서 해고의 서면통지 의무를 위반한 것은 부당하다고 판정하였다.

그러나 2심 법원은 ‘① 원고가 임대차조사원과 사이에 2015년경 체결한 계약서양식에는 위임직 임대차조사원이 원고의 근로자가 아니고, 임대차조사원에 대하여 근로기준법이 적용되지 않으며, 원고의 정규근로자에게 적용되는 취업규칙 및 제반규정이 적용되지 않음이 명시되어 있다. 임대차조사원이던 참가인도 이를 잘 알면서 원고와 사이에 위임계약을 체결한 것으로 보인다. ② 2015년경 이후부터는 원고가 임대차조사원들을 대상으로 업무평가를 실시하지 않았고 이를 기초로 인센티브나 패널티를 지급하지 않았으며, 원고가 임대차조사원들을 대상으로 목표 부여 및 실적 평가, 근무태도 평가, 출퇴근 관리 등을 하였다고 볼 만한 자료를 발견할 수 없는 점 등을 종합하면, 2015년 전후로 참가인의 업무수행 내용·방식이나 원고의 관리·감독의 정도가 실질적으로 달라진 것으로 봄이 타당하다. ③ 원고가 2015년 이후에도 임대차조사원들을 대상으로 하여 업무수행 방법, 개인정보 보호 등의 유의사항을 전달하는 각종 교육을 정기적으로 실시하였고, … 그러나 위와 같은 교육 내용은 개인정보를 포함한 조사 업무를 수행하는 데 있어 필수적인 조치에 관한 것으로 관련 법령에서 요구하는 내용이거나 조사서 작성에 있어 유의할 사항 등 임대차조사원의 업무 처리를 위해서 필요한 사항이나 정보를 제공한 것으로서, 통상적인 위임관계에서 이루어지는 업무 처리 지시나 요청에 해당하는 것으로 볼 수 있고, 위와 같은 교육은 참가를 신청한 임대차조사원을 대상으로 하여 이루어졌으며, 원고가 교육에 참여하지 아니한 임대차조사원에 대하여 어떠한 불이익을 주었다고 볼 만한 사정도 없다. … 참가인 등이 납기를 준수하지 못하거나 원고의 지시를 이행하지 않았다고 하여 제재나 불이익을 받았다고 볼 자료도 없으므로, 이러한 사정만으로 원고가 참가인에 대하여 근로관계에서의 상당한 지휘·감독을 하였다고 보기 어렵다. ④ 대가 지급 체계를 보면, 원고는 2015. 12. 31. 임대차조사 성과수수료 체계를 개편하여, 임대차 조사 항목별 난이도에 따라 수수료를 차등 적용하는 방식을 도입하였다. 원고는 임대차조사원들에게 기본급이나 고정급 없이 조사업무 실적 등에 따라 산정된 수수료를 매월 지급하였다. 2015년 1·6·7·12월을 기준으로 원고가 임대차조사원들에게 지급한 수수료 금액은 임대차조

사원별로 최저 4,800원에서 최고 6,492,999원에 이른다’는 등의 사실에 주목하여, 참가인은 임금을 목적으로 종속적인 관계에서 원고에게 근로를 제공하는 근로자라 할 수 없으므로, 참가인이 원고의 근로자임을 전제로 한 재심판정은 위법하다고 결론 내렸다.

이 건의 경우 중노위와 2심 법원이 인정한 객관적 사실관계에 특별한 차이가 없었던 것으로 보인다. 그럼에도 각 사실에 대한 경중 및 평가를 달리함으로써, 2심법원이 중노위의 결론과는 상반되는 결론을 내린 것으로 평가할 수 있을 것이다.

일련번호	2022-83					
판결번호	서울행정법원 2022. 1. 13. 선고 2021구합00000					
중노위판정번호	중노위 2020. 12. 14. 2020부해1487					
사건 종류	부당해고, 부당직위해제					
세부 쟁점	당사자적격(근로기준법상 근로자에 해당하는지 여부)					
심급별 소송결과	1심 법원	재심 취소	2심 법원	항소 취하	대법원	-
항 소 인	중앙노동위원회위원장		참 가 인		홍○○	
피항소인	에드○○		피고측 대리인 선임 여부		선임 안 함	
노동조합 지원 여부	없음		원고측 대리인 선임 여부		선임 함	
재심 결과	초심취소					
초심의 대법원 판례 일치여부	일치		재심의 대법원 판례 일치여부		불일치	
기타 특이사항						

주요 사실관계

<사실관계>

원고는 외국인학교를 설치, 경영하는 사립학교경영자이다. 참가인은 1995. 10. 20.부터 2010. 10. 31.까지 근무하다 퇴사하였고, 2016. 7. 1. 총부무 부장대우로 재입사한 뒤 2018. 10. 19. 이 사건 학교장과 사이에 근로기간을 정하지 않은 근로계약서를 작성하였으며, 2018. 11. 12.부터 행정총괄처장직을 수행하였다.

2020년 경, 학교 경영권의 양도.양수 업무 관련 분쟁이 발생하였고, 원고는 참가인에게 2020. 6. 6.자로 행정총괄처장으로서의 위임관계를 종료한다고 통보하였다. 이에 참가인은 부당해고 구제신청을 하였다.

<심급별 결과>

[경기지노위] 사용자의 권한을 포괄적으로 위임받아 행사한 ‘사업 경영 담당자’로서 ‘사용자’는 구제신청의 당사자 적격이 없다고 판정

[중노위] 근로기준법상 근로자에 해당하고, 근로관계 종료는 해고에 해당하며, 해고의 정당성도 인정되나, 학칙의 절차를 거치지 않고 해고한 것은 부당하다며 초심 취소

[1심 법원] 근로기준법상 근로자에 해당하지 않는다며 재심 취소

[2심 법원] 항소 취하

판결 요지

근로기준법상의 근로자에 해당하는지는 계약의 형식이 고용계약인지 위임계약인지보다 근로제공관계의 실질이 근로제공자가 사업장에서 임금을 목적으로 종속적인 관계에서 사용자에게 근로를 제공하였는지 여부에 따라 판단하여야 한다. 여기에서 종속적인 관계가 있는지 여부는 업무내용을 사용자가 정하고 취업규칙 또는 복무규정 등의 적용을 받으며 업무수행과정에서 사용자가 상당한 지휘·감독을 하는지, 사용자가 근무시간과 근무장소를 지정하고 근로제공자가 이에 구속을 받는지, 근로제공자가 스스로 비품·원자재나 작업도구 등을 소유하거나 제3자를 고용하여 업무를 대행하게 하는 등 독립하여 자신의 계산으로 사업을 영위할 수 있는지, 근로제공을 통한 이윤의 창출과 손실의 초래 등 위험을 스스로 안고 있는지, 보수의 성격이 근로 자체의 대상적 성격인지, 기본급이나 고정급이 정하여졌고 근로소득세를 원천징수하였는지, 그리고 근로제공관계의 계속성과 사용자에 대한 전속성의 유무와 그 정도, 사회보장제도에 관한 법령에서 근로자로서 지위를 인정받는지 등의 경제적·사회적 여러 조건을 종합하여 판단하여야 한다(대법원 2006. 12. 7. 선고 2004다29736 판결, 대법원 2020. 6. 25. 선고 2018다292418 판결 등 참조).

패소 이유 (사실관계에 관한 인정 차이)

중노위는 첨가인의 종전 근로관계가 단절된 것이 아니고, 내부승진에 의해 상위직으로 임명되었을 뿐 종전 근로자의 지위는 유지되었다고 보고, 해고절차 위반으로 부당해고라고 판정하였다.

법원은 ‘▲원고는 변론종결일 현재 만 87세(1934. 5. 29.생)의 고령으로, 2001. 2.경 학교의 시설지원 및 관리 등을 위해 설립된 ○○○○교육재단 이사장직에서 사임하였고, 2003년경 미국으로 출국하여 이후 이 사건 학교에 출근하지 않았다. … 사립학교경영자인 원고를 대신하여 학교의 운영을 책임지고 담당할 사람이 필수적으로 요구되었다고 봄이 타당하다. ▲원고를 대신하여 학교의 운영을 담당할 사람이 필요한 상황에서 첨가인은 2018. 11. 12. 행정총괄처장으로 임명되었다. ▲학칙에서는 사립학교경영자에게 학교를 경영할 모든 권리와 권한이 있다고 규정하면서, 총교장과 행정총괄처장을 임명 또는 해임할 권한을 부여하고 있다. 그리고 학칙은 ‘행정총괄처장은 행정적 리더십을 다하기 위하여 ㉠ 예산 및 기타 재정 계획의 수립 및 관리, 자원 배분, 신규 수입원의 개발, 지출의 적정성을 보장하기 위한 모니터링을 포함하여 본교의 재정을 관리해야 할 권한과 책임, ㉡ 본교의 사무직원 또는 다른 고용인의 임용에 관하여 사립학교경영자와 협의하고 사무직원 등의 복무를 관리·감독해야 할 권한과 책임 등이 있다’고 규정하고 있다. … 행정총괄처장에게는 행정 부문과 관련된 업무 일체에 관한 포괄적인 권한과 책임이 부여되어 있었다고 봄이 타당하다. ▲위임전결규정은 … ‘중요정책 및 중요방침에 따른 계획 수립 및 조정, 중요업무의 집행 및 관계기관 협의, 기본방침에 관한 사항’은 행정총괄처장이 각 결재하도록 정하고 있다. 그리고 학교의 재정과 인사에 관한 주요 사항 대부분을 행정총괄처장의 전결사항으로 규정하고 있다. ▲학교의 규정들은 행정총괄처장을 다른 직원들과 다르게 취급하는 규정을 여러 두고 있다. 행정총괄처장의 임기를 3년으로 하되, 사립학교경영자의 결정에 따라 1회에 한하여 중임할 수 있다고 정하고 있고, 행정총괄처장을 이사회의 당연직 이사로 정하고 있다. 인사규정은 ‘학교에 의해 임용된 직원에 대하여 적용한다’고 정하고 있는데 행정총괄처장에게는 인사규정

이 적용되지 않도록 하고 있다.’는 사실에 주목하여, 참가인은 근로기준법상 근로자에 해당하지 않는다는 재심판정을 취소하였다.

법원이 중노위와 결정적으로 시각을 달리한 부분은 ‘근로기준법상 근로자에 해당하는지 여부는 계약의 형식이 아니라 근로제공관계의 실질에 따라 판단하여야 한다며, 참가인이 행정총괄처장으로 임명된 뒤부터 이 사건 학교의 업무 중 행정 부문 전체를 포괄적으로 위임받아 이를 총괄하면서 상당한 정도의 독자적인 권한과 책임을 바탕으로 처리하는 지위에 있었다는 점’에 주목한 것이다. 이는 중노위가 단지 내부승진에 불과하다고 본 것과 배치되는 관점으로, 결론에 결정적인 영향을 미친 것으로 보이는 부분이다.

일련번호	2022-84					
판결번호	대법원 2022. 11. 17. 선고 2022두00000					
중노위판정번호	중노위 2020. 6. 30. 2020부해545					
사건 종류	부당해고					
세부 쟁점	당사자적격(근로기준법상 근로자에 해당하는지 여부)					
심급별 소송결과	1심 법원	재심 유지	2심 법원	1심 취소	대법원	심리불속행 기각
상 고 인	중앙노동위원회위원장		참 가 인		대한불교조계종 ○○사	
피상고인	백○○		피고측 대리인 선임 여부		선임 안 함	
노동조합 지원 여부	없음		원고측 대리인 선임 여부		선임 안 함	
재심 결과	초심유지					
초심의 대법원 판례 일치여부	불일치		재심의 대법원 판례 일치여부		불일치	
기타 특이사항						

주요 사실관계

<사실관계>

원고는 1988. 9. 9. 대한불교조계종으로부터 승려증을 발급받은 사람으로서, 대한불교조계종 ○○사에서 ‘○○’이라는 법명으로 예불(禮佛)업무에 종사하였다.

한편 인터넷 홈페이지 ‘사찰넷’의 불교 관련 구인광고에는 사찰 내에서 기도업무에 종사하는 ‘노전’ 또는 ‘부전’ 승려를 모집하는 구인광고가 다수 포함되어 있는데, ‘월 보시 280만 원’ 또는 ‘보시금 협의’, ‘월 휴가 3박 4일’, ‘개인방사 제공’, ‘4대보험 가입’ 등을 비롯하여 기도업무에 따른 유무형적 경제적 대가를 지급한다는 취지의 내용이 기재되어 있다.

부록.1. 주요 사건 경과 및 패소 원인 분석

원고는 2018. 11. 22.부터 2019. 11. 4.까지 ○○사에서 기거하면서 ‘노전’(또는 부전)의 소임을 맡아 불교의 전통 예법에 따라 예불을 하였다. ○○사는 2018. 12. 24.부터 2019. 10. 25.까지 매월 23 내지 25일에 원고에게 1,800,000원을 송금하였고, 노전으로서의 소임이 종료된 2019. 11. 15.경에는 원고에게 581,000원을 송금하였다.

○○사는 원고가 2019. 11. 1. 및 2019. 11. 2.경 두 차례 범종 타종과 새벽 예불을 하지 않았다는 이유를 들어 2019. 11. 4. 원고로 하여금 기도스님으로서의 소임을 면하게 하였고, 이에 원고가 부당해고 구제신청을 하였다.

<심급별 결과>

[충남지노위] 사찰에서 예불을 수행한 승려는 근로기준법상 근로자에 해당하지 않아 당사자적격이 없다며 구제신청 각하

[중노위] 초심유지

[1심 법원] 재심판정 유지

[2심 법원] 근로기준법상 근로자에 해당한다며, 1심판결 및 재심판정 취소

[대법원] 심리불속행 기각

판결 요지

근로기준법상의 근로자에 해당하는지 여부는 계약의 형식이 고용계약인지 도급계약인지보다 그 실질에 있어 근로자가 사업 또는 사업장에 임금을 목적으로 종속적인 관계에서 사용자에게 근로를 제공하였는지 여부에 따라 판단하여야 하고, 여기에서 종속적인 관계가 있는지 여부는 업무 내용을 사용자가 정하고 취업규칙 또는 복무(인사) 규정 등의 적용을 받으며 업무 수행 과정에서 사용자가 상당한 지휘·감독을 하는지, 사용자가 근무시간과 근무장소를 지정하고 근로자가 이에 구속을 받는지, 노무제공자가 스스로 비품·원자재나 작업도구 등을 소유하거나 제3자를 고용하여 업무를 대행케 하는 등 독립하여 자신의 계산으로 사업을 영위할 수 있는지, 노무 제공을 통한 이윤의 창출과 손실의 초래 등 위험을 스스로 안고 있는지, 보수의 성격이 근로 자체의 대상적 성격인지, 기본급이나 고정급이 정하여졌는지 및 근로소득세의 원천징수 여부 등 보수에 관한 사항, 근로 제공 관계의 계속성과 사용자에게 대한 전속성의 유무와 그 정도, 사회보장제도에 관한 법령에서 근로자로서 지위를 인정받는지 등의 경제적·사회적 여러 조건을 종합하여 판단하여야 한다(대법원 2006. 12. 7. 선고 2004다29736 판결 등 참조).

다만, 기본급이나 고정급이 정하여졌는지, 근로소득세를 원천징수하였는지, 사회보장제도에 관하여 근로자로 인정받는지 등의 사정은 사용자가 경제적으로 우월한 지위를 이용하여 임의로 정할 여지가 크기 때문에, 그러한 점들이 인정되지 않는다는 것만으로 근로자성을 쉽게 부정하여서는 안 된다(대법원 2006. 12. 7. 선고 2004다 29736 판결 등 참조).

패소 이유 (사실관계에 관한 인정 차이)

이 사건은 사찰에서 예불업무를 담당한 승려가 근로기준법상 근로자에 해당하는지 여부가 문제가 된 사안이다.

중노위는 ‘① 조계종 승려법에 따라 정식 승려의 자격을 받은 자가 수행한 기도는 종교 고유 의식의 하나로서 근로기준법에서 정한 정신노동이라고 볼 수 없는 점, ② 기도 소임을 맡게 된 경위, 기도의 시간, 방식, 내용에 대해 종속적인 관계에서 사용자로부터 지휘·감독을 받았다고 볼 수 없는 점, ③ 사찰의 취업규칙이나 복무규정을 적용받거나 근로계약서를 작성한 사실이 없고, 매월 받은 180만 원의 금품은 종교 포교활동의 일환으로서 행해진 기도에 대해 생활보조적 성격의 금품으로 보여지는 점 등’을 들어 신청인은 순수 종교인에 해당하고 근로기준법상 근로자에 해당하지 않는다고 당사자적격이 없다고 판정하였다.

그러나 2심 법원은 ‘▲○○사 등 대한불교조계종 소속 사찰들은 전통적인 불교 예법에 따라 매일 일정한 시간에 새벽예불, 사시불공, 저녁예불을 거행하고 있고, 원고는 매일 위와 같은 시각에 불교의 예법이 정하는 절차에 따라 예불을 집전하면서 법구를 사용하거나 불경을 염송하였으며, ○○사는 원고가 범종을 타종하지 않았거나 새벽예불을 집전하지 않았다는 이유로 원고를 기도 소임에서 해임하였다고 진술하고 있으므로, 업무내용과 근무시간 및 근무장소가 사전에 정하여져 있고, 원고가 스스로의 의사에 따라 이를 변경할 수 없음은 분명하다. … 원고는 업무내용, 근무시간 및 근무장소에 대하여 사용자로부터 지시를 받고 있다고 봄이 타당하다. ▲원고는 ○○사에서 기거하며 업무를 시작한 때부터 이를 종료할 때까지 매월 정기적으로 월 180만 원을 지급받았다. … 설령 피고의 주장과 같이 원고가 사찰 내 기거하는 승려의 자격으로 ‘생활보조금’을 지급받았다는 점이 인정된다고 하더라도, 사찰 내 기거하는 승려는 말은 소임에 따라 그러한 ‘생활보조금’의 액수에 차이가 있으므로 결국 원고에게 지급한 생활보조금은 순수한 생활보조금에 해당하는 부분과 원고의 소임인 예불 집전 업무에 대한 대상적 성격을 가진 부분으로 구성되어 있다고 봄이 타당하고, 적어도 그러한 한도 내에서 원고가 받은 금원 중 일부가 근로의 대상적 성격을 가지고 있음은 충분히 인정된다. ▲원고가 집전한 예불은 ○○사 내에서 다수의 승려와 불교신자들의 참여 하에 정기적으로 이루어지는 집단적 종교의식(儀式)으로서, 원고는 다수의 사람에게 공개된 장소에서 매일 일정한 시각에 정해진 방식으로 예불을 하여야 하고, 편의에 따라 전부 또는 일부를 생략하거나 개인적인 종교의식으로 대체할 수도 없다. … 원고 개인의 종교적 수양에 기여하는 부분이 있다고 하더라도, 그러한 예불 업무는 기본적으로 ○○사의 지시 하에 해당 종교단체 본연의 목적에 기여하기 위한 단체적 종교활동의 일환으로서 행하여진 것이므로, 이를 가리켜 개인적 차원에서 이루어지는 종교적 수양 또는 수행행위에 불과하다고 볼 수 없음은 명백하다. 따라서 원고의 예불업무는 근로기준법 제2조 제1항 제3호가 정하는 정신노동 및 육체노동 모두에 해당한다고 봄이 타당하다.’는 이유로 원고가 근로기준법상 근로자에 해당한다고 보고 1심 판결 및 재심판정을 취소하였다.

이 건의 경우 중노위와 2심 법원이 인정한 객관적 사실관계에 특별한 차이가 없었던 것으로 보인다. 다만 중노위가 정식 승려의 자격을 받은 자가 수행한 기도는 종교 고유 의식이라는 점을 중시한 것과 달리, 2심 법원은 승려 업무의 특수성보다 근로자성 판단의 법리를 우선시하여 각 사실에 대한 경중 및 평가를 달리한 것으로 평가할 수 있을 것이다.

부록 2. 노동위원회 판정 분류 체계안

1. 개별적 근로관계

대분류	중분류	세분류	세세분류	세세세분류	검색어
본안전 사항	당사자 적격	근기법상 근로자 해당 여부			위임계약, 근로계약, 임원, 도급, 파견, 용역
		사용자 해당 여부	실질적 근로관계		위임계약, 근로계약, 위탁, 도급, 파견 요역, 입주자대표회의
			사업주 변경		양도, 양수, 시설양수, 고용승계
	구제이익	실현 불가능한 경우			근로관계 종료, 근로계약기간 만료, 이 행강제금,
		이미 달성된 경우			복직명령, 해고의 부존재
		임금상당액의 독자성			지급명령, 정년도래
	제척기간	기간 계산			
		계속되는 행위			
	근기법상 사업장				상시 근로자 수 산정, 국내사무소, 국 제사법, 준거법
근로관계 의 성립	채용내정, 수습, 시용				본채용 거부, 시용계약, 채용내정, 수습 계약, 해고,
	채용 취소				부정행위, 거부사유, 경력요건
	파견				파견 기간, 불법파견, 파견 허용 업종
	근로계약의 해석	근로기간의 존부			기간제, 기간의 정함이 없는
		근로조건의 특정			임금, 근로시간, 근로제공 장소, 업무내용
		근로계약과 취업규칙의 우열			유리한 조건, 효력

대분류	중분류	세분류	세세분류	세세세분류	검색어
근로관계 의 전개	근로관계 종료 외의 인사처분	구제대상 해당 여부 (그 밖의 징벌인지 여부)			인사발령, 전직, 전보, 강등, 대기발령, 근무형태 변경
		징계(내지 징계성 처분)	사유		징계, 단체협약, 성희롱, 직장 내 괴롭 힘, 정당한 사유
			양정		형평성, 양정 과다
			절차		징계절차, 절차 위반, 서면통지, 징계취 소(후 재징계 여부), 시효
		인사명령	업무상 필요성		필요성, 성과평가, 근무평가, 배치전환, 부당전직, 전보, 조직개편
			생활상 불이익		불이익, 임금, 출퇴근 시간, 통근차량, 숙소, 근로조건
			신의칙상 협의 절차		성실한 협의, 관행, 근로내용
	직장 내 괴롭힘				괴롭힘, 지위, 관계, 우위, 폭언, 폭행, 모욕, 지시, 강요
근로관계 의 종료	해고의 존부 문제	해고의 의사표시 해당 여부			해고의 권한, 구두 해고, 서면통지
		합의 해지			청약, 합의서, 권고사직, 사직서
		사직의 의사표시			사직서, 진의/비진의, 철회
	해고	징계해고	사유		징계사유, 직권면직, 단체협약
			양정		징계양정, 형평성, 포상,
			절차		징계절차, 단체협약, 시효, 서면통지, 징계위원회, 사전통지
		통상해고			당연퇴직사유, 직권면직, 정년

대분류	중분류	세분류	세세분류	세세세분류	검색어
	경영상 해고	경영상 해고	긴박한 경영상 필요		긴박한 경영상 필요, 매출, 회계
			해고회피노력		해고회피, 비용 절감, 경영합리화, 우선 채용, 고용승계
			해고대상자 선정		선정 기준, 근로자 대표, 사전통보, 사전협의
	기간 만료	기간제 근로자 여부			정규직, 비정규직, 무기계약직, 근로계약 기간, 갱신
		기간의 정함이 없는 근로자 전환 여부	계속 근로기간 산정		계속 근로기간, 무기계약직, 전환, 2년
			전환의 예외		사용기간 제한
		촉탁직 근로자	갱신기대권		갱신, 관행, 갱신거절, 기간만료
			갱신거절의 합리적 이유		갱신, 거절, 인사평가, 관행
		정년, 계약기간 만료 등으로 인한 근로자 지위 상실			당연퇴직, 소의 이익
차별	제척기간	계속되는 차별적 처우			차별, 임금, 복리후생
		계속되지 않는 차별적 처우			차별, 일회성 지급 금품, 근로조건
	당사자 적격	기간제근로자			기간의 정함 없는 근로자 전환, 무기계약직, 2년
		단시간근로자			단시간, 통상근로자
		파견근로자			파견, 불법파견, 도급, 용역
		(모집.채용상 차별) 취업할 의사 여부			채용절차, 응시, 지원, 모집공고, 차별
	시정이익				시정이익, 시정 완료

대분류	중분류	세분류	세세분류	세세세분류	검색어
	시정명령	금전배상명령			소멸시효, 정신적 손해배상, 위자료
		제도개선명령			취업규칙, 단체협약, 근로계약
		배액금전배상명령			명백한 고의, 차별적 처우 반복
	비정규직 차별	비교대상근로자	비교대상근로자 존재		비교대상근로자, 동종 업무, 유사업무, 합리적 이유
			비교대상근로자 선정		처우, 임금, 호봉, 근로계약
		차별금지영역			임금, 정기상여금, 명절상여금, 성과금, 그 밖의 근로조건, 복리후생, 근로시간, 휴일, 휴가, 안전, 보건, 재해보상
		불리한 처우	항목별 비교		
			범주화 비교		
			총액 비교		
		합리적 이유			채용조건, 기준, 업무 내용, 권한, 책임, 임금체계, 업무수행 능력, 성과, 자격
	고용상 성차별	모집·채용	비교대상근로자		임금, 직무, 직급, 근로계약
			불리한 처우		불합리한 처우, 모집, 직종, 직급, 남녀, 성별, 질문, 간접차별
			합리적 이유		자격, 성별, 학력, 모성보호, 적극적 고용개선조치
		임금, 임금 외 금품	비교대상근로자		임금, 직무, 직급, 근로계약

대분류	중분류	세분류	세세분류	세세세분류	검색어
			차별금지영역		임금, 임금 외 금품
			불리한 처우		동일가치노동 동일임금, 성별, 지급, 간접차별
			합리적 이유		업무 내용, 성과, 자격, 학력, 평가
		교육.배치.승진	비교대상근로자		임금, 직무, 직급, 근로계약
			불리한 처우		특정 성 배제, 교육과정·내용 차등, 보조업무 배치, 순환 배치 제외, 전직 제한, 불리한 조건, 절차 적용, 승진 단계, 기간 차등, 간접차별
			합리적 이유		업무 내용, 성과, 자격, 학력, 평가
		정년.퇴직.해고	비교대상근로자		임금, 직무, 직급, 근로계약
			불리한 처우		임금, 성별, 차등, 임신, 출산, 육아, 해고, 정년, 간접차별
			합리적 이유		
	직장 내 성희롱	조치의무 위반			근무장소 변경, 배치전환, 유급휴가 명령, 단시간근로, 통상근무 전환, 야간근무 배제
		고객에 의한 성희롱 조치의무 위반			거래 관계, 서비스 이용, 출장, 회식.야유회, 업무협약, 고객, 고객응대
		불리한 처우	인사조치		파면, 해임, 해고, 징계, 정직, 감봉, 강등, 승진 제한, 직무미부여, 직무재배치
			차별이나 기회 제한		성과평가, 동료평가 차별, 교육훈련 기회 제한, 역량, 향상

대분류	중분류	세분류	세세분류	세세세분류	검색어
			괴롭힘		괴롭힘, 희롱, 따돌림, 폭행, 폭언
		고객에 의한 성희롱 불이익한 조치			신고, 제보, 고객, 거래 관계, 서비스 이용, 출장, 회식.야유회, 업무협의, 고 객응대

2. 집단적 노사관계.

대분류	중분류	세분류	세세분류	세세세분류	검색어
부당노동 행위	당사자 적격	근로자			특고, 특수형태, 종사자, 원청, 하청, 도 급, 수급, 플랫폼, 종사조합원
		사용자	구제명령 수급자		사업주, 사업경영담당자, 사업주를 위하 여 행동하는 자
			부당노동행위 주체의 외부적 확장		원청, 하청, 도급, 수급, 사용사업주, 지 배력
		노동조합	형식적 요건		설립신고, 지부, 지회, 규약, 임원
			실질적 요건		주체성, 자주성, 목적성, 단체성,
			기타		대표성
	구제이익 신청기간				원직복직, 해고, 해산
					제척기간, 시효
	불이익 취급	정당한 노동조합 활동	유인물 배포, 벽보 부착 등 언론활동		노동조합, 조합활동, 단체행동, 노동조 합 활동, 시설관리권, 노무지휘권, 조합 사무실, 업무저해, 중단
			취업시간 중 조합활동 리본·머리띠·투쟁복 (조끼)		
			초기업 노동조합 조합원(상급단체 임원) 사업장 출입		
			기타		
					명시적·묵시적 수권

		불이익 취급	경제적 불이익	인사처분(신분) 기타	징계, 배치전환, 해고, 정직, 승진, 감봉, 보직해임, 경고
			정신적 불이익		시말서, 경고
			조합활동상 불이익		조합활동, 배치전환, 승진, 강등
			기타 불이익		
		부당노동행위 의사			의사, 지배개입, 불이익취급, 비열계약(황건계약), 유니온, 유니언, 습, 샵
	반조합계약				유니온, 유니언, 습, 샵
	단체교섭 거부.해태	주체			교섭권한
		교섭의 시기와 장소			
		교섭대상			의무적 교섭사항, 임의적 교섭사항, 채무적 부분, 규범적 부분, 근로조건, 결정
	지배개입	지배개입	노동조합 설립.조직.가입		설립, 지배, 개입
			노동조합 운영		임원, 선거, 조합비, 공제, 운영비 원조
			노동조합 활동		쟁의행위, 직장폐쇄, 근로시간면제, 위장폐업, 복귀명령
			노동조합 간 차별		승진, 강등, 수당, 임금
			기타		언론의 자유, 시설관리권,
			부당노동행위 의사		
		근로시간면제 한도 초과 급여 지급			근로시간면제 시간 배분 합의서, 연간 한도, 사후 정산,
		운영비 원조			노동조합 운영비,원조 목적과 경위, 횟수, 기간, 금액, 총수입 차지 비율, 사용처
복수노조	교섭단위 분리	시기			교섭요구, 교섭요구사실, 공고
		주체			노동조합, 조합원, 지부, 지회, 분회, 교섭단위분리, 신청

		근로조건 차이			임금, 근로시간, 복리후생, 수당
		고용형태			사무직, 생산직, 정규직, 기간제, 인사교류, 직종 전환, 정년
		교섭관행			통일교섭, 대각선교섭, 공동교섭, 기업별교섭 등
		교섭단위 분리 필요성			근로조건, 교섭관행, 고용형태, 필요성
	교섭창구단일화 절차	교섭요구 사실의 공고	당사자 적격		근로자, 사용자, 원청, 하청, 도급, 수급, 위원장, 지부, 지회, 본조, 조합원
			주체		위원회, 지부, 지회, 본조, 조합원
			시기		단체협약, 유효기간, 만료, 교섭대표, 교섭대표노조, 노동조합
			방법		공고, 게시판, 전산망, 기간
			기타		단수노조, 조합원 수, 변동, 감소
		교섭요구 노동조합의 확정	당사자 적격		근로자, 사용자, 원청, 하청, 도급, 수급, 초일불산입, 산입
			신청기간		조합원 수, 확정, 교섭단위
			기타		조합원 수, 확정, 교섭단위
		과반수 노동조합의 확정	당사자 적격		근로자, 사용자, 원청, 하청, 도급, 수급, 지부, 지회, 위임, 권한, 위임, 연합
			주체		지부, 지회, 위임, 권한, 위임, 연합
			시기		개별교섭
			조합원 수 산정		기준일, 조합비, 중복가입(이중가입), 해고자, 종사조합원
		공동교섭대표단 구성	주체		교섭대표단, 10% 이상
			기타		과반수, 비율, 비례
	공정대표의무 위반	시정이익			
		신청기간			단체교섭, 단체협약, 체결일, 차별행위
		절차적 위반	의견수렴 및 정보제공		인준투표, 찬반투표, 단체협약, 잠정합의, 창구단일화
		실체적 위반	단체협약 내용, 이행.준수	규범적 부분	가입범위, 임금, 성과금, 차별
				채무적 부분: 노조 사무실	조합원 규모, 점유율, 사무실
				채무적 부분:	경비원조, 조합사무실, 전임자, 위원장,

부록 2. 노동위원회 판정 분류 체계안

				근로시간면제 한도	근로시간면제, 근로시간면제자, 근로시 간 면제한도
				기타 차별	조합비공제, 창립기념일, 선물